

eBook
2020

Coleção Carreiras Jurídicas

DIREITO CONSTITUCIONAL

Autor:
Tatiana Batista

CP  IURIS



Organizado por CP Iuris
ISBN 978-85-5805-013-5

DIREITO CONSTITUCIONAL

**1ª edição
Brasília
CP Iuris
2020**

SOBRE A AUTORA

TATIANA DOS SANTOS BATISTA. Advogada. Pós-Graduada (Emerj). Professora de Direito Constitucional e Humanos na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ) e em cursos preparatórios para concursos públicos.

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 — DIREITO CONSTITUCIONAL: OBJETO E CONTEÚDO	30
CAPÍTULO 2 — CONSTITUCIONALISMO	31
1. Conceito	31
2. Constitucionalismo antigo.....	31
3. Constitucionalismo moderno	32
4. Neoconstitucionalismo	33
4.1. <i>Conceito</i>	33
4.2. <i>Características</i>	34
5. Transconstitucionalismo	35
6. Constitucionalismo Abusivo	35
7. Informativos de jurisprudências	36
7.1. <i>Supremo Tribunal Federal</i>	36
<i>Questões</i>	36
<i>Comentários</i>	37
CAPÍTULO 3 — CONSTITUIÇÃO	40
1. Sentidos da Constituição.....	40
1.1. <i>Sentido sociológico (Lassalle)</i>	40
1.2. <i>Sentido político (Schmitt)</i>	40
1.3. <i>Sentido Cultural</i>	41
1.4. <i>Sentido jurídico (Kelsen)</i>	41
1.5. <i>Força Normativa da Constituição (Konrad Hesse)</i>	42
1.6. <i>Constitucionalização Simbólica (Marcelo Neves)</i>	42
1.7. <i>Concepção Cultural</i>	42
1.8. <i>Constituição Dúctil</i>	43
2. Bloco de Constitucionalidade	43
3. Classificação das Constituições.....	44
3.1. <i>Quanto à ORIGEM</i>	44
3.2. <i>Quanto à FORMA</i>	44

3.2.1. Escrita	44
3.2.2. Não escrita (costumeira)	44
3.3. Quanto ao MODO DE ELABORAÇÃO.....	44
3.3.1. Dogmáticas.....	44
3.3.2. Históricas.....	45
3.4. Quanto ao CONTEÚDO	45
3.4.1. Material	45
3.4.2. Formal.....	45
3.5. Quanto à ESTABILIDADE.....	45
3.5.1. Imutáveis.....	45
3.5.2. Rígida	45
3.5.3. Flexível	45
3.5.4. Semirrígida (semi-flexível).....	45
3.6. Critério Ontológico.....	46
3.6.1. Normativas.....	46
3.6.2. Nominativas	46
3.6.3. Semântica.....	46
3.7. Quanto à EXTENSÃO	46
3.7.1. Analíticas.....	46
3.7.2. Sintéticas.....	46
3.8. Quanto à FINALIDADE	46
3.8.1. Garantia	46
3.8.2. Balanço	47
3.8.3. Dirigente	47
3.9. Constituição Nominalista	47
3.10. Constituições reduzidas e variadas.....	47
3.10.1. Reduzidas	47
3.10.2. Variadas.....	47
3.11. Constituições liberais e sociais	47
3.11.1. Liberais	47
3.11.2. Sociais.....	47
3.12. Constituição Expansiva.....	48
3.13. Heteroconstituições.....	48
3.14. Constituição Principiológica e preceitual	48

3.14.1. Principiológica	48
3.14.2. Preceitual	48
3.15. <i>Constituição Plástica</i>	48
3.15.1. Conceito de Pinto Ferreira	48
3.15.2. conceito de Raul Machado Horta	48
3.16. <i>Constituição Simbólica</i>	48
3.16.1. Forma do compromisso dilatatório	49
3.16.2. Confirmação de valores sociais de um grupo em detrimento de outro.....	49
3.16.3. Legislação álibi.....	49
4. Constituições do Brasil.....	49
4.1. <i>Constituição de 1824</i>	49
4.2. <i>Constituição de 1891</i>	50
4.3. <i>Constituição de 1934</i>	50
4.4. <i>Constituição de 1937</i>	50
4.5. <i>Constituição de 1946</i>	50
4.6. <i>Constituição de 1967</i>	51
4.7. <i>Constituição de 1969</i>	51
4.8. <i>Constituição de 1988</i>	51
5. Classificação e estrutura da Constituição de 1988	51
5.1. <i>Preâmbulo</i>	52
5.2. <i>Parte Dogmática</i>	53
5.3. <i>Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)</i>	53
5.4. <i>Elementos da Constituição</i>	54
5.5. <i>Vacatio Constitutionis</i>	54
<i>Questões</i>	54
<i>Comentários</i>	55
CAPÍTULO 4 – PODER CONSTITUINTE	59
1. Material	59
2. Formal.....	59
3. Poder constituinte originário	59

3.1. Conceito	59
3.2. Características	60
4. Poder constituinte derivado	61
4.1. Conceito	61
4.2. Espécies	61
4.2.1. Revisão – art. 3º, ADCT	61
4.2.2. Emendas – art. 60, CF	62
4.2.3. Circunstanciais — art. 60, §1º, CF.	62
4.2.4. Materiais: art. 60, § 4º, I, II, III e IV	62
4.2.5. Poder Constituinte Derivado Decorrente	64
4.2.6. Limites	64
4.2.7. Diferença entre as normas de pré-ordenação das normas de imitação	65
4.2.8. Poder Constituinte Difuso	65
4.2.9. Poder Constituinte Supranacional	65
QUESTÕES	66
Comentários	66
CAPÍTULO 5 — NORMAS CONSTITUCIONAIS	69
1. Conceitos e Espécies	69
2. Classificação das normas da Constituição quanto ao grau de eficácia	69
2.1. Classificação de Ruy Barbosa	69
2.2. Classificação de José Affonso da Silva	69
2.3. Classificação de Maria Helena Diniz	71
3. Normas Constitucionais no tempo	72
3.1. Ilimitação do poder constituinte originário	72
3.2. Relação entre a nova Constituição e a pretérita	72
3.3. Relação entre a nova Constituição e o direito pré-constitucional incompatível	72
3.4. Relação entre a nova Constituição e o direito pré-constitucional compatível	73
3.5. Alteração de competência entre os entes federativos	73
3.6. Recepções parciais e totais	73
3.7. Repristinação automática	73
3.8. Período de vacatio legis e nova constituição	74

3.9. Controle de constitucionalidade de direito pré-constitucional	74
Questões	74
Gabarito	75
CAPÍTULO 6 — HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL	77
1. Conceito	77
2. Métodos de interpretação	78
2.1. Método jurídico	78
2.2. Método tópico-problemático	79
2.3. Método hermenêutico concretizador	79
2.4. Método científico-espiritual	80
2.5. Método normativo-estruturante	80
2.6. Interpretação comparativa	80
3. Princípios de interpretação constitucional	81
3.1. Princípio da Unidade da Constituição	81
3.2. Princípio do Efeito Integrador	81
3.3. Princípio da Máxima Efetividade	81
3.4. Princípio da Justeza	81
3.5. Princípio da Harmonização	81
3.6. Princípio da Força Normativa da Constituição	82
3.7. Princípio da Interpretação Conforme à Constituição	82
3.8. Teoria dos poderes implícitos (implied powers)	82
4. Informativos de jurisprudências	82
4.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	82
Questões	83
Comentários	84
CAPÍTULO 7 – PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS	86
1. Fundamentos	86
1.1. Soberania	86

1.2. <i>Cidadania</i>	86
1.3. <i>Dignidade da pessoa humana</i>	86
1.4. <i>Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa</i>	87
1.5. <i>Pluralismo político</i>	87
2. <i>Objetivos</i>	87
3. <i>Princípios na ordem internacional</i>	87
4. <i>Informativos de jurisprudência</i>	88
4.1. <i>Supremo Tribunal Federal</i>	88
<i>Questões</i>	88
<i>Comentários</i>	89
CAPÍTULO 8 – DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS	91
1. <i>Teoria Geral</i>	91
1.1. <i>Origem dos direitos fundamentais</i>	91
1.2. <i>Conceito dos direitos fundamentais</i>	91
1.3. <i>A relação entre os direitos fundamentais e os direitos humanos</i>	92
1.4. <i>Características dos direitos fundamentais</i>	92
1.5. <i>Dimensão objetiva e dimensão subjetiva</i>	93
1.6. <i>Destinatário dos direitos fundamentais</i>	94
1.7. <i>Vetores de eficácia dos direitos fundamentais</i>	94
1.8. <i>Restrições dos direitos fundamentais e Teoria dos limites dos limites</i>	94
1.9. <i>Colisão de direitos fundamentais</i>	94
1.10. <i>Estado de coisas inconstitucional (ECI)</i>	95
1.11. <i>Teoria interna e externa dos direitos fundamentais</i>	95
1.11.1. <i>Teoria interna</i>	95
1.11.2. <i>Teoria externa</i>	96
2. <i>Informativos de jurisprudência</i>	96
2.1. <i>Supremo tribunal federal</i>	96
2.2. <i>Superior tribunal de justiça</i>	96
<i>Questões</i>	97

<i>Gabarito</i>	98
CAPÍTULO 9 – DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988	102
1. Restrições e suspensões dos direitos fundamentais	102
1.1. <i>Estado de Defesa</i>	102
1.2. <i>Estado de Sítio</i>	102
1.2.1. Inciso I do art. 137	102
1.2.2. Guerra externa ou resposta à agressão armada estrangeira (inciso II do art. 137) ..	102
2. Tratados e convenções internacionais na Constituição de 1988.....	102
3. Tribunal Penal Internacional	103
4. Análise do art. 5º da Constituição de 1988.....	103
4.1. <i>Direito à vida</i>	104
4.2. <i>Direito à liberdade</i>	104
4.3. <i>Direito à reunião</i>	106
4.4. <i>Direito à igualdade</i>	107
4.5. <i>Princípio da legalidade</i>	108
4.6. <i>Direito de Propriedade</i>	108
4.7. <i>Direito à Privacidade</i>	109
4.8. <i>Defesa do Consumidor</i>	111
4.9. <i>Direito à informação</i>	111
4.10. <i>Direito de petição</i>	112
4.11. <i>Direito de certidão</i>	112
4.12. <i>Direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito</i>	112
4.12.1. Direito adquirido.....	113
4.12.2. Ato jurídico perfeito	113
4.12.3. Coisa julgada	113
4.13. <i>vedação ao racismo</i>	113
4.14. <i>tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional</i>	114
5. Informativo de jurisprudências	114
5.1. Supremo Tribunal Federal	114

<i>Questões</i>	115
<i>Comentários</i>	116
CAPÍTULO 10 – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS	117
1. Princípio da inafastabilidade da jurisdição	117
2. Juízo natural	118
3. Júri Popular	118
4. Princípio da legalidade penal e da retroatividade da lei penal mais benéfica	119
5. Pessoalidade da pena	119
6. Princípio da individualização da pena	119
7. Extradicação	120
8. Devido processo legal	120
<i>8.1. Contraditório e ampla defesa</i>	121
9. Vedação à prova ilícita	121
<i>9.1. Prova ilícita</i>	121
<i>9.2. Prova ilegítima</i>	122
10. Princípio da presunção de inocência (ou não culpabilidade)	122
11. Identificação criminal do civilmente identificado	123
12. Ação penal privada subsidiária da pública	123
13. Prisão	124
14. Direito a não autoincriminação	124
15. Prisão civil por dívida	125
16. Assistência jurídica gratuita	125
17. Indenização por erro judiciário por excesso de prisão	126
18. Gratuidade dos registros de nascimento e de óbito	126
19. Celeridade processual	126
20. Informativo de jurisprudência	126
<i>20.1. Supremo Tribunal Federal</i>	126
<i>Questões</i>	127
<i>Comentários</i>	128
CAPÍTULO 11 – AÇÕES CONSTITUCIONAIS	130
1. Habeas Corpus	130
2. Mandado de segurança	131
3. Mandado de Injunção	133

3.1. Requisitos da petição inicial	136
3.2. Casos de indeferimento da petição inicial (art. 6º)	136
3.3. Recurso contra o indeferimento da petição inicial	136
3.4. Recebimento da petição inicial	136
3.5. Ministério Público	137
4. Habeas data	138
5. Ação Popular	139
6. Informativos de jurisprudência	141
Questões	143
Comentários	143
CAPÍTULO 12 – DIREITOS SOCIAIS	146
1. Direitos sociais do trabalhador	146
2. Reserva do possível e Mínimo Existencial	148
3. O papel do Poder Judiciário na consecução de políticas públicas	149
3.1. Princípio da proibição do retrocesso (efeito cliquet), “jurisprudência da crise” e princípio do limite do sacrifício	149
4. Informativo de jurisprudência	150
4.1. Supremo Tribunal Federal	150
Questões	151
Comentários	152
CAPÍTULO 13 – NACIONALIDADE	154
1. Conceito	154
2. Espécies de nacionalidade	154
2.1. Originária (primária)	154
2.2. Adquirida (secundária)	154
3. Critérios da nacionalidade	155
3.1. Brasileiros natos	155
3.2. Brasileiros naturalizados	155
4. Os Portugueses	156
5. Diferenças entre brasileiros natos e naturalizados	156
6. Perda da Nacionalidade	156

7. Informativo de jurisprudência	157
7.1. <i>Supremo Tribunal Federal</i>	157
<i>Questões</i>	158
<i>Comentários</i>	159
CAPÍTULO 14 – DIREITOS POLÍTICOS	160
1. Capacidade eleitoral ativa	160
2. Plebiscito e Referendo	161
3. Capacidade eleitoral passiva	161
4. Inelegibilidades constitucionais.....	161
4.1. <i>Inelegibilidade absoluta</i>	161
4.2. <i>Inelegibilidade relativa</i>	162
4.3. <i>Inelegibilidade por motivos funcionais</i>	162
4.4. <i>Inelegibilidade por motivos de parentesco</i>	162
4.5. <i>Inelegibilidade do militar</i>	162
4.6. <i>Lei complementar pode trazer hipóteses de inelegibilidade</i>	163
5. Privação dos direitos políticos	163
6. Princípio da anualidade eleitoral (ou anterioridade eleitoral).....	164
7. Partidos Políticos	164
8. Informativo de jurisprudência	164
8.1. <i>Supremo Tribunal Federal</i>	164
<i>Questões</i>	165
<i>Comentários</i>	165
CAPÍTULO 15 – ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO	167
1. Formas de Estado	167
1.1. <i>Estado federado</i>	167
1.2. <i>Estado unitário</i>	167
1.2.1. Unitário puro.....	167
1.2.2. Unitário descentralizado administrativamente	167
1.2.3. Unitário descentralizado administrativamente e politicamente	167
1.3. <i>Confederação</i>	168
2. Forma de governo.....	168

2.1. República.....	168
2.2. Monarquia.....	168
3. Sistema de Governo.....	169
3.1. Sistema presidencialista	169
3.2. Sistema parlamentarista	169
4. Regime de Governo	169
4.1. Regime democrático	169
4.2. Regime autocrático.....	169
5. A Federação e suas características.....	170
5.1. Classificações do Federalismo	170
5.1.1. Federalismo centrípeto	170
5.1.2. Federalismo centrífugo	170
5.1.3. Federalismo dual ou clássico	170
5.1.4. Federalismo cooperativo ou neoclássico.....	170
5.1.5. Federalismo por integração.....	171
5.1.6. Federalismo simétrico	171
5.1.7. Federalismo assimétrico.....	171
6. O Federalismo da Constituição de 1988	172
6.1. Auto organização.....	173
6.2. Auto Governo.....	173
6.3. Auto administração.....	174
6.4. Técnicas de repartição de competências entre os entes	174
6.4.1. Técnica de Repartição Horizontal	174
6.4.2. Técnica da Repartição Vertical	174
6.5. Federação de equilíbrio	175
6.6. Garantias à federação.....	175
6.7. União.....	175
6.7.1. Territórios	176
6.7.2. Estados-membros	177
a) Princípios constitucionais sensíveis.....	177
b) Princípios constitucionais extensíveis	177
c) Princípios constitucionais estabelecidos	177

6.7.3. Formação dos Estados	180
6.7.4. Municípios	182
a) Formação dos Municípios.....	183
6.7.5. Distrito Federal.....	184
7. Repartição de Competências.....	184
7.1. <i>Modelo de repartição de competências</i>	185
7.1.1. modelo clássico	185
7.1.2. modelo moderno.....	185
7.1.3. modelo horizontal	185
7.1.4. modelo vertical	185
7.2. <i>Repartição horizontal</i>	186
7.2.1. Competências da União	186
a) Competência exclusiva da União	186
b) Competência privativa da União.....	188
7.2.3. Possibilidade de Delegação	190
7.2.4. Competências dos Estados	190
7.2.5. Competências do Distrito Federal	191
7.2.6. Competências dos Municípios	191
7.3. <i>Repartição vertical</i>	193
7.4. <i>Considerações finais</i>	195
8. Vedações constitucionais aos entes federados.....	196
9. Intervenção Federal.....	196
9.1. <i>Intervenção federal espontânea</i>	196
9.2. <i>Intervenção federal provocada</i>	197
9.3. <i>Controle político da intervenção</i>	198
9.4. <i>Princípios que regem a intervenção</i>	199
9.4.1. Excepcionalidade	199
9.4.2. Necessidade	199
9.4.3. Taxatividade.....	199
9.4.4. Temporalidade	199
9.4.5. Procedimento.....	199
a) Procedimento das hipóteses do art. 34, I, II, III e V, CF.....	199
b) Procedimento da hipótese do art. 34, IV, CF	200
c) Procedimento da hipótese do art. 34, VI, CF.....	200

d) Procedimento do art. 34, VII, CF	200
9.5. <i>Considerações finais</i>	200
10. Intervenção no Municípios	201
11. Informativo de jurisprudência	201
11.1. <i>Supremo Tribunal Federal</i>	201
<i>Questões</i>	202
<i>Comentários</i>	203
CAPÍTULO 16 — A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988	205
1. Supremacia do interesse público	205
2. Indisponibilidade do interesse público	205
3. Princípio da legalidade.....	206
4. Princípio da impessoalidade.....	206
5. Princípio da moralidade	206
6. Princípio da publicidade.....	206
7. Princípio da eficiência	207
8. Princípio da organização legal do serviço público na vertente federal.....	207
9. Princípio da organização legal do serviço público no âmbito dos Estados.....	207
10. Ingresso no serviço público	208
10.1. <i>Cargos privativos de brasileiro nato</i>	208
10.2. <i>Ingresso por concurso público</i>	208
10.3. <i>Prazo de validade do concurso público</i>	209
10.4. <i>Direito subjetivo ao cargo público</i>	209
10.5. <i>Funções de confiança</i>	210
10.6. <i>Contratação por tempo determinado</i>	210
11. Normas constitucionais sobre o regime jurídico dos agentes públicos	211
11.1. <i>Agentes públicos</i>	211
11.1.1. Agentes políticos	211
11.1.2. Agentes administrativos.....	211
a) Servidores públicos	211
b) Empregado público	212
c) Agentes temporários	212
12. Irredutibilidade de vencimentos e subsídios	214
13. Disposições constitucionais relativas ao servidores em exercício do mandato eletivo	215

14. Estabilidade do servidor público.....	215
15. Regime de previdência dos servidores públicos	216
16. Obrigatoriedade de licitar	218
17. Responsabilidade civil da Administração Pública	219
18. Informativo de jurisprudência	220
<i>Questões</i>	220
<i>Comentários</i>	221
CAPÍTULO 17 – ORGANIZAÇÃO DO PODER	223
1. Funções.....	223
2. Poder Legislativo	223
2.1. <i>Composição</i>	224
2.1.1. Congresso Nacional.....	225
a) Sessões conjuntas	225
b) Sessões unicamerais	225
2.1.2. Câmara dos Deputados	225
2.1.3. Senado Federal	226
2.2. <i>Órgãos</i>	226
2.2.1. Mesas diretoras	226
2.2.2. Comissões	226
a) Comissão Mista.....	227
b) Comissão Representativa	227
c) Comissões parlamentares de inquérito (CPI)	227
d) Direitos do depoente	231
2.2.3. Plenário.....	231
2.3. <i>Atribuições do Congresso Nacional</i>	232
2.4. <i>Atribuições da Câmara dos Deputados</i>	234
2.5. <i>Atribuições Senado Federal</i>	235
2.6. <i>Estatuto dos Congressistas</i>	236
2.6.1. Imunidades	236
a) Imunidades materiais.....	236
b) Imunidades formais	237
c) Foro especial em razão da função	240
d) Afastamento do Poder Legislativo	241
e) Desobrigação de testemunhar	241

f) Incorporação às Forças Armadas	241
2.6.2. Incompatibilidades	242
2.6.3. Perda do mandato	242
2.6.4. Renúncia ao mandato	244
2.6.5. Deputados estaduais, distritais e vereadores	245
2.7. <i>Tribunais de Contas</i>	245
2.7.1. Tribunal de Contas da União	245
2.7.2. Tribunal de Contas Estaduais, Distritais e Municipais	248
3. <i>Processo Legislativo</i>	249
3.1. <i>Conceito</i>	249
3.2. <i>Classificação do processo legislativo</i>	249
3.2.1. Quanto à forma de organização política	249
a) Autocrático	249
b) Indireto (representativo).....	249
c) Direto	249
d) Semidireto	249
3.2.2. Quanto ao rito	250
a) Ordinário	250
b) Sumário	250
c) Espécies de iniciativa	251
d) Iniciativa e casa iniciadora	252
e) Iniciativa popular	252
f) Iniciativa privativa do chefe do executivo	252
g) Iniciativa dos tribunais	253
h) Iniciativa em matéria tributária	253
i) Prazo para exercício de iniciativa reservada	253
j) Iniciativa privativa e emenda parlamentar	254
k) Vício de iniciativa	254
3.2.3. Fase constitutiva	254
a) Fase constitutiva do poder legislativo	255
b) Fase constitutiva do poder executivo.....	256
c) Fase complementar	257
d) Fases do Processo legislativo sumário.....	258
3.2.4. Espécie Normativa.....	259
a) Lei ordinária.....	259

b) Lei complementar	259
3.2.5. Processos legislativos especiais	261
a) Emendas à constituição	261
3.2.6. Processo Legislativo da Emenda Constitucional	263
3.2.7. Medidas provisórias.....	264
a) Requisitos das medidas provisórias	266
b) Vedações às medidas provisórias	266
c) Procedimento legislativo da MP.....	266
d) Prazo de eficácia da MP.....	268
e) Trancamento de pauta	268
f) Efeitos após a perda de eficácia da medida provisória.....	269
g) Apreciação plenária.....	269
h) Conversão parcial.....	269
i) Reedição	270
j) MP sobre direito tributário	270
k) Intervalo proibitivo de medida provisória (art. 246 da CF)	270
l) Medidas provisórias anteriores à EC 32/01.....	270
m) Retirada da medida provisória.....	271
n) Revogação da medida provisória	271
o) Efeitos da medida provisória sobre a lei pretérita	271
p) Apreciação judicial dos pressupostos constitucionais da medida provisória	271
q) Lei de conversão e vício de medida provisória.....	271
r) Medida provisória nos estados-membros e nos municípios.....	272
s) Considerações finais sobre Medidas Provisórias	272
3.2.8. Leis delegadas	272
3.2.9. Decretos legislativos.....	273
3.2.10. Resoluções	274
3.2.11. Processo legislativo nos estados-membros e municípios.....	275
3.2.12. Decretos autônomos	275
3.2.13. Hierarquia entre leis federais, estaduais, distritais e municipais.....	276
3.2.14. Tratados internacionais e suas relações com as demais espécies normativas.....	276
3.2.15. Controle judicial do processo legislativo	276
3.2.16. Modificação da CF/88	276
3.2.17. Limitações ao poder de reforma.....	278
a) Limitações temporais.....	278
b) Limitações circunstanciais.....	278

c) Limitações processuais ou formais	278
d) Limitações quanto à iniciativa	278
e) Limitações quanto à deliberação	278
f) Limitações quanto à promulgação	279
g) Limitações quanto à vedação de reapreciação da emenda rejeitada	279
h) Limitações materiais	279
i) Limitações materiais explícitas	279
j) Limitações materiais implícitas	279
3.2.18. Aplicabilidade imediata das emendas constitucionais e a retroatividade mínima .	280
3.2.19. Inconstitucionalidade de lei e posterior emenda constitucional	280
2. Poder Executivo.....	280
2.1. <i>Noção de presidencialismo</i>	280
2.2. <i>Funções do poder executivo</i>	281
2.3. <i>Investidura</i>	281
2.4. <i>Impedimentos e vacâncias</i>	282
2.4.1. Impedimentos	282
2.4.2. Vacância	282
2.5. <i>Atribuições do Presidente da República</i>	284
2.6. <i>Vice-Presidente da República</i>	286
2.7. <i>Ministros de Estado</i>	286
2.8. <i>Órgãos consultivos</i>	287
2.8.1. Conselho da República	287
2.8.2. Conselho de defesa nacional	287
2.9. <i>Responsabilização do Presidente da República</i>	288
2.9.1. Crimes de responsabilidade	288
2.9.2. Crimes comuns	291
2.10. <i>Crimes praticados por Governadores e Prefeitos</i>	293
3. Poder Judiciário	295
3.1. <i>Conceito</i>	295
3.2. <i>Órgãos do Poder Judiciário</i>	295
3.3. <i>Funções típica e atípica</i>	296
3.4. <i>Garantias do Poder Judiciário</i>	296

3.5. Organização da carreira	297
3.6. Garantias dos magistrados.....	297
3.7. Vedações aos magistrados	298
3.7.1. Proposta orçamentária do Poder Judiciário	298
3.8. Conselho Nacional de Justiça	299
3.9. Criação de órgãos de controle administrativo pelos estados-membros	303
3.10. Supremo Tribunal Federal.....	303
3.10.1. Competência originária	303
3.10.2. Competência recursal.....	305
3.10.3. Preservação das competências do STF e da autoridade de suas decisões	305
3.11. Superior Tribunal de Justiça	306
3.11.1. Competência originária	307
3.11.2. Competência recursal do STJ	307
3.12. Justiça Federal	308
3.12.1. TRF.....	308
3.12.2. Juízes federais.....	309
3.13. Justiça do Trabalho	310
3.13.1. TST	310
3.13.2. TRT.....	311
3.13.3. Justiça do trabalho.....	311
3.14. Justiça Eleitoral	312
3.14.1. TSE	312
3.14.2. TRE's.....	312
3.15. Justiça militar.....	313
3.15.1. Justiça militar da União	314
3.15.2. Justiça militar estadual.....	314
3.16. Justiça Estadual.....	315
3.17. Julgamento de autoridades	315
3.17.1. Ministros do STF	315
3.17.2. Governadores	315
3.17.3. Prefeitos.....	316
3.18. Quinto Constitucional.....	316
3.19. Precatórios judiciais	317

3.19.1. Introdução	317
3.19.2. Exceção ao regime de precatório	317
3.19.3. Ordem de pagamento dos precatórios	317
3.19.4. Sequestro de valor	317
3.19.5. Decretação de intervenção	318
3.19.6. Vedação ao fracionamento.....	318
3.19.7. Precatórios para compra de imóveis públicos	318
3.19.8. Cessão de precatórios	318
3.19.9. Crime de responsabilidade do presidente do Tribunal	318
3.19.10. Inconstitucionalidades da EC	318
4. Informativo de jurisprudência	318
4.1. <i>Supremo Tribunal Federal</i>	318
<i>Questões</i>	319
<i>Comentários</i>	320
CAPÍTULO 18 – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE	323
1. Presunção de constitucionalidade das leis	323
2. Requisitos	324
2.1. <i>Requisitos formais</i>	324
2.2. <i>Requisitos materiais</i>	324
2.3. <i>Tipos de inconstitucionalidade formal</i>	324
2.3.1. Orgânica.....	324
2.3.2. Por descumprimento de pressupostos objetivos do ato.	324
2.3.3. Propriamente dita	325
3. Sistemas (matrizes) do Controle de Constitucionalidade	325
3.1. <i>Sistema Norte-Americano (Sistema Judicial)</i>	325
3.2. <i>Sistema austríaco</i>	326
3.3. <i>Sistema Francês (Sistema Político)</i>	326
3.4. <i>Modelos de controle</i>	327
3.5. <i>Vias de ação</i>	327
3.6. <i>Momento de controle</i>	327
3.7. <i>Jurisdição constitucional</i>	328

3.8. Fiscalização não jurisdicional.....	328
3.8.1. Poder Legislativo.....	328
3.8.2. Poder Executivo	328
3.8.3. Tribunais de Contas.....	328
3.9. Controle Político Preventivo	329
3.10. Controle Político Repressivo.....	329
3.11. Controle Judicial Preventivo.....	330
3.12. Controle difuso.....	330
3.12.1. Competência	330
3.12.2. Declaração da inconstitucionalidade pelos Tribunais (reserva de plenário)	330
3.13. Parâmetro de controle	332
3.14. Recurso extraordinário	332
3.15. Efeitos da decisão.....	333
3.16. Atuação do Senado Federal	333
3.17. Súmula vinculante.....	333
3.17.1. Iniciativa.....	334
3.17.2. Requisitos.....	334
3.17.3. Deliberação	334
3.17.4. Descumprimento	334
3.17.5. Cancelamento ou revisão	335
3.17.6. Súmulas anteriores à EC 45	335
3.18. Controle abstrato	335
3.18.1. Introdução.....	335
3.18.2. Ação direta de inconstitucionalidade.....	335
a) Legitimação ativa	335
3.18.3. Objeto	336
3.18.4. Parâmetro de controle	337
3.18.5. Causa de pedir aberta	338
3.18.6. Impossibilidade de desistência	338
3.18.7. Prestação de informações	339
3.18.8. Impossibilidade de intervenção de terceiros	339
3.18.9. Admissibilidade de <i>amicus curiae</i>	339
3.18.10. Atuação do AGU	340

3.18.11. Atuação do PGR	340
3.18.12. Atuação do Relator na instrução do processo.....	341
3.18.13. Medida cautelar em ADI	341
3.18.14. Decisão de mérito em ADI	342
a) Quórum de instalação e de julgamento	342
b) Natureza dúplice ou ambivalente.....	343
c) Efeitos da decisão	343
d) Modulação dos efeitos temporais	344
e) Definitividade da decisão de mérito	345
f) Limites da eficácia retroativa	345
g) Transcendência dos motivos determinantes	346
h) Inconstitucionalidade por arrastamento.....	346
i) Momento da produção de efeitos da decisão	346
3.18.15. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO).....	346
a) Características da ADO	347
b) Legitimidade ativa	347
c) Legitimidade passiva	347
d) Objeto	347
e) Atuação do AGU	347
f) Atuação do PGR.....	348
g) Concessão de medida cautelar.....	348
h) Efeitos da decisão de mérito.....	348
3.18.16. Ação declaratória de constitucionalidade (ADC)	349
a) Legitimidade ativa.....	349
b) Principais aspectos comuns.....	349
c) Objeto da ADC.....	349
d) Relevante controvérsia judicial	349
e) Medida cautelar em ADC.....	350
f) Não atuação do AGU.....	350
3.18.19. Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF)	350
a) Arguição autônoma	350
b) Arguição incidental	350
c) Objeto da ADPF e conteúdo do pedido.....	351
d) Preceito fundamental.....	351
e) Subsidiariedade da ADPF.....	351
f) Competência da ADPF	352

g) Petição inicial e procedimento da ADPF	352
h) Medida liminar	352
i) Informações adicionais da ADPF	352
3.18.20. Representação de inconstitucionalidade interventiva.....	352
3.18.21. Controle abstrato nos Estados	354
a) Legitimação da ADI Estadual.....	354
b) Defesa da norma impugnada no âmbito estadual	355
c) Parâmetro de controle	355
d) Inconstitucionalidade do parâmetro de controle estadual.....	355
e) Simultaneidade de ações diretas	355
f) Recurso extraordinário contra decisão de ADI estadual.....	357
g) Distrito Federal	357
h) Representação interventiva dos Estados.....	358
4. Controle de convencionalidade	358
5. Ação civil público como instrumento de controle de constitucionalidade	358
6. Espécies de inconstitucionalidades.....	358
6.1. <i>Inconstitucionalidade por ação e por omissão</i>	359
6.2. <i>Inconstitucionalidade material e formal</i>	359
6.3. <i>Inconstitucionalidade total e parcial</i>	359
6.4. <i>Declaração parcial de nulidade sem redução de texto e interpretação conforme a</i> <i>Constituição</i>	359
6.5. <i>Inconstitucionalidade direta e indireta</i>	360
6.6. <i>Inconstitucionalidade circunstancial</i>	360
6.7. <i>Inconstitucionalidade originária e superveniente</i>	361
6.8. <i>Inconstitucionalidade chapada, enlouquecida ou desvairada</i>	361
7. Histórico do controle de constitucionalidade no Brasil	361
8. Informativo de jurisprudência	362
8.1. <i>Supremo Tribunal Federal</i>	362
<i>Questões</i>	364
<i>Comentários</i>	365
CAPÍTULO 19 – FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA.....	368
1. Ministério Público.....	368

1.1. Composição do MP.....	368
1.2. Princípios do MP	368
1.2.1. Iniciativa concorrente da Lei de Organização do MP	369
1.2.2. Princípio do promotor natural	369
1.3. Funções do MP.....	369
1.3.1. Poder de investigação do MP	370
1.4. Atuação do PGR	370
1.5. Ingresso na carreira	370
1.6. Nomeação dos Procuradores-Gerais	370
1.6.1. PGR	370
1.6.2. PGJ	370
1.7. Garantias dos membros	371
1.8. Vedações ao membro.....	371
1.9. Conselho Nacional do Ministério Público.....	371
1.10. Ministério Público junto aos Tribunais de Contas.....	373
1.11. Prerrogativa de foro.....	373
1.12. Atuação perante o STF	373
1.13. Advocacia Pública	373
1.13.1. AGU.....	373
1.13.2. Procuradoria dos Estados	374
1.14. Advocacia	374
1.15. Defensoria Pública	374
2. Informativo de jurisprudência	375
2.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.....	375
2.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	375
Questões.....	376
Comentários.....	377
CAPÍTULO 20 – DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS.....	379
1. Estado de defesa	379
1.2. Pressupostos.....	379

1.3. Prazo	380
1.4. Medidas coercitivas	380
1.5. Controle do estado de defesa	380
2. Estado de sítio	381
2.1. Duração.....	381
2.2. Medidas coercitivas	381
2.3. Controle.....	382
3. Forças Armadas	382
4. Segurança Pública.....	383
4.1. Polícia federal.....	384
4.2. Polícia Civil	385
4.3. Polícia militar.....	385
4.4. Corpo de bombeiros militar	385
4.5. Polícia Penal.	386
5. Informativo de jurisprudência	386
5.1. Supremo Tribunal Federal	386
Questões.....	388
Comentários.....	388
CAPÍTULO 21 – FINANÇAS PÚBLICAS	390
1. Princípio constitucionais orçamentários	390
2. Leis orçamentárias.....	391
2.1. Plano plurianual.....	391
3. Lei de diretrizes orçamentárias	391
4. Lei orçamentária anual	391
5. Processo legislativo das leis orçamentárias.....	391
6. Emendas aos projetos de leis orçamentárias	392
7. Orçamento impositivo	392
8. Créditos adicionais.....	393
9. Limites para despesa com pessoal	393
Questões	394
Comentários.....	394

CAPÍTULO 22 – ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA	397
1. Fundamentos e princípios gerais da atividade econômica	398
2. Princípios básicos da ordem econômica.....	398
3. Política Urbana	401
4. Política Agrária	402
4.1. <i>Reforma Agrária</i>	402
4.2. <i>Política Agrícola</i>	402
5. Sistema Financeiro Nacional	402
<i>Questões</i>	403
<i>Comentários</i>	403
CAPÍTULO 23 – ORDEM SOCIAL.....	406
1. Seguridade social.....	406
1.1. <i>Saúde</i>	407
1.2. <i>Previdência social</i>	407
1.2.1. regras para aposentadoria.....	408
1.2.2. regime de previdência privada complementar	408
1.3. <i>Assistência social</i>	408
2. Educação	408
2.1. <i>Princípio constitucionais do ensino</i>	408
2.2. <i>Autonomia das universidades</i>	409
2.3. <i>Deveres do Estado em relação ao ensino</i>	409
2.4. <i>Participação da iniciativa privada</i>	409
2.5. <i>Organização dos sistemas de ensino</i>	410
2.6. <i>Aplicação de recursos na educação</i>	410
2.7. <i>Plano nacional de educação</i>	410
3. Cultura	410
4. Desporto	411
5. Ciência Tecnologia e Inovação	411
6. Comunicação Social	412
7. Meio Ambiente.....	413
8. Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso	414
9. Índios	415

10. Informativo de jurisprudência	416
<i>10.1. Supremo Tribunal Federal.....</i>	416
<i>Questões</i>	417
<i>Comentários.....</i>	417
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA.....	421

CAPÍTULO 1 — DIREITO CONSTITUCIONAL: OBJETO E CONTEÚDO

O objeto do Direito Constitucional é o estudo das constituições a partir de uma análise histórica, teórica e dogmática. É o estudo das diversas constituições do mundo, a partir de teorias constitucionais em momentos históricos e dogmáticos.

O objeto, portanto, é uma análise crítica das constituições, do ponto de vista teórico, histórico e dogmático.

Direito constitucional é o ramo de direito público, fundamental ao funcionamento do Estado, cujo centro de estudo é o ser humano inserido nas normas de organização do Estado e do Poder.



CAPÍTULO 2 — CONSTITUCIONALISMO

1. CONCEITO

Constitucionalismo é uma ideia bastante antiga que é ligada a existência de uma Constituição nos Estados, independentemente do momento histórico ou do regime político adotado. É com a revolução francesa que essa ideia de Constitucionalismo ganha forma¹.

Numa visão TRADICIONAL é ligado ao princípio da separação de poderes, uma vez que TODO poder político tem de ser legalmente limitado. Isto é, o fim do CONSTITUCIONALISMO é o ideal de liberdade dos cidadãos.

Assim, seu CONCEITO é a técnica jurídica por meio da qual os direitos fundamentais são garantidos em face do Estado².

No sentido estrito, compreende as noções do princípio da separação dos poderes e a garantia de direitos, ambos como limitação do exercício do poder estatal com o objetivo de proteger as liberdades fundamentais.

O conceito de Constitucionalismo evolui ao longo dos tempos, de acordo com o momento histórico social que se vivia.

2. CONSTITUCIONALISMO ANTIGO

O constitucionalismo antigo é o período destacado entre a antiguidade clássica até fim do século XVIII.

No constitucionalismo antigo, há quatro experiências importantes:

1. Estado Hebreu: como se tratava de um estado teocrático, o governo era limitado por dogmas religiosos.
2. Grécia: havia instrumentos de democracia direta entre governantes e governados.
3. República Romana: havia uma separação de poderes dentre os cônsules, senado e povo, ainda que embrionária.
4. Inglaterra: diferente da França, o modelo de poder inglês não ostentou um absolutismo porque o poder real sempre encontrou algum tipo de limitação, como exemplo a Carta Magna de 1215. De toda forma, a Revolução Gloriosa de 1688 consolidou a supremacia do Parlamento Inglês (princípio constitucional de soberania do Parlamento), que reafirmou o respeito aos direitos individuais aliado ao respeito às tradições constitucionais. Importante destacar que não há uma Constituição escrita na Grã-Bretanha, mas sim documentos constitucionais como: Petition of Rights (1628); Habeas Corpus Act (1679); Bill of Rights (1689); Human Rights Act (1998) e Constitutional Reform Act (2005)³.

As principais características do constitucionalismo antigo são a inexistência de uma constituição escrita; a forte influência da religião; e a supremacia do monarca ou do Parlamento.

No constitucionalismo antigo não havia controle de constitucionalidade e sequer se falava na existência de um Poder Judiciário organizado como se desenvolveu no período constitucional seguinte. As constituições eram consuetudinárias ou baseadas nos precedentes judiciais.

¹ NOVELINO, Marcelo. *Curso de Direito Constitucional*. 10. ed. rev.amp.atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2015. P. 48.

² BULOS, Uadi Lammêgo. *Curso de Direito Constitucional*. 6. ed. rev.amp.atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p.71.

³ SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. SARMENTO, Daniel. *Direito Constitucional: teoria, história e métodos de trabalho*. 2.ed.Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 75.



3. CONSTITUCIONALISMO MODERNO

Foi um movimento que ocorreu no final do século XVIII nos Estados Unidos e na França e que teve como objetivo limitar o poder (com uma nova organização do Estado) e estabelecer direitos e garantias fundamentais. Veio para superar o poder absoluto dos monarcas, para apresentar um estado de direito constitucionalizado com limitação deste mesmo poder e direitos individuais. Assim, pode-se afirmar que a ideia do constitucionalismo é a ideia de libertar o poder e estabelecer direitos fundamentais.

A doutrina estabelece que as constituições da França e dos EUA, ambas provenientes dos ideais iluministas e liberais, caracterizadas pela ausência de interferência do Estado nas relações privadas, foram a origem do constitucionalismo moderno.

Essas constituições escritas elencavam a organização do estado; a transmissão de poder; a limitação do poder estatal pela divisão de poderes e direitos e garantias fundamentais.

É possível dividir o constitucionalismo moderno em suas fases clássica e social, vejamos.

O **constitucionalismo clássico ou liberal** começa no fim do século XVIII e vai até o fim da Primeira Guerra Mundial (1917). O principal diferencial do constitucionalismo clássico, em relação à fase anterior, é o aparecimento das primeiras constituições escritas. A partir delas, surgem as noções de rigidez constitucional e supremacia da constituição. O que define a rigidez das constituições é o processo diferenciado de modificação e não a presença de cláusulas pétreas.

No constitucionalismo clássico, duas experiências constitucionais merecem destaque, com características peculiares: a norte-americana e a francesa.

- a) Constitucionalismo norte-americano (estadualista). A experiência constitucional americana possui os seguintes pilares.
 - Criação da primeira constituição escrita, elaborada em 1787: originariamente, tinha sete artigos, mas possui dispositivos bastante amplos. Atualmente, conta com 27 emendas. Diante da dificuldade de modificação formal do texto, a atualização constitucional ocorre muitas vezes pela via interpretativa do Poder Judiciário.
 - Surgimento do primeiro controle de constitucionalidade tendo como parâmetro uma constituição escrita: o controle de constitucionalidade difuso surgiu com o famoso caso *Marbury vs. Madison* (1803).
 - Fortalecimento do Poder Judiciário: os norte-americanos tinham bastante receio dos abusos perpetrados pelo Parlamento inglês, razão pela qual optaram pelo fortalecimento do Judiciário (judicial review)
 - Contribuição para as noções de separação dos poderes com a criação do *check and balance*, forma federativa, sistema republicano, presidencialista e regime democrático
 - Existência de declarações de direitos fundamentais.
- b) Constitucionalismo francês (individualista). O marco inicial do constitucionalismo francês é a Revolução Francesa, de 1789, sendo certo que a primeira constituição francesa escrita é de 1791. Duas ideias que constam da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, são fundamentais para a compreensão do



constitucionalismo francês: garantia de direitos e separação dos poderes. São pilares do constitucionalismo francês:

- Consagração do princípio da separação dos poderes
- Distinção entre poder constituinte originário e derivado
- Supremacia do Parlamento
- Surgimento da escola da exegese, a partir do Código de Napoleão de 1804

Por seu turno, o **constitucionalismo social** vai do fim da Primeira Guerra Mundial (1917) até o fim da Segunda Guerra Mundial (1945). O Estado Liberal funciona quando há equilíbrio de condições entre as pessoas. A crise econômica do pós-guerra aprofunda as desigualdades econômicas existentes, ocasionando, como consequência, a crise do Estado Liberal, que deixou de ser abstencionista para assumir um modelo intervencionista.

Os dois principais modelos de Constituição do constitucionalismo social foram a Constituição Mexicana (1917) - a primeira a incluir os direitos trabalhistas entre os direitos fundamentais, e a Constituição de Weimar (1919) que também elencou os direitos sociais em seu rol de limites ao poder estatal.

No período do constitucionalismo moderno, verifica-se em alguns Estados a transformação do Estado de Direito (ou Liberal) em Estado Social, cujas principais características são as seguintes:

- intervenção no âmbito social, econômico e laboral: o Estado Social abandona a postura abstencionista e passa a intervir nas relações econômicas, sociais e trabalhistas.
- papel decisivo na produção e distribuição de bens
- garantia de um mínimo de bem estar social “Welfare State” (“O Estado do Bem Estar Social”)

4. NEOCONSTITUCIONALISMO

4.1. CONCEITO

É um movimento pós-Segunda Guerra Mundial (segunda metade do século XX), que tem como objetivo desenvolver um novo modo de compreender, interpretar e aplicar o direito constitucional e as constituições. É também chamado de constitucionalismo contemporâneo.

Como marcos que melhor explicam essa teoria constitucional destacam-se o histórico, o filológico e o teórico.

O **marco histórico** é o estado constitucional de direito do pós-Segunda Guerra Mundial na Europa, surgido em constituições como a da Itália, a da Alemanha, a de Portugal, a da Espanha, entre outras.

O **marco filosófico** é o chamado pós-positivismo, que é um fenômeno que visa superar a dicotomia entre o Positivismo e o Jusnaturalismo. O pós-positivismo supera essa dicotomia, indo além da legalidade estrita e confrontando o positivismo, pois a legitimidade do direito não advém apenas da lei. Precisamos ir além da legalidade estrita analisando componentes para que se produza o mínimo de justiça. Robert Alexy, por exemplo, faz uso da fórmula de Radbruch, para dizer que “a extrema injustiça não é direito”, pois se ficar caracterizada a extrema injustiça esse direito é inválido.

O pós-positivismo ainda não desconsidera o direito posto, que confronta com o jusnaturalismo. Com o escopo de repelir as injustiças da legalidade estrita, o pós-positivismo não irá sair do direito positivo para resolver os problemas deste. Não irá usar categorias metafísicas, ilusórias, com a ideia de que existe um direito que está acima do direito positivo,



que advém da natureza humana. O pós-positivismo defende que o jusnaturalismo é ilusão, por não ter o direito nada de natural – **o direito é luta**.

O pós-positivismo vai além da legalidade estrita, mas não desconsidera o direito posto. Ao contrário, busca resolver o problema do direito positivo dentro dele mesmo e, para tanto, o pós-positivismo defende uma reaproximação entre o direito e a moral, o direito e a ética e o direito e a justiça. É possível um direito que seja justo, moral e ético, ainda que estes conceitos sejam subjetivos e abstratos, pois possuem um conceito mínimo que todos conhecem dentro de sua comunidade.

O **marco teórico** é um conjunto de teorias que dizem respeito à força normativa da constituição, à expansão da jurisdição constitucional e de novos métodos de interpretação, chamada de nova hermenêutica constitucional.

4.2. CARACTERÍSTICAS

1. *A Constituição como centro do ordenamento jurídico* – a Constituição passa a ser o centro do ordenamento, deixa de ser algo paralelo. Com isso temos o movimento de constitucionalização do direito. É o momento de constitucionalização de todo o direito, a invasão das normas constitucionais. Essa ideia de invasão das normas constitucionais é o que pode ser chamado de ubiquidade constitucional, já que o Direito Constitucional está em todos os lugares e o ordenamento se constitucionalizou. Além disso, temos a filtragem constitucional, por justamente todo ordenamento ter que passar pela constituição. Essa filtragem é o que se entende por interpretação conforme a constituição, pois qualquer norma jurídica só tem sentido e só é válida, hoje, se for interpretada conforme a constituição.

2. *Força normativa da Constituição* – paulatinamente, da segunda metade do século XX em diante, aconteceu na Europa e no Brasil: a Constituição deixa de ser um documento político para ser efetivamente jurídico, realmente vinculado.

3. *Busca pela concretização de direitos fundamentais tendo como base a dignidade da pessoa humana* – o constitucionalismo busca explicitar os direitos fundamentais, enquanto o neoconstitucionalismo quer concretizar tais direitos, tendo como eixo a dignidade da pessoa humana, que é uma norma de eficácia irradiante.

4. *Judicialização da política e das relações sociais* – tudo se judicializa. Temos um deslocamento de poder do legislativo e executivo para o judiciário, que passa a ser protagonista de ações, coisa que até então não era. O judiciário passa a interferir nas relações de políticas públicas, afastando a reserva do possível, de forma ativista. Essa quarta característica do neoconstitucionalismo tem como objetivo o interesse de políticas públicas, a tese do mínimo existencial de direitos fundamentais sociais com base na dignidade da pessoa humana.

5. *Reaproximação entre direito e moral, direito e ética, direito e justiça e direito e filosofia* – o direito se aproxima da filosofia.

6. *Novas teorias* – teremos novas teorias da norma jurídica, com o reconhecimento da força normativa dos princípios, que passam a ser tão normas quanto as regras. Canotilho afirma que a Constituição é um sistema aberto de normas e princípios, pois não tem só normas, tem princípios e estes são tão normas quanto as regras. Os princípios tinham antes uma função de integração, eram normas de natureza secundária, de preenchimento de lacunas, só apareciam quando faltavam regras. Atualmente os princípios são considerados normas tanto quanto as regras, o que deriva de autores como Dworkin e



Alexy. Essa ideia é criticada por Lênio Streck, que propõe a ideia do panprincípioalismo, a qual dispõe sobre afastar a regra existente ao caso concreto para que se aplique o princípio, gerando uma forte discricionariedade.

Importante destacar ainda a **Teoria das Fontes no Neoconstitucionalismo**, que explica o deslocamento de poder do legislativo para o judiciário. O judiciário passa a ser o protagonista de ações e a participar de forma mais ativa da criação do Direito, com a súmula vinculante e a teoria dos precedentes trazidas pelo novo Código de Processo Civil. Há um empoderamento do poder judiciário. E a **Teoria da interpretação no Neoconstitucionalismo**, com o uso de uma nova hermenêutica constitucional. Ainda são utilizados os métodos clássicos pelos representantes do Poder, contudo, houve a inserção de novas técnicas hermenêuticas, como: a regra da proporcionalidade, ponderação ou sopesamento de direitos, teorias da argumentação, a metódica normativa estruturante, teoria da integridade, dentre outras.

5. TRANSCONSTITUCIONALISMO

É o entrelaçamento de ordem jurídicas diversas (estatal, internacional, transnacional e supranacional) em torno dos mesmos problemas de natureza constitucional, ou seja, o transconstitucionalismo ocorre quando ordens jurídicas diferenciadas passam a enfrentar concomitantemente as mesmas questões de natureza constitucional, como por exemplo separação de poderes e direitos humanos.

Portanto, nada mais é que a ideia de globalização aplicada na perspectiva do direito.

Exemplo 1: ADPF 101, quando o STF enfrentou o tema da produção e importação de pneus usados. Ao mesmo tempo que o STF decidiu sobre a produção e importação de pneus usados, o mesmo tema estava sendo discutido no Mercosul, na União Europeia, na Organização Mundial do Comércio, na Organização Mundial do Meio Ambiente e na Organização Mundial da Saúde. Isto é, vamos ter uma série de ordens jurídicas discutindo concomitantemente um problema de natureza constitucional.

Exemplo 2: ADPF 153, do tema justiça de transição, o qual envolve a passagem do regime ditatorial para o regime democrático. O STF enfrentou esse tema em 2010, julgando-o improcedente, e, ao mesmo tempo em que o STF estava decidindo sobre esse tema, a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi chamada ao caso Gomes Lund, e disse que a lei de anistia do Brasil não pode ser empecilho para investigação e punição dos agentes da repressão na época do regime militar no Brasil.

Qual ordem deve preponderar? A transnacional, a internacional, a supranacional? Marcelo Neves afirma que não se pode defender a prevalência absoluta, *a priori*, de uma ordem constitucional sempre sobre as outras. Para o autor, o que se deve trabalhar são os diálogos entre as várias ordens, isto é, pontes de transição entre elas. Quanto mais conversação entre as ordens e quanto mais elas entrarem em conexão, mais decisões legítimas e justas poderão ser tomadas.

6. CONSTITUCIONALISMO ABUSIVO

O conceito de constitucionalismo abusivo foi pensado por David Landau⁴ como abuso de instrumentos de origem democrática para minar o espaço político e plural em determinada

⁴ LANDAU, David. Abusive constitutionalism. V.47, n. 1. UC Davis Law Review. Estados Unidos da América, 2013, p. 189-260.



país. Assim, o autor identificou que chefes do poder executivo podem utilizar elementos como o seu poder de regulamentar ou de participar do processo legislativo para enfraquecer outros poderes, rejeitar proteção à direitos fundamentais de grupos minoritários ou vulneráveis, num verdadeiro abuso dos instrumentos democráticos que são dispostos na Constituição local.

7. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIAS

7.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E AO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.369.832. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA À AUTORIDADE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR ESTA CORTE. INTERPRETAÇÃO DA NORMA NO CASO CONCRETO, SEM JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...)Por outro lado, a mera menção à Carta Magna não representa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão julgador. Determinadas citações constitucionais representam tão somente um reflexo da constitucionalização do Direito, fenômeno característico do **neoconstitucionalismo**, que implica a irradiação das normas constitucionais por todo o ordenamento. Sobre o tema, Daniel Sarmento afirma que “cabe ao intérprete não só aplicar diretamente os ditames constitucionais às relações sociais, como também reler todas as normas e institutos dos mais variados ramos do Direito à luz da Constituição” (O Neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades, in Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 143). (...)grifamos. (Rcl 25125, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 03/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 06/03/2017 PUBLIC 07/03/2017)

Direito da criança e do adolescente. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Decreto nº 10.003/2019. Composição e funcionamento do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente – Conanda. Cautelar parcialmente deferida.

1. Importância de evitar os riscos do **constitucionalismo abusivo**: prática que promove a interpretação ou a alteração do ordenamento jurídico, de forma a concentrar poderes no Chefe do Executivo e a desabilitar agentes que exercem controle sobre a sua

atuação. Instrumento associado, na ordem internacional, ao retrocesso democrático e à violação a direitos fundamentais (...) grifamos. (ADPF/MC 622, Relator: Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 20/12/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31/01/2020 PUBLIC 03/02/2020)

Questões

1) (MPE PR/2019) — Assinale a alternativa incorreta:

- a) A corrente interpretativista defende que as dúvidas interpretativas sobre a Constituição devem ser solucionadas apenas dentro do texto constitucional (os juízes devem se limitar a cumprir normas explícitas ou claramente implícitas na Constituição), enquanto a corrente não-interpretativista afirma que só é possível definir o sentido controvertido das cláusulas abertas da Constituição com amparo em princípios e valores que transcendem o próprio texto.
- b) Segundo a concepção dualista de democracia, há dois tipos de decisão que podem ser tomadas nesse regime: o primeiro tipo são as decisões do povo, que estabelecem a norma



constitucional; o segundo tipo são as decisões dos governantes, que ocorrem pelas leis, decretos e demais atos regulares do governo.

c) Embora se costume afirmar que a norma é o produto da interpretação do texto, não existe correspondência necessária entre norma e um dispositivo, pois há normas que não encontram suporte físico em um dispositivo específico, e há dispositivos a partir dos quais não se constrói norma alguma.

d) O liberalismo igualitário supera a noção de individualismo, pois seu foco se centra em entidades supraindividuais como o Estado, a Nação, a Sociedade, os grupos étnicos e outros conjuntos de pessoas.

e) Atribui-se viés antidemocrático à panconstitucionalização – excesso de constitucionalização do Direito –, porque, se o papel do legislador se resumir ao de mero executor de medidas já impostas pelo constituinte, nega-se autonomia política ao povo para, em cada momento de sua história, realizar suas escolhas.

2) (TJ AC/2019) — Assinale a alternativa correta a respeito do constitucionalismo.

a) O constitucionalismo antigo teve início com a Magna Carta de 1215, não havendo antes desse período indícios de experiências democráticas que contrastassem com os poderes teocráticos ou monárquicos dominantes.

b) John Locke, Montesquieu e Rousseau são reconhecidos como os principais precursores do constitucionalismo contemporâneo, em virtude de concepções revolucionárias que defendiam a unificação e consagração dos ideais e valores humanos universais.

c) No constitucionalismo moderno, as Constituições de sintéticas passam a analíticas, consagrando nos seus textos os chamados direitos econômicos e sociais, e a democracia liberal-econômica dá lugar à democracia social, mediante a intervenção do Estado na ordem econômica e social.

d) A transição da Monarquia Absolutista para o Estado Liberal, em especial na Europa, no final do século XVIII, que traçou limitações formais ao poder político vigente à época, é um marco do constitucionalismo moderno.

Comentários

1. Gabarito: D

Errado, pois Dworkin entende a igualdade liberal ou liberalismo igualitário rejeita a igualdade de bem-estar material que neutralizaria as consequências das decisões éticas tomadas pelo indivíduo. O liberalismo igualitário trabalha com um valor de neutralidade:

"Essa forma de liberalismo (baseado na igualdade), insiste que o governo deve tratar as pessoas como iguais no seguinte sentido. Não deve impor sacrifícios nem restrições a nenhum cidadão com base em um argumento que o cidadão não poderia aceitar sem abandonar seu senso de igual valor". (DWORKIN, Ronald. Foundations of Liberal Equality in DARWALL, Stephen (Ed.) Equal Freedom: Selected Tanner Lectures on Human Values. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995, p. 194). (Tradução livre)

Portanto, Dworkin não abandona o individualismo, mas vincula-o ao respeito ao livre arbítrio do indivíduo de tomar suas decisões, a cavaleiro de interferências externas. Entretanto, ele reconhece que limitações econômicas podem interferir nos parâmetros de "boa vida" de um indivíduo (por óbvio), e assevera que

"Certamente, os recursos devem figurar como parâmetros de alguma forma, porque não podemos descrever o desafio de viver bem sem fazer algumas suposições sobre os recursos que uma boa vida deve ter disponíveis. Os recursos não podem contar apenas como limitações, porque não podemos fazer qualquer sentido da melhor vida possível, abstraindo-se



completamente de suas circunstâncias econômicas". (DWORKIN, Ronald. Foundations of Liberal Equality op. cit., p. 259) (tradução livre)

2. Gabarito: D

a) O constitucionalismo antigo teve início com a Magna Carta de 1215, não havendo antes desse período indícios de experiências democráticas que contrastassem com os poderes teocráticos ou monárquicos dominantes.

O documento formal que procurou estabelecer limites e controles ao poder do soberano surgiu na Idade Média, foi a Carta Magna de 1215, na qual os donos de terras cultivadas e barões impuseram ao Rei "João Sem Terra" um documento estabelecendo limites à tributação e a outras prerrogativas da Coroa. A Magna Carta é considerada o marco histórico do constitucionalismo antigo, e esse nome é utilizado, muitas vezes, para designar a nossa Constituição.

Entretanto, existiram antes experiências que apontaram para o acolhimento da ideia democrática e da dignidade humana. O Cristianismo primitivo marcou impulso relevante para esse ideal, ao estabelecer a dignidade única de todos os homens. Atenas é identificada como um dos primeiros precedentes de limitação do poder político e de participação dos cidadãos, como berço do ideal constitucionalista e democrático, e ali se vislumbrava a divisão das funções estatais em órgãos distintos, a separação entre religião e Estado, a existência de um sistema judicial e a supremacia da lei. O centro da vida política ateniense era a "assembleia" onde se reuniam aqueles que detinham a condição de cidadãos.

O ideal constitucionalista de limitação de poder observou-se igualmente no período da República romana, especialmente com a instituição da Lei das Doze Tábuas, em 529 A. C., não obstante a participação dos cidadãos fosse reduzida.

b) John Locke, Montesquieu e Rousseau são reconhecidos como os principais precursores do constitucionalismo contemporâneo, em virtude de concepções revolucionárias que defendiam a unificação e consagração dos ideais e valores humanos universais.

Na realidade, existem importantes distinções entre esses pensadores e filósofos. Montesquieu (1689-1755) em seu "Espírito das Leis", afirmava que para que não se possa abusar do poder, é preciso que o próprio poder freie o poder. Uma Constituição pode ser de tal modo que ninguém será constrangido a fazer coisas que a lei não obriga e a não fazer as que a lei permite.

Acreditava que no estado de natureza, o homem sente-se amedrontado e inferior, no máximo igual ao semelhante e a vida em sociedade amenizaria esse sentimento de fraqueza, organizada por um Estado Político, cujas leis se relacionem à natureza. Na mesma obra O Espírito das Leis, defende a liberdade e a igualdade entre os cidadãos, desenvolvendo uma teoria política de tripartição dos poderes como garantia da liberdade política. Preconizou o sistema de freios e contrapesos, em que a separação de poderes é mantida por uma eterna vigilância de um Poder sobre o outro.

John Locke (1632-1704) foi um dos precursores do pensamento liberal, e suas ideias repercutiram no processo revolucionário na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Para ele, no estado de natureza, no qual todos os homens são iguais e independentes e ninguém deve prejudicar a outrem em sua vida, saúde ou liberdade. O homem possui um domínio precário sobre qualquer propriedade, e cada indivíduo é promotor e juiz em causa própria, podendo não deter força suficiente para punir os transgressores. Isso justifica a instituição do Estado.

O Estado é então criado por meio de um contrato social, no qual os governantes também participam, ao contrário de Thomas Hobbes defendia, no qual os homens entregam a um governo os seus direitos, para se assegurem de que a lei natural será observada. Devem



franquear ao Legislativo o direito de fazer leis e ao Executivo o de executá-las. A manutenção do contrato dependia do consentimento permanente dos cidadãos.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) foi um dos mais célebres pensadores do século XVIII, autor de "Discurso sobre a Desigualdade", o "Contrato Social", e estabeleceu algumas premissas como "os homens nascem bons por natureza, e a sociedade os perverte; a existência de uma "vontade geral", a ideia de soberania popular, que germinou a ideia de democracia representativa. Para ele, a associação de pessoas passa a atuar soberanamente, sempre no interesse total que alcança o interesse individual e que tem uma vontade própria, que é a vontade geral. Entretanto, essa vontade geral não se confunde com a simples soma das vontades individuais, mas é uma síntese delas. Nesse sentido, cada indivíduo pode ter uma vontade própria inclusive diversa e contrária à vontade geral que essa mesma pessoa tem como cidadão. A diferença é que a soma da vontade de todos olha o interesse individual e a vontade geral, o interesse coletivo.

Portanto, Montesquieu visava mais o estabelecimento de limites ao exercício do poder, enquanto Locke e Rousseau vertiam suas teorias com base nos direitos de liberdade e participação dos homens.

c) No constitucionalismo moderno, as Constituições de sintéticas passam a analíticas, consagrando nos seus textos os chamados direitos econômicos e sociais, e a democracia liberal-econômica dá lugar à democracia social, mediante a intervenção do Estado na ordem econômica e social.

As chamadas constituições analíticas, de conteúdo extenso, que passaram a consagrar direitos econômicos e sociais, notadamente a partir da segunda metade do século XX, não implicaram a substituição das democracias liberais pelas democracias sociais, visto que ambas coexistem até os nossos dias. Nesse sentido, a Constituição liberal norte-americana de 1787 permanece vigente até hoje.



CAPÍTULO 3 — CONSTITUIÇÃO

A Constituição é a norma suprema de um Estado regendo a configuração jurídico-política dele.

A Teoria da Constituição sempre foi um tema muito analisado pelos constitucionalistas porque está umbilicalmente ligada ao próprio Estado e a forma como ele se desenvolve. Se antes a ideia era analisar a crise do constitucionalismo liberal e do positivismo político, procurou-se depois desenvolver uma Teoria voltada para as transformações políticas, econômicas e sociais.

O QUE É CONSTITUIÇÃO?

É uma palavra polissêmica, na medida em que comporta várias definições, desde as pertencentes a física a filosofia.

J.J. Canotilho chama de Constituição Ideal aquela que é:

- Escrita;
- Direitos e garantias individuais enumerados;
- Sistema democrático formal, com a participação do povo nos atos legislativos;
- Limitações de poder através do princípio da separação dos poderes.

O Supremo Tribunal Federal toma que existem múltiplas acepções para a palavra CONSTITUIÇÃO e já se posicionou que, na verdade, existe o chamado BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE - ADI 595/ES, afirmando que Constituição permite que sejam inclusos em seu conceito: o documento formal escrito, valores de caráter suprapositivos, princípios com raízes do direito natural e que a Constituição é muito mais que o conjunto de normas e princípios nela inscritos.

1. SENTIDOS DA CONSTITUIÇÃO

1.1. SENTIDO SOCIOLÓGICO (LASSALLE)

O sentido sociológico foi escrito por Ferdinand Lassalle em 1863. O sentido sociológico entende que a constituição é definida pelos fatores reais de poder que regem a sociedade. Esses fatores reais são fatores econômicos, militares, religiosos, midiáticos, etc. Lassalle afirma que a constituição em sua forma escrita não passa de uma mera “folha de papel”, e que sucumbe diante da constituição real, aquela formada por fatores reais de poder.

O sentido sociológico dá ênfase não à constituição “folha de papel”, jurídica e normativa, mas sim à chamada de constituição real, a qual possui fatores de poder que regem a sociedade e que a conduzem.

Aqui, a Constituição é conhecida como um fato social. É fruto da realidade social do país, de forma que as forças que imperam definem o conteúdo da Constituição.

Assim, cabe à Constituição apenas documentar os valores que reinam naquela sociedade. Ferdinand Lassalle diz que “*a Constituição seria a soma dos fatores reais de poder que atuam naquele país*”. Esta seria a Constituição. No entanto, também haveria uma Constituição escrita, denominada de “folha de papel”.

A força condicionante da realidade e a normatividade da Constituição são independentes. Nesse sentido, surgem duas constituições: a Constituição real e a Constituição jurídica devem se apresentar de forma autônoma.

1.2. SENTIDO POLÍTICO (SCHMITT)

O autor do sentido ou concepção política é Carl Schmitt, que escreveu a sua teoria da constituição no século XX, no ano de 1928. Dentre as várias concepções de constituição que Carl Schmitt escreve, a mais adequada é a concepção política, que são as decisões políticas



fundamentais do povo (poder constituinte). Para Carl Schmitt, constituição é decisão, e por isso esse conceito também é chamado de conceito decisionista.

“A Constituição é uma decisão política fundamental”, tomada pelo titular do Poder Constituinte.

Carl Schmitt dizia que se a Constituição refletir a decisão do titular, ela será válida, ainda que suas normas sejam injustas. Essa decisão é um ato político.

Por conta disso, Carl Schmitt diferencia Constituição e leis constitucionais:

- Constituição: são normas que tratam de organização do Estado, limitação do Poder, direitos e garantias fundamentais etc.
- Leis constitucionais: é o resto das normas que tratam de assuntos não essencialmente constitucionais.

1.3. SENTIDO CULTURAL

Tem como autor Peter Häberle, no século XX, e entende que constituição é produto da cultura. Constituição como espelho, reflexo, retrato, de uma sociedade num determinado momento histórico. É, portanto, condicionada para a cultura daquele momento histórico daquele determinado país. Além de condicionada, é também condicionante, formando, daí o que se chama de um movimento dialético. Diz-se que é condicionada à cultura por ser um produto da cultura, mas ao mesmo tempo condicionante à cultura por ter a capacidade de mudá-la, conduzindo o Estado, ou, como diz Canotilho, possui uma razão projetante.

1.4. SENTIDO JURÍDICO (KELSEN)

Esse sentido deriva de autores como Hans Kelsen (Teoria Pura do Direito – 1961) e de Konrad Hesse (Força Normativa da Constituição – 1959). Tanto Kelsen quanto Hesse entendem que constituição é uma norma jurídica prescritiva de dever-ser que vincula o Estado e a sociedade. A ênfase aqui é jurídica. Konrad Hesse fala em um sentimento, uma vontade de Constituição que temos que ter, ainda que eventualmente ela seja descumprida. O que interessa é o documento constitucional e a forma como este vai prescrever uma série de possibilidades para o Estado e sociedade, organizando o Estado, estabelecendo direitos fundamentais de forma vinculante.

“Constituição é norma pura”, dizia Hans Kelsen.

Constituição é a norma fundamental do Estado, pois dá validade a todo o ordenamento jurídico. Kelsen, pela obra “Teoria Pura do Direito”, dizia que a Constituição é puro *dever ser*.

Por isso, a Constituição não deveria levar em consideração o caráter político, sociológico, filosófico, etc. Isto não teria a ver com o Direito.

A partir da desvinculação da ciência jurídica de valores morais, sociológicos e políticos, Kelsen desenvolve dois sentidos para a Constituição:

- Sentido lógico-jurídico: Constituição é a norma fundamental hipotética. Ela serve como fundamento transcendental de validade da Constituição jurídico-positivo. Só há uma norma trazida pela norma fundamental: “obedeçam a Constituição”.
- Sentido jurídico-positivo: são as normas previstas no texto constitucional e que devem ser obedecidas por conta da Constituição lógico-jurídico.

Consoante Hans Kelsen, a concepção jurídica de Constituição é concebida como a norma por meio da qual regula a produção das normas jurídicas gerais, podendo ser produzida, inclusive, pelo direito consuetudinário.

Como se sabe, a Constituição pode ser produzida por via consuetudinária ou através de um ato de um ou vários indivíduos a tal fim dirigido, isto é, através de um ato legislativo.



Como, neste segundo caso, ela é sempre condensada num documento, fala-se de uma Constituição “escrita”, para a distinguir de uma Constituição não escrita, criada por via consuetudinária.

A Constituição material pode consistir, em parte, de normas escritas, noutra parte, de normas não escritas, de Direito criado consuetudinariamente. As normas não escritas da Constituição, criadas consuetudinariamente, podem ser codificadas, situação na qual poderão ser codificadas por um órgão legislativo e, portanto, com caráter vinculante, transformando-a em Constituição escrita.

A Constituição pode – como Constituição escrita – aparecer na específica forma constitucional, isto é, em normas que não podem ser revogadas ou alteradas como as leis normais mas somente sob condições mais rigorosas. Mas não tem de ser necessariamente assim, e não é assim quando nem sequer exista Constituição escrita, quando a Constituição surgiu por via consuetudinária, quer dizer: através da conduta costumeira dos indivíduos submetidos à ordem jurídica estadual, e não foi codificada. Nesse caso, também as normas que têm o caráter de Constituição material podem ser revogadas ou alteradas por leis simples ou pelo Direito consuetudinário.

1.5. FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO (KONRAD HESSE)

Critica e rebate a concepção tratada por Ferdinand Lassalle. A Constituição possui uma força normativa capaz de modificar a realidade, obrigando as pessoas. Nem sempre cederia frente aos fatores reais de poder, pois obriga. Tanto pode a Constituição escrita sucumbir, quanto prevalecer, modificando a sociedade. O STF tem utilizado bastante esse princípio da força normativa da Constituição em suas decisões.

1.6. CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA (MARCELO NEVES)

Cita o autor que a norma é mero símbolo. O legislador não a teria criado para ser concretizada. Nenhum Estado Ditatorial elimina da Constituição os direitos fundamentais, apenas os ignora.

1.7. CONCEPÇÃO CULTURAL

Remete ao conceito de Constituição total, que é a que possui todos os aspectos vistos anteriormente. De acordo com esta concepção, a Constituição é fruto da cultura existente dentro de determinado contexto histórico, em uma determinada sociedade, e ao mesmo tempo, é condicionante dessa mesma cultura, pois o direito é fruto da atividade humana. José Afonso da Silva é um dos autores que defendem essa concepção. Meirelles Teixeira⁵ a partir dessa concepção cultural cria o conceito de Constituição Total, segundo o qual: "Constituição é um conjunto de normas jurídicas fundamentais, condicionadas pela cultura total, e ao mesmo tempo condicionantes desta, emanadas da vontade existencial da unidade política, e reguladoras da existência, estrutura e fins do Estado e do modo de exercício e limites do poder político" (expressão retirada do livro do professor Dirley da Cunha Júnior na página 85, o qual retirou do livro de J. H. Meirelles Teixeira página 78).

5



1.8. CONSTITUIÇÃO DÚCTIL

Entende o jurista italiano GUSTAVO ZAGREBELSKY, para quem as constituições atuais podem ser consideradas tanto pluralistas quanto dúcteis. “Pluralistas, porque não representam uma única ideologia, já que são obras de consenso formado a partir de recíprocas concessões acertadas entre forças políticas distintas. Dúcteis, porque veiculam conteúdos tendencialmente contraditórios entre si, sem que se lhes possa traçar uma hierarquia rigorosa. Pelo contrário, eles devem ser assim preservados, de modo a conceder ampla margem à configuração legislativa, além de abertos a possíveis ponderações judiciais. Assim, estabelecem-se mútuas relações entre legislador e juiz, política e justiça. Numa constituição dúctil e repleta de princípios, dificilmente haverá matérias subtraídas, seja da justiça, seja da política”

2. BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE

Existem duas grandes correntes acerca do tema bloco de constitucionalidade. A primeira dela é a corrente extensiva e a segunda é a corrente restritiva.

Para a **teoria extensiva** o bloco de constitucionalidade é o conjunto de normas materialmente constitucionais que estão fora da constituição formal somado à constituição formal. Ressalta-se que dentro da constituição formal existem normas só formalmente constitucionais e normas material e formalmente constitucionais. Todas as normas que tratam sobre organização do Estado e direitos fundamentais e que estão dentro da constituição, compõe a constituição formal. No entanto, também existem várias normas que são só formalmente constitucionais, como por exemplo, o art. 242, § 2º da Constituição Federal, que trata do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro.

As normas materialmente constitucionais, que estão fora da constituição formal, não possuem supremacia, justamente por estarem fora da constituição. Temos as normas infraconstitucionais materialmente constitucionais, que são leis ordinárias, não possuindo qualquer supremacia, mas que podem versar sobre matéria constitucional. Qualquer matéria que versar sobre organização do Estado ou direitos fundamentais é direito constitucional mesmo estando em lei ordinária. Exemplo: Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei ordinária mas que versa sobre matéria constitucional; Estatuto do Idoso, pois envolve direitos fundamentais do idoso e por isso é lei materialmente constitucional.

Temos ainda os costumes jurídicos constitucionais, que nascem de dois elementos, quais sejam: repetição habitual e convicção de juridicidade. Esse costume jurídico pode ser constitucional como, por exemplo, eleição para presidente do STF, onde o mais antigo que ainda não foi presidente o será.

A jurisprudência constitucional também integra o bloco de constitucionalidade para a corrente extensiva.

Ou seja, para a corrente extensiva, bloco de constitucionalidade é a soma de normas materialmente constitucionais que estão fora da constituição formal, mais costumes jurídicos constitucionais, mais jurisprudência constitucional mais a constituição formal.

Já a **corrente restrita ou teoria restritiva** entende o bloco de constitucionalidade de forma restrita. Para essa corrente o bloco de constitucionalidade é apenas a constituição formal, com suas normas expressas ou implícitas. É somente a constituição formal. Equivale o bloco de constitucionalidade ao parâmetro de controle de constitucionalidade.

Diante disso, qual a corrente adotada pelo STF?

Porém, no Brasil, a corrente majoritária é a corrente restritiva. Para o STF, o bloco de constitucionalidade é só a constituição formal, com suas normas expressas ou implícitas mais



os Tratados Internacionais de Direitos Humanos que foram submetidos ao procedimento que dispõe o art. 5º, §3º, CF.

Exemplo: ADI 1588 e ADI 595, que discutiram exatamente acerca do tema bloco de constitucionalidade e qual das correntes adotadas no Brasil. Divergindo dos demais, mas acompanhando o entendimento do professor Bernardo Gonçalves está o Min. Celso de Melo, que também entende que deveria se adotar a ideia da corrente extensiva, englobando não só a constituição formal, mas também as demais leis que são materialmente constitucionais, ainda que estejam fora da constituição.

3. CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES

3.1. QUANTO À ORIGEM

- **Outorgada:** é a Constituição imposta, sem participação popular. É uma usurpação do titular do poder constituinte.
- **Democrática:** é a Constituição popular, pois há participação popular direta (referendo ou plebiscito) ou indireta (representatividade popular). No Brasil, já houve constituições promulgadas (1891, 1934, 1946 e 1988) e outorgadas (1824, 1937, 1967 e 1969).
- **Cesarista (Bonapartista):** há a elaboração unilateral da Constituição, mas ela é submetida à uma ratificação popular, por meio de referendo. O povo não participa da elaboração da Constituição, motivo pelo qual ela não trata dos anseios populares. Obs.: A Constituição de 1937 previa a submissão ao plebiscito, mas isto jamais ocorreu.
- **Pactuada (dualista):** há um pacto, originando-se de duas forças políticas rivais. É o que ocorreu com a burguesia ascendente e a realza descendente. Há basicamente dois titulares do Poder Constituinte.

3.2. QUANTO À FORMA

3.2.1. ESCRITA

Regras sistematizadas em documento escrito. Apresentam-se de duas formas:

- Codificadas: num único texto.
- Legais: esparsas em diversos documentos.

A CF/88 é codificada, mas a EC 45 trouxe uma mitigação a esta classificação, tendo em conta os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum de emenda constitucional.

3.2.2. NÃO ESCRITA (COSTUMEIRA)

Normas constitucionais não são solenemente elaboradas. Ela surge pelos costumes, usos, jurisprudência e leis. Tanto em Constituições escritas como não escritas existem leis que tratam de normas constitucionais, mas nas costumeiras não há procedimento solene de inclusão.

3.3. QUANTO AO MODO DE ELABORAÇÃO

3.3.1. DOGMÁTICAS

São sempre escritas, elaborada pelo órgão constituinte. Traz dogmas. Poderão ser:



- Ortodoxas: uma só ideologia;
- Eclética: soma de diferente ideologia.

3.3.2. HISTÓRICAS

São as não escritas, pois resultam de um lento processo histórico de formação.

3.4. QUANTO AO CONTEÚDO

3.4.1. MATERIAL

Traz assuntos essenciais do Estado.

3.4.2. FORMAL

É composta por todas as normas que a integram.

Para se falar em constituições materiais ou formais, é forçoso que a Constituição seja rígida, pois, do contrário, não haveria como falar em constituição.

3.5. QUANTO À ESTABILIDADE

3.5.1. IMUTÁVEIS

São aquelas que o texto não pode ser alterado. Não existe.

3.5.2. RÍGIDA

Existe um processo especial mais difícil de alteração do que para as demais normas. Garante maior estabilidade ao texto constitucional.

3.5.3. FLEXÍVEL

Possibilidade de alteração pelo mesmo processo das demais leis. Ex.: Inglaterra.

3.5.4. SEMIRRÍGIDA (SEMI-FLEXÍVEL)

Parte da constituição é mais rígida do que outras partes mais flexíveis. Ex.: Constituição de 1824.

Não quer dizer que quanto mais rígida seja a Constituição mais estável ela será. Isso porque, se não puder haver a atualização do texto constitucional, poderá ocorrer o rompimento da Constituição.

A partir da rigidez, há o princípio da supremacia formal da Constituição, que garante a ela uma superioridade frente às demais leis.

Por conta da supremacia formal, haverá o controle de constitucionalidade, o qual é dependente da rigidez constitucional.

- Cláusulas pétreas

As cláusulas pétreas são cláusulas que trazem matérias que não podem ser abolidas por meio de emendas constitucionais. Estão previstas no art. 60, §4º, da CF.

Há um núcleo não suprimível na Constituição, que são essas cláusulas pétreas. A existência de cláusulas pétreas é o que justifica a posição de Alexandre de Moraes, o qual classifica a CF/88 como uma constituição super-rígida.

- Constituições transitoriamente flexíveis

Uadi Lammego Bulos diz ser transitoriamente flexíveis as constituições suscetíveis de reforma pelo mesmo rito das demais leis por um determinado período. Após este período, passam a ser rígidas.



3.6. CRITÉRIO ONTOLÓGICO

Onto = ser, lógica = estudo.

Ontologia é estudar a essência de algo, que visa diferenciar aquele algo de tudo o quanto é mais da natureza, buscando a sua essência, no âmago, no seu ser.

Se eu quero realmente estudar a ontologia das constituições eu preciso não só analisar o texto das constituições, mas também realidade social vivenciada por esse texto.

A classificação ontológica, portanto, é a técnica metodológica de classificação das constituições que visa fazer uma análise do texto da constituição com a realidade social vivenciada pelo texto.

Neste sentido, o critério ontológico, segundo Karl Loewenstein, classifica as constituições segundo a realidade política do respectivo Estado.

Pela classificação de Loewenstein, existem três grandes tipos de constituição: normativa, nominal e semântica:

3.6.1. NORMATIVAS

São aquelas que conseguem regular a vida política de um Estado, pois estão em consonância com a realidade social. Em outras palavras, é aquela em que há uma adequação entre o texto constitucional e a realidade social, traduz os anseios de justiça dos cidadãos. É um alto grau de adequação de realidade social. Ex.: Constituição dos Estados Unidos

3.6.2. NOMINATIVAS

São aquelas que ainda não conseguem efetivar o papel de regular a vida política do Estado. É aquela em que não há uma adequação do texto à realidade social. São prospectivas, voltadas para o futuro. A constituição do Brasil de 1988 ainda é nominal

3.6.3. SEMÂNTICA

é aquela que não tem a finalidade de regular a vida política do Estado. Apenas busca beneficiar o detentor do poder. Ela trai o significado do termo constituição. Constituição significa, desde o constitucionalismo, limitação do poder e a constituição semântica é aquela que ao invés de limitar o poder, legitima o poder autoritário. São constituições ditatoriais, autocráticas. No Brasil, foram as constituições de 1937 (Getúlio Vargas) e as de 1967 e 1969 (Regime Militar).

3.7. QUANTO À EXTENSÃO

3.7.1. ANALÍTICAS

São extensas e versam sobre matérias além da organização básica do Estado.

3.7.2. SINTÉTICAS

São concisas, versando somente sobre princípios e regras gerais básicas de realização e funcionamento do Estado. Ex.: Constituição dos EUA.

3.8. QUANTO À FINALIDADE

3.8.1. GARANTIA

É sintética, pois só quer garantir a limitação do poder estatal. São típicas dos séculos XVIII e XIX e própria dos estados liberais. Aparentemente, não fazem opções de política social ou econômica. São constituições negativas, abstencionistas. São constituições quadro, só traçam molduras mas não interferem, não intervêm na sociedade e nem no Estado. São



constituições que visam garantir direitos frente à possíveis ataques do poder público. O viés é o do passado.

3.8.2. BALANÇO

Faz um balanço quanto ao momento que passa o Estado. Destinada a disciplinar a realidade do Estado. Ex.: antiga União Soviética. Tem como viés o presente. São constituições dos estados socialistas, de cunho Marxista.

3.8.3. DIRIGENTE

É analítica, pois define planos para o Estado. O constituinte dá as regras de como ele vai querer a sociedade futuramente. Caracteriza-se por normas programáticas, principalmente as sociais (Welfare State). São aquelas voltadas para o futuro, que visam alterar a sociedade a partir dela. Típicas dos estados sociais de direito do século XX, do constitucionalismo social. São aquelas que estabelecem uma ordem concreta de valores e uma pauta de vida para o Estado e a sociedade. São constituições que estabelecem uma gama de programaticidade para o Estado e sociedade, com o objetivo conduzir e alterar a realidade social. Daí a ideia de dirigismo constitucional. São comuns em seus textos as normas programáticas, que são aquelas que estabelecem programas, tarefas e fins para o cumprimento pelo Estado e pela sociedade. Ex.: Constituição do Brasil de 1988. Nós temos hoje uma constituição dirigente, mas com um dirigismo muito menos impositivo e mais reflexivo.

3.9. CONSTITUIÇÃO NOMINALISTA

Segundo Alexandre de Moraes, é a Constituição que traz normas passíveis de resolver problemas concretos. Ela diz o problema a ser resolvido diretamente com a aplicação da norma constitucional.

O autor diz que neste tipo de Constituição só se admite interpretação gramatical e literal.

3.10. CONSTITUIÇÕES REDUZIDAS E VARIADAS

Segundo Pinto Ferreira, as constituições podem ser:

3.10.1. REDUZIDAS

A constituição traz normas em um só código. São unitárias, conforme diz Uadi Lammego Bulos.

3.10.2. VARIADAS

As normas constitucionais estão previstas em textos esparsos. São pluritextuais.

3.11. CONSTITUIÇÕES LIBERAIS E SOCIAIS

Segundo André Ramos Tavares, as constituições podem ser:

3.11.1. LIBERAIS

A constituição traz ideais do liberalismo, de não intervenção do Estado. A constituição é negativa.

3.11.2. SOCIAIS

A constituição exige atuação estatal, assegurando igualdade material. A constituição é positiva.



3.12. CONSTITUIÇÃO EXPANSIVA

De acordo com Raul Machado Horta, a constituição expansiva aborda novos temas não presentes nas constituições anteriores. Além disso, os demais temas passam a ter tratamento mais amplo.

3.13. HETEROCONSTITUIÇÕES

São constituições decretadas fora do Estado, por um ou por outro Estado, ou ainda por um organismo internacional. Ex.: Canadá e Nova Zelândia tiveram suas primeiras constituições decretadas pelo Parlamento britânico.

3.14. CONSTITUIÇÃO PRINCIPIOLÓGICA E PRECEITUAL

Segundo Diogo Figueiredo, as constituições podem ser:

3.14.1. PRINCIPIOLÓGICA

Predominância de princípios.

3.14.2. PRECEITUAL

Predominância de regras.

3.15. CONSTITUIÇÃO PLÁSTICA

A constituição plástica é definida de diferentes formas por Pinto Ferreira e Raul Machado Horta:

3.15.1. CONCEITO DE PINTO FERREIRA

É sinônimo de constituição flexível.

3.15.2. CONCEITO DE RAUL MACHADO HORTA

Há uma grande análise de um conteúdo aberto. Estas normas de conteúdo aberto dão maior elasticidade ao legislador que passa a ter ampla margem de atuação.

3.16. CONSTITUIÇÃO SIMBÓLICA

Segundo Marcelo Neves, a Constituição simbólica (também chamada de legislação simbólica) se define como aquela cujo objetivo é eminentemente político.

Trata-se, portanto, de um instrumento do Legislador para provocar determinados efeitos sociais. Desta feita, a Constituição simbólica pode servir para:

- fortalecer a confiança do cidadão no legislador, fazendo-lhe crer no compromisso deste último com os interesses sociais – é o que se chama de Constituição-Álibi (Ex.: criação de leis penais que geram o chamado direito penal simbólico);
- confirmar determinados valores sociais;
- solucionar um impasse político por meio daquilo o que doutrinariamente se denomina de compromisso dilatatório, isto é, a postergação de uma efetiva resolução do conflito por meio de expedientes normativos – é o que ocorre com algumas normas constitucionais de eficácia limitada, cuja complementação depende de uma lei posterior.

Para o professor Marcelo Neves, existem três tipos de legislação simbólica:



3.16.1. FORMA DO COMPROMISSO DILATÓRIO

Se dá na situação de conflito social, em que surge uma legislação que sabidamente não resolve o conflito, mas apenas adia a solução do conflito para um momento posterior. Ocorre em decorrência de circunstâncias políticas nas quais aquela sociedade não está pronta para resolver o conflito, daí surge uma legislação que apenas adia a solução do conflito para momento posterior, para quando a sociedade estiver pronta para resolver aquele conflito, visto que no atual momento não está, mas a legislação tem que surgir. Ex.: Legislação das empregadas domésticas na Noruega, na década de 40 do século passado, que agradou eleitores socialista e liberais. A referida legislação não previa sanções, cláusulas sancionatórias para aqueles que descumprissem a norma.

3.16.2. CONFIRMAÇÃO DE VALORES SOCIAIS DE UM GRUPO EM DETRIMENTO DE OUTRO

Ocorre quando a legislação não vem para ter eficácia, não vem para resolver um problema jurídico-normativo social, apenas vem para confirmar os valores sociais de um grupo em detrimento de outro; para dizer que aquele grupo que está produzindo a legislação é mais virtuoso, é melhor que outro grupo. Ex.: Lei Seca nos EUA, na década de 30 do Século XX.

3.16.3. LEGISLAÇÃO ÁLIBI

É aquela legislação produzida pelo Estado com a finalidade de acalmar a sociedade, mas que é sabidamente ineficaz. A legislação vem como um álibi, diante de um público aflito, de uma comoção social, é produzida uma legislação que sabidamente não vai resolver o problema. O Estado responde para a sociedade, embora o próprio Estado saiba que aquela legislação não vai resolver o problema. Ex.: Lei dos crimes hediondos (Lei 8.072/90).

4. CONSTITUIÇÕES DO BRASIL

4.1. CONSTITUIÇÃO DE 1824

- outorgada por Dom Pedro I;
- forte influência pelo liberalismo clássico (direitos individuais de 1ª geração);
- adotou a separação de poderes, mas foi além, por conta do Poder Moderador;
- classificada como rígida;
- Estado Unitário, dividido em províncias;
- forma de governo era a monarquia hereditária;
- eleições indiretas e voto censitário (pela condição financeira);
- eleições dos deputados, mas os senadores eram vitalícios, nomeados pelo Imperador;
- foi a Constituição mais longa, acabando apenas em 1889;
- classificada também como nominativa, pois não regulou a vida política do Estado.



4.2. CONSTITUIÇÃO DE 1891

- Constituição republicana;
- províncias passaram a ser Estados, integrantes de uma federação, vindo a ser denominado de Estados Unidos do Brasil;
- foi realizada uma assembleia constituinte para promulgar a constituição;
- seu principal mentor foi Ruy Barbosa, fortemente influenciado pelos norte-americanos;
- forma federativa de Estado e forma republicana de governo;
- regime era representativo, com eleições diretas e prazos certos de mandato;
- sistema de governo era o presidencialista;
- poder moderador foi abolido;
- acréscimo de garantias, mas a principal foi o *habeas corpus*;
- rígida e nominativa, pois suas disposições não encontraram a realidade social.

4.3. CONSTITUIÇÃO DE 1934

- era democrática, fruto da revolução de 1930;
- passou a enumerar direitos fundamentais sociais – grande marca de Getúlio Vargas;
- influenciada pela Constituição de Weimar de 1919;
- estruturalmente, em relação à Constituição de 1891, não houve grandes mudanças, pois continuou sendo república, federação, divisão de poderes, presidencialismo e regime representativo.

4.4. CONSTITUIÇÃO DE 1937

- foi outorgada, sendo denominada de Constituição Polaca;
- instauração do Estado Novo;
- a carta outorgada por Getúlio era de inspiração fascista e autoritário;
- a sua inspiração seria a Constituição Polonesa de 1935;
- havia pena de morte para crimes políticos;
- censura prévia da imprensa;
- formalmente existia legislativo e judiciário, mas materialmente não;
- presidente legislava por decretos-leis;
- previa a necessidade de ser submetida à apreciação popular denominado de plebiscito, o qual jamais aconteceu.

4.5. CONSTITUIÇÃO DE 1946

- fim da 2ª guerra mundial (em 1945);
- fim do estado novo;
- redemocratização;
- foi promulgada a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil;
- forma de estado era a federação, com autonomia dos Estados;
- eleições diretas;
- instituição do princípio da inafastabilidade da jurisdição, proibição da pena de morte, banimento e confisco;
- direitos dos trabalhadores passaram a ser constitucionalizados, com acréscimo do direito de greve;
- partidos políticos passaram a ser trazidos pela constituição, com o princípio da liberdade da criação e organização partidária;



- em 1961, uma emenda instaurou o parlamentarismo como sistema de governo com objetivo de reduzir os poderes de João Goulart, que tinha intenções comunistas;
- o parlamentarismo foi rejeitado pelo plebiscito, fixando o presidencialismo, o que ocasionou o golpe militar, encerrando a democracia.

4.6. CONSTITUIÇÃO DE 1967

- produto dos militares que outorgaram a constituição;
- houve uma preocupação com aquilo que se convencionou a chamar de segurança nacional;
- tendência de centralização político-administrativa na União, e de ampliação dos poderes do Presidente da República;
- a Constituição limitou os direitos de propriedade, passando a prever a desapropriação para fins de reforma agrária com indenização por meio de títulos públicos.

4.7. CONSTITUIÇÃO DE 1969

- instituída por meio da Emenda 1, mas era uma nova constituição;
- foi uma constituição outorgada;
- passou a ser a Constituição da República Federativa do Brasil;
- trouxe hipóteses de suspensões de direitos individuais;
- era marcadamente autoritária;

4.8. CONSTITUIÇÃO DE 1988

Em 1985, a EC 86 modificou a história do país, pois convocou a Assembleia Nacional Constituinte, cujo trabalho resultou na Constituição de 1988. A instauração dessa assembleia ocorreu em fevereiro de 1987, finalizando os seus trabalhos em 5 de outubro de 1988, com a promulgação da Constituição.

Trata-se de uma social democracia. A CF/88 se caracteriza pela imensa carga de obrigações do Estado, passíveis de serem exigidas pela população (direitos subjetivos). Ficou conhecida como Carta Cidadã, pois continha direitos de 1ª, 2ª e 3ª geração.

A CF/88 fortaleceu instituições democráticas com destaque ao Ministério Público. Tornou mais abrangente o controle de constitucionalidade, aumentando a importância do controle abstrato, o que fez surgir as ações de ADPF e ADO. Houve ainda o alargamento da legitimidade ativa da propositura das ações, sendo o fim do monopólio da legitimidade exclusiva do PGR.

Houve a extinção dos territórios, além de prever uma maior autonomia dos municípios. A administração pública passou a ter um rígido regramento.

Também houve o fortalecimento do Poder Judiciário e do Poder Legislativo.

5. CLASSIFICAÇÃO E ESTRUTURA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988

A CF/88 é classificada como sendo:

- Quanto a forma: Escrita e Codificada
- Quanto a origem: Democrática
- Quanto ao modo de elaboração: Dogmática
- Quanto a ideologia: eclética (ela é aberta, plural)



- Quanto a estabilidade: Rígida
- Quanto ao conteúdo: Formal
- Quanto a extensão: Analítica
- Quanto a finalidade: Dirigente
- Quanto a ontologia: Normativa (ou nominativa, a depender do autor)
- Quanto a sistemática: Principiológica
- Quanto a unidade documental: orgânica
- Quanto a origem: Promulgada

Também pode ser classificada como sendo social, expansiva e dúctil.

A CF/88 tem como estrutura:

- Preâmbulo;
- Parte dogmática (corpo permanente) e;
- Atos das disposições transitórias (ADCT).

5.1. PREÂMBULO

A Constituição brasileira traz a seguinte redação:

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

O **preâmbulo** pode ser definido como uma carta de intenções ou uma proclamação de princípios ou um diploma de origem e legitimidade da constituição, que indica a ruptura com o passado (com uma ordem anterior) e o estabelecimento de uma nova ordem constitucional para o Estado e a sociedade. Esse conceito de preâmbulo é conhecido como a definição tríade.

Em termos de história constitucional brasileira, todas as constituições continham preâmbulo (1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969, 1988).

Discussão sobre a relevância jurídica do preâmbulo:

- **Teoria da irrelevância jurídica:** o preâmbulo não é dotado de força normativa. Para essa corrente, o preâmbulo é mera declaração política, de cunho simbólico, sendo irrelevante juridicamente. Não é dotado de força normativa, não sendo considerado norma constitucional.
- **Teoria da plena eficácia jurídica ou relevância jurídica direta/imediata:** consiste na ideia de que o preâmbulo é dotado de força normativa constitucional, ou seja, teria natureza de norma constitucional como qualquer outra da constituição. Essa corrente surge de uma decisão do Conselho Constitucional da França de 1971, que reconheceu a força normativa do preâmbulo nas constituições.
- **Teoria da relevância indireta/mediata:** não reconhece o preâmbulo como uma norma constitucional vinculante, mas reconhece relevância jurídica ao preâmbulo. Essa corrente entende que o preâmbulo é um vetor de cunho hermenêutico, ou seja, não é uma norma jurídica propriamente dita, como também não pode ser considerado como sendo somente uma declaração



política de cunho simbólico. Para a corrente da relevância jurídica, o preâmbulo é um elemento que auxilia na interpretação e aplicação das normas constitucionais propriamente ditas.

Para o Professor Bernardo Gonçalves, o preâmbulo possui relevância jurídica direta/imediata, defendendo, assim, a força normativa do preâmbulo. No entanto, a corrente majoritária no STF é a corrente da irrelevância jurídica, como se observa da decisão da ADI 2076/AC. Nesse caso concreto, foi ajuizada a ADI por omissão (hoje conhecida como ADO), que questionava a omissão da constituição do Estado do Acre de não ter colocado, no preâmbulo da Constituição desse Estado, o termo “sob a proteção de Deus”. O STF, então, decidiu que o nosso preâmbulo é irrelevante juridicamente, sendo uma mera declaração política, de cunho simbólico, não caracterizando norma de reprodução obrigatória.

Porém, apesar de ser essa a posição majoritária, existe uma decisão mais recente do STF, na ADI 2649 em que a Min. Carmem Lúcia entende o preâmbulo com base na tese da relevância jurídica indireta/mediata. Ou seja, nessa decisão o STF reconhece que o preâmbulo é um vetor de cunho hermenêutico, e que pode ser usado para interpretar e aplicar normas que estão no decorrer da Constituição.

Assim, é possível concluir que:

- STF: o preâmbulo não se situa no âmbito do direito, fazendo apenas parte da política, sem possuir valor normativo. O Supremo adotou a teoria da irrelevância jurídica do preâmbulo como tese principal, mas já adotou a teoria da relevância jurídica indireta/mediata.
- Doutrina majoritária: o preâmbulo tem função interpretativa, auxiliando na interpretação de valores primordiais que orientaram o constituinte na sua elaboração. A doutrina adotou a teoria da relevância indireta do preâmbulo.

5.2. PARTE DOGMÁTICA

A parte dogmática constitui o corpo principal e permanente da Constituição. Vai do artigo 1º ao 250, sendo composto por diversos títulos e capítulos importantes, como, por exemplo, os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, envolvendo os Poderes, a defesa do Estado e de suas instituições democráticas, ordem tributária, ordem social e econômica, dentre outros, que serão objeto de estudo durante todo o curso.

5.3. ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT)

O ADCT reúne dois grupos distintos de preceitos:

- Regras necessárias para assegurar um regime de transição entre as normas do direito anterior e o regime constitucional vigente (ex.: art. 16 do ADCT – Presidente da República nomearia governador e vice-governador do Distrito Federal até que houvesse as eleições diretas);
- Estabelece regras não relacionadas a esta transição, mas com eficácia temporária, capaz de tornar a norma exaurida após a sua regulação (ex.: art. 3º do ADCT – que dizia ser possível, após 5 anos da promulgação da Constituição, que houvesse a revisão constitucional).

Em ambos os casos, a característica própria de uma norma do ADCT é a sua eficácia jurídica até que o momento disposto para nela regular ocorra.



Os dispositivos do ADCT são normas constitucionais, bem como parâmetro para fins de controle de constitucionalidade e que só podem ser alteradas formalmente por emendas constitucionais ou Tratados Internacionais de Direitos Humanos que passarem pelo mesmo procedimento que as emendas constitucionais. As disposições transitórias do ADCT são consideradas normas constitucionais tanto quanto a do corpo dogmático da Constituição.

Portanto, existem as disposições transitórias que serão normas de eficácia exaurida, que já cumpriram sua função no ordenamento e não mais vinculam. Mas as que ainda estão no ordenamento pátrio, regulando relações entre passado, presente e futuro, vigorando e vinculando condutas, são tão normas constitucionais quanto aquelas presentes no corpo dogmático entre os artigos 1º e 250 da Constituição.

5.4. ELEMENTOS DA CONSTITUIÇÃO

José Affonso da Silva divide os elementos da Constituição em:

- Elementos orgânicos: compostos por normas que regulam a estrutura do Estado;
- Elementos limitativos: consagram direitos e garantias fundamentais;
- Elementos sócio-ideológicos: revelam o compromisso da Constituição com o povo;
- Elementos de estabilização constitucional: são normas que objetivam solucionar conflitos constitucionais, defendendo a Constituição e as instituições democráticas nela consagradas (ex.: intervenção);
- Elementos formais de aplicabilidade: são normas que estabelecem regras de aplicação das normas constitucionais. Dispositivos consagram cláusulas que regulam como uma norma vai entrar em vigor (ex.: art. 5º, §1º, CF).

5.5. VACATIO CONSTITUTIONIS

Normalmente, a constituição não traz uma cláusula que estabelece quando ela entra em vigor. Portanto, em regra, a constituição promulgada entra em vigor imediatamente.

Como o poder constituinte originário é ilimitado, poderá trazer o momento em que a Constituição entrará em vigor. Neste caso, o período entre a publicação e o início da vigência da Constituição é denominado *vacatio constitutionis*.

A CF/88 não adotou a *vacatio constitutionis*, motivo pelo qual entrou em vigor imediatamente.

Questões

1) (TJBA/2019) — A concepção que compreende o texto da Constituição como não acabado nem findo, mas como um conjunto de materiais de construção a partir dos quais a política constitucional viabiliza a realização de princípios e valores da vida comunitária de uma sociedade plural, caracteriza o conceito de Constituição

- a) em branco.
- b) semântica.
- c) simbólica.
- d) dúctil.
- e) dirigente.

2) (TJ SC/2019) — A respeito das constituições classificadas como semânticas, assinale a opção correta.



- a) São aquelas que se estruturam a partir da generalização congruente de expectativas de comportamento.
- b) São aquelas cujas normas dominam o processo político; e nelas ocorrem adaptação e submissão do poder político à constituição escrita.
- c) Funcionam como pressupostos da autonomia do direito; e nelas a normatividade serve essencialmente à formação da constituição como instância reflexiva do sistema jurídico.
- d) São aquelas cujas normas são instrumentos para a estabilização e perpetuação do controle do poder político pelos detentores do poder fático.

3) (TJ CE/2018) — No sentido moderno, o conceito de Constituição articula fundamentalmente a limitação de poder do Estado e a garantia de direitos dos cidadãos em textos dotados de supremacia que diferenciam normas de caráter formal das de caráter material. O conceito contemporâneo de Constituição, por sua vez, contempla aspectos diversos àqueles. Com relação a esses aspectos, assinale a opção correta.

- a) Constituição compromissória é o pacto político-jurídico celebrado pelo poder constituinte que não incorpora limites ao poder de reforma.
- b) Constituição plástica é aquela definida pelos fatores reais presentes nas disputas de poder na sociedade.
- c) Constituição unitextual consagra, em um único documento, emendas à Constituição, embora admita a existência de leis com valor normativo igual ao da Constituição.
- d) Constituição subconstitucional admite a constitucionalização de temas excessivos e o alçamento de detalhes e interesses momentâneos ao patamar constitucional.
- e) Constituição processual é aquela que define um programa e estabelece parâmetros para gerir a atividade estatal.

Comentários

1. Gabarito: D

Correta definição de constituição dútil, suave ou maleável, desenvolvida pelo italiano Gustavo Zagrebelsky, para quem nas sociedades plurais, dotadas de um certo grau de relativismo e de diversidade de interesses, ideologias e aspirações, a meta de uma Constituição deve ser o de assegurar as condições possíveis de uma vida comunitária, e o autor utiliza a metáfora de um conjunto de materiais de construção, sendo a Constituição o pilar ou o fundamento básico de partida para a construção do edifício concreto, levantado a partir da combinação desses materiais, feita pela política (NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 92-93)

Demais incorretas:

- a) em branco.

São Cartas que não contém limitações expressas ao Poder Constituinte Derivado Reformador. Eventuais reformas ficam sujeitas à discricionariedade do poder constituinte de reforma, que recebem "carta branca" para tanto.

- b) semântica.

Constituições semânticas: objetivam unicamente justificar e manter o poder dominante em um determinado momento político, conferindo legitimidade formal ao grupo ou indivíduo que assumiu o controle do Estado, normalmente de forma não democrática. Serve para ratificar a situação existente, em benefício dos comandantes de ocasião.

- c) simbólica.

Classificação de Marcelo Neves, para quem a Constituição simbólica é que possui predomínio de um aspecto político-ideológico, em detrimento da função jurídico-instrumental, de caráter normativo-jurídico. Segundo Daniel Sarmiento e Cláudio Pereira Neto,



"Trata-se de Constituição que não corresponde minimamente à realidade, não logrando subordinar as relações políticas e sociais subjacentes. Ela não é tomada como norma jurídica verdadeira, não gerando, na sociedade, expectativas de que seja cumprida. Neste ponto, ela se assemelha à categoria da Constituição nominal, de Loewenstein. Porém, a apreciação de Marcelo Neves do fenômeno é mais negativa do que a do autor alemão. Para Neves, as constituições simbólicas tendem a servir como álibi para manutenção do status quo." (Sarmiento, Daniel e Souza Neto, Cláudio Pereira de. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho, Ed. Fórum 2014, 2ª ed, Locais do Kindle 1214-1215)

e) dirigente.

Também chamadas de programáticas, diretivas ou compromissórias, normalmente de texto extenso (analíticas), além de estabelecer as garantias negativas ou fundamentais frente ao Estado (direitos de 1ª dimensão), preocupam-se em fixar programas e diretrizes para a atuação dos órgãos e entidades estatais, a fim de reduzir a desigualdade material entre os indivíduos, por meio de políticas de cunho social (direitos de 2ª dimensão).

Tais normas constitucionais constituem as chamadas normas programáticas, aquelas em que a Constituição estabelece os princípios e diretrizes a serem cumpridos futuramente pelos órgãos estatais (legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos), visando à realização dos fins sociais do Estado. Ou seja, que estabelecem programas de ação futura, especialmente na área social, a serem perseguidos pelos órgãos, entidades e agentes do Estado, ou bloco normativo-programático.

2. Gabarito: D

Segundo Karl Loewenstein as Constituições semânticas objetivam unicamente justificar e manter o poder dominante em um determinado momento político, conferindo legitimidade formal ao grupo ou indivíduo que assumiu o controle do Estado, normalmente de forma não democrática. Serve para ratificar a situação existente, em benefício dos comandantes de ocasião.

Loewenstein oferece ainda duas outras classificações:

Constituições normativas: são aquelas que mantêm estreita sintonia com a realidade social e política, e que efetivamente regulam a atividade estatal. As disposições constitucionais são regamente obedecidas pelos agentes do poder, que se submetem às limitações e diretrizes impostas pela ordem constitucional.

Constituições nominativas: também denominadas nominalistas ou nominais, são aquelas constituições que, apesar de terem sido elaboradas com a finalidade de disciplinar os poderes estatais, estabelecendo limites à atuação do Estado, não conseguem exercer esse papel por total discrepância entre a realidade social e política que regulam e o previsto no texto constitucional. É ignorada pelo poder dominante. Esta concepção lembra muito a "mera folha de papel" de que falava Ferdinand Lassalle. Mas para cada conceito, uma expressão própria; guarde isso pois o examinador não irá além dos conceitos gerais, nesses tópicos.

Demais alternativas incorretas:

a) São aquelas que se estruturam a partir da generalização congruente de expectativas de comportamento.

Definição errada.

b) São aquelas cujas normas dominam o processo político; e nelas ocorrem adaptação e submissão do poder político à constituição escrita.

Essas seriam as Constituições normativas.

c) Funcionam como pressupostos da autonomia do direito; e nelas a normatividade serve essencialmente à formação da constituição como instância reflexiva do sistema jurídico.

Definição incorreta.

3. Gabarito: D



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



Hild Krüger afirma que as constituições devem ser concisas, e trazer somente aquilo que interessa à organização do Estado e aos direitos dos indivíduos. Assevera que o excesso de temas constitucionalizados transformam os textos em Subconstituições.

As Subconstituições englobam aquelas normas que, mesmo inseridas no texto constitucional, encontram-se limitadas nos seus objetivos, vinculando-se a preocupações momentâneas, interesses esporádicos e próprios do tempo em que foram elaboradas. Não servem para o futuro, pois já nascem divorciadas das características de estabilidade perenidade que devem encampar a elaboração desses documentos.

Demais alternativas incorretas:

a) Constituição compromissória é o pacto político-jurídico celebrado pelo poder constituinte que não incorpora limites ao poder de reforma.

As Constituições dirigentes, chamadas de programáticas, diretivas ou compromissórias, normalmente de texto extenso (analíticas), além de estabelecer as garantias negativas ou fundamentais frente ao Estado (direitos de 1ª dimensão), preocupam-se em fixar programas e diretrizes para a atuação dos órgãos e entidades estatais, a fim de reduzir a desigualdade material entre os indivíduos, por meio de políticas de cunho social (direitos de 2ª dimensão).

Tais normas constitucionais constituem as chamadas normas programáticas, aquelas em que a Constituição estabelece os princípios e diretrizes a serem cumpridos futuramente pelos órgãos estatais (legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos), visando à realização dos fins sociais do Estado. Ou seja, que estabelecem programas de ação futura, especialmente na área social, a serem perseguidos pelos órgãos, entidades e agentes do Estado, ou bloco normativo-programático.

b) Constituição plástica é aquela definida pelos fatores reais presentes nas disputas de poder na sociedade.

Constituições plásticas (denominação de Pinto Ferreira) são as que permitem alteração integral de seu texto por processo legislativo comum, utilizado para elaboração das leis infraconstitucionais, ordinárias. São também chamadas de flexíveis.

São flexíveis, via de regra, as Constituições não escritas ou costumeiras, não obstante possam existir dentre as escritas, consoante Celso Ribeiro Bastos.

Isso não significa que no sistema flexível as normas constitucionais são alteradas com maior frequência. A simples flexibilidade formal não implica em instabilidade. Devem ser consideradas as tradições culturais e a solidez das instituições políticas, como se observa, por exemplo com a Constituição Inglesa, não-escrita, flexível e de notável longevidade.

Nesse sentido, segundo James Bryce, estudioso das Constituições Italiana e Inglesa, "é um mérito e uma marca distintiva das Constituições flexíveis a sua elasticidade, que lhes permite a adaptação a diferentes circunstâncias". Em outros termos, "a Constituição verga mas não quebra". (BRYCE, James, *Constituciones Flexibles y Constituciones rígidas*, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1988, p. 31-36).

c) Constituição unitextual consagra, em um único documento, emendas à Constituição, embora admita a existência de leis com valor normativo igual ao da Constituição.

A constituição unitextual é característica das constituições rígidas, cujo processo de alteração, mais dificultoso, não se assemelha ao das leis ordinárias. É condensada em um único texto constitucional, tal qual a Constituição de 1988.

e) Constituição processual é aquela que define um programa e estabelece parâmetros para gerir a atividade estatal.

Errado, pois para Willis Santiago Guerra Filho e Henrique Garbellini Carnio,

A Constituição em sentido processual corresponderia à dinâmica jurídica, para recorrer a uma categoria kelseniana, introduzida na Teoria Pura do Direito, como a parte da teoria do direito que tem por objeto o processo do direito, na qual se estuda o direito em movimento, sendo produzido e aplicado, através de condutas



que, obedecendo normas, resultam em outras normas. Daí hoje um modelo mais sofisticado de figuração da ordem jurídica, há de distinguir três níveis, a saber, o dos princípios, o das regras e o dos procedimentos. É neste último nível em que os valores, consagrados positivamente ao nível dos princípios, e qualificadores, ainda que em graus diversos de generalidade e abstração, dos fatos previstos normativamente pelas regras, resultam vertidos em novas normas, aptas a incidirem em determinadas situações concretas, conformando-as juridicamente. O aspecto processual da Constituição, portanto, está para a Constituição em sentido substancial, recorrendo a uma maneira metafórica de se expressar, assim como a fisiologia de um corpo está para a sua anatomia". (GUERRA FILHO, Willis Santiago e GARBELLINI CARNIO, Henrique, Teoria Processual da Constituição. Tomo Direito Administrativo e Constitucional, 1ª edição, abril de 2017. Enciclopédia Jurídica da PUC-SP).



CAPÍTULO 4 – PODER CONSTITUINTE

É aquele poder ao qual incumbe elaborar (criar), reformar (alterar) ou complementar uma constituição. O poder constituinte pode ser classificado quanto à dimensão em:

1. MATERIAL

É o conjunto de forças político-sociais que vão apresentar uma nova ideia de direito para o Estado e para a sociedade. Rompe com o *status quo* para estabelecer uma nova ordem. A ruptura deve ocorrer, e será por revolução (de baixo para cima), por golpe (de cima para baixo) ou através de um consenso jurídico-político.

2. FORMAL

É aquele grupo encarregado de formalizar a ideia de direito apresentada pelo poder constituinte material, ou seja, é o grupo encarregado de redigir o texto da nova constituição.

Existem três tipos de poder constituinte:

- poder constituinte originário: visa elaborar a constituição;
- poder constituinte derivado reformador: visa reformar a constituição;
- poder constituinte decorrente: visa complementar a constituição.

A teoria do Poder Constituinte foi esboçada pelo abade francês Emmanuel Sieyès (“O que é o Terceiro Estado”). Ele faz uma distinção entre poder constituinte e poderes constituídos. O primeiro é o que cria a Constituição, enquanto os segundos resultam da criação da Constituição. Este é o ponto fundamental.

O titular do poder constituinte para Sieyès era a nação, mas atualmente a doutrina entende que o titular é o povo, ainda que o poder constituinte seja usurpado.

O poder constituinte originário se manifesta na criação de um novo estado ou na refundação de um estado, com a substituição de uma Constituição por outra. O primeiro é o poder constituinte histórico, enquanto o segundo é o poder constituinte revolucionário, ainda que se dê num período de normalidade institucional.

Se o exercício do poder constituinte é legítimo, então significa dizer que foi democrático. Por outro lado, se o poder constituinte foi usurpado, então o poder constituinte foi exercido de forma autocrática, sendo uma constituição outorgada.

3. PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO

3.1. CONCEITO

Tem sua origem no movimento do constitucionalismo do século XVIII, pois é neste momento que se inicia a era das constituições escritas. É imprescindível a existência de um poder encarregado de elaborar as constituições. Antes do século XVIII, a constituição era o modo de ser de uma comunidade, ela não era o ato constitutivo da comunidade, um documento escrito. É justamente no momento em que surgem as constituições escritas que se fará necessário um poder encarregado de criá-las.

O autor da teoria da constituição originária é o francês Emmanuel Joseph Sieyès, que escreveu o livro “O que é o terceiro estado?”, lançando as bases da ideia de um poder constituinte. O terceiro estado é o povo, e primeiro e segundo estados eram a nobreza e o clero. Passou-se a enxergar o povo, a se importar com ele, a fim de garantir o mínimo de sobrevivência. Com o povo participando, a França iria se constituir através de uma Constituição.



O poder constituinte originário é o que elabora a Constituição do Estado, sendo possível identificar dois momentos de manifestação dele:

- momento material do poder constituinte originário: é a decisão política de criação de um novo Estado. Isto quem vai dizer é Carl Schmitt.
- momento formal do poder constituinte originário: é o momento em que há efetivamente a elaboração da Constituição, dando a ideia do direito que surgiu. Trata-se da formalização do momento material.

Neste sentido podemos dizer que o poder constituinte originário é um poder extraordinário, que surge em um momento extraordinário, visando desconstituir uma ordem e a constituir uma nova ordem para o Estado e para a sociedade. Assim, ele é ao mesmo tempo desconstitutivo e constitutivo, despositivo e positivo.

3.2. CARACTERÍSTICAS

As características do poder constituinte originário são:

- **POLÍTICO**: é um poder de fato, não sendo um poder jurídico, pois não se baseia numa ordem jurídica. Pelo contrário, faz nascer a ordem jurídica.
- **INICIAL**: dá início ao Estado, não tendo ele como referência. Ele é sempre uma ruptura jurídico-política que apresenta um novo Estado e uma nova sociedade. É sempre um “começar de novo”. Para a teoria constitucional, a constituição cria o Estado, ainda que o estado exista historicamente. Demarca a ruptura com o passado e o estabelecimento de um novo Estado, de uma nova sociedade a partir da nova constituição.
- **INCONDICIONADO**: não guarda condições ou termos pré-fixados procedimentalmente para a elaboração da nova constituição. Ou seja, em regra, quem define os procedimentos para a elaboração da constituição é o próprio Poder Constituinte.
- **PERMANENTE**: o poder constituinte originário não se esgota, podendo se manifestar a qualquer tempo, quando manifestado pelo seu titular (o povo). Mesmo após a elaboração da constituição, o Poder Constituinte continua vivo, ainda que em estado de latência (ainda que em hibernação), pois está alocado no povo, que é o seu titular. Ex.: Copa das Confederações em 2013 (movimentação nas ruas, PEC do MP, quase houve uma ruptura).

Obs.: Titular do poder constituinte é o POVO e é PERMANENTE $\neq$ **Agente** do poder constituinte é o GRUPO encarregado de redigir a constituição e NÃO É PERMANENTE (tão logo a constituição seja feita, ao finalizar seu trabalho, ele se esvai).

Titular – poder constituinte material

Agente – poder constituinte formal

- **ILIMITADO**: aqui há uma divergência doutrinária. Em provas objetivas marcar como ilimitado. Contudo, é preciso saber que este poder é ilimitado/não guarda limites do ponto de vista do direito positivo anterior. Vai estabelecer um novo direito positivo. Este é o entendimento adotado pela **corrente positivista**, que entende que se trata de um poder de fato, que ele é ilimitado quanto ao direito positivo anterior. Por sua vez, a **corrente jusnaturalista** assevera haver perigo se considerar essa ausência de limites, na verdade, ele é limitado por cânones/vetores do direito natural, como vida, liberdade, igualdade, dignidade. Neste embate, prepondera a corrente positivista. A **corrente sociológica**, que é a mais moderna, entende que o Poder Constituinte Originário é ilimitado quanto ao direito positivo anterior, mas não é absoluto, uma vez que guarda limites internos na própria sociedade que o fez emergir (no movimento revolucionário o



que o fez eclodir ou na própria cultura daquele povo, naquele determinado momento).

Ex.: (i) Constituição Russa de 1918 – limite interno – revolução socialista – o poder constituinte é limitado pela própria sociedade, pela cultura que vigora naquele momento.

(ii) Constituição Polaca de 1937 (Getúlio Vargas) – constituição autocrática, ditatorial, que não presava pelas liberdades.

Segundo Canotilho, existem ainda limites externos em um mundo globalizado, diante do transconstitucionalismo, em princípios de direito internacional, como: princípio da não intervenção, da independência dos povos e da prevalência dos direitos humanos.

- **AUTÔNOMO:** significa que só a ele cabe fixar as bases da nova constituição.

4. PODER CONSTITUINTE DERIVADO

4.1. CONCEITO

O poder constituinte derivado pode modificar a Constituição, podendo também criar as constituições estaduais. No primeiro caso, o poder constituinte derivado é o reformador e o segundo é o poder constituinte derivado decorrente.

Aspectos comuns:

- São poderes de segundo grau;
- São poderes constituídos;
- São sempre poderes limitados/condicionados pelo Poder Originário;

4.2. ESPÉCIES

a) Poder Constituinte Derivado Reformador

É o poder constituinte que reforma a constituição federal por meio de

- Emendas constitucionais (rito do art. 60 da CF/88): dizem respeito a reformas pontuais, por temas.
- Revisão constitucional (rito do art. 3º do ADCT): é uma reforma geral, global, de uma vez só se reforma todo o texto

Este poder é limitado pelo texto constitucional, de forma que a doutrina enumera as espécies de limitações do poder constituinte derivado reformador:

4.2.1. REVISÃO – ART. 3º, ADCT

Limites:

- Temporais: após 5 anos da promulgação da constituição (5.10.1993).
- Formais: a revisão será realizada em sessão unicameral.
- Quórum: maioria absoluta.

Obs. 1: A revisão constitucional já foi realizada, entre 01/03/1994 a 07/06/1994. Nessa oportunidade, foram aprovadas apenas seis emendas. Acabou sendo fracassada pelo escândalo nos anos do orçamento.

Obs. 2: É possível, com base no atual texto da constituição, estabelecer uma nova revisão constitucional? Óbvio que não, porque o texto constitucional é muito claro, a revisão será realizada após 5 anos da promulgação da constituição, em sessão unicameral, com quórum de maioria absoluta.

Obs. 3: É possível alterar o texto da constituição via emenda e estabelecer uma nova revisão? Uma primeira corrente afirma que é possível e estabelece uma nova revisão. Já a



segunda corrente entende que não, porque a vontade originária do Poder Constituinte Originário era só uma revisão, somente uma reforma global. Para esta corrente, a emenda a constituição é para alterar a Constituição, mas não para alterar o processo de reforma. A emenda constitucional já é reforma (como é que a reforma altera a reforma?).

4.2.2. EMENDAS – ART. 60, CF

- **Formais:** art. 60, incisos I, II e III, CF- Trata-se daquele que tem legitimidade para apresentar Proposta de Emenda Constitucional.

Obs.: O povo tem legitimidade para apresentar PEC? José Afonso da Silva defende que sim, em razão de uma interpretação sistemática da constituição (art. 1º, parágrafo único + art. 14 + art. 61, §2º). No entanto, nas provas objetivas prevalece a interpretação literal, que aduz que só tem legitimidade para apresentar a PEC aqueles previstos no art. 60, I, II e III, CF.

O parágrafo 5º do art. 60 da Constituição também é um limite formal, pois a forma pela qual uma PEC rejeitada ou prejudicada pode ser reapresentada, segundo o artigo mencionado, a proposta de emenda constitucional prejudicada ou rejeitada só pode ser apresentada novamente na próxima sessão legislativa, não podendo ser na mesma sessão legislativa. Além disso, é necessário esclarecer que por “sessão legislativa” deve se entender “ano legislativo”, é diferente do ano do calendário gregoriano. O ano legislativo começa em fevereiro.

4.2.3. CIRCUNSTANCIAIS — ART. 60, §1º, CF.

Nas circunstancias do estado de sítio, de defesa e intervenção federal, a constituição não pode alterada/emendada. O poder constituinte originário achou por bem determinar esses limites circunstanciais por uma razão simples: são circunstâncias de eclosão social, desequilíbrio social. É necessário que retorne a ordem para que a constituição seja alterada. Art. 60, §1º, CF.

Por exemplo, o presidente Michel Temer decretou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro (art. 34, III, CF – grave comprometimento da ordem pública) até 31 de dezembro de 2018, e, até aquela data, a constituição não pode sofrer qualquer tipo de alteração.

4.2.4. MATERIAIS: ART. 60, § 4º, I, II, III E IV

São matérias, temas ou assuntos, que não podem ser abolidos ou tendentes a serem abolidos. São chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser abolidas ou tendentes a abolir do ordenamento.

O inciso II trata do voto direto, secreto, universal e periódico. No entanto, **no inciso II não está o voto obrigatório, não sendo, portanto, cláusula pétrea.**

A interpretação adequada do art. 60, §4º, IV, da CF é sobre o que é ou não cláusula pétrea, se são só os direitos que ali constam ou se todos os direitos fundamentais podem ou não sofrer alteração. Existem quatro grandes correntes que vão trabalhar a questão do que é cláusula pétrea em relação aos direitos fundamentais.

A **primeira corrente é a da interpretação literal**, que defendem que cláusulas pétreas são as normas do art. 5º da Constituição. É uma corrente clássica.

A **segunda corrente é a da interpretação literal restrita ou restritiva**, que defende que cláusulas pétreas não são todas as normas do art. 5º, mas sim apenas os direitos individuais propriamente ditos, ou seja, os direitos de liberdade. É uma corrente pouco protetiva dos direitos fundamentais enquanto cláusulas pétreas. O Min. Gilmar Mendes já foi adepto dessa corrente.



A **terceira corrente é a da interpretação extensiva**. Essa corrente é o oposto da primeira e da segunda. Essa corrente defende que cláusulas pétreas são todos os direitos fundamentais. O problema dessa corrente é que proteger demais é ruim, já que tudo o que tende ao absoluto pode virar nada. Essa é uma forma de interpretação que pode banalizar a proteção aos direitos fundamentais. Proteção demais gera déficit.

A **quarta corrente é a da interpretação extensiva sistemática**, que é uma corrente intermediária, que interpreta as cláusulas pétreas como sendo direitos de primeira, segunda e terceira geração. Não são todos os direitos fundamentais. São direitos de primeira, segunda e terceira geração que dizem respeito ao mínimo existencial que tendo como base a dignidade da pessoa humana. Essa corrente é uma interpretação sistemática, correlaciona o art. 60, § 4º, IV, com o art. 1º, III, CF. A análise deve ser casuística, de situações de aplicação. Deve se analisar se aquele direito, naquele contexto histórico específico, é ou não cláusula pétrea.

Determinados direitos fundamentais sociais que já alcançaram um grau de densidade normativo adequado no ordenamento não tem como retroceder, não tem como voltar atrás, que é o chamado vedação do retrocesso. Na doutrina, a corrente majoritária é a quarta. O STF não possui um posicionamento explícito sobre qual corrente ele adota, porém, vem adotando a quarta corrente, ainda que não de forma explícita, pois o STF vem entendendo que cláusulas pétreas não são só aquelas previstas no art. 5º, CF. Ex.: ADI 939, quando STF disse que é cláusula pétrea o art. 150, III, b, CF; na ADI 3685, o STF disse que art. 16, CF, princípio da anterioridade eleitoral (anualidade eleitoral), também é cláusula pétrea.

Atenção!

I – Além dos limites materiais explícitos (art. 60, §4º), temos também limites materiais implícitos (Prof. Canotilho). Os limites materiais implícitos são tirados por interpretação da Constituição.

Ex.1: a impossibilidade de revogação dos limites materiais explícitos, pois, se o constituinte originário criou o art. 60, §4º, CF para proteger determinadas matérias, revogar tais dispositivo desprotegeria os direitos nele assegurados, sendo um golpe na vontade do Poder Constituinte Originário. Canotilho chama esse golpe de dupla revisão. Cláusula pétrea não é só explícita, é também implícita.

Ex.2: impossibilidade de revogação dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Não é possível uma emenda que revoge o art. 1º, III, CF.

II – Poder Constituinte Derivado via emendas é o único modo de alterar a constituição? Não. Existem outros modos de alterar a constituição, sendo um deles o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que passar pelo mesmo procedimento das emendas constitucionais e entrar no ordenamento com *status* equivalente a emenda constitucional, como uma norma constitucional. Dessa forma, muda a constituição. Outra forma de alterar a constituição é pela mutação constitucional, também chamada de poder constituinte difuso, que ocorre quando o texto constitucional continua o mesmo, mas ele é reinterpretado em virtude de novas realidades sociais, de novos contextos. O texto ganha novas atribuições de sentido. Ex.1: art. 5º, *caput* – quem são os titulares de direitos fundamentais: brasileiros (natos e naturalizados) e os estrangeiros residentes, mas o STF considera a interpretação extensiva da constituição para abranger os não residentes. Ex.2: união estável entre homoafetivos.



- Qual a diferença entre poder constituinte derivado via emendas constitucionais para o poder constituinte difuso via mutação constitucional? Ambos mudam a constituição, mas o PCD é uma alteração formal, já a mutação constitucional é uma alteração informal: o texto continua o mesmo, o que muda é a atribuição do sentido hermenêutico que se dá ao texto em virtude de novas realidades sociais.

Atenção! Tema já cobrado em prova: O que é mutação inconstitucional? São processos informais de alteração da constituição, que deturpam, deterioram ou delegitimam uma constituição. Interpreta a constituição contra a própria constituição. Essa mutação inconstitucional pode ser feita pelo poder judiciário, interpretando a constituição de forma a deturpar a constituição e pode ser feita pelo legislativo quando este é omissor em regulamentar ou complementar normas constitucionais, pois isso também deslegitima a constituição.

- **Diferenças entre Revisão e Emenda:** No que tange à promulgação, as emendas devem ser promulgadas pela mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Quanto à emenda de revisão, a promulgação se deu pela mesa do Congresso Nacional.

4.2.5. PODER CONSTITUINTE DERIVADO DECORRENTE

É aquele poder que visa complementar a constituição com a elaboração das constituições estaduais pelos estados membros nos termos do art. 11 do ADCT e art. 25 da CF. É o poder de os Estados elaborarem e alterarem suas constituições. Esta competência é atribuída pelo poder constituinte originária, decorrendo diretamente da CF/88.

As constituições estaduais foram elaboradas entre os anos de 1989 e 1990, portanto, o que resta do poder constituinte decorrente não é mais um poder constituinte decorrente inicial para elaborar as constituições estaduais. O que resta é um poder constituinte anômalo, que reforma as constituições estaduais via emendas.

4.2.6. LIMITES

Os limites ou condições são princípios da constituição da República Federativa do Brasil⁶. Os princípios a serem observados são os **princípios sensíveis** (são os princípios do art. 34, VII, CF, que se descumpridas ensejam a intervenção federal no ente), os **princípios extensíveis** (são normas centrais comuns a todos os entes e que se estendem por toda a constituição; p.e. art. 5º III, XVI, CF) e os **princípios estabelecidos** (são normas que dizem respeito à organização do nosso federalismo – mais cai em prova). Dentro dos princípios estabelecidos, temos as normas de competência, que são regras de repartição de competência, e normas de pre-ordenação ou de reprodução obrigatória, ou seja, normas da constituição federal em que estão pre-definidas, que os estados devem alocar nas constituições estaduais. Essas normas que são de reprodução obrigatória desenvolvem um famoso princípio: o da simetria, que indicam que as normas da constituição federal, tanto quanto possível, podem ser reproduzidas por simétricas paridade nas constituições estaduais.

⁶ **Art. 11, ADCT.** Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecendo os princípios desta.



4.2.7. DIFERENÇA ENTRE AS NORMAS DE PRÉ-ORDENAÇÃO DAS NORMAS DE IMITAÇÃO

As normas de pre-ordenação são normas pre-ordenadas, pre-definidas, de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Já as normas de imitação, são normas da constituição federal que os estados vão ter a faculdade de alocar ou não, nas constituições estaduais. Se o estado quiser imitar e colocar em sua constituição, vai obrigar, vincular, em suas obrigações. Ex.: sobre o art. 57, §4º, CF, o STF já entendeu que não é uma norma de reprodução obrigatória, mas sim de imitação. Os estados não são obrigados a colocar isso em suas constituições, mas sim é uma faculdade do estado.

- Os municípios são dotados de poder constituinte decorrente?

Para a corrente majoritária, não. Portanto, as leis orgânicas não são consideradas verdadeiros estatutos constitucionais propriamente ditos. Para a corrente majoritária, não são considerados constitucionais propriamente ditos por uma questão de interpretação constitucional, porque a constituição, em nenhum momento, menciona constituição municipal e, além disso, não se pode ter um poder constituinte decorrente de um poder constituinte decorrente. Se há uma lei municipal que contraria a lei orgânica, aquela é ilegal em face desta, não se fala em inconstitucionalidade.

Porém, mesmo para a corrente majoritária, existe uma exceção. Existe uma lei orgânica que é considerada um verdadeiro estatuto constitucional, a LODF (Lei Orgânica do Distrito Federal). Dessa forma, teríamos sim na LODF um verdadeiro poder constituinte decorrente, segundo o art. 32, §1º, CF⁷. Diferente do art. 29, CF⁸, que diz que as leis orgânicas devem obediência às constituições estaduais e à constituição federal, a LODF deve respeito somente à CF.

Além disso, nos termos da Lei 9868/99 (leis da ADI, ADO e ADC), a LODF é parâmetro para controle de constitucionalidade de leis distritais, controle esse a ser enfrentado pelo TJDF, via representação de inconstitucionalidade.

O STF na REC. 3436 já afirmou que a LODF é sim um verdadeiro estatuto constitucional, e o STF voltou a afirmar isso na ADI 1167.

4.2.8. PODER CONSTITUINTE DIFUSO

É um poder de fato político, econômico ou social que produz este poder, atuando na mutação constitucional, que é um processo informal de alteração da Constituição. O texto é o mesmo, mas a norma que se extrai do texto é modificada.

4.2.9. PODER CONSTITUINTE SUPRANACIONAL

É o poder de fato, pois não há uma ordem jurídica que o precede, encarregado de fazer ou reformular constituições supranacionais.

⁷ **Art. 32.** O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios.

⁸ **Art. 29.** O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos



Exemplo disso é a viabilidade de adoção de uma Constituição transnacional democrática na Europa. O projeto de Constituição europeia já foi rejeitada há algum tempo, mas poderá voltar um dia.

QUESTÕES

Questão 1: (PGE/PE – 2018) — Acerca da teoria do poder constituinte, julgue os seguintes itens.

I Constituição superveniente torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitantes.

II Uma vez aprovada proposta de emenda constitucional pelo Congresso Nacional em exercício do seu poder constituinte derivado reformador, não haverá sanção ou veto pelo presidente da República.

III Norma anterior não será recepcionada se sua forma não for mais admitida pela Constituição superveniente, ainda que seu conteúdo seja compatível com esta.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está certo.
- b) Apenas o item II está certo.
- c) Apenas os itens I e III estão certos.
- d) Apenas os itens II e III estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

Questão 2 (DPE/PE – 2018) Com relação ao conceito, às espécies e às características do poder constituinte decorrente, assinale a opção correta.

- a) Trata-se do poder incumbido aos estados-membros de auto-organização.
- b) Classifica-se como originário se incondicionado ou derivado quando se resume a alterar texto pré-existente.
- c) Possui as mesmas limitações materiais que o poder constituinte originário.
- d) O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 é manifestação do poder constituinte decorrente.
- e) O poder constituinte decorrente reformador manifesta-se por intermédio do Congresso Nacional por ocasião das emendas à Constituição Federal de 1988.

Comentários

1. Gabarito: letra B, uma vez que a proposta de Emenda aprovada é promulgada diretamente pelas Mesas da Câmara e do Senado, de acordo com o § 3º do art. 60 da CF/1988.

A Constituição superveniente torna não-recepcionadas as leis materialmente incompatíveis com o novo texto constitucional. Nossa ordem constitucional não adotou a teoria da inconstitucionalidade superveniente.

I - Constituição superveniente torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitantes.

A Constituição superveniente torna não-recepcionadas as leis materialmente incompatíveis com o novo texto constitucional.

Nossa ordem constitucional não adotou a teoria da inconstitucionalidade superveniente. Segundo o Supremo Tribunal Federal:

O vício da inconstitucionalidade é congênito à lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de sua elaboração. Lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente; nem o legislador poderia



infringir Constituição futura. A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitantes: revoga-as (ADI 4.222-MC, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 8/2/2011).

Por seu turno, leis que forem formalmente incompatíveis podem ser recepcionadas pela nova Constituição, no formato exigido por esta. É o exemplo da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), que embora editada à época como lei ordinária, foi recepcionada pela Constituição de 1988 com força de lei complementar, pois a CF/88, em seu art. 146, III, exige essa espécie normativa para dispor sobre normas gerais de legislação tributária.

II - Uma vez aprovada proposta de emenda constitucional pelo Congresso Nacional em exercício do seu poder constituinte derivado reformador, não haverá sanção ou veto pelo presidente da República.

Correta, uma vez que a proposta de Emenda aprovada é promulgada diretamente pelas Mesas da Câmara e do Senado, de acordo com o § 3º do art. 60 da CF/1988:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

... § 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

III - Norma anterior não será recepcionada se sua forma não for mais admitida pela Constituição superveniente, ainda que seu conteúdo seja compatível com esta. (vide item I)

2. Gabarito: letra A. Podemos conceituar Poder Constituinte como uma força política, proveniente do povo, capaz de criar, garantir ou eliminar uma Constituição de determinado país, entendia esta como a Carta fundamental a reger todas as demais normas-regras que vierem a ser estabelecidas.

Assim, de acordo com a doutrina majoritária, temos que o poder constituinte se divide basicamente em originário (podendo ser histórico ou revolucionário) e derivado (reformador, decorrente ou revisor): (Lenza, P..Direito Constitucional Esquematizado, 19ª Ed, 2015, Saraiva, Ebook, pág. 324-356)

PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO: é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica precedente, sendo inicial, autônomo, ilimitado juridicamente, incondicionado, soberano na tomada de suas decisões, um poder de fato e político, e permanente. Subdivide-se em Histórico (verdadeiro poder constituinte originário, estruturando, pela primeira vez, o Estado) ou Revolucionário (todos os posteriores ao histórico, rompendo por completo com a antiga ordem e instaurando uma nova, um novo Estado)

PODER CONSTITUINTE DERIVADO: como o próprio nome sugere, é derivado do poder originário, devendo obedecer às regras colocadas e impostas por ele, sendo limitado e condicionado. Subdivide-se em Reformador (tem a capacidade de modificar a Constituição Federal, por meio de um procedimento específico, como através das emendas constitucionais), Decorrente (tem a função de estruturar a Constituição dos Estados-Membros ou, em momento seguinte, havendo necessidade de adequação e reformulação, modificá-la,



decorrente da capacidade de auto-organização estabelecida pelo poder constituinte originário) e Revisor (art. 3º do ADCT, que determinou uma revisão constitucional a ser realizada após 5 anos da promulgação da Constituição de 1988, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral).

Como vimos, a alternativa está correta porque o poder incumbido aos estados-membros de auto-organização é denominado decorrente.

b) Em nosso esquema ficou claro que o poder decorrente não é originário, mas sim derivado do originário.

c) O poder constituinte originário é ilimitado, ao passo que o derivado decorrente é limitado.

d) O ADCT da Constituição Federal de 1988 é manifestação do poder constituinte derivado REVISOR.

e) Por fim, consta do nosso esquema que o poder constituinte DERIVADO reformador é que se manifesta por intermédio do Congresso Nacional por ocasião das emendas à Constituição Federal de 1988.



CAPÍTULO 5 — NORMAS CONSTITUCIONAIS

1. CONCEITOS E ESPÉCIES

Normas constitucionais são todas as disposições inseridas numa Constituição ou reconhecidas por ela, só pelo fato de aderirem ao texto constitucional ou serem admitidas por ele, essas normas serão constitucionais.

Com o pós-positivismo, as normas, inclusive as de natureza constitucional, podem ser divididas em duas espécies: regras e princípios. A eficácia normativa dos princípios é uma das principais características da atual fase constitucional.

2. CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS DA CONSTITUIÇÃO QUANTO AO GRAU DE EFICÁCIA

Teoria Brasileira da aplicabilidade das normas constitucionais

Essa teoria tem um pressuposto de que todas as normas constitucionais são dotadas de aplicabilidade. Consiste na ideia de que norma constitucional não é um “conselho”, um pedido; norma constitucional é um comando que vincula condutas, rege o Estado e a sociedade. Para José Afonso da Silva todas as normas constitucionais pelo simples fato de serem são dotadas de aplicabilidade.

Diz também que toda norma constitucional possui, no mínimo, dois efeitos: positivo e negativo. O efeito positivo é o efeito de revogar tudo do ordenamento anterior contrário a elas. As normas constitucionais, pelo simples fato de surgirem, revogam tudo do ordenamento anterior contrário a elas, tratando de uma análise de conteúdo. Tecnicamente não se trata de revogação, mas sim de não recepção.

Já o efeito negativo é o efeito de negar ao legislador ordinário a possibilidade de produzir normas contrárias às normas constitucionais.

Segundo José Afonso, toda e qualquer norma constitucional será dotada de aplicabilidade, porque todas trazem consigo, pelo menos, os efeitos positivos e negativos.

No entanto, ainda que diga que todas possuem aplicabilidade, estas também possuem grau de aplicabilidade ou de eficácia jurídica.

O constitucionalismo, atualmente, refuta a ideia de que uma norma constitucional não possa ter eficácia jurídica. Toda norma constitucional tem eficácia, ainda que varie em maior e menor grau. Desta ideia decorrem as classificações de Ruy Barbosa, José Affonso da Silva e Maria Helena Diniz:

2.1. CLASSIFICAÇÃO DE RUY BARBOSA

Ruy Barbosa classificava as normas constitucionais em normas autoexecutáveis (*self executing*) e normas não autoexecutáveis (*not self executing*). Ele foi fortemente influenciado pelo direito norte-americano.

- **normas autoexecutáveis (*self executing*):** Produzem seus plenos efeitos com a simples entrada em vigor da Constituição.
- **normas não autoexecutáveis (*not self executing*):** São indicadoras de princípios que demandam atuação legislativa posterior que dará plena aplicação.

2.2. CLASSIFICAÇÃO DE JOSÉ AFFONSO DA SILVA

Segundo José Affonso da Silva, as normas constitucionais são classificadas:

- **Normas de eficácia plena:** são normas que desde a entrada em vigor da Constituição possuem possibilidade de gerar todos os seus efeitos. Aplicabilidade direta, imediata e integral. Exemplos: arts. 1º, 44, 46, CF.



- **Normas de eficácia contida (norma de contenção):** são normas tratadas pelo legislador constituinte, possuindo eficácia imediata e direta, mas podem ser restringidas em sua integralidade. São as normas em que o legislador constituinte regulou suficientemente, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária do Poder Público, nos termos que a lei estabelecer ou conforme os conceitos gerais nelas enunciados. Ou seja, não apenas a lei pode restringir as normas de eficácia contida, mas também a restrição pode decorrer dos próprios conceitos por elas utilizados. Ex.: no caso do estado de sítio, a aplicação fica restrita às situações de fato que o autorizam. Veja, o constituinte deixou margem para o legislador reduzir os efeitos da norma. Outro exemplo é o livre exercício da profissão na forma da lei. Esta lei pode restringir a norma constitucional. A norma de eficácia contida por ser restringida por uma lei ou até mesmo por outra norma constitucional, sendo exemplo disso a restrição pelos direitos fundamentais (ex.: estado de sítio que restringe direitos fundamentais). É ainda possível que a norma de eficácia contida seja restringida pelo intérprete, como ocorre com as normas que contenha conceitos abertos, tal como segurança nacional, ordem pública, etc. A norma de eficácia contida faz um apelo para que o legislador ordinário faça uma restrição. Até que não ocorra essa restrição a norma constitucional será plena.
- **Normas de eficácia limitada:** são aquelas normas constitucionais que não produzem seus efeitos desejados com a entrada em vigor da Constituição. A aplicabilidade das normas de eficácia limitada é indireta, mediata, razão pela qual somente incidem totalmente os seus efeitos por conta de uma normatização ulterior.

As normas de eficácia limitada podem ser divididas em:

- **Normas definidoras de princípios institutivo (ou organizativo):** são as normas que traçam ordens constitucionais para que o legislador organize a estruturação do Estado, estabelecendo órgãos, entidades, institutos, etc. Exemplo disso é o art. 33 da CF/88, que estabelece que a lei disporá sobre a organização administrativa dos territórios. Esta norma pode ser de caráter impositivo ou de caráter facultativo. Ou seja, pode ser que o legislador constituinte ordene que o legislador constitucional regulamente ou institua o órgão mediante lei, mas também pode ser que faculte ao legislador a criação do órgão por meio de lei. Exemplos: art. 18, §2º, art. 33, caput, art. 90, §2º.

- **Normas definidoras de princípios programáticos:** o constituinte, ao invés de regular diretamente como será a função estatal, haverá a fixação de diretrizes para fixar os princípios, metas, objetivos que irão orientar a forma de agir dos órgãos constituídos. Por exemplo, a Constituição estabelece que um dos seus objetivos é a erradicação da pobreza. Ou seja, a Constituição cria um programa que deverá ser realizado pelo Poder Público. Portanto, a norma que visa o combate ao analfabetismo, ou a instituição da defesa dos idosos e das crianças, são normas programáticas. Estas normas são típicas de Constituições Dirigentes, assim como o é a Constituição de 1988.

Vale lembrar que as normas de eficácia limitada não produzem a integralidade de seus efeitos sem que haja a norma regulamentadora, mas produzem certos efeitos, os quais já são vistos desde a promulgação da Constituição. Tais normas, ao menos, produzem eficácia negativa da norma de eficácia limitada. Esta eficácia negativa se desdobra basicamente em dois efeitos:



- Eficácia paralisante: a norma de eficácia limitada vai revogar as normas contrárias ou incompatíveis com seu comando.
- Eficácia impeditiva: mesmo normas constitucionais posteriores à norma programática não poderão tratar de assuntos contrários a ela, em razão da eficácia impeditiva.

Estas normas programáticas servirão também de parâmetro de interpretação das outras normas constitucionais, ou seja, servirá como vetor interpretativo.

A diferença entre as normas constitucionais de eficácia contida para as de limitada está no modo ou maneira de atuação do legislador. Nas normas constitucionais de eficácia contida, o legislador vai atuar para que contere o âmbito de eficácia. Diferentemente das normas constitucionais de eficácia limitada, que o legislador atua para aumentar o âmbito de eficácia porque elas não produzem todos os efeitos possíveis.

Importante ressaltar que todas as normas constitucionais são dotadas de aplicabilidade, ainda que essa aplicabilidade seja baixa, indireta, mediata. O ideal é o Poder Público atuar, mas enquanto não o fizer, a norma continua a ter aplicabilidade.

Obs.: Atualmente o Poder Judiciário, em virtude da judicialização da política e das relações sociais e de determinadas ondas de ativismo mundial, vem, em determinadas situações afirmando que normas programáticas de direitos fundamentais sociais devem ter aplicabilidade imediata, tendo em vista o mínimo existencial social, e como base a dignidade da pessoa humana.

O nosso Poder Judiciário vem em determinadas situações, sobretudo em temas como saúde, educação ou sistema prisional, dizendo que essa teoria clássica das normas programáticas precisa ser relativizada, pois se envolver direitos fundamentais sociais a aplicabilidade tem que ser imediata tendo em vista o mínimo existencial tendo como base a dignidade da pessoa humana. Exemplo: RE 410.715 é um exemplo do mínimo existencial de direitos fundamentais sociais, no qual o Poder Judiciário passa a interferir em políticas públicas afastando a reserva do possível, afastando a discricionariedade do poder público, afastando a ideia de que são normas meramente programáticas e buscando a aplicação imediata dos direitos fundamentais sociais.

2.3. CLASSIFICAÇÃO DE MARIA HELENA DINIZ

De acordo com a professora Maria Helena Diniz, as normas constitucionais podem ser da seguinte forma:

- **normas de eficácia absoluta (normas supereficazes):** são as chamadas supereficazes, já tendo eficácia direta da Constituição. Estas normas não podem ser contrariadas nem mesmo por emenda constitucional. As normas de eficácia absoluta são as cláusulas pétreas.
- **normas de eficácia plena:** são normas plenamente eficazes, mas que podem ser suprimidas ou atingidas por emendas constitucionais.
- **normas de eficácia relativa restrigível:** correspondem às normas de eficácia contida (José Affonso) e também às normas de eficácia redutível (Michel Temer).
- **normas de eficácia relativa dependente de complementação legislativa (complementável):** são normas que não possuem aplicação imediata, pois necessita de uma norma posterior para alcançar a sua eficácia desejada.



3. NORMAS CONSTITUCIONAIS NO TEMPO

3.1. ILIMITAÇÃO DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO

O poder constituinte originário é ilimitado em razão de não dever obediência a qualquer das normas do regime constitucional anterior, não devendo respeito sequer ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, ou à coisa julgada.

As novas normas constitucionais retroagem?

O STF entendeu que, salvo disposição expressa em contrário pelo poder constituinte originário, as normas constitucionais novas têm o que se chama de retroatividade mínima, ou seja, elas alcançam os efeitos futuros de fatos passados. Em outras palavras, elas se aplicam desde já, alcançando efeitos futuros de fatos ocorridos no passado.

- Retroatividade mínima: a nova norma alcança prestações futuras de negócios celebrados no passado.
- Retroatividade média: a nova norma alcança prestações pendentes de negócios celebrados no passado, além de prestações futuras.
- Retroatividade máxima: a nova norma alcança fatos já consumados no passado, inclusive já alcançados pela coisa julgada.
- Irretroatividade: a lei não retroage para sequer alcançar fatos passados. Só alcança negócios celebrados a partir de quando entrar em vigor.

As normas constitucionais, em regra, possuem retroatividade mínima, mas podem adotar retroatividade média e máxima, se assim o constituinte regular.

E mais, as constituições dos Estados, diferentemente da CF, devem observar as limitações desta, entre as quais está do art. 5º, inciso XXXVI, que protege o ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada.

Portanto, Constituições Estaduais não podem prejudicá-los.

3.2. RELAÇÃO ENTRE A NOVA CONSTITUIÇÃO E A PRETÉRITA

A promulgação de uma Constituição revoga completamente a Constituição antiga, ainda que haja compatibilidade.

Há uma doutrina que defende a desconstitucionalização da Constituição pretérita. Isso significa que é possível que a antiga constituição seja recepcionada pela nova ordem constitucional sem, contudo, possuir força constitucional.

Como regra, não se admite a desconstitucionalização. Todavia, o Poder Constituinte originário pode trazer disposição expressa nesse sentido.

3.3. RELAÇÃO ENTRE A NOVA CONSTITUIÇÃO E O DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL INCOMPATÍVEL

As leis anteriores à nova Constituição devem ser aproveitadas, mas desde que o conteúdo seja compatível com o novo texto constitucional.

Se o conteúdo do direito pré-constitucional é incompatível, a nova constituição revoga essas leis. O STF não admite a chamada inconstitucionalidade superveniente.

Os defensores desta tese queriam que as normas do direito anterior incompatíveis com a nova constituição não deveriam ser revogadas, e sim declaradas inconstitucionais.

Uma lei só pode ser inconstitucional se estiver conflitante com o texto constitucional no momento da elaboração dela.

O controle de constitucionalidade pressupõe contemporaneidade entre a Constituição e a lei (princípio da contemporaneidade).

- Mas qual é a utilidade dessa diferença?

Na verdade, se houvesse um juízo de constitucionalidade, os Tribunais teriam que observar a cláusula de reserva de plenário, declarando a lei constitucional por meio da maioria



absoluta dos seus membros ou do órgão especial. Já que o STF diz que não é controle de constitucionalidade, havendo apenas revogação, os Tribunais não estão obrigados a observar a cláusula de reserva de plenário para não recepcionar essas leis. Por não ser controle de constitucionalidade, não cabe ação direta de inconstitucionalidade de normas anteriores à CF (STF).

3.4. RELAÇÃO ENTRE A NOVA CONSTITUIÇÃO E O DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL COMPATÍVEL

Nesse caso, as leis serão recepcionadas.

No entanto, nem todo o direito compatível com a nova constituição pode ser recepcionado, havendo os seguintes requisitos:

- a norma pré-constitucional deve estar em vigor no momento de promulgação da Constituição;
- o conteúdo da norma deve ser compatível com a Constituição (não necessita ter a forma compatível);
- a norma deve ter sido produzida de forma válida, de acordo com a Constituição anterior.

Se a norma não foi produzida validamente pela Constituição anterior, ela será natimorta, não havendo como a nova Constituição sanar este vício. Trata-se de uma nulidade congênita.

Em outras palavras, segundo o STF, não se admite a constitucionalidade superveniente. Isto também vale para emendas constitucionais. Isto significa que uma norma que nasce inconstitucional, mesmo que esta norma seja constitucional por meio da nova constituição, não poderá ter a sua constitucionalidade considerada, em razão de ter nascido morta.

A compatibilidade entre a norma pré-constitucional e a nova constituição só leva em conta o conteúdo da norma, e não a sua forma.

Exemplo disso ocorre com os decretos leis, leis complementares com natureza de lei ordinária, etc.

A recepção não necessariamente é expressa.

Se houver conflito, quem decide é o Poder Judiciário.

O CTN é exemplo de forma incompatível com a nova Constituição, mas com o conteúdo compatível, tendo natureza de lei complementar com relação às normas gerais, apesar de ser lei ordinária.

3.5. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS

Se na vigência da constituição anterior uma determinada matéria é tratada pela União, mas passa com o novo texto constitucional a ser de atribuída aos estados, é possível que a norma seja recebida pela legislação estadual, a fim de que não haja uma descontinuidade jurídica. Neste caso os estados continuam aplicando a lei federal até que decidam alterar as regras.

3.6. RECEPÇÕES PARCIAIS E TOTAIS

A recepção pode ser parcial ou total.

3.7. REPRISTINAÇÃO AUTOMÁTICA

A nova constituição não restaura normas que já não mais se encontravam em vigor na constituição pretérita. A Constituição não gera a repristinação automática.



É possível que exista a repristinação, sendo a volta da vigência da lei com a entrada de uma nova Constituição, mas é necessário que haja disposição expressa do poder constituinte originário.

3.8. PERÍODO DE VACATIO LEGIS E NOVA CONSTITUIÇÃO

A doutrina discute esta situação.

Se a lei não estava em vigor quando da inauguração da nova Constituição, a doutrina entende que esta lei não pode ser recepcionada. Isso porque, para ser recepcionada no novo texto constitucional, é necessário que a norma esteja em vigor quando da promulgação da Constituição, e lei em período de *vacatio legis* é lei sem vigor, razão pela qual não poderia ser recepcionada.

3.9. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL

Existem duas situações a ser analisadas:

- controle de constitucionalidade difuso: admite a análise de norma infraconstitucional ordinária perante a constituição anterior, a isto se dando um controle de constitucionalidade.
- controle de constitucionalidade difuso ou arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF): por estes dois instrumentos é admitida a análise da validade da norma infraconstitucional ordinária anterior à CF/88 em face da atual Constituição.

Obs.: não se admite controle concentrado de constitucionalidade com base na constituição antiga. O STF entende que o controle abstrato é uma forma de proteger apenas a Constituição atual.

Questões

1) (PGM/Ribeirão Preto – 2019) — O artigo 205 da Constituição Federal possui a seguinte redação:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

A partir da classificação das normas constitucionais, é correto afirmar que referida norma pode ser classificada como de

- a) eficácia contida.
- b) eficácia restrita.
- c) aplicabilidade plena.
- d) eficácia limitada de princípio programático.
- e) eficácia limitada de princípio institutivo.

2) (MPE/PI – 2019) — De acordo com a doutrina, norma constitucional superveniente editada pelo poder constituinte originário sem qualquer ressalva tem eficácia

- a) retroativa máxima.
- b) retroativa média.
- c) retroativa mínima.



- d) somente para o futuro.
- e) exauriente.

Gabarito

1. Gabarito: letra D. As normas de eficácia limitada (nomenclatura de José Afonso da Silva) ou restringíveis dependentes de regulamentação legislativa (nomenclatura de Maria Helena Diniz), ou diferidas no tempo, são aquelas que só produzem seus plenos efeitos depois da exigida regulamentação. Elas asseguram determinado direito, mas esse direito não poderá ser exercido enquanto não for regulamentado pelo legislador ordinário. Isso não significa que não possa ser exigível! Tanto assim é, que tais normas atraem a impetração de mandado de injunção, individual ou coletivo, para instar o legislador a regulamentá-las! As normas de eficácia limitada podem ainda ser divididas em dois grupos:

- I) de princípio institutivo ou organizativo;
- II) de princípio programático.

As normas definidoras de princípio institutivo ou organizativo são aquelas em que a Constituição estabelece regras para a criação, estruturação e organização de órgãos, entidades ou institutos, mediante lei (por exemplo, “a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios” (CF, art. 33).

As normas de princípio programático requerem dos Poderes Públicos uma atuação positiva para consecução do programa estabelecido pelo constituinte originário ou derivado. Não são normas voltadas para a organização do Estado em si, e nem para o indivíduo, para para a ação estatal, para a execução de programas de ação. Entretanto, pelo fato de serem normas de eficácia limitada não quer dizer que não possuam qualquer eficácia jurídica.

Essas normas são dotadas da chamada eficácia negativa, ou seja:

- (i) revogam o direito com elas conflitante, pela não recepção da legislação anterior à nova Constituição em elas em confronto (eficácia paralisante);
- (ii) limitam a ação do legislador positivo, na medida em que impedem a produção de normas contrárias aos programas definidos na Constituição Federal, tornando-se perfeitamente utilizável como paradigma para declaração de inconstitucionalidade (eficácia impeditiva).
- (iii) servem de parâmetro de interpretação do texto constitucional, em um sentido teleológico (finalístico), de integração e de aplicação das normas jurídicas, cujo resultado deverá ser harmônico com os valores e princípios definidos nas normas programáticas.

2. Gabarito: letra C. As normas constitucionais originárias possuem a denominada retroatividade mínima, isto é, alcançam fatos futuros de situações constituídas no passado. Apenas quando a Constituição determine expressamente de modo diverso, a norma poderá abarcar fatos consumados no passado, por exemplo, como as regras de transição relativas a aposentadoria consoante jurisprudência do STF:

As normas constitucionais federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declararem podem alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e máxima). Não assim, porém, as normas constitucionais estaduais que estão sujeitas à vedação do art. 5º, XXXVI, da Carta Magna Federal, inclusive a



concernente à retroatividade mínima que ocorre com a aplicação imediata delas.
(AI 258.337-AgR, Relator Ministro Moreira Alves, DJe 4/8/2000)



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



61 3033-3739



61 98442-2591

CAPÍTULO 6 — HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL

1. CONCEITO

Hermenêutica está ligada à mitologia greco-latina. O Deus Hermes era um mensageiro dos deuses, era a divindade incumbida de levar a mensagem dos homens aos deuses e a mensagem dos deuses aos homens. A interpretação em geral, e a interpretação jurídica, é uma atividade de mediação comunicativa, que é muito importante o estudo que vamos desenvolver.

Hermenêutica é o exame do saber sobre os pressupostos, a metodologia e a interpretação do direito. É a ciência filosófica que possui regras e princípios próprios norteadores da interpretação de textos. A interpretação transforma textos normativos em normas jurídicas, viabilizando sua aplicação para as situações que se apresentarem em concreto

Em qualquer campo da hermenêutica, esse exame será uma forma de comunicação mediativa. O intérprete do direito mediará a relação que existe entre o sistema jurídico e a sociedade. A lei não fala, o intérprete é que faz a lei falar, sendo portando uma espécie de “médium”.

A hermenêutica constitucional será entendida como o saber que se propõe a estudar os princípios, os fatos, e compreender os institutos da Constituição para colocá-la diante da sociedade.

Conforme aduzido por Gilmar Mendes, em sua doutrina, Curso de Direito Constitucional:

“Interpretação constitucional é a atividade que consiste em achar o sentido das normas da lei fundamental – sejam essas normas regras ou princípios -, tendo em vista resolver problemas práticos, se e quando a simples leitura dos textos não permitir, de plano, a compreensão do seu significado e alcance.”

A finalidade mais relevante da produção da norma jurídica, resultante da interpretação do texto legal, é a sua aplicação num caso concreto e isso ocorrerá mediante uma decisão judicial ou administrativa.

Para o formalismo jurídico, o juiz seria a “boca da lei”, não cabendo ele interpretar a lei conforme a realidade. Ele só poderia refletir a vontade do legislador.

Para o realismo jurídico, a Constituição é aquilo que o juiz diz que ela é. O Poder Judiciário não estaria preocupado com aquilo que a Constituição diz. É o extremo contrário ao formalismo jurídico.

Há um ponto de equilíbrio: positivismo jurídico (Kelsen). A decisão judicial não seria apenas um ato de aplicação do direito, mas também um ato de criação. O direito positivo fornece uma moldura, cabendo ao juiz escolher uma opção dentre aquelas trazidas pelos limites da lei. No positivismo puro não há ética e moral, havendo a escolha entre critérios técnicos. O positivismo caiu por terra por conta do nazismo.

Segundo Eros Grau, texto é norma em potencial, mas não se confunde com a norma, que é o resultado da interpretação.

A interpretação, na visão contemporânea, não é mais exclusiva do aplicador do direito. Ou seja, seria errado dizer que a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que ela é, pois haveria um monopólio da interpretação.

Inclusive há duas correntes norte-americanas de hermenêutica:

- Interpretativismo: os juízes, ao interpretar, a constituição, devem limita-se a captar o sentido dos preceitos expressos na Constituição, ou, pelo menos, nela claramente implícitos. Há uma ideia muito próxima ao formalismo tradicional ou



jurídico. Nega-se a função criativa do direito pelos juízes por meio da interpretação. Esses limites aos juízes é a semântica textual e a vontade do legislador.

- Não interpretativismo: aqui, há a possibilidade e a necessidade de os juízes invocarem e aplicarem valores e princípios substantivos – princípios da liberdade e da justiça – contra atos da responsabilidade do legislativo em desconformidade com o projeto da constituição. Admite-se a possibilidade de ativismo judicial e função criativa do juiz. Leva-se em conta a textura semântica, a vontade do legislador e também o papel do intérprete, a partir da pré-compreensão de fatos, consequências e ideologias. Ao final desse processo, chega-se à norma jurídica.

O professor Eros Grau ainda diferencia:

- Norma jurídica: resultado da interpretação em geral.
- Norma de decisão: resultado da interpretação do juiz.

Na concepção contemporânea, por exercer o juiz um papel ativo, há aqui uma função criadora do juiz, exercendo atividade na própria formação da norma. O juiz já não é mais aquele do formalismo jurídico.

A partir do momento em que se admite a função criativa, surge um perigo: a ausência de limites à atuação do juiz, podendo gerar a ruptura de poderes, substituindo o legislador. Com isso, o Poder Judiciário poderia se tornar um poder onipotente, insuscetível de limitações.

Montesquieu dizia que não se pode admitir que o juiz seja legislador, pois, do contrário, haveria arbitrariedade. Isso porque quem detém poderes demasiados tende abusá-lo.

Por tudo isso, entende-se que é necessário colocar limites reais à interpretação judicial. Ou seja, devem haver constrangimentos reais, impedindo a liberdade absoluta.

A respeito desses limites, o professor Eros Grau utilizou a chamada metáfora da Vênus de Milo, a fim de ilustrar essa imposição de limites. Quando é encomendada uma estátua da Vênus de Milo a 3 artistas, cada um deles a realiza de sua maneira, havendo um resultado diverso entre eles, mas sempre havendo a semelhança. Ou seja, nenhum deles traz uma estátua totalmente diferente do que a Vênus de Milo. Portanto, os juízes são os artistas, os quais têm liberdade de interpretação, mas isto não pode levar à tarefa encomendada ao juiz.

Esses vetores limitativos poderão ser:

- Texto constitucional em vigor (dogmática): não se pode desprezar a literalidade da CF.
- Observar os precedentes judicial
- Princípios constitucionais
- Princípios e regras da hermenêutica constitucional
- Métodos da hermenêutica constitucional

2. MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO

2.1. MÉTODO JURÍDICO

Vai dizer que a Constituição é uma lei, razão pela qual se utiliza da mesma interpretação que se faz a lei. Para descobrir o sentido da norma constitucional, o intérprete deverá se valer de elementos interpretativos típicos, tais como elemento filológico (gramatical/literal), elemento lógico (sistemático), elemento histórico (contexto histórico), elemento teleológico (finalidade da norma), elemento genético (fundado na origem dos conceitos) etc.

O método jurídico se vale dos métodos interpretativos clássicos.



Eles são passíveis de serem utilizados para interpretar a Constituição, mas não são suficientes.

2.2. MÉTODO TÓPICO-PROBLEMÁTICO

Foi idealizado por Theodor Viehweg, colocando ênfase no problema enfrentado. A tópica é uma invenção, uma técnica mental de pensar o problema com o objetivo de solucioná-lo.

O método tópico-problemático parte das seguintes premissas:

- A primeira premissa estabelece que a interpretação constitucional deve ter caráter prático, resolvendo o problema concreto.
- A segunda premissa estabelece que as normas constitucionais possuem um caráter fragmentário, sem abranger todas as situações capazes de ocorrer, mas apenas aquelas com alto grau de abstração e generalidade.
- A terceira premissa estabelece que não é possível fazer apenas a subsunção do fato à norma constitucional. O ponto de partida deve ser o problema, e não a norma.

Diante dessas premissas, o método tópico-problemático se desenvolve. Para tanto, o intérprete deverá encaixar o problema que se quer resolver dentro da Constituição. A partir daí, o intérprete reputará como justo a resolução do problema extraído do texto constitucional.

A crítica que se faz ao método tópico-problemático é que há um casuismo sem limites, em razão de que cada problema é diverso dos demais.

2.3. MÉTODO HERMENÊUTICO CONCRETIZADOR

O método Hermenêutico-Concretizador, que tem como principal idealizador Konrad Hesse, parte da ideia de que os aspectos subjetivos do intérprete dão-lhe uma inevitável “pré-compreensão” acerca da norma a ser interpretada.

O método hermenêutico concretizador faz o caminho inverso ao método tópico-problemático. Isto é, o caminho feito pelo método hermenêutico concretizador é a partir da norma constitucional para o problema a ser resolvido, e depois do problema a ser resolvido para a norma constitucional.

O método hermenêutico concretizador diz que o intérprete que, ao fazer a primeira leitura do texto constitucional, extrai um conteúdo, chamado de pré-compreensão da norma. Quando o intérprete se defronta com o problema, ele deverá voltar à norma que ele havia pré-compreendido. Ou seja, o intérprete faz a primeira leitura (pré-compreensão) e compara com a realidade existente. A partir do confronto da primeira leitura e da realidade existente, ele irá reformular a sua própria compreensão, de forma que irá reler o texto da forma que a realidade se apresentou. Nesta releitura do texto, haverá repetições sucessivas do texto para a realidade até que se encontre uma solução harmoniosa do problema.

No âmbito constitucional, marcado pela abertura e imprecisão de muitas de suas normas, a busca do sentido delas envolve mais concretização do que interpretação, assumindo, portanto, as pré-compreensões um papel decisivo. Nesse quadro, os defensores da interpretação concretista, dentre os quais Konrad Hesse, pugnam que toda leitura inicial de um texto deve ser reformulada, mediante uma comparação com a realidade, justamente para serem suprimidas interpretações equivocadas. Por isso, o método concretizador funda-se em uma constante mediação entre o problema e a norma, no qual a concretização é lapidada por meio de uma análise mais profunda, em que a norma prevalece sobre o problema.

Perceba que existe um movimento de ir e vir, entre a norma e a realidade, é denominado de círculo hermenêutico.



A grande ideia que se pode concluir do método hermenêutico concretizador é que ele dá prevalência ao texto constitucional, o qual sempre irá começar esse movimento, a partir da pré-compreensão da norma.

Em suma, o método hermenêutico-concretizador possui 3 elementos básicos:

- Pressupostos subjetivos: o intérprete possui uma pré-compreensão da Constituição, exercendo um papel criador na atividade de descobrir o sentido do texto constitucional.
- Pressupostos objetivos: dizem respeito ao contexto no qual o texto vai ser aplicado, atuando o intérprete como um mediador entre o texto e a situação na qual ele se aplica (contexto).
- Relação entre texto e contexto: com a mediação criadora feita pelo intérprete, transformando a interpretação em movimento de ir e vir (círculo hermenêutico), na busca da concretização, da construção da norma, que é o resultado da interpretação.

2.4. MÉTODO CIENTÍFICO-ESPIRITUAL

O método Científico-Espiritual é produto das concepções de Rudolf Smend, o qual defende que a interpretação deve buscar o conteúdo axiológico último da Lei Maior, por meio de uma leitura flexível e extensiva, onde os valores comunitários e a realidade existencial do Estado se articulam com o fim integrador da Constituição. O método científico-espiritual tem um cunho sociológico, não procurando exatamente extrair ou interpretar a norma constitucional pelo conteúdo textual, pois visa procurar precipuamente os valores que estão subjacentes ao texto constitucional.

Com base nesta preocupação, o intérprete conseguiria integrar a Constituição à realidade espiritual da comunidade. É preciso interpretar a Constituição com base nos seus valores, a fim de extrair o espírito da sociedade, motivo pelo qual é denominado de científico-espiritual.

2.5. MÉTODO NORMATIVO-ESTRUTURANTE

O método normativo-estruturante estabelece que não há identidade entre norma jurídica e texto normativo. Com base nisso, o que se pretende é que a norma que se extrai do texto da Constituição seja capaz de levar à concretização da Constituição na realidade social. Isso porque, a norma que vai ser extraída do texto da Constituição vai resolver o problema prático através da resolução de questões de problemas práticos.

É preciso que a norma extraída do texto constitucional possa resolver um problema prático.

2.6. INTERPRETAÇÃO COMPARATIVA

A interpretação comparativa busca analisar os institutos jurídicos, normas de diversos ordenamentos jurídicos. A ideia é que por meio da comparação de diferentes ordenamentos jurídicos seja possível extrair o significado real que deve ser atribuído ao instituto ou ao enunciado.



3. PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

3.1. PRINCÍPIO DA UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO

O princípio da unidade da Constituição vai dizer que a Constituição é uma só, razão pela qual o texto constitucional deve ser interpretado a fim de evitar contradições entre as suas normas. O intérprete deve analisar a Constituição em sua globalidade, havendo uma unidade harmônica.

Em decorrência disso, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo dizem que todas as normas constitucionais têm igual dignidade, não podendo uma norma se sobrepor à outra, pois não há hierarquia entre normas constitucionais (inexistência de hierarquia entre normas constitucionais).

Por outro lado, não há normas originárias inconstitucionais, tendo em vista que não é possível fazer o controle de constitucionalidade de normas originárias (inexistência de inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias).

O que é capaz de existir entre normas constitucionais é tão somente uma antinomia aparente, não existindo antinomias verdadeiras entre os dispositivos constitucionais, pois ela é interpretada de forma harmônica, por conta da unidade da Constituição.

3.2. PRINCÍPIO DO EFEITO INTEGRADOR

O princípio do efeito integrador é um corolário do princípio da unidade da Constituição. A ideia é de que seja necessário promover uma interpretação que favoreça a integração política, social, etc. O que se procura é a integração política, social, harmonizando os valores.

3.3. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE

Segundo o princípio da máxima efetividade, o intérprete deve atribuir à norma constitucional um sentido que lhe dê uma maior eficácia.

3.4. PRINCÍPIO DA JUSTEZA

O princípio da justeza, também chamado de princípio da conformidade funcional, vai dizer que o órgão encarregado de interpretar a Constituição (STF) não pode chegar ao resultado que subverta o esquema organizatório funcional estabelecido pelo legislador constituinte.

Por isso, quando o STF afastou o presidente da Câmara, houve questionamento sobre a legitimidade do ato jurisdicional. O Supremo pode fazer isso, pois se ele pode decretar a prisão do parlamentar, o afastamento do cargo seria uma medida menos drástica.

3.5. PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO

O princípio da harmonização, também denominado de princípio da concordância prática, é uma decorrência do princípio da unidade da Constituição. É preciso que haja coordenação de bens jurídicos, quando houver um certo conflito entre eles. Com a situação de conflito, busca-se interpretar a constituição a fim de evitar o sacrifício dos direitos em colisão.



3.6. PRINCÍPIO DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO

Segundo Konrad Hesse, o princípio da força normativa, o intérprete deve realizar a interpretação de forma a conferir a Constituição força normativa, cogente, que se impõe. Isto só é possível quando o intérprete adote aquela que promova uma atualização normativa.

3.7. PRINCÍPIO DA INTEPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO

O princípio da Intepretação conforme à Constituição estabelece que o texto constitucional admita diferentes interpretações ou significados. O que se conclui é que existem normas polissêmicas ou plurissignificativas. Neste caso, o intérprete deverá dar a essa norma uma interpretação que compatibilize ou permita que seja compatível com o conteúdo da Constituição.

A regra é que, se for possível conservar a validade de uma lei, deverá adotar a interpretação conforme a Constituição. Existem limites para isso.

O intérprete não pode contrariar o texto literal, razão pela qual se o texto diz “não”, o intérprete não pode dizer “sim”. O intérprete deve manter a vontade do legislador.

3.8. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS (*IMPLIED POWERS*)

Esta teoria dos poderes implícitos foi desenvolvida pelo constitucionalismo norte-americano, estabelecendo que, sempre que a constituição designa o fim, ela também designa o meio necessário para alcançar o fim.

O STF tem reconhecido a teoria dos poderes implícitos no Brasil. Exemplo disso é o caso do Tribunal de Contas da União conceder medidas cautelares, pois ele já profere decisões de mérito, podendo conceder meios necessários para alcançar a sua finalidade principal.

4. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIAS

4.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A Primeira Turma, em conclusão de julgamento e por maioria, deu provimento a agravo regimental para julgar procedente reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar ação ordinária em que se pretende afastar a aplicação da Resolução 151/2012 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A reclamante alegava que a Justiça Federal teria usurpado a competência do STF ao processar e julgar feito em que se questiona a aludida resolução, bem como se busca impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas dos servidores daquela Justiça e do tribunal regional eleitoral, ambos do Estado do Paraná. Prevaleceu o voto do ministro Luiz Fux. À luz do ato do CNJ, o ministro verificou que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), a impor o reconhecimento da competência do STF. A seu ver, a exegese do art. 102, I, r, da Constituição Federal (CF) (1) reclama a valoração do caráter genérico da expressão “ações” acolhida no dispositivo; das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; da natureza das atribuições constitucionais do STF e da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário. Logo, a hermenêutica sistemático-teleológica do mencionado preceito conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação. Em regra, as ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser processadas e julgadas na Justiça Federal. Revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitar a banalização da jurisdição extraordinária e preservar a própria funcionalidade da Corte. Dessa forma, a



competência originária do STF alcança ações ordinárias em que se impugnam atos do CNJ que possuam caráter normativo ou regulamentar; que desconstituam ato normativo de tribunal local e que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário. Entretanto, não são de competência do STF as demandas contra atos do CNJ que atinjam tão somente servidores dos órgãos fiscalizados ou mesmo as serventias extrajudiciais; que não digam respeito a interesse exclusivo de toda magistratura ou que revejam atos administrativos gerais dos tribunais, assim considerados os que não se sujeitam a regulamentação distinta do Poder Judiciário, de que seriam exemplo os relacionados a concursos públicos ou licitações dos tribunais locais. Vencida a ministra Rosa Weber (relatora), que negou provimento ao agravo e manteve a decisão agravada. Assinalou que a competência prevista no art. 102, I, r, da CF deve ser interpretada de forma restritiva, a alcançar apenas os casos em que o CNJ tenha personalidade judiciária para figurar no feito, como em mandado de segurança, habeas data e habeas corpus. Como se passa com qualquer ato praticado pela Administração do Judiciário da União, a impugnação das decisões do CNJ, por via de ação ordinária, deve ser promovida perante a Justiça Federal. (1) CF: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: (...) r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;” Rcl 15564 AgR/PR, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgamento em 10.9.2019. (Rcl-15564)

Questões

1) (DPE/MG – 2019) — Analise as afirmativas a seguir.

I. O princípio da “concordância prática ou harmonização” estabelece ao intérprete constitucional a aplicação do sentido normativo que respeite os limites da divisão de funções constitucionalmente estabelecidas pelo poder constituinte originário entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

II. No caso de normas plurissignificativas, o princípio da “força normativa” estabelece ao intérprete constitucional a vedação de aplicação de normas inconstitucionais e a proibição do exercício da função de legislador positivo criando normas divergentes dos propósitos do legislador.

III. Na interpretação dos direitos fundamentais, o princípio da “máxima efetividade das normas constitucionais” orienta o intérprete constitucional à aplicação do sentido normativo que confira o maior grau de efetividade social à norma constitucional aplicável ao caso concreto.

À luz dos princípios hermenêuticos de interpretação constitucional, está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- a) I e III, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I, II e III.

2) (MPE/GO – 2019) — José Afonso da Silva parte da classificação das normas constitucionais realizada por Vezio Crisafulli, segundo o qual, quanto à eficácia e aplicabilidade, essas mesmas normas podem ser classificadas em dois grupos: as normas constitucionais de eficácia plena e as normas constitucionais de eficácia limitada. Entretanto, José Afonso acrescentou a essa classificação mais um grupo, sob o argumento de que há normas que exigem uma legislação futura, mas que não podem ser tidas por normas de eficácia limitada. O referido doutrinador,



então, deu a esse novo grupo a denominação de normas constitucionais de eficácia contida. Com base nas lições doutrinárias de José Afonso da Silva acerca das normas constitucionais de eficácia contida, informe qual das assertivas abaixo está incorreta:

- a) A interpositio legislatoris não se destina a lhes conferir plena eficácia.
- b) Os interesses advindos das matérias tratadas pelas normas constitucionais de eficácia contida receberam do legislador constituinte normatividade suficiente.
- c) Caso algumas dessas normas eventualmente contenham um conceito ético juridicizado, elas não poderão ser restringidas por meio de mera interpretação de um conceito desse.
- d) Presentes determinados pressupostos de fato, é possível, para essa categoria de normas, que se afaste a sua eficácia por meio da incidência de outras normas constitucionais, por exemplo, o estado de sítio.

Comentários

1. Gabarito: letra C.

I. Incorreta, pois a assertiva traz a definição do princípio da Conformidade Funcional. Também chamado de princípio da justeza ou correção funcional, esse princípio preconiza que os intérpretes não poderão chegar a uma posição que subverta, altere ou perturbe o esquema organizatório-funcional estabelecido na Constituição, como é o caso da separação dos poderes. É um critério orientador da atividade do intérprete, que busca corrigir desvios nas distribuições de competências entre os entes federados ou das funções dos diversos Poderes estabelecidas pelo constituinte originário.

Pelo Princípio da Concordância Prática ou da harmonização, os encarregados da interpretação deverão coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito de forma a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros. Tem como decorrência a igual dignidade dos bens constitucionais, sendo muito utilizado para solução de conflitos aparentes entre princípios fundamentais.

II. O Princípio da Força Normativa idealizado por Konrad Hesse, propugna que o intérprete, diante das possíveis alternativas, deve escolher aquela que garanta maior aplicabilidade e permanência das normas constitucionais. Segundo este postulado, devem ser valorizadas as soluções que possibilitem a atualização normativa, a eficácia e a perenidade da constituição, em que pese toda norma jurídica – constitucional ou não –, precisa de um mínimo de eficácia, sob pena de perder sua vigência e aplicabilidade.

Para Hesse, a Constituição está condicionada pela realidade histórica, entretanto, não é forjada apenas pela expressão da realidade política vigente. É em virtude mesmo de seu imperativo normativo, que ela ordena e ajusta a realidade política e social. Graças à pretensão de eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e conformação à realidade política e social. Determinada pela realidade social e, ao mesmo tempo, determinante em relação a ela, não se pode definir como fundamental nem a pura normatividade, nem a simples eficácia das condições sócio-políticas e econômicas. A força condicionante da realidade e a normatividade da Constituição podem ser diferenciadas; elas não podem, todavia, ser definitivamente separadas ou confundidas.

III. Correta, de acordo com a classificação do constitucionalista José Gomes Canotilho. Também chamado princípio da eficiência, encontra-se estritamente vinculado ao princípio da força normativa, configurando um sub princípio deste, e orienta os aplicadores da Constituição para



que, sempre que possível, interpretem suas normas em ordem a lhes otimizar a eficácia, sem alterar seu conteúdo. Em suma, no exercício da interpretação deve-se extrair da norma aquele sentido que forneça a máxima eficácia para a Constituição. É também chamado de Princípio da Imperatividade das normas constitucionais, segundo o qual as normas da Constituição são imperativas, de ordem pública e emana da vontade popular.

2. Gabarito: letra C.

Letra A) Correto: A figura do interpositio legislatoris na verdade significa a regulamentação de determinado tema, porém as normas de eficácia contida já estão aptas a produzir seus efeitos, porém estes podem ser restringidos por outra norma. Possuem aplicabilidade direta e imediata, mas possivelmente não integral.

Nesse sentido as normas constitucionais de eficácia contida possuem aplicabilidade direta e imediata, porém tanto uma norma infraconstitucional (1) como também constitucional (2) pode limitar a sua atuação, ou seja, possuem aplicabilidade possivelmente não integral.

Letra B) Correto: Conforme a explicação anterior as normas de eficácia contida por possuírem força suficiente para produzir os seus efeitos não necessitam de legislação regulamentadora para tal fim

Letra C) Errado: Conforme a explicação anterior as normas de eficácia contida podem possuir um alcance de seus efeitos restringidos por outra norma, porém algumas normas desta categoria já possuem a restrição identificada por conceito ético judicizado, ou seja, um valor mínimo que deverá ser preservado.

Letra D) Correto: Independente dos efeitos da norma de eficácia contida já estarem aptas a produzirem seus efeitos os mesmos poderão ser afastados em decorrência de outros mandamentos constitucionais, como é o caso da hipótese do estado de sítio. (CF/88, art. 139)



CAPÍTULO 7 – PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

O art. 1º diz que “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.

O parágrafo único diz que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos (indireta) ou diretamente, nos termos desta Constituição (direta)”. Nossa democracia é semidireta.

Portanto, a nossa forma de Estado é uma federação, mas isto é desde a república. Isto significa dizer que as unidades federativas são dotadas de autonomias políticas, possuindo competências próprias diretamente do texto constitucional.

Todavia, não pode ser dissolvido o vínculo federativo, sendo denominado este fenômeno de princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. Se houvesse o direito de secessão não seríamos federação, e sim uma confederação.

A forma federativa de estado é cláusula pétrea (art. 60, §4º, I, CF). O Brasil, além de federação, é uma república, ainda que antes fôssemos uma monarquia.

A mais notória característica da forma republicana é a forma de alternância de poder, mas a doutrina moderna diz que isto não basta. É necessário que haja ainda o princípio da igualdade. A república não admite privilégios em razão da estirpe.

Com isso, os representantes do poder passarão a exercer o poder em caráter eletivo, representativo, transitório e com responsabilidade, já que é preciso observar o princípio da igualdade.

O poder é exercido pelo povo, seja por meio da eleição de representantes, seja diretamente. Por isso, a nossa democracia é semidireta. Há a conjugação do princípio representativo com institutos da democracia direta: plebiscito, referendo e iniciativa popular.

1. FUNDAMENTOS

O art. 1º traz os fundamentos da República Federativa do Brasil:

1.1. SOBERANIA

O poder do Estado brasileiro, na ordem interna, é superior a todas as manifestações de poder que existam na ordem interna. E no âmbito internacional encontra-se em igualdade com os Estados independentes.

1.2. CIDADANIA

É mais do que conferir direitos políticos positivos e ativos ao cidadão. A expressão tem um sentido mais abrangente, significando o incentivo e o oferecimento de condições para que seja exercida uma participação política dos indivíduos. Deve haver o fomento pelo Poder Público em benefício do cidadão.

1.3. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Deixa claro que o Estado brasileiro não se funda em propriedade, a incorporações, organizações religiosas, etc., pois o fundamento é a pessoa humana.



1.4. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA

O Brasil é necessariamente um país capitalista, pois este é um desses fundamentos. Num embate entre o capital e o trabalho, deverá ser valorizado o trabalho.

1.5. PLURALISMO POLÍTICO

Isso quer dizer que a nossa própria Constituição é fruto de um conjunto ou uma combinação de ideologias e, portanto, é eclética, faz com que a nossa sociedade garanta no processo de formação da vontade geral de formação de leis que sejam respeitadas, ouvidas, e que participem as diversas correntes de pensamentos.

Poderes da República: O art. 2º define os poderes da República, os quais são independentes e harmônicos entre si, sendo eles o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Este artigo consagra o princípio da separação dos poderes.

2. OBJETIVOS

O art. 3º trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, sendo eles normas programáticas:

- Construir uma sociedade livre, justa e solidária;
- Garantir o desenvolvimento nacional;
- Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
- Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Ao ler os objetivos fundamentais, em síntese, o objetivo fundamental é garantir igualdade material entre os brasileiros. Trata-se de uma atuação positiva do Estado e, portanto, um direito de segunda dimensão.

3. PRINCÍPIOS NA ORDEM INTERNACIONAL

Segundo o art. 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

- Independência nacional;
- Prevalência dos direitos humanos;
- Autodeterminação dos povos;
- Não-intervenção;
- Igualdade entre os Estados;
- Defesa da paz;
- Solução pacífica dos conflitos;
- Repúdio ao terrorismo e ao racismo;
- Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
- Concessão de asilo político.

O parágrafo único diz que “A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações”.

Esses princípios são cobrados, mas é importante que se perceba que nenhum deles possui caráter absoluto, os quais devem observar a necessidade de ponderação.



O princípio da prevalência dos direitos humanos vai justificar que o Brasil apoie outro Estado na interferência num terceiro que estejam cometendo violações aos direitos humanos. Neste caso, os direitos humanos teriam prevalecido sobre a soberania do outro Estado.

4. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

4.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

EMENTA CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DE PARTE DO §1º DO ARTIGO 3º, BEM COMO DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.715, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004, DO ESTADO DE GOIÁS POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE HUMANA E DO QUANTO DISPOSTO NOS ARTS. 7º, XXXI; 23, II; 24, XIV; 37, VIII; 203, IV; e 227, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS. PROCEDÊNCIA. 1. A legislação sobre a proteção e a integração social das pessoas portadoras de deficiência é prevista constitucionalmente como de competência concorrente pelo artigo 24, XIV, da Constituição da República. Ao Estado é permitido o exercício da competência plena apenas na ausência de legislação federal que fixe as normas gerais (§ 3º). Existência, ao tempo da vigência da lei estadual impugnada, de lei federal acerca da proteção e da integração social das pessoas portadoras de deficiência. Legislação estadual com normas que contrastam com a normativa geral nacionalmente estabelecida. Inconstitucionalidade formal verificada. 2. A lei impugnada fragiliza o princípio constitucional da igualdade e a proteção à dignidade humana. Inconstitucionalidade material por apresentar infundados limites à sistemática de inclusão almejada e delineada pela Constituição da República. 3. Pedido da ação direta de inconstitucionalidade julgado procedente. ADI 4.573

Questões

1) (SEFAZ/RS – 2019) — À luz do disposto na CF, assinale a opção correta no que se refere aos princípios fundamentais da CF.

a) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário — poderes independentes e harmônicos entre si, integrantes da República Federativa do Brasil — não estão sujeitos ao princípio da indissolubilidade do vínculo federativo.

b) A República Federativa do Brasil é composta pela união entre os estados federados, municípios e o Distrito Federal, não podendo ser nem mesmo objeto de deliberação uma proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa.

c) A independência nacional como princípio significa a manifestação da soberania na ordem interna com superioridade a todas as demais manifestações de poder em âmbito global.

d) A solução pacífica dos conflitos é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.

e) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são poderes harmônicos e preservam o equilíbrio no exercício das funções estatais essenciais, coibindo o sistema de freios e contrapesos.

2) (TJ/PR - 2019 Titular de Serviços de Notas e de Registro) — No tocante às suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil possui alguns princípios fundamentais.

Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- a) O Brasil prima pela sua vinculação às grandes potências internacionais como meio de desenvolvimento nacional.
- b) Pode ser considerado um dever da República a busca pela integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina.
- c) Segundo a Constituição brasileira, é prioridade fundamental das relações diplomáticas a promoção do Mercosul.
- d) O Brasil repudia o terrorismo e o racismo e tem como política de Estado a negação de asilo político.
- e) A prevalência dos direitos humanos implica em seu conteúdo que cabe ao Estado buscar o bem de todos mediante a vedação dos preconceitos de origem, raça, sexo, cor e idade, permitindo, todavia, outras discriminações, tais como as relativas à orientação sexual (cuja vedação é remetida à legislação infraconstitucional).

Comentários

1. Gabarito: letra B: trata-se de uma união indissolúvel, ou seja, não se permite o direito de secessão. Sobre o tema, a CF até permite a medida extrema da intervenção federal, no caso de dissolução. E o §4º do art. 60 da CF trata a forma de Estado (federalismo, no nosso caso) como cláusula pétrea. Significa dizer que as Emendas, resultado do poder constituinte derivado reformador, não podem ser sequer tendentes a abolir a federação.

Na letra “A”, o pacto federativo é uma cláusula pétrea. Nem por Emenda pode ser abolido.

Na letra “C”, importante que se esclareça que não existe uma hierarquia entre as disposições constitucionais. Sobre o tema, dispõe a CF:

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

I - independência nacional;

II - prevalência dos direitos humanos;

V - igualdade entre os Estados;

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

Fiz citar outros princípios regentes nas relações internacionais. Será que o Brasil não deve se preocupar com a ordem global? Não há superioridade, requer-se a igualdade entre os Estados. E, mais, o Brasil, enquanto República, não pode desprezar os direitos humanos.

Não quero dizer que, obrigatoriamente, deva assinar um tratado internacional, mas o comando constitucional incentiva essa integração.

Na letra “D”, trata-se de um princípio que rege a nossa república em suas relações internacionais.

Na letra “E”, o sistema de freios e contrapesos é necessário para a manutenção da harmonia. É um balizador da desejada independência. Um poder não pode querer ser totalmente independente, desregrado do comando constitucional, por exemplo

2. Gabarito letra B de acordo com o art. 4º parágrafo único da CF/88:



Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

- I - independência nacional;
- II - prevalência dos direitos humanos;
- III - autodeterminação dos povos;
- IV - não-intervenção;
- V - igualdade entre os Estados;
- VI - defesa da paz;
- VII - solução pacífica dos conflitos;
- VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
- IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
- X - concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.



CAPÍTULO 8 – DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

1. TEORIA GERAL

1.1. ORIGEM DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Alguns autores dizem que os direitos fundamentais iniciaram pela Magna Carta de 1215. Nesta Magna Carta foi imposta uma limitação aos poderes do Rei João Sem Terra. Todavia, este marco é insuficiente para demonstrar o momento efetivo da ocorrência dos direitos fundamentais.

J.J. Canotilho diz que os direitos fundamentais surgiram efetivamente na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na França, e na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem dos EUA.

Essas primeiras declarações visam frear o Estado Absolutista. Os primeiros direitos fundamentais nasceram com a intenção de impor limites ao Estado, protegendo os direitos individuais, razão pela qual são denominados de direitos negativos, direitos de defesa, ou ainda de direitos de primeira geração.

Somente no século XX foi percebido que não basta apenas que o Estado não haja, sendo necessário também que o Estado exerça atividades positivas, garantindo igualdade material. Neste momento, passaram a exercer os direitos de segunda geração: direitos sociais, culturais e econômicos, sendo denominados também de direitos positivos, uma prestação estatal em benefício do indivíduo.

Teoria dos quatro *status* de Jellinek

Segundo Jellinek, há a teoria dos quatro *status*:

- Status passivo: o indivíduo está numa posição de subordinação dos poderes públicos, tendo deveres perante o Estado.
- Status negativo: o indivíduo é titular de direitos de liberdade, sem ingerências do Estado.
- Status positivo: o indivíduo é beneficiado pela atuação estatal, por meio de prestações positivas.
- Status ativo: o indivíduo passa a influir na vontade estatal, participando politicamente da opinião do Estado.

1.2. CONCEITO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Direito fundamental é o bem em si considerado. Ex.: direito à liberdade de locomoção.

Garantia fundamental é instrumento para proteção desse direito fundamental. Ex.: *habeas corpus*, que protege a liberdade de locomoção.

É inegável que o grau de democracia em um país mede-se precisamente pela expansão dos direitos fundamentais e por sua afirmação em juízo. Ou seja, os direitos humanos fundamentais servem de parâmetro de aferição do grau de democracia de uma sociedade. Não há que se falar em democracia sem o reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais.

Os direitos fundamentais possuem papel decisivo na sociedade porque é por meio dos direitos fundamentais que se avalia a legitimação de todos os poderes sociais, políticos e individuais. Onde quer que esses direitos padeçam de lesão, a Sociedade se acha enferma. Assim, os direitos fundamentais impõem à atuação estatal deveres de abstenção (Não dispor contra eles) e deveres de atuação (dispor para efetivá-los).



1.3. A RELAÇÃO ENTRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E OS DIREITOS HUMANOS

Os conceitos de direitos fundamentais e direitos humanos são interrelacionados e com dimensões próximas, pois aqueles compõe o grupo escolhido e eleito pelo legislador constitucional para constar no rol da Carta Política, enquanto os chamados direitos humanos estão protegidos em documentos internacionais – tratados, pactos e convenções – e fruto de atuação pelas pessoas jurídicas de direito internacional.

- Direitos humanos: têm base jusnaturalista. Os direitos humanos são pertencentes ao homem universalmente considerado, não precisando estar consagrado em qualquer ordenamento jurídico. Pertencem ao homem por ser uma pessoa humana.
- Direitos fundamentais: refere-se a direitos relacionados às pessoas inscritos dentro dos textos normativos de cada Estado. Eles vigoram numa determinada ordem jurídica.
- Direitos do homem: é uma expressão jusnaturalista que conceitua direitos naturais aptos a proteção global do homem, carecendo estes direitos de qualquer positivação, seja nacional ou internacional.

A partir do momento em que esses "direitos do homem" passaram a ser positivados nas constituições contemporâneas, passaram a ser denominados "direitos fundamentais". Quando esses direitos previstos nas normas internas passaram a ser regulados em tratados internacionais, seja no plano global, seja no plano regional, passaram a receber o nome de "direitos humanos".

Vale atentar que há 4 teorias para fundamentar os direitos do homem:

- para os jusnaturalistas: os direitos do homem são imperativos do direito natural, anteriores e superiores à vontade do Estado.
- para os positivistas: os direitos do homem são faculdades outorgadas pela lei e reguladas por ela.
- para os idealistas: os direitos humanos são ideias, princípios abstratos que a realidade vai acolhendo ao longo do tempo.
- para os realistas: seriam o resultado direto de lutas sociais e políticas.

Nesse sentido, enquanto os direitos humanos possuem uma proteção universal disposta em documentos internacionais, os direitos fundamentais estão delineados na Constituição Federal, que, inclusive, reconhece a complementariedade entre as duas categorias de direitos.

1.4. CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

- Imprescritibilidade: o não exercício do direito fundamental não faz com que ele desapareça. Em caso de violação, as ações que visem reparar um direito fundamental tem caráter imprescritível, dada esta característica.
- Inalienabilidade: não é possível vender o direito fundamental a outrem.
- Irrenunciabilidade: não se renuncia em caráter perene.
- Inviolabilidade: não é possível que o direito fundamental seja violado.



- Universalidade: os direitos fundamentais é de titularidade de todos os indivíduos.
- Relatividade (Ilimitabilidade): não existem direitos fundamentais de caráter absoluto. Os direitos fundamentais são de caráter aberto, admitindo a previsão de novos direitos fundamentais não previstos, quando da elaboração da Constituição. A própria CF, no art. 5º, §2º, adota esta característica de caráter aberto dos direitos fundamentais. Existe uma exceção: O direito à proibição de tortura e do tratamento desumano ou degradante possui um caráter absoluto, considerado o disposto no sistema nacional e internacional. A tortura é prática vedada em toda e qualquer situação, havendo de se reconhecer o direito à sua proibição como verdadeiro direito absoluto.

1.5. DIMENSÃO OBJETIVA E DIMENSÃO SUBJETIVA

Os direitos fundamentais possuem uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva:

- dimensão subjetiva: tem a ver com o sujeito da relação jurídica, sendo o indivíduo em face do poder público ou em face de outro indivíduo.
- dimensão objetiva: tem a ver com um conjunto de valores básicos de conformação do Estado, devendo ser analisados os direitos fundamentais como parâmetro da forma que o Estado deverá agir. Com isso, os direitos fundamentais passam a ter uma eficácia irradiante. Isto é, é a capacidade de orientar o exercício da atividade do poder público, fazendo ele atuar daquela determinada forma.

8.1.6. Dimensões dos direitos fundamentais

- Direitos de 1ª geração (Liberdade): princípio da liberdade, ganhando o contorno de direitos civis e políticos, impondo restrições à atuação do Estado. O direito clássico é o direito de propriedade. São os direitos de liberdade (status negativo) e direitos políticos (status ativo).
- Direitos de 2ª geração (Igualdade): exige um agir do Estado, estabelecendo um direito de igualdade material. São os direitos econômicos, sociais e culturais. Exige do Estado um fazer: saúde, trabalho e educação. São os direitos prestacionais (direitos positivos).
- Direitos de 3ª geração (Fraternidade): tem a ver com o princípio da fraternidade, protegendo direitos de titularidade coletiva, tais como direito ao meio ambiente e paz. Estão aqui os direitos difusos.
- Direitos de 4ª geração: Paulo Bonavides diz que é o direito à democracia, informação e pluralismo político. Para Norberto Bobbio, é direito de 4ª dimensão a decorrência da engenharia genética, pois ela coloca em risco a própria existência humana, quando é possível fazer a manipulação do patrimônio genético.
- Direito de 5ª geração: Paulo Bonavides diz que a paz seria um direito de quinta geração. No entanto, há autores que defendem seriam de 5ª geração os direitos advindos da realidade virtual, em função a preocupação do sistema constitucional com a difusão e desenvolvimento da cibernética na atualidade, o que envolve a internacionalização da jurisdição constitucional em virtude do rompimento das fronteiras físicas através da "grande rede".
- Direito de 6ª geração: Segundo Uadi Lammego Bulos, a sexta dimensão alcança democracia, pluralismo político e o direito à informação.



Também há doutrina diversa mencionando que a sexta geração seria referente ao direito à água potável.

- Direito de 7ª geração: Não há entendimento consolidado acerca de sétima geração, mas já há apontamentos doutrinários defendendo que se trata do direito à internet, com a crítica que a internet seria meio para alcançar certos direitos, e não uma nova dimensão.

O surgimento de uma nova dimensão não implica o fim da geração antecedente.

1.6. DESTINATÁRIO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Os destinatários dos direitos fundamentais podem ser as pessoas naturais, as pessoas jurídicas e até mesmo o Estado.

Para se ter uma ideia, o direito de propriedade é garantido a todos eles, inclusive ao Estado.

Há direitos que não se enquadram em todos os destinatários, tal como ocorre com o direito à locomoção. Todavia, também há direitos fundamentais próprios do Estado, como é o direito à requisição administrativa.

1.7. VETORES DE EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Em regra, os direitos fundamentais se aplicam entre as relações verticais. Todavia, é possível que os direitos fundamentais se apliquem entre particulares, por meio da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais (ou privada ou externa).

Eficácia horizontal dos direitos fundamentais, também chamada de Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, eficácia provada dos direitos fundamentais ou eficácia externa dos direitos fundamentais É A INCIDÊNCIA E APLICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES PRIVADAS – Indivíduo x Indivíduo.

1.8. RESTRIÇÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E TEORIA DOS LIMITES DOS LIMITES

É admissível que os direitos fundamentais comportem restrições, inclusive de caráter legal, pois não têm caráter absoluto. É possível que a CF estipule que os direitos fundamentais serão restringidos por meio de uma lei ordinária.

Exemplo disso é o direito de profissão que será exercido nos termos da lei.

Esta reserva legal pode ser qualificada, restringido a que termos esta lei deverá atuar, conforme ocorre com o art. 5º, XII, em relação à interceptação telefônica.

A restrição dos direitos fundamentais não pode ser total, pois, do contrário, haveria restrição ao núcleo duro do direito e o desnaturaria, violando a proporcionalidade.

Os direitos fundamentais possuem um limite interno que contém a essência do direito fundamental, o qual não pode ser restringido.

1.9. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Em caso de colisão dos direitos fundamentais, o que se resolve é através da ponderação. Isso porque não há hierarquia entre direitos fundamentais, razão pela qual o intérprete deve se valer da técnica de ponderação.

Cada caso concreto é específico, podendo prevalecer o direito X em detrimento do Y e noutro caso o contrário. Mas sempre deve-se tentar compatibilizar os direitos sem gerar sacrifício do direito fundamental.



Cabe ressaltar que colisão não se confunde com concorrência de direitos fundamentais. Haverá concorrência quando se possa exercer, ao mesmo tempo, dois ou mais direitos fundamentais (afluxo de direitos).

A teoria da proporcionalidade é o instrumento através do qual se operacionaliza o método da ponderação entre os princípios que objetiva solucionar as colisões entre princípios, e não é a técnica utilizada para fins de concorrência de direitos fundamentais.

1.10. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL (ECI)

Surgido na Colômbia, em 1997, o ECI ocorre quando verifica-se a existência de um quadro de violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, causado pela inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura, de modo que apenas transformações estruturais da atuação do Poder Público e a atuação de uma pluralidade de autoridades podem modificar a situação inconstitucional.

São pressupostos do ECI:

- violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais;
- inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura;
- situação que exige a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de autoridades para resolver o problema.

O ECI é uma técnica que não está expressamente prevista na Constituição ou em qualquer outro instrumento normativo, mas que só deve ser manejada em hipóteses excepcionais.

No Brasil, o STF reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro vive um "Estado de Coisas Inconstitucional", pois as penas aplicadas acabam sendo penas cruéis e desumanas. No entanto, o STF entendeu que não pode substituir o papel do Legislativo e do Executivo na consecução de suas tarefas próprias, visto que não lhe incumbe definir o conteúdo próprio dessas políticas.

Por outro lado, é lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, não podendo falar em princípio da reserva do possível, tampouco violação à separação de poderes (Inf. 794).

No informativo 798, o STF, concedeu parcialmente medida cautelar para:

- haver a implementação da audiência de custódia no prazo máximo de 90 dias;
- determinar que a União libere o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional para utilização na finalidade para a qual foi criado.

1.11. TEORIA INTERNA E EXTERNA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Em que pese seja admitido excepcionalmente o balanceamento ou sopesamento de direitos fundamentais, a ponto de vedar qualquer entendimento que vise contrariá-lo indefinidamente, tais direitos não são absolutos.

1.11.1. TEORIA INTERNA

O próprio direito traz consigo suas próprias restrições. O tema guarda íntima conexão com a responsabilidade por abuso do direito. Não existe outros limites que não aqueles que estão na lei e na constituição. Os direitos fundamentais e a extensão deles, se delimitados por ela, não podem sofrer sopesamento, quando determinado indivíduo exercita algo garantido por um direito fundamental, a garantia é definitiva, não apenas *prima facie*.



1.11.2. TEORIA EXTERNA

Segundo Virgílio Afonso da Silva, as restrições, qualquer que seja a sua natureza, não têm qualquer influência no conteúdo do direito. Direito e restrição não se confundem, devendo o intérprete se valer de normas de ponderação, como a proporcionalidade. O direito deve ser pensado com base na sua utilidade (pensamento utilitarista), chegando-se, assim, à conclusão de que, com exceção da proibição da tortura e da escravidão, os direitos fundamentais, são relativos. Em casos concretos, apenas o sopesamento ou a regra da proporcionalidade podem estabelecer o que realmente vale, com a definição do conteúdo do direito em si “a partir de fora”. Para tal teoria, as restrições, seja qual for sua natureza, não influenciam o conteúdo do direito, embora possam restringir o exercício deste, no caso concreto. Caso haja colisão entre princípios, um deles tem de ceder em favor do outro sem serem afetadas sua extensão *prima facie* nem sua validade.

No Brasil, a maioria da doutrina, adota a teoria externa dos direitos fundamentais, já que se admite o sopesamento de direitos fundamentais. Como a teoria interna não admite a ponderação ou o sopesamento, esta teoria não se mostra compatível com o entendimento firmado no Brasil.

2. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

2.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Uma decisão judicial determinou a retirada de matéria de “blog” jornalístico, bem como a proibição de novas publicações, por haver considerado a notícia ofensiva à honra de delegado da polícia federal. Essa decisão afronta o que o STF decidiu na ADPF 130/DF, que julgou não recepcionada a Lei de Imprensa. A ADPF 130/DF pode ser utilizada como parâmetro para ajuizamento de reclamação que verse sobre conflito entre a liberdade de expressão e de informação e a tutela das garantias individuais relativas aos direitos de personalidade. A determinação de retirada de matéria jornalística afronta a liberdade de expressão e de informação, além de constituir censura prévia. Essas liberdades ostentam preferência em relação ao direito à intimidade, ainda que a matéria tenha sido redigida em tom crítico. O Supremo assumiu, mediante reclamação, papel relevante em favor da liberdade de expressão, para derrotar uma cultura censória e autoritária que começava a se projetar no Judiciário. (STF. 1ª Turma. Rcl 28747/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 5/6/2018).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – JUDICIÁRIO – INTERVENÇÃO – EXCEPCIONALIDADE. Ante excepcionalidade, verificada pelas instâncias ordinárias a partir do exame de quadro fático, é possível a intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas direcionadas à concretização de direitos fundamentais, especialmente considerado o estado de coisas inconstitucional do sistema de custódia brasileiro. Precedente: recurso extraordinário nº 592.581, julgado no Pleno sob a sistemática da repercussão geral – Tema nº 220 –, relator o ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de fevereiro de 2016. (ARE 1192016 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

2.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Responsabilidade civil. Obra literária. Figura pública. Informação inverossímil. Abuso do direito de expressão e de informação. Direito à retratação e ao



esclarecimento da verdade. Cabimento. Julgamento da ADPF n. 130/DF. Não recepção da Lei de Imprensa. Inicialmente cumpre salientar que a partir do julgamento da ADPF n. 130/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, a Lei n. 5.250/1967 (Lei de Imprensa) foi considerada, em sua integralidade, não recepcionada pela Constituição da República de 1988. Contudo, os direitos ao esclarecimento da verdade, à retificação da informação inverídica ou à retratação não foram banidos do ordenamento jurídico brasileiro, pois eles ainda encontram amparo na legislação civil vigente. O art. 927 do Código Civil impõe àquele que, cometendo ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo, ao passo que o art. 944 do mesmo diploma legal determina que a indenização seja medida pela extensão do dano. Isso significa que a principal função da indenização é promover a reparação da vítima, anulando, ao máximo, os efeitos do dano. Nessa linha, o Poder Judiciário deve reformular sua visão e dar um passo à frente, abrandando a natureza essencialmente patrimonialista da responsabilidade civil e buscando a reparação do dano, em toda a sua extensão. Assim, imperativo o reconhecimento da subsistência do direito de retratação fundamentado na legislação civil (arts. 927 e 944 do CC), mesmo após o julgamento da ADPF n. 130/DF, preservando-se a finalidade e a efetividade da responsabilidade civil, notadamente nos casos em que o magistrado, sopesando a necessidade de impor a condenação de publicação da decisão condenatória, vislumbre que a medida é proporcional e razoável no caso concreto. Portanto, na hipótese, a publicação da petição inicial e do acórdão condenatório nas próximas edições do livro não impõe, de um lado, uma obrigação excessiva, onerosa, desarrazoada ou desproporcional aos réus, pois tal publicação deverá se dar nas edições que vierem a ser editadas. Não se trata, ainda, de censura ou controle prévio dos meios de comunicação social e da liberdade de expressão, pois não se está impondo nenhuma proibição de comercialização da obra literária, nem mesmo se determinando que as edições até então produzidas sejam recolhidas ou destruídas, o que seria de todo contrário ao ordenamento jurídico, mas satisfaz aos anseios da vítima, que terá a certeza de que os leitores da obra literária terão consciência de que os trechos que a ele se referem foram considerados ofensivos à sua honra. (REsp 1.771.866-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Questões

1) (MPE/PR – 2019) — Sobre direitos fundamentais, é correta a afirmação:

a) A caracterização de um direito como fundamental não é determinada apenas pela relevância do bem jurídico tutelado por seus predicados intrínsecos, mas também pela relevância que é dada a esse bem jurídico pelo constituinte, mediante atribuição da hierarquia correspondente (expressa ou implicitamente) e do regime jurídico-constitucional assegurado às normas de direitos fundamentais.

b) O princípio da universalidade significa que todas as pessoas, pelo fato de serem pessoas, são titulares dos direitos fundamentais consagrados na Constituição, sendo ilegítima qualquer distinção entre nacionais e estrangeiros.

c) O desfrute dos direitos fundamentais por parte dos brasileiros depende da efetiva residência em território brasileiro, pois a titularidade não depende exclusivamente do vínculo jurídico da nacionalidade.

d) As pessoas jurídicas de direito público são titulares de direitos fundamentais apenas de cunho processual (por exemplo, o contraditório e a ampla defesa), sendo incompatíveis com sua natureza direitos de natureza estritamente material.

e) Por serem dotadas de eficácia plena e de aplicabilidade direta, as normas de direitos fundamentais não estão sujeitas à regulamentação, sendo imunes à imposição de restrições e limitações.



2) (TJ/SC – 2019) — A respeito da eficácia mediata dos direitos fundamentais, assinale a opção correta segundo a doutrina e a jurisprudência do STF.

- a) A eficácia mediata dos direitos fundamentais independe da atuação do Estado.
- b) De acordo com o STF, as normas de direitos fundamentais que instituem procedimentos têm eficácia mediata.
- c) Nas relações privadas, a eficácia dos direitos fundamentais é necessariamente mediata.
- d) A eficácia mediata desobriga o juiz de observar o efeito irradiante dos direitos fundamentais no caso concreto.
- e) A eficácia mediata dos direitos fundamentais dirige-se, primeiramente, ao legislador.

Gabarito

1. Gabarito: letra A.

a) Correto. consoante a doutrina de J. J. Gomes Canotilho, para quem Alexy aponta para a proteção dos direitos fundamentais em duplo sentido: material (relevância do bem jurídico tutelado por seus predicados intrínsecos) e formal (relevância dada a esse bem pelo constituinte). Nesse sentido, Canotilho distingue fundamentalidade formal e a fundamentalidade material.

A fundamentalidade formal é associada à constitucionalização, em quatro dimensões relevantes: (i) as normas consagradoras de direitos fundamentais são colocadas no topo da hierarquia das normas; (ii) essas normas submetem-se a procedimentos mais rígidos de modificação; (iii) constituem, muitas vezes, limites materiais à própria revisão; (iv) são normas dotadas de vinculação imediata dos poderes públicos, como parâmetros materiais de escolhas e decisões.

Já a fundamentalidade material, para Canotilho, insinua que o conteúdo dos direitos fundamentais é "decisivamente constitutivo das estruturas básicas do Estado e da sociedade". Por outro lado,

só a ideia de fundamentalidade material pode fornecer suporte para: (1) a abertura da constituição a outros direitos, também fundamentais, mas não constitucionalizados, isto é, direitos materialmente mas não formalmente materiais (...); (2) a aplicação a estes direitos só materialmente constitucionais de alguns aspectos do regime jurídico inerente à fundamentalidade formal; (3) a abertura a novos direitos fundamentais (Jorge Miranda). Daí o falar-se, nos sentidos (1) e (3), em cláusula aberta ou em princípio da não tipicidade dos direitos fundamentais (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 378-379)

b) Errado. De acordo com o princípio da universalidade, todas as pessoas, pelo fato de serem pessoas, são titulares dos direitos fundamentais consagrados na Constituição, conforme bem explica Ingo Wolfgang Sarlet, o que por sua vez,

não significa que não possa haver diferenças a serem consideradas, inclusive, em alguns casos, por força do próprio princípio da igualdade, além de exceções expressamente estabelecidas pela Constituição, como dá conta a distinção entre brasileiro nato e naturalizado, algumas distinções relativas aos estrangeiros, entre



outras (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 210)

Com efeito, o Supremo, com base no princípio da universalidade dos direitos fundamentais, pronunciou-se no sentido de que os estrangeiros em trânsito no território federal - não somente os domiciliados, conforme indicado no art. 5º, caput da CF - são destinatários das garantias previstas na Constituição Federal que lhe assegurem o status de liberdade e do devido processo legal:

O súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do status libertatis e a observância, pelo Poder Público, da cláusula constitucional do devido process. O súdito estrangeiro, mesmo o não domiciliado no Brasil, tem plena legitimidade para impetrar o remédio constitucional do habeas corpus, em ordem a tornar efetivo, nas hipóteses de persecução penal, o direito subjetivo, de que também é titular, à observância e ao integral respeito, por parte do Estado, das prerrogativas que compõem e dão significado à cláusula do devido processo legal (HC 94.477, rel. min. Gilmar Mendes, julg. 6.9.2011, 2ª Turma).

Alguns desses direitos, entretanto, como a ação popular, são restritos aos cidadãos brasileiros, ou portugueses equiparados (art. 12, § 1º, CF) que devem comprovar, inclusive, essa condição, que dentre outros requisitos, exige a regularidade eleitoral (alistamento, comprovante de votação).

c) Errado. O desfrute dos direitos fundamentais não se sujeita a domicílio, condição social ou vínculo jurídico de nacionalidade, conforme já se pronunciou o Supremo. Ademais, a Constituição estabeleceu a igualdade entre todos os brasileiros, salvos os casos expressamente previstos na própria Carta Política:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

Art. 12.....

.....

§ 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

d) Errado. Se inicialmente os direitos fundamentais surgiram como tendo titulares as pessoas naturais, pessoas físicas, atualmente o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido direitos fundamentais às pessoas jurídicas, tais como o direito ao nome e à honra, e nesse sentido, há doutrina que defende a existência de direitos de natureza material em favor de pessoa jurídica de direito público, como o direito de propriedade e a imunidade recíproca de impostos (art. 150, VI, "a", CF). O STF assentou ainda que pessoa jurídica pode ser vítima de difamação, mas não de injúria ou calúnia (RHC 83.091/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 26/9/2003).

Entretanto, há autores, como Ricardo Duarte Júnior, que discordam desse posicionamento, entendendo que os eventuais conflitos de direitos entre entes públicos na realidade seriam conflitos de competência e não de direitos fundamentais, ou garantias institucionais inerentes ao órgão ou entidade. Mas o povo adora inventar, então fique com esse posicionamento da banca.



e) Errado. As normas que consagram os direitos e garantias fundamentais têm, em regra, aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º). Entretanto, nem todas as normas definidoras de direitos e garantias individuais possuem eficácia plena ou imediata. Algumas constituem normas de eficácia contida ou restringível, que podem ser restringidas por norma infraconstitucional ou mesmo eficácia limitada, que necessitam de concretização normativa ou da Administração.

Art. 5º

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Ingo Wolfgang Sarlet, ao enfrentar esse controverso tema, afirma que a inovação mais significativa da CF/88 no campo dos direitos fundamentais foi justamente o §1º do art. 5º, de acordo com o qual as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicabilidade imediata, excluindo, em princípio, o caráter programático destes preceitos, mas não há consenso quanto ao alcance desse dispositivo. O que é certo é a consagração do status jurídico diferenciado e reforçado dos direitos fundamentais na Constituição, inclusive com a sua inclusão no rol das cláusulas pétreas, do art. 60, § 4º. (SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 10 ed. rev. atual. e ampliada. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2009. p. 66).

2. Gabarito: letra E: segundo Paulo Roberto Lyrio Pimenta, as normas programáticas em sentido estrito "mencionam uma legislação futura para a atuação positiva do programa que veiculam, ou seja, preveem um programa, exigindo que o legislador o implemente por meio de lei. Como exemplo dessa modalidade, podem-se citar as normas veiculadas pelos arts. 186, 174, §1º, e 173, §4º, da Constituição Federal"

a) Errado. Depende principalmente, da atuação do legislador.

b) Errado. A eficácia mediata ou imediata dos direitos fundamentais está ligada ao caráter programático ou de eficácia limitada da norma constitucional, e não necessariamente está vinculada a procedimentos. Por exemplo, a norma que estabelece o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LIV e LV, CF/1988) possui eficácia plena, e aplicabilidade imediata.

c) Errado. A chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais diz respeito à incidência desses direitos nas relações entre particulares, pessoas físicas e também jurídicas. Desse modo, as pessoas físicas e jurídicas privadas devem igualmente observar e respeitar entre si o direito à honra, à vida, à imagem, à integridade, à intimidade, à inviolabilidade de comunicações, à inviolabilidade de domicílio e diversos outros, podendo tais direitos, caso violados, serem exigidos judicialmente.

A eficácia horizontal é classificada pela doutrina também como eficácia privada, externa, reflexa, particular ou civil dos direitos fundamentais. Esses direitos devem ser observados por todos os atores sociais. Isso decorre inclusive da chamada eficácia irradiante dos direitos fundamentais segundo a qual os direitos e garantias constitucionais devem conformar a atuação de todos os Poderes de Estado, mas também as relações entre particulares (JÚNIOR, José Eliaci Nogueira Diógenes. Da Eficácia dos Direitos Fundamentais Aplicada às Redações Privadas. Universo Jurídico, Juiz de Fora, 2012).

A jurisprudência do STF vem consagrando a eficácia imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas em diversos julgados, como a proibição da revista íntima de mulheres em fábricas de lingerie (RE 160.222-8); a vedação da exclusão de associado de cooperativa sem o exercício do direito de defesa (RE 158.215-4); a discriminação de



empregado brasileiro em relação ao francês na empresa aérea "Air France", mesmo realizando atividades análogas ou idênticas (RE 161.243-6).

d) Errado. Dentro da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, a chamada eficácia irradiante conforma a atuação dos Poderes do Estado, atribuindo-lhes eficácia dirigente, tanto para o Poder Legislativo na elaboração de suas leis quanto para a Administração Pública, para que implemente políticas que promovam e salvaguardem os direitos fundamentais, além do próprio Poder Judiciário, que ao dirimir as querelas entre particulares ou entre um particular e o Estado, deve ter em vista a proteção dos direitos fundamentais, podendo mesmo judicializar a positivação de alguns direitos sociais, ditos "mediatos", como por exemplo, a determinação do STF de que é dever do Estado a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, CF).



CAPÍTULO 9 – DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

Os direitos fundamentais, segundo a CF/88, têm aplicação imediata (art. 5º, §1º).

Embora esta seja a regra, existem princípios ou direitos fundamentais que estão em normas de eficácia limitada, razão pela qual dependem de uma atuação do Poder Público.

Os direitos fundamentais são considerados uma categoria aberta. Isto significa que o rol de direitos fundamentais não é exaustivo. Esta não exaustividade está previsto no art. 5º, §2º da CF.

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet, os direitos fundamentais podem ter uma amplitude muito maior que a do universo dos direitos humanos.

Além disso, podemos dizer que os direitos fundamentais têm um caráter mutável quanto ao seu alcance e sentido. Exemplo disso é o direito à propriedade na Revolução Francesa, o qual é muito diferente do que é nos dias de hoje.

1. RESTRIÇÕES E SUSPENSÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

A CF/88 prevê basicamente duas situações em que é possível a restrição dos direitos fundamentais:

1.1. ESTADO DE DEFESA

É possível que haja restrições aos direitos de reunião, sigilo da correspondência, sigilo das comunicações telefônica e telegráfica.

1.2. ESTADO DE SÍTIO

Acontece basicamente em duas situações:

1.2.1. INCISO I DO ART. 137

Comoção grave de repercussão nacional ou em caso de ineficácia do estado de defesa: as medidas que poderão ser tomadas são: obrigação de permanência em determinada localidade, detenção em edifício não destinado a acusados por crime comum, restrição à violabilidade de correspondências, violação aos sigilos das comunicações, restrição à liberdade de imprensa, suspensão da liberdade de reunião, busca apreensão em domicílio, requisição de bens, etc. A restrição é maior no estado de sítio em relação ao estado de defesa.

1.2.2. GUERRA EXTERNA OU RESPOSTA À AGRESSÃO ARMADA ESTRANGEIRA (INCISO II DO ART. 137)

A CF/88 não trata sobre os direitos que podem ser restringidos, razão pela qual quaisquer deles podem ser restringidos ou suspensos. A CF/88 prevê inclusive o caso de pena de morte para a situação de guerra declarada.

Essas medidas se caracterizam pelo fato de poderem ser tomadas sem necessidade de uma prévia autorização do Poder Judiciário. Nestes casos, o controle judiciário é *a posteriori*, motivo pelo qual poderá ser provocado para fiscalizar a validade das medidas tomadas no estado de defesa ou estado de sítio.

2. TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988.

Com a Emenda Constitucional 45/2004, os tratados sobre Direitos Humanos que forem aprovados pelo Congresso Nacional pelo procedimento previsto no art.5º, §3º, da CF serão equivalentes a uma emenda constitucional.



Até o momento, temos três tratados de direitos humanos aprovado nos termos do art. 5º, §3º da CF e equivalentes a emendas constitucionais: 1. A convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência; 2. O Protocolo dos Direitos das Pessoas com Deficiência; 3. O Tratado de Marraqueche

Os tratados anteriores sobre direitos humanos passaram a receber a natureza supralegal, ou seja, não possuem status constitucional, mas sim infra-constitucional e acima das leis ordinárias e complementares.

A natureza supra-legal dos tratados sobre direitos humanos decorreria do próprio art.5º, §3º, da CF, o qual os teria distinguido dos demais tratados, a exigir uma nova interpretação sobre a matéria, que prestigiasse a distinção feita pela norma.

3. TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

A EC 45 não se limitou a introduzir o §3º, inserindo também o §4º do art. 5º, dizendo que “O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão”.

O TPI surgiu em 2002, sendo a primeira corte internacional de caráter permanente, criado pelo Estatuto de Roma. O TPI é competente para julgar crimes de genocídio, de guerra, contra a humanidade e de agressão de um país ao outro. São crimes com importância supranacional, global.

O Brasil, apesar de se submeter ao TPI, deve exigir que o Tribunal observe o princípio da complementaridade. Este princípio estabelece que a competência da Corte Internacional não se sobrepõe à jurisdição penal dos Estados soberanos.

Isso significa dizer que só haverá intervenção do TPI em situações gravíssimas, quando o país não se mostrou capaz de processar aquele crime.

Se o ditador comete um crime de genocídio, naquele país dificilmente haverá disposição política para puni-lo, de modo que caberia ao TPI exercer a sua jurisdição.

Alguns constitucionalistas dizem que o TPI não é constitucional, defendendo a inconstitucionalidade do Estatuto de Roma. Dentre várias ideias colocadas, está a pena de prisão perpétua trazida pelo TPI, enquanto a CF/88 veda.

O Estatuto de Roma não tipifica crimes e não estabelece penalidades, motivo pelo qual haveria violação ao princípio da legalidade.

O Estatuto também prevê a entrega de brasileiros para o TPI julgar. Neste caso, haveria violação à vedação de entrega de extradição de brasileiros natos.

Não há declaração do STF, dizendo que é inconstitucional.

Primeiramente, entrega ao TPI e extradição não se confundem. A extradição é a entrega de uma pessoa para outro país soberano julgá-la. O brasileiro nato não pode ser extraditado. No entanto, o TPI não é um Estado soberano, e sim um organismo internacional, razão pela qual haveria uma entrega, não encontrando óbice na Constituição.

4. ANÁLISE DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DE 1988

O texto do *caput* assegura esses direitos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil.

A primeira leitura parece que os estrangeiros que não possuem residência no Brasil não estariam abrangidos por esses direitos, mas não é essa a interpretação que se dá. É pacífico que os direitos fundamentais se estendem aos estrangeiros que não residem no país.



4.1. DIREITO À VIDA

A lei protege a vida de uma forma geral: extrauterina e intrauterina (ex.: proibição da prática do aborto, salvo no caso de estupro ou se a saúde da gestante exigir-lo).

O direito à vida não seria apenas no aspecto biológico (direito à integridade psíquica e física), tendo caráter também de condições materiais e espirituais mínimas necessárias a uma existência digna (dignidade humana). Ou seja, não basta sobreviver, é preciso viver com dignidade.

Com relação ao aborto, o STF já entendeu que não há crime de aborto quando a interrupção da gravidez se dá com feto anencéfalo (antecipação terapêutica do parto). Houve aqui um conflito de direitos fundamentais: vida intrauterina x integridade física e psíquica da gestante. Neste caso, o Supremo entendeu que prevaleceria os direitos da gestante em detrimento do feto anencéfalo.

Um dos argumentos que a Suprema Corte é de que não há chance de vida extrauterina do feto anencéfalo, fazendo prevalecer o direito à dignidade e à saúde da gestante.

Ainda em relação ao direito à vida, o STF entendeu que é legal o uso, para fins de pesquisa, de células-tronco embrionárias, produzidas em fertilização in vitro, desde que não tenham sido utilizados. Se for observadas as condições da Lei 11.105, é possível a utilização das células tronco embrionárias.

4.2. DIREITO À LIBERDADE

Quando falamos em liberdade, é preciso destacar que a liberdade não se trata apenas da liberdade física, de locomoção, mas também de crença, de pensamento, de reunião, de associação, etc. e que pressupõe o direito de não se reunir e de não se associar, mas tudo isso falaremos mais a frente.

A liberdade de expressão está em alguns incisos do art. 5º.

No inciso IV, a CF estabelece que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, o pensamento é livre, mas é vedado o anonimato.

Para assegurar a liberdade de pensamento, que é uma liberdade de expressão, o STF já deu máxima efetividade a este princípio, decidindo que não é necessário diploma de jornalismo para o indivíduo exercer a profissão de jornalista. Para o STF, essas exigências contrariam a liberdade de imprensa e a livre manifestação do pensamento, que é um direito fundamental.

Nesta mesma ideia de ser livre a manifestação do pensamento, o STF afastou a necessidade de autorização prévia da pessoa biografada ou de seus familiares, quando morto, para que sejam escritas e publicadas obras bibliográficas ou audiovisuais.

Mas lembremos: é vedado o anonimato! Qual é a razão para isso?

Simple: possibilitar a responsabilização de quem causar dano a outrem.

Como consequência disso, não é possível do acolhimento de denúncias anônimas ou apócrifas.

Em verdade, o Poder Público não admite que com base exclusivamente em denúncia anônima se instaure investigações criminais. Primeiro, é necessário promover um procedimento preliminar de averiguação das informações para somente então se instaurar o inquérito policial.

Com relação ao processo administrativo, a jurisprudência do STJ já decidiu que não há ilegalidade na instauração de processo administrativo com fundamento em denúncia anônima, por conta do poder-dever de autotutela imposto à Administração e, por via de consequência, ao administrador público (STJ, 2013).

O art. 5º, inciso V, dirá que é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.



Trata-se, segundo o STF, de norma de eficácia plena e de aplicabilidade imediata, conforme classificação de José Afonso da Silva. Para Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, é uma norma de pronta aplicação, conforme a obra doutrinária conjunta.

O constituinte está dizendo que é assegurado o direito de resposta nas mesmas condições em que foi promovido o agravo. No entanto, o fato de exercer o direito de resposta não inviabiliza o direito de obter indenização por dano material, moral ou à imagem. A CF diz que isto é cumulativo.

Cabe ressaltar que o Supremo já afirmou que o direito de resposta deve ser assegurado, sendo necessário que a pessoa demonstre ofensa experimentada.

O direito de resposta foi regulamentado pela Lei 13.188/15, estabelecendo que o direito de resposta é proporcional e gratuito pelo sujeito ofendido. O prazo decadencial para o exercício do direito de resposta é de 60 dias, contados da divulgação da notícia.

Com base nessa vedação ao anonimato, o STF decidiu que o Tribunal de Contas da União não pode manter o sigilo da autoria de denúncias apresentadas a ele. Isso porque, neste caso, é preciso assegurar o direito de resposta que o ofendido sofreu.

Já foi decidido que não cabe reclamação para o STF contra sentença que julgou improcedente pedido de direito de resposta sob o fundamento de que não houve, no caso concreto, ofensa. Esta sentença não afronta a autoridade da decisão do STF no julgamento da ADPF 130/DF.

Como a sentença não violou nenhuma decisão do STF proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o que se percebe é que o autor, por meio da reclamação, deseja que o Supremo examine se a sentença afrontou, ou não, o art. 5º, V, da CF/88. Para isso, seria necessário reexaminar matéria de fato, o que não é possível em reclamação, que se presta unicamente a preservar a autoridade de decisão do STF. Ademais, isso significaria o exame per saltum, ou seja, "pulando-se" as instâncias recursais do ato impugnado diretamente à luz do art. 5º, V, CF/88 (Inf. 851).

No art. 5º, inciso IX, estabelece que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

Com base nesta ideia, o STF considerou não recepcionada a Lei de Imprensa, a qual foi editada em tempo de regime militar, sendo integralmente revogada.

O art. 5º, XIV, dispõe que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

Como se percebe, é assegurado o sigilo da fonte quando for necessário ao exercício profissional e assegurado a todos o acesso à informação. Essa informação deve ser de interesse geral.

O jornalista não é obrigado a divulgar sua fonte. No caso de responsabilização, quem responderá será o jornalista, pois assinará a matéria em seu próprio nome.

Cabe ressaltar que o STF já admitiu a proibição de edição de livro antissemita, diante da vedação constitucional ao racismo (HC 82.424/RS), sem que isso tenha violado a liberdade de expressão.

A liberdade de crença religiosa, liberdade política e filosófica está prevista no art. 5º em alguns incisos.

No inciso VIII está previsto que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

Esse dispositivo consagra a chamada escusa de consciência (objeção ou imperativo de consciência). É uma norma de eficácia contida, tendo efeitos imediatos. Se a lei criar uma obrigação alternativa e ainda assim houver o descumprimento, a lei poderá aplicar uma sanção.

O art. 143, §1º, da CF, dispõe que “às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de



consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar”.

O sujeito que está alistado pode receber um serviço alternativo, alegando a escusa, mas somente em tempos de paz, pois no momento de guerra os direitos podem ser suspensos.

Segundo o inciso XIII, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

Trata-se de uma norma de eficácia contida, restringível (Michel Temer).

4.3. DIREITO À REUNIÃO

Previsto no art. 5º, inciso XVI, estabelece que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.

Quando falamos em direito de reunião não estamos falando de reuniões estáticas, mas também falamos em comícios, passeatas, manifestações, ou seja, passeatas em curso móvel.

Esse exercício do direito fundamental à reunião, somada à livre manifestação do pensamento, subsidiaram a decisão do Supremo que reputou legal e constitucional a chamada “marcha da maconha”, que é a favor da descriminalização da maconha. Não há fato criminoso, tampouco apologia ao crime. Os fundamentos seria a liberdade do pensamento e o direito de reunião.

São características do direito de reunião:

- Finalidade pacífica;
- Ausência de arma (isto, em tese, impede a passeata de policiais);
- Locais abertos ao público (isto é para não invadir propriedades particulares);
- Não haja a frustração de uma reunião já marcada para o mesmo local;
- Desnecessidade de autorização para exercer o direito;
- Prévio aviso à autoridade competente (a fim de organizar a manifestação).

Em caso de lesão ou ameaça de lesão ao direito de reunião, o remédio constitucional cabível é o mandado de segurança.

A CF/88, em seu art. 5º, XVII, dispõe que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.

Em seguida o inciso XVIII estabelece que a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Aqui há uma liberdade pública, não podendo o Estado interferir na associação.

O inciso XX traz uma garantia que é decorrência do direito de se associar, que é o direito de não se associar, e não se reunir: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.

O inciso XIX estabelece que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. A dissolução compulsória só é possível com decisão transitada em julgado.

É preciso ainda diferenciar representação processual e substituição processual. O inciso XXI estabelece que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.

O inciso LXX diz que LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

Não há necessidade de expressa autorização para que seja impetrado mandado de segurança coletivo. No caso do mandado de segurança coletivo, a associação impetra o MS em



seu próprio nome, defendendo interesse alheio, eis que se trata de substituição processual. Neste caso, conforme o inciso LXX, não é necessária autorização específica, bastando a genérica, prevista no estatuto da associação.

Por outro lado, o STF entendeu que na hipótese do inciso XXI, para representar os associados na defesa de seus interesses, a entidade atua como representante processual, de forma que não bastaria uma autorização genérica no estatuto, sendo indispensável a autorização específica do associado ou dos associados em assembleia geral. Na representação processual, a entidade age em nome do associado e em interesse dele.

No tocante aos sindicatos, a CF, em seu art. 8º, III, estabelece que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

O STF entende que neste caso, a CF, quando disse que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, assegura ampla legitimidade extraordinária. Ou seja, os sindicatos atuam como substitutos processuais. E mais, eles entrarão em juízo em nome próprio para defender interesse alheio (dos sindicalizados). Cabe ressaltar que os sindicatos poderão continuar atuando inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização do sindicalizado. Como visto, são substitutos processuais.

4.4. DIREITO À IGUALDADE

Igualdade, na concepção liberal, é a formal (igualdade na lei), fazendo com que a lei apenas trate todos iguais. Todavia, não basta esta igualdade. É preciso que haja a igualdade material, propiciada por uma atuação estatal, a fim de equilibrar os menos vulneráveis com os mais vulneráveis.

A igualdade deve ser na lei, ou seja, o Poder Público não deveria criar distinções àquelas situações que não se justificam.

A igualdade também deve ser perante a lei, que é aquela que se destina ao intérprete ou aplicador da lei, o qual não pode fazer distinções não feitas pela lei.

O princípio da igualdade não veda o tratamento discriminatório, mas apenas quando há razoabilidade para discriminação e na medida do razoável.

Por exemplo, a Lei Maria da Penha traz uma diferença de tratamento entre homens e mulheres, tendo já sido chancelado pelo STF. Esta diferenciação é razoável. A própria CF faz diferenciações, como o caso de aposentadoria mais cedo do que os homens.

O princípio da igualdade não veda o tratamento discriminatório no concurso público, mas é preciso que haja razoabilidade para discriminação, sendo inclusive objeto da Súmula 683 do STF: o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pelas naturezas das atribuições do cargo a ser preenchido”.

Essas restrições só são lícitas se previstas em lei, não podendo o edital impor estas restrições, pois o direito à profissão é direito fundamental que é de eficácia contida, podendo ser restringido por lei, mas não por edital.

O STF vai ainda ensinar que o princípio da isonomia não autoriza o Poder Judiciário a estender vantagem a um determinado grupo quando a lei estendeu vantagens a um grupo em igual situação. Haveria aqui uma violação à separação dos poderes, eis que o Poder Judiciário não pode legislar positivamente, mas somente negativamente. Esse é o teor da Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

No entanto, segundo o Supremo, é possível a concessão de equiparação, pelo Judiciário, de diferentes índices previstos em lei que faz revisão geral de remunerações em determinado órgão público, sem que isto viole a súmula vinculante 37 (Rcl 20864 AgR – 2016). Por outro lado, o reconhecimento de direito de férias aos servidores temporários em



equiparação ao direito de férias dos servidores efetivos não viola à súmula vinculante 37, pois o direito de férias não se confunde com o aumento de remuneração (Rcl 19.359 AgR – 2016).

Em relação às políticas de ações afirmativas, cabe ressaltar que são medidas públicas que impõem um tratamento diferenciado em favor de minorias. A ideia é de que as desvantagens sejam compensadas.

Basicamente, os defensores dizem que as ações afirmativas são um meio eficaz para reduzir a desigualdade material existente entre os indivíduos. Outros, dirão que as ações afirmativas aumenta a desigualdade entre os indivíduos.

O STF, todavia, entendeu que as o sistema de cotas é constitucional, eis que se trata de um meio de efetivar a igualdade material, mas deve haver proporcionalidade.

Ainda sobre o princípio da igualdade, o STF já se posicionou que não há violação ao princípio da igualdade a instituição de família por pessoas do mesmo sexo. Isso é aplicação do princípio da igualdade. O STF vai igualar a união estável homoafetiva com a união estável heteroafetiva, dando uma interpretação conforme ao dispositivo civilista.

4.5. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Segundo o art. 5º, II, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Pela ótica do particular, é possível fazer tudo que não está proibido pela lei, vigorando o princípio da autonomia privada. Todavia, aos olhos do Poder Público, quer dizer que só poderá fazer aquilo que a lei manda ou permite fazer. Isso porque o Estado se sujeita às leis, e mais, o Estado governa através das leis.

Relevante é a distinção entre princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. Basicamente, quando falamos em reserva legal, o texto constitucional exige que haja lei em sentido formal para tratar de matérias específicas (*art. 5º, XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer*). Este dispositivo traz uma reserva legal, somente podendo fazer a regulação por meio de lei em sentido formal.

Neste caso, não apenas a lei ordinária ou complementar cumpririam este requisito, podendo ser realizado também por medidas provisórias e leis delegadas. O que devemos ter como consciência é de que a CF/88 está tratando de atos normativos primários, cuja referência inicial direta é a Constituição Federal.

Todavia, quando falamos em princípio da legalidade, não temos necessariamente a necessidade de uma lei, mas a instituição de uma obrigação de fazer ou não fazer pode decorrer também de ato infralegal. Um contrato pode criar obrigação de fazer, mas neste caso ele deve estar nos limites estabelecidos na lei.

4.6. DIREITO DE PROPRIEDADE

O direito de propriedade está previsto em vários incisos da CF/88.

O art. 5º, inciso XXII, estabelece que é garantido o direito de propriedade. O art. 170, inciso II, vai dizer que é princípio da ordem econômica do Brasil, a propriedade privada.

Todavia, o direito à propriedade não é ilimitado, pois, segundo o inciso XXIII, a propriedade atenderá a sua função social. Neste caso, o direito de propriedade não é como na época do liberalismo, pois o Estado é social e deve cumprir a sua função social.

O direito à propriedade não se limita a bens corpóreos, sendo extensível aos bens incorpóreos. Em relação a estes, vale mencionar a propriedade intelectual, o qual abarca os direitos do autor e os direitos relativos à propriedade industrial. Dentro de propriedade industrial existem marcas e patentes, sendo estudados em Empresarial.



A CF, como corolário do direito de propriedade, vai dizer no inciso XXX que é garantido o direito de herança. Este direito de herança serve tanto para o herdeiro quanto para quem falece, pois ele trabalha e constrói um patrimônio com a confiança de que o seu patrimônio não será tomado pelo Estado quando ele morrer.

Uma das formas de intervenção na propriedade privada, ou a principal delas, é a desapropriação. Portanto, o direito de propriedade convive com o direito que o Estado tem de tomar essa propriedade, que é a desapropriação.

O art. 5º, inciso XXIV diz que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

Haverá o aprofundamento deste ponto em D. Administrativo.

Perceba que a própria CF vai mitigar o direito de propriedade quando houver necessidade ou utilidade pública, assim como quando houver interesse social.

Se o indivíduo não cumpre a função social da sua propriedade, com base neste comando constitucional, haverá no mesmo texto constitucional, outras hipóteses de desapropriação, tal como a do art. 182, §4º, III, que trata da desapropriação urbanística. Esta espécie possui caráter sancionatório, pois dirá que o proprietário de solo urbano, que não atenda a exigência de promover o adequado aproveitamento de sua propriedade, nos termos do Plano Diretor, terá sua propriedade expropriada, recebendo tão somente títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

O art. 184, caput, trata de outra hipótese de desapropriação com caráter sancionatório, que é a desapropriação rural, imóveis destinados à reforma agrária: “Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei”. Neste caso, o expropriante é exclusivamente a União para imóveis rurais destinados à reforma agrária.

A terceira hipótese de desapropriação sancionatória é aquela prevista no art. 243. Esta desapropriação confiscatória não assegura ao proprietário qualquer direito à indenização. Segundo este dispositivo, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.

Ainda em relação ao direito de propriedade, é necessário falar nos casos de requisição administrativa. Diz o art. 5º, inciso XXV, que no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

O perigo público deve ser próximo (iminente). O sujeito não perde a propriedade, mas tem suspenso o direito de propriedade naquele momento. Só se houver dano é que haverá indenização. Essa requisição administrativa é um direito fundamental do Estado.

4.7. DIREITO À PRIVACIDADE

Segundo o inciso X, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

A preocupação em se proteger a dignidade humana na intangibilidade do corpo humano, o STF entendeu que em ações de paternidade não é possível que o suposto pai seja



coagido a realizar o exame de DNA. Se ele fosse obrigado a ter coletado o seu sangue, haveria violação à dignidade e intangibilidade do corpo humano. Sendo assim, recai sobre ele uma presunção relativa de paternidade.

Com relação ao sigilo bancário, que é uma espécie de exercício da privacidade, cabe ressaltar que não há direito absoluto no ordenamento jurídico, podendo o sigilo servir para fins judiciais desde que cumpridos os requisitos previstos em lei. A LC 105/01 estabelece que o fisco pode quebrar o sigilo bancário sem necessidade de autorização judicial.

São as hipóteses em que cabe o afastamento do sigilo bancário sem autorização judicial:

- Por determinação judicial;
- Por determinação do Poder Legislativo, por meio de CPI;
- Por determinação de autoridades e agentes fiscais da União, dos Estados e dos Municípios quando houver processo administrativo e o sigilo for indispensável para a finalidade fiscal.

O MP precisa de autorização judicial para quebrar sigilo, não podendo fazê-lo mediante prova emprestada apenas. Adverte-se que o STF já admitiu que o MP se utilizasse como prova emprestada, as informações passadas por pessoa jurídica diretamente ao Fisco, sem que esse houvesse ter que proceder a quebra do sigilo. Nota-se que são situações diversas.

Com relação à imagem, existem duas espécies de imagem:

- Imagem-retrato: é o conceito do senso comum, é aquele visualmente perceptível, abrangendo tudo que puder ser concretamente individualizado. Não diz apenas à representação do seu corpo físico ou da expressão material da pessoa, mas, sim, da representação de todos os aspectos que individualizam o homem, como a voz, os gestos, forma de caminhar, tiques, ou seja, todas as características comportamentais que o tornam único no mundo.
- Imagem-atributo: corresponde às qualidades e características intrínsecas do indivíduo, ao prestígio, a reputação que a pessoa desfruta no meio social, sua conduta particular ou em sua atividade profissional e que deverá ser igualmente tutelada pelo Estado.

A CF/88 determina no art. 5º, XI que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Quando falamos em “casa”, não se restringe à residência do indivíduo, dando-se interpretação da máxima efetividade do direito fundamental. Ou seja, casa é um compartimento não aberto ao público onde alguém exerce sua profissão. Pode ser o quarto do hotel, por exemplo.

O STJ já entendeu que o gabinete do delegado de polícia é privativo e a sua violação é quebra do respeito à inviolabilidade domiciliar.

O STF também considerou válida a ordem judicial que autoriza o ingresso à noite de autoridade policial para introduzir materiais de escutas ambientais dentro do ambiente de trabalho, ainda que se trate de escritório de advocacia. Não sendo à noite, haverá frustração do próprio objeto de investigação. A escuta ambiental não se submeteria às mesmas situações que a busca, e para sua legalidade basta a existência de uma ordem judicial fundamentada.

A doutrina diz que a boleia do caminhão pode ser considerada casa, se o caminhoneiro nela habitar, mas não se aplica nas hipóteses de *blitz*, pois caracteriza operação de revista geral que passam por determinado local.

O art. 5º, XII, diz que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem



judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

A lei aqui mencionada é uma reserva legal qualificada. A lei que virá autorizando a quebra e interceptação telefônica só poderá autorizar nos casos de instrução processual ou investigação criminal, configurando reserva legal qualificada.

Estas possibilidades se estenderia a outras formas de interceptações, inclusive as correspondências, sempre que as liberdades públicas estiverem sendo utilizadas para a prática de ilícitos. Este é o entendimento do STF. Exemplo é a carta enviada pelo sequestrador à família da vítima, podendo ser interceptada pelo agente penitenciário.

As interceptações telefônicas, pelo texto constitucional, exigem três requisitos:

- Lei que preveja as hipóteses e a forma de como essas interceptações poderão ocorrer;
- O caso de instrução criminal ou investigação processual penal;
- Autorização judicial, sendo uma reserva de jurisdição, sem caber por CPI.

Esta interceptação telefônica, ainda que seja de processo penal, poderá servir de prova para processo administrativo disciplinar, pois foi produzida validamente, admitindo-se o compartilhamento da prova.

A Lei 9.296/96 tratou da interceptação telefônica, só podendo haver interceptação se houver indícios de materialidade e autoria do sujeito que está sendo investigado, devendo o crime ser punível com reclusão, bem como não couber outra forma de prova (*ultima ratio*).

O prazo da interceptação telefônica é de 15 dias, renovável por igual tempo, mas o STF entendeu que possam haver sucessivas renovações, desde que haja fundamentações.

- Interceptação telefônica: é a captação de uma conversa feita por um terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores, sendo indispensável autorização judicial prévia.
- Escuta telefônica: é feita por um terceiro, mas um dos interlocutores sabe.
- Gravação telefônica: não há um terceiro, mas um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, faz a gravação.
- A escuta e a gravação telefônica não se sujeitarão a uma ordem judicial prévia, porque a CF fala em interceptação e não em escuta e gravação.

4.8. DEFESA DO CONSUMIDOR

Segundo o art. 5º, XXXII, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.

O que temos aqui é uma norma de eficácia limitada. A proteção demanda lei. O próprio ADCT traz a previsão de que o Estado elabore o código no prazo de 120 dias, a contar da promulgação da Carta.

O prazo não foi observado, eis que a Lei 8.078 é de 1990, mas percebeu-se que a CF foi obedecida.

O art. 170, V, da CF diz que a defesa do consumidor é princípio fundamental da ordem econômica.

Quando se percebe esta preocupação em proteger o consumidor, significa que há uma disparidade entre as partes na relação de consumo, dando a ordem para que o legislador possa corrigir essa disparidade através da proteção do vulnerável.

4.9. DIREITO À INFORMAÇÃO

A CF, através do inciso XXXIII, assegura que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.



Dessa norma do direito de informação se extrai o princípio da publicidade.

A pessoa tem o direito de receber informações a seu respeito ou de interesse coletivo, salvo quando esta informação for imprescindível à segurança do Estado ou da sociedade. Portanto, a regra é a publicidade.

4.10. DIREITO DE PETIÇÃO

No inciso XXXIV, a CF estabelece o direito de petição.

A CF assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição.

Esta petição é dirigida aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Perceba que o direito de petição independe do pagamento de taxas. A legitimação é universal, podendo qualquer pessoa, até mesmo aquele sem personalidade jurídica, pode peticionar ao Poder Público. Não há sequer necessidade de assistência por meio de advogado.

Atenção, o direito de petição consagrado constitucionalmente não se confunde com o direito de ação (direito de obter uma decisão judicial), pois este exige a capacidade postulatória por meio de advogado.

São exemplos de inexistência de capacidade postulatória para fins de obtenção de decisão judicial:

- Habeas corpus
- Revisão judicial
- Lei dos Juizados Especiais com valor da causa de até 20 salários mínimos

Mas, como regra, para postular em juízo, é necessária a capacidade postulatória (advogado inscrito na OAB).

4.11. DIREITO DE CERTIDÃO

O direito de certidão está previsto no art. 5º, XXXIV, “b”, assegurando a todos, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Atenção, pois o direito que está sendo assegurado é o direito de obter uma certidão, a fim de atestar uma situação. Não pode ser invocado o direito de petição para fins de obtenção de informações de interesse de terceiros, eis que o interesse é pessoal. Como é de interesse pessoal, não se exige do administrado explicitação da finalidade do pedido.

A injusta recusa estatal em fornecer certidões, não obstante presentes os pressupostos legitimadores dessa pretensão, autorizará a utilização de instrumentos processuais adequados, como o **mandado de segurança** ou a própria ação civil pública. O Ministério Público tem legitimidade ativa para a defesa, em juízo, dos direitos e interesses individuais homogêneos, quando impregnados de relevante natureza social, como sucede com o direito de petição e o direito de obtenção de certidão em repartições públicas (RE 472.489-AgR).

4.12. DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADO E ATO JURÍDICO PERFEITO

Segundo a CF, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Essa garantia constitucional precisa ser lida de maneira atenta para perceber que a CF não impede que sejam publicadas leis retroativas. No entanto, estas leis retroativas só podem estabelecer situações mais favoráveis ao indivíduo do que a situação anterior. Isso porque a lei não prejudicará!



Vale uma distinção do que seria direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito:

4.12.1. DIREITO ADQUIRIDO

Ocorre com o cumprimento das exigências para conquistar aquele direito. Na verdade, o indivíduo reúne os elementos necessários para aquisição do direito para determinado bem jurídico sob a vigência de uma determinada lei. Se outras leis futuras vierem, estas não poderão atingir este indivíduo. Ex.: o sujeito precisa cumprir 30 anos de contribuição para se aposentar. Ele cumpriu 30 anos e um mês, mas ainda não requereu a aposentadoria. Neste momento, surge uma nova lei exigindo que seja necessário 35 anos de contribuição para se aposentar. Esta lei não vai atingi-lo, pois ele já possui o direito adquirido à aposentadoria, eis que já preencheu todos os requisitos perante a antiga lei. A expectativa de direito significa que o indivíduo quase cumpriu os requisitos, como no caso em que a pessoa tem 29 anos e 11 meses de contribuição, momento em que surge uma nova lei exigindo 35 anos de contribuição. Neste caso, o indivíduo deverá cumprir os 35 anos, eis que ele detinha apenas a expectativa de direito.

4.12.2. ATO JURÍDICO PERFEITO

É um ato já realizado sob as regras da lei anterior. O ato jurídico perfeito é um adicional ao direito adquirido, pois este é cumprido quando se cumpre os requisitos. O ato jurídico perfeito ocorre quando já se tem os requisitos para a prática do ato e este já foi efetivamente realizado (Ex.: sujeito já foi ao INSS e se aposentou, a lei nova não poderá retroagir; contrato realizado anteriormente realizado antes da nova lei).

4.12.3. COISA JULGADA

É uma decisão judicial irrecorrível, da qual não mais cabe recurso.

O STF diz que em face da Constituição, texto originário, não há direito adquirido, pois o Poder Constituinte originário é ilimitado.

Mas há outras hipóteses em que não há direito adquirido:

- Em face de uma nova Constituição;
- Em face de mudança de padrão monetário (mudança de moeda);
- Em face de criação ou aumento de tributo (ex.: uma empresa vai para um Estado com baixo ICMS, não poderá alegar posteriormente que teria direito adquirido a não sofrer um aumento).
- Em face de mudança de regime jurídico estatutário;

O servidor que entra na posse do cargo não adquire todos os direitos ao longo da sua carreira no cargo. O regime jurídico estatutário poderá ser alterado.

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo explicitam que todo o ano o servidor terá aumento de 1% de seu vencimento. Se o sujeito tomar posse em janeiro e em setembro esta lei é revogada, no ano seguinte ele não terá mais direito a isto, eis que não há direito adquirido em face de mudança de regime jurídico estatutário.

4.13. VEDAÇÃO AO RACISMO

A Constituição define o racismo como um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei (exige lei). Este inciso XLII é um mandado de criminalização. Trata-se de ordem do constituinte ao legislador ordinário para criminalizar determinada conduta.

O antissemitismo seria prática de racismo? Biologicamente, não há distinção de raças entre seres humanos. Então, a expressão racismo, utilizada na Constituição, não é no sentido biológico, e sim no sentido de vedar qualquer forma de discriminação que implique distinção entre homens por restrições ou preferências oriundas de raça, cor, credo, origem, etnia etc.



O STF entende que a xenofobia, antissemitismo, são formas de racismo, vedadas pela Constituição.

Recentemente, o Supremo proferiu importante decisão na ação direta de inconstitucionalidade por omissão nº 26 e mandado de injunção nº 4733, reconhecendo que o art. 5º, incisos XLI e XLII da Constituição trazem mandados de criminalização condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social.

4.14. TORTURA, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, TERRORISMO, CRIMES HEDIONDOS E AÇÃO DE GRUPOS ARMADOS CIVIS OU MILITARES CONTRA A ORDEM CONSTITUCIONAL

O inciso XLIII estabelece que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.

O inciso XLIV também diz que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Trata-se de mais um mandado de criminalização. É uma garantia do próprio Estado, de forma que o crime será inafiançável e imprescritível.

Anistia é um perdão, concedido por meio de lei, aplicado aos crimes em geral, produzindo efeitos retroativos. Desfaz os efeitos penais da condenação. Os extrapenais permanecem.

O indulto é um perdão concedido pelo presidente da República, e não por meio de lei. O indulto pode ser delegado aos ministros de Estado, bem como ao Procurador Geral da República e ao Advogado Geral da União. O indulto é ato privativo do presidente. Enquanto a anistia exige lei do Congresso Nacional.

5. INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIAS

5.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

1. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”);

2. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou



teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero;

3. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito.

STF. Plenário. ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MI 4733/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 13/6/2019 (Info 944).

Questões

1) (Procurador da Câmara Municipal de Boa Vista-2016) — Acerca dos Direitos Fundamentais, com fundamento na Doutrina e no entendimento do STF, assinale a opção correta.

a) A situação atual do sistema penitenciário brasileiro, ainda que viole preceitos fundamentais da Constituição Federal, não se submete ao manejo de ADPF para realização de tal proteção.

b) A proibição a tratamento desumano ou degradante é exemplo de aplicação do princípio da eficácia mediata positiva das liberdades públicas.

c) A potencialidade de congestionamento da justiça pelo fato de que todos os indivíduos que tiverem seus direitos violados acorrerão individualmente ao Poder Judiciário, configura uma das condições de existência do Estado de Coisas Inconstitucional.

d) Toda e qualquer pretensão decorrente de relação estatutária, e, portanto, surgindo no interior de uma entidade privada, pode ser alçada à hierarquia de questão constitucional e, como tal, se sujeita a eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

e) A dimensão objetiva dos direitos fundamentais corresponde à característica desses mesmos direitos, em maior ou menor escala cujo resultado opera na pretensão, ensejando a adoção de um dado

2) (TRF1/Piauí-2016) — Marque a opção em que há ERRO.

Os direitos fundamentais, segundo Habermas, estruturantes da ordem constitucional, sendo o seu ponto de partida, estão positivados na CF-88:

a) nas liberdades negativas situadas no art. 5º.

b) na condição de membro da comunidade política, no art. 12 que trata da nacionalidade.

c) no direito de petição, na alínea a do inciso XXXIV do art. 5º.

d) no direito de participar, no art. 14, que trata dos direitos políticos.



e) nas condições sociais, técnicas e ambientais que se encontram no art. 6º dos direitos sociais.

Comentários

1. Gabarito: letra C. O Estado de Coisas Inconstitucional ocorre quando se verifica a existência de um quadro de violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, causado pela inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura, de modo que apenas transformações estruturais da atuação do Poder Público e a atuação de uma pluralidade de autoridades podem modificar a situação inconstitucional. O STF reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro vive um "Estado de Coisas Inconstitucional", com uma violação generalizada de direitos fundamentais dos presos. As penas privativas de liberdade aplicadas nos presídios acabam sendo penas cruéis e desumanas. Assim, cabe ao STF o papel de retirar os demais poderes da inércia, coordenar ações visando a resolver o problema e monitorar os resultados alcançados (STF. Plenário. ADPF 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 9/9/2015 - Info 798)

a) Errado. Como vimos acima, O STF reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro vive um "Estado de Coisas Inconstitucional", com uma violação generalizada de direitos fundamentais dos presos, exatamente em ADPF ajuizada pelo Partido Socialista e Liberdade (PSOL) pedindo que o STF declare que a situação atual do sistema penitenciário brasileiro viola preceitos fundamentais da Constituição Federal e, em especial, direitos fundamentais dos presos.

b) Errado. A teoria da eficácia mediata NEGA a possibilidade de aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações privadas porque, segundo seus adeptos, esta incidência acabaria exterminando a autonomia da vontade e desfigurando o Direito Privado ao convertê-lo numa mera concretização do Direito Constitucional. (SARMENTO. Daniel. Vinculação dos particulares aos direitos fundamentais no direito comparado e no Brasil. Salvador, editora JusPodivm, 2007, pág 143)

d) Errado. Como vimos acima, a teoria da eficácia mediata (indireta ou horizontal) NEGA a possibilidade de aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações privadas.

e) Errado. Essa é a dimensão SUBJETIVA dos direitos fundamentais. Já no plano objetivo, os direitos fundamentais assumem uma dimensão institucional, são da essência do Estado democrático.

2. Gabarito: letra E. a partir dos estudos do filósofo Jürgen Habermas, com base na sua teoria discursiva, que visa a adequação do sistema normativo as demandas da sociedade multicultural e suas respectivas contradições, ou seja, uma concepção universalista e ao mesmo tempo sensível as diferenças, buscando-se uma efetivação dos direitos fundamentais. Senso assim os direitos fundamentais são uma consequência da escolha de cidadãos livres iguais, que podem legitimamente regular suas vidas por intermédio do direito positivo.



CAPÍTULO 10 – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

1. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO

Previsto no art. 5º, XXXV, da CF, estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

A CF diz que a lei não vai excluir do Poder Judiciário a apreciação da lesão ou ameaça a direito.

Algumas pessoas questionaram a constitucionalidade da Lei de Arbitragem, pois a pessoa que se submete ao árbitro não poderia bater às portas do Poder Judiciário, ofendendo este dispositivo. No entanto, a lei é constitucional, pois não é a lei que exclui a apreciação do Poder Judiciário, e sim a própria parte. Portanto, são as partes que irão excluir a apreciação do Poder Judiciário no caso de arbitragem, e não a lei.

Esta garantia também se dirige ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, pois o Legislativo não pode trazer uma lei que reduza o campo de atuação do P. Judiciário, assim como o Executivo não pode publicar medida provisória para reduzir esse campo, pois violaria o dispositivo constitucional.

Há atos que não estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário, tais como os atos *interna corporis*. O STF já se manifestou várias vezes nesse sentido. Outro ponto que não pode ser apreciado pelo Poder Judiciário é o mérito administrativo.

Portanto, nem toda a controvérsia pode ser submetida ao Poder Judiciário.

Este princípio não impede que haja restrições à forma de agir do Poder Judiciário. Por exemplo, pode vir uma lei que restrinja a concessão de medidas cautelares ou de liminares em ações judiciais. Determinados assuntos não são passíveis de concessão dessas medidas. Neste ponto, não há exclusão da lesão da apreciação do Poder Judiciário, mas a possibilidade de concessão de medida cautelar. A lesão continua sendo apreciada pelo Judiciário.

Em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o Brasil, via de regra, não adota o contencioso administrativo. Não se exige o esgotamento da via administrativa para buscar a tutela do Poder Judiciário.

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo trazem quatro exceções a essa máxima:

- ações relativas à disciplinas e competições desportivas: primeiro se esgota as instâncias desportivas. Trata-se de órgãos de natureza administrativa;
- ato administrativo que contrarie súmula vinculante: o STF não pode ser instado diretamente. Se o ato contraria a súmula vinculante, este só pode ser reclamado perante o STF, após o esgotamento das vias administrativas. Isso está na Lei 11.417, em seu art. 7º, §1º.
- indeferimento da informação de dados pessoais ou omissão em atender este pedido para que nasça o interesse de agir no *habeas data*: isto é segundo a jurisprudência do STF. Para ele, sem que haja esse indeferimento, não há falar em interesse de agir. Não se trata de esgotamento da via administrativa.
- indeferimento de pedido perante o INSS, ou mesmo a omissão em atender o pedido administrativo para obtenção de benefícios previdenciários: Trata-se de uma mora não razoável. Se não houver esse pedido, não há interesse de agir. Este é o posicionamento do STF.

E se o sujeito decide utilizar simultaneamente a via administrativa e via judicial? O STF considerou constitucional a previsão legal de que a opção da via judicial implica renúncia tácita ao processo administrativo. Aqui há uma ponderação à celeridade processual, pois se o sujeito opta por uma via significa que abriu mão da outra.

O STF diz que viola a garantia de acesso à jurisdição a taxação do valor da causa sem que haja um valor máximo. Isso porque se a ação for de um valor muito alto, a depender do valor da taxa, haverá a inviabilização do acesso à jurisdição. A taxa judiciária deve ter uma



relação com o custo que o Estado terá em julgar aquela causa. Se não houver limites, não haverá equilíbrio.

O STF diz que viola o princípio da inafastabilidade a exigência de depósito como condição para ajuizamento de ação em que se discute a imposição de tributo. Este entendimento está na súmula vinculante 18, que diz ser inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Isto retiraria do particular a possibilidade de acessar a justiça, excluindo a apreciação do Poder Judiciário pela lei.

2. JUÍZO NATURAL

Diz a CF, em seu art. 5º, XXXVII, que não haverá juízo ou tribunal de exceção, assim como o inciso LIII estabelece que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.

Percebemos que há uma preocupação com a vedação ao tribunal de exceção. O Tribunal deve ser competente anterior ao fato que irá julgar. Não pode o sujeito ser julgado senão pela autoridade competente, ainda que o Tribunal seja competente.

Essas são as garantias de previsibilidade. O juízo natural tem estrita relação com o devido processo legal. Segundo o STF, o princípio do juiz natural não se aplica apenas aos órgãos do Poder Judiciário. Este princípio se aplica a qualquer órgão julgador constitucionalmente previsto, implicando na vedação à usurpação de suas competências por outro órgão julgador, como, por exemplo, ao Senado no julgamento de impeachment.

3. JÚRI POPULAR

No inciso XXXVIII, a CF diz que é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a LEI (norma de eficácia limitada). Trata-se de uma reserva legal qualificada, eis que a lei deve observar os parâmetros das alíneas a, b, c e d:

- Plenitude de defesa: é além da ampla defesa, sendo a ideia de que pode inclusive alegar de cunho moral e extrajudicial.
- Sigilo das votações: permite que o jurado vote com sua consciência, vigorando o princípio da íntima convicção.
- Soberania dos veredictos: as decisões de mérito não podem ser reformadas pelo Tribunal, podendo, no máximo, ser declaradas nulas ou submetidas ao novo julgamento.
- Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Há uma orientação para o legislador infraconstitucional.

O fato do veredicto ser soberano não impede que haja recursos de suas decisões. Não quer dizer que o Tribunal irá reformar, mas é possível que declare nulo, pois a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Além disso, a decisão do júri pode ser objeto de revisão criminal. Neste caso, poderá inclusive ser absolvido, se a decisão do Tribunal do Júri tenha sido arbitrária.

Em relação à competência do Tribunal do Júri, a doutrina entende que o legislador não pode ampliar o objeto de julgamento. Se o constituinte quisesse, teria feito este acréscimo.

A competência do Tribunal do Júri é prevista na CF, mas há autoridades que têm foro por prerrogativa de função que também está na CF. É o caso do juiz que detém o seu próprio Tribunal para julgá-lo.

Procurador do Estado e Defensor Público não têm foro por prerrogativa de função na Constituição Federal, mas podem ser previstos na Constituição Estadual. Aí o STF trouxe a súmula vinculante 45, estabelecendo que a competência do Tribunal do Júri nestes casos

prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela competência prevista na Constituição Estadual.

4. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL E DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA

O art. 5º, XXXIX, estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.

Este dispositivo subsidia a tese de que o Estatuto de Roma é inconstitucional, eis que ele não prevê o crime e tampouco a pena.

Este princípio é de tamanha rigidez que a própria EC 32 passou a proibir o uso de medidas provisórias relativas a direito penal e a direito processual penal. A competência para legislar sobre direito penal é privativa da União.

Já o inciso XL diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Admite-se a lei penal retroativa para beneficiar o réu, mesmo que a sentença já tenha transitado em julgado.

É possível a combinação de leis penais, alcançando a situação mais favorável ao réu?

Não. O STF não admite. Na visão do Tribunal, haveria uma terceira lei, não cabendo ao juiz atuar como legislador positivo.

5. PESSOALIDADE DA PENA

Segundo o inciso XLV, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.

A pena não pode passar da pessoa do condenado, mas a obrigação de reparar o dano se estende ao patrimônio do de cujus.

6. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Segundo o inciso XLVI, a lei regulará a individualização da pena.

Há uma especial preocupação do constituinte em individualizar a pena, eis que ela tem a finalidade de retribuir o mal causado, mas também tem a ideia de ressocialização. Isto só é possível se houver a individualização da pena.

Além disso, a CF estabelece que lei adotará um rol exemplificativo de pena, dentre as quais estão:

- a) privação ou restrição da liberdade;
- b) perda de bens;
- c) multa;
- d) prestação social alternativa;
- e) suspensão ou interdição de direitos;

Excepcionalmente, poderá haver a pena de morte em caso de guerra declarada.

Há outras penas que são vedadas pela CF:

- a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
- b) de caráter perpétuo;
- c) de trabalhos forçados;
- d) de banimento;
- e) cruéis;

O Estatuto de Roma é considerado inconstitucional em razão da pena de morte, a qual é vedada pela CF/88.



Para o STF, a pena de prisão em regime integralmente fechado não atende a exigência constitucional de individualização da pena, sendo inconstitucional.

O STF entende que a vedação de penas de caráter perpétuo, por exemplo, não se limita a esfera penal, não se admitindo inclusive no âmbito das sanções administrativa. Ex.: indivíduo sofre a perda do cargo público, isto não significa que jamais poderá prestar concursos.

7. EXTRADIÇÃO

O inciso LI estabelece que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

Inclusive recentemente o STF (inf. 834) decidiu que é possível conceder extradição para brasileiro naturalizado envolvido em tráfico de droga.

O estrangeiro também não será extraditado por crime político ou de opinião (LII).

Extraditar é pegar o indivíduo e entrar a outro país para que lá seja julgado conforme as leis daquele país. A lei faz diferença entre extradição, deportação e expulsão:

- **Deportação:** é a devolução do indivíduo para outro país que aceite receber o deportado. O sujeito entrou no país ou permaneceu no país irregularmente. Com isso, ele é devolvido ao estrangeiro por uma medida compulsória.
- **Expulsão:** é uma medida coercitiva a fim de retirar forçadamente um estrangeiro que praticou um atentado a ordem jurídica do país em que se encontra. É uma medida de caráter político ou administrativo. Quem decide isto é o presidente da República, sendo uma decisão discricionária, movida por conveniência e oportunidade.
- **Extradição:** é a entrega de uma pessoa para outro país soberano para que lá seja julgada pelo crime que cometeu.
- A doutrina faz uma diferenciação entre extradição ativa e passiva:
- **Extradição ativa:** o Estado brasileiro pede a extradição.
- **Extradição passiva:** o Estado brasileiro é quem recebe o pedido de extradição feita por outro Estado soberano.

A competência para julgar o pedido de extradição feito pelo Estado estrangeiro é do Supremo Tribunal Federal.

Não é da competência do STF a entrega do extraditando, pois o STF julga, mas a entrega é realizada pelo Presidente da República, na condição de Chefe de Estado. Esta entrega é decisão discricionária.

Suponhamos que o país solicitante prevê no país a pena de morte, a extradição pode ser concedida? Sim, desde que o país se comprometa a substituir a pena de morte pela pena privativa de liberdade, reduzindo a pena ao limite máximo de 30 anos.

8. DEVIDO PROCESSO LEGAL

O inciso LIV diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

É uma garantia constitucional. O min. Celso de Melo traz alguns elementos essenciais do devido processo legal:

- Indivíduo tem direito ao processo
- Direito à citação e ao conhecimento prévio
- Julgamento célere e público
- Direito ao contraditório e ampla defesa, inclusive à plenitude de defesa

(Júri)

- Igualdade entre as partes, a fim de que seja devido processo legal



- Observância do juízo natural
- Direito de participar ativamente do processo, inclusive no seu interrogatório.

Do ponto de vista formal, o devido processo legal está relacionado ao processo. No entanto, do ponto de vista material, está relacionado, segundo o STF, com o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Esse princípio ou postulado constitucional implícito.

A proporcionalidade é composto pela adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito:

- Adequação: é analisar se aquela medida é idônea ao atingimento da finalidade pretendida. Quando há uma lei, ou medida administrativa, é preciso ver se para aquilo que ela pretende atingir é um meio idôneo.
- Necessidade: é saber se não há um outro modo, ou providência menos gravosa, e que seja capaz de atingir o mesmo objetivo.
- Proporcionalidade em sentido estrito: significa que a medida deve trazer mais benefícios do que prejuízos.

Esse princípio encontra previsão expressa na Lei 9.784, estabelecendo que o princípio da proporcionalidade deve ser observado na administração pública federal em seu processo administrativo.

8.1. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

Segundo o inciso LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

É todo aqueles corolários de defesa técnica, direito de ser ouvido, direito de participar do processo etc.

No inquérito policial não é garantido o contraditório e ampla defesa, eis que ele não se trata de um processo, mas sim um procedimento. O STF abrandou isto no caso da SV 14, em que permite o defensor acesso amplo aos documentos já documentado por órgão da polícia judiciária.

Quando falamos em ampla defesa fica clara a ideia que o duplo grau de jurisdição é corolário da ampla defesa.

O duplo grau de jurisdição é a possibilidade de uma causa ser reapreciada por um órgão de instância superior. Geralmente, o órgão superior é colegiado.

O STF entende que o duplo grau de jurisdição não é uma garantia prevista na Constituição. A própria CF prevê hipóteses de competência originária, por exemplo, para julgar presidente da república e parlamentares, sendo o Supremo instância única.

A respeito do duplo grau, sob o ponto de vista dos recursos administrativos, é necessário lembrar da SV 21, que indica que é inconstitucional o arrolamento de bens ou depósitos para admissibilidade de recursos administrativos.

9. VEDAÇÃO À PROVA ILÍCITA

Segundo o inciso LVI, são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.

A doutrina diferencia provas ilícitas das ilegítimas, das quais seriam gênero das provas ilegais:

9.1. PROVA ILÍCITA

Infringe o direito material (ex.: obtenção de prova por meio de tortura).



9.2. PROVA ILEGÍTIMA

Afronta o direito processual (ex.: produção de prova a destempo no caso do Tribunal do Júri, que o prazo é de 3 dias antes da audiência, mas o sujeito junta 1 dia antes).

A prova ilícita originária contamina as provas delas advindas, ou todas as provas produzidas a partir dela. Trata-se da teoria dos frutos da árvore envenenada, havendo exceções como a teoria da descoberta inevitável, da fonte independente e da mancha purgada. Isto é assunto de processo penal.

Quanto à ilicitude/licitude da prova, vale ressaltar alguns posicionamentos do STF:

- É lícita a prova obtida por meio de gravação de conversa própria feita por um dos interlocutores, se uma das partes é vítima de um crime praticado por quem está sendo gravado. Não é possível que o sujeito que pratica um crime alegue que tenha sua vida privada violada. A ordem jurídica não admite que uma garantia constitucional seja invocada para acobertar a prática criminosa. Por isso, se alguém grava conversa própria contra um indivíduo que está cometendo um crime, esta gravação é lícita.
- É lícita a gravação de uma conversa realizada por um terceiro com autorização do interlocutor e sem o consentimento do outro, desde que utilizado para legítima defesa. Ou seja, se esta medida está sendo utilizada para coibir uma infração criminosa, é absolutamente válida.
- É válida a prova de um crime descoberta acidentalmente, durante a escuta telefônica autorizada judicialmente para apuração de um crime diverso, desde que haja uma certa conectividade entre eles. É o chamado encontro fortuito de provas, também denominado de serendipidade. Se a interceptação foi autorizada judicialmente e o sujeito interceptado conta que praticou outro crime, aquela prova será absolutamente válida.
- A confissão sob prisão ilegal é prova ilícita e, portanto, invalida a condenação fundada naquela confissão. Trata-se de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.
- É ilícita a prova obtida por conversa informal entre o indiciado com policiais, sem que eles tenham advertido sobre o direito ao silêncio. Trata-se, em verdade, de um interrogatório sem as formalidades legais.
- É lícita a prova feita mediante gravação em local público. O STF estabelece que em local público não há ofensa à intimidade e à vida privada, podendo ser lícita a prova.

10. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (OU NÃO CULPABILIDADE)

Segundo o inciso LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Atualmente, o plenário do STF se posicionou, majoritariamente, pela impossibilidade de execução provisória da pena porque o princípio não comporta interpretação diversa e deve-se aguardar a pena definitiva com o trânsito em julgado para iniciar a execução. O réu até pode ficar preso antes do trânsito em julgado, mas cautelarmente, e não como execução provisória da pena.

Essa presunção de inocência justifica o *in dubio pro reo*.

Com base neste dispositivo, o STF entende que a simples existência de investigações policiais ou perseguições criminais em curso, se não houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não podem caracterizar maus antecedentes, não podendo justificar a



exasperação. Este também é o teor da Súmula 444 do STJ. A verificação dos maus antecedentes é feita na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59, CP).

O STF também diz que eventual condenação criminal recorrível não impede que o sujeito participe de um concurso público ou curso de formação, eis que ele é presumivelmente inocente.

Todavia, excepcionalmente, segundo precedente do STJ, é possível excluir candidato de concurso público de delegado de polícia, em função de haver ação penal em curso pela prática de crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa (RMS 43.172/MT).

Por conta desse princípio, o STF entendeu que no julgamento criminal, caso haja empate nos votos do acórdão, a decisão beneficiará o réu, que será absolvido. Diferentemente do mandado de segurança, em que há uma presunção em favor do ato da autoridade coatora, razão pela qual, havendo empate, denega-se a ordem.

11. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DO CIVILMENTE IDENTIFICADO

O inciso LVIII diz que o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei.

Aqui, há uma norma de eficácia contida. Ou seja, a lei poderá restringir que o civilmente identificado não seja submetido à identificação criminal em certas hipóteses.

Essa lei é a 12.037/09. Em seu art. 2º estabelece que a identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos: I – carteira de identidade; II – carteira de trabalho; III – carteira profissional; IV – passaporte; V – carteira de identificação funcional; VI – outro documento público que permita a identificação do indiciado. Parágrafo único. Para as finalidades desta Lei, equiparam-se aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militares.

No seu art. 3º diz que em determinadas situações o civilmente identificado pode ser submetido também à identificação criminal:

- documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;
- documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado;
- indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si;
- identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa;
- constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;
- o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais.

A identificação criminal engloba o processo datiloscópico e fotográfico.

Em algumas hipóteses a identificação criminal pode também alcançar a coleta de material genético, tendo a sua constitucionalidade questionada neste ponto.

O STF entendeu que lei estadual que torna obrigatória a inclusão na carteira de identidade do tipo sanguíneo do requerente é constitucional. Não há violação ao dispositivo que veda a identificação criminal nos casos em que o sujeito se identifica civilmente, eis que quem requer tal medida é o próprio indivíduo.

12. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA

A CF diz que será admitida ação penal privada nos crimes de ação penal pública, se esta não for intentada no prazo legal (LIX).



Só é possível quando o MP é inerte, e não quando ele requer o arquivamento. Dentro do prazo legal, o MP pode oferecer denúncia, requerer o arquivamento ou ainda requisitar novas diligências. Todavia, se o MP quedar-se inerte. Neste caso, surge o direito de postular o particular a ação pública de iniciativa privada.

13. PRISÃO

Consoante o inciso LXI, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.

Ainda diz a CF que, em seu art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.

Percebe-se que a CF tem uma especial preocupação com a liberdade, que é o principal fundamento do direito de liberdade, de primeira geração (atuação negativa do Estado).

A ideia é que o indivíduo só pode ser preso em flagrante delito ou por ordem judicial.

A própria CF cria temperamentos a essas regras, pois no estado de defesa e no estado de sítio é possível a prisão administrativa, decretada pelo executor da medida, sem a necessidade de breve autorização judicial.

Outro temperamento a essa regra se encontra na imunidade processual absoluta do presidente da República, o qual não se sujeita a qualquer medida cautelar, eis que diz a CF que ele não pode ser preso enquanto não sobrevier uma sentença penal condenatória nas infrações comuns. Tal prerrogativa não é extensível ao governador de Estado-membro.

A CF também traz uma imunidade aos parlamentares, dizendo que congressistas, após a expedição do diploma, só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável.

No caso Delcídio do Amaral, o STF entendeu que houve uma obstrução das investigações, em razão do crime permanente que estaria cometendo, o que geraria uma situação de flagrante, além de não ter configurado a hipóteses de fiança. Neste caso, estariam configurados os requisitos para concessão da prisão do parlamentar.

14. DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO

Segundo o inciso LXIII, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.

Esse direito de permanecer calado não se resume ao preso, podendo ser estendido ao réu, acusado, investigado etc., desde que possa recair suas alegações contra si próprio. O STF entende que qualquer pessoa que não ostente a condição de investigado, mas que com suas alegações possam resultar provas contra si, poderá se beneficiar do *nemo tenetur se detegere*.

Além disso, a CF consagra o direito do preso à integridade física e moral, bem como o direito de receber assistência e do advogado.

Vigora a garantia de que o preso terá sua prisão imediatamente comunicada à sua família e ao juiz competente.

Ademais, segundo o LXIV, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.

No inciso LXV, a CF diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.

O STF, com a ideia de preservar a integridade física, psíquica e a imagem do preso, entende que a utilização de algemas tem o caráter excepcional, editando inclusive a Súmula Vinculante 11: “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e



penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

Veja, só cabe algemas nos casos de:

- resistência
- fundado receio de fuga
- perigo à integridade física própria ou alheia

Esta excepcionalidade deve ser justificada por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

15. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA

Segundo o inciso LXVII, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.

Esta é uma norma que já comportaria execução imediata, sem depender de lei.

Ocorre que o Brasil ratificou o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, bem como a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e estes diplomas, que foram ratificados sem ressalvas, só permitem a prisão pelo descumprimento voluntário de pensão alimentícia.

O art. 5º, §2º, da CF diz que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

O STF entendeu que os tratados internacionais de direitos humanos incorporados pelo Brasil, sem o status de emenda constitucional, teriam status supralegal. Então, estariam acima da legislação infraconstitucional, mas abaixo da CF.

Assim sendo, é possível apenas a prisão do inadimplente voluntário e inescusável do devedor de alimentos, não mais sendo possível a prisão do depositário infiel.

Esses dois tratados tornaram inaplicável a prisão do depositário infiel, seja esta legislação anterior ou posterior. Estes pactos teriam eficácia paralisante, de modo que o texto da Constituição continuaria vigente, mas a legislação ordinária que tratava do dispositivo acerca da possibilidade de prisão do depositário infiel seria revogada.

O STF inclusive editou a súmula vinculante 25, estabelecendo que “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito”.

16. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA

O inciso LXXIV diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Perceba que, em tese, o sujeito deve comprovar a insuficiência de recursos.

A Defensoria Pública presta integral assistência jurídica gratuita em todos os graus. Trata-se de uma instituição permanente. Isto significa que se trata de uma função essencial à função jurisdicional do Estado, pois dá acesso à Justiça ao hipossuficiente.

Essa norma tem eficácia plena. Neste caso, tinha-se que ser nomeado advogados dativos pagos pelo Estado.

A assistência jurídica integral e gratuita compreende não apenas os honorários do advogado, mas também os honorários do perito que irá atuar no processo.

O sujeito beneficiário pela assistência gratuita deve ser beneficiado inclusive no exame de DNA, eis que, se não custear, não haverá efetivamente o amplo acesso ao hipossuficiente. Isto assegura a igualdade.

Esse benefício da assistência jurídica integral e gratuita pode ser extensivo às pessoas jurídicas de direito privado, tenham fins lucrativos ou não. O que não pode ter é capacidade de



pagamento da verba honorária. Impõe-se a ela a obrigação de demonstrar a impossibilidade de sua capacidade financeira. Esta comprovação deve ser mais robusta àquela concedida à pessoa física.

17. INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO POR EXCESSO DE PRISÃO

O inciso LXXV diz que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

Regra geral, a responsabilidade civil do Estado se dá quando o Estado atua como Administração Pública. As atividades legislativas e jurisdicionais ensejam, como regra, a teoria da irresponsabilidade civil.

A questão da responsabilização do Estado por erro judiciário é uma exceção à responsabilidade por atos jurisdicionais. Esta responsabilidade é exclusiva da jurisdição penal indevida.

Primeiro, o sujeito deve promover uma revisão criminal para que a condenação seja invalidada. Depois, busca-se o juízo cível para obter a sua indenização.

Atenção, aquele que fica preso além do tempo fixado na sentença não há erro na esfera jurisdicional, mas tão somente na esfera administrativa, motivo pelo qual o Estado claramente pode ser responsabilizado.

18. GRATUIDADE DOS REGISTROS DE NASCIMENTO E DE ÓBITO

Segundo o inciso LXXVI, são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei o registro civil de nascimento e a certidão de óbito.

O STF foi além, dizendo que é válida a previsão legal de que garante a gratuidade de registro de nascimento, do assento de óbito, bem como da primeira certidão, para todos os cidadãos, seja reconhecidamente pobre ou não.

19. CELERIDADE PROCESSUAL

A CF dispõe em seu art. 5º, inciso LXXVIII que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Essa previsão, apesar de encontrar implicitamente na CF, passou a contar com expressa previsão a partir da EC 45/04. “Quando a Justiça tarda, ela já falhou” (Ruy Barbosa).

20. INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA

20.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACORDO HOMOLOGADO - PRESTADORES DE SERVIÇO - DISPENSA - SINDICATO - LITISCONSÓRCIO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à existência de litisconsorte passivo necessário - sindicato -, ante interesses dos substituídos demitidos em razão de acordo celebrado em ação civil pública entre empresa de economia mista e o Ministério Público do Trabalho, considerado o direito ao devido processo legal. (RE 629647 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-173 DIVULG 22-08-2018 PUBLIC 23-08-2018)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO COMO ORDENADOR



DE DESPESAS. COMPETÊNCIA: PODER LEGISLATIVO OU TRIBUNAL DE CONTAS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. Inadmissão do recurso no que diz respeito às alegações de violação ao direito de petição, inafastabilidade do controle judicial, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988). Precedentes: AI 791.292 QO-RG e ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Constitui questão constitucional com repercussão geral a definição do órgão competente – Poder Legislativo ou Tribunal de Contas – para julgar as contas de Chefe do Poder Executivo que age na qualidade de ordenador de despesas, à luz dos arts. 31, § 2º; 71, I; e 75, todos da Constituição. 3. Repercussão geral reconhecida.

(RE 848826 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 02-09-2015 PUBLIC 03-09-2015)

Ao julgar as ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, em 7/11/2019, o Plenário do STF firmou o entendimento de que não cabe a execução provisória da pena. A 1ª Turma do STF aplicou esse entendimento em um caso concreto no qual o réu estava preso unicamente pelo fato de o Tribunal de Justiça ter confirmado a sua condenação em 1ª instância, não tendo havido, contudo, ainda, o trânsito em julgado. Logo, o STF, afastando a possibilidade de execução provisória da pena, concedeu a liberdade ao condenado até que haja o esgotamento de todos os recursos. STF. 1ª Turma. HC 169727/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 26/11/2019 (Info 961).

Questões

1) (MPE/GO-2019) — Assinalar a alternativa que não corresponde à jurisprudência do STJ:

- a) Não é possível a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei.
- b) É ilegal a cobrança da taxa de esgoto quando não realizado o tratamento final dos dejetos.
- c) Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
- d) A administração pública possui interesse de agir para tutelar em juízo atos em que ela poderia atuar com base em seu poder de polícia, em razão da inafastabilidade do controle jurisdicional.

2) (Juiz TRF2 -2018) — Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta:

- a) Nos casos de acumulação de cargos, empregos e funções, a observância do teto remuneratório é aferida mediante somatório dos ganhos do agente público nos cargos acumulados.
- b) É lícita a acumulação de dois cargos privativos da área de saúde, bastando a demonstração concreta da compatibilidade de horários, mesmo que a soma das horas semanais trabalhadas ultrapasse o limite de jornada estipulado em ato administrativo.
- c) A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais do momento da declaração de invalidade. Nesse caso, não cabe considerar entendimentos ou orientações que prevaleciam à época.
- d) Embora não caiba ao STF obrigar o Poder Executivo a encaminhar projeto de lei destinado a fixar o reajuste anual dos servidores públicos, previsto no artigo 37, inciso X da CF/88, é possível ao Poder Judiciário conceder indenização pleiteada por servidor, a pretexto



de perdas salariais por conta de inflação não repostas em decorrência de tal omissão do Poder Executivo.

e) Em tema de concurso público é possível ao Poder Judiciário reexaminar amplamente o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, com base no princípio da inafastabilidade do controle judiciário.

Comentários

1) Gabarito: letra B. O STJ decidiu que é legal a cobrança de tarifa de esgoto na hipótese em que a concessionária realize apenas uma das quatro etapas em que se desdobra o serviço de esgotamento sanitário, como o tratamento final dos dejetos. (REsp nº 1339313)

2) Gabarito: letra B. Apesar de haver orientação traçada pela Advocacia-Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União no sentido de limitar a 60 horas semanais a carga horária máxima para quem acumule lícitamente cargos públicos, orientação essa seguida pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal afirma que norma infraconstitucional que estipule limite horário não afasta o direito à acumulação. Nesse sentido, os julgados do STJ e do STF, prevalecendo este último, por ser o Supremo o guardião da Constituição Federal. (ARE 859.484 AgR/RJ)

a) Errado. Conforme interpretação do Supremo Tribunal Federal do art. 37, XI (teto remuneratório) e XVI (acumulação lícita de cargos públicos), da Constituição Federal:

"Ementa: TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido" (RE 602.043/MT, rel. min. Marco Aurélio, julg. em 26/4/2017).

c) Errado. Com base no art. 24, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 13.655/2018:

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.

d) Errado. Por força da jurisprudência do Supremo, que não admite essa função do Poder Judiciário, por considerá-la atentatória ao princípio da separação dos poderes:

"Em outras palavras, os apelantes querem que o Judiciário, operando como se fosse legislador, supra a mora do Executivo, concedendo a revisão vencimental. Trata-se, na verdade, de pedido juridicamente impossível, como já proclamou o Supremo Tribunal Federal (...). O meio apropriado para superar a mora do Executivo em dar concretude ao postulado constitucional é o mandado de injunção (...). Registre-se que, nem mesmo no mandado de injunção, o Judiciário poderá fixar os índices de revisão; nele poderá apenas ser cominada ao Executivo a obrigação de, em determinado prazo, encaminhar ao Legislativo projeto de lei de revisão geral dos vencimentos do funcionalismo". (ARE 655.057, relator min. Cármen Lúcia, julgado em 19/9/2011)



e) Errado. Por contrariar sólida jurisprudência do Supremo em contrário:

"O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora de concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas e o conteúdo das questões formuladas, exceto no que diz respeito à cobrança de conhecimento de matéria não prevista no edital do certame". (RE 734.520/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 12/3/2015)



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



61 3033-3739



61 98442-2591

CAPÍTULO 11 – AÇÕES CONSTITUCIONAIS

1. HABEAS CORPUS

O habeas corpus está previsto no art. 5º, que diz em seu inciso LXVIII, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Trata-se de um remédio constitucional (garantia), mas não é só. Trata-se de uma garantia que se traduz em um instrumento colocado à disposição do indivíduo para proteger seus direitos, diante de uma ilegalidade ou abuso de poder cometido pelo poder público.

A CF fala em liberdade de locomoção, incluindo o direito de ir, vir e permanecer do indivíduo. Trata-se apenas de pessoa natural, não cabendo ser impetrado em favor de pessoa jurídica.

A ação de habeas corpus possui natureza penal e isenta de custas, conforme o inciso LXXVII, que diz são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.

O habeas corpus pode ser:

- repressivo ou liberatório: o indivíduo já teve desrespeitado o seu direito de locomoção.
- preventivo (com salvo-conduto): há apenas uma ameaça de que seu direito de locomoção fique limitado.

É possível a obtenção de liminar em habeas corpus, a fim de que não haja uma violação ao direito de locomoção.

Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus, nacional, estrangeiro, analfabeto, doente mental, com ou sem representação, pessoa jurídica em favor de pessoa física etc.

Não há necessidade de advogado, mas em caso de eventual recurso surge uma discussão sobre a existência de capacidade postulatória ou não. O professor Samer Agi entende que não necessita de capacidade postulatória.

O HC será impetrado contra um ato do sujeito coator. Quem pode ser coator?

- Autoridade pública (delegado, promotor, juiz)
- Particular (ex.: médico que não dá alta ao paciente)

Ofensa indireta ao exercício de locomoção justifica a impetração de HC? O STF diz que o HC é cabível também nos casos de ofensa indireta, potencial, ao direito de locomoção. A ofensa indireta se dá quando o ato impugnado puder resultar em detenção ou reclusão do impetrante.

Então, é possível impetrar HC no caso em que se determinou a quebra do sigilo bancário, no caso em que o sujeito está respondendo a processo por sonegação fiscal. Neste caso, ao final, poderá ser condenado a uma pena de detenção ou reclusão. Ao contrário seria a hipótese de HC para um processo administrativo fiscal, sem que tenha havido ameaça à liberdade de locomoção. Aqui, caberia mandado de segurança.

Se o sujeito é convocado para depor numa CPI como testemunha, caberá a impetração de habeas corpus, pois esta convocação influi sobre o direito de locomoção, eis que se o sujeito não comparecer voluntariamente será conduzido coercitivamente, razão pela qual é cabível o HC.

O STF vai elencar algumas hipóteses em que é incabível o HC:



- para impugnar decisões do Plenário ou de qualquer Turma do STF, eis que será ele mesmo que irá decidir;
- para impugnar a suspensão de direitos políticos
- para impugnar penalidade imposta de caráter administrativo disciplinar
- para impugnar decisão condenatória a pena de multa, ou mesmo a processo penal, cuja pena prevista daquela infração seja apenas de multa
- para discutir mérito de punições disciplinares militar. A CF não impede que seja impetrado HC para que o P. Judiciário analise a legalidade da medida adotada, ainda que da seara militar (ex.: competência da autoridade militar).
- para discutir acerca da perda de cargo público, afastamento de cargo, controvérsia sobre guarda de filho etc.
- para discutir acerca de processo de extradição
- para questionar pena privativa de liberdade já extinta
- para questionar processos de impeachment, eis que o crime de responsabilidade tem natureza política
- para questionar indiciamento em inquérito policial, eis que isto não vincula o MP para oferecer a denúncia.

Se não há risco à liberdade de locomoção: ir, vir, permanecer não cabe HC. É uma ação de natureza criminal.

2. MANDADO DE SEGURANÇA

A CF diz no inciso LXIX que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O MS possui um caráter subsidiário, eis que cabe quando não cabível habeas corpus ou habeas data.

O particular em si não pode ser autoridade coator, salvo se estiver exercendo função do poder público.

É uma ação judicial de rito especial, possuindo natureza residual. É uma ação de natureza civil, ainda quando impetrado contra ato de processo criminal.

É cabível MS decorrente de uma ação comissiva ou omissiva, desde que haja violação a direito líquido e certo.

A lei dirá quando não cabe mandado de segurança:

- quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
- quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
- quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado.
- contra lei em tese. Lei de efeito concreto equivale a ato administrativo, razão pela qual caberia MS.

O STF vai abrandar a regra de que não cabe mandado de segurança quando couber recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, desde que o próprio administrado interponha o recurso administrativo. O que é vedado é que o administrado impetre recurso administrativo enquanto pendente a decisão do recurso que ele mesmo impetrou. Ou seja, não pode o administrado impetrar o MS e, ao mesmo tempo, recorrer administrativamente da decisão que lhe foi negativa.

O que é direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele que é demonstrado de plano, de existência manifesta. É apto a ser exercitado no momento da impetração do mandado de segurança.



Cabe atentar que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. As provas devem ser pré-constituídas e, em regra, documentais.

Atenção, a exigência de liquidez e certeza recai sobre a matéria de fato. A matéria de direito, por maior que ela seja, e por mais complexa que se apresente, pode ser apreciada em mandado de segurança.

Quem pode impetrar mandado de segurança?

- Pessoas física
- Pessoas jurídicas, nacionais ou estrangeiras, domiciliadas ou não no Brasil
- Universalidade de bens, como espólio, condomínio, massa falida, herança jacente, tendo capacidade processual para defesa de seus direito.
- Órgão público de grau superior podem impetrar MS para defender sua prerrogativa e atribuições.
- Agentes políticos também podem impetrar MS na defesa de suas atribuições (ex.: governador, magistrado, prefeito, etc.).
- Quem é legitimado passivo?
- Autoridade pública
- Representantes ou órgãos de partidos políticos
- Representantes de entidades autárquicas
- Dirigentes de pessoa jurídica de direito privado, desde que estejam no exercício de atribuição do poder público e somente no que diz respeito a essa atribuição.

E se for atribuição delegada, quem será a autoridade coatora, o agente delegado ou quem delegou? É o agente delegado a autoridade coatora. Isso é importante para definir de quem é a competência para processo e julgamento, eis que o juízo do Tribunal competente para apreciar os atos será o juízo do Tribunal competente para apreciar aquela autoridade delegada. Então, se um ministro de Estado receber uma delegação do presidente da República, o Tribunal competente será o STJ, e não o STF, o qual seria se a autoridade coatora fosse o presidente.

Impetrado o MS, cabe à autoridade coatora prestar as informações ao magistrado. Na petição inicial, o juiz determina a notificação da autoridade coatora com cópia da petição inicial, a fim de prestar informações no prazo de 10 dias.

Além dessa notificação, o juiz determina que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Ex.: ato de delegado federal, o juiz determinará que se dê ciência à AGU, para que, querendo, ingresse no feito, por meio da União).

Cabe medida liminar em mandado de segurança? SIM. O magistrado, ao despachar a inicial, pode apreciar, se houver, o requerimento de concessão do pedido de medida liminar. Neste caso, poderá exigir do impetrante que preste caução, fiança ou depósito para assegurar eventualmente o ressarcimento à pessoa jurídica.

Se for deferida a liminar, o processo passa a ter prioridade de julgamento, a fim de que não fique permanecendo definitivamente a medida precária. Não cabe medida liminar quando o MS tem por objeto:

- compensação de créditos tributários
- entrega de mercadorias ou bens provenientes do exterior
- reclassificação ou equiparação de servidores públicos, como a concessão de aumento ou pagamentos de qualquer natureza

Em suma, se for causar prejuízo para o ente público não cabe medida liminar.

Essas matérias podem ser objeto de mandado de segurança, mas o que não pode é ser objeto de liminar. Mesmo que, no mérito, seja concedida a segurança, não é admitida a execução provisória da medida, sendo necessário ganhar contornos de efetividade primeiro.



O prazo para impetração do MS é de 120 dias, a contar da data que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é decadencial, não sendo passível de suspensão ou interrupção, nem mesmo o pedido de reconsideração administrativo vai interromper a contagem deste prazo.

Todavia, se o ato impugnado é de trato sucessivo, o prazo renova-se a cada ato.

Se o MS for do tipo preventivo, não há que se falar em prazo decadencial, eis que não há ato para iniciar a contagem do prazo.

A competência para julgamento do MS é definida pela autoridade coatora e pela sua sede funcional.

Não cabe ao STF julgar MS contra atos de Tribunais e seus órgãos. Se o ato é do Tribunal, é ele mesmo quem detém a competência para julgar originariamente o mandado de segurança contra seus atos, seus respectivos presidentes, das Câmaras, Turmas, etc.

Sendo concedida a segurança em 1ª instância, aquela sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição por meio de reexame necessário. Trata-se de sentença de 1ª instância, ou seja, não há duplo grau de jurisdição obrigatório se a decisão é proferida por Tribunal, mesmo quando atue em competência originária.

No caso de pagamento de vencimentos e vantagens, assegurados em uma sentença concessiva de MS a servidor público, só será efetuado relativamente às prestações a partir do ajuizamento da ação. A ideia aqui é evitar que o MS substitua uma ação de cobrança. O servidor fazendo jus ao benefício desde 2014, por exemplo, em janeiro de 2016, ele impetra o MS, sendo que em outubro torna-se definitivo. Ele tem direito de receber a partir de janeiro de 2016. Para cobrar o que não foi pago antes de janeiro de 2016 só poderá ser cobrado por meio de uma ação de cobrança.

Lembrando que não há condenação de honorários advocatícios em mandado de segurança, mas há custas e demais despesas processuais.

É também admissível a desistência do mandado de segurança em qualquer momento e grau de jurisdição, independentemente do consentimento do impetrado.

No que toca ao mandado de segurança coletivo, este é direcionado à defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos.

Quem pode impetrar?

- Partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de interesses legítimos, relativos aos seus integrantes ou relativos à finalidade partidária;
- Organização sindical
- Entidade de classe
- Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano.

Este MS coletivo é em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma do Estatuto e pertinentes à sua finalidade, sendo dispensada autorização dos seus associados. Na verdade, neste caso, essas entidades atuam como substitutos processuais, em nome próprio, defendendo direito alheio.

No caso de mandado de segurança coletivo impetrado contra autoridade vinculada à pessoa jurídica de direito público, poderá ser concedida liminar, mas após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica. Ou seja, o juiz manda ouvir o representante judicial da pessoa jurídica, ou manda ele se pronunciar no prazo de 72 horas. Antes da concessão da liminar, deverá haver essa audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público.

3. MANDADO DE INJUNÇÃO

O mandado de injunção sofreu uma regulamentação recente pela Lei 13.300/16.



O que seria a ideia do mandado de injunção?

A CF consagra uma série de direitos, mas é possível que esses direitos, ou parte deles, não possa ser exercida efetivamente pelo seu titular, em razão da falta de norma regulamentadora. Neste caso, promove-se uma ação em que se pleiteia que o Judiciário reconheça a necessidade de edição dessa norma, seja pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, a fim de que o Judiciário supra a falta dessa lei ou ato normativo, para que o titular desse direito possa exercê-lo de maneira idônea.

A CF vai dizer no art. 5º, LXXI, que conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

A Lei 13.300, em seu art. 2º, traz, basicamente, a mesma redação do inciso LXXI, mas com um acréscimo: “Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.

Observe que a lei faz um detalhamento do que justifica a impetração do mandado de injunção, que é pela falta total ou parcial da norma regulamentadora:

- Falta total: inexistência da norma.
- Falta parcial: existência da norma, mas que é insuficiente para que o direito possa ser integralmente gozado (p.ú. do art. 2º).

Conceitua-se mandado de injunção como sendo uma ação de cunho constitucional (remédio constitucional) que pode ser proposta por qualquer interessado, com o objetivo de que torne viável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, e que não estão sendo possíveis ser exercidos em razão da falta total ou parcial da norma regulamentadora (Dizer O Direito – Márcio André).

A síndrome da inefetividade das normas constitucionais ocorre quando o legislador não edita a norma regulamentadora necessária para que seja exercido um direito constitucional, situação na qual o direito acaba por não ser exercido. Esta omissão é inconstitucional, pois viola a CF. Essa omissão faz com que as normas constitucionais fiquem ineficazes.

A CF dispõe sobre dois instrumentos para combate desta síndrome:

- ação direta de inconstitucionalidade por omissão
- mandado de injunção

Segundo a doutrina majoritária é um instituto tipicamente brasileiro.

A lei que regula o MI é de 2016, e a CF é de 1988. Todavia, o STF já entendia que a norma constitucional que previa a possibilidade de se conceder mandado de injunção seria autoaplicável, sendo classificada como norma de eficácia plena.

Qual era o procedimento a ser adotado? O MI seguia as regras procedimentais do mandado de segurança, por analogia.

Existem duas espécies de mandado de injunção:

- mandado de injunção individual: pode ser proposto por qualquer pessoa, seja física, jurídica, em nome próprio, defendendo interesse próprio.
- mandado de injunção coletivo: deve ser proposto por legitimados previstos em lei. Neste caso, propõem a ação em nome próprio, defendendo interesses alheios, razão pela qual atuará como substituto processual.

O MI coletivo não encontra previsão expressa na CF, mas o STF já o admitia antes da Lei 13.300/16.

O MI só cabe quando faltar uma norma regulamentadora. Se alguém promove a ação de mandado de injunção, e durante a pendência do processo é editada a norma regulamentadora, haverá a perda do objeto.



Mas qual é a natureza desta norma regulamentadora? Deve ser uma norma de caráter geral e abstrato. Com isso, pode ser proveniente tanto do Poder Executivo como um ato decorrente do Poder Legislativo.

No mandado de injunção se discute um direito subjetivo do impetrante, seja individual ou coletivo. Neste caso, o controle de constitucionalidade é concreto e incidental, eis que é analisado para viabilizar o exercício de um direito, diferentemente de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é um processo objetivo, tendo por finalidade declarar a omissão.

A própria competência para julgamento do mandado de injunção depende da autoridade que figura no polo passivo, a qual possui atribuição para editar a norma. Sendo o presidente da República, caberá ao STF julgar o processo.

Se for competente uma autoridade estadual, será necessário consultar a CE para definir se for um juiz estadual, ou um Tribunal de Justiça, caso a omissão, por exemplo, seja da Assembleia Legislativa.

É possível mandado de injunção estadual, desde que haja previsão na Constituição Estadual.

Ainda assim, o procedimento a ser observado será o da Lei 13.300/16.

No mandado de injunção, o seu autor é o impetrante.

A legitimidade ativa do mandado de injunção individual, segundo a lei, são as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no art. 2º (art. 3º).

É possível se extrair do trecho “*que se afirmam titulares*” que a Lei adota a teoria da asserção, pois a verificação da legitimidade *ad causam* é feita a partir daquilo que é narrado na petição inicial. Se ao final for verificado que o sujeito não é titular do direito que se diz ser titular, o feito é julgado improcedente, mas há legitimidade para a causa.

A legitimidade ativa do mandado de injunção coletivo está prevista no art. 12 da Lei:

- Ministério Público: quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis;
- Partido político com representação no Congresso Nacional: para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;
- Organização sindical, Entidade de Classe ou Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano: para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. Neste caso, atuam como substitutas processuais, não sendo representação, eis que atuam em nome próprio em interesse alheio.
- Defensoria Pública: quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Perceba que há uma ampliação da legitimidade ativa do MI coletivo com relação ao mandado de segurança coletivo, pois atribui ao Ministério Pública e à Defensoria Pública a legitimidade para promover o mandado de injunção.

Cabe ressaltar que, segundo o parágrafo único, os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes, indistintamente, a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria.

O legitimado passivo do MI pode ser o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora (art. 3º).



Cabe destacar que, se a lei é de iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo, do Presidente do STF ou do Procurador-Geral da República, por exemplo, e se não há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, sem que haja a denominada inércia deliberante, em verdade, esse mandado de injunção deverá ser impetrado em face do Presidente da República, ou em face do PGR, ou do Presidente do STF para que eles apresentem a proposição ao Parlamento, já que a iniciativa é reservada a eles.

O MI, no tocante a competência recursal, encontra disciplina expressa na CF.

Segundo o art. 102, inciso II, 'a', da CF, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. Se a decisão é denegatória, o recurso ordinário é para o STF.

No mesmo sentido é o teor do art. 121, §4º, V, da CF que estabelece ser competência do TSE julgar o recurso interposto pelo autor contra a decisão do Tribunais Regionais Eleitorais quando denegarem o mandado de injunção.

O procedimento do mandado de injunção está previsto na Lei 13.300/16. Se houver alguma omissão, aplica-se a lei do mandado de segurança e o Novo CPC.

3.1. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL

A petição inicial do mandado de injunção deve preencher os requisitos do art. 319 e 320 do NCPC. Na petição inicial, segundo o art. 4º da Lei, o autor deverá indicar, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra ou aquela a que está vinculado. Ou seja, se o ato impetrado for do presidente da República, o impetrante deverá indicar, além dele, a União, que é a pessoa jurídica a qual ele integra.

3.2. CASOS DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 6º)

Quais os casos de indeferimento da petição inicial? A verdade é que a lei vai dizer que a petição inicial será desde logo indeferida quando for:

- manifestamente incabível: quando há uma falha processual, como falta de legitimidade *ad causam*. Ex.: partido político impetrou, mas é causa de ilegitimidade do partido.
- manifestamente improcedente: ocorre quando o pedido é manifestamente improcedente, tal como no caso de o sujeito dizer que não há lei regulamentando, quando, na verdade, já existe a norma regulamentadora.

3.3. RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

Caso o juiz de 1ª instância indefira a petição inicial, o recurso cabível é o recurso de apelação, sendo admitido o juízo de retratação.

Se o indeferimento se der em decisão monocrática do Relator, no caso de competência originária do Tribunal, então o recurso será o de agravo interno. Atente-se que este agravo interno não tem o mesmo contorno do agravo interno do NCPC, eis que o prazo é outro. Na Lei 13.300, o agravo interno é de 5 dias, enquanto no NCPC esse recurso é de 15 dias. Cabe ressaltar que, por não haver a previsão expressa de como deve ser contado o prazo, será considerado como dias úteis, devendo ser aplicada a regra do art. 219 do NCPC.

3.4. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

Ao receber a petição inicial, o juiz ou Relator dará um despacho, ordenando a notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste informações.



No despacho também se ordena ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada cópia da petição inicial, para que, querendo, ingresse no feito.

3.5. MINISTÉRIO PÚBLICO

Não sendo caso de mandado de injunção coletivo, mas sim individual, após terminar o prazo para o impetrado apresentar as suas informações, o Ministério Público é ouvido, dando o seu parecer no prazo de 10 dias. Esgotado o prazo, quer tenha ou não dado o parecer, os autos são conclusos para a decisão, sentença ou acórdão (art. 7º).

A Lei não prevê a possibilidade de concessão, mas o STF já possui precedentes no sentido de não ser possível a concessão de liminar no mandado de injunção.

Existem, basicamente, duas correntes sobre a eficácia do MI:

- Teoria Não Concretista
- Teoria Concretista

A Teoria Não Concretista estabelece que, ao julgar o MI, o Poder Judiciário apenas comunica o órgão omissor, sem regulamentar a falta da norma, pois isto violaria a separação dos poderes. Ou seja, para esta corrente, não há concretização do direito.

A Teoria Concretista estabelece que há concretização do direito. O Poder Judiciário, ao julgar procedente o mandado de injunção, reconhece a omissão do poder público, editando a norma que regulamenta o caso, resolvendo o caso concreto.

Dentro dessa teoria, há algumas correntes:

- **Concretista direta:** o Poder Judiciário implementa desde já a solução para o caso concreto, não sendo necessária qualquer providência.
- **Concretista intermediária:** o Poder Judiciário, antes de viabilizar o direito, fixa um prazo para que o órgão omissor venha a criar a norma regulamentadora, e se esta determinação não é cumprida, então o Judiciário irá regulamentar a norma, viabilizando a prerrogativa.

Ainda dentro da corrente concretista, há aqueles que irão dizer quem serão as pessoas atingidas pela decisão, sendo possível que a solução encontrada para o MI valha para uma pessoa ou que ela já tenha efeito erga omnes, valendo para todas as pessoas na mesma situação.

- Concretista individual: é aquela corrente que entende que a norma concretizada pelo MI só valerá para a pessoa que impetrou o MI.
- Concretista geral: é aquela corrente que entende que a norma concretizada pelo MI valerá para todas as pessoas na mesma situação.

O STF já chegou a adotar a teoria não concretista, mas, após a superação do seu próprio entendimento adotado (*overruling*), o Supremo (2007) adotou a teoria concretista direta geral.

Todavia, a Lei 13.300 via de regra adota a teoria concretista intermediária individual (art. 8º)

Qual é a primeira providência quando o juiz julga procedente o mandado de injunção?

O juiz reconhece a mora, deferindo a injunção. Neste caso, o impetrado tem um prazo para editar a norma regulamentadora. Se ele não supre esta omissão, o Poder Judiciário estabelece as condições em que o direito será exercido.

Cabe ressaltar que este prazo para regulamentação poderá ser dispensado, cabendo ao Poder Judiciário regulamentar diretamente. Neste caso, será necessário demonstrar que outros mandados de injunções já foram julgados, e que já foram concedidos prazos, e aquele poder ou órgão não supriu a omissão no prazo estabelecido no mandado de injunção anterior à norma objeto de apreço. Neste caso, não precisaria adotar a primeira providência, que seria a concessão do prazo, podendo regulamentar o tema desde já (art. 8º, p.ú.).



Como se vê, a eficácia adotada pela Lei 13.300 é a eficácia subjetiva individual da decisão. Ou seja, num mandado de injunção individual, a decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes (art. 9º).

Todavia, no mandado de injunção coletivo, a lei vai além, estabelecendo que a coisa julgada atingirá as pessoas integrantes da coletividade substituídas pelo impetrante. Ou seja, vai atingir aquele grupo, mas ficará limitada a eles.

É possível que a decisão do mandado de injunção assuma efeitos erga omnes ou ultra partes?

A Lei 13.300 estabelece no art. 9º, §1º, que poderá ser conferida eficácia *ultra partes* ou *erga omnes* à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração.

Isto poderá ocorrer tanto no mandado de injunção individual como no coletivo.

A Lei 13.000/16 traz uma regra específica sobre coisa julgada. No mandado de injunção, a sentença faz coisa julgada, mas no mandado de injunção coletivo a sentença faz coisa julgada limitadamente às partes integrantes da coletividade e do grupo, substituídas pelo impetrante.

O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos individuais, então se o sujeito impetrou mandado de injunção individual, e posteriormente outro veio impetrar mandado de injunção coletivo, não haverá litispendência. Todavia, os efeitos da coisa julgada não irão beneficiar o impetrante se ele não requereu a desistência da demanda individual no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva (parágrafo único do art. 13).

Se houver uma norma posterior regulamentando a matéria, já tendo inclusive transitado em julgado a decisão concessiva do MI, a nova norma vai produzir efeitos *ex nunc*, ou seja, não retroage, devendo respeitar o ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. Poderá retroagir desde que seja mais favorável. O que a Constituição veda é que a lei prejudique o ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada, razão pela qual se for para beneficiar poderá retroagir.

A Lei 13.300/16 vai estabelecer a possibilidade de haver uma ação de revisão da decisão que concedeu o mandado de injunção. Esta ação não se confunde com a revisão criminal e nem com ação rescisória.

Essa ação de revisão está prevista no art. 10, que diz sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista, a pedido de qualquer interessado, quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito.

A ação de revisão vai ter o mesmo procedimento do mandado de injunção. Para apreciar a ação de revisão, o juízo será o mesmo que proferiu a decisão no mandado de injunção.

Se o mandado de injunção é julgado improcedente por falta de provas, poderá ser reproposto caso surjam novas provas.

Se vários mandados de injunções individuais tratarem sobre o mesmo tema, e tendo um deles sido julgado procedente, será possível que esta decisão seja aproveitada para os demais processos que tratam do mesmo assunto?

SIM. Conforme o art. 9º, § 2º transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Neste caso, há o princípio da celeridade processual. Há uma homenagem também à segurança jurídica.

4. HABEAS DATA

O *habeas data* é um remédio constitucional, sendo um instrumento das garantias constitucionais.

Segundo o art. 5º, LXXII, conceder-se-á habeas data:



a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

A Lei vai deixar isso mais claro, pois o habeas data vai se justificar tanto para o acesso à informação quanto para retificação, bem como para justificação da informação. O indivíduo pode requerer que na informação conste o motivo de sua existência.

O habeas data tem rito civil, sumário, e basicamente há três aspectos importantes que se busca proteger:

- direito de acesso aos registros;
- direito de retificação;
- direito de complementação do registro.

A Lei 9.507, em seu art. 7º, inciso III, prevê expressamente o cabimento dessa medida para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.

O STF já decidiu que o habeas data é um instrumento adequado para a obtenção de informações fiscais.

O habeas data pode ser impetrado por qualquer pessoa física, brasileira, estrangeira, bem como por pessoa jurídica.

A ação é personalíssima, só podendo ser impetrada pelo titular do direito.

São legitimados passivos as entidades governamentais, instituições e pessoas jurídicas de direito privado, detentoras de bancos de dados contendo informações que possam ser transmitidos a terceiros (ex.: SPC e Serasa).

São características do habeas data:

Interesse de agir: O STF entende que, para que exista interesse de agir para impetrar habeas data, é necessário que o impetrante tenha feito o prévio requerimento administrativo e este tenha sido negado, ou que tenha passado período superior ao razoável, para ser admitido o habeas data.

Inexistência de prazo prescricional: A ação de *habeas data* não está sujeito a um prazo decadencial ou prescricional.

Gratuidade da ação: é gratuita o *habeas data*, não havendo inclusive honorários advocatícios, mas é exigida a presença de advogado.

5. AÇÃO POPULAR

A ação popular está previsto no art. 5º, LXXIII, da CF, dizendo que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

A pessoa jurídica, o MP, a pessoa sem gozo dos direitos políticos não podem propor ação popular, eis que não são considerados cidadãos, pois indispensável o gozo dos direitos políticos.

A ação popular tem natureza coletiva, pois visa tutelar um direito da coletividade como um todo. Essa ação pode ser proposta de modo preventivo ou de modo repressivo:

- preventivo: visa evitar a ocorrência de um ato lesivo ao patrimônio público;
- repressivo: a ação ocorre após o ato lesivo ao patrimônio.

O cidadão é aquele que está no gozo dos seus direitos políticos, podendo, por esta razão, propor a ação a partir dos seus 16 anos, eis que aqui já há capacidade eleitoral ativa.



No polo passivo deve figurar todas as pessoas jurídicas em nome das quais o ato foi praticado e se busca anular, seja de direito privado ou público.

Além disso, todas as autoridades e administradores que houverem autorizado, aprovado ou ratificado a prática do ato.

Em suma, todas as autoridades que, de alguma forma, contribuíram para a ocorrência da lesão.

Além disso, todos os beneficiários do ato ou contrato ilegal deve, fazer parte do polo passivo.

Basicamente, são três grupos do polo passivo:

- pessoas jurídicas, públicas ou privadas, em nome das quais o ato foi praticado;
- pessoas ou autoridades que contribuíram para a prática do ato;
- todos os beneficiários diretos do ato ou do contrato ilegal.

O MP atuará como fiscal da lei. Todavia, se o autor da ação abandoná-la ou se omitir, o Ministério Público poderá atuar como substituto ou sucessor do autor. A análise do MP se fundamenta na existência de interesse público em continuar com o feito.

Com relação à gratuidade da ação popular, esta não se estende ao réu.

O objeto da ação popular é extremamente amplo, pois não é apenas o ato lesivo ao patrimônio material do Estado, podendo também justificar e ser objeto de uma ação popular o patrimônio moral do Estado, patrimônio histórico, patrimônio ambiental do Estado.

É possível perceber isso em razão da existência de ação popular, visando impedir o aumento de subsídio de vereadores que a própria Câmara Municipal concedeu.

Também é caso de ação popular quando o cidadão deseja anular uma isenção tributária concedida ilegalmente a uma empresa, por se tratar de uma violação ao patrimônio público.

O mesmo também caberá se houver o desmatamento de uma área protegida pelo patrimônio ambiental.

O STF entende que não cabe ação popular contra ato de conteúdo jurisdicional. Com base neste entendimento, é possível extrair que a ação popular se restringe à atuação administrativa de quaisquer dos Poderes, não cabendo em face de atuação legislativa ou jurisdicional.

A sentença que julga improcedente a ação popular está sujeita ao duplo grau de jurisdição, sendo denominado de reexame necessário.

A segunda turma do STJ entende que, em sede de ação popular, a lesividade é fato condição para que se possa condenar o agente que figure no polo passivo a ressarcir o dano causado. A corte entendeu que “o binômio ilegalidade-lesividade configura pressuposto elementar para a admissibilidade e a consequente procedência da Ação Popular, para que haja a condenação dos requeridos no ressarcimento ao Erário, decorrente dos prejuízos comprovadamente averiguados ou nas perdas e danos correspondentes (arts. 11 e 14 da Lei 4.717/65).

A competência para julgamento da ação popular é definida pela origem do ato a ser anulado.

Portanto, se o ato tem origem na União, a competência será do juiz federal da seção em que se consumou o ato.

Atenção! Se o presidente da República praticar uma ilegalidade, a ação popular será oferecida ao Juiz Federal, e não ao STF.

Todavia, se a ação popular é contra ato realizado pelo Estado-membro, a competência será do juiz estadual. Será também o juiz estadual nos casos de atos praticados pelo município.

O juízo da ação popular é um juízo universal, impondo-se a reunião de todas as ações conexas. Isso significa que a ação popular torna preventiva a jurisdição do juízo para que todas as ações posteriormente intentadas contra as mesmas partes e com os mesmos fundamentos sejam conexas, devendo ser remetidas a este juízo, por ele estar preventivo.



Não há foro por prerrogativa de função na ação popular.

6. INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA

1. A Primeira Turma, em julgamento conjunto, acolheu pedidos formulados em mandados de injunção para reconhecer o direito dos impetrantes — servidores públicos com deficiência — de ver analisado o requerimento de aposentadoria, apresentado com base no art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal (CF) (1), consideradas as normas da Lei Complementar (LC) 142/2013. Inicialmente, o Colegiado rejeitou as preliminares alusivas à atual tramitação de projeto de lei que regula a matéria, pois não afasta a impetração; e à suposta ausência de prévio requerimento administrativo. No ponto, a CF exauriu as situações que exigem a observância dessa fase: o dissídio coletivo, próprio da justiça do trabalho; e os processos relativos à justiça desportiva. No mérito, destacou que a adoção das normas da LC 142/2013 — retroativamente, inclusive — para suprir a omissão do Congresso Nacional na matéria exige um salto hermenêutico menor do que exigiria a aplicação da Lei 8.213/1991, que cuida da previdência dos trabalhadores em geral. (1) CF/1988: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...) § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: I – portadores de deficiência;” MI 6818/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 13.8.2019. (MI-6818)

Em conclusão de julgamento, o Plenário, por maioria, julgou procedentes os pedidos formulados em ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO) e em mandado de injunção (MI) para reconhecer a mora do Congresso Nacional em editar lei que criminalize os atos de homofobia e transfobia. Determinou, também, até que seja colmatada essa lacuna legislativa, a aplicação da Lei 7.716/1989 (que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor) às condutas de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, com efeitos prospectivos e mediante subsunção. Prevaleram os votos dos ministros Celso de Mello e Edson Fachin, relatores da ADO e do MI, respectivamente (Informativo 931). A corrente majoritária reconheceu, em suma, que a omissão do Congresso Nacional atenta contra a Constituição Federal (CF), a qual impõe, nos termos do seu art. 5º, XLI e XLII (1), inquestionável mandado de incriminação. Entendeu que as práticas homotransfóbicas se qualificam como espécies do gênero racismo, na dimensão de racismo social consagrada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do HC 82.424/RS (caso Ellwanger). Isso porque essas condutas importam em atos de segregação que inferiorizam os integrantes do grupo de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais (LGBT), em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Considerou, ademais, que referidos comportamentos se ajustam ao conceito de atos de discriminação e de ofensa aos direitos e liberdades fundamentais dessas pessoas. Na ADO, o colegiado, por maioria, fixou a seguinte tese: “1. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo,



compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”); 2. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero; 3. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito”. Ficaram vencidos, em ambas as ações, os ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Marco Aurélio. Os dois primeiros conheceram em parte das ações e as julgaram parcialmente procedentes apenas para reconhecer a mora legislativa e dar ciência ao Congresso Nacional para a adoção das providências necessárias. Para eles, não obstante a repugnância que provocam as condutas preconceituosas de qualquer tipo, somente o Poder Legislativo pode criminalizar condutas, sendo imprescindível lei em sentido formal. Portanto, a extensão do tipo penal para abarcar situações não especificamente tipificadas pela norma penal incriminadora atenta contra o princípio da reserva legal (2). O ministro Marco Aurélio inadmitiu o MI, diante dos limites impostos ao exercício, pelo STF, da jurisdição constitucional. Admitiu, em parte, a ADO, para julgar, nessa extensão, improcedente o pedido, por não assentar, peremptoriamente, que se tenha “criminalizar” no vocábulo “punirá”, contido no inciso XLI do art. 5º da CF. Em decorrência disso, não reconheceu a omissão legislativa quanto à criminalização específica da homofobia e da transfobia. Concluiu que, respeitada a liberdade legiferante franqueada ao legislador ordinário, espera-se que a sinalização do STF quanto à necessária proteção das minorias e dos grupos socialmente vulneráveis contribua para a formação de uma cultura livre de todo e qualquer preconceito e discriminação, preservados os limites da separação dos Poderes e da reserva legal em termos penais. (1) CF/1988: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;” (2) CF/1988: “Art. 5º (...) XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;” ADO 26/DF, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 13.6.2019. (ADO-26)



Questões

1) (TJ/AC-2019) — Assinale a alternativa correta a respeito do mandado de injunção.

a) Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora no prazo de trinta dias.

b) Não será cabível o mandado de injunção quando houver regulamentação da matéria por normas editadas pelo órgão legislador competente, ainda que insuficientes.

c) A decisão proferida no mandado de injunção terá eficácia subjetiva limitada às partes, mas ganhará eficácia ultra partes ou erga omnes se não cumprida no prazo estabelecido.

d) Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista, a pedido do interessado, se sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito.

2) MPE/CE-2020 — Com base nas regras que regulamentam os procedimentos especiais no CPC e na legislação extravagante, assinale a opção correta.

a) Conforme o rito previsto para o mandado de injunção, é eivada de nulidade absoluta a decisão do relator que amplie os limites subjetivos da decisão individual transitada em julgado para aplicá-la a casos análogos.

b) Conforme o rito previsto para a ação monitória, é vedado o oferecimento de reconvenção pelo réu, porque essa forma de resposta do réu é incompatível com a técnica de monitorização do procedimento.

c) Conforme o rito previsto para o mandado de segurança, é facultada a interposição simultânea de agravo de instrumento e de pedido de suspensão, pela pessoa jurídica de direito público interessada, contra decisão interlocutória que, em primeiro grau, defira, liminar e provisoriamente, a segurança pleiteada.

d) Conforme o rito previsto para a interdição judicial, caso o interditando não apresente advogado, algum membro do Ministério Público deverá ser nomeado como seu curador especial.

e) Conforme o rito previsto para os embargos de terceiro, a competência para exame dessa medida será do juízo deprecante em qualquer hipótese de constrição de bem de terceiro realizada por carta precatória

Comentários

1) Gabarito: letra D. art. 10 da Lei 13.300/2016: “Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista, a pedido de qualquer interessado, quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito”.

a) Errado. Em face do art. 8º, I da Lei 13.300/2016.

Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para:

I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora;

b) Errado. Nos termos do art. 2º, parágrafo único da Lei 13.300/2016, visto que cabível o mandado de injunção ainda que a regulamentação seja parcial e torne inviável o exercício do direito, liberdade ou prerrogativa.

Art. 2º Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente.

c) Errado. Nos termos do art. 9º, §1º da Lei 13.300/2016, pois a eficácia poderá ser expandida quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, liberdade ou prerrogativa objeto de impetração.

Art. 9º A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora.

§ 1º Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração.

2) Gabarito: letra C. De acordo com Fredie Didier, o disposto no art. 15, § 3º da Lei 12.016/2009, permite concluir que no mandado de segurança é possível a interposição de agravo de instrumento e, também, o ajuizamento do pedido de suspensão dirigido ao presidente do respectivo tribunal, podendo as medidas ser intentadas simultaneamente.

a) Errado. Conforme o rito previsto para o mandado de injunção (art. 9º, § 1º, Lei 13.300/2016), não há nulidade na decisão do relator que amplie os limites subjetivos da decisão individual transitada em julgado para aplicá-la a casos análogos.

§ 1º Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração.

Eficácia ultra partes é aquela que estende a decisão a terceiros que não participaram da relação processual, mas limitada ao grupo, classe ou categoria de lesados.

Eficácia erga omnes é aquela estende os efeitos da decisão a todos os jurisdicionados, tenham ou não participado do processo (Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr, Curso de Direito Processual Civil, vol. 4, 14ª ed., Juspodivm, 2020, p. 482).

b) Errado. É admitida a reconvenção na ação monitória (art. 702, § 6º, CPC).

§ 6º Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção.

A ação monitória é espécie de tutela que busca facilitar a obtenção de um título executivo quando o credor tem prova da existência de seu direito.

A reconvenção é um modo de exercício do direito de ação, sob a forma de contra-ataque do réu contra o autor, dentro de processo já iniciado, ensejando processamento simultâneo com a ação principal, a fim de que o juiz resolva as duas ações na mesma sentença (Nelson Nery Jr e Rosa Maria Nery, Comentários ao CPC, 17ª ed., RT, 2018, p. 1.030).

d) Errado. Conforme o rito previsto para a interdição judicial, caso o interditando não apresente advogado, algum membro do Ministério Público deverá ser nomeado como seu curador especial. ERRADO.

Conforme o rito previsto para a interdição judicial, caso o interditando não apresente advogado, deverá ser nomeado um defensor público como seu curador especial (art. 752, § 3º



em combinação com o art. 72, par. único, CPC). O Ministério Público quando não for parte atuará como fiscal a lei (art. 752, § 1º, CPC).

Art. 72, Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.

Art. 752, § 1º O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º O interditando poderá constituir advogado, e, caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial.

e) Errado. Conforme o rito previsto para os embargos de terceiro, a competência para exame dessa medida será do juízo deprecante se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta, na hipótese de constrição de bem de terceiro realizada por carta precatória (art. 676, par. único, CPC).

Parágrafo único. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta.



CAPÍTULO 12 – DIREITOS SOCIAIS

A partir do art. 6º da CF, que trata dos direitos sociais, é possível extrair que tratam de liberdades positivas (direitos de 2ª geração). Estes direitos exigem um fazer do Estado.

Segundo o art. 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Ressalta-se que o direito à moradia foi inserido pela EC 26.

Não é unânime na doutrina a ideia de que os direitos sociais são cláusulas pétreas. Isso porque o art. 60, §4º, fala que são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais. Os direitos sociais com cunho individual acabam, em verdade, por se tornar direitos individuais e, portanto, devem ser tido como cláusula pétrea. Esta tese é fundada no princípio da vedação do retrocesso.

1. DIREITOS SOCIAIS DO TRABALHADOR

O art. 7º vai enumerar os direitos sociais dos trabalhadores, mas o próprio artigo vai dizer que esta enumeração não é exaustiva.

Segundo o art. 7º são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (há equiparação entre eles), além de outros que visem à melhoria de sua condição social (rol exemplificativo):

- seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário
- fundo de garantia do tempo de serviço;
- salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
- irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
- décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
- salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;
- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
- repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
- gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
- proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
- aposentadoria;
- proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

O parágrafo único do art. 7º estabelece que são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, previstas nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.



Não contempla todos os direitos dos trabalhadores domésticos.

Com relação ao trabalhador doméstico, esta previsão foi inclusive regulamentada pela Lei das Domésticas, que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico.

A CF vai dizer, em seu art. 10 da ADCT, até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato. Também fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

A CF vai dizer no art. 7º que é direito do trabalhador o salário mínimo fixado por lei. A discussão que chegou ao Supremo é a de que se o Presidente da República poderia editar um decreto declarando o valor do salário mínimo. Segundo o STF, se uma lei prever a forma como deve ser realizado esse cálculo, fixando critérios e parâmetros objetivos bem definidos, a serem observados para o cálculo do valor, a mera declaração do valor exato do salário mínimo feita pelo Presidente da República através de decreto é constitucional. Neste caso, o presidente estaria apenas declarando o valor exato do salário mínimo, obedecendo aos critérios previstos em lei.

O STF ainda faz um temperamento em outro ponto do salário mínimo, pois a CF, em seu art. 7º, IV, vai vedar que o salário mínimo seja vinculado para qualquer fim. Todavia, o STF entende que a utilização do salário-mínimo para base de cálculo do valor da pensão alimentícia não ofende a Constituição, pois a ideia é resguardar o padrão de vida do alimentando (beneficiário da pensão).

O art. 7º, XVI, da CF, que cuida do direito dos trabalhadores urbanos e rurais à remuneração pelo serviço extraordinário com acréscimo de, no mínimo, 50%, aplica-se imediatamente aos servidores públicos, por consistir em norma autoaplicável. São direitos sociais atribuídos pela CF aos servidores públicos estatutários: remuneração do trabalho noturno superior à do diurno e a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

Norma constitucional que institui o repouso semanal remunerado é norma de eficácia plena, conforme art. 5, XV, CF.

Segundo o art. 8º da Constituição, é livre a associação profissional ou sindical, devendo ser registrados no órgão competente (Ministério do Trabalho e Emprego).

Compete aos trabalhadores e aos empregadores do sindicato estabelecerem a base territorial respectiva, que não poderá ser inferior a área de um município. Não é possível que haja mais de uma organização sindical na mesma base territorial. Havendo conflito, deverá observar o princípio da anterioridade daquele que realizou o registro no órgão competente.

O art. 8º ainda prevê duas contribuições dos trabalhadores à entidade sindical:

- contribuição confederativa: é fixada pela assembleia geral que não tem natureza tributária, eis que tributo somente pode ser fixado por lei. Esta contribuição somente é devida aos filiados dos sindicatos, não sendo o trabalhador obrigado a nele se filiar.
- Contribuição sindical: é instituída por lei, tendo natureza tributária, sendo devida por todo o trabalhador, seja filiado ou não, bastando que seja daquela categoria.

O STF editou a súmula vinculante 40, estabelecendo que a contribuição confederativa só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo, pois não tem natureza tributária.

Segundo a CF, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

A CF também vai dizer que é assegurado o direito de greve. Apesar de ser autoaplicável, esta norma já foi regulamentada pela Lei 7.783/89.



Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante dos empregados que terá a finalidade exclusiva de formar o entendimento dos empregados e empregadores.

O art. 10 vai dizer que é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.

2. RESERVA DO POSSÍVEL E MÍNIMO EXISTENCIAL

A doutrina estabelece que o Estado deve realizar prestações positivas, implementando direitos que assegurem o bem estar social do cidadão, por meio de direitos como a educação, saúde, segurança, transporte, trabalho etc. Em razão dos altos custos que tais direitos geram ao Estado, o poder público alega que a impossibilidade financeira de arcar com tais ônus, levantando a teoria da reserva do possível.

Essa teoria diz que os direitos sociais, por exigirem uma disponibilidade financeira do Estado para sua concretização, estariam sujeitos a uma cláusula, denominada de cláusula de reserva financeiramente possível, ou simplesmente reserva do possível. É preciso analisar se há possibilidade financeira ou se é impossível financeiramente.

O exemplo clássico dessa teoria é o chamado salário mínimo. A CF é ousada ao fixar o salário mínimo, pois, segundo o art. 7º, IV, este deverá ser nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.

Apesar de todos saberem que tais benefícios não são efetivamente garantidos, sabemos que não é possível simplesmente dobrar o salário mínimo. Esta impossibilidade de assim proceder se dá pela aplicação da teoria da reserva do possível, pois daria mais prejuízos ao próprio trabalhador do que benefícios.

A fim de contrapor a teoria da reserva do possível, a doutrina desenvolveu a teoria do mínimo existencial. Trata-se de um postulado implícito da CF/88, funcionando como um limite da cláusula da reserva do possível.

Em verdade, quando chegamos ao mínimo existencial, não pode o Estado negar a prestação do direito, nem mesmo por alegação de insuficiência de recursos financeiros. Há um mínimo existencial para existência digna que impede a alegação da reserva do possível.

Com base nisso, é possível entender como funciona a atuação do Poder Judiciário na implementação dos direitos sociais.

Cabe ressaltar que o mínimo existencial não se confunde com o mínimo vital, também denominado de mínimo de subsistência, podendo ser dividido em mínimo fisiológico e mínimo sociocultural:

- **Mínimo fisiológico:** compreende as condições materiais mínimas para uma vida condigna, no sentido da proteção contra necessidades de caráter existencial básico, o conteúdo essencial da garantia do mínimo existencial. Fundamenta-se no direito à vida e na dignidade da pessoa humana (ex.: prestações básicas de alimentação, vestimenta, abrigo, saúde ou os meios indispensáveis para a sua satisfação).
- **Mínimo existencial sociocultural:** objetiva assegurar ao indivíduo um mínimo de inserção na vida social e cultural da sociedade. Fundamenta-se no princípio do estado social e princípio da igualdade, mais precisamente no que diz respeito ao seu conteúdo material.



3. O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Sabemos que não é incumbência do Poder Judiciário promover a implementação de políticas públicas. A função de implementar e formular políticas públicas é tipicamente do Legislativo e do Executivo.

Apesar de o Poder Judiciário não ter essa função tipicamente, há reiteradas decisões, em especial do STF, no sentido de que o Judiciário não pode se omitir quando os órgãos com competência para tanto se omitem. Neste caso de omissão, em que há o comprometimento do direito, seja individual ou coletivo, o Judiciário deve intervir.

Cabe lembrar que a judicialização das políticas públicas não é sinônimo de ativismo judicial.

- Judicialização: em síntese, a judicialização consiste em levar ao Judiciário problemas relacionados a falta de concretização de direitos sociais pelo Legislativo e Executivo e, uma vez provocado, o Judiciário decidir o conflito efetivando direitos.
- Ativismo judicial: é uma postura de interpretar a constituição de modo ampliativo. Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo deslocamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva.

Segundo Douglas Eros Pereira Rangel, os direitos sociais originários são aqueles que geram posições jurídicas subjetivas que podem ser diretamente deduzidas das normas constitucionais definidoras de direitos fundamentais sociais, independentemente de concretização legislativa. Já os direitos sociais derivados correspondem às posições jurídicas subjetivas já concretizadas pelo legislador e que somente podem ser sacadas, não diretamente das normas constitucionais definidoras de direitos fundamentais sociais, mas da concretização destas pelo legislador infraconstitucional. Segundo a doutrina, tanto os direitos sociais originários, quanto os derivados podem ser concretizados, no âmbito judicial, por meio das judicializações das políticas públicas.

O STF já disse ser possível determinar que a administração pública realize obras ou reformar emergenciais em presídios, a fim de garantir direitos fundamentais dos presos, em especial a integridade física e mental.

Em verdade, o STF estabelece que é preciso dar efetividade aos direitos fundamentais, dando relevância ao cumprimento dos direitos sociais, pois são os direitos sociais que dão efetividade à Constituição. Por conta disso, o STF inclusive admite o bloqueio de verbas públicas em favor de determinadas pessoas insuficientes para garantir o fornecimento de medicamentos, a fim de respeitar o direito à saúde e ao direito à vida.

O Poder Judiciário reconhece que existem situações denominadas de Escolhas Trágicas, em que o próprio Poder Público deve enfrentar dilemas de difícil solução, como é o caso do fornecimento de um dispendioso tratamento médico a uma pessoa com poucas chances de sobreviver em detrimento de milhares de pessoas em que poderiam ter suas complicações solucionadas por aqueles recursos. Esta expressão de *tragic choices* é o embate entre atender e concretizar um direito e a dificuldade do poder público alocar esses recursos sem prejudicar outras pessoas, hipóteses em que há dificuldades de escolhas.

3.1. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO (EFEITO *CLIQUE*), “JURISPRUDÊNCIA DA CRISE” E PRINCÍPIO DO LIMITE DO SACRIFÍCIO

Esse princípio visa atingir o legislador, a fim de vedar a desconstrução daquilo que foi construído, ou simplesmente destruir o que foi concretizado através da regulamentação de normas constitucionais.



Esse legislador, uma vez tendo regulamentado determinado dispositivo constitucional, não poderia ser retrocedido, no tocante à matéria, e revogar ou prejudicar o direito já reconhecido ou concretizado. A proibição do retrocesso significa que se já foi concretizado determinados direitos, não é possível que tais direitos sejam retrocedidos.

Cabe atentar que, segundo a doutrina, o princípio da vedação do retrocesso social não teria como destinatário apenas o legislador ordinário, mas também ao constituinte derivado. Por esta razão, se uma emenda constitucional viesse a suprir certos direitos sociais, esta emenda seria inconstitucional, por violar o princípio da proibição do retrocesso social.

Vale ressaltar ainda que Gilmar Mendes afirma que não seria possível extinguir direitos sociais já implementados, evitando-se que atinja o núcleo essencial do direito.

Todavia, o ministro Gilmar Mendes aduz que nos momentos de crise econômica e de medidas de austeridade, como o corte de gastos por parte dos Estados, existe uma “jurisprudência da crise”, atenta aos limites materiais do Estado para a concretização de direitos. É o que chamou a atenção, mais recentemente, nas questões relacionadas a políticas de austeridade, as quais têm sido submetida ao Tribunal Constitucional português.

Apesar da “jurisprudência da crise”, é forçoso observar o enfrentamento duro com a realidade, fundado nos princípios do limite do sacrifício e da proibição do retrocesso. A ideia de “limites do sacrifício” foi mencionada pelo Tribunal português e que se relaciona aos princípios da proporcionalidade e da igualdade.

4. INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA

4.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Fornecimento pelo Poder Judiciário de medicamentos não registrados pela ANVISA

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: a) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); b) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e c) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. STF. Plenário. RE 657718/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/5/2019 (repercussão geral) (Info 941). Responsabilidade pelo fornecimento do medicamento ou pela realização do tratamento de saúde Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019 (Info 941).

O Estado, observado o binômio Laicidade do Estado (art. 19, I) / Consagração da Liberdade religiosa (art. 5º, VI) e o princípio da igualdade (art. 5º, caput), deverá atuar na regulamentação do cumprimento do preceito constitucional previsto no art. 210, §1º, autorizando na rede pública, em igualdade de condições, o



oferecimento de ensino confessional das diversas crenças, mediante requisitos formais e objetivos previamente fixados pelo Ministério da Educação.

Dessa maneira, será permitido aos alunos que voluntariamente se matricularem o pleno exercício de seu direito subjetivo ao ensino religioso como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa, por integrantes da mesma, devidamente credenciados e, preferencialmente, sem qualquer ônus para o Poder Público.

STF. Plenário. ADI 4439/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/9/2017

Questões

1) (DPE/AM-2018) — Determinado medicamento incluído em lista do Sistema Único de Saúde deixa de ser adquirido e fornecido por certo Estado, em função de seu alto custo e de ser destinado ao tratamento de doença com incidência muito pequena na população local. Um morador do Estado, portador da doença, que até então vinha se tratando em rede particular, precisará passar a fazer uso do referido medicamento, uma vez que, conforme laudo médico, não surtiram resultados em seu caso as demais formas conhecidas de tratamento para a doença. Move, então, ação judicial em face do Estado e da União, para compeli-los ao fornecimento do medicamento.

Nessa situação, considerando o que dispõe a Constituição Federal e à luz da jurisprudência do STF,

a) apenas o Estado teria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em função da descentralização das ações e serviços públicos de saúde, cabendo, ademais, ao paciente comprovar que não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos do medicamento, de modo a fazer jus ao atendimento pelo SUS.

b) apenas o Estado teria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em função da descentralização das ações e serviços públicos de saúde, sendo, no entanto, que o eventual reconhecimento do direito ao atendimento pelo SUS independe de o paciente dispor ou não de condições financeiras para arcar com os custos do medicamento.

c) em que pese a responsabilidade solidária de Estado e União quanto às ações de atendimento à saúde, não há o dever de fornecimento do medicamento, ainda que esse conste de lista do SUS, estando dentro da esfera de discricionariedade do Estado a alocação de recursos financeiros de modo a atender parcela mais significativa de sua população.

d) Estado e União podem figurar conjuntamente no polo passivo da demanda, em função da responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de prestar tratamento de saúde adequado a quem o necessite, cabendo, no entanto, ao paciente comprovar que não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos do medicamento, de modo a fazer jus ao atendimento pelo SUS.

e) Estado e União podem figurar conjuntamente no polo passivo da demanda, em função da responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de prestar tratamento de saúde adequado a quem o necessite, sendo que o eventual reconhecimento do direito ao atendimento pelo SUS independe das condições financeiras do paciente para arcar ou não com os custos do medicamento.

2) (TJ SP-2018) — O artigo 7º, IV, da Constituição Federal assegura ao trabalhador a percepção de salário-mínimo e proíbe sua vinculação “para qualquer fim”. Diante de tal vedação e de outros preceitos da Carta, como o artigo 39, § 3º, a Súmula Vinculante nº 4 estabeleceu, em relação a vantagem percebida por servidor público, que



a) a hipótese é excepcional, dada a garantia de irredutibilidade dos vencimentos, e a ela não se aplica a vedação de utilização do salário mínimo como indexador ou base de cálculo.

b) também nessa hipótese é vedada a utilização do salário-mínimo como indexador ou base de cálculo, permitida sua substituição por decisão judicial.

c) a hipótese é excepcional, dada a garantia de irredutibilidade de vencimentos, e a ela não se aplica a vedação de utilização do salário mínimo como indexador ou base de cálculo, até que seja substituído por ato do Executivo.

d) também nessa hipótese é vedada a utilização do salário-mínimo como indexador ou base de cálculo, proibida, ademais, sua substituição por decisão judicial.

Comentários

1) Gabarito: letra E. Entendimento do Supremo Tribunal Federal, consoante repercussão geral reconhecida e tese firmada no RE 855.178 RG. "Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Destaco, inicialmente, que a discussão posta nos autos não se confunde com aquela travada no RE 566.471-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, em que se debate o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo (RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5/3/2015, Plenário, Tema 793)".

a) Errado. Tanto o Estado como a União podem figurar no polo passivo, não havendo exigência de comprovação das condições financeiras para arcar com os custos do medicamento.

b) ~~apenas o Estado teria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em função da descentralização das ações e serviços públicos de saúde, sendo, no entanto, que o eventual reconhecimento do direito ao atendimento pelo SUS independe de o paciente dispor ou não de condições financeiras para arcar com os custos do medicamento.~~

c) ~~em que pese a responsabilidade solidária de Estado e União quanto às ações de atendimento à saúde, não há o dever de fornecimento do medicamento, ainda que esse conste de lista do SUS, estando dentro da esfera de discricionariedade do Estado a alocação de recursos financeiros de modo a atender parcela mais significativa de sua população.~~

d) Estado e União podem figurar conjuntamente no polo passivo da demanda, em função da responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de prestar tratamento de saúde adequado a quem o necessite, ~~cabendo, no entanto, ao paciente comprovar que não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos do medicamento, de modo a fazer jus ao atendimento pelo SUS.~~

2) Gabarito: letra D. Art. 7º, IV da CF/88 e Súmula vinculante 4. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;



(...)

§ 3º do art. 39. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Em relação à vantagem percebida pelos servidores públicos a Súmula Vinculante nº 4 prevê:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

a) Errado. A hipótese de vedação ao uso do salário mínimo como indexador ou base de cálculo também se aplica aos servidores públicos.

b) Errado. A parte final da súmula que traz o texto “nem ser substituído por decisão judicial”. Esse trecho refere-se ao adicional de insalubridade, pois, apesar da vedação, o salário mínimo ainda é utilizado como base de cálculo desse adicional, e não pode ser substituído judicialmente.

c) Errado. Como vimos, a vedação também se aplica aos servidores públicos.



CAPÍTULO 13 – NACIONALIDADE

1. CONCEITO

Nacionalidade é um vínculo jurídico-político de direito público interno, que liga a pessoa ao Estado, fazendo com que ela se torne um dos elementos do Estado.

Nação é um agrupamento humano. Este agrupamento está num território, estando ligado com elementos culturais, históricos, econômicos, tradições, costumes, tendo inclusive uma consciência coletiva.

Povo é um conjunto de pessoas que fazem parte de um Estado, sendo um elemento humano. E o povo está ligado entre si em razão de um vínculo jurídico-político, que é a própria nacionalidade.

População, por sua vez, é um conjunto meramente demográfico. Trata-se de um conjunto de pessoas que reside naquele território, podendo ser nacionais ou não.

Cidadão serve para designar os nacionais, natos ou naturalizados, que estejam no gozo dos direitos políticos, e que sejam participantes da vida do Estado.

Estrangeiro é todo aquele que não é nacional, não sendo nato ou naturalizado, sem que pertença aquele povo. Todos aqueles que não são tidos por nacionais são estrangeiros.

É possível que o sujeito tenha mais de uma nacionalidade?

SIM. Tendo o sujeito mais de uma pátria, será ele denominado de polipátrida. Isto ocorre quando dois Estados soberanos adotam critérios diferentes para determinação da nacionalidade:

- Ius sanguinis
- Ius solis

O Brasil adota o ius soli, ou seja, nasceu no Brasil, será considerado brasileiro. Já a Itália adota o ius sanguinis, estabelecendo que sendo filho de italiano, também será italiano. Portanto, tendo o sujeito nascido no Brasil e sendo filho de italiano, o sujeito será polipátrida.

Apátrida ou Heimatlos é o sujeito nasceu num lugar em que é adotado o critério do ius sanguinis, mas os seus pais são de outra nacionalidade, que adota o critério ius soli. Neste caso, o sujeito não adota nenhum critério por não se adequar a eles.

É o caso, por exemplo, de filhos de brasileiros, que nasceram e vivem na Itália. Neste caso, o indivíduo seria apátrida, pois o Brasil adota o critério ius soli, enquanto a Itália o critério ius sanguinis.

2. ESPÉCIES DE NACIONALIDADE

São espécies de nacionalidade:

2.1. ORIGINÁRIA (PRIMÁRIA)

É involuntária, decorrente de um fato natural.

2.2. ADQUIRIDA (SECUNDÁRIA)

É adquirida por um fato volitivo. É obtida pela naturalização.



3. CRITÉRIOS DA NACIONALIDADE

- ***ius sanguinis***: pelo vínculo do sangue (ex.: Itália)
- ***ius soli***: por meio do local do nascimento (ex.: Brasil).

A CF adotou, como regra, o *ius soli*, admitindo ligeiras atenuações.

3.1. BRASILEIROS NATOS

Segundo o art. 12, são brasileiros natos:

- os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.
- os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
- os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente **ou** venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Este critério é o *ius sanguinis*. Neste caso, há uma hipótese de nacionalidade originária potestativa, pois depende da vontade do indivíduo. Esta opção pela nacionalidade brasileira não é livre, devendo ser feita em juízo, num processo de jurisdição voluntária. Uma sentença irá homologar essa opção de nacionalidade, efetuando a sua inscrição, desde que presentes os requisitos objetivos e subjetivos. Cabe ressaltar que durante a menoridade, o sujeito é considerado brasileiro nato. Quando atingir a maioridade, o indivíduo passa a ser submetido a uma condição suspensiva, ficando suspensa a sua condição de brasileiro nato até que manifeste esta opção.

3.2. BRASILEIROS NATURALIZADOS

Como se sabe, não existe direito subjetivo à naturalização, ainda que as condições estejam plenamente atendidas. Isso porque a concessão da naturalização é um ato de soberania nacional, discricionário do Chefe do Poder Executivo, podendo ser:

- nacionalidade tácita: é aquela que independe da manifestação expressa do naturalizando.
- nacionalidade expressa: é aquela que depende da manifestação expressa do interessado em adquirir sua nova nacionalidade. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 só contempla hipóteses de nacionalidade expressa.

A Constituição diz que são brasileiros naturalizados:

- **naturalização ordinária**: são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Neste caso, trata-se de uma forma de nacionalidade ordinária, em que o sujeito preenche os requisitos previstos na lei:

- a) capacidade civil, de acordo com a lei brasileira;
- b) visto permanente;
- c) saber ler e escrever em português;
- d) exercer profissão.



Cumpridos estes requisitos, adquire a nacionalidade brasileira. Se ele for de um país de língua portuguesa, bastará residir no Brasil por um ano e ter idoneidade moral.

- **naturalização extraordinária:** são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Nesse caso, a naturalização será concedida, pois não há discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. Há aqui direito subjetivo, pois o sujeito reside no país há mais de quinze anos, não tem condenação penal e requereu a nacionalidade brasileira.

4. OS PORTUGUESES

A CF estabelece que os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade dos brasileiros residentes em Portugal, são assegurados os mesmos direitos inerentes aos brasileiros daqui, salvo nos casos de brasileiro nato.

Não se trata de dar nacionalidade brasileira aos portugueses, mas somente os direitos inerentes aos brasileiros natos, desde que haja residência permanente e reciprocidade.

5. DIFERENÇAS ENTRE BRASILEIROS NATOS E NATURALIZADOS

A própria CF estabelece um tratamento diferenciado entre brasileiros natos e naturalizados. Todavia, a CF não permite que a lei estabeleça distinção entre brasileiros natos e naturalizados, pois somente a ela cabe distinguir.

São cargos privativos de brasileiros natos:

- de Presidente e Vice-Presidente da República;
- de Presidente da Câmara dos Deputados;
- de Presidente do Senado Federal;
- de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
- da carreira diplomática;
- de oficial das Forças Armadas;
- de Ministro de Estado da Defesa.

Também é exigido que seja brasileiro nato para integrar o Conselho da República, que é o órgão superior do Presidente da República, tendo 6 vagas destinadas a cidadãos brasileiros natos.

A Constituição também veda que o brasileiro nato seja extraditado. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado, desde que tenha cometido crime comum anterior à naturalização ou se tiver se envolvido com tráfico ilícito de drogas.

Em relação ao direito de propriedade, a CF também faz a distinção de que o brasileiro naturalizado, há menos de 10 anos, não pode ser proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Além disso, o brasileiro naturalizado não pode ser sócio, com mais de 30% do capital total votante e participar da gestão destas empresas. Isto visa assegurar o controle da informação.

6. PERDA DA NACIONALIDADE

É possível que o indivíduo perca a sua nacionalidade, mas só poderá ocorrer nas hipóteses expressamente prevista na Constituição, conforme art. 12, §4º, que diz que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:



- tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;
- adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.

O STF entende que o ato de cancelamento de naturalização de estrangeiro somente pode se dar pela via judicial, não podendo ser por ato administrativo.

7. INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA

7.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A Primeira Turma, por maioria, desproveu agravo interposto contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário e fixou a competência de tribunal do júri estadual para julgar ação penal movida contra brasileiro nato, denunciado pela prática de homicídio de cidadão paraguaio, ocorrido no Paraguai. O pedido de extradição do brasileiro foi indeferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em razão de sua condição de nacional [Constituição Federal de 1988 (CF/1988), art. 5, LI] (1). O colegiado entendeu que a prática do crime de homicídio por brasileiro nato no exterior não ofende bens, serviços ou interesses da União, sendo da Justiça estadual a competência para processar e julgar a respectiva ação penal. Asseverou, também, que o Decreto 4.975/2004 (2), que promulgou o Acordo de Extradição entre os Estados-Partes do Mercosul, por si só não atrai a competência da Justiça Federal (CF/1988, art. 109, III, IV, e X)] (3). Isso porque a persecução penal não é fundada no acordo de extradição, mas no Código Penal brasileiro. Citou o entendimento fixado pela Primeira Turma no HC 105.461. Vencido o ministro Alexandre de Moraes, que deu provimento ao agravo ao fundamento de ser competente a Justiça Federal para julgar o feito, com base no art. 11.3 do referido decreto, combinado com o art. 109, III, IV e X, da CF/1988. (1) CF/1988: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;” (2) Decreto 4.975/2004: “Artigo 11. Da Nacionalidade. 1. A nacionalidade da pessoa reclamada não poderá ser invocada para denegar a extradição, salvo disposição constitucional em contrário. 2. Os Estados-Partes que não contemplem disposição de natureza igual à prevista no parágrafo anterior poderão denegar-lhe a extradição de seus nacionais. 3. Nas hipóteses dos parágrafos anteriores, o Estado-Parte que denegar a extradição deverá promover o julgamento do indivíduo, mantendo o outro Estado-Parte informado do andamento do processo, devendo ainda remeter, finalizado o juízo, cópia da sentença.” (3) CF/1988: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) III – as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional; IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; (...) X – os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o exequatur, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;” RE 1.175.638 AgR/PR, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 2.4.2019. (RE-1175638)



EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS. LEI DE MIGRAÇÃO. ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL. PRISÃO PREVENTIVA. INTERPOL. SÚMULA 421 DO STF. DEFERIMENTO. 1. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais requisitos previstos na Lei de Migração e no Acordo de Extradicação entre os Estados Partes do Mercosul, não se verifica óbice ao deferimento da extradicação. 2. Ao Supremo Tribunal Federal não é dado analisar o mérito da acusação ou condenação em que se funda o pedido de extradicação, exceto se constituir requisito previsto na Lei 13.445/2017 ou no acordo de extradicação, em razão da adoção pelo ordenamento jurídico pátrio do princípio da contenciosidade limitada. 3. A existência de vínculo afetivo do extraditando, que possui companheira brasileira, não é, por si só, óbice suficiente ao deferimento do pedido de extradicação. Súmula 421 do STF. 4. Não se exige que o extraditando possua a nacionalidade do Estado requerente desde que, não ostentando a condição de brasileiro, tenha “o crime sido cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado” (art. 83, I, da Lei 13.445/2017). 5. Ausente prova do alegado, não há como acolher a alegação de afronta aos princípios da ampla defesa, da igualdade e do “due process of law”. 6. O pedido de prisão preventiva representado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) e deferido atende às exigências da Lei de Migração e do Acordo de Extradicação entre os Estados Partes do Mercosul. 7. Pedido de extradicação deferido e condicionado à assunção prévia pelo Estado requerente dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017, dentre eles o de detração da pena.

(Ext 1477, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 04-12-2017 PUBLIC 05-12-2017)

Questões

1) (DPE/MA-2018) — Aquele que, dada a circunstância do nascimento, não se vincula a nenhum dos critérios que lhe demandariam uma nacionalidade,

- a) é considerado polipátrida.
- b) é considerado Heimatlos.
- c) tem nacionalidade difusa.
- d) tem nacionalidade alternativa.
- e) tem nacionalidade restritiva

2) (Procurador Jurídico do Município de Poá-2019) — O reconhecimento do direito fundamental à nacionalidade traz como consequência, entre outras,

- a) a exigência em prol da concessão da nacionalidade ao estrangeiro, quando houver dúvida.
- b) que a perda da nacionalidade seja efetivada de modo a não favorecer a manutenção do vínculo, desconsiderando a vontade do indivíduo.
- c) o poder do Estado de obstar o desejo do indivíduo de renunciar ou mudar de nacionalidade.
- d) a relativização da regra da anualidade eleitoral.
- e) ser pressuposto básico para a obtenção da condição de cidadão, ou seja, estrangeiros não podem exercer direitos políticos.



Comentários

1) Gabarito: letra B. *Heimatlos* corresponde a uma expressão alemã originária de *Heimat* (pátria, terra natal) e *los* (solto, livre), e significa sem casa ou apátrida. É a situação da pessoa que, dada a circunstância de nascimento, não se vincula a nenhum daqueles critérios que lhe demandariam uma nacionalidade.

2) Gabarito: letra A.

O reconhecimento do direito fundamental à nacionalidade traz importantes consequências: 1) exige que a interpretação da concessão da nacionalidade a estrangeiro seja sempre feita em prol da concessão; 2) exige que a interpretação da perda da nacionalidade seja sempre restritiva, de modo a favorecer a manutenção do vínculo, caso o indivíduo assim queira; 3) não pode o Estado obstar o desejo legítimo do indivíduo de renunciar e mudar de nacionalidade. (Ramos, André de Carvalho Curso de direitos humanos. São Paulo : Saraiva, 2014, p. 59-60)

b) Errado. De acordo com o mesmo autor, o reconhecimento do direito fundamental à nacionalidade exige que a interpretação da perda da nacionalidade seja sempre restritiva, de modo a favorecer a manutenção do vínculo, caso o indivíduo assim queira.

c) Errado. Não pode o Estado obstar o desejo legítimo do indivíduo de renunciar e mudar de nacionalidade.

d) Errado. Consoante interpretação do mesmo autor acerca do art. 16 da Constituição de 1988: "Para evitar manipulações, dispõe o art. 16 da CF/88 que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, porém não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Esse artigo representa a chamada regra da anualidade eleitoral, que garante o direito de segurança e de certeza jurídicas do cidadão-eleitor contra alterações abruptas das regras inerentes à disputa eleitoral (ADI 3.345, Rel. Min. Celso de Mello, e ADI 3.685, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 22-3-2006)" (Ramos, André de Carvalho Curso de direitos humanos. São Paulo : Saraiva, 2014, p. 61)

e) ser pressuposto básico para a obtenção da condição de cidadão, ou seja, estrangeiros não podem exercer direitos políticos.

Errado, pois apesar de a nacionalidade ser pressuposto básico para a obtenção da condição de cidadão, é possível o exercício de direitos políticos por estrangeiro, por exemplo no Brasil, em relação aos portugueses equiparados (CF/88, art. 12):

Art. 12.....

....

§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.



CAPÍTULO 14 – DIREITOS POLÍTICOS

Nos termos da CF, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto secreto (democracia indireta) e, nos termos da lei, por plebiscito, referendo e iniciativa popular (democracia direta).

O direito ao sufrágio é a capacidade de votar e ser votado, devendo ser visto sob dois aspectos:

- capacidade eleitoral ativa: direito de votar;
- capacidade eleitoral passiva: direito de ser votado.

No Brasil, o direito de sufrágio é universal, pertencendo o direito de votar a todo os cidadãos.

Não há mais o sufrágio restrito, que ocorre quando o direito de votar só é concedido a algum grupo de pessoas que cumprem certas condições, sendo denominado de sufrágio censitário ou sufrágio capacitatório (capacitário). O sufrágio censitário é aquele que exige condições econômicas. O sufrágio capacitário é aquele que exige certas características notadamente intelectual para votar.

A Carta Política ainda impõe que o voto seja direto, votando diretamente no sujeito para exercer o cargo. O voto é periódico, advindo da marca notória da república. O voto também é secreto.

A importância do voto secreto foi demonstrada pelo STF quando considerou inconstitucional um artigo de lei que estabelecia a obrigatoriedade da impressão do voto das eleições. Isto iria retirar o caráter secreto do voto, ocorrendo um retrocesso político.

1. CAPACIDADE ELEITORAL ATIVA

Essa capacidade eleitoral ativa se dá quando o sujeito se alista. Portanto, o alistamento é meio de aquisição para a capacidade eleitoral ativa, dando a ele a qualidade de eleitor, que é um cidadão, pois goza dos direitos políticos.

O alistamento eleitoral e o voto no Brasil são obrigatórios para os maiores de 18 anos.

São facultativos o alistamento e voto para os indivíduos:

- maiores de 16 e menores de 18;
- analfabetos;
- maiores de 70 anos.

A CF não permite o alistamento de estrangeiros e nem dos militares conscritos, que estão no serviço militar.

Alexandre de Moraes trata das características do voto:

- É um direito político-subjetivo
- É de personalidade: só pode ser exercido individualmente.
- É obrigatoriedade formal do comparecimento, ainda que seja para anular o voto.
- É livre
- É sigiloso
- É direto
- É periódico
- É igual a todos, tendo o mesmo valor (*one man, one vote*)

No Estado brasileiro, existe eleição direta para governante?

Há uma opção em que a própria CF trouxe, que se houver vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da república nos dois últimos anos do mandato, haverá eleição para ambos os cargos pelo Congresso Nacional, trinta dias após a abertura da última vaga. É o mandato tampão.



2. PLEBISCITO E REFERENDO

Tanto o plebiscito como o referendo são consultas formuladas ao povo para que deliberem sobre determinada matéria de acentuada relevância. Ambos devem ser autorizados pelo Congresso Nacional:

- Plebiscito: deve ser convocado antes de o ato legislativo ou administrativo ser elaborado;
- Referendo: é convocado posteriormente ao ato legislativo ou administrativo, podendo ser rejeitado ou aprovado pela população.

3. CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA

A capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado.

Para que alguém seja votado, é necessário:

- Cumprir as condições de elegibilidade;
- Não incidir nas inelegibilidades
- As condições de elegibilidade são:
 - Nacionalidade brasileira, ou equiparado a português;
 - Pleno exercício dos seus direitos políticos;
 - Alistamento eleitoral;
 - Domicílio eleitoral na circunscrição;
 - Idade mínima, verificada na data da posse (35 anos para Presidente e Senador, 30 anos para Governador, 21 anos para Deputados, Prefeitos e Juiz de Paz e 18 anos para Vereador). Para vereador a data da idade mínima é verificada na data do registro, e não da posse.
- Filiação partidária: não se admite a candidatura avulsa.
- As condições de elegibilidade podem ser estabelecidas por simples lei ordinária federal, diferentemente das hipóteses de inelegibilidade, que são reservadas a lei complementar.

A Constituição proíbe o recebimento de recursos de entidades ou governos estrangeiros, obrigando que os partidos políticos façam a prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A ideia é que os preceitos se apliquem aos partidos políticos, mas os indivíduos somente poderão participar mediante filiação partidária.

Segundo o STF, a filiação partidária é condição compatível com o exercício da justiça de paz. Os ministros salientaram, ainda, o caráter não jurisdicional das atividades exercidas pelos juízes de paz.

4. INELEGIBILIDADES CONSTITUCIONAIS

A CF também prevê certas hipóteses de inelegibilidades, mas que não são exaustivas, podendo a Lei Complementar tratar sobre outras hipóteses:

4.1. INELEGIBILIDADE ABSOLUTA

O cidadão não pode concorrer em qualquer eleição para qualquer cargo. Estão previstas na Constituição Federal. São inelegíveis os analfabetos e os inalistáveis (conscritos e os estrangeiros).



4.2. INELEGIBILIDADE RELATIVA

É aquela que não está relacionada a sua condição pessoal. Trata-se de uma restrição imposta a determinados cargos eletivos, podendo ser por motivos funcionais, parentesco, afinidade etc.

4.3. INELEGIBILIDADE POR MOTIVOS FUNCIONAIS

Com relação aos motivos funcionais, a CF vai dizer que o presidente da República pode ser reeleito para um único período subsequente (art. 14, §5º). A CF veda a candidatura a um terceiro mandato sucessivo.

Cabe ressaltar que o vice-presidente da República pode se candidatar ao cargo de presidente, mesmo tendo substituído o titular do mandato durante o período em que cumpria o mandato de vice.

O que não pode acontecer é, por exemplo, o governador ganhar a eleição, depois ser reeleito e, no final do segundo mandato, renunciar ao cargo 6 meses antes para se candidatar novamente. Neste caso, há fraude, sendo inadmissível. Da mesma forma, o candidato que já foi reeleito não poderá se candidatar a vice para o terceiro mandato consecutivo, pois haveria uma fraude eleitoral.

O STF também não admite o prefeito profissional (prefeito itinerante). Ou seja, o candidato que foi prefeito reeleito numa cidade não poderá exercer o terceiro mandato eleitoral em qualquer outro município.

Atenção, para se candidatar à reeleição, o chefe do poder executivo não precisa se desincompatibilizar, mas para concorrer a outros cargos é necessário renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Por exemplo, o governador de Goiás deve renunciar ao cargo 6 meses antes para se candidatar a senador.

4.4. INELEGIBILIDADE POR MOTIVOS DE PARENTESCO

A CF também estabelece que a inelegibilidade pode decorrer de casamento ou de parentesco, razão pela qual serão inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

Este dispositivo trata da denominada inelegibilidade reflexa, eis que incide sobre terceiros, alcançando somente o território de jurisdição do titular. Ou seja, a mulher do prefeito não pode ser candidata a vereadora, mas poderá ser candidata a governadora do Estado.

A Súmula Vinculante 18 estabelecerá que a dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade pelo parentesco prevista no art. 14, §7º, da CF. Todavia, o STF entende que não se aplica a súmula vinculante 18 quando a dissolução do vínculo conjugal se der em razão de morte do cônjuge.

O STF ainda vai dizer que se o governador tiver direito à reeleição, mas não o faz, deixando para que sua esposa o faça, não haverá óbice a isso, eis que, se ele mesmo poderia se candidatar, não haveria fraude em relação ao cônjuge, sendo este elegível.

4.5. INELEGIBILIDADE DO MILITAR

É vedada a elegibilidade com relação a condição de militar.

O militar é alistável e pode ser eleito, mas enquanto ele tiver em serviço ativo não poderá se filiar a partido político.



Nesse caso, segundo TSE, a ausência de prévia filiação partidária é suprida pelo registro da candidatura apresentada pelo partido político, desde que seja autorizado pelo candidato.

Todavia, se o militar tem mais de 10 anos de serviço, neste caso ele é agregado pela autoridade superior. Ou seja, se ele for eleito, automaticamente passará, no ato da diplomação, para a inatividade.

Se o militar tiver menos de 10 anos de serviço, para ser candidato, ele deverá se afastar da atividade.

4.6. LEI COMPLEMENTAR PODE TRAZER HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE

Segundo o art. 14, §9º, da CF, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerando a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

Com base nisso, surgiu a LC 64/90, bem como a LC 75/10 (lei da Ficha Limpa).

Houve uma controvérsia sobre a lei da ficha limpa se ela seria constitucional, visto que poderia violar a presunção de inocência, já que o sujeito com condenação em órgão colegiado, mas ainda não transitada em julgado, passaria a ser inelegível.

Além disso, falaram que poderia ser inconstitucional em razão da irretroatividade da lei, pois atingia condutas anteriores à vigência da lei.

No entanto, o STF já se manifestou no sentido de não haver inconstitucionalidade quanto à presunção de inocência e à irretroatividade da lei.

Vale lembrar que o STF já entendeu que é inconstitucional as doações de empresas às campanhas eleitorais e aos partidos políticos. Este entendimento já se encontra inclusive vedado por lei.

O STF também, visando homenagear a transparência do processo eleitoral, reputou inconstitucional dispositivo da lei eleitoral que permitia doações ocultas a candidatos. A doação deve ser declarada sobre quem doou e para quem foi doado.

5. PRIVAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS

O cidadão em situações excepcionais pode ser definitivamente ou temporariamente privado de seus direitos políticos:

- **Privação definitiva:** é a perda dos direitos políticos.
- **Privação temporária:** é a suspensão dos direitos políticos.

A CF não admite a cassação dos direitos políticos. Isso porque se trata de motivação política, o que a CF não permite.

A perda ou suspensão só se dará nos casos de:

- cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
- incapacidade civil absoluta;
- condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
- recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa;
- improbidade administrativa.

A CF não faz distinção sobre o que seria perda ou suspensão.



Alguns casos são evidentes, como o caso de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, eis que configura perda dos direitos políticos.

6. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE ELEITORAL (OU ANTERIORIDADE ELEITORAL)

Segundo o art. 16, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

Isto significa que a lei entra em vigor na data da publicação, só que não se aplicará na eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência.

Este princípio visa assegurar a previsibilidade ao eleitor das regras do jogo.

7. PARTIDOS POLÍTICOS

São grupos sociais com formação ideológica definida e com o objetivo de conquista do poder estatal.

Possuem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado devendo seu estatuto ser registrado no RCPJ de sua sede. Deve ser subscrito pelos seus fundadores com número nunca inferior a 101 com domicílio eleitoral em no mínimo 1/3 dos Estados.

Após adquirida a personalidade jurídica com o registro no RCPJ, deve ser o estatuto registrado no TSE. O registro se inicia de acordo com o previsto no art. 7º, §1º da lei 9096/95: O caráter nacional significa que o partido político tem que ter representatividade nacional.

Organização e funcionamento dos partidos políticos:

- Liberdade de criação: norma dada pelo art. 17 da CF/88
- Caráter nacional: art. 17, I da CF/88
- Autonomia partidária: art. 17, §1º da CF/88. É a liberdade de organização de sua estrutura interna, organização e seu funcionamento.
- É vedado aos partidos receberem recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou subordinar-se a eles.
- É vedada a sua utilização como organização paramilitar .

Não pode haver coligação nas eleições proporcionais – vedação dada em 2017, pela primeira vez aplicada nas eleições de 2020. A EC 97/17 criou uma cláusula de barreira/desempenho prevendo que os partidos somente terão acesso aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e televisão se atingirem um patamar mínimo de candidatos eleitos, cujo efeitos totais somente se produzirão em 2030.

8. INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA

8.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, III, da Constituição Federal, aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Havendo condenação criminal transitada em julgado, a pessoa condenada fica com seus direitos políticos suspensos tanto no caso de pena privativa de liberdade como na hipótese de substituição por pena restritiva de direitos. Veja o dispositivo constitucional: Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; STF. Plenário. RE 601182/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 8/5/2019 (repercussão geral)



A vedação ao exercício de três mandatos consecutivos de prefeito pelo mesmo núcleo familiar aplica-se também na hipótese em que tenha havido a convocação do segundo colocado nas eleições para o exercício de mandato-tampão. STF. 2ª Turma. RE 1128439/RN, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 23/10/2018

Questões

1) (TJ/RJ-2019) — Narciso, 19 anos de idade, que está em pleno gozo dos seus direitos políticos, pretende candidatar-se ao mandato de Vereador em seu Município nas próximas eleições, que ocorrerão em outubro de 2020. Poliana, que é sua cunhada, ocupava o cargo de Presidente da Câmara de Vereadores, no mesmo Município, mas, atualmente, veio a assumir o cargo de Prefeito em razão da perda de mandato dos seus ocupantes anteriores. Segundo o disposto na Constituição Federal, nessa situação hipotética, é correto afirmar que Narciso

a) poderá se candidatar, desde que tenha se tornado cunhado de Poliana somente após esta ter assumido o mandato eletivo.

b) poderá se candidatar, pois a relação com Poliana não é condição que o impeça de concorrer, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

c) não está impedido de se candidatar ao mandato de Vereador, desde que não seja para reeleição, uma vez que Poliana assumiu o cargo de Prefeito em substituição aos titulares.

d) não poderá se candidatar, tendo em vista a sua condição de inelegibilidade por ser cunhado de Poliana, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

e) poderia se candidatar, não havendo incompatibilidade eleitoral para o exercício do mandato, mas não poderá fazê-lo por não ter a idade mínima para se candidatar.

2) (TJ/MS-2020) — O artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar federal nº 64, de 18 de maio de 1990, estabelece, como causa de inelegibilidade para qualquer cargo, a condenação, pelos crimes que especifica, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena. A esse respeito, o Tribunal Superior Eleitoral tem decidido que

a) o reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça Comum afasta a inelegibilidade em questão.

b) os crimes contra a ordem tributária não estão abrangidos pela citada hipótese de inelegibilidade.

c) o Tribunal do Júri não pode ser considerado órgão judicial colegiado para os fins da aplicação dessa hipótese de inelegibilidade.

d) os crimes previstos na Lei de Licitações (Lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993) não estão abrangidos pela citada hipótese de inelegibilidade.

e) o prazo concernente à hipótese de inelegibilidade em questão projeta-se por 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

Comentários

1) Gabarito: letra D. Narciso se enquadra na regra trazida pelo § 7º do art. 14 da CF/1988, de inelegibilidade reflexa, em razão do parentesco em segundo grau, por afinidade.

a) Errado. A inelegibilidade reflexa permanece.

b) Errado. Se for titular de mandato e candidato a reeleição, poderá concorrer.



c) Errado. Se for para reeleição, poderá se candidatar. Além disso, são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito.

e) Errada. Narciso tem a idade mínima para se candidatar a Vereador, de acordo com o § 3º, VI, "d" do art. 14 da CF/1988.

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

...

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

...

VI - a idade mínima de:

...

d) dezoito anos para Vereador.

2) Gabarito: letra E. Nos termos do art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, o prazo de inelegibilidade, hipótese que abrange somente os condenados pelos crimes previstos no mencionado dispositivo, projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena imposta, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

a) Errado. Prescrita a pretensão executória pela Justiça Comum, permanecem os efeitos secundários da condenação, entre os quais fica a inelegibilidade. TSE, Súmula 59: O reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça Comum não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, porquanto não extingue os efeitos secundários da condenação.

b) Errado. O TSE entende que os crimes contra a ordem tributária enquadram-se nos crimes contra a Administração Pública, previstos no art. 1º, I, e, 1 (Ac de 19.12.2016 no AgR-REspe nº 40650, rel. Min. Luiz Fux.)

c) Errado. O TSE entende que o Tribunal do Júri é órgão judicial colegiado soberano cujas decisões são aptas a ensejar a inelegibilidade daqueles que condenar (Ac. de 11.11.2014 no RO nº 263449, rel. Min. João Otávio de Noronha, red. designado Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura)

d) Errado. O TSE se posiciona no sentido de que os crimes contra a Administração e o patrimônio públicos abrangem os previstos na Lei de Licitações (Ac. de 4.10.2012 no REspe nº 12922, rel. Min. Nancy Andrighi.)



CAPÍTULO 15 – ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO

A Constituição de 1988 estabelece que a organização Político-administrativa da República compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos.

É preciso nos atentar a algumas classificações.

1. FORMAS DE ESTADO

Forma de Estado pode ser conceituada como sendo a distribuição geográfica do poder político em um determinado estado nacional. Espécies de forma de estado: Estado Unitário, Estado Federal e Confederação.

1.1. ESTADO FEDERADO

É aquele em que há uma repartição constitucional de competências, havendo diferentes entidades governamentais com autonomia. Há uma descentralização política de competências. No Estado federado, estas diferentes entidades políticas autônomas formam, através de um vínculo indissolúvel, em que diversas formam um Estado Soberano. Por conta disso, não há um direito de secessão em um Estado federado.

1.2. ESTADO UNITÁRIO

É aquele em que há um centro de poder político, podendo ser dividido em:

1.2.1. UNITÁRIO PURO

Há uma centralização do poder. Esse tipo de estado unitário puro, que não há nenhum tipo de distribuição do poder político, é uma característica de microestados (Vaticano, Malta, Mônaco etc). Atualmente, apesar desse conceito, os atuais estados unitários complexos ou compostos trabalham com a descentralização administrativa, ou seja, braços da administração são criados com personalidade jurídica própria para a tomada de decisões. Esses braços podem ser em forma de distritos, regiões, departamentos, municípios, etc. São criadas regiões administrativas com poder de mando, com personalidade jurídica própria para tomada de decisões, mas tudo ligado ao poder central (França, Portugal). Por conta disso, pode-se dizer que dois problemas são resolvidos, pois há uma maior democratização com o Estado se aproximando da população, chegando às mais variadas regiões por conta da descentralização, fazendo com que o povo se sinta mais partícipe do poder. Além disso, há a desburocratização, pois havendo qualquer problema, não há necessidade de ir até o polo central/capital, bastando ir à regional na qual se tem a possibilidade de tomada de decisões.

1.2.2. UNITÁRIO DESCENTRALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE

As decisões políticas são centralizadas, mas as execuções dessas decisões políticas são delegadas.

1.2.3. UNITÁRIO DESCENTRALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE E POLITICAMENTE

Aqui há uma descentralização administrativa dessas decisões políticas tomadas, mas essas entidades são dotadas de uma autonomia para execução das decisões tomadas pelo governo central. Diante disso, podem decidir, no caso concreto, o que é mais conveniente ou oportuno fazer.

Qual é a diferença entre o Estado descentralizado administrativamente e politicamente e o Estado federado? No Estado federado, esta repartição de competências é dada pela Constituição. Mesmo as decisões políticas são tomadas por entes diversos. No



Estado unitário, apesar de poder haver a descentralização, poderá regredir à centralização. Nesse caso, esta regressão poderá se dar no momento e na forma que entender mais conveniente, ao contrário do estado federado em que encontra guarida da repartição pela CF.

1.3. CONFEDERAÇÃO

Enquanto no Estado Federal há uma distribuição do poder político, na qual temos entes dotados de autonomia e que se reúnem por um vínculo indissolúvel para formação de um estado soberano, não admitindo o direito de secessão (ex.: CF/88), na Confederação também há uma distribuição efetiva do poder político, mas nesta todos os estados que se reúnem não abrem mão de sua soberania, podendo a qualquer momento sair da confederação, ou seja, admite-se o direito de secessão. A confederação nasce a partir de um tratado internacional, pois os estados são soberanos.

As principais diferenças entre o estado federal e a confederação são:

- No estado federal se tem um ente soberano e os demais entes são autônomos, enquanto na confederação todos os entes são dotados de soberania.
- No federalismo é proibido o direito de secessão, ou seja, o direito de ruptura do vínculo. No Brasil, o art. 1º da Constituição⁹ traz o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. Já na confederação permite-se o direito de secessão.
- O estado federal nasce de uma constituição do ente soberano. A confederação nasce de um tratado ou um acordo entre os entes soberanos e cada um desses entes soberanos da confederação tem sua própria constituição.
- No estado federal existe um órgão de cúpula do poder judiciário. No caso do Brasil é o STF¹⁰, seja por via originária ou recursal. Na confederação não existe esse órgão de cúpula do poder judiciário, porque todos os entes são soberanos e cada um possui o seu órgão máximo do judiciário. O vínculo na confederação é mais tênue, mais fraco.

Não se pode confundir forma de estado com forma de governo, nem com sistema de governo e nem com regime político.

2. FORMA DE GOVERNO

É o conhecimento da maneira pela qual se dará o governo, bem como a relação entre governantes e governados. Em outras palavras, é o modo como se dá a relação entre representantes e representados. São basicamente duas as formas de governo:

2.1. REPÚBLICA

São características básicas da república:

- eletividade dos governantes;
- temporalidade do exercício do poder;
- representatividade popular;
- responsabilidade do governante, que inclusive deve prestar contas.

2.2. MONARQUIA

São características da monarquia:

9 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos.

10 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...)
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta



- hereditariedade do governo;
- vitaliciedade no governo;
- inexistência da representação popular, pois quem colocou o governante lá foi o seu sangue;
- irresponsabilidade do governante, sem que haja dever de prestar contas.

3. SISTEMA DE GOVERNO

É o modo como se dá a relação dos poderes dentro de um estado nacional, sobretudo entre o legislativo e o executivo. Os dois principais sistemas de governo são o presidencialismo e o parlamentarismo:

3.1. SISTEMA PRESIDENCIALISTA

Há uma maior independência entre o poder executivo e o legislativo. É característica do presidencialismo que o Presidente da República acumula as funções de chefe de estado (na esfera internacional) e chefe de governo (na esfera interna), além de ser o chefe da administração pública federal. O governante tem um mandato com prazo certo.

3.2. SISTEMA PARLAMENTARISTA

Há uma colaboração entre o executivo e legislativo. O chefe do executivo, que é chefe do estado, escolhe o primeiro ministro, o qual irá exercer a função de chefe de governo. Uma vez escolhido o primeiro-ministro, ele elabora um plano de governo, devendo este ser submetido à apreciação do Parlamento. A partir de então, o primeiro-ministro somente permanecerá no poder enquanto o seu plano de governo obtiver o apoio do Parlamento. Ou seja, no sistema parlamentarista a chefia é dual: chefia de estado, a ser exercida por uma monarca ou presidente, e a chefia de governo, exercida pelo primeiro-ministro. O chefe de governo permanece na chefia enquanto obtiver a maioria parlamentar, pois depende do apoio do Parlamento.

Exemplo de perda do apoio do Parlamento ocorreu recentemente no Reino Unido, quando aprovou a saída da União Europeia. Nessa situação, David Cameron disse que não seria mais o primeiro-ministro, pois o seu plano de governo seria ficar na União Europeia, razão pela qual não caberia mais a ele se manter como chefe de governo, tendo em vista que perdeu o apoio ao seu plano.

4. REGIME DE GOVERNO

O Regime de governo diz respeito à participação do povo nos processos de poder.

Os regimes de governo se dividem basicamente em dois:

4.1. REGIME DEMOCRÁTICO

Há participação popular.

4.2. REGIME AUTOCRÁTICO

Não há participação popular.

O Brasil, à luz da Constituição Federal de 1988, é:

- **Forma de Estado:** Estado Federal;
- **Forma de Governo:** República;
- **Sistema de Governo:** Presidencialista e
- **Regime Político:** Democracia.

5. A FEDERAÇÃO E SUAS CARACTERÍSTICAS

A federação na Constituição de 1988 não é uma típica federação, pois o estado brasileiro não é um típico estado federado. Isso porque, em verdade, somos compostos de 4 espécies distintas de entes federados, dotados de autonomia: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A União e os Estados são típicos da federação, porém o Distrito Federal e os Municípios são atípicos.

A doutrina explicita que existe o federalismo típico (federalismo de 1ª grau), que é aquele exercido da relação da União com os Estados. Porém, no Brasil, temos também um federalismo de 2º grau, pois além da relação da União com os Estados, também há relação dos Estados com os Municípios.

5.1. CLASSIFICAÇÕES DO FEDERALISMO

Temos dois federalismos: federalismo centrípeto e o federalismo centrífugo.

5.1.1. FEDERALISMO CENTRÍPETO

Também chamado de federalismo de agregação, é aquele que nasce de um movimento da periferia para o centro. Há um conjunto de estados dependentes e soberanos que abrem mão de sua soberania, fazendo um movimento centrípeto (de fora para dentro) que forma um estado federado. Exemplo: federalismo norte-americano, porque em 1781 os EUA eram uma confederação, e, então resolveram alienar sua soberania para um único ente e ficar somente com a autonomia, criando um estado federado em 1787.

5.1.2. FEDERALISMO CENTRÍFUGO

Também chamado de federalismo de segregação, é aquele que nasce de um movimento do centro para a periferia. Ocorre quando um estado unitário decide se descentralizar. Há um estado soberano que decide conferir autonomia a entidades dentro do Estado. Trata-se de um movimento de dentro para fora, sendo denominado de movimento centrífugo. Neste federalismo, há ainda um poder central, no caso a União, que detém certas competências mais amplas do que os demais estados. Exemplo: Brasil. Em 1824 o Brasil era um estado unitário, na nossa primeira constituição. Não existiam estados membros, eram nove províncias. Em 1891 tivemos nossa primeira constituição republicana e federalista. Saímos de um estado unitário para o federalismo, ou seja, do centro para a periferia, fazendo com o que nosso federalismo seja centrífugo.

Temos o chamado federalismo dual e o federalismo cooperativo:

5.1.3. FEDERALISMO DUAL OU CLÁSSICO

É aquele que estabelece competências fechadas e específicas para os entes que vão desenvolvê-las de forma separada e independente. Ou seja, os entes terão suas competências específicas não dividindo-as com os demais. É típico de estados liberais.

5.1.4. FEDERALISMO COOPERATIVO OU NEOCLÁSSICO

É aquele em que dois ou mais entes vão atuar conjunta ou concorrentemente para a mesma matéria. Não há uma separação rígida de competências, pois a ideia é de que os entes federativos atuem em conjunto de forma comum ou concorrente. O federalismo brasileiro é cooperativo, pois a CF prevê vários artigos de competência comum ou concorrente. Típico de estados sociais.



O Brasil trabalha com os dois. Temos uma parte dual e uma parte cooperativa ou de integração.

5.1.5. FEDERALISMO POR INTEGRAÇÃO

Há uma relação de subordinação dos Estados em relação à União (repartição vertical de competências), desvirtuando a natureza do federalismo, o que o aproxima do Estado Unitário descentralizado.

Há, ainda, o federalismo simétrico e assimétrico.

5.1.6. FEDERALISMO SIMÉTRICO

É aquele que visa a uma divisão de competências e receitas de forma paritária (equivalente e igualitária) entre os entes da mesma categoria, mesma estrutura. Ex.: Estados Unidos, onde existem 50 estados e existem 2 senadores para cada estado. O que se busca é a igualdade de tratamento, como por exemplo quando a CF estabelece tratamento igualitário entre os Estados (ex.: repartição de competências, regime tributário, representação dos Estados, etc.). O problema é que o federalismo simétrico pressupõe uma igualdade de desenvolvimento entre os entes, como a homogeneidade de cultura, grau de desenvolvimento, de educação, etc. São características a possibilidade de intervenção federal, Poder Legislativo bicameral, Poder Judiciário dual (federal e estadual) e poder constituinte originário e poder constituinte decorrente

5.1.7. FEDERALISMO ASSIMÉTRICO

É aquele que parte do pressuposto da existência de desigualdades regionais (sócioeconômicas, políticas, culturais, geográficas, etc), e busca reverter esse quadro com atribuições de competências e receitas de forma desigual. Também se busca reverter esse quadro mediante a realização de programas direcionadas a determinadas regiões que acabam sendo tratadas de forma diferenciadas. Ex.: Canadá.

A Constituição vai estabelecer tratamentos distintos aos entes federados em certas disciplinas, tendo por certa finalidade igualar os entes. Visa reduzir as desigualdades regionais, que é objetivo fundamental da República.

Existe um debate na doutrina acerca do tipo de federalismo brasileiro no que diz respeito ao equacionamento de desigualdades. Muitos afirmam que faz parte do federalismo assimétrico, mas a corrente majoritária (Professor Bernardo Gonçalves é adepto a essa corrente), entende que é classificado como simétrico. Por exemplo, cada estado brasileiro possui 3 senadores.

Porém, por mais que o estado brasileiro seja classificado como simétrico, existem manifestações assimétricas no nosso federalismo. Por exemplo, os art. 3º, III¹¹; art. 43¹²; art. 151, I¹³; art. 159, I, c¹⁴, todos da CF, demonstram exceções ao federalismo simétrico, são todos

11 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

12 Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais

13 Art. 151. É vedado à União: I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

14 Art. 159. A União entregará: I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na seguinte forma: (...) c) três por



esses exemplos de situações assimétricas possíveis no nosso federalismo, classificado como simétrico.

Quadro-resumo: A Federação brasileira é de primeiro grau, visto que declina competências da União para os Estados, e de segundo grau, pois avança dos Estados para os Municípios. Foi formada por segregação ou desagregação, ou seja, havia um Estado unitário que se descentralizou criando várias unidades autônomas. É vedado o direito de secessão, pois um ente não pode decidir se separar do Brasil. E, por fim, realmente não há superioridade de nenhum ente.

6. O FEDERALISMO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988

Cabe lembrar que os entes federados possuem tão somente autonomia. Nem mesmo a União tem soberania, sendo autônoma.

Essa autonomia da União, Estados, Distrito Federal e Municípios se desdobra numa tríplice capacidade:

- Capacidade de auto-organização: é a capacidade de elaborar sua própria legislação.
- Capacidade autogoverno: capacidade de se autogovernar.
- Capacidade autoadministração: capacidade de se auto gerenciar.

Não há precedência de um ente federado sobre o outro, mas somente uma distribuição de competências constitucionais. Esta é a razão pela qual um ente pode ter sua atividade julgada inconstitucional quando violar a iniciativa cabível a outro ente.

Inclusive o STF já entendeu que a fixação, pelas Constituições dos Estados, de data para o pagamento dos vencimentos dos servidores estaduais e a previsão de correção monetária em caso de atraso não afrontam a CF. No entanto, a Constituição do Estado que estende a obrigação aos servidores municipais e aos empregados celetistas de empresas públicas e sociedades de economia mista viola a autonomia desses entes.

O ente soberano é a República Federativa do Brasil. A União não goza de soberania. Se confunde muito a União como sendo o ente soberano pois a República Federativa do Brasil (RFB) tinha que escolher alguém para representá-la e exercer suas prerrogativas tanto no âmbito internacional quanto no interno. Por exemplo, o art. 21, I, CF¹⁵ diz que é de competência da União manter relações com os estados estrangeiros, mas está exercendo prerrogativas da República Federativa do Brasil, que é o ente soberano.

Outro exemplo da posição da União em relação à RFB é o art. 18, CF¹⁶, que diz que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos.

Mas do que se trata essa autonomia? Autonomia, que os entes federativos possuem, é a capacidade para desenvolver atividades dentro de limites previamente determinados pelo ente soberano.

cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer;

15 Art. 21. Compete à União: I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais

16 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição



Dentro do nosso federalismo, a capacidade para desenvolver atividades se divide numa tríplice capacidade: **auto organização** (normatização própria), **auto governo** e **auto administração**.

6.1. AUTO ORGANIZAÇÃO

A União se auto organiza através da constituição federal e leis federais. O estados, da constituição estadual e leis estaduais. O municípios da lei orgânica do município e leis municipais. E o DF da lei orgânica do DF e leis distritais.

6.2. AUTO GOVERNO

A União se auto governa através do poder legislativo, executivo e judiciário (art. 2º, CF¹⁷). A própria constituição delimita os poderes do ente autônomo. Aqui, o Congresso Nacional é o poder legislativo da União e também da RFB. Tanto é assim que o Congresso Nacional produz dois tipos de leis: lei nacional e lei federal. A lei nacional tem amplitude nacional e vincula todos os entes, como por exemplo, Código Penal. E também o próprio Congresso Nacional faz leis só federais, como, por exemplo, a Lei 8.112/90, que vincula só a União e a sua estrutura, não vinculando os servidores estaduais e municipais que terão seus próprios estatutos.

A mesma coisa com o Presidente da República (poder executivo). O Presidente da República Federativa do Brasil e, ao mesmo tempo chefia e preside a estrutura federal da União.

O auto governo dos estados também tem poder legislativo (art. 27, CF¹⁸) executivo (art. 28, CF¹⁹) e judiciário (art. 125, CF²⁰), tudo sempre delimitado pela constituição da República Federativa do Brasil.

Os municípios e o DF fogem à lógica do auto governo, porque existem exceções. Para os municípios teremos somente os poderes legislativo e executivo (art. 29, CF²¹), não existindo poder judiciário municipal. Além de faltar poder judiciário, falta representação federativa no Senado. É tradicional, no federalismo, ter uma câmara de representantes dos entes, mas não existe representação federativa dos municípios.

Por conta disso, autores como José Afonso da Silva defendem que municípios não são propriamente entes federativos com autonomia política, sendo somente nominal na constituição.

No entanto, a corrente majoritária defende que o municípios é um ente federativo dotado de autonomia política, embora existam exceções à sua autonomia.

O mesmo ocorre com o DF. O DF não deixa de ser um ente federativo com autonomia política, mas tem exceções. O DF tem poder legislativo, executivo e judiciário. Mas existem exceções da autonomia do DF, como seu próprio poder judiciário, que é organizado e

17 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

18 Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

19 Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77.

20 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

21 Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:



estruturado pela União, assim como o Ministério Público do DF que está dentro da estrutura do Ministério Público da União. Além disso, as polícias civil e militar do DF são organizadas e mantidas pela União (Súmula 647, STF²²). Em termos constitucionais, temos os artigos 22, XVII²³; art. 21, XIII²⁴ e XIV,²⁵ todos da CF, que provam as exceções à autonomia do DF.

Sobre as polícias civil e militar do DF, quem as organiza e mantém é a União, mas quem manda é o Governador do DF (art. 144, § 6º, CF²⁶).

6.3. AUTO ADMINISTRAÇÃO

É o exercício de competências administrativas, legislativas e tributárias pelos entes. Competências são faculdades juridicamente atribuídas aos entes para a tomada de decisões (administrativas, legislativas e tributárias) e com isso se auto administram.

6.4. TÉCNICAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS ENTES

Serão analisadas duas grandes técnicas: repartição horizontal de competências e repartição vertical de competências.

6.4.1. TÉCNICA DE REPARTIÇÃO HORIZONTAL

É aquela na qual existe uma distribuição fechada e específica de competência entre os entes, em que cada ente terá suas competências específicas não dividindo-as com os demais. É “cada um no seu quadrado”.

Tem origem com a constituição dos Estados Unidos em 1787, em que a União terão competências enumeradas e os estados as competências remanescentes.

Repartição Horizontal desenvolve o federalismo dual ou clássico e nasce no Brasil na constituição de 1891, em que a União terão competências enumeradas e os estados as competências remanescentes.

Atualmente, na CF/88 temos a União com competências enumeradas e os estados as competências remanescentes e os municípios com competências também enumeradas.

6.4.2. TÉCNICA DA REPARTIÇÃO VERTICAL

É aquela na qual dois ou mais entes vão atuar conjunta ou concorrentemente para uma matéria ou tema. Por exemplo, temas como saúde e educação são temas concorrentes entre os entes nos âmbitos federais, estaduais e municipais.

22 Súmula 647, STF. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar do Distrito Federal.

23 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes

24 Art. 21. Compete à União: (...) XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios.

25 Art. 21. Compete à União: (...) XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio

26 Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...) § 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.



A repartição vertical tem origem na Alemanha, na constituição de Weimar de 1919 e desenvolve o federalismo cooperativo ou de integração. Os entes vão atuar conjuntamente, concorrentemente, sobre a mesma matéria. Há uma cooperação entre os entes para agirem em conjunto e atingirem objetivos que, talvez sozinhos, não iriam ser atingidos em termos estratégicos.

No Brasil, a repartição vertical surge com a constituição 1934, a primeira constituição do Brasil de estado social.

Na CF/88 temos a repartição vertical com competências comuns e concorrentes.

- Nosso sistema de repartição de competências da constituição de 1988 é misto, pois temos a repartição horizontal, com competências mais remanescentes, convivendo com a repartição vertical, de competências comuns e concorrentes.

6.5. FEDERAÇÃO DE EQUILÍBRIO

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo dizem que a CF/88 se enquadra na federação de equilíbrio, pois está fundada no equilíbrio entre as competências e a autonomia conferidas aos entes federados.

6.6. GARANTIAS À FEDERAÇÃO

A CF/88 tem uma especial motivação para se enquadrar na forma federativa, eis que elenca uma série de garantias à federação.

Por exemplo, as competências são definidas constitucionalmente. Ao distribuí-las, a CF assegura equilíbrio federativo, o que transmite segurança e equilíbrio. Ou seja, se a competência está na CF, ela deve ser respeitada, sob pena de uma atuação inconstitucional, passível de controle de constitucionalidade.

A fim de observar a unidade da federação, ou seja, vedação ao direito de secessão, é possível até a chamada intervenção, que assegura o equilíbrio e a manutenção da nossa federação.

Para manter o equilíbrio entre os entes federados a CF consagra uma imunidade recíproca de impostos, além da própria repartição das receitas tributárias.

Percebemos que a federação é de tão grande importância que o art. 60, §4º, da CF consagra a forma federativa de estado como cláusula pétrea.

A república não é cláusula pétrea. Nem mesmo o sistema de governo presidencialista é cláusula pétrea. Com relação à forma de governo republicana, vale lembrar que, apesar de não ser cláusula pétrea, é um princípio constitucional sensível, autorizando a intervenção federal.

6.7. UNIÃO

A União é pessoa jurídica de direito público interno. A pessoa jurídica de direito público externo é a República Federativa do Brasil. Todavia, a União representa a República Federativa do Brasil. Portanto, cabe à União exercer as prerrogativas da República nas relações internacionais. E estas prerrogativas são de atribuição exclusivas da União.

Veja, a União somente representa a República Federativa do Brasil. Ou seja, não é ela quem age, e sim o Estado Federal, o qual pratica os respectivos atos.

A CF/88 traz os bens da União. O art. 20 da CF estabelece que são bens da União:



- os que lhe pertencem e os que vierem a lhe pertencer;
- as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;
- os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio (águas em seu estado), ou que banhem mais de um Estado (águas interestaduais), sirvam de limites com outros países (águas limítrofes), ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham (águas internacionais), bem como os terrenos marginais e as praias fluviais.
- as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios (Florianópolis), exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;
- os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;
- o mar territorial;
- os terrenos de marinha e seus acrescidos;
- os potenciais de energia hidráulica;
- os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
- as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;
- as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
- Em relação às competências da União, serão estudadas posteriormente.

6.7.1. TERRITÓRIOS

Territórios Federais não são entes federados, pois não dispõem de autonomia política e não integram o estado federado. Tratam-se de descentralizações administrativas, pertencentes à União.

É denominada de autarquia territorial federal.

Atualmente não há territórios federais.

O texto constitucional prevê que territórios federais possam ser criados, consoante regulamentação que deve ser estabelecida por lei complementar federal. A CF já estabelece as seguintes regras:

- Territórios podem ou não ser divididos em municípios. Sendo divididos em municípios, haverá a única hipótese em que poderá ocorrer intervenção federal em municípios.
- Territórios federais com mais de 100 mil habitantes terão órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais; e a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa;
- Governador de Território é escolhido pelo Presidente da República, devendo seu nome ser previamente aprovado por voto secreto, após arguição pública pelo Senado Federal.
- Compete à União em Território Federal os impostos estaduais e, se não for divididos em municípios, também competirá os impostos municipais.
- Cada Território elegerá 4 deputados federais.



6.7.2. ESTADOS-MEMBROS

Os Estados-membros são dotados de autonomia, que começa com a auto-organização, também denominada de auto legislação. Dessa característica, advém a possibilidade de elaborar suas próprias Constituições Estaduais, desde que observe os princípios da Constituição Federal, sendo denominados de:

a) Princípios constitucionais sensíveis

A observância é obrigatória, sob pena de intervenção federal. Estão previstos no art. 34, VII, da CF, sendo, portanto, princípios sensíveis:

- forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
- direitos da pessoa humana;
- autonomia municipal (prova a importância que a CF deu ao federalismo de 2º grau);
- prestação de contas da administração pública, direta e indireta (decorre da forma republicana de governo);
- aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

Ofensa a esses princípios poderá ensejar representação interventiva, proposta pelo Procurador Geral da República perante o STF. Neste caso, o PGR buscará a declaração de inconstitucionalidade daquela medida pelo STF, por meio da intervenção, bem como a própria Corte faça uma requisição ao Poder Executivo, a fim de que ele decrete a intervenção federal.

b) Princípios constitucionais extensíveis

São regras de organização que a CF estendeu aos Estados-membros, ao Distrito Federal e ao municípios.

c) Princípios constitucionais estabelecidos

São diversos princípios que se encontraram na CF/88 e que limitam a autonomia organizatória do Estado, ainda que não estejam expressamente previstos como limitadores.

Os Estados ainda são dotados de auto-governo. Isso significa que o estado é organizado em Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário.

A CF estabelece importantes regras para limitar a definição do Poder Estadual.

O poder legislativo estadual é unicameral, visto que é composto por uma única câmara, denominada de Assembleia Legislativa, composta por deputados estaduais. Vigora o sistema proporcional dos deputados estaduais, ou seja, não podem ser eleitos pelo sistema majoritário. O mandato dos parlamentares estaduais será de quatro anos, não podendo ser de cinco anos.

O número de deputados estaduais corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Isso até que o número de deputados federais seja igual a 12 deputados federais será definido a partir do número de deputados federais. A partir do momento em que se tem 36 deputados estaduais, passamos a ter o acréscimo de 1 para 1. Então, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze. O Estado de São Paulo tem 70 deputados federais, razão pela qual tem 94 deputados estaduais. O subsídio dos deputados estaduais deverá ser no máximo de 75% do subsídio de um deputado federal, sendo de iniciativa da Assembleia Legislativa.

A CF estabelece que é obrigatório o Estado tratar sobre a lei de iniciativa popular.

A eleição de governador e vice devem corresponder ao período de 4 anos.

O subsídio do governador é de iniciativa da Assembleia Legislativa, conforme o art. 28, §2º, CF.



O limite remuneratório, no âmbito do poder legislativo, é o subsídio dos deputados estaduais. No âmbito do poder executivo, o limite é o subsídio do governador, exceto para procuradores de estado e defensores públicos, cujo teto é 90,25% do subsídio do ministro do STF.

A CF autoriza que os Estados fixem como limite único para o teto remuneratório do Estado o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, o qual tem como limite o quantum de 90,25% do subsídio do ministro do STF. Este teto de subsídio não se aplica aos deputados estaduais, distritais e nem aos vereadores, eis que a própria CF assim já estabelece.

É possível que a Constituição Estadual estabeleça mecanismos de controle abstrato de constitucionalidade, a fim de verificar se as leis estaduais e municipais guardam relação com a Constituição Estadual. A legitimidade para representação de inconstitucionalidade não poderá ser atribuída a um único órgão.

A CF admite que a Constituição Estadual crie uma Justiça Militar Estadual, sendo composta em 1º Grau pelo juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em 2º grau pelo próprio Tribunal de Justiça. É possível que em 2º Grau exista um Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 integrantes, caso contrário será do Tribunal de Justiça a competência.

É constitucional norma de Constituição estadual que preveja que as proibições e os impedimentos estabelecidos para os Deputados Estaduais deverão ser aplicados também para o Governador e o Vice-Governador do Estado.

A CF estabelece que a competência dos Estados é residual. São reservadas aos Estados as competências que não estejam vedadas pela própria CF. Os Estados terão sua auto-administração dentro das competências administrativas e legislativas definidas constitucionalmente. A CF vai estabelecer quais são essas competências.

A própria CF também vai dizer que, internamente, por meio de lei complementar, os estados poderão instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões (§3º do art. 25). Mediante lei complementar, o Estado poderá pegar um conjunto de municípios limítrofes e criar uma microrregião, região metropolitana ou aglomeração urbana, tendo por fim a organização ou planejamento de funções públicas de interesse comum.

A diferença entre elas é:

- Regiões metropolitanas: conjuntos de municípios limítrofes com certa continuidade urbana e que se reúnem em torno de um município polo (em destaque), tendo em relação aos outros municípios uma continuidade urbana. Ex.: região metropolitana de São Paulo.
- Aglomeração urbana: são áreas urbanas de municípios limítrofes, mas não há município sede (central), havendo uma grande densidade populacional (demográfica). Há também uma continuidade urbana entre esses municípios, porém não há o município polo.
- Microrregiões: há também municípios limítrofes, porém apresentam características homogêneas e problemas comuns. Estes municípios não estão ligados a uma continuidade urbana.

A competência para criá-los é exclusiva dos Estados, sempre por meio de lei complementar.

Quando o Estado membro se vale de sua auto legislação e cria a Constituição Estadual, estará exercendo o poder constituinte derivado decorrente.

Todavia, existem limitações ao poder constituinte derivado decorrente. Algumas matérias, segundo já decidido pelo STF, não podem ser definidas pela Constituinte Estadual.



- CE não pode condicionar a nomeação de secretário de Estado a uma prévia aprovação da Assembleia Legislativa, pois violaria a separação dos poderes;
- CE não pode estabelecer em 4/5 dos membros da Assembleia o quórum para aprovação de emendas à constituição estadual, visto que o estabelecido pela CF seria uma norma de observância obrigatória (3/5 em dois turnos);
- CE não pode tratar de matérias de iniciativa privativa do Executivo, a partir de uma proposta de emenda apresentada por parlamentar. A ideia é coibir a fraude, pois se a CF estabelece que uma determinada matéria é de iniciativa do presidente da república, isso deve ser observado obrigatoriamente pela Constituição do Estado.
- CE não pode subordinar a nomeação do Procurador Geral de Justiça a uma prévia aprovação do seu nome pela Assembleia Legislativa. Isso porque a CF estabeleceu regra própria para a matéria, conforme art. 128, §3º, que diz que os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. Sendo assim, a CF estabeleceu processos distintos para o Procurador Geral da República e para os Procuradores Gerais de Justiça;
- CE não pode outorgar aos governadores de estado imunidade à prisão em flagrante, à prisão preventiva e à prisão temporária, tampouco estabelecer a irresponsabilidade na vigência do mandato por atos estranhos aos exercícios de suas funções. Para o STF, estas garantias são exclusivas do Presidente da República, como chefe de estado. A única imunidade do presidente da República que pode ser estendida aos governadores de Estado é a relativa à necessidade de autorização legislativa, por 2/3 da Câmara dos Deputados, para sua responsabilização criminal perante o Superior Tribunal de Justiça.
- CE não pode condicionar a eficácia de convênio celebrado pelo Poder Executivo à prévia aprovação do Poder Legislativo Estadual, pois isto violaria o princípio da separação dos poderes. Por conta disso, é inconstitucional norma da CE que exija autorização da Assembleia Legislativa para o Estado celebrar acordo que implique no aumento da dívida do ente;
- CE não pode estabelecer prazo para que o detentor de uma iniciativa privativa apresente projeto de lei ao legislativo, pois violaria a separação dos poderes. Caso haja inércia poderá configurar um caso de inconstitucionalidade por omissão.
- CE não pode outorgar competência para que a Assembleia Legislativa julgue suas próprias contas e dos administradores do Poder Executivo e Judiciário. Isso porque é preciso que a norma constitucional sobre o julgamento de contas seja reproduzida nos Estados, guardados os órgãos competentes. Segundo a CF, o Tribunal de Contas irá julgar as contas dos administradores na esfera federal. Esse modelo seria de observância obrigatória dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Na esfera estadual, a competência para julgar as contas do Governador será da Assembleia Legislativa, após a apreciação por meio de parecer prévio, no prazo de 60 dias, do Tribunal de Contas do Estado, pois essa competência para julgamento das contas do presidente da república é do Congresso Nacional, após a apreciação e parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Ocorre que a competência para julgar as contas dos demais administradores públicos estaduais, no âmbito dos três poderes (Executivo,



Legislativo e Judiciário), é do Tribunal de Contas dos Estados. Previsão em sentido diverso viola a CF.

- CE não pode adotar sistemas eleitorais distintos daqueles previstos na CF. Há basicamente dois sistemas: majoritário e o proporcional. Esses sistemas eleitorais são de observância obrigatória pelos Estados-membros.
- CE não pode definir os crimes de responsabilidade do governador, tampouco cominar as respectivas penas. Esta competência é de direito penal, cabendo à União legislar privativamente. O STF faz uma interpretação extensiva para enquadrar os crimes de responsabilidade na competência de direito penal da União. Este entendimento está esposado na súmula vinculante 46.
- CE não pode impor, ao Prefeito municipal, o dever de comparecimento perante a Câmara de Vereadores, pois semelhante prescrição normativa, além de provocar estado de submissão institucional do chefe do Executivo ao Poder Legislativo municipal (sem qualquer correspondência com o modelo positivado na Constituição da República);
- CE não pode submeter à Assembleia Legislativa Estadual a escolha, pelo Governador, de Desembargador que integrará o Tribunal de Justiça, eis que esse procedimento já está exaustivamente previsto no artigo 94, CF, havendo invasão da competência do Poder Executivo.
- CE não pode estabelecer que lei de iniciativa parlamentar autorize o chefe do Poder Executivo Estadual a extinguir sociedade de economia mista, destinando os bens remanescentes da entidade à autarquia estadual. Isso porque a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública é de iniciativa do Presidente da República, sendo, por simetria, de competência do Governador do Estado.
- CE não pode criar órgão de segurança pública diverso daqueles previstos no art. 144 da Constituição.

6.7.3. FORMAÇÃO DOS ESTADOS

A CF prevê a possibilidade de alteração da estrutura interna, territorial, dos Estados.

Não há na CF a previsão de alteração territorial do Distrito Federal, mas apenas dos Estados, podendo incorporar-se entre si, subdividir-se, desmembrar-se, seja para se anexar em outro ou para formar um novo Estado, ou ainda para formar um território federal. Para tanto, é indispensável que haja aprovação da população diretamente interessada, por plebiscito, e além disso, é preciso que o Congresso Nacional edite lei complementar a respeito do assunto.

Cabe atentar que esse dispositivo constitucional deve ser lido em conjunto com o art. 48 da CF, que faz referência à obrigatoriedade de prévia manifestação das assembleias legislativas envolvidas.

Com relação à população diretamente interessada, o STF já entendeu que é a população de todo o Estado-membro, e não apenas da área que será desmembrada.

Se o plebiscito, que é uma consulta prévia, for pela reprovação da alteração territorial, o processo legislativo fica impedido de prosseguir, não podendo ser aprovada a lei complementar. Todavia, caso o plebiscito aprove a alteração territorial, o Congresso Nacional não está vinculado a aprovar a lei complementar. Isto é, a decisão positiva não obriga o Congresso a legislar.

Com relação à manifestação das assembleias legislativas, não haverá qualquer obrigatoriedade no tocante ao trâmite do processo legislativo, funcionando apenas como um manifestação de caráter opinativo.

O procedimento de alteração territorial ocorrerá da seguinte forma:



- Plebiscito é convocado por meio de um decreto legislativo, proposto por no mínimo de 1/3 dos membros que compõe qualquer das casas do Congresso Nacional. O plebiscito da(s) população(ões) interessada(s) consiste numa condição de procedibilidade para o restante;
- Proclamada a consulta plebiscitária, sendo favorável a alteração o projeto de lei poderá ser proposto por qualquer das casas do congresso nacional;
- Cabe à casa em que tiver sido apresentado o projeto de lei complementar federal, ouvir as respectivas assembleias legislativas, que elaborará um mero parecer não vinculante;
- Uma vez aprovado o projeto de lei complementar, é encaminhado ao presidente da república para sanção ou veto. A lei complementar da União, feita no Congresso Nacional consiste no requisito de decidibilidade. O interesse da União, do Congresso Nacional, é um interesse nacional e não regional; deve-se pensar no país.

Para a corrente majoritária, o estados-membros poderão decorrer de uma incorporação (fusão), subdivisão e desmembramento.

- **Incorporação (fusão)** – ocorre quando dois ou mais entes vão se incorporar havendo a perda da personalidade jurídica dos entes primitivos. Se torna um novo estado.
- **Subdivisão** – ocorre quando o estado se divirá em dois ou mais estados havendo a perda da personalidade jurídica do ente primitivo.
- **Desmembramento** – única espécie em que não há perda da personalidade jurídica do ente primitivo. O ente perde parte de sua população e parte de seu território sem que haja a perda da personalidade jurídica.

O desmembramento pode ser de dois tipos: anexação ou formação. No tipo anexação, o estado perde parte de sua população e parte de seu território que será anexado a outro estado. Na formação, o estado perde população e território para a formação de um novo estado. Foi o que ocorreu com Goiás para a formação do estado de Tocantins na Constituição de 1988, no art. 13, §1º da ADCT²⁷.

Outro caso de desmembramento e formação, ocorrido na década de 70, sob a égide da constituição de 1969, é sobre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso perdeu população e território para a formação do novo estado Mato Grosso do Sul, mas permeneceu Mato Grosso, não perdendo a sua personalidade jurídica.

O desmembramento e formação é o que mais ocorre, por exemplo, na formação de novos municípios

A Constituição da República cria uma vedação à União neste caso, estabelecendo que em decorrência da criação de um Estado novo a União não poderá direta ou indiretamente assumir encargos, com relação a despesas com pessoal inativo ou outros encargos, como

²⁷ **Art. 13.** É criado o Estado do Tocantins, pelo desmembramento da área descrita neste artigo, dando-se sua instalação no quadragésimo sexto dia após a eleição prevista no § 3º, mas não antes de 1º de janeiro de 1989.

§ 1º O Estado do Tocantins integra a Região Norte e limita-se com o Estado de Goiás pelas divisas norte dos Municípios de São Miguel do Araguaia, Porangatu, Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos, conservando a leste, norte e oeste as divisas atuais de Goiás com os Estados da Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso.



amortização de dívidas, da administração pública, inclusive a indireta. Esta vedação está prevista no art. 234 da CF.

6.7.4. MUNICÍPIOS

Os municípios têm autonomia municipal. Esta expressão foi arrolada como princípio constitucional sensível.

O município é organizado por uma lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias entre os dois turnos, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal (art. 29), devendo observar alguns preceitos constitucionais.

A eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos.

No tocante ao Poder Legislativo municipal:

- o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do Município;
- os vereadores são invioláveis pelas suas palavras, votos e opiniões no exercício do mandato e na circunscrição do município;
- a Lei Orgânica deve tratar sobre iniciativa popular de projeto de lei mediante manifestação de pelo menos 5% do eleitorado.
- os limites máximos do subsídio dos vereadores têm como percentuais os subsídios dos deputados estaduais. Então, seguirá a tabela trazida pela CF:
 - i. Municípios de até 10 mil habitantes, subsídio máximo corresponderá a 20% do subsídio dos Deputados Estaduais;
 - ii. Municípios de 10 mil e um a 50 mil habitantes, o subsídio máximo corresponderá a 30% do subsídio dos Deputados Estaduais;
 - iii. Municípios de 50 mil e um a 100 mil habitantes, o subsídio máximo corresponderá a 40% do subsídio dos Deputados Estaduais;
 - iv. Municípios de 100 mil e um a 300 mil habitantes, o subsídio máximo corresponderá a 50% por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;
 - v. Municípios de 300 mil e um a 500 mil habitantes, o subsídio máximo corresponderá a 60% do subsídio dos Deputados Estaduais;
 - vi. Municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo corresponderá a 75% por cento do subsídio dos Deputados Estaduais.

Obs.: o máximo que um deputado estadual pode ganhar é 75% do subsídio do deputado federal. Ou seja, o máximo que o vereador poderá ganhar é 75% dos 75% dos deputados federais, que é o que o deputado estadual recebe.

- a Câmara Municipal não pode gastar mais do que 70% da sua receita com folha de pagamento, já incluído o subsídio dos vereadores.
- A Câmara Municipal terá uma variação de no máximo 9 vereadores para o Município de 15.000 habitantes. Se o município tiver mais de 8 milhões, o máximo será de 55 vereadores.
- o total da despesa do Poder Legislativo Municipal não poderá ultrapassar, já incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos a 7% para Municípios com população de até 100 mil habitantes; havendo entre 100 mil e 300 mil habitantes, o limite será de 6% do total da despesa municipal; caso tenha entre 301 mil e 500 mil habitantes, o máximo será de 5%; sendo a população entre 501 mil e 3 milhões, o máximo será de 4,5%; para 3 milhões e 1 pessoa a 8 milhões, o máximo total das despesas será de 4%; e será de 3,5% para os municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes.

Segundo a CF, quem julga prefeito por crime comum é o Tribunal de Justiça. Todavia, o STF faz uma interpretação desse dispositivo constitucional, estabelecendo que a competência



é originária de Tribunal de 2º Grau, de forma que a competência para julgamento de prefeito dependerá da matéria a ser julgada, podendo ser o TRF, o TRE ou o TJ.

Sendo crime de responsabilidade do prefeito, e os delitos sendo próprios (crimes de responsabilidade próprios), por se tratar de infração político-administrativa, a sanção é a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos, razão pela qual será de competência da Câmara Municipal. Por outro lado, sendo crimes de responsabilidade impróprios, por ser infrações penais comuns, com penas privativas de liberdade, quem julgará será o Tribunal de Justiça.

A CF não prevê foro por prerrogativa de função para vereadores. No entanto, é possível que a Constituição Estadual estabeleça o foro por prerrogativa de função dos vereadores no Tribunal de Justiça.

A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Embora a lei orgânica municipal esteja subordinada aos termos da Constituição estadual correspondente, a CE não pode estabelecer condicionamentos ao poder de auto-organização dos municípios.

Isso porque, segundo o STF, a Constituição Federal fixou os parâmetros limitadores do poder de auto-organização dos Municípios, excetuando apenas aqueles que contém remissão expressa ao direito estadual (art. 29, VI, IX e X). Por conta disso, a Constituição do Estado não os poderá abrandar nem agravar. Só pode estabelecer os limites já previstos na CF.

a) Formação dos Municípios

Essa criação sofre uma modificação muito forte em 1996. Nos primeiros oito anos da Constituição, de 1988 a 1996, criar um novo município era muito fácil: era somente plebiscito da população diretamente interessada e lei estadual.

Em 1996, com a EC 15, foram estabelecidos novos requisitos para a criação de novos municípios, a fim de dificultar o processo. Dessa forma, o art. 18, §4º, CF, sofreu modificação.

A EC 15/96 passou a exigir novos requisitos para criação, incorporação, fusão, desmembramento de municípios.

Essas alterações se dão através de lei municipal, mas esta lei deve ser promulgada dentro de um período estabelecido por lei complementar federal, e depende de uma prévia consulta, por meio de plebiscito, à população dos municípios envolvidos, após a divulgação de um estudo de viabilidade municipal, apresentado e publicado na forma da lei.

O procedimento é o seguinte:

- Primeiro, é feito um estatuto de viabilidade municipal;
- Segundo, esse estudo é divulgado, sendo submetido ao plebiscito;
- Sendo o plebiscito favorável, uma lei estadual poderá criar o município. No entanto, só poderá criar um município dentro do período previamente determinado por uma lei complementar federal.

Ocorre que não há lei complementar federal sobre o tema. Enquanto não editada esta lei complementar, não poderá haver criação de municípios no Brasil.

Todavia, até a EC 15/96, mais de 50 municípios já haviam sido criados em desrespeito ao art. 18, §4º, da CF. Esta questão chegou ao STF. A Suprema Corte entendeu que este procedimento de criação de municípios foi inconstitucional, mas também reconheceu que havia uma inconstitucionalidade por omissão do Congresso Nacional.

Por conta disso, o STF modulou os efeitos da decisão que julgou inconstitucional os procedimentos de criação dos municípios, fixando um prazo de 18 meses para que o



Congresso Nacional suprisse esta omissão, editando a lei complementar federal para estabelecer o momento de criação dos municípios.

O Congresso Nacional não criou a lei complementar, porém, para resolver o problema, promulgou a EC 57/98, acrescentando o art. 96 ao ADCT, convalidando os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios cuja lei tenha sido publicada até 31/12/2006, que atendiam aos requisitos das legislações dos respectivos estados à época de sua criação. Esta manobra trazida pelo Congresso Nacional foi denominada de municípios putativos.

6.7.5. DISTRITO FEDERAL

O Distrito Federal terá as mesmas ideias de auto-administração, auto-governo e auto-organização, mas não tem competência para organizar e manter o Poder Judiciário. Isso porque não há Poder Judiciário do Distrito Federal, pois este é da União. Ou seja, o TJDF é da União.

Em relação ao distrito federal, este não pode ser dividido em municípios. Por essa razão, em regra, foram atribuídas ao DF as competências legislativas e tributárias reservadas tanto aos estados membros quanto aos municípios.

Em relação à organização Judiciária e ao Ministério Público do Distrito Federal, bem como a organização administrativa, são de competência privativa da União.

O Distrito Federal não dispõe de competência para organizar e manter no seu âmbito:

- Poder Judiciário
- Ministério Público
- Polícia Civil
- Polícia Militar
- Corpo de bombeiros militar

Por este motivo, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo dizem que cabe à lei federal dispor sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal das polícias civis, militar e do corpo de bombeiros militar. Isso explica a súmula vinculante 39 que diz que compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.

A Constituição Federal diz, em seu art. 18, que Brasília é a capital federal, enquanto a CF de 1969 dizia que o Distrito Federal seria a capital.

7. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Nosso sistema de repartição de competências da constituição de 1988 é misto, pois temos a repartição horizontal, com competências mais remanescentes, convivendo com a repartição vertical, de competências comuns e concorrentes.

Repartição de competência são as competências administrativas, legislativas e tributárias, basicamente. Esta repartição é típica do estado federal, eis que está prevista na Constituição Federal.

Primeiramente se faz necessário diferenciar competência legislativa de administrativa. Competência Legislativa é aquela em que compete ao ente legislar. As Competências Administrativas são aquelas que envolvem o fomento, gerenciamento da máquina administrativa, execução de políticas públicas, dentre outras.

A partir da repartição, principalmente da competência tributária, é que a entidade federativa terá autonomia.



7.1. MODELO DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

O modelo de repartição de competências adotados varia de acordo com o dispositivo constitucional que for lido.

A doutrina constitucionalista divide este modelo em:

7.1.1. MODELO CLÁSSICO

É aquele vindo desde a Constituição dos EUA, fazendo uma enumeração das competências da União, e confere aos Estados as demais competências. São as competências residuais dos Estados. Em tese, foi este o modelo adotado pelo Brasil, mas não é assim em todas as matérias, como é o caso da competência tributária, sendo a competência residual da União, e não dos Estados, como são os demais casos.

7.1.2. MODELO MODERNO

Há a descrição no texto constitucional não só das atribuições da União, como também as atribuições comuns e as concorrentes. Na CF/1988 também se encontra as competências comuns e concorrentes.

Por tudo isso, não se pode dizer em absoluto que o Brasil adotou o modelo clássico ou moderno, visto que cada modelo dependerá do dispositivo que será analisado.

A repartição de competências pode ser vista sob as seguintes vertentes:

7.1.3. MODELO HORIZONTAL

As competências não são subordinadas entre as entidades federativas. A CF estabelece cada competência que será tratada. O Brasil também adota o modelo horizontal, como é o caso do gás canalizado pelo Estado.

7.1.4. MODELO VERTICAL

A União outorga a diferentes entes federativos a competência para atuar na mesma matéria, porém há uma subordinação, eis que irão atuar sobre a mesma matéria num chamado condomínio legislativo. Isto é, a União irá legislar sobre normas gerais e os estados irão legislar sobre normas específicas, as quais não podem contrariar as normas gerais. Sob este ponto de vista, é possível verificar que há uma relação de subordinação e há uma relação de repartição vertical da competência. Ex.: competência legislativa concorrente.

Segundo Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, predomina na CF/88 o modelo horizontal de repartição de competência.

Essa competência possui espécies, podendo ser legislativa, administrativa e tributária:

- **competência administrativa (material):** trata-se da competência de execução das tarefas. Ex.: a União detém a competência exclusiva para emissão de moedas.
- **competência legislativa:** é a competência para elaborar leis e estabelecer normas. A CF vai estabelecer quais os entes que detêm as competências, podendo ser privativa, concorrente, comuns, etc. Ex.: a União tem competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte, podendo delegar, por meio de lei complementar, aos Estados. Se não houver esta lei complementar, não poderá o Estado tratar da matéria.
- **competência tributária:** é a competência para instituir tributos. Trata-se de flagrante intenção do constituinte de garantir autonomia financeira ao Estado ou à entidade federativa, pois, do contrário, não haveria federação.

A CF/88, a fim de discriminar as competências, adota o princípio da predominância do interesse. Isto é, se o interesse é predominantemente local, é o município que tratará da matéria. Se o interesse for regional, caberá ao Estado tratar da matéria. Se o interesse for nacional, caberá à União tratar da matéria.



O constituinte repartiu as competências dos entes federados da seguinte maneira:

- enumera taxativamente e expressamente quais são as competências da União;
- a CF consagra o município como entidade federativa, enumerando taxativamente a sua competência, mas abre margem para que o operador do direito vislumbre no caso concreto se há função legislativa, como quando há interesse local;
- em relação ao DF, a CF vai outorgar as competências dos estados e dos municípios. Algumas competências dos Estados não serão outorgadas como é o caso da organização do MPDFT, Defensoria Pública do DF e o Poder Judiciário do DF, os quais ficarão a cargo da União.
- em relação aos estados membros, a CF estabelece a eles uma competência residual. Isto quer dizer que a competência do Estado é tudo aquilo que não foi vedado pela CF.
- a CF vai prever competências administrativas concorrentes (vertical) e comuns (horizontal);
- a regra é a enumeração expressa das competências União, assim como as competências dos municípios. As competências dos Estados são residuais, como regra. Excepciona estas regras a competência tributária, eis que a enumeração é expressa para todas as entidades federativas, inclusive para a União, porém esta última é a única que possui competência tributária residual para tais matérias.

7.2. REPARTIÇÃO HORIZONTAL

7.2.1. COMPETÊNCIAS DA UNIÃO

Na Repartição Horizontal²⁸, a União terá competências enumeradas no art. 21 e 22 da Constituição.

As competências exclusivas da União são indelegáveis, diferentemente da competência privativa. Na privativa, só a União trata do assunto, mas é possível delegar ao Estado, por lei complementar, para legislar sobre determinada matéria.

a) Competência exclusiva da União

O art. 21 estabelece que compete exclusivamente à União:

- manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais: é quem representa a República Federativa do Brasil.
- declarar a guerra e celebrar a paz;
- assegurar a defesa nacional;
- permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
- decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;
- autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;
- emitir moeda;
- administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada;
- elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;

²⁸ É aquela na qual existe uma distribuição fechada e específica de competência entre os entes, em que cada ente terá suas competências específicas não dividindo-as com os demais.

- manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
- explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;
- explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária; os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; os portos marítimos, fluviais e lacustres: em relação aos serviços de transportes rodoviários, se tiver caráter intermunicipal, será de competência dos Estados, e se for de caráter interurbano, será de caráter municipal; sendo caráter interestaduais, haverá competência da União. Tudo por conta do princípio da predominância do interesse.
- organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios;
- organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio;
- organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;
- exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão;
- conceder anistia;
- planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;
- instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;
- instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;
- estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;
- executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
- explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:

A CF estabelece princípios para atuação com materiais nucleares:

- a. toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;
- b. sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais;
- c. sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas;



d. a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa (teoria da responsabilidade objetiva sob a teoria do risco integral).

- organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
- estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa.

Como visto, a principal característica da competência exclusiva é a indelegabilidade.

b) Competência privativa da União

Aqui, a delegabilidade é permitida, sendo uma característica da competência privativa. A competência privativa é a legislativa.

No artigo 22, resta claro que são competências legislativas Segundo o art. 22, compete privativamente à União legislar sobre:

- direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho: é competência concorrente para tratar de assuntos sobre junta comercial, mas a competência é privativa da União para tratar de direito comercial. Da mesma forma, é competência concorrente tratar sobre procedimentos, mas sobre processo é competência privativa da União. Percebamos que o constituinte fala em direito comercial, e não direito empresarial.

- desapropriação;
- requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;

- águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
- serviço postal;
- sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;
- política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;
- comércio exterior e interestadual;
- diretrizes da política nacional de transportes;
- regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;

- trânsito e transporte;
- jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
- nacionalidade, cidadania e naturalização;
- populações indígenas;
- emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
- organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

- organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes;

- sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;
- sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;
- sistemas de consórcios e sorteios: com base neste inciso, o STF estabelece que Estado não pode legislar sobre bingo e loteria.

- normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;
- competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;

- seguridade social;



- diretrizes e bases da educação nacional;
- registros públicos;
- atividades nucleares de qualquer natureza;
- normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III: não há equívoco, ainda que o assunto parecer tratar de competência concorrente, pois quando a competência é concorrente, se a União não legisla sobre normas gerais, o Estado pode legislar supletivamente, exercendo a competência plena. No entanto, como se trata de competência privativa, caso falte atuação da União sobre normas gerais, o Estado não poderá legislar supletivamente sobre normas gerais. Ainda que a União fosse omissa, mas não o é, o Estado não poderia suplementar para tratar de normas gerais de licitação. Portanto, não haveria impropriedade do constituinte.
- defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;
- propaganda comercial.

Em relação a essas matérias de competências privativas, cabe ressaltar que os Estados, os municípios e o DF não compõem competência para legislar.

Com base nisso, o STF editou a súmula vinculante 2, que estabelece ser inconstitucional a lei ou ato normativo Estadual ou Distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.

Ou seja, ainda que a União seja inerte, não poderá o Estado legislar sobre competência legislativa privativa, pois o caso não se trata de competência concorrente.

Porém, os Estados e o DF poderão legislar sobre os temas de competência privativa da União, desde que sejam de questões específicas enumeradas em uma delegação de competência feita por meio de lei complementar (parágrafo único do art. 22 da CF).

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo trazem um exemplo em que a LC 103 autorizou os entes políticos a instituir um piso salarial às categorias que não tivessem um piso salarial fixado por lei federal ou por acordo ou convenção coletiva.

Segundo o STF, a competência para determinar o horário bancário é da União, não podendo os municípios legislar sobre o assunto, pois tem repercussão no sistema financeiro nacional. Todavia, os municípios poderão legislar sobre o tempo máximo para o consumidor aguardar a fila de espera, eis que se trata de interesse local.

O STF ainda afirma que compete à União tratar sobre direito penal, razão pela qual somente ela poderá tratar sobre crime de responsabilidade. Houve até mesmo a edição da súmula vinculante 46, estabelecendo que a definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento dos agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial (art. 85 da Constituição da República).

É inconstitucional lei estadual que disponha sobre punições a empresas privadas e a agentes públicos que exijam a realização de teste de gravidez e a apresentação de atestado de laqueadura para admissão de mulheres ao trabalho. Isso porque legislar sobre direito do trabalho é matéria de competência da União.

Da mesma forma, é inconstitucional lei estadual que disponha sobre condições de cobrança dos valores da assinatura básica residencial nos serviços de telefonia fixa, pois a competência para legislar sobre telecomunicações é da União.



Por ser da competência da União legislar sobre energia, é inconstitucional lei estadual que preveja que os postes de sustentação da rede elétrica, que estejam causando transtornos, sejam removidos sem ônus aos proprietários, pela concessionária de energia elétrica.

7.2.3. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO

O art. 22, parágrafo único, CF, prevê a possibilidade de delegação de competência da União aos Estados.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Pode haver delegação para os estados, desde que preenchidos os requisitos formal, material e implícito.

O **requisito formal** da delegação é que deverá sempre se feito por lei complementar da União.

O **requisito material** da delegação é que deverá ser uma matéria específica de um dos incisos. Ex.: A União delegará para o estado a competência de legislar sobre Fundo de Garantia Sobre Serviço; Salário Mínimo; Inelegibilidade; Furto; etc.

O **requisito implícito** é o da isonomia. É implícito porque não está previsto no art. 22, mas sim no art. 19, III, CF²⁹. Um ente não pode discriminar o outro, é a ideia que traduz o nosso federalismo simétrico da homogeneidade federativa. Ou seja, se a União delegar para o estado de São Paulo, tem que delegar para o estado do Piauí, etc, não pode ter privilégio.

Para o Distrito Federal, o art. 22, parágrafo único, não fala sobre o Distrito Federal, mas por uma interpretação sistemática, se no art. 32, § 1º diz que são reservadas ao Distrito Federal, Estados e Municípios, as competências, então tudo o que for competência para o Estado, também caberá ao Distrito Federal. Ou seja, se a União delegar para os estado também terá que delegar para o Distrito Federal.

7.2.4. COMPETÊNCIAS DOS ESTADOS

Competências remanescentes presente no art. 25, §1º, CF, que diz que aos estados são reservadas as competências legislativas ou administrativas que não sejam vedadas pela constituição.

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

Se a competência não é da União, seja ela administrativa ou legislativa e nem do Municípios, seja ela administrativa ou legislativa, será dos Estados.

Exemplo: Ao município compete organizar e fiscalizar o transporte local. À União compete organizar e fiscalizar o transporte interestadual, com a Polícia Rodoviária Federal. Mas a quem compete organizar a fiscalizar as rodovias intermunicipais? Não é dos municípios

²⁹ Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

III - criar distinções entre brasileiros ou **preferências entre si**.



e nem da União. Não está prevista expressamente a competência na constituição, mas a competência é dos estados, com a Polícia Militar Rodoviária.

No entanto, a Constituição em certo momento enumera expressamente algumas competências dos Estados, como por exemplo:

- competência para criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios;
- exploração de gás canalizado diretamente, ou mediante concessão, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação;
- competência para instituir regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões, bem como de estruturar a segurança viária. Neste caso, o município também é competente, mas prevalece o princípio da predominância do interesse.
- competência comum;
- competência delegada decorrente da competência privativa da União;
- competência legislativa concorrente
- competência tributária expressa

Lembre-se que é inconstitucional lei estadual que prevê prioridade de tramitação de processos relativos à mulheres vítimas de violência doméstica. Isso porque as regras sobre a tramitação das demandas judiciais é aspecto abrangido pelo ramo processual do direito, de competência privativa da União.

Por outro lado, é constitucional lei estadual que limite a quantidade de alunos por sala de aula em escolas públicas ou particulares.

7.2.5. COMPETÊNCIAS DO DISTRITO FEDERAL

Em relação às chamadas competências do DF, este possui as competências reservadas aos Estados e as competências reservadas aos municípios.

Nem todas as competências dos Estados foram outorgadas ao Distrito Federal, como é o caso em que compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

O Poder Judiciário do DF é poder da União.

Cabe ressaltar que a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal são subordinados ao Governo do Distrito Federal, mas serão organizados e mantidos pela União.

O DF possui as seguintes competências:

- competências dos Estados, como regra;
- competências dos municípios;
- competência comum;
- competência legislativa concorrente;
- competência tributária expressa dos Estados e municípios

7.2.6. COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS

Com relação às competências dos municípios, o art. 30 trata de maneira clara quais são elas:

- compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local;
- competência para suplementar lei federal e estadual, no que couber;
- competência para instituir e arrecadar tributos da sua circunscrição: isso garante sua autonomia;



- competência para organizar e prestar serviços públicos de interesse local, incluindo transporte coletivo intramunicipal: sendo intermunicipal, quem trata é o estado; sendo interestadual ou internacional, será tratada pela União.
- competência para promover programas da educação infantil e ensino fundamental;

Há uma preocupação de que os municípios tratem da educação básica infantil, enquanto os Estados tratarão com mais profundidade sobre o ensino fundamental, cabendo à União tratar sobre ensino superior.

O que seriam esses “interesses locais”? O município está dentro do estado, que, por sua vez, está dentro do país. Esses interesses locais seriam também de interesse regional, estadual, nacional. Não há como separar os interesses do município com os demais. No entanto, pela teoria ou princípio da predominância dos interesses, quando a Constituição diz o disposto no art. 30, I, CF, diz que compete ao município legislar sobre assunto predominantemente, primariamente, local. Não significa que não haverá interesse estadual e nacional, pois o município não está desacoplado, mas no caso do município, o interesse é predominantemente local.

Não há uma taxatividade sobre o que seja assunto de interesse local, depende das peculiaridades do caso:

- município vai dizer como se dará a exploração de estabelecimento comercial, no sentido de emissão de alvará e licença de funcionamento;
- município fixa horário de funcionamento de ônibus, loja, drogaria, farmácia, etc.;
- município pode impor ao estabelecimento bancário a obrigação de instalação de portas elétricas, detector de metais, espera na fila do banco, etc., mas não pode tratar sobre o horário bancário;
- município pode fixar limite máximo de tempo máximo na espera do banco: deve-se observar o princípio da proporcionalidade, eis que se trata de um princípio constitucional.
- municípios podem instituir guardas municipais, as quais inclusive poderão lavrar auto de infração e fiscalizar o trânsito: esta atuação decorre da estruturação da sua segurança viária.
- municípios têm competência comum;
- competência para arrecadar tributos.
- súmula Vinculante 38: É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

ATENÇÃO! Deve-se observar sempre questões jurisprudenciais que tratam sobre o tema.

Segundo a Súmula Vinculante 38 do STF, no que se refere a fixação de horário de funcionamento de estabelecimento comercial, a competência será dos municípios.

Súmula Vinculante 38, STF. É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

No entanto, quando se trata de horário de funcionamento de bancos, não é de interesse local, porque requer uma padronização nacional, pois envolve o sistema financeiro nacional, envolve, por exemplo, remessa de dinheiro para o estrangeiro, bolsa de valores de vários países. É o teor da Súmula 19 do STJ.

Súmula 19, STJ. A do fixação de horário bancário, para atendimento ao público, é da competência da União.

No informativo 394 do STF, o STF entendeu que os municípios são dotados de competência para legislar sobre comodidade de cliente dentro dos bancos, sobre o tempo de permanência em fila, dentre outros.



Quem fixa a repartição de competências do município é o próprio município e entra no embate de competências no que diz respeito à ordem econômica. A súmula vinculante 49 do STF diz que ofende a livre iniciativa a proibição dos municípios de ter estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em uma mesma área.

Súmula Vinculante 49, STF. Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.

Exemplo: ocorreu com o município de Joinville a questão atinente a farmácias, em que o município manifestou-se no sentido de ser competente para isso, de acordo com o art. 182, CF, e definiu no plano diretor que estabelecimentos comerciais do mesmo ramo na mesma área não poderia ser instalado. Alegou que não poderia ter mais de uma farmácia na mesma rua. O município, por mais que tenha competência pelo plano diretor, impedir isso foge da questão de repartição de competência e ofende a livre iniciativa do comércio.

7.3. REPARTIÇÃO VERTICAL

É aquela na qual dois ou mais entes vão atuar conjunta ou concorrentemente para uma matéria ou tema. Por exemplo, temas como saúde e educação são temas concorrentes entre os entes nos âmbitos federais, estaduais e municipais.

A repartição vertical tem origem na Alemanha, na constituição de Weimar de 1919 e desenvolve o federalismo cooperativo ou de integração. Os entes vão atuar conjuntamente, concorrentemente, sobre a mesma matéria. Há uma cooperação entre os entes para agirem em conjunto e atingirem objetivos que, talvez sozinhos, não iriam ser atingidos em termos estratégicos.

No Brasil, a repartição vertical surge com a constituição 1934, a primeira constituição do Brasil de estado social.

Na CF/88 temos a repartição vertical com competências comuns e concorrentes.

O art. 23, CF traz as competências comuns à União, aos Estados, Municípios e Distrito Federal. São competências administrativas.

Existe, nesse art. 23, o princípio da cooperação ou da integração, mais precisamente no seu parágrafo único. O parágrafo único diz, categoricamente, que lei complementar da União vão fixar **normas para a cooperação** entre os entes. Ex.: LC 140.

Já o art. 24 traz as competências concorrentes, que são competências legislativas.

Deve-se fazer a comparação do art. 24 com o art. 22, CF.

Existem dois tipos de repartição vertical concorrente: a cumulativa e a não cumulativa.

Repartição vertical concorrente cumulativa ou competência concorrente cumulativa é aquela em que **não** existem limites previamente definidos pra a atuação concorrente.

Já na repartição vertical concorrente não cumulativa ou competência concorrente não cumulativa existem limites previamente definidos para a atuação concorrente, ou seja, os entes vão atuar concorrentemente, mas há sim uma definição prévia nessa atuação.

O Brasil adota a competência concorrente não cumulativa, porque existem limites previamente definidos. Para o temas do art. 24, a União vai estabelecer normas gerais (interesse nacional) e os Estados irão suplementar, de forma complementar, essas normas gerais, para atender as suas peculiaridades regionais.

A complementação dos estados serão diferentes entre si. Por exemplo, numa lei sobre meio ambiente, de âmbito nacional, será complementado pelos estados e a complementação do estado de São Paulo será diferente da complementação do estado do Amazonas.

A União não poderá legislar sobre questões específicas dos Estados, pois a sua competência se restringe à atuação por meio de normas gerais. Caso a União legisle sobre questões específicas, a atuação será considerada inconstitucional, conforme dispõe o art. 24, §1º, CF: “No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais”.



No caso da competência legislativa concorrente, se a União não edita normas gerais, os Estados e o DF passam a ter a competência legislativa plena. Sendo omissa a União, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo dizem que haverá uma outorga tácita da competência legislativa aos Estados.

No entanto, isto não impede que haja a superveniência de lei federal sobre normas gerais, a qual suspenderá a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

A consequência prática da não revogação da lei estadual por superveniência da lei federal é de que, se houver uma norma revogando a lei federal, a norma estadual, que tinha eficácia suspensa, volta a ser eficaz, pois ela não foi retirada do ordenamento jurídico, mas apenas os seus efeitos foram suspensos.

Em razão dessa competência suplementar, a doutrina classifica as normas estaduais em:

- competência suplementar complementar: a União tratou das normas gerais e o Estado trata das normas específicas.
- competência suplementar supletiva: a União não tratou das normas gerais, razão pela qual os Estados trataram sobre a competência plena.

Caso a União não edite as normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena, suplementar supletiva, conforme o art. 24, §3º, CF.

Se a União editar as normas gerais, mesmo quando há suplementação plena dos estados, essas normas gerais vão suspender as normas estaduais que lhes forem contrárias. As que não forem contrárias continuam valendo.

CUIDADO! Nas provas colocam que as normas gerais que forem contrárias irão revogar as estaduais. Está errado! **É suspensão.** Está previsto no art. 24, §4º, CF.

→ Caso concreto cobrado em provas de magistratura: suponha que a União tenha que editar as normas gerais e não o faz. Os Estados exercem sua competência legislativa plena. A União, por sua vez, edita as normas gerais (NG1) e, as normas estaduais que forem contrárias ficarão, automaticamente, suspensas. Posteriormente, edita novas normas gerais (NG2), que revogam as anteriores (NG2 revoga NG1), mudando o paradigma. Normas estaduais que contrariavam as normas gerais (NG1), e estavam suspensas, não as contrariam mais (NG2). Essas normas estaduais voltam a vigorar com eficácia jurídica? **SIM.** Só fica suspenso aquilo que contraria as normas gerais da União. Deve-se atentar pelo fato de que aquilo que volta a vigorar por não mais contrariar as normas gerais da União **não se dá por conta do chamado efeito repristinatório.** O efeito repristinatório é a volta da vigência de uma lei que já foi revogada, o que não ocorre aqui, pois há somente a suspensão da lei estadual contrária. Em momento algum a lei estadual contrária à norma geral foi revogada, mas somente suspensa.

→ Os municípios são dotados de competência suplementar complementar? **SIM**, nos termos do art. 30, II, CF.

Os municípios participam da repartição vertical concorrente legislativa, não nos termos do art. 24, mas sim do art. 30, II, CF. No entanto, os municípios não possuem competência para suplementar qualquer matéria, como por exemplo, sobre direito penal, civil, etc, pois estas são matérias do art. 22, CF, ou seja, de repartição horizontal enumerada privativa da União.

O art. 30, II, CF, traz no final a expressão “no que couber”, não sendo sobre qualquer matéria que o município poderá legislar de forma complementar. O padrão adotado pelo STF à luz da doutrina para regular o tema é que o município poderá suplementar complementar a legislação estadual no que couber, devendo demonstrar o interesse local, deve ser uma das matérias do art. 23, CF, e as matérias, em regra, do art. 24, CF, de competência concorrente.

O município deve demonstrar interesse local ao legislar de forma concorrente. Exemplo: município de Ouro Preto pode legislar de forma complementar e concorrente sobre preservação do patrimônio, pois consegue comprovar o interesse local. No entanto, não poderá legislar sobre o disposto no inciso IV do art. 24, que trata sobre custas forenses, já que, por não possuir Poder Judiciário, não terá também interesse local.



Os municípios podem legislar de forma suplementar supletiva? Temos duas correntes.

A **primeira corrente**, de cunho municipalista, entende que sim, que o município, na falta de normas da União e Estados pode exercer competência legislativa plena das matérias do art. 24. Essa corrente defende uma interpretação sistemática do art. 24, §3º conjugado com o art. 30, II, todos da CF. Essa corrente diz que o texto do inciso II do art. 30 diz, ainda que de forma implícita, da competência supletiva. Se a suplementar pode ser complementar ou supletiva, e os municípios tem complementar, se aplica aos municípios a norma do art. 24, §3º, CF. E aí seguiria a mesma lógica, pela interpretação sistemática, de que na falta de normas da União e dos Estados, os municípios vão exercer competência legislativa plena. Se existir norma da União e dos Estados, as normas municipais contrárias ficarão automaticamente suspensas.

A **segunda corrente** defende que não, interpreta de forma literal a constituição e diz que os municípios, nos termos do artigo 30, II, só tem a suplementar complementar. O município vai suplementar o que já existe no que couber. Um dos argumentos dessa corrente é baseado justamente na interpretação literal, pois, segundo defendem, se o constituinte originário quisesse que os municípios tivessem competência suplementar supletiva estaria expresso no texto constitucional. Há outro argumento, de cunho hermenêutico, o argumento consequencialista. Para os consequencialistas, interessa muito mais as consequências da decisão ou da prática, os efeitos sistêmicos que envolvem aquela decisão do que a perspectiva normativa que está por trás dela. Essa corrente defende que dar aos municípios a suplementar supletiva é, em determinado sentido, abrir a possibilidade para o caos no ordenamento jurídico. São mais de 5.500 municípios, geraria o caos. Não há como controlar.

A corrente majoritária no nosso federalismo, na nossa organização do Estado é a segunda, a corrente da interpretação literal, que possui um argumento consequencialista.

Conclui-se, então, que o município possui competência suplementar sim, mas somente a complementar, não possuindo a supletiva.

7.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

a) As competências enumeradas para a União na repartição horizontal não está apenas nos artigos 21 e 22, CF. Existem outras competências para União no decorrer da constituição. Exemplos: artigos 48, 49, 149, 164, 184.

b) As competências dos municípios enumeradas na repartição vertical não estão apenas no art. 30, pois existem outras competências enumeradas para os municípios no decorrer da constituição. Exemplos: artigos 144, §8º e 182, §1º.

c) Na repartição horizontal, a competência dos estados é remanescente (art. 21, §1º, CF). Porém, existem exceções, existem competências enumeradas para os estados. Exceções: art. 25, §§2º, 3º e art. 18, §4º, todos da CF.

d) Territórios. Os territórios são descentralizações administrativas da União, que funcionam nos moldes das autarquias e, portanto, são dotadas de personalidade jurídica própria. No entanto, não são entes federativos dotados de autonomia política, estão dentro da estrutura da União. Atualmente não existem territórios no Brasil, sendo os últimos foram Amapá, Roraima e Fernando de Noronha; Amapá e Roraima se tornaram estados e Fernando de Noronha foi anexado ao estado de Pernambuco. Podem existir novos territórios no Brasil, pois são criados por lei complementar e após plebiscito da população diretamente interessada. Se criados, a sua organização administrativa e judiciária, far-se-á por lei ordinária federal. Os territórios serão administrados por um governador, que será nomeado pelo Presidente da República após aprovação do Senado Federal, nos termos do art. 84, XIV, CF. Esse governador não terá mandato de quatro anos como os demais governadores, pois não se trata de um cargo de mandato, mas sim de investidura. Se o território Federal for criado, terá direito a quatro deputados federais, conforme dispõe o art. 45, §2º, CF, independente do tamanho do território. Os territórios podem ser divididos por municípios e serão aplicadas, no que couber,



as normas constitucionais atinentes aos municípios (Título III, Capítulo IV, da Constituição; arts. 29 a 31). Os territórios com mais de 100 mil habitantes terão órgãos do Poder Judiciário de primeiro de segundo grau, além de Ministério Público e Defensoria Pública Federais, conforme dispõe o art. 33, CF.

8. VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS AOS ENTES FEDERADOS

Como se sabe, existem vedações constitucionais aos entes federados, seja à União, Estados, Municípios e ao Distrito Federal.

O art. 19 diz, por exemplo, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada uma aliança para fim de interesse público, como é o caso de uma creche ou hospital.

Isso significa dizer que o Estado brasileiro é laico, não podendo ter religião oficial. Isto explica a razão da Escola Pública poder ter a disciplina de religião, mas esta não ter caráter obrigatório. Ou seja, faz quem quiser.

Da mesma forma, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios recusar fé aos documentos públicos. Então, sendo o documento público, a União ou qualquer outro ente não pode recusar dar-lhe fé pública.

9. INTERVENÇÃO FEDERAL

O Estado federal fundamenta-se no princípio da autonomia das entidades que compõem o Estado federal. Então, o afastamento desta autonomia tem caráter excepcional que se dá através de uma entidade política sobre a outra. Isso só é possível quando houver um interesse maior em jogo e este interesse é justamente a manutenção da federação.

Somente pode ser sujeito ativo de uma intervenção a União e os Estados-membros. Não há intervenção pelo município.

A intervenção da União se dá sobre o Estado. Não existe intervenção da União sobre município localizado em Estado-membro, mas tão somente localizado em Território Federal, caso passe a existir algum.

A decretação da intervenção se dá por decreto do chefe do poder executivo, eis que se trata de um ato político, ainda que se origine de uma requisição, que tenha caráter de ordem.

A intervenção federal poderá ser:

- Espontânea: decretada diretamente pelo chefe do poder executivo
- Provocada: alguém insta o chefe do poder executivo a decretar a intervenção federal. Nesse caso, poderá ser:
 - a) Solicitação ou pedido: caráter não vinculante;
 - b) Requisição: é uma ordem em que o chefe do poder executivo deve decretar, tendo caráter vinculante.

9.1. INTERVENÇÃO FEDERAL ESPONTÂNEA

A intervenção federal espontânea é feita diretamente por iniciativa do chefe do poder executivo, sendo hipóteses:



- Para defesa da unidade nacional;
- Para defesa da ordem pública;
- Para defesa das finanças públicas.

9.2. INTERVENÇÃO FEDERAL PROVOCADA

A intervenção federal provocada depende de provocação de algum órgão, tendo esta competência prevista na Constituição, podendo se dar de duas formas:

- **Por solicitação:** se algum dos órgãos previstos na CF solicitar, o chefe do poder executivo não está obrigado a atender, ou seja, não é vinculante.
- **Por requisição:** aqui, o chefe do poder executivo não tem discricionariedade, devendo cumprir a ordem de decretação.

A provocação do chefe do executivo podem ser realizada pelo:

- **Poder Legislativo:** Assembleia legislativa estadual, Câmara Legislativa do Distrito Federal ou
- **Poder Executivo:** Prefeitos, governador de Estado, governador do Distrito Federal.

A CF diz que para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação, ou seja, estes poderes locais irão solicitar ao presidente da república a decretação da intervenção federal (art. 34, IV).

Também é admissível que o Supremo Tribunal Federal requirite a intervenção, quando o Poder Judiciário estiver sendo coagido. Neste caso, sendo o Tribunal de Justiça o órgão coagido, deverá solicitar ao STF para que requirite a intervenção. Se o Supremo entender cabível, requisitará a intervenção federal ao presidente da República. O que temos aqui é uma ordem ao Presidente para que decrete a intervenção federal.

No caso do Poder Judiciário, serão legitimados o STF, STJ e o TSE, no caso de desobediência à ordem ou decisão judicial. A intervenção dependerá de requisição desses Tribunais e quem será o legitimado vai depender da ordem ou da decisão descumprida. O STF, STJ ou o TSE requisitarão ao presidente da república para que decrete a intervenção federal, de modo que a ordem ou decisão judicial seja cumprida.

Segundo o STJ, se o Estado/DF estiver descumprindo uma decisão de juiz ou Tribunal de 2ª instância, o Tribunal local deverá fazer uma representação ao Tribunal Superior competente (STF, STJ ou TSE) solicitando a intervenção. Se o Tribunal Superior concordar, ele irá requisitar ao Presidente da República a intervenção. Para saber qual o Tribunal Superior será competente, deverá ser analisada a matéria discutida e para quem seria dirigido o eventual recurso.

Compete ao STJ julgar pedido de intervenção federal baseado no descumprimento de ordem de reintegração de posse de imóvel rural ocupado pelo MST expedida por Juiz Estadual e fundada exclusivamente na aplicação da legislação infraconstitucional civil possessória. Isso porque a decisão descumprida analisou tema relacionado com direito civil privado, não tendo feito considerações sobre questões constitucionais. Logo, o eventual recurso contra a decisão, quando o processo superasse as instâncias ordinárias e chegasse aos Tribunais Superiores, seria apreciado pelo STJ em sede de recurso especial. Não caberia, no caso, recurso extraordinário ao STF, razão pela qual esta Corte não seria competente para julgar o pedido de intervenção relacionada com o desatendimento da decisão (Inf. 550, STJ).

O Procurador Geral da República também poderá desencadear a intervenção federal, no caso de recusa ao cumprimento de lei federal e de ofensa aos princípios constitucionais sensíveis, a intervenção dependerá de representação interventiva. Neste caso, o PGR apresenta a ação perante o STF. Quando se nega a executoriedade à lei federal, essa ação



viabiliza obrigar o ente federado a cumprir a lei. Quando há ofensa aos princípios constitucionais sensíveis, a representação interventiva (ou ação declaratória de inconstitucionalidade interventiva) visa provocar o Poder Judiciário para declarar inconstitucional o ato interventivo pelo ente federal, de forma que o STF irá requisitar ao presidente da república que se decrete a intervenção.

Será ação de executoriedade de lei federal nos casos em que se busca a execução da lei federal. No caso de ofensa a princípio constitucional sensível, o nome será representação interventiva ou ação direta de inconstitucionalidade interventiva.

Quem faz o controle de constitucionalidade é o Poder Judiciário que decidirá se haverá o afastamento da autonomia do ente federado. Se for dado provimento à representação, o presidente do STF dará conhecimento ao presidente da República que tem o prazo improrrogável de 15 dias para promover o decreto. Nessa hipótese, a atuação do presidente da república é vinculada.

Se a suspensão do ato impugnado for suficiente para o restabelecimento da normalidade, suspende-se a aplicação do ato impugnado. Caso seja necessário, o decreto interventivo implicará o afastamento da autonomia do ente federado.

A intervenção federal é implementada por meio de decreto expedido pelo Presidente da República. Este decreto vai especificar qual é a amplitude da intervenção, qual é o prazo da intervenção, quais são as condições de execução desta intervenção, de modo que, se for o caso, este decreto interventivo vai nomear temporariamente o interventor, o que implicará o afastamento das autoridades locais de suas funções.

Nas chamadas intervenções não vinculadas, em que ele age espontaneamente ou através de uma provocação por solicitação, e portanto, discricionariamente, deverá ouvir antes de decretar a intervenção federal o conselho da república e o conselho de defesa nacional, ainda que estas decisões não sejam vinculantes.

A intervenção tem caráter temporário, razão pela qual, cessados os seus motivos, as autoridades afastadas retornam aos seus cargos ou não retornarão por impedimento legal de retornar (Ex.: cassação do mandato).

Durante a intervenção federal, a Constituição não poderá ser emendada. Trata-se de uma limitação de caráter circunstancial.

9.3. CONTROLE POLÍTICO DA INTERVENÇÃO

A decisão é do presidente da república. O decreto de intervenção federal é submetido ao Congresso Nacional no prazo de 24 hrs. Caso esteja em recesso, ele será convocado extraordinariamente no mesmo prazo de 24 hrs.

Veja: primeiro decreta; depois submete ao Congresso.

O Presidente decreta a intervenção e, em 24 horas, deve ser encaminhado ao Congresso para apreciar e aprovar. É o decreto do Presidente que deflagra a intervenção, o Congresso vai aprovar ou não algo que já está em curso. Não é a aprovação do Congresso Nacional que dá início à intervenção.

O Congresso Nacional poderá aprovar ou suspender a decretação da intervenção federal. Caso suspenda o decreto, a intervenção federal passará a ser inconstitucional, de modo que deverá cessar imediatamente. Neste caso, se o Presidente da República insiste na intervenção, incide em crime de responsabilidade, segundo o art. 85, II, CF, sujeito à impeachment.

Atente-se que nem todo o decreto de intervenção federal será apreciado pelo Poder Legislativo. Ou seja, somente haverá apreciação do Congresso quando houver uma discricionariedade do presidente da República.

Nos casos em que a intervenção federal foi decidida pelo Poder Judiciário, e o presidente da república estiver vinculado àquela decisão, não haverá a submissão do decreto de intervenção ao Congresso Nacional.

Ou seja, não será submetida à apreciação do Congresso Nacional os casos em que a intervenção federal servir para:

- Prover a execução de lei federal;
- Negação de cumprimento à ordem ou decisão judicial;
- Ofensa aos princípios constitucionais sensíveis.

Não há controle pelo Congresso em observância do princípio da Separação dos Poderes, pois a hipótese do art. 34, VI e VII, CF é uma intervenção que vem acompanhada de uma ordem judicial que a determina.

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo ainda afirmam que é desnecessário que o decreto interventivo seja submetido ao Congresso Nacional na hipótese do art. 34, IV, que serve para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação. Isso porque, quando é o Poder Judiciário que requisita ao presidente da República o decreto de intervenção federal, em razão de ele não estar no livre exercício de seu poder, isto será uma ordem, sendo uma ordem, não há outro caminho ao presidente da república senão a intervenção. Neste caso, não seria necessário submeter ao Congresso Nacional.

Todavia, pela letra da CF, somente os casos em que não se está executando lei federal ou não se está obedecendo a ordem ou decisão judicial, ou ainda quando houver ofensa aos princípios constitucionais sensíveis é que será desnecessário que o decreto interventivo seja submetido ao Congresso Nacional.

9.4. PRINCÍPIOS QUE REGEM A INTERVENÇÃO

São quatro os princípios que regem a intervenção:

9.4.1. EXCEPCIONALIDADE

A intervenção é sempre medida excepcional. A regra no federalismo é a autonomia. É o que diz o art. 34, *caput*, CF.

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para

9.4.2. NECESSIDADE

Só cabe intervenção se não existir outro meio menos gravoso para reestabelecer o equilíbrio. A intervenção é a *ultima ratio*. Daí a crítica ao Presidente Michel Temer que decretou a intervenção federal no Rio de Janeiro, pois se questiona a necessidade, se não haveria outra forma de solucionar.

9.4.3. TAXATIVIDADE

O rol de hipóteses é um rol taxativo, é um rol fechado; *numerus clausus*. Só poderá intervir se estiver previsto numa das hipóteses dos sete incisos do art. 34, CF:

9.4.4. TEMPORALIDADE

O decreto de intervenção tem sempre que ter prazo certo. Intervenção é exceção e precisa ter prazo certo.

9.4.5. PROCEDIMENTO

O procedimento das hipóteses do art. 34, I, II, III e V será o mesmo. Já o da hipótese do art. 34, IV, outro, bem como o procedimento do art. 34, VI será diferente. Por sua vez, o procedimento do art. 34, VII, CF, também será outro. Não são sete procedimentos diferentes.

a) Procedimento das hipóteses do art. 34, I, II, III e V, CF

A intervenção será decretada de ofício pelo Presidente da República, por intermédio um ato voluntário, sem provocação. Aqui a intervenção depende da simples verificação de motivos. O máximo que esse procedimento exige é que sejam ouvidos o Conselho da



República e o Conselho de Defesa, que emitirão pareceres não vinculantes. A intervenção do estado do Rio de Janeiro foi baseada no art. 34, III, CF.

b) Procedimento da hipótese do art. 34, IV, CF

A intervenção nesse caso depende de solicitação do Poder Legislativo ou Executivo ou requisição do Poder Judiciário via STF para o Presidente da República. Se for solicitação, o Presidente não é obrigado a decretar intervenção. Se for requisição do STF, o Presidente é obrigado a decretar a intervenção, ele está vinculado à requisição.

c) Procedimento da hipótese do art. 34, VI, CF

No caso de descumprimento de ordem judicial, quando o estado descumpra ordem judicial, depende de requisição do STF, STJ ou TSE para o Presidente da República. Como é requisição, o Presidente é obrigado a decretar a intervenção. Se for uma ordem judicial de Tribunal de Justiça Estadual, existem duas correntes: a primeira diz que caberá sempre ao STF ser guardião dos outros órgãos do poder judiciário, ou seja, se uma ordem de algum TJ não está sendo cumprida pelo estado, caberá ao STF requisitar a intervenção para o Presidente da República.

A segunda corrente defende que se for uma questão de natureza constitucional, caberá ao STF requisitar ao presidente da República, mas se for uma questão de natureza infraconstitucional, caberia ao STJ requisitar ao Presidente da República. A segunda corrente vem sendo adotada por diferenciar competências.

No caso de inexecução de lei federal, quando o estado não cumpre lei federal, a intervenção depende de provimento do STF em representação do Procurador Geral da República. Se o estado descumprir lei federal, o PGR representa no STF, dá início a uma ação de inexecução de lei federal e no final tem-se o provimento do STF. Não basta o provimento do STF para que seja decretada a intervenção, sendo necessária a decretação da intervenção pelo Presidente da República. Esse provimento do STF tem natureza de uma requisição, sendo o Presidente da República obrigado a decretar a intervenção.

Esse procedimento é regulamentado pela lei 12.562/2011.

d) Procedimento do art. 34, VII, CF

Quando o estado ou o DF deixam de cumprir princípios sensíveis da Constituição. A intervenção nesse caso também depende de provimento do STF em representação do Procurador Geral da República. Não basta só o provimento do STF, sendo o Presidente da República obrigado a decretar a intervenção. A lei que rege esse procedimento também é a lei 12.562/2011. A diferença desse procedimento para o anterior é que estamos diante de um outro tipo de ação, apesar do procedimento ser baseado na mesma lei. Nesse caso, a ação é outra, é uma ADI Interventiva. Quando um estado membro ou DF está descumprindo princípio sensível da constituição, este descumprimento, se o PGR é notificado ou cientificado, ele irá representar no STF ajuizando uma ADI Interventiva, sendo o PGR seu único legitimado para propor tal ação.

9.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em regra, não há possibilidade de controle judicial no ato de intervenção por ser um ato de natureza política. No entanto, caso fique provado o descumprimento de procedimentos previstos na Constituição, haverá controle judicial do ato de intervenção.

Ex. 1: O Presidente da República decretou a intervenção de ofício e fundamenta que essa intervenção do legislativo do estado está coagindo o executivo do estado. Pergunta-se: essa intervenção é constitucional? Não. O presidente aqui decretou uma intervenção das hipóteses dos incisos I, II, III e V numa hipótese do inciso IV. Nessa hipótese, a intervenção



depende de solicitação (do legislativo e executivo) ou requisição (judiciário) e o presidente decretou de ofício.

Ex. 2 (caso concreto ocorrido em 2005): O Presidente Lula decretou a intervenção federal no município do Rio de Janeiro, no setor hospitalar, com base no inciso III, do art. 34, CF. O município do Rio de Janeiro impetrou Mandado de Segurança no STF (MS 25295).

No entanto, não é cabível intervenção federal em município. Além disso, a intervenção tinha como base o inciso III do art. 34, CF, devendo ter o controle pelo Congresso Nacional, o que não teve. Também, o decreto de intervenção não possuía prazo determinado, o que não pode ocorrer.

O Mandado de Segurança impetrado pelo município do Rio de Janeiro teve, ao final, 11 votos favoráveis.

10. INTERVENÇÃO NO MUNICÍPIOS

A intervenção nos municípios segue a mesma lógica da intervenção federal.

Basta que se faça a simetria entre o art. 34 com o art. 35, CF. Nas hipóteses judicializadas, hipótese do art. 35, IV, vai ser aquele em que vai haver provimento e representação para que o Governador decrete.

O provimento será do Tribunal de Justiça, e a representação será do Procurador Geral de Justiça. O Governador do Estado estará obrigado, após a representação do PGJ e provimento do TJ, a decretar a intervenção estadual.

Vale apenas ressaltar que a decisão do TJ na representação interventiva para estabilizar a situação de instabilidade pela qual passa o Estado, a fim de viabilizar a medida que passa o município, possui um caráter político-administrativo. E, portanto, tem um caráter definitivo.

Em outras palavras, não cabe recurso extraordinário da decisão do Tribunal de Justiça que requisita ao Governador do Estado que decrete a intervenção municipal. Isto inclusive está na Súmula 637 do STF:

Súmula 637, STF – Não cabe Recurso Extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município.

11. INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA

11.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Para a criação de novos Municípios, o art. 18, § 4º, da CF/88 exige a edição de uma Lei Complementar Federal estabelecendo o procedimento e o período no qual os Municípios poderão ser criados, incorporados, fundidos ou desmembrados. Como atualmente não existe essa LC, as leis estaduais que forem editadas criando novos Municípios serão inconstitucionais por violarem a exigência do § 4º do art. 18. STF. Plenário. ADI 4992/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/9/2014

O Tribunal, por unanimidade, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 3.606/2017 do Município de Itaguaí/RJ, nos termos do voto do Relator. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 14.2.2020 a 20.2.2020. EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI 3.606/2017 DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ/RJ. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO E INATIVO. ESTABELECIMENTO DE SANÇÕES E CONSEQUÊNCIAS PARA DESCUMPRIMENTO DOS LIMITES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO.



DESRESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (ARTIGOS 30, 30, II; 163, I ao VII, e 169, CAPUT, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. No plano financeiro, a Constituição estabeleceu, em seu art. 169, caput, que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios respeite os limites estabelecidos em lei complementar de caráter nacional, atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). 4. A norma impugnada apartou-se do figurino constitucional e da legislação editada pela União ao vedar medidas que são expressamente autorizadas pela LRF (art. 22, parágrafo único, I), a qual, flexibilizando a proibição de concessão de vantagens, autoriza o pagamento decorrente de sentença judicial, determinação legal/contratual ou quando se tratar de revisão geral anual (CF, art. 37, X), mesmo no cenário de inobservância dos limites de gastos com despesa com pessoal ativo e inativo. 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente (DJE DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2020 ADPF 584 RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAES)

Questões

1) (MPE PR-2019) — Sobre o princípio federativo, é correto afirmar:

- a) O princípio federativo tem por elemento informador a pluralidade consorciada e coordenada de mais de uma ordem jurídica incidente sobre um mesmo território estatal, posta cada qual no âmbito de competências previamente definidas.
- b) No Estado Federal, as ordens jurídicas central e periféricas gozam de soberania.
- c) É constitucional lei estadual que estabelece que os veículos utilizados para atender contratos estabelecidos com a Administração Direta e Indireta, devem, obrigatoriamente, ter seus respectivos Certificados de Registro de Veículos expedidos pelo Estado contratante.
- d) Os Estados podem subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população da área a ser desmembrada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
- e) É inconstitucional a vedação à aquisição pelos demais Estados-membros de ações de propriedade do Estado no capital de concessionárias de serviço público.

2) (PGM de Ribeirão Preto-2019) — Considere que o Município X tenha a intenção de se fundir ao Município Y e lhe solicita, na condição de Procurador, parecer a respeito de como efetivar a medida. Nesse caso, a partir do quanto previsto pela Constituição Federal, a fusão deve ser efetivada mediante

- a) lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
- b) lei estadual e depende de consulta posterior, mediante referendo, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal.
- c) lei estadual, não se fazendo necessária consulta às populações dos Municípios, considerando se tratar de interesse exclusivamente estadual.



d) lei municipal e depende de consulta prévia, por meio de plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos.

e) lei municipal com a exigência de consulta posterior, mediante referendo, das populações dos Municípios envolvidos, exigindo-se também a publicação prévia de estudos de viabilidade municipal.

Comentários

1) Gabarito: letra A. Federação implica em descentralização administrativa e política de poder, compartilhado entre o poder central (União), e os poderes regionais (Estados). No Brasil, firmou-se o federalismo de terceiro grau, onde os municípios também detêm autonomia. A Ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, assinala em obra doutrinária que "O elemento informador do princípio federativo é pluralidade consorciada e coordenada de mais de uma ordem jurídica incidente sobre um mesmo território estatal, posta cada qual no âmbito de competências previamente definidas, a submeter um povo".

b) Errado. As ordens jurídicas internas gozam de autonomia. A soberania é exclusiva da Pessoa Jurídica de Direito Público internacional, a República ou a Monarquia, quando for o caso. No Brasil, a autonomia é assegurada pelo art. 18 da Constituição, e a soberania, pelo art. 1º, I:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

c) Errado. Para o Supremo, tal medida fere o pacto federativo, sendo, portanto, inconstitucional:

Lei do Município de São Paulo 13.959/2005, a qual exige que "os veículos utilizados para atender contratos estabelecidos com a Administração Municipal, Direta e Indireta, devem, obrigatoriamente, ter seus respectivos Certificados de Registro de Veículos expedidos no Município de São Paulo". Exigência que não se coaduna com os arts. 19, III, e 37, XXI, da CF. (...) Consoante a jurisprudência firmada na Corte no exame de situações similares, o diploma em epígrafe ofende, ainda, a vedação a que sejam criadas distinções entre brasileiros ou preferências entre os entes da Federação constante do art. 19, III, da CF/1988 (RE 668.810 AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgamento 30/6/2017)

d) Errado. A aprovação da população deverá abranger toda a área envolvida no desmembramento (art. 18, § 3º, CF):

Art. 18.....

.....

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.



Nesse sentido, o STF já assentou que o termo "população diretamente interessada" corresponde à população total dos estados envolvidos; nesse sentido, o Supremo entendeu compatível o art. 7º, da Lei 9.709/1998 com a Constituição Federal, e que se aplica tanto a modificação territorial de estados quanto de municípios (ADI, 2.650, rel. Min. Dias Toffoli, julg. 24/8/2011):

Art. 7º Nas consultas plebiscitárias previstas nos arts. 4º e 5º entende-se por população diretamente interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento; em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar quanto a da que receberá o acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada.

e) Errado. O Supremo considerou constitucional norma que proíba a referida aquisição, por razões econômicas, políticas e federativas:

Vedação à aquisição pelos demais Estados-membros de ações de propriedade do Estado de São Paulo no capital das concessionárias de eletricidade paulistas. Razões econômicas e políticas legitimam a restrição contida no preceito impugnado. A limitação mencionada afasta possível tensão nas relações entre as unidades federativas envolvidas (ADI 2.452, rel. min. Eros Grau, j. 17/6/2010)

2) Gabarito: letra A. Art. 18, §4º, da Constituição Federal. Art. 18

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Em resumo, estes são os passos, para a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios:

- 1º) aprovação de lei complementar federal fixando genericamente o período dentro do qual poderá ocorrer a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios;
- 2º) aprovação de lei ordinária federal estabelecendo a forma de apresentação e publicação dos estudos de viabilidade municipal;
- 3º) divulgação dos estudos de viabilidade municipal, na forma estabelecida pela lei ordinária federal acima mencionada;
- 4º) consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, como condição prévia, essencial e prejudicial, porém não vinculante, a partir de proposta aprovada no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado, conforme o art. 5º, da Lei 9.709/1998:
Art. 5º O plebiscito destinado à criação, à incorporação, à fusão e ao desmembramento de Municípios, será convocado pela Assembléia Legislativa, de conformidade com a legislação federal e estadual.
- 5º) aprovação de lei ordinária estadual formalizando a criação, a incorporação, a fusão ou o desmembramento do município, ou dos municípios.

b) Errado. Lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Alternativas “c”, “d” e “e” erradas com justificativas na assertiva “a”.



CAPÍTULO 16 — A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

Não há apenas um conceito de administração pública, razão pela qual a definição vai depender do enfoque: material e formal.

Sob o enfoque material (objetivo), conceitua-se administração pública como a atividade exercida sob um regime jurídico, sem importar quem o esteja exercendo.

A doutrina vai apresentar 4 hipóteses em que administração pública atua em sentido material:

- serviço público: confere utilidades à população em geral. Serviço público é administração pública em sentido material;
- polícia administrativa: são restrições de atividades privadas em benefício do interesse público. Esta é atividade em sentido material.
- fomento da iniciativa privada: é o incentivo à iniciativa privada, a fim de que possa orientar a maneira pela qual esta iniciativa irá atuar.
- intervenção: abrange toda a intervenção de estado na esfera privada, como a desapropriação, intervenção no domínio econômico (ex.: criação de agência reguladora), a fim de estipular as regras que os particulares devem observar etc.

Há apenas uma exceção no sentido de que a intervenção não configurará administração pública em sentido material, que será a hipótese em que o Estado age diretamente no domínio econômico, como é o caso de atividade bancária (ex.: Banco do Brasil).

Sob o enfoque formal (subjetivo), administração pública não seria o quê, mas quem é. Trata-se de um conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas que o nosso ordenamento jurídico identifica como administração pública, não importando a atividade que estes órgãos estejam exercendo.

O direito brasileiro adota o critério formal de administração pública, pois a preocupação aqui é com quem estão tratando.

Estes órgãos poderão ser integrantes da administração direta (desconcentração), mas também poderão ser entidades da administração indireta (descentralização), como são as autarquias, fundações, sociedades de economia mista e as empresas públicas.

São dois os princípios que orientam o regime jurídico administrativo:

- supremacia do interesse público
- indisponibilidade do interesse público

Estes dois princípios não encontram previsão expressa na CF.

1. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO

Supremacia do interesse público está acima dos interesses particulares.

Ex.: num contrato administrativo, há de um lado a administração e do outro o particular. Nos contratos administrativos, são válidas as cláusulas exorbitantes, podendo a Administração alterar unilateralmente o contrato.

A ideia desse princípio é a de que, havendo conflito entre interesses públicos e particulares, prevalece o público.

2. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO

Significa que o administrador não pode abrir mão do interesse público. Na verdade, este princípio é um recado para a administração pública, não podendo desistir dos feitos, não poderá dispor de prerrogativas, etc. A coisa é pública (a *res* é pública).

Está aqui a necessidade de se prestar concurso público. Outro exemplo é o caso de construção de prédio por meio de licitação, não podendo abrir mão desse interesse público.



A CF, em seu art. 37, trata expressamente dos princípios que orientam a administração pública:

- legalidade
- impessoalidade
- moralidade
- publicidade
- eficiência

3. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

O princípio da legalidade, sob a ótica da administração, estabelece que a administração só pode agir se houver uma determinação legal ou uma autorização legal.

A administração pública não pode atuar contrariamente à lei tampouco além da lei, pois só atua segundo a lei.

4. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo dizem que o princípio da impessoalidade da administração possui uma dupla finalidade:

- atuação administrativa voltada para o interesse público: a atuação da administração pública deve sempre visar atingir interesse público;
- veda a promoção pessoal do administrador: quem atua é o Estado, e não o governante.

Esta vedação quanto ao administrador encontra previsão no art. 37, §1º, que estabelece que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dessa publicidade não podem contar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

5. PRINCÍPIO DA MORALIDADE

A ideia da previsão do princípio da moralidade na CF é a ideia de tornar jurídica a moral.

A exigência de atuação ética passa a ganhar contorno no mundo do dever ser, vindo a ser uma norma jurídica. Com isso, o ato imoral também passa a ser um ato ilegal, podendo inclusive ser anulado pelo poder judiciário.

Isto é facilmente percebido na ação popular, em que, segundo a CF, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

Ou seja, se o ato ofender a moralidade administrativa não estará dentro do mérito administrativo, podendo ser reconhecido a nulidade do ato.

O §4º do art. 37 trata de maneira qualificada sobre a moralidade administrativa, isto é, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

6. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

O princípio da publicidade também possui duas vertentes:

- exige a publicação em órgão oficial como requisitos para que os atos administrativos possam ter efeitos: sendo ato interno ou externo da administração.



- transparência: a atuação da administração pública deve ser transparente, pois, neste caso, há controle da administração pelos administrados, pois a coisa é pública.

7. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

A EC 19 acrescentou o princípio da eficiência ao *caput* do art. 37.

O princípio da eficiência é uma consequência do modelo denominado de administração gerencial, a qual vai se opor ao sistema burocrático.

A ideia é fazer com que a administração se aproxime ao máximo, e na medida do possível, da ideia, ou dos princípios, que orientam o setor privado, pois é um setor que funciona.

São características da ideia de administração gerencial:

- resultados e metas da administração: a ideia de administração gerencial está diretamente ligada a ideia de resultado.
- ampliação da autonomia dos entes federativos: para obter resultados, é possível aumentar as autonomias de instituições. A partir daí, surgem controle finalísticos, ficando para trás a ideia de controle da atividade meio, que é típico do sistema burocrático. Este burocracia fomenta a corrupção.

Ex.: previsão constitucional, inserida pela EC 19, é o contrato de gestão, o qual diz que a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto fixar uma meta de desempenho para o órgão ou entidade (parte do §8º do art. 37).

A doutrina vai tratar de normas constitucionais sobre a organização da administração pública.

8. PRINCÍPIO DA ORGANIZAÇÃO LEGAL DO SERVIÇO PÚBLICO NA VERTENTE FEDERAL

Haverá um princípio que vai reger esta atuação da administração pública, o qual se denomina de princípio da organização legal do serviço público.

Esse princípio estabelece que cargos, empregos, funções, ministérios, órgãos públicos devem ser criados ou extintos por meio de lei. Este princípio não tem caráter absoluto, eis que a própria administração prevê os denominados decretos autônomos.

O princípio da organização legal do serviço público, defendido pela doutrina administrativista, não tem caráter absoluto, pois, a partir da EC 32, o presidente da República passou a ter competência para dispor mediante decretos autônomos sobre a organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos.

Apesar de não poder extinguir órgãos, o decreto do Presidente da República poderá extinguir função ou cargos públicos, desde que estejam vagos.

Este decreto é autônomo, pois ele não regulamenta uma lei, vindo diretamente da Constituição, como um ato normativo primário.

Veja como foi mitigado o princípio da organização legal do serviço público.

9. PRINCÍPIO DA ORGANIZAÇÃO LEGAL DO SERVIÇO PÚBLICO NO ÂMBITO DOS ESTADOS

Cabe ressaltar que estas regras também serão aplicadas aos Estados.

Por exemplo, a iniciativa de lei que disponha sobre cargo, função, emprego público, na administração direta ou autárquica, será do Presidente da República. Com isso, na esfera estadual, a competência para iniciativa desta lei será do Governador do Estado.



O mesmo se aplica à criação de órgãos, funções e empregos na esfera federal, eis que é da competência do STF e Tribunal Superior. Se for no âmbito estadual, a competência será do Tribunal do Estado.

10. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO

A CF trata da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual não pode o administrador contratar o sobrinho para atuar no Poder Judiciário como magistrado, pois ele deverá prestar concurso público.

A Constituição, em relação a ingresso no serviço público, vai estabelecer que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, ou aos estrangeiros, na forma da lei (art. 37, I).

Em relação aos estrangeiros, a norma é de eficácia limitada, razão pela qual depende de lei para que o estrangeiro tenha acesso aos cargos no Brasil.

10.1. CARGOS PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO

São cargos privativos de brasileiros natos:

- de Presidente e Vice-Presidente da República;
- de Presidente da Câmara dos Deputados;
- de Presidente do Senado Federal;
- de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
- da carreira diplomática;
- de oficial das Forças Armadas;
- de Ministro de Estado da Defesa.

A partir do art. 37, I, é possível perceber que os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que atendam aos requisitos previstos em lei.

A partir dessa ideia, percebemos que, como decorrência desse artigo, haverá exigências previstas no edital, em dissonância à lei. O edital não pode estabelecer exigências sem base legal. Com base nisso, o STF editou a súmula vinculante 44, estabelecendo que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. O edital não pode submeter o candidato a psicotécnico se a lei não exige isso.

O STF estabelece que é razoável exigir altura mínima para candidatos a cargos de segurança, desde que a altura mínima esteja prevista em lei, em sentido material e formal.

No mesmo sentido, o STF diz que, se não houver base legal, o edital não pode prever uma restrição.

O Supremo, homenageando o princípio da presunção de inocência, estabeleceu que a administração não pode recusar a inscrição, ou excluir do concurso público, ou impedir a nomeação de sujeito aprovado, sob o fundamento de que ele não tem idoneidade moral para o cargo, pois responde há inquéritos policiais ou ações penais em curso. Mesmo que ele tenha uma sentença condenatória, mas que não tenha havido o trânsito em julgado, o princípio da presunção de inocência impede que a administração obste o sujeito de ingressar no cargo.

10.2. INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO

A CF/88 tornou obrigatória a aprovação de concurso público para ingresso na carreira pública para cargo efetivo.

O STF decidiu que provas de título não podem ter caráter eliminatório, mas classificatório. Isto não define a aprovação ou não.

A CF estabelece que é necessário reservar um percentual das vagas para as pessoas com deficiência. Este percentual vem descrito em lei.

Esta exigência de concurso público é para emprego permanente, mas não abrange os cargos em comissão. Estes são cargos de livre nomeação e exoneração, ficando sujeito ao



critério da autoridade competente. Estes cargos em comissão são de chefia, assessoramento e direção.

Segundo o STF, não é possível convalidar um ato de nomeação ou contratação sem que o sujeito tenha sido aprovado previamente por concurso público, pois esta é uma ordem constitucional.

O STF não admite a teoria do fato consumado em matéria de concurso público. Ou seja, se o sujeito não foi aprovado no concurso público, não poderá alegar fato consumado, sob a alegação de que já tomou posse no cargo, fundado em decisão judicial provisória. Se o indivíduo foi reprovado numa das fases do concurso e só continuou no certame em decorrência de uma decisão liminar, ainda que ao final tenha sido aprovado, se a decisão inicial for alterada, ou desconstituída, poderá ele vir a perder o cargo.

10.3. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO

Segundo a CF, o prazo de validade do concurso público é de até dois anos, renovável por igual período. Ou seja, o prazo poderá ser de 1 ano, podendo ser renovado por mais 1 ano.

Este prazo começa a ser contado a partir da homologação do concurso público. Homologar é dizer que o concurso está validamente concluído.

10.4. DIREITO SUBJETIVO AO CARGO PÚBLICO

Segundo o STF, candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas indicado no edital, tem direito subjetivo a ser nomeado, dentro do prazo de validade do concurso público.

Se o indivíduo for aprovado fora do número de vagas, o sujeito não tem direito subjetivo à nomeação.

Caso durante o prazo de validade do concurso surgirem novas vagas, não significará que haverá direito subjetivo à nomeação. Para o STF, mesmo que haja a abertura de um novo concurso para o mesmo cargo, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação.

O STF, em sua Súmula 15, estabelece que dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Veja, se o indivíduo foi aprovado fora do número de vagas do edital (10 vagas), mas o Governador nomeou 15 pessoas, mas pulou o 12º, significa dizer que ele foi preterido. Neste caso, há direito subjetivo à nomeação.

Esta preterição fica evidente nos casos de contratação de servidores temporários. O administrador, para não fazer concurso, contrata terceirizados para exercer atribuições do cargo em questão. Nesta situação, há preterição, razão pela qual o STF entende que, se isto ocorreu dentro do prazo de validade do concurso, haverá direito subjetivo à nomeação para o cargo de provimento efetivo.

No caso de impugnações de gabaritos ou questões de prova, o STF vai estabelecer que critérios de correção, se a questão está certa ou errada, não configura controle de legalidade, pois estaria adentrando no mérito. Nesta seara, o Poder Judiciário não poderia ingressar no mérito. Diante disso, não poderia o Poder Judiciário fazer o controle de gabaritos oficiais ou contestar critérios de avaliações das provas objetivas.

Essa questão chegou ao STF, em sede de repercussão geral, em abril de 2015, momento em que fixou a tese: “Os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.

Veja, o Poder Judiciário não pode entrar no mérito. Mas o Poder Judiciário continua podendo fazer o controle de legalidade e o controle de constitucionalidade.

Na mesma decisão em que fixou a tese da repercussão geral, o STF entendeu que é possível o Poder Judiciário fazer o controle de pertinência entre o que foi cobrado e o que estava previsto no edital. Ou seja, é possível analisar se a questão cobrada estaria dentro do edital do concurso. Isto é controle de legalidade, pois o edital é a lei do concurso.



10.5. FUNÇÕES DE CONFIANÇA

O inciso V do art. 37 disciplina como se dá o preenchimento dos cargos em comissão e as funções de confiança.

As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Algumas regras poderão ser destacadas:

- as funções de confiança e cargos em comissão se destinam exclusivamente a cargos de direção, chefia e assessoramento;
- não precisa de ingresso de serviço público, salvo um percentual mínimo que deve ser preenchido pelos servidores da casa: ou seja, em regra, o cargo em comissão pode ser preenchido por pessoa que não tenha prestado concurso público, porém há um percentual mínimo que deve ser preenchido por servidores públicos de cargos efetivo da entidade.
- as funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores de cargo efetivo: ou seja, não podem ser realizadas por pessoa de fora da administração.

O STF decidiu a questão sobre o nepotismo, o qual é violador do princípio da moralidade. Para o STF, a Constituição veda o nepotismo, inclusive o nepotismo cruzado. A próprio CF veda o nepotismo quando consagra o princípio da moralidade, que é uma norma.

Esta decisão do STF se tornou a súmula vinculante 13, que diz que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

Se o sujeito nomeia o primo, que é colateral de 4º grau, pela leitura da súmula vinculante, não há nepotismo.

O STF (Inf. 815) já decidiu que não há nepotismo na nomeação de servidor para ocupar o cargo de assessor de controle externo do Tribunal de Contas mesmo que seu tio (parente em linha colateral de 3º grau) já exerça o cargo de assessor-chefe de gabinete de determinado Conselheiro, especialmente pelo fato de que o cargo do referido tio não tem qualquer poder legal de nomeação do sobrinho.

Segundo a Suprema Corte, a incompatibilidade da prática enunciada na SV 13 com o art. 37 da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público, mas de presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionado à pessoa com relação de parentesco com quem tenha potencial de interferir no processo de seleção.

10.6. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

O art. 37, IX, da CF diz que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

O pessoal contratado temporariamente não ocupam cargo público, não estando sujeito ao regime estatutário. Também não fazem parte do regime trabalhista.

Portanto, estes agentes não são considerados servidores e nem empregados públicos, estando vinculados à administração pública por um regime funcional de direito público de caráter jurídico-administrativo.

Esses agentes temporários possuem as seguintes características:



- exercem função pública;
- contrato de direito público: esta função implica uma relação funcional com o poder público, sendo uma relação jurídico-administrativa. Portanto, o contrato entre o agente temporário e a administração pública é um contrato de direito público, e não de relação trabalhista.
- competência da Justiça Estadual ou Federal, a depender do ente: isso significa que, se houver litígio entre o contratado temporariamente e a administração, não será da competência da Justiça do Trabalho, e sim da Justiça Estadual, caso o ente seja estadual, ou Justiça Federal, caso seja ente federal.
- regime geral de previdência social: por não haver o vínculo estatutário, entendeu-se que os agentes temporários estão sujeitos ao regime geral de previdência social.

A contratação pela esfera federal não é feita através de concurso público, e sim por meio de um processo seletivo simplificado. Em determinadas hipóteses, é possível dispensar este processo seletivo simplificado, como nos casos de calamidades públicas, emergência ambiental ou emergência em saúde pública.

O STF entendeu que são necessário 5 requisitos para que se possa considerar válida a contratação temporária:

- caso excepcional previsto em lei
- prazo predeterminado da contratação
- necessária essa contratação em caráter temporário, pois se for perene, deve-se fazer concurso público;
- interesse público excepcional
- necessidade indispensável, não havendo outra forma de resolver o problema.

Observe que não é possível contratar pessoas em caráter temporário para prestação de serviços ordinários, de caráter permanente do Estado, estando dentro da conjuntura normal da administração.

11. NORMAS CONSTITUCIONAIS SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS AGENTES PÚBLICOS

11.1. AGENTES PÚBLICOS

Não há consenso sobre o que são agentes públicos. São todos aqueles que possuem algum vínculo com o Poder Público, remunerado ou não.

Podem ser classificados por categorias:

11.1.1. AGENTES POLÍTICOS

Chefes dos poderes, membros do MP, conselheiros e ministros dos Tribunais de Contas.

11.1.2. AGENTES ADMINISTRATIVOS

Delegado de polícia é um exemplo. Exercem uma atividade pública de natureza profissional e remunerada, estando sujeito à hierarquia funcional. O regime jurídico é estatutário, bem como ocupantes de cargos públicos, empregos públicos ou de função pública. Devem ser classificados em:

a) Servidores públicos

Exercem uma atividade pública de natureza profissional e remunerada, estando sujeito à hierarquia funcional. O regime jurídico é estatutário, bem como ocupantes de cargos públicos, empregos públicos ou de função pública. A relação com o poder público é legal, e não contratual.



b) Empregado público

Está sujeito ao regime jurídico contratual, sendo um celetista.

c) Agentes temporários

Existem agentes administrativos denominados de agentes temporários, sendo contratados para tempo determinado em razão de uma necessidade excepcional de interesse público. Não possuem cargo nem mesmo emprego público, mas exercem função pública. O vínculo com a administração é contratual, considerado um vínculo jurídico-administrativo. O contrato com a administração é de direito público.

O STF já decidiu que compete à Justiça comum (estadual ou federal) julgar litígios envolvendo servidores temporários (art. 37, IX, da CF/88) e a Administração Pública. A competência não é da Justiça do Trabalho, ainda que o autor da ação alegue que houve desvirtuamento do vínculo e mesmo que ele formule os seus pedidos baseados na CLT ou na lei do FGTS (Inf. 807, STF).

Funcionário público é uma expressão que inexiste na CF, mas o direito penal fala sobre quem seria funcionário público para fins do direito penal.

Há outras definições:

- **Cargo público:** conjunto de atribuições e responsabilidades, previstos em lei, nas quais o servidor deve ser investido. Este cargo é criado por lei. O cargo público é típico de pessoas jurídicas de direito público com regime estatutário, podendo ser cargo efetivo ou cargo em comissão.
- **Empregos públicos:** são de caráter permanente, preenchidos pelos contratados, os quais obedecerão a CLT. Há uma relação trabalhista. A pessoa jurídica de direito privado é que vai contratar os empregados públicos. Ex.: sociedade de economia mista e empresas públicas.
- **Funções públicas:** podem ser autônomas (contratação temporárias) ou de confiança, sendo estas ocupadas por servidores de cargo efetivo. No caso de funções de confiança, não há concurso público, mas quem ocupa faz parte do quadro efetivo (ocupa cargo efetivo).

Na redação originária do *caput* do art. 39, a CF estabelecia que os entes federados adotassem um regime jurídico único, denominado RJU, para contratação das pessoas da administração direta, autarquias e fundações. Com a EC 19/98, houve a extinção de obrigatoriedade do regime jurídico único. Em 2007, o STF suspendeu a eficácia da EC 19/98. O fundamento foi de que a Câmara dos Deputados não observou a votação em dois turnos. A redação originária voltou a valer da ideia de regime jurídico único. A consequência é de que os contratos anteriores firmados pela administração, entre a emenda e a suspensão da eficácia, continuaram válidos, eis que o STF deu efeitos prospectivos da decisão (efeitos *ex nunc*).

Portanto, há uma obrigatoriedade do regime jurídico único para aqueles que possuem vínculo com a administração pública, sendo este denominado de regime jurídico estatutário.

II. Direito de associação sindical dos servidores públicos

O inciso VI do art. 7º garante o direito de associação sindical. Há um direito à livre associação, podendo se associar ou não. Trata-se de uma norma de eficácia plena, dispensada a regulamentação legal.

A CF estabelece uma exceção a esta sindicalização, que é a sindicalização militar, a qual é vedada pela Constituição. Ou seja, militar não pode se sindicalizar.

III. Direito de greve dos servidores públicos

Segundo o inciso VII do art. 37, os servidores tem direito de greve. Esta norma é de eficácia limitada, dependendo de lei regulamentadora. Até hoje esta lei não veio.



Há uma omissão constitucional na CF. Por conta disso, o STF adotou a posição concretista geral, de modo que, enquanto não há lei de greve dos servidores públicos, aplicar-se-á a Lei 7.783/89, sendo a lei do direito de greve dos servidores privados, no que couber.

Ao militares é vedado o direito de greve. O STF estendeu esta vedação aos policiais civis, apesar de não existir esta vedação expressa na CF.

O STF decidiu que Constituição Estadual pode prever que é proibido que os servidores estaduais substituam trabalhadores de empresas privadas em greve (Inf. 793).

IV. Regras constitucionais pertinentes à remuneração dos agentes públicos

O art. 37, X, CF regulamenta o tema, estabelecendo que a remuneração dos servidores públicos somente poderão ser fixados e alterados por lei específica, assegurada a revisão geral anual. Veja os pontos que o dispositivo deixa claro:

- Iniciativa privativa;
- Lei específica;
- Revisão geral anual.

No que toca à lei específica, é possível que uma lei ordinária trate de vários subsídios, mas somente pode tratar desse assunto.

Remuneração é gênero. Subsídio é espécie remuneratória que foi introduzida pela EC 19/98. O art. 39, §4º, estabelece que o subsídio é uma parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação ou outras espécie remuneratória.

Recentemente, o STF decidiu que o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de férias e 13º salário. Isso porque o regime de subsídio é incompatível apenas com o pagamento de outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro e das férias, que são verbas pagas a todos os trabalhadores e servidores, com periodicidade anual.

Dessa forma, o STF julgou constitucional a previsão de férias e 13º salário e, por outro lado, inconstitucional o pagamento da chamada “verba de representação” (Inf. 852).

Vencimentos são parcelas remuneratórias que são compostas por: um vencimento básico, acrescido de vantagens pecuniárias de caráter permanente.

A iniciativa que trata sobre remuneração deve ser privativa. Quem dá início a estes projetos de lei é o Presidente da República, para cargos do Poder Executivo Federal. Sendo do Poder Legislativo Federal, será de competência da própria Casa Legislativa.

Em se tratando de serviços do Poder Judiciário, a iniciativa de lei será do STF ou dos Tribunais Superiores ou dos Tribunais de Justiça, a depender da esfera.

Subsídio de Deputado Federal, Senador, Presidente e Vice Presidente, Ministro de Estado não é por iniciativa do presidente da república, sendo de competência exclusiva do Congresso Nacional. Por esta razão, não será por meio de lei. Esta determinação é feita por meio de decreto legislativo do CN.

Em relação à revisão geral anual, o STF interpretou que se trata de direito consagrado na CF, mas quem define isso é a lei. Esta lei é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo de cada ente da Federação.

A revisão geral, como é geral, deve alcançar todos os servidores públicos do ente federado, e mesmo assim a iniciativa é do chefe do poder executivo.

O art. 37, XI, trata dos tetos das remunerações. A EC 41/03 promoveu uma alteração da redação deste inciso. Este dispositivo dispõe que a remuneração mensal não poderá ultrapassar o subsídio mensal do ministro do STF.

- Nos municípios, o limite é o subsídio do prefeito.
- Nos Estados e no DF, o limite é o subsídio do governador. Isto no âmbito do Poder Executivo. No âmbito do Poder Legislativo, o teto é dos deputados estaduais e distritais.
- No âmbito do Poder Judiciário, o limite é dos desembargadores. A CF fixa um teto aos desembargadores de 90,25% dos subsídio mensal de ministro do STF.



Este limite aplicável no âmbito do Poder Judiciário se estende ao MP, aos procuradores e aos defensores públicos.

O STF já decidiu que esse limite leva em conta a remuneração bruta de ministro do STF.

No §11º, a CF estabelece que dentro da remuneração este teto não comporta as parcelas de caráter indenizatório.

O §12º cria uma possibilidade aos Estados, os quais podem, por meio de emenda, fixar como limite único o subsídio dos Desembargadores. No entanto, este limite único, ainda que previsto na CE, não se aplicará aos deputados estaduais e aos vereadores, pois os seus subsídios encontram limites expressos na CF.

Caso o sujeito seja empregado público, o teto somente se aplica se essas empresas e sociedades de economia mista receberem recursos para custeio em geral e para despesas de pessoal. Do contrário, não haverá de observar o teto.

O inciso XII do art. 37 determina que os vencimentos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem superar os vencimentos dos chefes do Poder Executivo. Isto significa que cargos da mesma complexidade, mas nas diferentes esferas de poder, não podem ter remuneração superior àquelas fixadas pelo Poder Executivo.

O inciso XIII do art. 37 proíbe a equiparação de qualquer espécie remuneratória para fins de remunerar o pessoal do serviço público. Ex.: alguns Estados alteravam a CE e estabeleciam que o subsídio do delegado de polícia seria igual ao subsídio do promotor de justiça. Essa lei, conforme a constituição, é inconstitucional.

Esse mesmo inciso veda a vinculação da espécie remuneratória para fins de remuneração de pessoal. No Estado de Rondônia, fizeram uma vinculação ao índice de preços do consumidor (IPC). A variação de IPC iria atingir diretamente a espécie remuneratória. Isto é vedado pela Constituição, sendo dirigida ao legislador, para que ele não faça essa equiparação. Isto evita os chamados ajustes automáticos ou reajustes em cascata.

O STF trata disso na súmula vinculante 42, a qual estabelece que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

O inciso XIV vai dizer que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. O que significa é que o servidor ganhou um acréscimo, caso ele receba outro acréscimo, não poderá o valor já acrescido ser utilizado como base de cálculo para este novo acréscimo. Todos os acréscimos devem incidir sobre o vencimento básico.

12. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS

A CF consagra isso no inciso XV. O subsídio e os vencimentos são irredutíveis. Para o STF, essa irredutibilidade é nominal.

No caso de benefícios previdenciários (pensão por morte e aposentadoria, por exemplo), não haverá redução do valor real (art. 201, § 4º). Já no caso de outros benefícios da seguridade social (como o benefício assistencial), a CF/88 garante a preservação do valor nominal.

Irredutibilidade não impede criação ou majoração de tributos sobre o vencimento. Ou seja, nada impede que a alíquota suba.

O STF decidiu que a irredutibilidade do subsídio tem como ressalva o teto constitucional do STF. Ou seja, não há irredutibilidade perante o teto.

VI. Vedação à acumulação de cargos, empregos e funções públicos

Os incisos XVI e XVII do art. 37 vão tratar dessa vedação à acumulação.

O XVI diz que é vedada a acumulação de cargos, salvo quando houver compatibilidade de horários:

- 2 cargos de professor



- 1 de professor e 1 de técnico científico
- 2 cargos de profissionais de saúde

O inciso XVII diz que esta proibição abrange tanto a administração direta como a indireta.

Há ainda a possibilidade de acumulação para os vereadores, desde que haja compatibilidade de horários.

Os membros do MP e os membros do Poder Judiciário também podem exercer o magistério.

A CF ainda permite que a acumulação se dê por profissionais de saúde das Forças Armadas.

Ainda no que toca aos profissionais da saúde, o STF entende que a CF prevê a possibilidade da acumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, em que se incluem os assistentes sociais.

Observe-se, contudo, que, segundo o STF, a acumulação de dois cargos de médico não comporta interpretação ampliada para abrigar os médicos veterinários que também atuem como peritos criminais.

Essa proibição de acumulação vai se estender para a inatividade. Isto é, a proibição de acumulação vai se estender aos proventos de aposentadoria pelos dois cargos que não poderia ter acumulado.

É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, ressalvados os cargos acumuláveis, cargos eletivos, cargos em comissão e os declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Neste caso, é possível a percepção simultânea de aposentadoria.

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo vão dizer que ainda que seja possível a acumulação, qualquer acumulação está submetida ao teto constitucional.

Ocorre que, em 2012, o STJ decidiu que os cargos acumuláveis serão considerados seus limites isoladamente para cada uma das remunerações o teto constitucional.

Segundo o STJ, o cargo de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais pode ser cumulado com outro de professor, pois ainda que o cargo não exija curso superior, é de cunho técnico.

13. DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS RELATIVAS AO SERVIDORES EM EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO

O art. 38 da CF estabelece que o servidor que for eleito para qualquer cargo deve ser afastado do seu cargo, função ou emprego público. A remuneração será a do cargo eletivo.

O prefeito pode escolher a remuneração de prefeito ou do cargo, função ou emprego público. Esta disposição se estende aos vice-prefeitos.

Em relação aos vereadores, a CF estabelece que, se tiver compatibilidade de horários, poderão acumular o exercício da vereança com o cargo, função ou emprego público. Neste caso, receberá as duas remunerações.

Não havendo compatibilidade de horários, deverá optar pela remuneração de vereador ou pela remuneração cargo, função ou emprego público afastado.

O art. 38 estabelece que o tempo do mandato eletivo conta para todos os efeitos legais do cargo, função ou emprego público que ocupava, salvo para fins de merecimento.

14. ESTABILIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO

A CF trata da estabilidade do servidor público, sendo somente aplicada aos estatutários.

Prevalece que não há estabilidade de empregados públicos e para aqueles ocupantes em cargo em comissão.

São requisitos para estabilidade:



- aprovação em concurso público
- nomeação para o cargo
- 3 anos de efetivo exercício no cargo
- desde que seja aprovado através de avaliação especial de desempenho
- O servidor público pode perder o cargo nos seguintes casos:
- sentença transitada em julgado
- processo administrativo disciplinar
- procedimento de avaliação periódica de desempenho

No caso da avaliação periódica, esta é fruto da denominada administração gerencial.

É possível que o servidor perca o cargo por excesso de despesa com pessoal, conforme o art. 169 da CF. Este dispositivo diz que a despesa de pessoal ativo e inativo deve observar os limites estabelecidos em lei. Nesse caso, se não cumprir o limite legal, o §3º do art. 169 estabelece as seguintes providências, nesta ordem:

- reduz em pelo menos em 20% as despesas com cargos em comissão e funções de confiança
- exoneração dos servidores não estáveis
- exoneração dos servidores estáveis

Se o servidor estável perder o cargo, terá direito a uma indenização de um mês de remuneração ou vencimento por ano de serviço.

O cargo que tenha sido objeto de redução deve ser extinto, sendo vedada a criação do mesmo cargo com as mesmas atribuições pelo prazo de 4 anos.

Os limites de gastos são regulados pela LC 101, em que no seu art. 19 diz que a despesa total de pessoal não pode ultrapassar os seguintes limites:

- 50% em relação à União
- 60% em relação aos Estados e Municípios

O STF estabeleceu que o salário mínimo é referente à remuneração, e não ao vencimento básico. Portanto, não é necessário que o vencimento básico corresponda ao salário mínimo, bastando que a remuneração integral seja observada.

15. REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Somente servidores públicos de caráter efetivo fazem jus a ao regime próprio de previdência social.

O §13 do art. 40 diz que ao servidor ocupante de cargo em comissão bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.

O regime geral se aplica subsidiariamente aos servidores públicos submetidos ao regime próprio.

A partir da EC 41, trouxe algumas características do regime de previdência dos servidores de cargo efetivo:

- regime de caráter contributivo e solidário: não será analisado o tempo de serviço, e sim a sua contribuição. O caráter contributivo é de que todos contribuem para a aposentadoria de todos. O legislador não pode estabelecer qualquer tipo de contagem fictício, devendo ser contagem real. A CF estabelece que quem contribui é o ente público, servidores ativo, inativos e pensionistas.
- é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência, salvo no caso dos militares;
- para concessão de aposentadoria, é vedado que se adotem critérios diversos: a própria CF traz exceções, as quais serão disciplinadas por lei complementar:
 - a) portadores de deficiência
 - b) exerçam atividades de risco
 - c) exerçam atividades especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física



Há aqui uma omissão inconstitucional, pois essa lei complementar não veio. Por conta disso, o STF editou a súmula vinculante 33, estabelecendo que se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Ou seja, não há lei complementar tratando do assunto, então deverá aplicar as regras do regime geral de previdência social.

Por conta dessa omissão em editar uma lei complementar da aposentadoria dos portadores de deficiência, o STF estabeleceu que já existe uma lei complementar que trata da aposentadoria das pessoas com deficiência (LC 142), devendo aplicar o disposto da LC 142 para os servidores portadores de deficiência. É a aposentadoria das pessoas com deficiência que estão submetidas ao regime geral da previdência.

- fim das aposentadorias com proventos integrais: isto está no art. 40, §3º, CF, estabelecendo que a aposentadoria será realizada com base na média das remunerações sobre as quais o servidor contribuiu ao longo da sua vida profissional. Há algumas hipóteses em que há aposentadoria com provento integral:
 - a) aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço
 - b) aposentadoria por moléstia profissional
 - c) aposentadoria por doença grave, contagiosa ou incurável
 - d) servidores que ingressaram no serviço antes da EC 41 e que estão nas regras de transição
- os proventos são reajustados com base em índices previstos em lei, devendo ter um caráter permanente e mantido o seu valor real: a CF deixa claro que não há nenhuma relação entre o reajuste sofrido e a remuneração do servidor na ativa do mesmo cargo.

A EC 41 suprimiu a paridade entre a remuneração do servidor ativo e o servidor inativo.

Tratando-se da pensão por morte, também encontram regulamentação na CF. A Constituição estabelece que há o valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo dos regimes de previdência social. A partir desse limite, ou seja, o benefício da pensão por morte observará os limites estabelecidos pelo regime de previdência social, porém o que passar do teto do regime geral de previdência passará a receber 70% da parcela excedente.

Supondo que o teto da previdência social seja de 5 mil reais. O sujeito recebe 15 mil reais, mas morre. Sendo ele aposentado, a viúva receberá 5 mil reais, pois este é o máximo, e da parcela excedente aos 5 mil reais, receberá 70% daquilo que o de cujus recebia. Ou seja, ela passará a receber 7 mil, pois seria 70% da diferença entre os 15 mil reais menos os 5 mil reais, que é o teto do regime geral. No total, a viúva receberá 12 mil reais.

O §14 do art. 40 prevê que os entes políticos poderão fixar os valores de aposentadoria e pensões como limite máximo o benefício previsto para o regime geral de previdência social. É possível que o máximo percebido de aposentadoria seja o máximo do regime geral.

Para o ente federativo fazer isso, deverá ele instituir isso através de lei complementar. E mais, se ele decidir estabelecer o limite máximo com base no regime geral, deverá o ente criar um regime de previdência complementar. Ou seja, cada ente político deverá instituir o regime de previdência complementar por meio de lei. Isto permite que o servidor contribua mais, permitindo que ele receba mais que o teto quando se aposentar.

Perceba que o mais importante é que, se fixar o regime geral como limite máximo da aposentadoria, deverá dar ao servidor a oportunidade de optar de fazer sua contribuição complementar.



No §18 do art. 40, está previsto que incide contribuição previdenciária sobre os proventos que ultrapassarem o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social.

Isto é, o sujeito que recebe como aposentadoria o valor de 15 mil, terá que contribuir com a diferença que percebe a mais daquilo que está estabelecido como teto do regime geral. Ou seja, o sujeito deverá contribuir com base nos 10 mil que ganha a mais dos 5 mil que é o teto da previdência.

Nesse caso, a alíquota que incidirá sobre isso será idêntica às que o servidor em atividade paga.

A EC 47 acrescentou o §21, estabelecendo que a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela de proventos que superem o dobro do teto do regime geral de previdência quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

Se o sujeito receber 12 mil, e considerando que o teto da previdência é 5 mil, o sujeito só irá passar a contribuir sobre os 2 mil, eis que é o dobro do regime geral permite que somente incida quando superar o dobro do regime geral que é de 5 mil.

O §19 do art. 40 criou o abono de permanência. O sujeito já pode se aposentar, mas continua trabalhando. O servidor vai receber como abono de permanência o valor correspondente àquilo que iria pagar de contribuição social. Esta quantia somente será recebida se estiver em atividade. O abono de permanência equivale a dispensar o servidor de contribuir.

São hipóteses de aposentadoria pelo regime próprio de previdência social:

- invalidez permanente: como regra, recebe proventos proporcionais ao tempo de contribuição, salvo acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável;
- compulsoriamente: no caso, os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos ou aos 75 anos, na forma da lei complementar. Esta alteração veio através da EC 88/15 e mais tarde veio a EC 152, estabelecendo que a aposentadoria compulsória ocorre aos 75 de idade para os servidores titulares de cargo efetivo, tendo caráter nacional.
- voluntariamente: para esta aposentadoria, é preciso que tenha cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Além desse tempo, deverá cumprir outras condições:
 - a) homem: 60 anos de idade e 35 de contribuição
 - b) mulher: 55 anos de idade e 30 de contribuição
 - c) homem: 65 anos de idade, observado o tempo de contribuição
 - d) mulher: 60 anos de idade, observado o tempo de contribuição

Se o servidor ficar no cargo, tiver 60 anos e tiver 35 anos de contribuição, o servidor, homem, terá direito ao abono de permanência.

A CF estabelece que, no caso de professor, se ele comprovar exclusividade de tempo no exercício de atividade de magistério no educação infantil, fundamental ou no ensino médio, o tempo de contribuição e o limite de idade serão reduzidos em 5 anos para concessão da aposentadoria voluntária.

16. OBRIGATORIEDADE DE LICITAR

O art. 37, XXI, diz que ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações são contratados mediante processo de licitação, que deve assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes. Portanto, a regra é de que deve ser submetido à licitação.



A competência para estudar sobre normas gerais de licitação é de competência privativa da União. O principal instrumento é a Lei 8.666/93, mas também há a Lei 12.520, que trata do pregão. A Lei 12.462, trazendo o RDC.

O Regime Diferenciado de Contratações trouxe a facilitação da licitação para:

- Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016
- Copa das Confederações
- Copa do Mundo
- Obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km das cidades sedes dos mundiais
- Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
- Obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS
- Obras e serviços de estabelecimentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo
- Ações no âmbito da segurança pública
- Obras e serviços de engenharia para mobilidade urbana ou infraestrutura logística
- Ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação
- Contratos de locação de bens móveis e imóveis, nos quais o locador realiza prévia aquisição, construção ou reforma substancial, com ou sem aparelhamento de bens, por si mesmo ou por terceiros, do bem especificado pela administração

É importante ressaltar que o §1º do art. 173 da CF prevê que deve ser editado um estatuto jurídico próprio das sociedades de economia mista e empresas pública que explorem atividade econômica. Este estatuto deverá disponibilizar as regras de licitação, as quais deverão ser mais céleres.

A Lei 13.303/16 trouxe esta regulamentação.

Obs.: ainda não tinha sido editada quando a aula foi dada.

17. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O §6º do art. 37 trata da responsabilidade civil da administração e das pessoas que atuem na condição de administração pública, as quais causem danos a terceiros.

Este dispositivo estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A CF consagra a responsabilidade civil objetiva da administração, em razão da teoria do risco administrativo. Esta teoria estabelece que havendo conduta, nexo causal e resultado, há obrigação de indenizar, salvo se presentes as excludentes: culpa exclusiva da vítima, força maior e caso fortuito.

Havendo culpa recíproca, a obrigação de indenizar do Estado será atenuada proporcionalmente.

O STF entende que inclusive as prestadoras de serviços públicos estão sujeitas às responsabilidades civil objetiva, e não apenas em relação ao usuário, mas também em relação a terceiros não usuários.

Isso tudo é em relação à ação da administração.

No caso de omissão da administração pública, ou seja, em se tratando de um não fazer estatal, a responsabilidade do poder público é subjetiva, razão pela qual deve ser demonstrada



a culpa da administração (culpa administrativa), não sendo necessário demonstrar qual agente público ocasionou, mas é necessário demonstrar a falha do Estado.

Mas, se a pessoa ou a coisa, estiverem sob a custódia do Estado, e a administração se omite, o STF entende que se trata de responsabilidade objetiva, ainda que o dano tenha se dado por mera omissão estatal. Ex.: presidiário assassinado no presídio; aluno agredido por outro aluno dentro da sala de aula.

18. INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA

1. Em regra, a proibição da SV 13 não se aplica para cargos públicos de natureza política, como, por exemplo, Secretário Municipal. Assim, a jurisprudência do STF, em regra, tem excepcionado a regra sumulada e garantido a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos políticos, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. Exceção: poderá ficar caracterizado o nepotismo mesmo em se tratando de cargo político caso fique demonstrada a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral do nomeado. STF. 1ª Turma. Rcl 28024 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 29/05/2018.

Súmula 615-STJ: Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/05/2018, DJe 14/05/2018.

Questões

1) (TJ SC-2019) — A constituição de determinado estado da Federação dispõe que aos defensores públicos serão garantidas as mesmas prerrogativas, os mesmos impedimentos e os mesmos vencimentos dos membros do Ministério Público.

Nessa situação hipotética, à luz do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e do entendimento jurisprudencial do STF, a referida norma estadual é

- a) constitucional, pois é uma opção viável do constituinte originário do estado.
- b) inconstitucional, pois ofende norma da CF, que veda a equiparação e a vinculação remuneratória entre os referidos órgãos.
- c) constitucional, pois a CF confere as mesmas vantagens e os mesmos impedimentos aos integrantes das carreiras dos referidos órgãos.
- d) inconstitucional, pois o constituinte estadual não pode dispor sobre a organização dos órgãos que componham as funções essenciais à justiça.
- e) constitucional, por consagrar a isonomia entre integrantes das carreiras dos referidos órgãos, que têm estatutos jurídicos semelhantes.

2) (TJ MS-2020) — Ao dispor sobre a criação de cargos em comissão, o legislador deve observar as normas constitucionais e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nessa matéria, segundo as quais

- a) a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, pressupondo necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.



b) cabe à lei que os instituir definir, objetivamente, suas atribuições, podendo, todavia, delegar essa competência ao administrador, para que discipline a matéria por meio de ato regulamentar, uma vez que a Constituição Federal não veda a delegação de competências entre os Poderes.

c) pode a lei do ente federativo facultar aos servidores públicos ocupantes exclusivamente de cargo público em comissão a opção entre aderir ao Regime Geral de Previdência Social ou ao Regime Próprio de Previdência Social.

d) os servidores públicos ocupantes exclusivamente de cargo público em comissão devem aposentar-se compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade ou, na forma da lei complementar federal, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade.

e) é inconstitucional, por violação à norma constitucional que permite a livre nomeação pelo administrador público, norma estadual que estabeleça requisito de formação, em curso de nível superior, para o preenchimento de cargo em comissão.

Comentários

1) Gabarito: Letra A.

a) Correta.

Art.37, V, CRFB - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

b) Incorreta.

Art. 40, §13, CRFB- Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.

c) Incorreta.

Art. 40, §13, CRFB - Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.

d) Incorreta.

Art. 40, §1º, II, CRFB - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar.

e) Incorreta.

Art. 37, V, CRFB. Art.37, V, CRFB- as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

2) Gabarito: letra A. Conforme o inciso V do art. 37 da CF/88. Art. 37....

....

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de



carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

b) Errado. Os requisitos e atribuições do cargo só podem ser definidos em lei, nunca em ato administrativo ou edital (art. 37, I, CF):

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Nesse sentido, o Supremo editou as seguintes súmulas vinculantes:

Súmula Vinculante 14/STF: Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público

Súmula Vinculante 44/STF: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

c) Errado. Em relação ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, o § 13 do art. 37 da CF estabelece o Regime Geral de Previdência Social:

Art. 37.....

....

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.

Já o § 20 do mesmo artigo veda a existência de mais de um regime próprio em cada ente da Federação:

Art. 37....

.....

§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X.

d) Errado. Essa regra aplica-se somente aos servidores de cargo público efetivo (art. 40, § 1º, II, CF):

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;

e) Errado. A norma estadual (lei) pode estabelecer os requisitos necessários ao preenchimento dos cargos em comissão ou efetivos. Além disso, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei (art. 37, I, CF).



CAPÍTULO 17 – ORGANIZAÇÃO DO PODER

Existe uma crítica de parcela da doutrina sobre o porquê da tripartição, eis que o poder é uno, mas as funções são divisíveis.

A separação de poderes, tratada por Montesquieu, foi iniciada por Aristóteles (“A Política”), o qual dizia que só existe o poder de julgar, um poder de executar as leis e o poder de criar as leis. No entanto, Aristóteles não dizia que o poder deveria ser separado.

Quem efetivamente separou os poderes foi Montesquieu, por meio da obra “O Espírito das Leis”. Ele dizia que a separação deveria ser rígida, eis que quem detém o poder tende a abusar dele.

Ocorre que, mesmo com a separação dos poderes, o legislador abusou do poder de legislar, o julgador abusou do poder de julgar e a administração abusou do exercício da sua função.

Percebeu-se que esta separação de poderes não era mais sustentável, devendo ser mantida a separação dos poderes, porém com mais flexibilidade. Isto é, os poderes devem ser independentes, mas harmônicos entre si.

1. FUNÇÕES

A partir daí, os poderes não exercem mais apenas as suas funções típicas, passando a exercer também funções atípicas, pois em tese seriam próprias de outro poder.

Com isso, surgiu a teoria dos freios e contrapesos, pois, neste caso, há um controle recíproco entre os poderes. Quem julga, é o senado quando o presidente comete crime de responsabilidade, apesar dessa função ser típica do Judiciário. O pedido de impeachment é apreciado pela Câmara, mas quem julga é o Senado, com a presidência do STF.

É exemplo do sistema de freios e contrapesos quando o Poder legislativo elabora leis, mas se o Poder Executivo entender que esta lei não está de acordo com a CF, poderá vetar juridicamente o veto. Se houver a aprovação, o Poder Judiciário poderá julgar a lei como nula. É um controle recíproco entre os poderes.

2. PODER LEGISLATIVO

O Poder Legislativo terá sempre as funções típicas e as funções atípicas. A **função típica** do Legislativo é legislar, mas também de fiscalizar. Ou seja, as funções típicas do poder legislativo são legislar e fiscalizar. Em relação à função típica de legislar, por exemplo, o art. 49, IX e XX tratam de matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional (envolvem prestação de contas) e o art. 58, §3º, exemplificando a função típica fiscalizatória com as Comissões Parlamentares de Inquérito.

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

(...)

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.



(...)

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

As **funções atípicas**, que são funções não tradicionais que o legislativo irá exercer por determinação constitucional. O poder legislativo vai exercer funções administrativas (típica do poder executivo) e judiciais (típica do poder judiciário) por dicção constitucional.

Funções atípicas administrativas do poder legislativo podem se exemplificar nos artigos 51, IV e art. 52, XIII, CF.

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

(...)

IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

(...)

XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

Em relação à função atípica de legislar, exemplo é o artigo 52, I e II, CF. Os senadores estarão atuando como verdadeiros juízes, julgando os arrolados nos incisos I e II pela eventual prática de crime de responsabilidade.

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

I – processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza **conexos** com aqueles;

II – processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;

2.1. COMPOSIÇÃO

No sistema federativo brasileiro, o poder legislativo é bicameral, constituindo-se de duas casas.

A Câmara dos Deputados e o Senado que compõem o Congresso Nacional.

A ideia do bicameralismo é ligada ao fato de haver a forma federativa de estado. Segundo a teoria federalista, todos os entes devem participar da vontade nacional. Por isso, o município é anômalo, visto que ele não participa.

O Estado participa através do Senado Federal, o qual é responsável pela representação dos Estados. Por isso que o Acre possui 3 senadores São Paulo também. Portanto, há uma representação paritária do estado-membro no Congresso.



A Câmara dos Deputados é a representação do povo, razão pela qual se deve ser proporcional à população do Estado. Diante disso, há uma representação proporcional aos habitantes.

No âmbito estadual, o Poder Legislativo é unicameral, sendo a Assembleia Legislativa o órgão responsável. No âmbito municipal, também é unicameral, por meio das Câmaras Municipais.

2.1.1. CONGRESSO NACIONAL

O CN se manifesta por meio de suas duas casas legislativas, de maneira separada.

a) Sessões conjuntas

Há situações em que a CF exige o trabalho simultâneo e o conjunto do Congresso, recebendo o nome de sessões conjuntas. Na sessão conjunta, as casas atuam ao mesmo tempo, mas o sistema não deixa de ser bicameral, ou seja, a contagem de votos é em separado.

Por exemplo, a CF exige sessão conjunta para conhecer o veto, sendo necessário a maioria absoluta. Ou seja, se há 513 deputados federais e 81 senadores federais, significa que há 594 parlamentares. Por isso, se 513 deputados federais votam pela derrubada do veto, ou seja, sua totalidade, mas 40 senadores votam pela derrubada do veto, o veto é mantido, pois é preciso que haja maioria absoluta em cada uma das casas, contadas em separado.

O art. 57, 3º, estabelece que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:

- inaugurar a sessão legislativa;
- elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;
- receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República;
- conhecer do veto e sobre ele deliberar.

b) Sessões unicamerais

Além da sessão conjunta, a CF prevê a hipótese de sessão unicameral, a qual já foi exaurida, pelo processo de revisão constitucional.

Na sessão unicameral, há uma Câmara só. Ou seja, há uma sessão único com senadores e deputados, mas só há uma Casa legislativa a ser considerada. Portanto, se há 594 senadores e deputados, será considerado a maioria absoluta sobre este número.

2.1.2. CÂMARA DOS DEPUTADOS

Com relação à Câmara dos Deputados, é composta pelos representantes do povo, por meio do sistema proporcional, sendo o mandato de 4 anos, admitidas sucessivas eleições.

A CF atribuiu à lei complementar fixar o número de deputados, não podendo delegar ao TSE, pois isto violaria a Constituição.

A CF estabelece o mínimo de 8 e o máximo de 70 deputados federais por Estado. Estes números são estabelecidos de acordo com a lei complementar federal.

O número de deputados estaduais corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Atingido o número de 36 deputados federais, será acrescido tantos quantos forem os deputados federais acima de doze. Por exemplo, um Estado tem 29 deputados federais. O número de deputados estaduais será de igual aos 12 primeiros deputados federais multiplicados pelo triplo, totalizando-se 36. Os outros 17 deputados federais serão somados, atingindo o montante de 53 deputados estaduais.

Com relação aos territórios federais, este número é fixo, devendo ser 4 deputados federais.



Segundo o STF, se o parlamentar foi eleito por uma coligação, deve-se considerar o segundo mais bem votado da coligação, caso o deputado saia do cargo. No caso de coligação, a vaga pertence a ela, e não ao partido.

2.1.3. SENADO FEDERAL

Em relação ao Senado, este é composto pelos representantes dos Estados e do DF.

O número é fixo de 3 senadores, os quais possuem mandato de 8 anos, renovados a cada 4 anos.

Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário simples, o que significa dizer que vencerá o mais bem votado, que se dará em um único turno.

Ademais, segundo o STF, não se aplica aos senadores a perda do mandato por infidelidade partidária, eis que o sistema é o majoritário. Do contrário, haveria violação à soberania popular.

2.2. ÓRGÃOS

2.2.1. MESAS DIRETORAS

São órgãos de diretorias da casa legislativa, tendo a função de exercer as funções administrativas e conduzir os trabalhos legislativos.

Há mesa na câmara, senado e congresso nacional. As mesas diretoras são presididas pelos seus respectivos presidentes da câmara e do senado.

A mesa do CN é presidida pelo presidente do senado. Os demais cargos são exercidos alternadamente pelos ocupantes equivalentes na Câmara e no Senado. O 1º Vice presidente do CN é o 1º vice da Câmara. O 2º Vice presidente do CN é o 2º vice do Senado.

Os membros da mesa cumprem mandato de 2 anos, vedado a recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura (4 anos). Por exemplo, o presidente da câmara não poderá ser na próxima eleição, mas poderá ser candidato a vice-presidência.

Esta norma não é de reprodução obrigatória para os estados membros, razão pela qual poderão reconduzir para o mesmo cargo na legislatura subsequente.

2.2.2. COMISSÕES

As comissões são órgãos instituídos com a finalidade de facilitar o trabalho do Plenário.

Elas estudam e examinam proposições legislativas, bem como emitem pareceres.

O art. 58, §2º, estabelece as atribuições das comissões parlamentares:

- discutir e votar projeto de lei que dispensar a competência do Plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa: é possível que a comissão vote e aprove um projeto de lei que não exija que o Plenário delibere a respeito. Por isso, a comissão deve ter representação proporcional dos partidos políticos;
- realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
- convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;
- receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
- solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
- apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

As comissões podem ter caráter permanente ou caráter temporário. Um exemplo de comissão permanente é a Comissão de Constituição e Justiça.

Segundo o STF, é inconstitucional preceito da Constituição do Estado que submete o relatório de impacto ambiental (RIMA) ao crivo de comissão permanente e específica da



Assembleia Legislativa. A concessão de autorização para desenvolvimento de atividade potencialmente danosa ao meio ambiente consubstancia ato do poder de polícia (ato da administração pública), de atribuição do Poder Executivo.

As comissões temporárias são criadas para apreciar determinado assunto, extinguindo-se com o término da legislatura, alcançando a finalidade que se destinavam ou expirado o prazo. As comissões representativas são exemplos de caráter temporário, assim como a CPI e a comissão mista representativa do CN.

A sessão legislativa (anual) é dividida em dois períodos: do dia 02.02 ao dia 17.07 e do dia 01.08 ao dia 22.12. No período de recesso, que fica entre esses períodos, há a comissão mista representativa do CN. A ideia é representar o congresso para garantir suas prerrogativas. Essa comissão guardará proporcionalidade à sua representação. Essa comissão será eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum.

Lembrando que sessão ordinária é o lapso temporal diário. Corresponde ao dia no poder legislativo em que temos as discussões e principais deliberações. Enquanto sessões extraordinárias são aquelas que ocorrem em dia ou hora diferentes das sessões ordinárias dentro do período legislativo.

Na Câmara dos Deputados temos o pequeno expediente (60 minutos) e o grande expediente (50 minutos) e ordem do dia (3 horas).

No Senado, temos o período do expediente (120 minutos) e ordem do dia (150 minutos).

Para instaurar a ordem do dia é necessário a presença do quórum mínimo, de maioria absoluta. Para instaurar a ordem do dia na Câmara é necessária a presença de 257 dos 513 deputados, ou ao menos o seu nome no painel.

No Senado, para instaurar a ordem do dia, é necessária a presença de 41 senadores (maioria absoluta), ainda que seja para aprovar projeto de lei de maioria simples.

a) Comissão Mista

Composta por Deputados e Senadores.

b) Comissão Representativa

Aquela comissão que representa o Congresso Nacional no período de recesso, composta exclusivamente por deputados e senadores.

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.

(...)

§ 4º Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

c) Comissões parlamentares de inquérito (CPI)

As CPI's são comissões temporárias, tendo a finalidade de investigar um fato determinado, o qual deve ser de interesse público.

O quórum para instaurar uma CPI é de 1/3 de deputados (171 deputados), 1/3 de senadores (27 senadores) ou 1/3 dos membros do Congresso Nacional (198 membros, pelo menos). A CPI pode ser só de deputados, só de senadores ou mista, com membros das duas casas.

O STF entende que CPI são direito público subjetivo das minorias (1/3 é minoria), ou seja, a maioria não pode impedir e nem prejudicar a instauração ou a tramitação de CPI já



instaurada. O remédio constitucional caso ocorra o impedimento de intauração de uma CPI pela é o Mandado de Segurança.

Segundo o STF, além da função contramajoritária fiscalizatória do Poder Executivo, incumbe às CPI's instrumentalizar a atividade legiferante do Parlamento, a avaliação da conveniência de alocação de recursos e de financiamento de políticas públicas, etc. Nesse cenário, é natural que se confira às CPI's ampla autonomia para o exercício do relevante múnus.

O art. 58, §3º, estabelece que as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (não pode atuar em casos de cláusula de reserva de jurisdição), além disso, serão criadas mediante requerimento de 1/3 de seus membros da Casa respectiva, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Todas as decisões da CPI devem se dar por maioria dos membros da CPI, em razão do princípio da colegialidade.

A comissão deve investigar um fato determinado, isto significa que não pode ter por objeto algo genérico e inespecífico, sob pena de inconstitucionalidade.

A CPI deve indicar o fato determinado objeto da investigação, mas não impede a apuração de outros fatos conexos a ele, ou ainda, não impede a apuração de outros fatos inicialmente desconhecidos (encontro fortuito de provas). Para tanto, é indispensável que haja um aditamento do objeto inicial da CPI.

Se a CPI é temporária, deverá ter um prazo certo, podendo, segundo o STF, haver prorrogações, as quais deverão no máximo o fim de legislatura.

Para o STF é constitucional regra de regimento interno da Câmara dos Deputados que estabelece limite quantitativo para a criação simultânea de CPIs.

Cumpridos estes requisitos, é determinada a sua criação no mesmo ato de apresentação do requerimento ao presidente da câmara. A instauração da CPI se dá com a apresentação do requerimento.

Compete ao STF processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado em face das CPIs do Congresso Nacional e de suas casas, muito embora não haja previsão constitucional para tanto. Todavia, segundo o STF, o mandado de segurança não é meio hábil para questionar relatório parcial de CPI, cujo trabalho, presente o § 3º do artigo 58 da Constituição Federal, deve ser conclusivo.

No âmbito estadual, é possível a instauração de CPI's, em razão do princípio da simetria. No caso da Assembleia Legislativa, também terá os mesmos poderes da autoridade judicial.

No caso do município, a câmara de vereadores poderá investigar por meio da CPI, porém não terá poderes próprios de autoridade judiciária, pois não há justiça municipal.

Segundo o STF, a menção de poderes de investigação próprio de autoridade judicial da CPI são os poderes que o juiz é dotado na fase de instrução processual (ouvir testemunhas e réu, determinar perícia, quebrar sigilos, dentre outros), conhecido como amplitude de uma CPI, o que ela pode diretamente fazer sem que haja necessidade de autorização judicial.

Conforme o STF, as CPI podem quebrar (sem necessidade de autorização judicial) os sigilos bancários, fiscal e de dados dos investigados (inclusive os telefônicos). Pode também determinar algumas perícias (outras podem ser que seja necessária autorização judicial). Podem ouvir testemunhas e investigados, sempre respeitando o direito constitucional ao silêncio e podem determinar buscas e apreensões genéricas (que não são domiciliares).

No entanto, existem impedimentos, ou seja, determinadas situações em que a CPI não pode, diretamente, investigar. As CPI não são dotadas de poder geral de cautela (aquele poder de garantir a eficácia de uma eventual sentença condenatória), que são exclusivas do



magistrado. Por isso, por exemplo, a CPI não pode determinar prisão, com exceção da prisão em flagrante.

A CPI federal não alcança fatos específicos dos Estados, DF ou municípios. Não se pode instaurar CPI no ente federal para investigar os fatos ocasionados no estado de Sergipe, pois, do contrário, haveria violação de poderes.

Da mesma forma, fatos de interesse exclusivamente privado não podem ser investigados pela CPI. Essa noção de presença de interesse público ficou bastante clara quando do estudo das pessoas que podem ser investigadas pelas CPI's.

Os atos da CPI não alcançam atos de natureza jurisdicional. Ou seja, não pode a CPI intimar o magistrado para que explique a decisão de caráter jurisdicional, pois violaria a separação dos poderes.

A CF permite que as CPI's investiguem fatos ligados à população indígena, podendo inclusive interrogá-los, porém o índio somente poderá ser ouvido no âmbito da área indígena, com dia e hora previamente marcado, além de haver um representante da FUNAI e de um antropólogo com conhecimento da comunidade.

CPI não pode determinar arresto, sequestro, impedimento, de bens de investigados justamente pela falta do poder geral de cautela. Não podem também impedir a atuação advogado, nem em sessões secretas, pois a lei 10.679/13 diz que os advogados poderão acompanhar seus clientes mesmo em sessões secretas³⁰.

Lei. 1.579/52 com alteração dada pela lei 10.679/13.

Art. 3º. Indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal.

(...)

§ 2º O depoente poderá fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reunião secreta.

CPI também não podem impedir a saída de indivíduos do país ou de comarcas. A CPI também não podem realizar atividades que envolvam as chamadas Cláusulas de Reservas Jurisdicional (CRJ), ou seja, são cláusulas previstas na constituição reservadas apenas ao poder judiciário. Portanto, a CPI não pode determinar busca e apreensão domiciliar e nem interceptações telefônicas (art. 5º, XI e XII, CF).

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Cuidado para não confundir dado telefônico com interceptação telefônica (lei 9.216/96).

As decisões da CPI devem ser fundamentadas (princípio da fundamentalidade), sob pena de nulidade das decisões, nos termos do art. 93, IX, CF.

³⁰ A Lei 10.679/13 alterou o art. 3º, §2º da Lei 1.579/52, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito.



Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

O Min. Marco Aurélio já se manifestou no sentido de que essa fundamentação não é rígida ou rigorosa, como é exigida de um magistrado, mas necessita de fundamentação nos mesmos termos do poder judiciário.

As decisões da CPI também devem ser tomadas por colegiado e maioria de votos (princípio da colegialidade).

Devem respeito ao princípio federativo ou pacto federativo, ou seja, CPI nacional investiga questões nacionais, CPI estadual, questões estaduais e CPI municipal, questões municipais. Uma não poderá invadir a outra.

A CPI devem guardar um nexo causal com a gestão da coisa pública, ou seja, qualquer procedimento investigativo da CPI tem que guardar relação com a coisa pública, tem que envolver bens, serviço ou interesse da união e da sociedade como um todo.

O STF já decidiu (por 6 votos a 5, em 2004), que CPI estadual pode quebrar o sigilo bancário de seus investigados diretamente, sem precisar requerer ao poder judiciário. Foi aplicado aqui o princípio da simetria.

As leis 10.001/00 e 13.367/16 (modifica a lei 1.579/52), são legislações importantes.

A lei 13.367/16 diz que os relatórios da CPI serão encaminhados não só ao Ministério Público como também para a Advocacia Geral da União, enquanto a constituição só menciona que os relatórios devem ser encaminhados ao Ministério Público.

A lei 10.001/00 irá estabelecer a prioridade nos procedimentos posteriores à aprovação do relatório de uma CPI, para impedir que uma CPI “acabe em pizza”.

Lei 10.001/00

Art. 1º. Os Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional encaminharão o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito respectiva, e a resolução que o aprovar aos chefes do Ministério Público da União ou dos Estados, ou ainda às autoridades administrativas ou judiciais com poder de decisão, conforme o caso, para a prática de atos de sua competência.

E depois de 2006, se encaminha o relatório inclusive para a AGU.

Art. 2º. A autoridade a quem for encaminhada a resolução informará ao remetente no prazo de trinta dias, as providências adotadas ou a justificativa pela omissão.

Assim que o Ministério Público recebe o relatório de uma CPI, terá trinta dias para tomar providências ou justificar porquê não o fez.

Art. 2º (...)

Parágrafo único. A autoridade que presidir processo ou procedimento, administrativo ou judicial, instaurado em decorrência de conclusões de Comissão Parlamentar de Inquérito, comunicará, semestralmente, a fase em que se encontra, até a sua conclusão.

Se o MP recebe relatório de uma CPI, dá andamento, oferece denúncia contra determinadas pessoas, o judiciário recebe as denúncias e se inicia o processo penal, o MP tem, semestralmente, que enviar um relatório relatando o que ocorre nesse processo penal



(derivado de uma CPI) para a Câmara, Senado e Congresso Nacional. Isso no âmbito judicial e também processo administrativo.

Ações judiciais derivadas de CPI terão prioridade sobre outras ações, exceto sobre o Habeas Corpus, Habeas Data e Mandado de Segurança.

Art. 3º. O processo ou procedimento referido no art. 2º terá prioridade sobre qualquer outro, exceto sobre aquele relativo a pedido de habeas corpus, habeas data e mandado de segurança

Art. 4º. O descumprimento das normas desta Lei sujeita a autoridade a sanções administrativas, civis e penais.

Se membro do MP ou da AGU (ou outras autoridades) descumprir as normas da lei 10.001/00 estarão sujeitos à sanção administrativa, cível e penal.

d) Direitos do depoente

As CPI's podem convocar e inquirir pessoas, podendo inclusive determinar a condução coercitiva de testemunha.

O interrogado tem o direito de permanecer calado, conforme art. 5º, LXIII.

A condição de testemunha não afasta o direito de ficar calado sempre que a resposta, de alguma forma, significar autoincriminação.

O sujeito pode ser convocado e poderá ser um advogado. Neste caso, é possível que o advogado invoque o direito profissional de sigilo. No entanto, poderá invocar o sigilo profissional, mas não poderá se furtar de comparecer perante a comissão. Caso não viole o sigilo profissional, deverá responder.

A CPI possui um cunho inquisitivo, razão pela qual não se assegura o contraditório e ampla defesa, sendo garantido estes direitos somente no processo.

A CPI pode determinar busca e apreensão, desde que não se constitua em violação de domicílio. Isso porque o STF entende que é caso de cláusula de reserva.

A CPI pode determinar a quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico do investigado. Não se confunde com a interceptação telefônica.

Todas as decisões proferidas pelas CPI's, devem ser fundamentadas. Elas só se mostram razoáveis quando forem imprescindíveis à investigação, bem como limitado no tempo. A maioria absoluta é quem decide o caminho da CPI, com base no princípio.

São exemplos de cláusulas de reserva de jurisdição:

- as CPI's não podem determinar prisão, salvo a em flagrante
- CPI não pode determinar medida cautelar de natureza penal ou civil
- CPI não pode determinar busca e apreensão que resulte em violação de domicílio
- CPI não pode determinar a anulação de ato do Poder Executivo
- CPI não pode determinar a quebra de sigilo judicial

A função da CPI se esgota no relatório final de investigação, o qual deverá ser enviado ao MP para tratar do assunto.

2.2.3. PLENÁRIO

O plenário é o órgão máximo de deliberação das casas legislativas, sendo composto por todos os parlamentares.

V.Reuniões

A CF estabelece que o CN se reúne anualmente, em Brasília, do dia 02.02 a 17.07 e do dia 01.08 a 22.12. Esta é a sessão legislativa ordinária. Cada sessão possui dois períodos legislativos.

Não se confunde com a legislatura que tem o período de 4 anos.



A sessão legislativa não será interrompida enquanto não houver a aprovação de projeto de lei de diretrizes orçamentárias (LDO). É preciso que a LDO seja remetida para sanção do presidente da república até o fim do 1º período da sessão legislativa.

Durante o período de recesso, a CF prevê a hipótese de convocações extraordinárias do CN, podendo ser convocado por:

- Presidente do Senado
- Presidente da República
- Presidente da Câmara
- Requerimento da maioria dos membros das Casas Legislativas

O presidente do Senado, no período de recesso, convocará sessão legislativa extraordinária em casos de:

- estado de defesa
- intervenção federal
- pedido de autorização para decretação de estado de sítio

Os demais, inclusive o presidente do senado, podem, em caso de urgência ou de interesse público, fazer esta convocação.

A CF estabelece que a sessão legislativa extraordinária se restringirá à matéria que justificou a sua convocação. A própria CF diz que, se houver esta sessão legislativa extraordinária, incluirão na pauta as medidas provisórias em vigor, a fim de que o CN delibere a respeito delas.

Até a EC 50/06 não era vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão de convocação extraordinária superior ao subsídio mensal. Atualmente não se paga qualquer valor a título de parcela indenizatória em razão de convocação extraordinária.

Pode haver mais de uma convocação extraordinária por recesso desde que os requisitos sejam preenchidos.

2.3. ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL

A CF vai, via de regra, trazer um rol exemplificativo daquilo que seja atribuição do congresso nacional nos arts. 48 e 49.

Segundo o art. 48, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Se depende da sanção do presidente, só poderá dispor, nestes casos, por meio de lei, especialmente sobre:

- sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
- plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
- fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
- planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
- limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União;
- incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;
- transferência temporária da sede do Governo Federal;
- concessão de anistia;
- organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal;
- criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b;
- criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública;



- telecomunicações e radiodifusão;
- matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações;
- moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
- fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I.

Já o art. 49 estabelece que é da competência exclusiva do Congresso Nacional:

- resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
- autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;
- autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a 15 dias;
- aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;
- sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
- mudar temporariamente sua sede;
- fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
- fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
- julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
- fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
- zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;
- apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
- escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União (nomeados pelo Presidente)
- aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;
- autorizar referendo e convocar plebiscito;
- autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
- aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares.

Não havendo que passar pelo Presidente da República, as matérias do art. 49 serão tratadas por meio de decreto legislativo.

Subsídio de Deputados, Senadores, Ministros de Estado, Presidente e Vice-Presidente da República não é fixado por meio de lei, e sim por decreto legislativo.

É da competência exclusiva do CN julgar as contas prestadas pelo presidente da república. O TCU apresenta um parecer, mas quem julga é o CN.



É o CN que autoriza referendo e convoca plebiscito. São consultas populares, sendo o plebiscito antes da elaboração do projeto de lei, enquanto o referendo é uma consulta popular posterior ao ato.

O CN atua como legislador federal, mas também atua como legislador nacional. Como legislador federal, quando produz normas que atingirão somente o âmbito da União, sem atingir os Estados. Ex.: regime jurídico dos servidores públicos federais.

Mas também atua como legislador nacional quando a norma vinculará todos os Estados membros. Ex.: normas gerais de licitação (Lei 8666/93).

2.4. ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

A CF, em seu art. 51, traz as competências privativas da CD:

- autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;
- proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa;
- elaborar seu regimento interno;
- dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
- eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

Por 2/3 dos membros, autoriza-se a instauração do processo, mas isto não obriga ao Senado instaurar.

Cabe atentar que à Câmara compete tomar as contas do Presidente da República, quando não houver apresentação ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa.

A competência privativa da Câmara se dá por meio de resolução.

O STF decidiu que essa necessidade de 2/3 da Câmara para que haja a instauração de processo contra o ministro de Estado está restrita às hipóteses em que o ministro de estado é denunciado em crime de responsabilidade conexo com o presidente da república.

Após a autorização da Câmara, o processo vai ser analisado pelo Senado Federal, se o crime for de responsabilidade. Sendo uma infração penal comum, irá para o STF.

Recentemente, o STF decidiu que esta autorização prévia da Câmara não obriga a instauração de processo pelo órgão julgador, mas apenas autoriza que o Senado instaure o processo.

O Presidente da República não possui direito à defesa prévia antes da análise de recebimento ou não da denúncia pelo presidente da câmara, contudo, após esse momento, poderá exercer seu direito de defesa tanto na Câmara, quanto no Senado.

Observa-se que estas regras também se aplicam ao processo criminal comum contra o Presidente. Isso porque se a Câmara autorizou, o STF não está obrigado a receber a denúncia.

O Senado exercerá dois juízos, um juízo de admissibilidade, eis que ele não está obrigado a instaurá-lo, e, caso instaure, promoverá um juízo de mérito, propriamente dito. Cabe ressaltar que, para o juízo de admissibilidade, basta que o Senado vote por maioria simples.

Caso o juízo de admissibilidade do Senado seja positivo, haverá o afastamento do presidente da república pelo prazo de 180 dias.

Para que haja a condenação no juízo de mérito pelo Senado, sob a presidência do presidente do STF, será necessário o voto de 2/3 dos membros do Senado.



2.5. ATRIBUIÇÕES SENADO FEDERAL

De acordo com o art. 52, compete privativamente ao senado federal:

- processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;
- processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;
- aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:
 - a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;
 - b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;
 - c) Governador de Território;
 - d) Presidente e diretores do banco central;
 - e) Procurador-Geral da República;
 - f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
- aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;
- autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
- fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;
- dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno;
- estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;
- aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;
- elaborar seu regimento interno;
- dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
- eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.
- avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

Com base no inciso II, o ministro do STF poderá sofrer impeachment, assim como os membros do CNJ e do CNMP, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, além do Presidente e o Vice-Presidente da República.



No tocante ao inciso X, Gilmar Mendes entende que houve mutação constitucional. Este dispositivo, originariamente, prevê que se o STF, em controle concreto (incidental), diz que uma norma é inconstitucional, poderá o Senado simplesmente suspender a lei. É uma decisão discricionária. Todavia, Gilmar Mendes afirma que a norma constitucional é outra, entendendo que se o STF reconheceu a inconstitucionalidade de uma norma, não será necessário que o Senado Federal suspenda a execução da lei, ainda que tenha se dado por controle difuso. Trata-se de uma abstrativização do controle difuso. Ou seja, esta suspensão da execução serve apenas para fins de publicidade. Esta posição, no entanto, é minoritária.

Chamemos a atenção do parágrafo único do art. 52. Este dispositivo diz que, nos casos de impeachment, o Presidente do Supremo Tribunal Federal funcionará como presidente da sessão de julgamento. Esta condenação somente é possível por 2/3 dos votos do Senado Federal, razão pela qual haverá as seguintes consequências:

- perda do cargo
- inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública

Isto justifica a razão pela qual a renúncia permite o julgamento do processo. Como há duas punições, uma de perda do cargo e outra a inabilitação por 8 anos, a renúncia somente inviabiliza a perda do cargo, mas não impede que haja a pena de inabilitação.

O senado disciplina as matérias por meio de resolução.

O Senado, no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, decidiu que são separáveis as punições de perda do cargo e da inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública. Dessa forma, ficou decidido que a ex-presidente apenas perdesse o cargo, não havendo a aplicação de qualquer inabilitação para o exercício da função pública.

2.6. ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS

Esta expressão advém ao conjunto de regras que está no art. 53, 54, 55 e 56 da CF.

A CF estabelece um conjunto de prerrogativas e vedações aos parlamentares. Não se tratam de privilégios, pois visa garantir a independência do parlamentar para o livre exercício da função. Por este motivo as imunidades são irrenunciáveis.

2.6.1. IMUNIDADES

A finalidade das imunidades parlamentares é a garantia da independência do poder legislativo frente aos outros poderes e à sociedade para que exerçam as suas funções típicas e atípicas de forma adequada.

As imunidades podem ser classificadas em:

- imunidades materiais
- imunidades formais (processual)

a) Imunidades materiais

As imunidades materiais estão previstas no art. 53, estabelecendo que os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

Essa inviolabilidade deve ter uma pertinência com o exercício da função.

A imunidade é ultrativa, pois mesmo depois de extinguir o mandato não poderá responder por aquilo.

É preciso que as opiniões, palavras e votos estejam relacionadas com o exercício do mandato. Podem ser proferidas em qualquer lugar. Se essas opiniões, palavras e votos se der dentro do parlamento, haverá uma presunção absoluta que haja pertinência com o desempenho da função, qualquer que seja o conteúdo.

Cabe ressaltar que se o parlamentar proferir essas opiniões, palavras e votos em excesso, ainda que dentro da casa legislativa, poderá sofrer punições disciplinares da própria casa, de acordo com o seu regimento interno.



A imunidade material é adquirida a partir da diplomação. O parlamentar suplente não possui imunidade material.

A diplomação é o atestado de que o sujeito foi regularmente eleito.

A imunidade material independe do logradouro de proferimento, desde que guarda relação com o mandato. Porém, existe uma exceção: vereador. O vereador só possui imunidade parlamentar na circunscrição do município.

Art. 29 (...)

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município;

Os deputados federais, estaduais e distritais possuem imunidade parlamentar material independente do local de proferimento, os vereadores não.

A imunidade material é de ordem pública, não tendo como renunciar a ela. A imunidade material também não se estende aos assessores.

b) Imunidades formais

A CF protege o parlamentar contra a prisão nos crimes cometidos após a diplomação:

- imunidade contra a prisão, pois só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável
- nos crimes após a diplomação, é possível a sustação do processo penal instaurado pelos STF

O art. 53, §2º diz que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. No caso do Delcídio do Amaral, o STF entendeu que estaria em crime permanente, admitindo a prisão em flagrante, além de não admitir fiança, razão pela qual o considerou inafiançável. Diante disso, o STF decretou a prisão.

Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Casa respectiva, para que a maioria de seus membros vote, resolvendo sobre a prisão. O diploma é anterior à posse, sendo apenas um atestado de que o sujeito foi regularmente eleito.

Atenção a isso nas provas, porque não é desde a posse, mas sim no momento anterior, ou seja, desde a expedição do diploma.

Porém, existem duas exceções: a primeira delas está prevista na própria constituição de forma expressa no art. 53, §2º, onde diz “salvo em flagrante de crime inafiançável”. O voto dos parlamentares, feita em maioria absoluta, que decide pela prisão, é uma votação aberta e não secreta.

A segunda exceção não está prevista constitucionalmente, mas foi construída jurisprudencialmente pelo STF, que será no caso de uma condenação criminal transitada em julgado. O precedente é o caso Natan Donadon (AP 396), que foi condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão. À época que o processo transitou em julgado, Natan Donadon havia sido reeleito.

- O informativo 437 do STF envolveu o HC 89417, onde o STF relativizou o art. 53, §2º, CF. Foi o caso de uma operação da Polícia Federal (Operação Dominó), que prendeu em flagrante pela prática de crimes inafiançáveis, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia. Mas os autos da prisão em flagrante não foram encaminhados em 24 horas para que a Assembleia Legislativa de Rondonia para que deliberassem se o presidente iria ou não continuar preso.

Então o presidente da Assembleia se insurge contra isso, no STJ e posteriormente no STF no HC 89417, onde reclamava a aplicação da constituição no que se refere à imunidade parlamentar.

No entanto, a Min. Carmen Lucia, relatora, levanta a tese da relativização do art. 53, § 2º, CF, dizendo que, embora essa seja a regra, nesse caso, a Constituição não pode ser



utilizada contra ela mesma. Carmen Lucia vai dizer que se está diante de uma anomalia institucional, ética e jurídica, pois 23 dos 24 parlamentares de Rondônia estão envolvidos no crime organizado

- Informativo 881 STF na ADI 5526, julgado em 11/10/2017. Trata de um debate que existe no STF sobre medidas cautelares diversas da prisão. À essa época aconteceu o uso de medida cautelar diverso da prisão com o senador Aécio Neves. O STF aplicou a normatividade do art. 319, VI, (afastamento do cargo), V (recolhimento domiciliar noturno), III (proibição de entrar em contato com outros investigados por qualquer meio), IV (proibição de se ausentar do país com a entrega do passaporte) contra o senador Aécio Neves e essas medidas já tinham sido tomadas anteriormente contra Eduardo Cunha.

A grande questão que girou em torno dessa ADI, que tinha como plano de fundo o caso do Aécio, é a seguinte: pode o poder judiciário determinar medidas cautelares diversas da prisão a parlamentares? A segunda questão, também presente no informativo 881, é: o STF, determinando medida cautelar diversa da prisão a parlamentares, a Casa do parlamentar pode deliberar se essa medida cautelar vai permanecer ou não?

O STF decidiu, em 2017 que o poder judiciário pode sim tomar medidas cautelares diversas da prisão a parlamentares. Porém, se essa medida cautelar da prisão impedir, de forma direta ou indireta exercício do mandato, a Casa do parlamentar pode decidir se revoga ou não a medida cautelar diversa da prisão tomada pelo poder judiciário. Ou seja, o STF permite que no caso de medida cautelar diversa da prisão, que venha a impedir, de forma direta ou indireta o exercício do mandato do parlamentar, que seja aplicado por analogia, a norma do art. 53, §2º, CF.

Segundo o STF, é possível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, aos deputados federais e senadores, pois foi com base nisso que o Supremo afastou o ex-deputado Eduardo Cunha de suas funções parlamentares.

Essa imunidade de prisão se refere a crimes praticados inclusive antes da diplomação.

Por exemplo, um sujeito está sendo processado sob atuação do Juiz Sergio Moro. Porém, em outubro foi eleito deputado. Em novembro há a diplomação. O juiz Sergio Moro deverá remeter o processo ao STF. Se cabia prisão preventiva antes, não mais caberá, eis que não está mais em situação de flagrante. Ou seja, mesmo que o crime tenha sido cometido antes, a partir do momento em que é diplomado, neste caso não cabe mais prisão provisória, pois somente é possível em flagrante de crime inafiançável.

A manutenção da prisão é definida pela maioria dos membros da Casa Legislativa. Esta votação é por votação ostensiva e nominal.

Além da imunidade formal em relação à prisão, temos também a imunidade em relação ao processo. Está no art. 53, §3º, CF.

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

(...)

§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.

O §3º estabelece que, recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva. E aí, por iniciativa de partido político nela representado, a maioria de seus membros poderá sustar o andamento da ação até a decisão final.

Ou seja, se o STF receber a denúncia por crime ocorrido antes da diplomação, poderá receber a denúncia e seguir o trâmite processual.



O partido político, com representação, é quem fará o pedido de sustação.

O pedido de sustação deve ser apreciado de no máximo 45 dias. Se houver a deliberação para suspender o processo, haverá também a suspensão da prescrição.

Na hipótese de crime praticado por parlamentar em concurso de pessoas com indivíduo não tenha foro por prerrogativa de função perante o STF, poderá haver a atração da competência para a Corte Suprema. Neste caso, poderá o STF julgar o corréu, mesmo que não tenha prerrogativa de função. Esta medida não viola a CF. Todavia, o STF pode dizer que o processo deve ser separado, mas a análise cabe ao próprio Tribunal, a depender do motivo. Ex.: a decisão do Min. Teori Zavascki determinou o encaminhamento dos autos que estariam nas mãos do Juiz Sérgio Moro.

Supondo que a Casa delibere pela sustação do processo que se trate de concurso de pessoas entre um réu parlamentar e outro sem foro por prerrogativa de função. Neste caso, ocorre a separação do processo, devendo o Tribunal superior mandar o processo do corréu sem esta prerrogativa para as instâncias ordinárias. Isso porque a imunidade processual se refere apenas ao parlamentar.

Essa imunidade formal em relação ao processo se modificou muito no decorrer dos anos. Por 13 anos, de 1988 a 2001, era um tipo; de dezembro de 2001 em diante passou a ser de outro tipo. A EC 35/2001 a modificou. Na imunidade em relação ao processo, antes da EC 35/2001, existia a necessidade de autorização da Casa para que o STF pudesse iniciar a ação penal contra parlamentar, se fosse senador, o Senado e, se fosse deputado, a Câmara. Isso gerava muita impunidade. O caso do deputado federal do Acre, Hildebrando Pascoal, conhecido como deputado serra elétrica, foi o caso marcante para que acabasse com a necessidade de haver autorização para que pudesse dar início à ação penal contra parlamentar.

Hoje, a imunidade parlamentar em relação ao processo é a mera possibilidade de sustação de ação contra parlamentar em virtude da prática de crime após a diplomação.

Procedimento: denúncia feita pelo Procurador Geral da República (ação penal pública) ou queixa crime feita pelo ofendido (ação penal privada), para o STF.

Para que seja processado penalmente pelo STF pela prática de um crime comum, tem que praticar o crime no exercício do mandato e guardar relação com este. Isso desde a Ação Penal 937/QO julgada em maio de 2018 pelo STF, à luz do Informativo 900 do STF.

O STF, então, recebe a denúncia ou a queixa crime e inicia a ação penal e comunica à mesa da respectiva Casa. Aí, um partido político com representação na Casa pode provocar a mesa para que esta coloque em votação um pedido de sustação da ação penal. A mesa não pode colocar em votação de ofício.

Provocada a mesa, inicia-se o prazo de 45 dias para que se coloque em votação.

Art. 53. (...)

§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.

Em seguida a mesa decidirá se susta ou não a ação penal. O quórum para sustação é de maioria absoluta em votação aberta: na Câmara, 257 deputados tem que votar para sustar a ação penal e, no Senado, 41 senadores.

Se sustada essa ação penal, também será suspensa a prescrição.

Art. 53. (...)

§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.

Terminado o mandato, a ação penal volta a tramitar e a prescrição volta a correr.



OBSERVAÇÃO: Informativo 900 na decisão da Ação Penal 937/QO, julgada em maio de 2018. O Min. Barroso vai propor uma reinterpretação do art. 102, I, b³¹, e do art. 53, §1º³², CF. Esses artigos indicam, expressamente, que se o deputado ou senador praticar crime comum, o foro para julgá-los será o STF. O STF vai aplicar a tese da redução teleológica (Karl Larenz), vai interpretar de forma diferente, buscando uma interpretação mais restritiva e finalística para o art. 102, I, b e art 53, § 1º, CF. Alguns autores também chamariam de técnica de dissociação (Riccardo Guastini).

O Min. Barroso defende que o STF deve agir como corte constitucional e não como juiz de primeiro grau, pois acaba gerando impunidade. Barroso defende a tese de que os parlamentares só teriam foro para o exercício de função no STF se o crime for praticado no mandato e for praticado em função do mandato. Foi essa tese que, em maio de 2018, fez a maioria dos ministros concordar.

Ou seja, a partir do Informativo 900 e da Ação Penal 937/QO, o STF, usando de uma técnica de redução teleológica, interpreta restritivamente os art. 102, I, b e art 53, § 1º, CF para entender que o foro para o exercício de função, pela prática de crime no STF, só se dará se o crime for praticado no exercício do mandato e guardar relação com este.

Se o crime foi praticado antes do início do mandato, não há deslocamento de competência. Se o crime foi praticado depois do início do mandato, mas sem guardar relação com este, não será de competência do STF.

Quando o foro por prerrogativa de função se aplicava para toda prática de crime, independente de relação ou não com o mandato, antes ou depois do mandato, o STF tinha que autorizar o indiciamento. Sem a sua autorização não podia, inclusive o ministro relator acompanhava as investigações. Hoje só prevalece a autorização do STF se o crime que foi praticado guarda relação com o mandato. Mas se o crime foi praticado antes do início do mandato, ou, após o mandato, mas não guarda qualquer relação com este, não há mais necessidade de autorização do STF para investigar.

O marco temporal que define a preservação da competência do STF é o fim da instrução processual. Se ocorreu o fim da instrução processual no STF, mesmo que o indivíduo deixe de ser parlamentar, a ação penal vai continuar no STF e será julgada por este.

c) Foro especial em razão da função

A CF, no art. 53, §1º, estabelece que os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

Neste caso, são alcançadas todas as infrações penais, ainda que se tratem de crimes eleitorais, após a diplomação. Ainda que o ilícito seja anterior à diplomação, a competência será do STF.

O termo final é o término do mandato.

O STF entende que a cessação do exercício da função pública depois que o STF tiver dado início ao julgamento, não significa a cessação da prerrogativa de foro. Este foi o Caso do ex-deputado Donadon.

O STF fixou um termo *ad quem* para o parlamentar renunciar: até antes do início do julgamento.

Samer Agi diz que os suplentes não detêm foro por prerrogativa de função, porém a sinopse diz que se aplica.

³¹ Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;

³² Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. § 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.



d) Afastamento do Poder Legislativo

É possível que o parlamentar se afaste de sua função para assumir o cargo de ministro.

A CF diz no art. 56 que os congressistas não perderão o mandato de quando estiverem investidos no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária, ou ainda quando estiverem licenciados por motivo de doença pela Casa respectiva, ou para tratar de interesse particular, desde que não ultrapasse 120 dias, e seja de modo não remunerado.

O STF decidiu que o congressista afastado de suas funções não dispõem de imunidades, salvo o foro por prerrogativa de função.

O STF entende que o afastamento do congressista não impede a instauração de processo disciplinar perante a respectiva casa. Mesmo fora da casa, deverá respeitar o decoro parlamentar, pois, do contrário, responderá o parlamentar afastado pela quebra de decoro.

e) Desobrigação de testemunhar

A CF diz no art. 53, §6, que os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

Cabe ressaltar que esta imunidade pode ser renunciada, de modo que o parlamentar poderá testemunhar, caso queira.

A imunidade testemunhal é parecida com a imunidade material, que tem por regra que as palavras e opiniões devem guardar relação com o mandato. Existe uma equivalência em relação à imunidade testemunhal, ou seja, também deve guardar relação com o mandato, não sendo obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do mandato.

Ex.: deputado vai assistir ao jogo de futebol no estádio e acaba sendo testemunha ocular de um homicídio. Não guarda qualquer relação com o mandato, tendo que testemunhar e não se falando, nessa hipótese, em imunidade testemunhal.

Além dessa desobrigação, os congressistas têm a prerrogativa de testemunhar no dia, local e na hora previamente agendados entre eles e a autoridade competente. Esta prerrogativa serve para as hipóteses em que o parlamentar seja testemunha ou vítima. Quando for investigado, não há esta prerrogativa.

f) Incorporação às Forças Armadas

O §7 diz que a incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, ainda que sejam militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva. Se a Casa não autorizar e ainda assim o parlamentar quiser de incorporar às Forças Armadas, basta renunciar ao mandato.

- As imunidades parlamentares são irrenunciáveis? Sim. Pode renunciar ao mandato, mas não às imunidades. As imunidades não pertencem ao indivíduo, mas sim do cargo que ele exerce.
- O Deputado Federal que assume cargo de Ministro de Estado carrega consigo as imunidades? Não, porque as imunidades não são do indivíduo, mas sim do cargo que ele exerce.

Não perde o cargo de deputado, será um deputado licenciado no cargo de ministro. Quem assumirá o cargo do deputado é aquele que era suplente e esse suplente terá as imunidades.

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:



I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária;

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela remuneração do mandato

O STF decidiu, no MS 25579/2005, excepcionalmente, que o parlamentar quando assume o cargo de ministro, não carrega o ônus das imunidades, mas carrega o ônus de perder o cargo de deputado por quebra de decoro parlamentar por atos praticados enquanto ministro. Esse é o famoso caso do José Dirceu. José Dirceu era Deputado Federal e foi nomeado Ministro da Casa Civil no governo Lula, mas perdeu o cargo de deputado por quebra de decoro parlamentar por sem nunca ter pisado na Câmara.

- Durante o estado de sítio, as imunidades podem ser suspensas? Sim, mas só podem ser suspensas por 2/3 dos votos das casas respectivas, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Para os atos praticados no congresso nacional, a manutenção das imunidades é absoluta.

2.6.2. INCOMPATIBILIDADES

A ideia de incompatibilidade é evitar o exercício da influência para alcançar favores indevidos.

Segundo o art. 54, os Deputados e Senadores não poderão, desde a expedição do diploma:

- firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;
- aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea anterior;
- Também não podem os Deputados e Senadores, desde a posse:
- ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;
- ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas no inciso I, "a";
- patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, "a";
- ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

2.6.3. PERDA DO MANDATO

A CF trata do tema no art. 55, pois perderá o mandato o Deputado ou Senador:

- infringir as incompatibilidades;



- adotar um procedimento incompatível com o decoro parlamentar;
- não comparecer à terça parte das sessões ordinárias da sessão legislativa, salvo licença ou missão por esta autorizada;
- perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
- quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;
- que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

No caso de infringir incompatibilidades ou quebra de decoro parlamentar, a perda do mandato depende de decisão do Plenário da Casa Legislativa, por maioria absoluta dos membros, com votação aberta e nominal.

A quebra do decoro parlamentar é aferida pela Casa Legislativa, não podendo o Judiciário fazer esta análise de mérito, pois é hipótese de decisão *interna corporis*. Contudo, o poder judiciário, pode sim (e até deve) analisar os **pressupostos de legalidade da medida**. O STF pode apreciar se foi respeitado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Decoro Parlamentar é um conjunto de regras legais e morais que envolvem o exercício de atividade parlamentar, sobretudo no que diz respeito ao abuso de prerrogativas e à percepção de vantagens indevidas. O STF, nos informativos 401 e 406 apresentou um entendimento interessante sobre decoro parlamentar. O STF não tem legitimidade e competência para entrar no mérito da decisão da perda de mandato por decoro parlamentar. É uma questão interna da Câmara para os deputados e do Senado para os Senadores.

No caso de condenação criminal em sentença transitada em julgado, a decisão da perda do mandato também é decidida pela Casa Legislativa.

Nesse caso, há uma discussão se esta condenação criminal já implicaria perda automática do cargo e a casa legislativa apenas declara a perda, ou se depende de decisão da casa legislativa, no sentido de que há ou não a perda do mandato.

O STF, no que diz respeito ao inciso VI do art. 55, que trata sobre a perda de mandato em caso de condenação criminal transitada em julgado, vem adotando duas posições:

→ Uma posição foi desenvolvida no Informativo 863, no julgamento da Ação Penal 694 de 02/05/2017. O STF entendeu, através de uma decisão da 1ª Turma, que no caso de condenação criminal transitada e julgado, não há, de forma imediata, a aplicação do §2º do art. 55. A 1ª Turma do STF, em maio de 2017, vai dizer que depende de que tipo de condenação criminal transitada em julgado se está falando. Se a condenação criminal transitada em julgado for a mais de 120 dias em regime fechado, não se aplicará o §2º do art. 55, pois a perda do mandato será consequência lógica da condenação. E nesse caso, se aplicará o art. 55, § 3º, ou seja, a perda de mandato será declarada pela mesa, em virtude da conjugação do § 3º com o inciso III, do mesmo artigo 55, CF.

O STF repete esse entendimento no Informativo 903, em 2018, na Ação Penal 968, em 22/05/2018. Porém, se a condenação criminal for para um regime aberto ou semiaberto, vai ter como ele ser condenado e participar das sessões legislativas. Nesse caso, a perda de mandato depende da decisão da Casa, por maioria absoluta em votação aberta. Nesse caso, o STF entende que deve ser aplicado o art. 55, §2º, CF, ou seja, a perda de mandato será decidida pela Casa.

→ Porém, a 2ª Turma do STF não pensa do mesmo jeito, pois, no julgamento da Ação Penal 996, no dia 29/05/2018, diz que a condenação criminal transitada em julgado, a perda do mandato não é automática por declaração da mesa. Aqui não depende se a condenação criminal é a mais de 120 dias em regime fechado ou se é em regime aberto ou semiaberto. Para a 2ª Turma, condenação criminal transitada em julgado, independente do tipo de regime, é sempre algo que vai depender para a perda de mandato, da decisão da Casa, por maioria absoluta e votação aberta. A 2ª Turma não tem interpretação sistemática; ela busca na literalidade a resposta para qualquer tipo de condenação ou em qualquer regime. O máximo que ocorre é que o STF comunica ao presidente da Câmara ou do Senado, informando



que o parlamentar foi condenado e que a condenação transitou em julgado e caberá à Casa deliberar, nos termos do art. 55, § 2º, se o parlamentar vai ou não perder o mandato.

Cabe ressaltar que o STF só pode interferir em procedimentos legislativos (ex: processo de cassação) em uma das seguintes hipóteses:

- para assegurar o cumprimento da Constituição Federal;
- para proteger direitos fundamentais; ou
- para resguardar os pressupostos de funcionamento da democracia e das instituições republicanas (ex.: preservação dos direitos das minorias)

Essa medida nada mais é senão a aplicação do *judicial self-restraint*, também denominada de técnica da autocontenção.

Trata-se de medida oposta ao ativismo judicial, na qual o Poder Judiciário deixar de interferir, ou mesmo de atuar, em questões estritamente políticas, a fim de resguardar a independência dos demais poderes. Dessa forma, o Poder Judiciário deve se limitar apenas aos casos em que sua atuação seja absolutamente excepcional.

Exemplo disso pode ocorrer nos processos de cunho acentuadamente político, como é o caso da cassação de mandato parlamentar, em que o STF deve se pautar pela deferência (respeito) às decisões do Legislativo e pela autocontenção, somente intervindo em casos excepcioníssimos.

Os procedimentos para a perda do mandato também estão previstos na constituição.

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

(...)

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

O parágrafo 2º do art. 55 diz que nas hipóteses de infringência do art. 54, I, II e VI, CF, a perda de mandato será decidida pela Casa, com quórum de maioria absoluta em votação aberta (essa votação até 2013 era secreta, até o caso de Natan Donadon).

O parágrafo 3º do art. 55, CF, diz que nas hipóteses do art. 54, III e V, a perda de mandato será declarada pela Mesa, de ofício ou mediante provocação de membro do partido para a mesa ou partido político com representação no Congresso Nacional.

2.6.4. RENÚNCIA AO MANDATO

A CF dispõe sobre isso no art. 55, §4º, dizendo que a renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais da Casa respectiva.

Se o sujeito estiver sendo processado, e haver um risco de perder o mandato, caso o indivíduo renuncie, os efeitos da renúncia ficam suspensos até que a Casa delibere sobre a perda ou não do mandato.

Isso porque uma decisão desfavorável ao congressista implica, além da perda do mandato, a sua inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, subsequentes ao término da legislatura em que findaria o seu mandato. Então passa o tempo da legislatura e aí inicia o prazo de 8 anos.

Não adianta renunciar!



2.6.5. DEPUTADOS ESTADUAIS, DISTRITAIS E VEREADORES

Deputados estaduais e distritais têm a mesma prerrogativa dos deputados federais.

Os vereadores não têm as mesmas imunidades dos congressistas.

Vereador somente possui imunidade material pelas suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e dentro da circunscrição do município.

2.7. TRIBUNAIS DE CONTAS

Os Tribunais de Contas são órgãos vinculados ao Poder Legislativo, auxiliando no controle externo da Administração.

Não há hierarquia entre o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo. As decisões do TCU não fazem coisa julgada, tendo natureza administrativa.

O Tribunal de Contas é autônomo, e os seus membros possuem as mesmas prerrogativas dos magistrados, inclusive a vitaliciedade.

2.7.1. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

O Tribunal de Contas da União é composto por 9 ministros.

Os membros do TCU têm as mesmas prerrogativas, vencimentos, vantagens dos ministros do STJ.

Os requisitos para ser ministro do TCU são (§1 do art. 73):

- Mais de 35 e menos de 65 anos de idade;
- Idoneidade moral e reputação ilibada;
- Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública;
- Mais de 10 anos de exercício de função ou de atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

Recentemente, o STJ decidiu que o dispositivo prevê é que, para ser nomeado membro do Tribunal de Contas, a pessoa deve ter mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Desse modo, a pessoa pode ter apenas 7 anos, por exemplo, no cargo de Procurador de Contas, mas se ela tiver outros 3 anos de atividade profissional na qual se exija notórios conhecimentos jurídicos, ela terá preenchido o requisito constitucional.

Atente-se que, 1/3 dos membros do TCU são escolhidos pelo presidente da república e depois aprovados pelo Congresso Nacional. Desses 3, dois devem ser escolhidos alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público de Contas. O terceiro é de livre escolha do presidente da república.

O Congresso escolhe 2/3, ou seja, 6 membros, os quais serão nomeados pelo Presidente da República.

A CF dispõe que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, é exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, sem prejuízo do controle interno de cada Poder. Trata-se de uma função típica do poder legislativo. O Congresso exerce esse controle por meio do TCU.

Ademais, o Tribunal de Contas possui atribuição para apreciação, fiscalização e também para julgamento das contas públicas. Isto é mais precisamente visto quando da análise da teoria dos poderes implícitos.

Segundo o art. 71, ao TC compete:

- Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, elaborado em 60 dias a contar de seu



recebimento. Veja, o TCU não julga as contas do presidente, mas apenas aprecia, pois quem julga é o CN.

- Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta;
- Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, salvo as nomeações para cargo em comissão. Além disso, o TC aprecia as concessões de aposentadorias, reformas e pensões, salvo as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;
- Realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e da administração direta e indireta;
- Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;
- Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;
- Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
- Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Ou seja, o TC pode penalizar.
- Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
- Não atendido o disposto no inciso anterior, competes ao TC sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
- Representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

Segundo o STF, o TCU tem legitimidade para anular acordo extrajudicial firmado entre particulares e a Administração Pública, quando não homologado judicialmente. Se o acordo foi homologado judicialmente, o TCU não pode anulá-lo porque a questão já passou a ser de mérito da decisão judicial, o que não pode ser revisto pelo Tribunal de Contas. Contudo, sendo o acordo apenas extrajudicial, a situação está apenas no âmbito administrativo, de sorte que o TCU tem legitimidade para anular o ajuste celebrado (Inf. 780, STF).

Ademais, o TCU possui competência para decretar, no início ou no curso de qualquer procedimento de apuração que lá tramite, a indisponibilidade dos bens do responsável por prazo não superior a 1 ano (art. 44, § 2º da Lei 8.443/92) (Inf. 779, STF).

A competência para julgamento das contas do presidente da república é do CN. O TC somente aprecia as contas e emite parecer prévio. Esta regra também se aplica ao governador de estado.

No caso do prefeito, há uma maior dificuldade para a câmara de vereadores não manter o que foi apreciado pelo TC.

Verificada uma regularidade num ato administrativo, o TC fixa prazo para que adote as providências dentro da lei. Não cumprida, o TC susta os efeitos do ato.



Atente-se que a CF não fala em sustar o contrato. Diante disso, caso haja ilegalidade em contrato administrativo, o ato de sustação não é do Tribunal de Contas, mas sim do Congresso Nacional. Se ligue, caso o Poder Executivo e o Congresso Nacional fique inerte, e dentro do prazo de 90 dias, não haja promoção da correção das irregularidades, o TCU passa a ter competência inclusive para sustar e anular o contrato administrativo. E se for o caso, não somente poderá anular o contrato administrativo, como também o TC possui poderes para anular a licitação que precedeu o contrato.

O TC possui poderes para expedir medidas cautelares com base na teoria dos poderes implícitos. Esta teoria estabelece que quando a CF dispõe competência para se fazer algo, ela também garante os meios para que se atinja aquela finalidade. Quando a CF dá uma série de competências ao TCU, ela deve garantir a ele os meios de alcançar com êxito a sua função. Por conta disso, é possível que sejam concedidas medidas cautelares para que a competência do TC seja assegurada. Trata-se de uma aplicação da teoria dos poderes implícitos.

Como regra, o TC não tem competência para requisitar a quebra de sigilo bancário, mas quando há recursos públicos envolvidos, o TC pode exigir da instituição financeira que forneça a informação daquela informação específica.

A partir daí, operações financeiras que abranjam recursos públicos não estão asseguradas pelo sigilo bancário e sigilo empresarial, quando se está fundado em investigações financeiras pelo TC.

Como a CF confere ao TC a competência para apreciar as concessões de aposentadorias, reformas e pensões, o STF editou a súmula vinculante 3. Esta súmula garante o contraditório e a ampla defesa nos processos que tramitam no TC.

Segundo a súmula vinculante, nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

Ou seja, para apreciar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão não é preciso observar o contraditório e a ampla defesa.

No entanto, o STF ponderou a súmula vinculante, estabelecendo que o TCU tem o prazo de 5 anos para exercer a apreciação dessa legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão sem conceder a oportunidade de contraditório e ampla defesa. Após o prazo de 5 anos, aí deverá observar o contraditório e ampla defesa. Este prazo de 5 anos começa a ser contado da chegada do processo administrativo ao Tribunal de Contas.

O STF entendeu que os Tribunais de Contas podem apreciar a constitucionalidade das leis, mas somente pelo controle concreto, não cabendo controle abstrato. Esta é a razão pela qual os Tribunais de Contas devem observar a cláusula de reserva de plenário.

O STF ainda diz que os TCU não podem manter o sigilo de uma denúncia apresentada contra um administrador público. Isso porque o administrador tem direito de resposta, direito de honra e direito de imagem, não podendo aquele que fez a denúncia ser mantido em sigilo.

Com base neste entendimento, o STF declarou inconstitucional a expressão “*manter ou não o sigilo quanto ao objeto e autoria da denúncia*”, a qual estava previsto no art. 55 da Lei Orgânica do TCU.

Consoante o entendimento do STF, o prazo prescricional para que o TCU aplique multas é de 5 anos, aplicando-se a previsão do art. 1º da Lei nº 9.873/99. Caso esteja sendo imputada ao agente público a conduta omissiva de ter deixado de tomar providências que eram de sua responsabilidade, tem-se que, enquanto ele permaneceu no cargo, perdurou a omissão. No momento em que o agente deixou o cargo, iniciou-se o fluxo do prazo prescricional (Inf. 857).



2.7.2. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS

O art. 31, §1º, dispõe que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

Tribunal de Contas municipais só foram reconhecidos aqueles que já existiam quando da promulgação da CF, pois a CF veda que hoje venham criar novos tribunais de contas municipais.

Estados podem criar Tribunais de Contas.

A CF estabelece que as normas do seu texto para fiscalização contábil, financeira, orçamentária, etc. se aplicam, no que couber, aos Tribunais de Contas dos Estados, Distritais e Municipais.

Isto quer dizer que as composições dos Tribunais de Contas Estaduais, Distritais e Municipais devem observar o modelo federal, com relação aos conselheiros.

Todavia, a própria CF estabelece que os TC estaduais, distritais e municipais são compostos por 7 conselheiros.

Por conta disso, o STF estabeleceu que 3 serão escolhidos pelo governador e 4 pela assembleia legislativa. Com relação aos escolhidos pelo chefe do executivo:

- 2 membros do Ministério Público e auditores alternadamente;
- 1 de livre escolha.

O STF ainda afirma que não está inserida na atribuição do TC atuar em âmbito de processo administrativo tributário. Ou seja, não funcionará o TC como instância recursal de processo administrativo.

Em relação às contas municipais, a CF diz que é feito um parecer prévio pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito presta. Este parecer somente deixa de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal.

A LC 64/90 prevê no seu art. 1º, I, 'g' que os políticos que tiverem suas contas rejeitadas pelo órgão competente ficarão inelegíveis por até 8 anos. Por conta disso, surgiram duas correntes, eis que a dúvida pairava sobre quem seria o órgão competente para "barrar" o político para fins de ficha-limpa:

- 1ªC: dizia que se o prefeito teve suas contas rejeitadas por decisão do Tribunal de Contas já estaria inelegível;
- 2ªC: dizia que o Tribunal de Contas emite apenas um parecer prévio, não opinativo, devendo ser analisado pela Câmara Municipal. Caso ela mantenha o parecer do Tribunal de Contas, o prefeito será inelegível, mas a Câmara poderá rejeitar este parecer, situação na qual o prefeito poderia concorrer normalmente às eleições.

Segundo o STF, é constitucional a criação de órgãos jurídicos na estrutura de Tribunais de Contas estaduais, vedada a atribuição de cobrança judicial de multas aplicadas pelo próprio tribunal.

Por outro lado, é inconstitucional norma estadual que preveja que compete à Procuradoria do Tribunal de Contas cobrar judicialmente as multas aplicadas pela Corte de Contas, tendo em vista que a Constituição não outorgou aos Tribunais de Contas competência para executar suas próprias decisões. As decisões dos Tribunais de Contas que acarretem débito ou multa têm eficácia de título executivo, mas não podem ser executadas por iniciativa do próprio Tribunal (Inf. 851).

No informativo 834, o STF decidiu que para os fins de inelegibilidade (art. 1º, I, 'g', LC 64/90), quem decide se as contas do prefeito estão aprovadas, ou não, é a Câmara dos Vereadores. Ou seja, somente é com a decisão dela que o prefeito se tornará inelegível. A função do Tribunal de Contas é apenas admitir um parecer prévio, que poderá ser ou não aprovado pela Câmara dos Vereadores. O fundamento foi o art. 31, §2º, CF.



Caso a Câmara dos Vereadores demore para analisar o parecer do Tribunal de Contas, ou seja, a rejeição de contas do prefeito, ele poderá continuar concorrendo normalmente, pois a demora não impede que o prefeito concorra normalmente.

Em resumo, quem julga é a Câmara dos Vereadores.

Junto aos Tribunais de Contas, haverá atuação dos Ministérios Públicos de Contas, os quais terão as mesmas prerrogativas do Ministério Público ordinário.

O MP de Contas integra a própria estrutura orgânica junto ao qual atua.

A criação do MP de Contas se dá por lei ordinária, de iniciativa da Corte de Contas respectiva.

3. PROCESSO LEGISLATIVO

3.1. CONCEITO

É um conjunto de regras (fases e atos) que visa à produção (elaboração) de normas jurídicas em nosso ordenamento.

Não é qualquer norma jurídica que se origina do processo legislativo. Por exemplo, existem os atos normativos, chamados de via secundária (decretos, portarias, etc.), que derivam do direito administrativo e não do processo legislativo.

3.2. CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

3.2.1. QUANTO À FORMA DE ORGANIZAÇÃO POLÍTICA

a) Autocrático

O processo legislativo é elaborado pelo governante que impõe a sua norma.

b) Indireto (representativo)

É o que predomina nos estados democráticos, em que os cidadãos escolhem os seus representantes, os quais, em tese, elaboram as leis, de acordo com a vontade do povo. É o sistema adotado no Brasil.

c) Direto

O processo legislativo é feito diretamente pelo povo.

d) Semidireto

Há representantes que elaboram o projeto, o qual é submetido à apreciação do povo, a fim de aprovar ou não a norma. Sendo posterior a análise, há um referendo. Sendo anterior, há o plebiscito.

A doutrina já tratou sobre o sistema Recall. O recall é um mecanismo de democracia direta que permite ao eleitorado destituir determinados agentes políticos cujo comportamento não esteja agradando aqueles que o elegeram. É um instrumento de consulta popular. Aconteceu no primeiro mandato de Hugo Chávez, para verificar se ele continuaria ou não no governo.

O recall não se confunde com o impeachment. No recall, na medida em que mecanismo de democracia direta, a eleição cabe aos próprios eleitores, diretamente. No caso do impeachment, quem julga são os representantes (no caso do Brasil, o Senado).

O recall aplica-se a todos os poderes eleitos, indistintamente, inclusive o Judiciário, quando for o caso (nos EUA, os Juízes estaduais são eleitos). Já o impeachment, em geral, é um instrumento do Poder Legislativo utilizado para fiscalizar os Poderes Executivo e Judiciário. No caso do Executivo, o Brasil viveu o exemplo de Collor. No caso do Judiciário, houve pedido de impeachment do Ministro Gilmar Mendes.



Há quem defenda que o recall deveria ser inserido na CR, em eventual reforma política.

3.2.2. QUANTO AO RITO

a) Ordinário

O processo legislativo adota todas as etapas previstas para a lei ordinária e é implementado quando da produção das leis ordinárias, que são as leis que mais existem no ordenamento brasileiro.

b) Sumário

Também chamado de regime de urgência constitucional é o processo legislativo passa por todas as etapas do ordinário, mas de maneira mais célere, eis que existem prazos previstos na CF. Tem como principais características:

- I. é deflagrado por solicitação do Presidente da República em matérias de sua iniciativa privativa ou concorrente;
- II. possui prazo de no máximo 45 dias na Câmara, 45 dias no Senado e 10 dias para a apreciação de emendas, se houver;
- III. A sanção para o descumprimento do prazo, todas as matérias da Casa ficarão sobrestadas até que se vote legislativo sumário, exceto as matérias com prazo constitucionalmente determinado (ex.: medidas provisórias com prazo de 60 dias com prorrogação para 60 dias; Legislações Orçamentárias);
- IV. Tem seu prazo suspenso no recesso;
- V. Não se aplica a projetos de código.

Especiais: seguem um rito especial. São aqueles que visam à produção, elaboração, das emendas constitucionais, leis complementares, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções do poder legislativo.

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.

§ 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação.

§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior.

§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código.

- Fases do Processo Legislativo Ordinário

A corrente majoritária fala em três grandes fases do processo legislativo. São elas: Fase de Iniciativa, Fase Constitutiva e Fase Complementar.



1. Fase introdutória (de iniciativa):

É a fase que introduz o projeto de lei. Resume-se à iniciativa do projeto de lei.

É a fase de deflagração do processo na qual ocorre a apresentação da proposição. Essa proposição pode ser um projeto de lei ordinária, um projeto de lei complementar, pode ser uma PEC, etc.

Iniciativa é a faculdade atribuída a um ente para iniciar um processo legislativo. Temos a iniciativa parlamentar, dos deputados ou senadores, bem como das comissões de deputados ou comissões de senadores. Temos a iniciativa extraparlamentar, que vai ser do Presidente da República, STF e tribunais superiores, Procurador Geral da República e do povo, nos termos do art. 61, §2º, CF.

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

(...)

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

c) Espécies de iniciativa

Esta iniciativa pode ser:

- Parlamentar: qualquer deputado ou senador pode propor a iniciativa de projeto de lei.
- Extraparlamentar: a CF prevê hipóteses de iniciativa que venha de fora do Parlamento.
 - a. Chefe do executivo
 - b. Procurador-geral da república
 - c. Tribunais
 - d. Cidadãos
- Geral: é aquela em que pode dar início a qualquer projeto de lei. Os parlamentares e o cidadão possuem a iniciativa geral, ressalvadas as matérias que têm iniciativa reservada, como presidente da república, Tribunais, etc.
- Restrita: essa iniciativa ocorre quando uma autoridade ou órgão só pode apresentar projetos de lei sobre determinada matéria. Ex.: Poder Judiciário sobre vencimentos dos servidores.
- Reservada (exclusiva): só um órgão ou uma autoridade pode propor lei sobre aquela matéria. Ex: projeto de lei complementar do estatuto da magistratura é de iniciativa reservada ao STF.
- Concorrente: a iniciativa pertence simultaneamente a mais de um legitimado. Ex.: art. 61 que trata sobre a organização do MPU, que pode ser de iniciativa do PGR ou do Presidente da República. Aqui a faculdade é atribuída a mais de um ente em concorrência, diferente da iniciativa conjunta, que é atribuída a mais de um ente em conjunto, em grupo, se faltar um não pode apresentar o projeto. No Brasil, atualmente, não há previsão de iniciativa conjunta, mas já teve e era previsto no art. 48, XV, CF (teto do funcionalismo público era uma lei de iniciativa conjunta, Presidente da República, Presidente da Câmara, Presidente do Senado e Presidente do STF tinham que apresentar o projeto).



- **Vinculada:** o sujeito é obrigado a dar início ao processo legislativo para o projeto de lei. Ex.: leis orçamentárias, em que é preciso que se dê início ao projeto de lei orçamentária anual dentro do prazo previsto na CF.

d) Iniciativa e casa iniciadora

A iniciativa de cada parlamentar é exercida perante a sua casa legislativa.

No caso de iniciativa extraparlamentar (presidente, cidadão, Tribunais, PGR), o projeto é proposto perante à Câmara dos Deputados, que funcionará como casa iniciadora.

Comissões das Casas legislativas também pode propor projetos de leis. Havendo comissão mista, o projeto de lei é apresentado alternadamente, ou seja, um projeto inicia na câmara, mas no subsequente é apresentado ao senado.

Recentemente, o STF entendeu que não viola a Constituição Federal lei municipal, de iniciativa parlamentar, que veda a realização, em imóveis do Município, de eventos patrocinados por empresas produtoras, distribuidoras, importadoras ou representantes de bebidas alcoólicas ou de cigarros, com a utilização da respectiva propaganda (Info 844).

e) Iniciativa popular

É um dos meios de participação popular do cidadão, sendo forma de exercício de democracia direta. O cidadão tem iniciativa geral, desde que não se sobreponha às iniciativas reservadas, apesar de algumas discussões doutrinárias afirmando o contrário.

O exercício deve ocorrer da seguinte forma:

- (I) 1% do eleitorado nacional
- (II) distribuído por pelo menos 5 estados
- (III) não menos de 3/10 dos eleitores em cada um desses 5 estados

Os indivíduos devem ser cidadãos, ou seja, deve haver capacidade eleitoral ativa (título eleitoral).

A CF determina que a Constituição Estadual do ente federado deverá dispor sobre a iniciativa popular.

Com relação aos municípios, a CF diz que é obrigatória a iniciativa popular no processo legislativo municipal, estabelecendo que esta iniciativa deverá se dar em pelo menos 5% do eleitorado (art. 29, XIII).

O projeto de lei de iniciativa popular deve tratar de apenas um assunto. E mais, projeto de lei de iniciativa popular não pode ser rejeitado por vício de forma.

f) Iniciativa privativa do chefe do executivo

O art. 61, §1º, enumera matérias que são de iniciativa privativa do presidente da república.

O STF diz que esta iniciativa privativa do presidente da república é de observância obrigatória dos Estados, distrito federal e municípios, em razão do princípio da simetria e separação dos poderes, sendo também de iniciativa privativa do chefe do executivo respectivo.

Segundo o STF, não pode o parlamentar iniciar projeto de lei que estabelece normas para aplicação do salário mínimo profissional aos servidores estaduais, eis que se trata de matéria exclusiva do chefe do poder executivo. É da competência do chefe do executivo dispor sobre remuneração dos cargos e funções do serviço público (art. 61, § 1º, II, a).

O STF diz que, em PL de Governador instituindo regime de subsídio para os Procuradores do Estado, não é possível que emenda parlamentar crie uma gratificação aos servidores da Procuradoria Geral do Estado, ainda que haja estimativa de despesa e respectiva fonte de custeio, diante da falta de pertinência temática.

Lembre-se que é necessário que não aumente despesas e haja pertinência temática para que possa falar em emenda parlamentar.

g) Iniciativa dos tribunais

A iniciativa pode ser dos tribunais.

Haverá iniciativa do STF para tratar de lei complementar, que será do estatuto da magistratura (art. 93).

Ao STF, Tribunais Superiores e Tribunais de Justiça a iniciativa de projeto de lei para alteração do número de membros dos Tribunais, criação e extinção dos cargos e a remuneração dos serviços auxiliares dos juízos e fixação dos subsídios dos seus membros, e a fixação da organização e divisão judiciária.

Há aqui uma iniciativa reservada, mas de atuação restrita, eis que vão tratar sobre esses temas a fim de propor projeto de lei.

Recentemente, o STF entendeu que é inconstitucional norma do Tribunal de Justiça que permite a reeleição de desembargadores para cargos de direção após o intervalo de dois mandatos, visto que esta previsão viola o art. 93, caput, da CF/88. Este dispositivo estabelece que a regulamentação da matéria afeta à elegibilidade para os órgãos diretivos dos tribunais está reservada a lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Além disso, esta norma afronta o tratamento que foi dado à matéria pelo art. 102 da LOMAN (LC 35/79), que regulamenta o art. 93 da CF/88 (Inf. 851).

h) Iniciativa em matéria tributária

A CF estabelece que são de iniciativa privativa do presidente da república as leis que disponham sobre a organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios (art. 61, §1º, II, b).

Segundo o STF, este dispositivo aplica-se exclusivamente aos tributos relativos aos territórios federais. Ou seja, não há esta atuação do presidente da república relativo aos demais entes federativos.

A partir disso, é preciso interpretar que a iniciativa do presidente da república relativo a estas matérias se restringem à atuação no âmbito do território.

Lembrando ainda que os territórios não possuem autonomia e não são entes federados.

i) Prazo para exercício de iniciativa reservada

Segundo o STF, não pode o legislativo fixar prazo para que aquele que detém o poder de iniciativa apresente o projeto de lei.

Tampouco o Poder Judiciário pode determinar que outras autoridades proponham projetos de lei de suas iniciativas, ainda que se possa utilizar dos efeitos dos mandados de injunção e entender pela inconstitucionalidade por omissão de leis.

O STF entende que somente aquele que detém a prerrogativa de dar início ao processo legislativo é quem possui o juízo de conveniência e oportunidade para exercer esta prerrogativa.

Todavia, recentemente (2016), o STF julgou procedente a ADO e declarou haver mora, por parte do Congresso Nacional, em editar determinada lei complementar tributária. Diante disso, foi fixado um prazo de 12 meses para que o Legislativo faça a lei.

Na decisão, o STF consignou que, se for ultrapassado o prazo de 12 meses sem que a lei seja editada, o Tribunal de Contas da União (TCU) deverá:

- (I) Fixar o valor total a ser transferido anualmente aos Estados-Membros e ao Distrito Federal, considerando os critérios dispostos no art. 91 do ADCT, a saber, as exportações para o exterior de produtos primários e semielaborados, a relação entre as exportações e as importações, os créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente e a efetiva manutenção e aproveitamento do crédito do imposto a que se refere o art. 155, § 2º, X, “a”, do texto constitucional;



(II) Calcular o valor das quotas a que cada um fará jus, levando em conta os entendimentos entre os Estados-Membros e o Distrito Federal realizados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz)

j) Iniciativa privativa e emenda parlamentar

O projeto de lei de iniciativa privativa do Presidente da República pode sofrer emendas parlamentares.

Cabe ressaltar que a iniciativa privativa somente autoriza que aquele determinado pela constituição dê início ao projeto.

Assim, somente os legitimados acima podem propor leis dispondo sobre certos assuntos. Ex: um projeto de lei tratando sobre a forma de ingresso na carreira de juiz somente poderá ser proposto pelo STF (art. 93, I). Os parlamentares não podem iniciar um projeto de lei dispondo sobre este assunto.

Isso não significa, contudo, que tais temas não possam ser veiculados por meio de emenda constitucional. Seria possível, portanto, uma emenda constitucional versando sobre o ingresso na carreira de juiz. Não há nenhuma vedação nesse sentido. Exemplo disso foi a EC 45/2004, que tratou exatamente sobre esse tema e foi considerada constitucional pelo STF.

Atente-se que, caso um parlamentar dê início ao projeto de lei de iniciativa do presidente da república, e posteriormente haja a sanção presidencial, este projeto não será suprido pela sanção, havendo vício na origem.

No entanto, o STF decidiu que a emenda parlamentar ao projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da república deverá obedecer aos seguintes requisitos:

(I) não provocar aumento de despesas: nem mesmo os projetos sobre organização dos serviços administrativos da câmaras, do senado, dos tribunais ou dos ministérios públicos;

(II) pertinência temática: não pode o parlamentar trazer emendas fora do contexto do projeto de lei.

k) Vício de iniciativa

Suponha que exista uma matéria de iniciativa privativa do Presidente da República (art. 61, §1º, CF) e que seja proposta por um deputado um projeto de lei que verse sobre essa matéria privativa. O projeto de lei tramita nas duas Casas e é aprovado, chegando ao Presidente da República, que sanciona. O projeto de lei deixa de ser projeto e se torna lei. O Presidente, então, dá a sua aquiescência. Essa concordância, ao final, convalida, supre, o vício de iniciativa? O STF possuía um posicionamento exarado pela súmula 5³³, que diz que a sanção supre o vício de iniciativa, pela ideia da instrumentalidade das formas e por economia processual.

No entanto, esse posicionamento do STF é alterado a partir da Representação 890/1974 e, a partir de então, a sanção não supre o vício de iniciativa. O STF, hoje, entende que nesse caso há uma inconstitucionalidade formal subjetiva.

3.2.3. FASE CONSTITUTIVA

É a fase de tramitação do processo legislativo. É a fase na qual há discussão e votação do proposição.

O projeto de lei é apresentado, discutido e votado nas duas casas.

Após, o projeto é encaminhado ao chefe do executivo, o qual poderá sancionar ou vetar o projeto.

33 Súmula 5. A sanção do projeto supre a falta de iniciativa do Poder Executivo



Essa fase constitui a lei, podendo ser subdivida em:

- (i) fase constitutiva do poder legislativo;
- (ii) fase constitutiva do poder executivo.

O projeto de lei é apresentado, discutido e votado nas duas casas.

Após, o projeto é encaminhado ao chefe do executivo, o qual poderá sancionar ou vetar o projeto.

a) Fase constitutiva do poder legislativo

- Atuação prévia das comissões

O projeto de lei, quando apresentado, é submetido às comissões.

Neste caso, há a discussão das proposições.

Na casa iniciadora, o projeto é submetido à apreciação das comissões. Estas apreciações são feitas, via de regra, por duas comissões, uma delas analisa o conteúdo do projeto de lei, sendo denominada da comissão temática. A outra analisa os aspectos formais, ligadas à constitucionalidade do projeto, sendo denominada de comissão de constituição e justiça.

Nada impede que a lei possua diversos temas, hipótese em que deverá passar em várias comissões temáticas. O número de comissões depende do número de temas.

Os projetos são submetidos às discussões depois de examinados pelas comissões.

As comissões temáticas discutem e elaboram um parecer.

O parecer pode ser a favor ou contra a matéria, mas a comissão temática possui pouco poder, eis que é a comissão de constituição e justiça que tem mais força.

O parecer da comissão temática é meramente opinativo, podendo ser desconsiderado pelo Plenário da Casa. Por isso, o parecer negativo não significa a sua rejeição em Plenário.

No entanto, com relação à comissão de constituição e justiça, o parecer possui caráter terminativo. Ou seja, se a CCJ disser que o projeto viola a CF, o projeto de lei será arquivado.

Se o parecer for aprovado na comissão temática e na comissão de constituição e justiça, o projeto é encaminhado ao Plenário da casa, o qual será objeto de discussão e de votação.

O trabalho das comissões, que ocorre na Casa iniciadora, também ocorre na casa revisora.

- Deliberação plenária

Chegando ao Plenário, os membros da casa irão deliberar sobre a matéria.

O projeto de lei, para ser aprovado no plenário, basta uma maioria simples (relativa), ou seja, metade mais um dos presentes, desde que haja pelo menos a maioria absoluta dos membros da casa. Este é o quórum para deliberar sobre lei ordinária.

Sendo uma lei complementar, é necessário uma maioria absoluta. Neste caso, é necessário que estejam presentes todos os membros da casa legislativa, e, diante disso, para haver a aprovação do projeto de LC, será preciso metade e mais um da integralidade dos parlamentares da casa.

O projeto se aprovado na casa iniciadora será encaminhado à casa revisora, onde caso seja rejeitado, o projeto ser arquivado.

Quando o projeto de lei é arquivado, aplica-se o princípio da irrepetibilidade, ou seja, o projeto não poderá mais ser proposto naquela sessão legislativa. Esta é a regra.

No entanto, se houver proposta da maioria dos membros daquela casa, ou da outra casa, poderá ser reproposto na mesma sessão legislativa, configurando uma exceção ao princípio da irrepetibilidade.

Ao chegar na casa revisora, o projeto pode ser aprovado, de modo que será encaminhado à sanção presidencial.

Por outro lado, caso o projeto seja aprovado na casa iniciadora, e encaminhado à casa revisora, é possível que surjam emendas. No caso de aprovação com emendas da casa



revisora, o projeto retorna à casa iniciadora, hipótese em que serão apreciadas exclusivamente às emendas. Concordando a casa iniciadora com as emendas da casa revisora, o projeto de lei é encaminhado à sanção do chefe do executivo.

Havendo rejeição da casa iniciadora das emendas realizadas pela casa revisora, o projeto de lei é encaminhado à sanção do presidente da república, na sua forma original.

Percebam que há uma predominância da casa iniciadora, pois poderá enviar o projeto ao executivo sem as emendas da casa revisora.

- Aprovação definitiva pelas comissões

É possível que haja a aprovação definitiva pelas comissões e seja encaminhado diretamente ao presidente da república para sanção ou veto.

O art. 58, §2º, vai tratar do tema. A CF outorga competência às comissões para discutir e votar projeto de leis que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário. Neste caso, obsta a aprovação pela comissão se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa.

b) fase constitutiva do poder executivo

A sanção ou veto são atos de competência privativa do chefe do poder executivo.

- Sanção

A sanção do presidente da república poderá ser:

- (i) expressa: é formalizada no prazo de 15 dias úteis, a contar da data de recebimento.
- (ii) tácita: ocorre após o transcurso do prazo de 15 dias úteis.

Havendo a sanção expressa, a lei está constituída, passando-se para a próxima fase, que é a complementar, que se dá pela promulgação e publicação da lei.

Com a sanção do presidente, ele dá origem ao nascimento da lei.

Logicamente, a sanção não impede que a matéria seja questionada no poder judiciário. O STF entende que a sanção não impede sequer que o próprio presidente questione a inconstitucionalidade de uma lei que ele mesmo sancionou.

- Veto

O veto, ao contrário da sanção, deve ser expresse, não admitindo o “veto de bolso” (veto tácito).

O presidente da república pode não concordar com o projeto de lei, cabendo:

- (i) Veto jurídico: é a não concordância do PR sob o fundamento de inconstitucionalidade da lei. Aqui, o PR exerce um controle de constitucionalidade preventivo, pois é antes da lei.
- (ii) Veto político: é a não concordância do PR sob o fundamento de contrariedade ao interesse público.
- (iii) Veto total: há a rejeição integral do projeto de lei.
- (iv) Veto parcial: há rejeição parcial do projeto de lei. Este veto somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, não se admitindo o veto de causa (ou de pingente), que é aquele que abrange certas palavras ou expressões do texto.

São características do veto no direito brasileiro:

- (i) expresse: não pode ser tácito.
- (ii) formal: deve ser escrito.
- (iii) motivado: deve comunicar a motivação ao senado.
- (iv) supressivo: o PR não pode retirar uma parte do artigo para mudar o sentido do texto, pois, neste caso, estaria atuando como legislador positivo.
- (v) superável (relativo): o congresso pode rejeitar o veto.
- (vi) irretratável: não admite retratação.
- (vii) insuscetível de apreciação judicial: trata-se de um ato político.



(viii) incidência em texto de iniciativa do próprio presidente: ou seja, o próprio presidente pode vetar pontos do projeto que ele mesmo propôs.

O veto é um ato composto, eis que há uma manifestação negativa do PR, mas é preciso que haja a comunicação do veto ao presidente do Senado, para que faça a sessão conjunta de deliberação do veto. Esta comunicação deve ser feita no prazo de 48 horas.

O veto será apreciado pelo Congresso Nacional, a qual se dará em sessão conjunta, devendo acontecer no prazo de 30 dias, a contar do recebimento do veto. O veto poderá ser derrubado pela maioria absoluta dos deputados e dos senadores, sendo exigido votação aberta e nominal. Há aqui um exercício de freios e contrapesos.

Cabe ressaltar que, não havendo a apreciação do veto pelo CN no prazo de 30 dias, haverá o trancamento da pauta da sessão conjunta do Congresso Nacional, e não das casas individualizadamente.

Se houver a rejeição do veto, haverá o encaminhamento do projeto de lei ao presidente da república para que ele promulgue. Caso não promulgue, será o presidente do senado. Não o promulgando, caberá ao vice-presidente do senado.

Frise-se que poderá haver a rejeição parcial do veto presidencial.

Por outro lado, caso o veto seja mantido, o projeto de lei será arquivado, aplicando-se o princípio da irrepetibilidade, só podendo ser reapreciado esse projeto na mesma sessão legislativa, desde que seja apresentado pela maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do CN.

Com relação ao veto parcial, a parte que não foi rejeitada, já pode ser promulgada e publicada. Em outras palavras, a parte vetada não impede que a parte aprovada surta efeitos.

Se o chefe do executivo, ao sancionar a lei, incluir um artigo que não constava originalmente no projeto aprovado pelo Parlamento estará configurada a prática do crime de falsificação de documento público. Este entendimento é do STF no informativo 832, aplicando ao prefeito.

c) Fase complementar

Havendo a sanção expressa ou tácita do presidente da república, haverá a promulgação e publicação da lei, no prazo de 48 horas. No entanto, desde de a sanção ou superação do veto, já se pode falar em lei, e não mais em projeto de lei.

Essa fase possui dois atos: promulgação e a publicação:

- Promulgação

A promulgação é um ato solene que atesta a existência da lei.

A lei nasce com a sanção, porém a sua existência é declarada pela promulgação.

Esta promulgação é feita pelo chefe do poder executivo. No caso de sanção tácita, caso o presidente da república não a faça, caberá ao presidente do senado fazer no mesmo prazo de 48 horas. Não havendo atuação do presidente do senado, caberá ao vice-presidente do senado a promulgação da lei (art. 66, §7º).

Todavia, não havendo disponibilidade para o vice-presidente do senado, a CF não prevê o substituto. Diante disso, a doutrina estabelece que o vice-presidente do senado não possui faculdade de promulgar ou não a lei, cabendo a lei a obrigatoriedade de promulgação.

Existem casos de promulgação de lei de competência originária do poder legislativo, e não apenas subsidiária.

Nesse caso, não são leis em sentido formal, mas atos normativos primários, os quais devem ser promulgados originariamente pelo legislativo:

- (i) emenda constitucional: promulgação pelas mesas do senado e da câmara
- (ii) decreto legislativo: é ato privativo do congresso, o qual é promulgado pelo presidente do congresso.
- (iii) resolução: será promulgada pelo presidente da respectiva casa.

- Publicação

Publicação é dar ciência, comunicando às pessoas sobre a lei.

Trata-se de uma condição de eficácia da lei. A publicação é exigência necessária para a entrada em vigor da lei.

d) Fases do Processo legislativo sumário

O processo legislativo sumário é o procedimento ordinário com diminuição dos prazos, por conta da celeridade. É a diferença de prazos que diferencia o procedimento sumário do ordinário.

De acordo com o art. 64, §1º, o Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Atente-se que não precisa ser de iniciativa privativa, basta que sejam de sua iniciativa.

Este dispositivo cria exigências para que se tenha processo legislativo sumário:

- (i) urgência solicitada pelo presidente da república
- (ii) processos de sua iniciativa

Solicitada a urgência, se a Câmara ou o Senado não se manifestarem sobre a proposição em até 45 dias cada um deles, haverá o sobrestamento de todas as demais deliberações daquela casa. É o trancamento da pauta. A CF traz uma exceção ao sobrestamento para os casos em que as deliberações legislativas tenham prazo constitucional determinado.

No caso de proposição de emendas ao projeto de lei proposto pelo presidente da república, o senado (casa revisora) encaminhará novamente para a câmara (casa iniciadora), a qual deverá apreciar as emendas em até 10 dias, sob pena de trancamento da pauta.

Processo legislativo sumário não se aplica a processos legislativos de códigos, dada a complexidade.

A CF estabelece também uma hipótese de processo legislativo sumário para a apreciação de atos de outorga e renova concessão, permissão e autorização para radiodifusão sonoras e de sons e imagens, eis que deverá obedecer ao regime de urgência. Há aplicação do regime de urgência de forma direta do texto constitucional.

Em síntese, no caso típico de urgência, o presidente da república solicita a urgência de um processo de sua iniciativa, a câmara tem 45 dias para apreciar e o senado possui 45 dias para apreciar. Se houver emendas da casa revisora, a casa iniciadora terá mais 10 dias para apreciar. Não havendo a observância do prazo, haverá o trancamento da pauta.

Existem duas hipóteses excepcionais em que o Presidente da República não pode solicitar urgência na apreciação de um projeto de lei. A Constituição impede a existência de processo legislativo sumário:

- (i) com relação a Códigos, que exigem análise ampla e aprofundada;
- (ii) e no caso de suspensão do processo legislativo sumário durante os recessos do Congresso Nacional.

Vale lembrar que fora do período de sessão legislativa ordinária (23/12 a 01/02 e 16/07 a 31/07), os prazos não são computados.



3.2.4. ESPÉCIE NORMATIVA

As espécies normativas que derivam do processo legislativo são as espécies normativas primárias do art. 59, CF. São espécies constitutivas de direito novo.

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

- I - emendas à Constituição;
- II - leis complementares;
- III - leis ordinárias;
- IV - leis delegadas;
- V - medidas provisórias;
- VI - decretos legislativos;
- VII - resoluções.

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

No texto aprovado da redação original da constituição eram só seis incisos mas acrescentaram, no inciso V, a medida provisória. O estranho é porque, em tese, a medida provisória não deriva de um processo legislativo, vindo pronta e acabada do Executivo. No entanto, se diz que consta medida provisória no rol do artigo 59 porque, para que a medida provisória se torne lei ordinária requer um processo legislativo com tramitação das duas Casas do Congresso. Nesse diapasão consta medida provisória no rol do artigo 59 não pelo processo desta, que já vem pronta do executivo, mas sim o processo legislativo para saber se a medida provisória se tornará ou não lei ordinária.

a) Lei ordinária

Lei ordinária é um ato legislativo típico, sendo um ato primário e geral.
É característica da lei ordinária deverá ter:

- (i) generalidade
- (ii) abstração

b) Lei complementar

Lei complementar é uma lei em que a iniciativa é a mesma da lei ordinária, porém sua aprovação se dá por maioria absoluta, e não por maioria relativa.

Nos demais procedimentos, observa-se a mesma sistemática.

Ademais, a lei complementar possui matérias reservadas. Isso porque a CF quer que alguns assuntos tenham maior grau de estabilidade. Ex.: código tributário nacional.

O STF decidiu que a exigência de lei complementar prevista na CF deveria ser reproduzida nas Constituições Estaduais, mas a suprema corte disse que não há necessária dessa observância.

A lei complementar é criada por um processo legislativo especial. Lei complementar é uma espécie normativa primária que envolve taxativamente previstas na constituição e que exige um quórum de maioria absoluta para a aprovação.

O processo legislativo para a criação de uma lei complementar possui três grandes diferenças (que podem ser cobradas em provas de magistratura) em relação ao processo legislativo de uma lei ordinária.

Processo Legislativo Especial	Processo Legislativo Ordinário
-------------------------------	--------------------------------



(Lei Complementar)	(Lei Ordinária)
Há uma diferença material, por lei complementar envolver matérias taxativas da Constituição. Art. 22, parágrafo único ³⁴ ; art. 93, <i>caput</i> ³⁵ ; art. 79, parágrafo único ³⁶ .	A lei ordinária é subsidiária, ou seja, se a lei não é de matéria que deva ser de lei complementar ou de outra espécie especial, será ordinária.
Há também uma diferença formal, pois a lei complementar envolve maioria absoluta. Art. 69, CF ³⁷ .	A lei ordinária exige maioria simples. Art. 47, CF ³⁸ .
Há diferença de regime de tramitação. Os projetos de lei complementar sempre terão regime de tramitação tradicional. Obrigatoriamente irão a plenário.	Os projetos de lei ordinária podem ter os regimes de tramitação tradicional, que irão a plenário, e regime de tramitação conclusivo, ou seja, pode ser votado tanto em plenário quanto em comissões.

No mais, os processos se equivalem: os projetos de lei complementar também terão Casa iniciadora e Casa revisora. Se a Casa revisora alterar com emenda substancial, volta para a Casa iniciadora revisar. Tem sanção ou veto. Se há veto, o veto irá ao Congresso Nacional para apreciar, em sessão conjunta, no prazo de 30 dias e rejeitado o veto por maioria absoluta em votação aberta vamos ter a promulgação pelo Presidente da República, aplicando-se também o art. 66, CF.

Observação: existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar? Existem alguns autores que defendem que sim, que por causa da diferenciação feita pelo quórum exigido, há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Mas a corrente majoritária diz que não existe hierarquia, porque o que existe são campos materiais diferenciados, pois o constituinte decidiu que determinadas matérias serão alocadas para lei ordinária e determinadas matérias, por lei complementar. Além disso, tem o argumento de fundamento de validade, ou seja, uma lei complementar não é válida porque uma lei ordinária dá validade a ela e vice-versa. Uma não retira o seu fundamento de validade da outra.

Ambas retiram o seu fundamento de validade da constituição. Se existe hierarquia não é entre elas, mas sim delas para com a constituição. Essa é a corrente majoritária na doutrina e na jurisprudência.

Observação: apesar de não ter hierarquia, se uma lei ordinária invade a competência de lei complementar essa lei ordinária será inconstitucional. Se lei complementar invade a competência de lei ordinária, essa lei complementar não será inconstitucional, porque é a ideia de “quem pode mais, pode menos”. Ou seja, de qualquer modo o dispositivo seria aprovado, porque a lei ordinária exige maioria simples e foi aprovado por maioria absoluta da lei complementar.

Se, posteriormente, vier uma lei ordinária sobre essa matéria, essa lei ordinária revoga a lei complementar? Sim. Excepcionalmente sim. Nesse caso, uma lei ordinária posterior pode

³⁴ Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...)Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

³⁵ Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

³⁶ Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais.

³⁷ Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.

³⁸ Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.



revogar lei complementar, porque essa lei complementar é uma lei complementar formalmente complementar, mas materialmente ordinária.

Quando a lei complementar for formalmente complementar mas materialmente ordinária, ela pode ser revogada por lei ordinária.

O STF já se manifestou sobre isso em alguns informativos, como no Info. 529.

3.2.5. PROCESSOS LEGISLATIVOS ESPECIAIS

São aqueles que visam à produção, elaboração, das emendas constitucionais, leis complementares, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções do poder legislativo.

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.

§ 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação.

§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior.

§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código.

a) Emendas à constituição

Trata-se de um processo de alteração do texto constitucional.

Há basicamente 4 fases:

(iii) proposta de emenda: os legitimados são:

- a. 1/3 dos membros de uma das casas
- b. presidente da república
- c. mais da metade das AL's, manifestando-se cada uma por maioria relativa de seus membros

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível que Emenda Constitucional proposta por iniciativa parlamentar trate sobre as matérias previstas no art. 61, § 1º da CF/88, pois as regras de reserva de iniciativa ali fixadas não são aplicáveis ao processo de emenda à Constituição Federal, que é disciplinado em seu art. 60. Assim, a EC 74/2013, que conferiu autonomia às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal, não viola o art. 61, § 1º, II, alínea "c", da CF/88 nem o princípio da separação dos poderes, mesmo tendo sido proposta por iniciativa parlamentar. STF. Plenário. ADI 5296 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 18/5/2016 (Info 826).

Quando a CF/88 prevê que determinados projetos de lei somente podem ser apresentados por alguns legitimados, ela não proíbe que tais temas sejam tratados por emenda constitucional iniciada por qualquer dos legitimados.

Os parlamentares não podem iniciar um projeto de lei dispondo sobre este assunto. Isso não significa, contudo, que tais temas não possam ser veiculados por meio de emenda constitucional. Seria possível, portanto, uma emenda constitucional versando sobre o ingresso



na carreira de juiz. Não há nenhuma vedação nesse sentido. Exemplo disso foi a EC 45/2004, que tratou exatamente sobre esse tema e foi considerada constitucional pelo STF.

O STF não pode propor emendas à Constituição. Logo, deve-se permitir que qualquer dos legitimados do art. 60 possa propor emendas à Constituição Federal, ainda que dispondo sobre os assuntos do art. 61, § 1º, II, da CF/88.

No âmbito estadual, a conclusão é a mesma acima exposta? Os Deputados Estaduais podem apresentar emendas constitucionais tratando sobre os assuntos previstos no art. 61, § 1º da CF/88?

NÃO. O STF entende que se houver uma emenda à Constituição Estadual tratando sobre algum dos assuntos listados no art. 61, § 1º, da CF/88 (adaptados, por simetria, ao âmbito estadual), essa emenda deve ser proposta pelo chefe do Poder Executivo. Assim, é incabível que os Deputados Estaduais proponham uma emenda constitucional dispondo sobre o regime jurídico dos servidores públicos, por exemplo (art. 61, § 1º, II, “c”). Se isso fosse permitido, seria uma forma de burlar a regra do art. 61, § 1º, da CF/88.

Em suma, *“matéria restrita à iniciativa do Poder Executivo não pode ser regulada por emenda constitucional de origem parlamentar”* (STF. Plenário. ADI 2.966, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 06/04/2005). Assim, se for proposto um projeto de lei tratando sobre servidores públicos do Poder Executivo estadual, este projeto deverá ser apresentado pelo Governador do Estado, por força do art. 61, § 1º, II, “c”, da CF/88, que é aplicado ao âmbito estadual, por força da simetria.

Com base nisso, será inconstitucional emenda constitucional, de iniciativa parlamentar, que insira na Constituição Estadual dispositivo versando sobre servidores públicos estaduais. Isso porque seria uma forma de os Deputados Estaduais burlarem a vedação do art. 61, § 1º, II, “c”, da CF/88. Nesse sentido: STF. Plenário. ADI 3848/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/2/2015 (Info 774). Dessa forma, o poder das Assembleias Legislativas de emendar Constituições Estaduais não pode avançar sobre temas cuja reserva de iniciativa é do Governador do Estado.

Na fase constitutiva, seguirá pelo art. 60, §2º, CF. A PEC tramita pelo Congresso Nacional em dois turnos, nas duas Casas, com 3/5 de votos.

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

(...)

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

A fase complementar terá o procedimento do art. 60, §3º, CF, que é a promulgação de uma emenda constitucional pela Mesa da Câmara e do Senado, com seu respectivo número de ordem.

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

(...)

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem



3.2.6. PROCESSO LEGISLATIVO DA EMENDA CONSTITUCIONAL

Temos a apresentação da PEC (art. 60, I, II e III, CF³⁹), na fase de iniciativa, que vai para a Mesa da Casa da Câmara (mas poderia ser do Senado), que irá para a Comissão de Constituição e Justiça, que fará um juízo de admissibilidade sobre a PEC (se ferir cláusula pétrea, a CCJ pode determinar o arquivamento desde já) e, se não admitir a PEC, arquiva ou admite a PEC, que irá para uma Comissão Especial Temporária, que terá 40 sessões para elaborar um parecer sobre a PEC.

Feito isso, terá um primeiro turno de votação na Câmara dos Deputados, em que a PEC poderá ser rejeitada ou aprovada. Se rejeitada, arquiva-se. Se aprovada com quórum de 3/5, irá para o segundo turno de votação, onde poderá ser rejeitada (arquiva) ou aprovada, novamente por 3/5.

Se aprovada em dois turnos da Câmara, irá para a Mesa do Senado, que terá procedimento semelhante ao da Casa anterior. Irá para a CCJ do Senado, que fará um juízo de admissibilidade sobre a PEC e também emite um parecer sobre a PEC. Na Câmara, quem dá o parecer é a Comissão Especial. No Senado, a CCJ faz a admissibilidade e também dá o parecer, tendo o prazo de 30 dias para tanto. A CCJ admite e dá o parecer e já pode ter votação.

Será votada em primeiro turno, podendo ser rejeitada ou aprovada. Se rejeitada, arquiva. Se aprovada no primeiro turno, vai a segundo turno, que também pode ser rejeitada (arquiva) ou aprovada num quórum de 3/5.

Se aprovada em dois turnos em cada Casa por um quórum de 3/5, será promulgada pela Mesa da Câmara e Mesa do Senado com seu número de ordem.

Se, ao invés de começar na Câmara, começar no Senado, não irá ser igual à Câmara, que vai para CCJ e depois para Comissão Especial Temporária com 40 sessões. Se a PEC começar no Senado, terá CCJ, depois da CCJ que faz a admissibilidade em 30 dias, já irá para votação em primeiro e segundo turno. Quando fosse para a Câmara, terá CCJ e Comissão Especial.

Quando a PEC é rejeitada, ela não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Só poderá ser reapresentada na próxima sessão legislativa (art. 60, §5º, CF).

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

(...)

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Nas circunstâncias de estado de sítio, intervenção federal e estado de defesa, a constituição não poderá ser emendada. Art. 60, §1º, CF.

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

(...)

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio

³⁹ Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.



Podem ter emendas às PEC. Não pode ter contrabando legislativo, devendo as emendas guardarem pertinência temática com a PEC. Se chegar na segunda Casa a PEC aprovada com emendas, deve voltar à Casa iniciadora para apreciação das emendas também em dois turnos com quórum de 3/5.

- Por que existe essa diferença de tratamento entre emenda à Constituição Federal e emenda à Constituição Estadual?

O Poder Constituinte Estadual não é originário. É poder constituído, cercado por limites mais rígidos do que o poder constituinte federal. A regra da simetria é um exemplo dessa limitação. Por essa razão, as Assembleias Legislativas se submetem a limites mais rigorosos quando pretendem emendar as Constituições Estaduais. Assim, se os Deputados Estaduais apresentam emenda à Constituição Estadual tratando sobre os assuntos do art. 61, § 1º, da CF/88 eles estão, em última análise, violando a própria regra da Constituição Federal.

3.2.7. MEDIDAS PROVISÓRIAS

As medidas provisórias são atos normativos primários, tendo seu fundamento de validade extraído diretamente da CF.

Esses atos são provisórios, estando sob uma condição resolutiva, pois, do contrário, perderão sua eficácia.

Medida Provisória é uma espécie normativa primária elaborada e editada pelo Presidente da República, com força de lei, sob um fundamento de relevância e urgência e que deve ser apreciada pelo Poder Legislativo em um prazo de 60 dias prorrogável por mais 60 dias.

A EC 32/2001 alterou a exegese das medidas provisórias na Constituição

ANTES DA EC 32/2001	DEPOIS DA EC 32/2001
O prazo das MP's era de 30 dias.	O prazo é de 60 dias podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Formalmente, pelo menos, as MP podem valer por 120 dias.
O STF permitia a reedição de MP. O prazo de duração de uma MP era de 30 dias para vigorar e ser apreciada pelo Congresso, que, se não o fizesse, o PR poderia reeditá-la por 30 dias sucessivamente. Tivemos MP que foram reeditadas por mais 70 vezes. Exemplo: MP do plano real, elaborada em 1994 mas apreciada em 2001.	Proibida a reedição de MP. Hoje, caso uma MP ultrapasse os 120 dias (60 + 60) sem apreciação pelo Congresso, ocorrerá a rejeição tácita.
O prazo de tramitação não era suspenso no recesso.	O prazo de tramitação é suspenso no recesso. Supondo que no dia 20/12 o PR publica uma MP e o recesso tem início no dia 22/12, tendo tramitado, até então, por 2 dias. Ao retornar do recesso, no dia 02/01, volta no terceiro dia. No entanto, em que pese não possa ser apreciada pelo Congresso no período de recesso, a MP continua a vigorar. Ou seja, no fundo a MP pode durar muito mais do que



	120 dias. Porém, caso haja convocação extraordinária, nos termos do art. 57, §8º ⁴⁰ , as MP em vigor são incluídas na pauta de convocação e o prazo volta a ser contado no recesso.
Não existia regime de urgência para a tramitação de MP.	Existe regime de urgência, nos termos do art. 62, § 6º da CF. <i>Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (...)</i> <i>§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.</i> Do dia 46 ao dia 60 são 15 dias em que pode ficar em regime de urgência. Ou seja, tudo parado, enquanto não votar a MP não vota nada. E quando chegar no dia 60, pode ser prorrogado por mais 60 dias. Assim, podemos ter 75 dias de uma MP tramitando em regime de urgência, trancando pauta no Congresso*.
A apreciação da MP era feita pelo Congresso Nacional em sessão conjunta.	A apreciação da MP é feita de forma separada. Primeiro será apreciada na Câmara e, se aprovada, será apreciada pelo Senado. Se aprovada nas duas Casas, virará uma lei ordinária.

*Em 2004, após a EC 32, tivemos 246 dias legislativos e desses dias, tivemos MP trancando pauta de 220 dias, ou seja, a rigor, os congressistas só trabalharam por 26 dias. Em 2009, o então presidente da Câmara, Michel Temer, resolveu dar uma nova interpretação ao art. 62, §6º, dizendo que a partir de então MP só tranca pauta de projeto de lei ordinária e em matérias que guardam relação com a MP, que podem ser regradas por ela. Existem muitas matérias, mesmo em projeto de lei ordinária, que não podem ser regradas por MP (por exemplo de matéria penal, processual penal, nacionalidade, direito eleitoral, partidos políticos, etc).

Exemplo: imagine que o Brasil esteja sofrendo bombardeio, sendo atacado por outro país. Mas o Brasil não pode responder a essa agressão armada porque existe MP trancando pauta e impossibilita a tramitação de decreto legislativo para declarar guerra a esse país.

⁴⁰ Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (...)§ 8º Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação.



a) Requisitos das medidas provisórias

O art. 62 da CF diz que em caso de relevância e urgência (pressupostos da medida provisória), o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

Entende-se que a definição do que seja relevante e urgente para fins de edição de medidas provisórias consiste, em regra, em um juízo político (escolha política/discricionária) de competência do Presidente da República, controlado pelo Congresso Nacional.

Desse modo, salvo em caso de notório abuso, o Poder Judiciário não deve se imiscuir na análise dos requisitos da MP.

No caso de MP que trate sobre situação tipicamente financeira e tributária, deve prevalecer, em regra, o juízo do administrador público, não devendo o STF declarar a norma inconstitucional por afronta ao art. 62 da CF/88 (Inf. 851).

Lembrando que a CF estabelece que a edição de medida provisória não obriga a convocação extraordinária em período de recesso. Então, o prazo de medida provisória não é contado durante o período de recesso. Neste caso, se houver uma convocação extraordinária por outro motivo no Congresso, as medidas provisórias são automaticamente inseridas na pauta.

b) Vedações às medidas provisórias

Existem certas matérias que não podem ser tratadas por medidas provisórias:

- (i) matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral: tudo relacionado à capacidade eleitoral ativa ou passiva.
- (ii) direito penal, processual penal e processual civil
- (iii) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
- (iv) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;
- (v) que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro
- (vi) reservada a lei complementar
- (vii) matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

Além desses casos, é vedada a edição de medida provisória estadual para regulamentar a exploração diretamente, ou mediante concessão, dos serviços locais de gás canalizado.

Com relação à matéria orçamentária, é permitida a adoção de medida provisória somente para a abertura de crédito extraordinário, o qual só se justifica para despesas extraordinárias e urgentes, como guerra, comoção interna, calamidade pública, etc.

c) Procedimento legislativo da MP

As medidas provisórias devem ser submetidas ao congresso nacional, o qual terá o prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias para apreciar a medida provisória.

Este prazo não corre durante os prazos de recesso do congresso nacional.

No CN, as medidas provisórias são apreciadas por uma comissão mista, composta por senadores e deputados. Posteriormente, haverá a elaboração de um parecer, favorável ou não à conversão em lei. Este parecer é meramente opinativo.

Apesar de serem apreciadas numa comissão mista, a votação da medida provisória é feita em separado, iniciando-se na casa iniciadora e posteriormente sendo enviada para a casa revisora (senado). Se a MP é convertida em lei, o Presidente do Senado vai promulgar.



Todavia, esta medida provisória pode ser alterada. Se houver modificações no texto, a medida provisória se transforma num projeto de lei de conversão. Este projeto, aprovado no legislativo, deverá ser encaminhado ao presidente da república para ser sancionado ou vetado.

A outra opção que poderá acontecer com a medida provisória é de ela ser integralmente rejeitada, ou pela perda do prazo de 60 mais 60 dias.

Neste caso, a medida provisória é arquivada, devendo o congresso nacional disciplinar por meio de decreto legislativo, no prazo de 60 dias, as relações jurídicas que ocorreram durante a vigência daquela medida provisória.

A CF estabelece que o CN deverá disciplinar no prazo de 60 dias. Caso o CN não edite o decreto, as relações jurídicas que surgiram durante o lapso de atuação da medida provisória, serão ainda reguladas pelo conteúdo da medida provisória.

Em síntese, a medida provisória poderá sofrer 3 destinos:

- Aprovada sem emendas – o Presidente da República publica a MP (entra no ordenamento com força de lei), vai para a Mesa do Congresso Nacional, que determina uma comissão mista temporária composta por 12 deputados e 12 senadores que irão elaborar um parecer sobre a MP (sobre relevância e urgência, sobre mérito, etc), irá para a Câmara dos Deputados, que pode ser rejeitada ou aprovada om quórum de maioria simples. Se aprovada, irá para o Senado, e lá poderá ser rejeitada ou aprovada por maioria simples. Se ela foi aprovada por maioria simples nas duas Casas, o presidente do Senado promulga e o Presidente da República a lei ordinária derivada de MP.

- Aprovada com emendas – presidente da República publica a MP e vai para a Mesa do Congresso Nacional, que determina uma comissão mista temporária composta por 12 deputados e 12 senadores que irão elaborar um parecer sobre a MP. Os parlamentares podem apresentar emendas à MP num prazo de 6 dias contados da publicação da MP. O parecer, aqui, será não só sobre a MP, mas também sobre as emendas que os parlamentares irão apresentar sobre a MP. Após, a comissão mista vai apreciar a MP e suas emendas. A câmara aprovou com emendas e o Senado aprova com emendas, a MP se modificou e, por isso, será convertida em um projeto de lei ordinário, que será submetido ao Presidente da República para a sua apreciação. Deve-se dar ao Presidente da República oportunidade de apreciação sobre a MP, que agora está com emendas. O Presidente da República vai se manifestar e será encaminhado a ele para sanção ou veto à MP. Se o Presidente da República concorda com a modificações feitas em sua MP, que foi convertido num projeto de lei, sanciona. Se não concorda, veta o projeto de lei. Se o Presidente sanciona o projeto de lei, ele mesmo promulga e publica a lei ordinária. Se o presidente veta o projeto de lei, ocorrerá o procedimento do art. 66, CF, o projeto vai ao Congresso Nacional para apreciação em votação aberta, num prazo de 30 dias, em sessão conjunta e pode rejeitar o veto. As emendas à MP tem que guardar pertinência temática com esta, senão estaremos diante de um contrabando legislativo, algo que o STF não admite mais desde outubro de 2015, no julgamento da ADI 5127.

- Rejeição – teremos a rejeição expressa e a rejeição tácita. A rejeição expressa é aquela que ocorre dentro do prazo de tramitação da MP, ou seja, dentro do prazo de 60 dias que podem ser prorrogáveis por mais 60 dias, seja na Câmara ou no Senado. A rejeição tácita ocorre após o prazo de 60 dias prorrogáveis por 60 dias em virtude da MP não ter sido aprovada pelas duas Casas ou rejeitada expressamente por uma. Se foi aprovada pelas duas casas, se torna lei ordinária; se foi rejeitada expressamente por uma das casas, é rejeição expressa. Quando a MP, após 120 dias formais, não foi aprovada expressamente pelas duas Casas ou rejeitada expressamente por uma delas. **O efeito de rejeição de uma MP é ex-tunc**, ou seja, perde eficácia desde a edição, nos termos do artigo 62, §3º, CF.

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.



(...)

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.

Segundo o STF, caso o Congresso Nacional inclua, em projeto de lei, uma emenda de conteúdo diverso da medida provisória originária, ou seja, sem pertinência temática, tal prática será considerada incompatível com a Constituição Federal, configurando o chamado contrabando legislativo.

O uso de medidas provisórias se dá por motivos de urgência e relevância da matéria, cuja análise compete ao chefe do Poder Executivo. Assim, toda e qualquer emenda parlamentar em projeto de conversão de medida provisória em lei deve ficar restrita ao tema definido como urgente e relevante.

Dessa forma, o dispositivo inserido por meio de contrabando legislativo é considerado formalmente inconstitucional.

O problema é que quando uma MP surge no ordenamento não há como saber se ela irá ser rejeitada ou aprovada e, uma série de atos, contratos, negócios jurídicos, são feitos com base na MP. Como ficam todos esses atos, contratos e negócios jurídicos? A saída é o Congresso Nacional editar um Decreto Legislativo para regular as relações jurídicas que ocorreram à época da MP.

Exemplo: contrato que estava sendo adimplido com multa por inadimplemento de 2%. Surge uma MP aumentando a multa de 2% para 10%. Naquele mês que a MP estava vigorando, o sujeito se torna inadimplente e paga 10% de multa. 20 dias depois de pagar a multa de 10%, a MP é rejeitada. O Congresso Nacional deverá resolver a situação, regulando as relações jurídicas à época em que a MP estava vigorando.

Por outro lado, o art. 62, §11º, CF, diz que se o Congresso Nacional não editar o Decreto Legislativo em um prazo de 60 dias, contados da rejeição da MP (expressa ou tática), os efeitos da MP conservar-se-ão para as relações jurídicas constituídas com base nela.

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

(...)

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas

A MP já morta vai continuar regendo as relações jurídicas que foram constituídas com base nela até o Congresso Nacional editar o Decreto Legislativo.

d) Prazo de eficácia da MP

O prazo de eficácia da MP é de 60 dias prorrogável uma única vez por mais 60 dias.

Esta prorrogação é automática. No entanto, esta prorrogação é formalizada pelo presidente do congresso nacional, mas apenas serve para dar publicidade.

Lembrando que os prazos não correm durante o recesso.

e) Trancamento de pauta

A medida provisória deverá ser apreciada em até 45 dias, contados da sua publicação.

Se não for apreciada em até 45 dias, entrará em regime de urgência, hipótese em que haverá o trancamento da pauta.



Perceba que o prazo para apreciação é de 45 dias, mas o prazo de eficácia é de 60 dias prorrogável por mais 60 dias. Fora o recesso, que não correrá o prazo.

Atente-se que este prazo de 45 dias para apreciação não é contado no período de recesso, já que não há convocação extraordinária para deliberar sobre as medidas provisórias.

Cabe frisar que, se a câmara não apreciar a medida provisória no prazo de 45 dias, haverá o trancamento da pauta. Mas, caso a câmara resolva apreciar após o esgotamento do prazo de 45 dias, e encaminhe a medida provisória ao senado, esta deliberação já chega trancando a pauta do sendo, eis que este prazo é para todo o trâmite, e não para cada uma das casas.

MP só poderá trancar pauta em projeto de lei ordinária e de matérias que podem ser regradas por MP. Informativo 870, STF.

O art. 62, § 6º da CF/88 afirma que “se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando”. Apesar de o dispositivo falar em “todas as demais deliberações”, o STF, ao interpretar esse § 6º, não adotou uma exegese literal e afirmou que ficarão sobrestadas (paralisadas) apenas as votações de projetos de leis ordinárias que versem sobre temas que possam ser tratados por medida provisória. Assim, por exemplo, mesmo havendo medida provisória trancando a pauta pelo fato de não ter sido apreciada no prazo de 45 dias (art. 62, § 6º), ainda assim a Câmara ou o Senado poderão votar normalmente propostas de emenda constitucional, projetos de lei complementar, projetos de resolução, projetos de decreto legislativo e até mesmo projetos de lei ordinária que tratem sobre um dos assuntos do art. 62, § 1º, da CF/88. Isso porque a MP somente pode tratar sobre assuntos próprios de lei ordinária e desde que não incida em nenhuma das proibições do art. 62, § 1º.

STF. Plenário. MS 27931/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 29/6/2017 (Info 870).

f) Efeitos após a perda de eficácia da medida provisória

Apesar de uma divergência doutrinária, Marcelo Alexandrino e Vicente Pauto entendem que a perda da eficácia da medida provisória gera efeitos *ex tunc*, eis que a norma é retirada do plano normativo desde a sua edição.

A CF só fala que as relações jurídicas realizadas neste período serão regidas pela medida provisória no caso de omissão do CN, que não expediu decreto legislativo que não regulou a matéria.

g) Apreciação plenária

A medida provisória será apreciada nas duas casas separadamente. A câmara é a casa iniciadora obrigatória e o senado é casa revisora obrigatória.

A MP ocorre necessariamente em duas fases:

- (i) 1ª fase: preenchimento dos pressupostos constitucionais: existe relevância e urgência?
- (ii) 2ª fase: mérito da medida provisória

h) Conversão parcial

O texto constitucional trata da conversão parcial da medida provisória, tratando dessa possibilidade.

Segundo o §12 do art. 62, aprovado projeto de lei de conversão (*passou no CN*) alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.



Se há uma conversão parcial, é forçoso convir que houve emenda parlamentar. Neste caso, haverá a transformação da MP num projeto de lei de conversão.

O §12 significa que, se o projeto de lei de conversão é aprovado no poder legislativo, a medida provisória continua integralmente em vigor até que este projeto seja sancionado ou vetado pelo chefe do poder executivo.

i) Reedição

É vedada a sua reedição na mesma sessão legislativa.

O presidente da república não pode reeditar a medida provisória, mas poderá apresentar uma medida provisória que tenha sido objeto de um projeto de lei que foi rejeitado?

NÃO. O presidente da república não pode editar MP para disciplinar projeto de lei que tenha sido rejeitado na mesma sessão legislativa.

Da mesma forma, a matéria de medida provisória revogada por outra medida provisória não poderá ser alvo de nova medida provisória na mesma sessão legislativa.

j) MP sobre direito tributário

A medida provisória pode tratar de direito tributário.

A CF trata expressamente sobre a temática de impostos no art. 62, §2º, dizendo que medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.

Trata-se do princípio da anterioridade tributária, só podendo gerar efeitos no ano seguinte ao da sua publicação.

Se houver uma MP majorando ou instituindo tributos, só fará efeitos no próximo exercício financeiros se ela tiver sido convertida em lei antes de findado o exercício financeiro em que ela foi publicada.

A CF estabelece o princípio da anterioridade tributária. E a CF também trata do princípio da noventena, em que uma lei que institui ou aumenta tributo deverá observar um prazo mínimo de 90 dias.

É necessário conciliar os dois princípios.

k) Intervalo proibitivo de medida provisória (art. 246 da CF)

Segundo o art. 246, é vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive.

Trata-se de um intervalo proibitivo de medida provisória. Ora, entre 1º/01/95 e a EC 32/01, não poderá ser objeto de medida provisória.

l) Medidas provisórias anteriores à EC 32/01

Antes da EC 32/01, não havia essa revogação tácita da eficácia pelo decurso do prazo.

Após a EC 32/01, as medidas provisórias passaram a perder a eficácia com o decurso do prazo.

Para tratar das MP's anteriores à EC 32, o art. 2º dessa emenda constitucional dispôs que as medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação da EC 32/01 continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.

Perceba que esta vigência por prazo indeterminado das MP's anteriores à EC 32 independem de qualquer ato do chefe do executivo ou do congresso, mas continuam sendo medida provisória.



m) Retirada da medida provisória

Segundo o STF, não é possível que o congresso nacional promova a retirada da medida provisória pelo chefe do executivo. O presidente não pode solicitar a retirada da medida provisória submetida à apreciação do congresso nacional.

n) Revogação da medida provisória

Perceba que uma medida provisória pode ser revogada por outra. O STF admite que a medida provisória seja revogada por um ato normativo da mesma espécie.

Nesse caso, fica suspensa a eficácia da medida provisória que foi objeto de revogação por outra medida até que exista o pronunciamento do poder legislativo sobre a medida provisória revogadora.

O PR edita uma MP-1 (prazo de 60 mais 60). Quando a MP-1 está com 40 dias, o PR revoga a MP anterior e edita a MP-2. Neste caso, fica suspensa a eficácia da MP-1, e suspenso o prazo. Com isso, vem a MP-2. Se esta MP-2 é rejeitada, aí continua a correr os outros 20 dias que restavam para a MP-1, podendo ser renovável por mais 60 dias.

Por isso, apenas a suspensão da eficácia da medida provisória revogada pela medida provisória revogadora.

Se a medida provisória revogadora for convertida em lei, haverá uma definitiva revogação da medida provisória inicial.

Do contrário, a medida provisória retoma os seus efeitos e passa a vigorar pelo tempo que lhe restava.

o) Efeitos da medida provisória sobre a lei pretérita

Quando uma MP é editada, e há uma legislação ordinária com ela incompatível, esta legislação tem a sua eficácia suspensa, pois se esta MP for rejeitada, a lei com ela incompatível volta a produzir efeitos.

A MP não tem o condão de revogar a lei, pois ela somente suspende a lei.

Suspendendo a eficácia, a lei permanece no ordenamento jurídico, não produzindo efeitos enquanto a medida provisória tiver os seus efeitos em vigor.

Se esta MP for convertida em lei, aí sim, haverá a revogação da legislação ordinária em sentido contrário.

p) Apreciação judicial dos pressupostos constitucionais da medida provisória

A apreciação judicial dos pressupostos constitucionais da medida provisória, que são a relevância e urgência, possui um caráter político, razão pela qual, via de regra, o poder judiciário não pode se imiscuir.

No entanto, o STF entende que se houver flagrante improcedência ou inexistência de relevância ou urgência, o poder judiciário deverá decidir pela inconstitucionalidade da medida provisória.

q) Lei de conversão e vício de medida provisória

A medida provisória não tinha originariamente relevância ou urgência, mas posteriormente foi convertida em lei, neste caso, estaria suprido os vícios da medida provisória?

Segundo o STF, a lei de conversão não convalida os vícios existentes na medida provisória.

Em outras palavras, se quando a MP está em vigor há uma impugnação à inconstitucionalidade dela, e posteriormente esta MP é convertida em lei, não haverá perda de objeto da ação, que poderá ser apreciado judicialmente.



r) Medida provisória nos estados-membros e nos municípios

Segundo o STF, os estados podem adotar medidas provisórias, mas deverão estar previstas na Constituições Estaduais, devendo observar simetricamente em relação às regras constitucionais.

Com base nesse raciocínio, poderá também os municípios editar medidas provisórias, desde que haja previsão na lei orgânica e observem as regras constitucionais.

s) Considerações finais sobre Medidas Provisórias

Existe a possibilidade de controle de constitucionalidade sobre MP, pois é um ato normativo, ainda que não seja lei (mas com força de lei) e vincula condutas. A inconstitucionalidade material o STF analisa como regra, ou seja, se o conteúdo da MP contrariar o conteúdo da constituição, o STF declara a inconstitucionalidade. Já na inconstitucionalidade formal, o STF entende que deve analisar apenas como exceção, excepcionalmente. A inconstitucionalidade formal envolve os chamados requisitos de relevância e urgência, que são os requisitos formais de uma MP. Ou seja, o eventual descumprimento dos requisitos formais de uma MP só será analisado de forma excepcional pelo STF, pois se entende que tem dever de saber o que é relevante e urgente é o Presidente da República, pois é ele quem a produz. Além disso, num segundo momento ainda se tem o poder legislativo que vai apreciar a MP. O STF pode declarar a inconstitucionalidade formal, mas de forma excepcional, se o Presidente da República incorrer em desvio de finalidade e abuso no poder de legislar.

3.2.8. LEIS DELEGADAS

Lei delegada é uma lei cuja elaboração foi delegada pelo CN ao presidente da república. São leis elaboradas pelo PR que solicita uma delegação ao CN. Essa solicitação é chamada de iniciativa solicitadora.

Nelson de Souza Sampaio vai dizer que a lei delegada é uma delegação externa de função legiferante (função de fazer lei). A lei delegada veio da europa, com a ideia de que o legislador pode estar muito ocupado, cansado, com muitas atividades e delegaria ao executivo a faculdade de elaborar leis sobre determinados temas.

As leis delegadas não poderão tratar das seguintes matérias:

- (i) atos de competência exclusiva do Congresso Nacional
- (ii) atos de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal
- (iii) matéria reservada à lei complementar
- (iv) legislação sobre organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros
- (v) legislação sobre nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais
- (vi) legislação sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos

É possível lei delegada a respeito de direito processual civil, direito penal, direito civil, direito processual penal, direito comercial, etc.

Congresso vai apreciar a delegação e pode aprová-la. Essa aprovação se dará por meio do quórum de maioria simples.

A lei delegada terá status de lei ordinária. O Congresso aprecia e aprova a delegação e esta virá sob a forma de uma resolução do Congresso, que enumerará os conteúdos limitados e termos específicos para o seu exercício, na forma do art. 68, §2º, CF.



Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.

(...)

§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.

A delegação pode ser:

(i) Delegação típica (ampla ou própria): o CN delega ao presidente plenos poderes para elaborar a lei. Não há participação posterior do poder legislativo, pois é o presidente que edita, promulga e publica a lei.

(ii) Delegação atípica (estrita ou imprópria): O projeto voltará ao Congresso, que aprovará ou não, através de uma votação única e unicameral, o projeto de lei sem possibilidades de emenda. O legislativo deverá aprovar o projeto de delegação, hipótese em que a lei deverá ser promulgada e publicada pelo presidente. Se o Congresso Nacional rejeita o projeto de lei do Presidente da República, arquiva-se. Se o Congresso Nacional aprova o projeto de lei do Presidente da República, este irá promulgá-la e publicá-la.

O presidente da república não é obrigado a publicar ou elaborar a lei, em decorrência da delegação do CN.

Por outro lado, o ato de delegação não impede que o CN venha a cuidar da matéria por meio de lei, hipótese em que será revogada a delegação.

Observação: existe um controle político sobre a lei delegada realizado pelo Congresso Nacional, nos termos do art. 49, V, CF.

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

(...)

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

Caso o presidente exorbite a delegação do CN, o poder legislativo poderá sustar os efeitos da delegação legislativa. Esta é a conduta que cabe ao CN em caso de exorbitância dos limites da delegação. Trata-se de um efeito *ex nunc*, não retroagindo, em razão de ter havido a sustação da eficácia.

Esse controle legislativo que o CN faz é um controle de natureza política, sendo denominado pela doutrina de veto legislativo.

3.2.9. DECRETOS LEGISLATIVOS

São atos normativos proveniente do Congresso Nacional. Os decretos legislativos tratam de matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional.

Exemplo 1: art. 62, §3º, quando a medida provisória é rejeitada, expressa ou tacitamente, haverá perda de eficácia desde sua edição e haverá um decreto legislativo do Congresso Nacional para regular as relações jurídicas que ocorreram à época da MP.

Exemplo 2: art. 49, V, CF, quando o Congresso Nacional susta uma lei delegada que exorbitou os limites da delegação legislativa, que o próprio Congresso deu ao Presidente, mediante resolução do Congresso, a sustação se dá por Decreto Legislativo.

Exemplo 3: quando o Presidente da República vai se ausentar do país por mais de 15 dias, deverá pedir autorização do Congresso, que virá por um decreto legislativo.

A iniciativa é de membros do Congresso Nacional (Deputados, Comissão de Deputados, Mesa da Câmara; Senadores, Comissão de Senadores, Mesa do Senado).

Na fase constitutiva, a aprovação se dá pelo Congresso Nacional.

Na fase complementar, a apromulgação do decreto se dá pela Mesa do Congresso Nacional pelo Presidente do Congresso Nacional.



O Presidente da República não participa desse processo. Não há sanção ou veto do Presidente da República.

A Câmara, Senado e o próprio Congresso Nacional tratam do tema por meio de Resoluções.

Dentre as funções do decreto legislativo, previstas no art. 49, é possível destacar:

- (i) resoluções definitivas de tratados internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
- (ii) regulação dos efeitos da medida provisória quando não convertida em lei;
- (iii) aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

A regulamentação do decreto legislativo emana diretamente da Constituição, sendo, portanto, um ato normativo primário.

A CF não regula especificamente do decreto legislativo, sendo regulamentado pelos regimentos internos.

3.2.10. RESOLUÇÕES

É uma espécie normativa primária de competência privativa do Congresso Nacional ou privativa da Câmara ou do Senado, e que veicula matérias, em regra, com efeitos internos ao poder legislativo. Vão dispor sobre assuntos políticos e administrativos de sua competência, desde que não estejam sujeitos à lei.

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

(...)

VII – Resoluções.

Exemplo: Regimento Interno das Casas, que é aprovado por resolução da Casa.

Existem exceções de resoluções com efeito interno, que também tem efeito externo. Por exemplo, o art. 51, CF, traz que o Presidente da República vai ter, no processo de crime de responsabilidade, a necessidade da apreciação pela Câmara dos Deputados (admissibilidade na Câmara), para que ele seja processado no Senado. Essa aprovação vem por meio de uma resolução da Câmara, com quórum de 2/3. Essa resolução possui efeitos externos. É uma resolução do legislativo para o executivo.

Outro exemplo é o disposto no art. 68, §2º, CF, uma resolução do Congresso Nacional que autoriza o Presidente fazer lei delegada. Resolução que determina as condições, os termos, para que o Presidente da República possa produzir lei delegada. É uma resolução de efeitos externos pois é o legislativo autorizando o executivo a fazer a lei delegada.

Há ainda outros dispositivos constitucionais que falam sobre resolução, como é o caso da lei delegada, a qual é realizada por meio de resolução do CN.

Outro caso é a fixação de alíquotas do IPVA, as quais são fixadas por resolução do senado.

Há ainda o caso de suspensão da lei declarada inconstitucional pelo STF, que se dá por meio de resolução (art. 52, X).

Este procedimento não é tratado pela CF, ficando a cargo dos regimentos internos.

Se a resolução for o Congresso Nacional, a iniciativa é de qualquer membro, comissão ou Mesa do Congresso. Na fase constitutiva, a aprovação se dá pelos membros do Congresso e a promulgação se dá pelo Presidente do Congresso.



Se for uma resolução do Senado, a iniciativa envolve só senadores. Na fase constitutiva a aprovação se dá no Senado e a promulgação será pelo Presidente do Senado com a sua Mesa (Mesa do Senado).

Se for uma resolução da Câmara, a iniciativa envolve só deputados, ou comissão de deputados ou Mesa da Câmara. Na fase constitutiva a aprovação se dá na Câmara e a promulgação será pelo Presidente da Câmara com a sua Mesa (Mesa da Câmara).

Fica tudo dentro do Parlamento.

O Presidente da República não participa desse processo. Não há sanção ou veto do Presidente da República.

Observações: existem das grandes diferenças entre decretos legislativos e resoluções.

→ Os decretos legislativos são de competência exclusiva do Congresso Nacional. As resoluções podem ser ou do Congresso, ou só da Câmara ou só do Senado.

→ Decretos Legislativos, em regra, possui efeitos externos. Resoluções, em regra, possuem efeitos internos.

Sobre sanção ou veto, importante salientar que não há em: Proposta de Emenda Constitucional (PEC), Lei Delegada, Decretos Legislativos e Resoluções.

3.2.11. PROCESSO LEGISLATIVO NOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS

Basicamente, as regras do processo legislativo da CF são de observância obrigatória dos estados membros, distrito federal e municípios.

Portanto, as regras básicas, como é o caso do quórum de 3/5 para emenda constitucional, em dois turnos, devem ser observadas.

Esta regra vale para iniciativas, processos legislativos, vedações, deliberações, etc.

g) Relação hierárquica entre as espécies normativas

Prevalece o entendimento que não existe relação hierárquica entre os atos normativos, salvo as emendas constitucionais.

Há ainda os tratados internacionais recebidos com quórum de emenda constitucional também teriam força de emenda constitucional, possuindo um nível hierárquico superior.

A CF considera o princípio da especialidade, devendo cada matéria ser tratada por um ato normativo específico a depender do caso.

Havendo a invasão de um ato normativo sobre o campo de atuação de outro ato normativo, haverá inconstitucionalidade. Por exemplo, o CN não pode, por meio de lei, delegar à presidente da república a autorização para elaborar a lei delegada. Esta delegação deve se dar por meio de resolução.

Outra discussão é a divergência entre lei complementar e lei ordinária. No entanto, apesar de que a LC possui a necessidade de ser aprovada por maioria absoluta e a LO exigir maioria simples, não há hierarquia entre elas.

Se uma matéria deveria ter sido tratada por LO, mas acaba sendo tratada por LC, não haverá inconstitucionalidade, apesar do princípio da especialidade. Isso porque se uma LC trata de uma matéria de LO, esta lei é válida, pois quem pode mais poderá o menos. Todavia, apesar de ser formalmente ser LC, esta lei será materialmente LO. Isto significa que se uma LO posterior alterar a LC, será plenamente constitucional, pois materialmente é uma LO.

3.2.12. DECRETOS AUTÔNOMOS

Como se sabe, os decretos regulamentares não inovam na ordem jurídica, sendo atos infralegais, pois sua atuação se restringe a fiel execução das leis.

Todavia, a EC 32/01 criou o chamado decreto autônomo.

Este decreto autônomo tem competência emanada diretamente da CF. Neste caso, o PR, com competência privativa, poderá dispor sobre a organização e funcionamento da



administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Grave, não poderá o PR extinguir órgãos!

Mas, o PR poderá dispor, por meio de decreto autônomo, sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

O PR poderá delegar aos Ministros de Estado, ao PGR e ao AGU para que tratem via decreto autônomo sobre estes temas.

Por força do princípio federativo, esta ideia de decretos autônomos é aplicável no âmbito dos estados, DF e municípios.

3.2.13. HIERARQUIA ENTRE LEIS FEDERAIS, ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS

Não existe hierarquia entre leis federais, estaduais, distritais e municipais.

No caso de conflito entre as leis, deverá haver a análise pelo princípio da predominância do interesse, de modo que se a lei tiver um cunho eminentemente local, haverá inconstitucionalidade de uma lei federal, por exemplo.

3.2.14. TRATADOS INTERNACIONAIS E SUAS RELAÇÕES COM AS DEMAIS ESPÉCIES NORMATIVAS

A CF estabelece que compete privativamente ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.

O sistema de intimação dos tratados seguem os seguintes passos:

1. presidente da república celebra
2. é encaminhado para o CN, publicando-se o decreto legislativo
3. presidente promulga, por meio de um decreto, o texto publicado pelo legislativo
4. com essa promulgação, o tratado passa a ter vigência

Os tratados internacionais são normas primárias com status de lei ordinária.

Mas os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem status supralegal, estando acima da lei. Neste caso, torna-se inaplicável a legislação ordinária anterior ou posterior.

No entanto, sendo esses tratados internacionais sobre direitos humanos incorporado na forma do art. 5º, §3º. Neste caso, terão status de emenda constitucional.

3.2.15. CONTROLE JUDICIAL DO PROCESSO LEGISLATIVO

Não é comum, tendo um caráter excepcional. Trata-se de um controle preventivo, o que contraria a regra de que o STF atua num controle repressivo.

Este controle é preventivo, pois atua num projeto de lei ou projeto de emenda.

Só pode incidir sobre aspectos formais e procedimentais da atuação legislativas em duas hipóteses apenas:

- (I) PEC ofensiva à cláusula pétrea
- (II) PEC ou PL violar o processo legislativo constitucional

Este controle judicial preventivo só é possível na via incidental. É preciso que o parlamentar impetre o mandado de segurança, sob a alegação de que teriam o direito líquido e certo de não participar de uma deliberação que afronte flagrantemente a Constituição.

O controle judicial não pode alcançar norma meramente regimental, devendo somente alcançar a CF, pois, neste caso, o STF não poderia ingressar no juízo de matéria interna corporis.

3.2.16. MODIFICAÇÃO DA CF/88

A doutrina diferencia o que seria mutação e reforma constitucional:

1. mutação constitucional: é um procedimento informal de mudança da CF. É um poder paulatino e difuso. Todos os autores da comunidade política participam dessa mutação, mas o Poder Judiciário apenas reconhece.



2. reforma constitucional: é um procedimento formal e solene de alteração da CF.

O min. Gilmar Mendes sustenta que o art. 52, X, sofreu uma mutação constitucional, pois esta resolução do senado para suspender a execução da lei seria desnecessária, visto que bastaria ao STF reconhecer no caso concreto que a norma é inconstitucional que ela já teria perdido a validade. Mas esta posição é minoritária. A doutrina contrária a este entendimento sustenta que esta posição do min. Gilmar Mendes seria uma manipulação inconstitucional.

O ministro Gilmar Mendes inclusive admite que o Senado possa retirar a eficácia de lei, decreto ou, ainda, outro ato normativo de diferente denominação (ex.: Resolução da Câmara). Essa atuação do Senado abrange atos federais, estaduais, distritais e municipais.

A reforma constitucional, como dito, é um processo forma, podendo se dar através do poder constituinte derivado reformador, bem como através do poder constituinte derivado revisor, sendo certo que este já foi exaurido.

(I) revisão constitucional

(II) emenda constitucional

i. Revisão constitucional

A revisão constitucional é norma prevista no ADCT, cuja eficácia foi exaurida.

Segundo o art. 3º do ADCT, a revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.

Percebe-se que são requisitos da revisão:

(I) realização 5 anos após a promulgação da CF

(II) voto da maioria absoluta do CN

(III) sessão unicameral, isto é, seria necessário a maioria absoluta dos parlamentares, independentemente se é senador ou deputado.

A revisão constitucional se encerrou em julho de 1994, tendo uma tímida reforma de apenas 6 emendas de revisão. As emendas de revisão foram promulgadas pela mesa do CN, pois se trataria de sessão unicameral, diferentemente da promulgação das emendas constitucionais que exige que sejam promulgadas pela mesa do senado e pela mesa da câmara.

- É possível que o poder constituinte derivado reformador crie um novo procedimento de revisão?

NÃO. Isso porque se isto for permitido haverá fraude à Constituição. O poder constituinte originário assim determinou, não podendo criar uma nova revisão constitucional.

O STF enfrentou o tema na esfera do poder legislativo estadual, não é possível a Constituição do Estado criar uma revisão constitucional. Aliás, a forma de se alterar a constituição dos estados é a mesma da constituição federal, não podendo ser um procedimento menos rígido ou mais rígido.

ii. Emenda constitucional

A emenda à constituição é um procedimento formal, possuindo duas finalidades:

(I) assegurar a estabilidade do texto constitucional

(II) permitir que o texto se atualize com as mudanças sociais

A alteração de emenda se dá através de proposta de emenda pelos legitimados:

(I) 1/3 dos membros do senado ou da câmara

(II) presidente da república

(III) mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se cada um por maioria relativa

Apresentada a discussão em cada uma das casas, em dois turnos, deve haver votação por 3/5. A promulgação é pela mesa da câmara e do senado.

Sendo rejeitada o projeto de emenda, ela será arquivada. A matéria rejeitada não poderá ser proposta novamente na mesma sessão legislativa.



3.2.17. LIMITAÇÕES AO PODER DE REFORMA

A reforma da CF tem limitações que o poder constituinte originário impôs, podendo ser classificadas em:

1. limitações temporais
2. limitações circunstanciais
3. limitações processuais ou formais
4. limitações materiais

a) Limitações temporais

As limitações temporais são impedimentos de alterações constitucionais em determinados momentos.

A CF diz que é vedada a alteração da constituição durante um certo lapso de tempo. Esta limitação temporal não existe na nossa constituição.

O art. 60 da CR/88 não estabeleceu nenhuma limitação temporal. O art. 3º do ADCT, no entanto, é uma limitação temporal (aplicável ao poder revisor, não ao reformador).

b) Limitações circunstanciais

As limitações circunstanciais são aquelas em que determinadas circunstâncias não é possível a alteração da CF. Isso se dá quando o país passa por situações de anormalidades e excepcionalidades, como é o caso do estado de sítio, intervenção federal e estado de defesa.

c) Limitações processuais ou formais

As limitações processuais dizem respeito ao procedimento, podendo ser dividido em:

- limitações quanto à iniciativa
- limitações quanto à deliberação
- limitações quanto à promulgação
- limitações quanto à vedação de reapreciação da emenda rejeitada

d) Limitações quanto à iniciativa

Somente os legitimados poderão apresentar a proposta de emenda:

1. presidente da república
2. 1/3 dos membros da câmara ou senado
3. mais de metade das AL's, manifestando-se cada uma por maioria simples.

Município não pode propor. O cidadão também não pode propor, ainda que José Affonso da Silva pense que possa, sob alegação da soberania popular.

e) Limitações quanto à deliberação

Para aprovar uma emenda é preciso que seja discutida em cada casa, em dois turnos, sendo necessário em cada uma dessas deliberações a votação e 3/5 dos votos.

Perceba-se que, no caso de emenda, não se fala em casa revisora. A segunda casa recebe o texto da emenda constitucional e poderá fazer alterações substanciais, caso em que o texto voltará para a primeira casa, a qual deverá novamente votar em 3/5, em dois turnos. Se a primeira casa vota, mas faz algumas alterações, aí deverá passar pela segunda casa o novo texto para votação em 3/5, em dois turnos. Ou seja, o texto final da emenda passou em cada uma das casas com a votação de 3/5, em dois turnos.

Atente-se que o que foi dito serve para alteração substancial, eis que o STF decidiu que se houver alteração que não seja substancial poderá ser encaminhado para a promulgação.

Segundo o STF, não contraria a CF a proposta de emenda aprovada em dois turnos em sessões sequenciais, pois a Constituição não determina interstício mínimo (ADI 4425).



f) Limitações quanto à promulgação

As emendas são promulgadas pelas mesas da câmara e do senado conjuntamente.

g) Limitações quanto à vedação de reapreciação da emenda rejeitada

As emendas rejeitadas ou arquivadas não podem ser objeto de deliberação na mesma sessão legislativa.

h) Limitações materiais

Significa que determinadas matérias não podem ser abolidas. Neste caso, há a divisão em dois grupos:

- limitações explícitas
- limitações implícitas

i) Limitações materiais explícitas

Nas limitações materiais explícitas, o constituinte diz expressamente que é vedada a supressão.

O art. 60, §4º, estabelece que não será objeto de deliberação, o que justifica a impetração de MS pelos parlamentares, a proposta de emenda tendente a abolir:

- forma federativa de Estado: não é possível que o Brasil se torne província, pois o estado é unitário, sendo cláusula pétrea
- voto direto, secreto, universal e periódico
- separação dos Poderes
- direitos e garantias individuais

j) Limitações materiais implícitas

Nas limitações materiais implícitas, a CF não diz o que está limitado ao poder constitucional de reforma.

As limitações implícitas são:

- Art. 60, §4, da CF: é uma cláusula pétrea implícita: o artigo que consagra as cláusulas pétreas não pode ser suprimido;
- Art. 60, §2, da CF: consagra o procedimento de alteração da CF, também é cláusula pétrea implícita. Isso porque, se houvesse alteração, haveria uma ruptura da ordem constitucional.

- A expressão “não será objeto de deliberação”

A expressão “não será objeto de deliberação” dá azo ao congressista ingressar com MS em face ao processo legislativo de emenda, pois é direito líquido e certo do parlamentar não ser submetido a essa votação.

A ideia do MS impetrado por parlamentar é justamente impedir que o processo legislativo prossiga, devendo ser trancado. Isso é tão evidente que, se houver a aprovação do projeto de emenda constitucional durante o trâmite do MS, haverá perda do objeto do processo, pois já findou o processo legislativo.

- A expressão “tendente a abolir”

A expressão “tendente a abolir” significa que a emenda constitucional poderá tratar de direitos e garantias individuais, porém não pode buscar a supressão ou a abolição desses direitos e garantias.



Exemplo seria o art. 5º, o qual estabelece que a todos são assegurados a razoável duração do processo. Nesse caso, o poder constituinte reformador criou um direito individual, motivo pelo qual a emenda foi plenamente constitucional.

- Vedação à “dupla revisão” ou “dupla reforma”

Essa teoria possibilita que sejam modificados os limites constitucionais de reforma constitucional, através de uma “dupla revisão”. Por exemplo, já que não é possível abolir um direito fundamental, por se tratar de uma cláusula pétrea (art. 60, § 4, IV, CF), revoga-se o artigo 60, § 4, IV, CF.

Para uma corrente, a CF permite a dupla reforma. Para esses constitucionalistas, o art. 60, §4, somente apresenta uma rigidez maior, pois para modificá-las seria necessário uma dupla alteração.

Primeiro, revoga aquilo que diz o que é cláusula pétrea. Em seguida, em razão de não haver mais aquela proibição de alteração constitucional, é possível que aquilo seja suprimido por uma nova emenda constitucional.

A tese da dupla revisão não é aceita pela doutrina majoritária, pois o art. 60 seria uma cláusula pétrea implícita.

Segundo essa teoria, também seria possível fazer uma nova revisão constitucional no Brasil. Para tanto, bastaria modificar o artigo 3º, do ADCT (que prevê apenas uma revisão constitucional). Feita essa “primeira etapa”, as portas estariam abertas para novas revisões.

3.2.18. APLICABILIDADE IMEDIATA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS E A RETROATIVIDADE MÍNIMA

O STF entende que as emendas possuem aplicação imediata e retroatividade mínima. Na retroatividade mínima, a norma alcança os efeitos futuros de fatos celebrados no passado.

3.2.19. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E POSTERIOR EMENDA CONSTITUCIONAL

Segundo o STF, caso a Corte declare a inconstitucionalidade de uma lei e posteriormente o Poder Legislativo edite uma nova lei com idêntico conteúdo da anterior, essa norma nascerá com presunção de inconstitucionalidade, cabendo ao legislador demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente se afigura legítima.

Todavia, esta regra não se aplica à emenda constitucional, a qual, segundo o STF, será legítima, em qualquer caso, desde que respeite os parâmetros do artigo 60 da CF.

2. PODER EXECUTIVO

Composto pelo Presidente da República, pelo Vice-Presidente da República, os Ministros, Conselho da República e o Conselho de Defesa. Além dessa estrutura, temos ainda a Lei 13.502/2012, relativa à estrutura infraconstitucional, bem como a MP 821/2018, que determinou o Ministério extraordinário da segurança pública, dividindo o Ministério da Justiça.

2.1. NOÇÃO DE PRESIDENCIALISMO

O Brasil adota o presidencialismo como sistema de governo.

O presidencialismo tem como característica das funções executivas concentradas no presidente da república, além da separação rígida das funções do executivo e do legislativo, ao contrário do parlamentarismo.

Presidente da república exerce a função de:

- (I) chefe de estado
- (II) chefe de governo



(III) chefe da administração pública federal

2.2. FUNÇÕES DO PODER EXECUTIVO

As **funções típicas** são estudadas no campo do direito administrativo, que são as funções de fomento, gerenciamento da máquina administrativa, execução de políticas públicas, etc. A função de governo, de tomada de decisões, é apenas uma parte das funções do executivo, enquanto as demais são de administração, que se divide em atividades de intervenção, fomento e de serviço público

Já sobre as **funções atípicas**, o Poder Executivo realiza uma função que é típica do poder Legislativo e do poder Judiciário.

No exercício da função típica legislativa edita medidas provisórias, entre outras atribuições enumerados nos arts. 62 e 68, CF.

Na função atípica judicial, o poder executivo exerce o contencioso administrativo. Atividade esta que não há no Brasil, salvo no caso de direito desportivo. Ademais, o contencioso administrativo não é uma função judicial propriamente dita, não fazendo coisa julgada formal nem material (como na função judicial *stricto sensu*), não tem a equidistância (juiz é um terceiro na relação entre autor e réu, sendo também neutro).

2.3. INVESTIDURA

O Presidente da República e o Vice-Presidente são eleitos pelo sistema majoritário. Este sistema é dividido em:

1. **Sistema puro e simples:** o candidato é eleito pelo maior número de votos, sendo aplicado aos senadores e prefeitos de municípios com até 200 mil eleitores.
2. **Sistema majoritário de dois turnos:** o candidato é eleito se tiver maioria absoluta dos votos válidos (se exige 50% mais 1 dos votos válidos para que o indivíduo seja eleito). Nesse caso, não necessariamente haverá dois turnos, pois se alcançar no primeiro turno essa maioria absoluta dos votos, não haverá segundo turno. Este sistema é realizado para o presidente da república, governadores e municípios com mais de 200 mil eleitores.

O presidente é eleito simultaneamente com o vice.

O mandato é de 4 anos, permitida a reeleição para um único período subsequente. Se há um intervalo de 4 anos, em que não é presidente e nem vice, poderá se candidatar novamente à presidência.

Essa possibilidade de reeleição veio com a Emenda Constitucional 16/97. Esse mandato inicialmente não era de 4 anos, mas sim de 5 anos, sendo alterado pela Emenda Constitucional 5/94, que modificou o mandato de 5 para 4 anos.

Em 1891, 1934 o mandato era de 4 anos. Em 1937, o mandato foi para 6 anos. Em 1946 e 1967 o mandato era de 5 anos. A Emenda Constitucional 8, no regime militar, aumentou para 6 anos o mandato. Já em 1988, o mandato inicialmente era de 5 anos, e, logo em seguida, a Emenda Constitucional 5/94 alterou de 5 para 4 anos. Ainda sobre a Constituição de 1988, a Emenda Constitucional 16/97 possibilitou a reeleição em um mandato de 4 anos.

São requisitos para o cargo de presidente e vice-presidente da república:

- (1) brasileiro nato
- (2) gozo dos direitos políticos
- (3) alistamento eleitoral
- (4) filiação partidária
- (5) no mínimo 35 anos
- (6) não ser inelegível (inelistável, analfabeto, não ser candidato reeleito a uma 3ª reeleição, não possuir inelegibilidade por parentesco)



As eleições ocorrerão em outubro, no primeiro domingo, em primeiro turno e se nenhum dos candidatos alcançar 50% mais 1 dos votos válidos, far-se-á uma eleição no último domingo de outubro, com os dois candidatos mais votados, com seus respectivos vices, para a eleição do segundo turno.

Supondo que houve o primeiro turno, mas no segundo turno o segundo candidato mais votado morre ou desistiu, ou ainda surgiu um impedimento legal. Neste caso, deverá ser chamado o terceiro mais votado. Caso dois candidatos estejam empatados em terceiro lugar, deverá ser chamado o mais idoso.

Isso é diferente da situação de morte de um candidato já eleito para o cargo de presidente. Se o presidente morre após a eleição, mas antes da diplomação, neste caso, o vice-presidente é considerado eleito.

A posse do presidente e do vice-presidente acontece no dia 1º de janeiro em sessão conjunta do CN. Se passar 10 dias sem que o presidente e o vice assumam, salvo motivo de força maior, os cargos serão considerados vagos, mediante declaração será feita pelo Congresso Nacional.

2.4. IMPEDIMENTOS E VACÂNCIAS

A CF vai dizer que quem substitui o presidente no caso de impedimento, ou sucede no caso de vaga, é o vice-presidente da república.

2.4.1. IMPEDIMENTOS

Impedimentos são afastamentos temporários do presidente da república.

Dispõe a CF que o presidente e o vice não podem se ausentar do país por mais de 15 dias, sem autorização do CN, sob pena de perda do cargo.

Só é possível se houver licença do CN.

O STF entende que esta regra é de observância obrigatória pelos estados membros, razão pela qual o governador não pode passar mais de 15 dias fora do estado, sem que haja autorização da AL.

2.4.2. VACÂNCIA

A vacância é um afastamento definitivo do presidente (morte, renúncia, perda do cargo etc.). Neste caso, em regra, quem assumirá será o Vice-Presidente da República.

Caso haja impedimento do presidente ou do vice-presidente, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência:

- (A) Presidente da Câmara
- (B) Presidente do Senado
- (C) Presidente do STF

Nesse caso, há plena autonomia, podendo até mesmo demitir ministros de estado.

Cabe atentar que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os substitutos eventuais do Presidente da República a que se refere o art. 80 da CF/88, caso ostentem a posição de réus criminais perante o STF, ficarão impossibilitados de exercer o ofício de Presidente da República. No entanto, mesmo sendo réus, podem continuar na chefia do Poder por eles titularizados (Inf. 850, STF). Em outras palavras, o STF na ADPF 402/2016 decidiu que Presidente da Câmara ou Presidente do Senado, se estiverem sendo objeto de ação penal no STF, eles não ficarão afastados dos cargos de presidentes das casas, mas serão afastados da linha sucessória, sendo impedidos de participar da linha sucessória. Ex: o Presidente do Senado Renan Calheiros tornou-se réu em um processo criminal; logo, ele não poderá assumir a Presidência da República na forma do art. 80 da CF/88; porém, ele pode continuar normalmente como Presidente do Senado, não precisando ser afastado deste cargo.



O fundamento disso é simples: o Presidente da República se estiver sendo réu em ação penal no STF, após autorização da Câmara dos Deputados por 2/3 de seus membros, fica afastado de suas funções por 180 dias nos termos do art. 86, CF.

Somente o vice-presidente pode suceder definitivamente o presidente da república.

Diante da falta definitiva do Presidente e do Vice-Presidente da República, estaremos diante de uma dupla vacância. Neste caso, pela linha sucessória, sendo possível, assume o Presidente da Câmara, na sua falta o Presidente do Senado ou o Presidente do STF.

O Presidente da Câmara assume temporariamente, com o objetivo literal da constituição (art. 81, CF), de convocar novas eleições.

A nova eleição poderá ocorrer de duas formas distintas:

1. Vacância dos dois cargos nos dois primeiros anos: é feita uma nova eleição direta no prazo de 90 dias após a vacância do último cargo
2. Vacância dos dois cargos nos dois últimos anos: a eleição para presidente da república é feita pelo Congresso Nacional, acontecendo nos 30 dias seguintes à vacância do último cargo.

Nessas eleições quem poderá concorrer é qualquer um que preencher os requisitos eleitorais para ser Presidente da República.

Quem ganhar essa eleição, seja ela direta ou indireta, somente irá completar o período dos antecessores. Estamos diante do “mandato tampão”, que serve somente para completar o período restante dos 4 anos.

Essa norma, segundo o STF, não é de observância obrigatória pelas Constituições dos Estados e pelas Leis Orgânicas dos Municípios, pois faz parte da autonomia dos estados membros, da sua auto-organização decidir se vai ter a mesma regra da CF para Governador do Estado ou não.

Em que pese a competência para legislar sobre direito eleitoral seja privativa da União, entendeu-se na ADI 4309/09 que a legislação que regulamentaria essa eleição indireta seria uma regulamentação não propriamente eleitoral, mas sim da organização administrativa do Estado, do auto Governo, da auto-organização do estado, seguindo a lógica do federalismo.

Outra observação importante é a que consta do Informativo 893, STF. A decisão é da ADI 5525/DF. O STF enfrentou a recente alteração do art. 224, §4º, Código Eleitoral, que traz uma assertiva sobre a questão de eleições temporâneas, de vacância dupla, diferente do que traz o art. 81, CF, para Presidente da República, e também diferente do que traz o art. 56, CF, para os Senadores.

A Lei nº 13.165/2015 (minirreforma eleitoral de 2015) inseriu os §§ 3º e 4º ao art. 224 do Código Eleitoral. O § 3º prevê que “a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados.” O STF declarou a inconstitucionalidade da expressão “após o trânsito em julgado” e decidiu que basta a exigência de decisão final da Justiça Eleitoral. Assim, concluído o processo na Justiça Eleitoral (ex: está pendente apenas recurso extraordinário), a nova eleição já pode ser realizada mesmo sem trânsito em julgado. O § 4º, por sua vez, determina que: § 4º A eleição a que se refere o § 3º correrá a expensas da Justiça Eleitoral e será: I - indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis meses do final do mandato; II - direta, nos demais casos. O STF afirmou que esse § 4º deveria receber uma interpretação conforme a Constituição, de modo a afastar do seu âmbito de incidência as situações de vacância nos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, bem como no de Senador da República. Vale ressaltar que a regra do § 4º aplica-se aos cargos de Governador e Prefeito. STF. Plenário. ADI 5525/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 7 e 8/3/2018 (Info 893)



O STF decidiu que para Presidente da República prevalece a Constituição (art. 81, CF), não se aplicando o Código Eleitoral, com a mini-reforma eleitoral, para Presidente da República. E para os Senadores vigora o art. 56 da Constituição, que diz que ocorrendo a vaga do senador e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenche-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato.

A reforma eleitoral, nos termos do informativo 893 do STF, não se aplica, no sistema majoritário, para Presidente da República e Senador.

Para Governador e Prefeitos depende de qual será a regra a ser adotada, se o código eleitoral ou a constituição estadual ou lei orgânica do município. Se a dupla vacância tiver razões eleitorais, como por exemplo, Governador e Vice-Governador ou Prefeito e Vice-Prefeito, perderam o mandato por compra de votos, por uma decisão da Justiça Eleitoral, aplica-se o código eleitoral.

Mas se a vacância, do Governador ou Vice-Governador ou Prefeito e Vice-Prefeito, tiver causas não eleitorais, como por exemplo, a morte do Governador e seu vice durante o mandato, aplica-se a regra prevista nas constituições estaduais (Governador e seu vice) ou lei orgânica do município (Prefeito e seu vice). Aqui se trata de matéria político-administrativa e nesse caso os entes possuem autonomia.

2.5. ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

As competências privativas do PR estão previstas em **rol exemplificativo** do art. 84 da CF:

- nomear e exonerar os Ministros de Estado;
- exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;
- iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;
- sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
- vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
- dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
- dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
- manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;
- celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
- decretar o estado de defesa e o estado de sítio;
- decretar e executar a intervenção federal;
- remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias;
- conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei: a anistia, que é por meio de lei, é de atribuição do CN. Comutar é abrandar a pena.
- exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;
- nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral



da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei;

- nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União;
- nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;
- nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;
- convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;
- declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;
- celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;
- conferir condecorações e distinções honoríficas;
- permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
- enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;
- prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior: trata-se de corolário do princípio republicano.
- prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;
- editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62;
- exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.

Em regra, tais competências são indelegáveis, salvo nos casos em que o Presidente da República delegar aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União as seguintes atribuições:

- dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
- dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
- conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;
- prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;

Cabe ressaltar que uma dessas hipóteses delegada é a própria ideia de decreto autônomo, que é ato normativo primário. O ministro de estado, PGR ou AGU, poderão dispor dessas atribuições.

O STF entendeu que essa autorização que o art. 84, p.º, de provimento de cargo público na forma da lei também implica delegação de competência para o caso de desprovimento do cargo. À luz da CF, é possível que o ministro de estado venha a demitir alguém, se houver a delegação do PR nesse sentido.

O importante desse rol é identificar que possui funções de chefia de estado (incisos VII, VIII e XIX, por exemplo), chefia de governo (incisos I, III, IV, IX, etc, por exemplo), e chefia da administração pública federal (incisos II, VI, por exemplo). Por isso o nosso sistema de governo é o presidencialismo, onde há uma clara identidade entre chefia de estado e chefia de governo. Ou seja, o Presidente da República é aquele que representa internacionalmente o país, que exerce o simbolismo do país, corporifica a unidade interna do país e o representa internacionalmente e, ao mesmo tempo, na chefia do governo, executando as políticas públicas, gerenciando e fomentando a máquina, nomeia e exonera ministros, veta projeto de lei, expede decretos para fiel execução de leis, etc.



O Presidencialismo é diferente do Parlamentarismo. No parlamentarismo há uma não identidade entre chefia de estado e chefia de governo, porque o chefe de estado, aquele que representa o país simbolicamente é, caso seja uma república, o Presidente, ou, se for a Monarquia, o Rei ou Rainha. O chefe de governo é o chamado Primeiro Ministro. Há uma diferença entre quem representa o país e quem o efetivamente governa.

Na Alemanha e na Itália o sistema de governo é o parlamentarista com uma forma de governo republicano. Já na Espanha e Inglaterra, temos um sistema de governo parlamentarista com a forma de governo monarca.

No Brasil o sistema de governo é o presidencialista (forma de governo é a república). Já existiu parlamentarismo no Brasil, nossa forma de governo republicana, desde a proclamação da república até os dias atuais, já existiu parlamentarismo, na década de 60, entre os anos de 1961 a 1963, por cerca de um ano e meio. Na época o presidente da República era João Goulart e Tancredo Neves foi o Primeiro Ministro nessa época.

2.6. VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Os requisitos para ser vice-presidente são os mesmos para ser presidente. O modo de investidura é conjuntamente com o presidente da república, ou seja, se eleger o presidente se eleger o seu vice também. Mas nem sempre foi assim. Por exemplo nas eleições da década de 60, se podia votar o presidente de uma chapa e o vice de outra chapa. Por exemplo, Jânio Quadros foi eleito presidente da república em 1960/1961 por uma chapa e João Goulart foi eleito vice por outra chapa.

As atribuições do vice-presidente não estão no art. 84, CF. O vice-presidente possui funções próprias e impróprias.

As próprias são: substituir o presidente da república na falta deste, sucessão do presidente da república (morte, impeachment, renúncia), participação do Conselho da República e Conselho de Defesa (órgãos de consulta do presidente da república, arts 89 a 91, CF) e outras funções atribuídas por legislação complementar (art. 79, CF).

As impróprias são funções especiais a serem designadas pelo Presidente da República, não havendo uma definição legal ou infraconstitucional dessas funções.

2.7. MINISTROS DE ESTADO

Ministros de estado são auxiliares do presidente da república, sendo escolhidos livremente por ele. Os ministros são demissíveis *ad nutum*, sem necessidade de motivação.

São requisitos para ser ministro de estado:

- brasileiro, nato ou naturalizado, salvo no caso do ministro da defesa (só pode ser brasileiro nato, segundo art. 12, §3º, CF)
- maior de 21 anos
- gozo dos direitos políticos

O art. 87, CF também traz as atribuições do Ministro do Estado, num rol meramente exemplificativo:

- Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República: isto quer dizer que o presidente da república vai expedir um ato e será necessário a denominada referenda, que nada mais é do que uma assinatura do ministro do estado. Caso não haja referenda, há uma discussão doutrinária sobre qual seria esta consequência. Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo dizem que a ausência de referenda não interfere na validade ou eficácia do ato do presidente da república.
- Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;
- Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério;



- Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.

Os ministros de estado podem ser responsabilizados pelos seus atos. Esta responsabilização pode se dar pela prática de crimes comuns ou por crimes de responsabilidades (infrações político-administrativas).

A competência para julgar ministro de estado por crime de responsabilidade dependerá:

- se o crime de responsabilidade for praticado em conexão com o presidente da república, a competência será do Senado Federal;
- se o crime de responsabilidade não for conexo ao presidente da república, a competência será do STF;

No caso de crime de responsabilidade praticado pelo ministro de estado em conexão com o crime praticado pelo presidente da república, para haver a instauração do processo, será necessária autorização por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados.

2.8. ÓRGÃOS CONSULTIVOS

Órgãos consultivos são:

- conselho da república
- conselho da defesa nacional

São órgãos de consulta ao presidente da república, devendo deliberar sobre matérias constitucionais. Possuem caráter meramente opinativos, de modo que o presidente não precisará atender àquilo que foi deliberado.

2.8.1. CONSELHO DA REPÚBLICA

É um órgão superior de consulta, participando:

1. Vice-presidente da república
2. Presidente da câmara
3. Presidente do senado
4. Líderes da maioria e minoria da câmara
5. Líderes da maioria e minoria do senado
6. Ministro da justiça
7. 6 cidadãos brasileiros com mais de 35 anos, 2 sendo nomeados pelo PR, 2 eleitos pela Câmara e 2 pelo Senado. Estes cidadãos possuem mandato de 3 anos, vedada a recondução.

Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre:

- intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio;
- as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.

O presidente da república poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério.

2.8.2. CONSELHO DE DEFESA NACIONAL

O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático.

São membros do conselho de defesa nacional, os seguintes membros natos:

1. Vice-Presidente da República;
2. Presidente da Câmara dos Deputados;
3. Presidente do Senado Federal;
4. Ministro da Justiça;
5. Ministro de Estado da Defesa;



6. Ministro das Relações Exteriores;
7. Ministro do Planejamento.
8. Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
É de competência do Conselho de Defesa Nacional:
 - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz;
 - opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;
 - propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo;
 - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.

2.9. RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Uma das características da forma republicana se deve ao fato da possibilidade de responsabilização do presidente da república, exteriorizando-se pelo dever de prestar contas.

O Presidente da República não possui imunidade material, mas possui imunidade formal em relação à prisão e em relação ao processo.

A imunidade formal em relação à prisão está elencada no art. 86, §3º, CF, que diz, categoricamente, que o Presidente da República não poderá ser preso enquanto não sobrevier sentença penal condenatória.

A imunidade formal em relação ao processo, o Presidente da República só pode ser responsabilizado por crime de responsabilidade no Senado ou por crime comum no STF após autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados.

Além disso, o Presidente da República é acobertado por uma cláusula de responsabilidade penal relativa, à luz do art. 86, §4º, CF. Significa que o Presidente da República só poderá ser responsabilizado penalmente no mandato por atos praticados em ofício (*propter officium*) ou em razão do ofício. Ou seja, o Presidente da República não pode ser responsabilizado penalmente por atos que praticou antes do mandato e nem aqueles que são praticados no mandato, mas que não guardam relação com o ofício.

Ex.: Presidente da República comete crime de homicídio no exercício do mandato, não será responsabilizado enquanto estiver no mandato, somente depois.

Ex.: gravação lícita do Presidente da República sobre desvio de verba, propina, corrupção, etc, será responsabilizado penalmente. Caso das gravações do Presidente Michel Temer com JB, em que o ex-Procurador Geral, Rodrigo Janot, ofereceu denúncia, mas que não foi autorizada pela Câmara dos Deputados um eventual e futuro processo.

2.9.1. CRIMES DE RESPONSABILIDADE

O PR pode cometer crimes de responsabilidades.

São infrações político-administrativas praticados pelo Presidente da República (mas não só por ele), definidas em legislação federal que atentam contra a Constituição, em especial contra o rol exemplificativo do art. 85, CF.

- a existência da União [Infração política]
- o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação [Infração política]
- o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; [Infração política]
- a segurança interna do País; [Infração política]
- a probidade na administração; [Crime funcional]
- a lei orçamentária; [Crime funcional]
- o cumprimento das leis e das decisões judiciais. [Crime funcional]



Como visto, José Afonso da Silva classifica os crimes de responsabilidade em dois grupos: infrações políticas (art. 85, incisos I a IV, da CF/88) e crime funcional (art. 85, incisos V a VII, da CF/88).

Este rol é *numerus apertus*, ou seja, é exemplificativo, de forma que a CF apenas aponta genericamente o que é crime de responsabilidade, sendo necessário que a lei estabeleça a pena, processo, julgamento e regras do procedimento. É isto que o parágrafo único estabelece.

Os crimes de responsabilidade são sempre definidos em legislação federal.

Súmula Vinculante 46. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.

O STF disse na súmula vinculante 46 que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.

Como só a União pode legislar sobre direito penal, mesmo o crime de responsabilidade sendo uma infração político-administrativa, somente ela poderá legislar privativamente.

Para Presidente da República e os Governadores a lei supracitada é a Lei 1.079/50 e para Prefeitos é o Decreto Lei 201/67.

Os crimes de responsabilidade são dotados de duas grandes fases, sendo a primeira na Câmara dos Deputados, que faz um juízo de admissibilidade (não funciona como um tribunal de pronúncia) com a necessidade de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados para autorizar um futuro processo no Senado, onde ocorrerá a segunda fase.

Na segunda fase o Presidente da República será processado e julgado no Senado, com um quórum de 2/3.

Durante o julgamento do PR, quem funcionará como presidente da sessão de julgamento será o presidente do STF. Trata-se de um órgão híbrido, pois apesar de os congressistas julgarem, há o presidente do STF como presidente.

As penas/sanções serão: perda do cargo, chamada de *impeachment*, e a inabilitação para o exercício de funções públicas por 8 anos.

Observação: para que haja esse juízo de admissibilidade na Câmara, alguém precisa oferecer acusação/denúncia, na Câmara dos Deputados e quem faz isso é um cidadão, dotado de capacidade eleitoral, em dia com suas obrigações eleitorais. (art. 14 e seguintes da lei 1.079/50).

Qualquer cidadão é parte legítima para denunciar o presidente da república por crime de responsabilidade. É exigido que o sujeito esteja no gozo de seus direitos políticos, provado por meio do título de eleitor. Portanto, pessoa jurídica também não pode denunciar o PR.

O processo de impeachment tem início na Câmara dos Deputados, podendo esta denúncia ser recebida ou não pelo presidente da casa legislativa. Se o presidente da câmara dos deputados recebem a denúncia, autorizando a instauração do processo, o presidente da república passa a ostentar a condição de acusado.

A partir desse recebimento pela Câmara é que o Presidente da República poderá exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório. O exame da câmara é apenas político, sobre a procedência ou improcedência do pleito acusatório. Deve haver consistência.

O STF entende que, ainda que não haja previsão expressa na Lei 1.079/50, há que se dar oportunidade ao Presidente de se defender na Câmara dos Deputados, uma vez que o próprio processo, de per si, constitui grave ônus à figura pública. Caso o procedimento tenha sido instaurado pelo Senado, não se pode, de igual modo, subtrair do Chefe do Executivo o direito de defender-se em momento pré-processual, ou seja, durante o juízo de admissão do processo de responsabilidade.



Recebendo a denúncia de *impeachment* dando início ao procedimento, o Presidente da Câmara deve determinar a eleição de uma comissão especial com 65 parlamentares, que irá elaborar um parecer sobre a denúncia. No momento em que a comissão está reunida, antes do parecer, é dado 10 sessões para a defesa do Presidente da República.

Posteriormente, feito o parecer a favor do *impeachment*, será submetido a plenário para votação ou não do futuro processo de *impeachment* em votação aberta, com quórum de 2/3 de seus membros (342 votos), para autorizar o processo no Senado.

Após, o processo de admissão é encaminhado ao Senado, que irá julgar.

O STF, na ADPF 378 em dezembro de 2015, entendeu que o Senado, em que pese a autorização da Câmara do processo de *impeachment*, não está obrigado a processá-lo. A Câmara autoriza por 2/3 de seus membros e depois o Senado vai decidir, por maioria simples, em votação nominal e aberta, se inicia ou não o processo.

Iniciado o processo no Senado, o Presidente fica suspenso de suas funções por 180 dias, só retornando caso haja o julgamento de improcedência ou se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não esteja concluído. Nesta hipótese, o PR retorna às suas atividades.

No Senado, também haverá uma comissão, que contará com a participação da acusação e da defesa, e elaborará um parecer. Todo o processo e o julgamento no plenário do Senado serão conduzidos pelo Presidente do STF.

Para haver a condenação do presidente da república será necessário 2/3 dos membros do Senado Federal. A votação também é nominal e aberta.

Com essa condenação, em regra, o Presidente da República perde o cargo e fica inabilitado por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções de outras instâncias.

Vale lembrar que, no processo de *impeachment*, eventual decisão condenatória proferida pelo Senado Federal em julgamento por crime de responsabilidade não estará sujeita a controle judicial posterior.

Segundo o entendimento atual do STF, tais sanções não são cumulativas e indissociáveis entre si. Diante disso, é possível se falar em perda do cargo sem que haja inabilitação para o exercício da função pública pelo prazo de 8 anos. Como se vê, são sanções alternativas, as quais também podem ser cumuladas. Este, inclusive, foi o entendimento adotado no julgamento do *impeachment* de Dilma Rousseff, em 2016.

Diferenças entre o caso Collor e o caso Dilma: no caso Collor, quando se iniciou o julgamento no Senado, Fernando Collor renunciou ao cargo, e seus advogados alegaram perda do objeto e que sua inabilitação para o exercício de função pública era acessória e acompanhava o principal (perda do cargo). O Senado, à época, decidiu que ambas as penas eram principais, não tendo como condenar à perda do cargo e não condenar à inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. Ao final, Collor foi condenado à inabilitação para o exercício de funções públicas por 8 anos. No entanto, Collor não sofreu *impeachment*.

No caso Dilma, não renuncia, indo até o final. No caso Dilma ocorre um fatiamento (inadequado) do parágrafo único do art. 52, CF, porque o ministro Ricardo Lewandowski, juntamente com os senadores, por uma manobra, resolveram dividir os quesitos, colocando aos senadores sobre a perda do cargo (*impeachment*) e depois o outro quesito (inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos). Dilma foi condenada e absolvida ao mesmo tempo. Lewandowski rasga a Constituição e deturpa o parágrafo único do art. 52. Para a corrente majoritária, o Senado vai além do que poderia, transbordando o seu limite semântico, deturpando o disposto no parágrafo único do art. 52, CF.

Essa sentença condenatória é formalizada por meio de uma Resolução do Senado.

Caso o PR renuncie ao cargo durante a sessão de julgamento, não haverá a paralisação, pois há duas penas, as quais não há caráter acessório entre elas. Isto é, a renúncia pode inviabilizar a perda do cargo, mas não impede a punição por inabilitação da função pública por 8 anos. Este é o entendimento do STF no caso do ex-presidente Fernando Collor.



Para o STF, não há competência da Suprema Corte para alterar o julgamento proferido pelo Senado Federal, eis que a CF outorgou esta competência ao senado, e não ao Supremo. Caso haja violação à ampla defesa, poderá o STF se manifestar, mas não reformá-la.

De acordo com a Suprema Corte, é constitucional norma prevista em Constituição Estadual que preveja a necessidade de autorização prévia de 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa para que sejam iniciadas ações por crimes comuns e de responsabilidade eventualmente dirigidas contra o Governador de Estado. Durante a fase inicial de tramitação de processo instaurado contra Governador, a Constituição estadual deve obedecer à sistemática disposta na legislação federal. Isso porque não há nada que impeça que as Constituições estaduais estendam aos Governadores, por simetria, essa prerrogativa assegurada ao Presidente da República no art. 51, I, da CF/88. (Inf. 774, STF).

2.9.2. CRIMES COMUNS

Crimes comuns cometidos pelo Presidente da república são qualquer tipo de infração penal. Para o STF, crime comum é qualquer tipo de infração penal, incluindo os crimes eleitorais e até mesmo as contravenções penais.

O PR dispõe de prerrogativas ou imunidades em relação aos crimes comuns.

Não se trata de uma imunidade material, e sim imunidades processuais, sendo três delas as seguintes:

- Exigência de prévia autorização por 2/3 dos membros da câmara para processamento: o STF não fica vinculado ao recebimento da denúncia;
- Impedimento de que o PR seja preso prisão nas infrações comuns enquanto não houver sentença condenatória: impede que o PR seja preso em flagrante, provisoriamente ou preventivamente.
- Durante a vigência de seu mandato não possa responder por atos estranhos ao exercício de sua função: há uma temporária irresponsabilidade na vigência do mandato, mas após o término do mandato poderá responder. No caso também ficará suspenso o prazo prescricional, enquanto perdurar o mandato.

O PR só responde se ele praticar um ato criminoso na vigência do mandato, desde que guardem conexão com o exercício da função presidencial.

Cabe ressaltar que para a instauração de inquérito policial, não será necessária a autorização de 2/3 dos membros da Câmara. Há, tão somente, a necessidade de que o Procurador-Geral da República instaure o inquérito perante o STF, sendo certo que este deverá autorizar.

O procedimento no caso dos crimes comuns terá três fases: a primeira no STF, a segunda na Câmara do Deputados e a terceira no STF.

No STF temos a fase da análise da irresponsabilidade penal relativa. Finalizada a fase pré-processual de persecução penal ou numa atuação já direta do Ministério Público, o STF vai analisar se a pretensa prática do delito é uma prática que guarda ou não relação com o mandato. Porque, lembrando a questão da irresponsabilidade penal relativa, o Presidente da República no exercício do mandato só pode ser responsabilizado penalmente pelos atos praticados pelo ofício ou em razão do ofício.

Se foi um ato praticado antes do início do mandato não pode ser reponsabilizado penalmente ou se foi um ato praticado no mandato, mas que não guarda relação com este, também não pode ser responsabilizado penalmente.

Feita a análise pelo STF, poderá chegar a duas conclusões. Na primeira, o STF pode entender que aquele ato que está sendo imputado ao Presidente, que está sendo objeto de persecução penal, não guarda relação com o mandato. Nessa hipótese, o Presidente não pode ser responsabilizado penalmente. Por exemplo, um tráfico de drogas, homicídio, estupro, etc.

Obviamente, após o término do mandato ele poderá ser responsabilizado.



Na segunda hipótese, se aquele ato guarda relação com o mandato, o Presidente não está garantido pela irresponsabilidade penal. Por exemplo o caso do Michel Temer com JB, de corrupção passiva. Nesse caso, pode existir o oferecimento da denúncia (ação penal pública) ou da queixa-crime (ação penal privada) ao STF. No entanto, o STF não pode receber a denúncia ou a queixa-crime sem antes ter a autorização da Câmara dos Deputados.

O STF, então, solicita a autorização Câmara dos Deputados para que possa receber a denúncia e iniciar a ação penal. É a famosa imunidade formal em relação ao processo.

ATENÇÃO! O presidente só pode ser responsabilizado por crime de responsabilidade no Senado se a Câmara autorizar. O presidente só pode ser processado por crime comum no STF se a Câmara autorizar.

Já na Câmara dos deputados será feito o juízo de admissibilidade, vai decidir se o STF pode ou não receber a denúncia e iniciar a ação penal.

A Mesa da Câmara encaminha a denúncia de crime comum à Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) da Câmara para que ela elabore um parecer sobre ela. A CCJ elabora um parecer, que é votado na CCJ e, independentemente do resultado na CCJ, esse parecer vai à plenário. E, uma vez em plenário, decidirá se autoriza ou não o STF a iniciar ou não a ação penal. (DIFERENÇA: Se for um crime de responsabilidade, chega a denúncia na Mesa da Câmara, é designada uma comissão eleita, uma comissão especial, com 65 parlamentares para elaborar o parecer).

O quórum é de 2/3 dos membros da Câmara (= 342 votos). O PGR Rodrigo Janot ofereceu duas denúncias contra o Pres. Michel Temer, que foram entendidas como crimes que tiveram relação com o mandato e, ao chegar na Câmara, por duas vezes, foram rejeitados.

Essa votação na Câmara dos Deputados é aberta.

Supondo que a Câmara não tenha autorizado que se inicie a ação penal, após o mandato, o ex-presidente da República poderá ser processado. Haverá deslocamento de competência, não sendo mais do STF.

Se a Câmara autorizar, por 2/3 de seus membros em votação aberta, retorna ao STF para dar início à terceira fase.

- Pergunta-se: o STF é obrigado a iniciar a ação penal se a Câmara autorizar por 2/3 de seus membros?

Não! O judiciário não é obrigado a receber as denúncias, sejam elas feitas pela Câmara, como é esse o caso de crimes cometidos pelo Presidente da República, sejam elas feitas pelo Ministério Público em qualquer outra ação penal.

Portanto, a Câmara autorizando, o STF vai decidir se recebe ou não a denúncia. O procedimento diz, ainda, que haverá um primeiro julgamento. O STF vai dar o direito de defesa ao Presidente da República para que este se manifeste e vai, literalmente, se reunir em seu plenário para decidir se recebe ou não a denúncia após a autorização da Câmara.

Nesse primeiro julgamento pode dizer que não vai receber e arquivar ou pode receber a denúncia. Se o STF recebe a denúncia e inicia a ação penal, o Presidente da República ficará suspenso de suas funções por 180 dias. Aqui é igual ao crime de responsabilidade.

Essa ação penal será regida pela lei 8.038/1990, pelo Regimento Interno do STF e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Penal.

Ao final do procedimento o Presidente será julgado pelo plenário pelo STF, podendo ser condenado por um crime comum. Se condenado, a pena será uma das penas determinadas no ordenamento jurídico penal (reclusão, detenção, multa, etc).

Pergunta-se: o Presidente da República perde o mandato? A princípio, a condenação é por crime comum, não se tratando de crime de responsabilidade, em que uma das sanções é a perda do cargo. Mas existem duas possibilidades em que pode perder do mandato: uma é a do art. 92, I, do Código Penal.

Nas hipóteses do art. 92, I, CP, o STF pode determinar, não só a condenação mas também determinar a perda do mandato como efeito da condenação.



A outra situação é que a perda de mandato pode-se dar não pela condenação em si, quando não aplicado o art. 92, I, CP, mas pelos efeitos reflexos dessa condenação no art. 15, III, CF.

Os direitos políticos sendo suspensos, o indivíduo não pode votar e nem ser votado, razão pela qual um indivíduo que não pode votar e nem ser votado não pode continuar sendo Presidente da República.

Acaba perdendo o mandato não pela condenação em si, mas sim pelos seus efeitos reflexos.

2.10. CRIMES PRATICADOS POR GOVERNADORES E PREFEITOS

No caso dos Governadores, em relação aos crimes de responsabilidade, muitas constituições estaduais delimitam competência, procedimentos, quóruns, etc.

O STF, desde 2015, vem entendendo que essas previsões em constituições estaduais são inconstitucionais.

No caso dos crimes de responsabilidade dos governadores, é necessário relembrar da Súmula Vinculante 46:

Súmula Vinculante 46

A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.

A lei que determina o julgamento de crimes de responsabilidade cometidos por Governador é a lei 1.079/1950. O STF vem afastando normativas constitucionais estaduais, dizendo que prevalece a lei 1.079/50. Desta forma a mesma lei que regulamenta o crime de responsabilidade do Presidente da República, regulamenta do Governador.

No caso de Governador, reza na lei que este será julgado por um tribunal especial, que será composto por 5 deputados estaduais, 5 desembargadores, sob a presidência do Presidente do TJ. O quórum para condenar o Governador é de 2/3 dos membros desse tribunal.

As sanções que serão aplicadas ao governador, nos termos da jurisprudência atual do STF, são: perda do cargo (*impeachment*), e inabilitação para o exercício de funções públicas por 5 anos, conforme prevê o art. 78 da lei 1.079/50.

A ADI 1628 que enfrentou essa questão, envolvendo a constituição do estado de Santa Catarina, que colocou o crime de responsabilidade do governador como a perda do cargo e copiou os termos da constituição federal no que tange ao presidente da república, definindo a inabilitação para o exercício de funções públicas por 8 anos.

O STF, em 2001, declarou inconstitucional a constituição do estado de Santa Catarina, dizendo que não pode prevalecer norma sobre o crime de responsabilidade nas constituições estaduais, sendo de competência da União para legislar privativamente sobre o tema.

O órgão competente para julgar a prática de crime comum, se esta guardar relação com o mandato, cometido pelos governadores, nos termos do art. 105, CF, é o STJ. O crime comum praticado por Governador, para que seja julgado pelo STJ, precisa guardar relação com o mandato e tenha sido praticado durante o mandato.

Aquele entendimento do STF, recente, na AP 937, é aplicado para Governadores de estado. O STJ entende que a interpretação do art. 105 é restritiva, não sendo qualquer crime praticado pelo governador que será processado e julgado pelo STJ.

Pergunta-se: se o STJ vai julgar, existe a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa, por 2/3 de seus membros, para que o STJ receba a denúncia e dê início à ação penal?

O STF tinha um entendimento que essa previsão nas constituições estaduais era possível. Mas o STF mudou o entendimento no informativo 863 do STF, de maio de 2017, e



passa a entender que não há necessidade de autorização por Assembleia Legislativa do estado, por 2/3 de seus membros para que o STJ possa iniciar a ação penal contra o Governador.

Não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para que o STJ receba denúncia ou queixa e instaure ação penal contra Governador de Estado, por crime comum. Em outras palavras, não há necessidade de prévia autorização da ALE para que o Governador do Estado seja processado por crime comum. Se a Constituição Estadual exigir autorização da ALE para que o Governador seja processado criminalmente, essa previsão é considerada inconstitucional. Assim, é vedado às unidades federativas instituir normas que condicionem a instauração de ação penal contra Governador por crime comum à prévia autorização da Casa Legislativa. Se o STJ receber a denúncia ou queixa-crime contra o Governador, ele ficará automaticamente suspenso de suas funções no Poder Executivo estadual? NÃO. O afastamento do cargo não se dá de forma automática. O STJ, no ato de recebimento da denúncia ou queixa, irá decidir, de forma fundamentada, se há necessidade de o Governador do Estado ser ou não afastado do cargo. Vale ressaltar que, além do afastamento do cargo, o STJ poderá aplicar qualquer uma das medidas cautelares penais (exs: prisão preventiva, proibição de ausentar-se da comarca, fiança, monitoração eletrônica etc.). STF. Plenário. ADI 5540/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/5/2017 (Info 863). STF. Plenário. ADI 4764/AC, ADI 4797/MT e ADI 4798/PI, Rel. Min. Celso de Mello, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgados em 4/5/2017 (Info 863).

O entendimento do STF que estava no informativo 774, que dizia que as constituições estaduais poderiam, com base no princípio da simetria, estabelecer que haja a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa, por 2/3 de seus membros, para que o STJ iniciasse a ação penal contra o governador, não existe mais desde o informativo 863 do STF.

O STJ pode iniciar a ação penal contra o governador sem nenhuma necessidade de autorização da Assembleia Legislativa.

Se a constituição estadual prever essa possibilidade, é inconstitucional.

Pergunta-se: quando o STJ inicia a ação contra o governador, este fica suspenso de suas funções, automaticamente, por 180 dias? Não. Segundo o STF, o governador não fica automaticamente suspenso de suas funções por 180 dias quando o STJ dá início à ação penal. E isso por não haver previsão na constituição federal.

No entanto, não obsta que o STJ tome as medidas que entenda cabíveis no curso dessa ação penal, sendo possível que determine o afastamento do governador, podendo aplicar o art. 319, IV, VI, CPP, dentre outras medidas cautelares previstas em lei, bem como determinar a prisão preventiva do art. 311, também do CPP.

Depende do STJ para determinar alguma medida cautelar ou até mesmo prisão preventiva contra o governador.

Com relação aos governadores, o STF estabelece que é possível ser preso provisoriamente.

Já em relação a prefeitos, estes são julgados, por crime comum, que guarde relação com o mandato, no Tribunal de Justiça do respectivo estado.

Se for crime eleitoral, será julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Sempre em segunda instância conforme a súmula 702 do STF.

Súmula 702

A competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau.

Em relação aos crimes sujeitos à prestação de contas perante o órgão federal, é competente o Tribunal Regional Federal, conforme súmula 208 do STJ.



SÚMULA 208

Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.

Se há o desvio de verba, mas de uma verba que é incorporada ao patrimônio do município e o prefeito passa, paulatinamente, a desviar do próprio município. Nesse caso a competência para processar e julgar é do Tribunal do Justiça do respectivo estado.

Súmula 209

Compete à Justiça Estadual processar e julgar Prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.

Em sendo crime de responsabilidade, o prefeito será julgado pela Câmara de Vereadores, nos termos do Decreto-Lei 201/67.

3. PODER JUDICIÁRIO

3.1. CONCEITO

O Poder Judiciário é um dos três poderes, ao lado do executivo e do legislativo, sendo sempre um poder independente.

O Judiciário sempre guardará independência, a despeito de ser um sistema parlamentarista ou presidencialista, pois é ele quem guarda a Constituição.

Há países em que certas disciplinas são subtraídas do Poder Judiciário, eis que adotam o sistema francês, também denominado de contencioso administrativo (dualidade de jurisdições).

Nesses países, os conflitos que envolvem matérias de índole administrativa são solucionados no âmbito da própria administração. Nesses casos, o processo fará coisa julgada administrativa, eis que há dualidade de jurisdições.

Todavia, o Brasil adota o sistema inglês, ou de unidade de jurisdição. Só o poder judiciário tem jurisdição, cabendo apenas ele dizer o direito.

Coisa julgada é um atributo exclusivo do poder judiciário, conforme art. 5º, XXXV, da CF: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

No Brasil, o Poder Judiciário é dividido basicamente em duas esferas: a **esfera federal** e a **esfera estadual**.

A competência da Justiça Federal está prevista no art. 109 da CF. Quem tem competência residual é a Justiça Estadual.

A Justiça Federal poder ser classificada em:

- Justiça federal comum
- Justiça federal especializada: é a Justiça do Trabalho, Militar e Eleitoral.
- Há ainda dois tribunais de superposição:
- STF: última instância em questões que envolve a Constituição.
- STJ: última instância em questões que envolvem leis.

3.2. ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO

São órgãos do Poder Judiciário dispostos no art. 92 da CF:

- 1) Supremo Tribunal Federal;
- 2) Conselho Nacional de Justiça;
- 3) Superior Tribunal de Justiça;
- 4) Tribunal Superior do Trabalho;
- 5) Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
- 6) Tribunais e Juízes do Trabalho;



- 7) Tribunais e Juízes Eleitorais;
- 8) Tribunais e Juízes Militares;
- 9) Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

O STF é o órgão máximo do Poder Judiciário, sendo o guardião da Constituição.

Denomina-se **órgãos de convergência** os tribunais superiores, que tem sede em Brasília, capital federal, possuindo jurisdição em todo o território nacional: STF, STJ, TST, TSE e STM.

Temos, ainda, os **órgãos de superposição**, que são apenas dois dos tribunais superiores: o STF e o STJ. Estes tribunais são, além de órgãos de convergência, órgãos de superposição pelos fundamentos de que o STJ se superpõe à toda justiça comum, seja do âmbito dos tribunais federais ou dos tribunais estaduais. Já o STF se superpõe à toda justiça, seja a justiça comum ou à justiça especial (eleitoral, do trabalho e militar).

O Prof. Cândido Rangel Dinamarco diz que o STF e o STJ são tribunais que não estão em nenhuma das justiças, não fazendo parte nem da justiça comum e nem da especial.

À **justiça comum** pertencem os TRF (Tribunal Regional Federal), atualmente com 5 regiões (existe uma emenda constitucional ampliando para 9 regiões, mas foi suspensa liminarmente pelo STF), os juízes federais, os TJ (Tribunal de Justiça) e os juízes de direito.

À **justiça especial** fazem parte: os Tribunais de Justiça Militares, os juízes militares; a Justiça Do Trabalho composta pelo TST, os TRT e os juízes do trabalho; o TSE, os TRE e os juízes eleitorais; e o STM e as Juntas De Auditoria Militar.

O CNJ foi um órgão criado pela EC 45/04, sendo um órgão que promove o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, além de realizar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Apesar de integrar o Poder Judiciário, exerce esta função administrativa,

O STJ é o guardião da lei federal, assegurando a uniformização da interpretação da legislação federal.

3.3. FUNÇÕES TÍPICA E ATÍPICA

A função típica é exercer a função jurisdicional, de interpretar e aplicar as normas, resolver lides, com caráter de definitividade.

A função atípica é legislar (ex.: regimento interno) e exercer a função administrativa (ex.: nomeia servidores).

Em relação a funções atípicas administrativas, estão previstas no art. 96, I, CF.

Todo aparato administrativo do poder judiciário quem faz é o próprio poder judiciário.

3.4. GARANTIAS DO PODER JUDICIÁRIO

O poder judiciário detém garantias para possuir autonomia e independência. O poder judiciário possui autonomia financeira e administrativa.

Por conta disso, os Tribunais elaboram as suas próprias propostas orçamentárias, dentro dos limites estipulados na lei de diretrizes orçamentárias.

O encaminhamento se dá da seguinte forma:

- No âmbito da União, quem encaminha a proposta é o Presidente do STF e os Presidentes dos Tribunais Superiores.
- No âmbito dos Estados e do DF, quem encaminha são os Presidentes dos Tribunais de Justiça.

A EC 45 trouxe um novo dispositivo que consagra a autonomia financeira dos Tribunais, estabelecendo que as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.

Esta autonomia financeira será demonstrada pela eleição de seus órgãos diretivos, prover os cargos de juiz, elaborar seus regimentos, propor criação de novas varas, conceder licenças aos seus membros, juízes e servidores, etc.



Os TJ's e os Tribunais Superiores poderão propor a alteração do número dos membros de seus Tribunais. Podem propor ainda a criação e extinção de cargos, além da fixação de subsídio de seus membros e dos juízes.

3.5. ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA

A CF dispõe que através de LC, de iniciativa do STF, haverá o tratamento do denominado Estatuto da Magistratura.

O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica.

O cargo inicial é de juiz substituto. Este é o ingresso.

A promoção se dará de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, apurados na última ou única entrância. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira 5ª parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago.

No entanto, o acesso aos tribunais superiores também poderá se dar por antiguidade e merecimento, alternadamente.

Os subsídios dos Ministros de Tribunais Superiores são limitados a 95% do subsídio do Ministro do STF.

Os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores.

O juiz titular deve residir na comarca, salvo quando houver autorização do Tribunal.

O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, deve se fundar em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa.

Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros. Este Tribunal Especial exercerá as atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno.

Este órgão especial deverá ser composto por metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno.

A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízes e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. Todavia, o STF e STJ continuam tendo férias coletivas.

3.6. GARANTIAS DOS MAGISTRADOS

As garantias visam assegurar a independência dos juízes, sendo três as que se destacam:

- Vitaliciedade: no 1º grau, só será adquirida após o cumprimento do estágio probatório de 2 anos, dependendo a perda do cargo, no estágio probatório, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;
- Inamovibilidade: via de regra, o magistrado só será removido por iniciativa própria, salvo por motivo de interesse público, com decisão proferida por maioria absoluta do Tribunal ou do CNJ;
- Irredutibilidade de subsídio: ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

Aqueles que ingressarem no Tribunal através do quinto constitucional ou por nomeação do presidente da república, terão vitaliciedade adquirida imediatamente.



A inamovibilidade não impede que o magistrado seja removido pelo CNJ em razão de sanção administrativa. Há mitigação à inamovibilidade.

A irredutibilidade é meramente formal. Isto é, uma irredutibilidade nominal, não sendo real, ainda que haja uma maior incidência de tributos.

Os magistrados possuem foro por prerrogativa de função. Este foro é consagrado na CF:

- Juízes estaduais e juízes distritais: caso cometam crimes comuns ou de responsabilidade serão julgados pelos Tribunais de Justiça;
- Juízes federais, militares e do trabalho: caso cometam crimes comuns ou de responsabilidade serão julgados pelo Tribunal Regional Federal, pois os demais não têm competência criminal;
- Membros de TRT, TRF, TJ e TRE: são julgados perante o Superior Tribunal de Justiça.
- Membros de Tribunais Superiores: são julgados por crimes comuns ou de responsabilidade no Supremo Tribunal Federal;
- Membros do Supremo Tribunal Federal: se cometerem crimes comuns, serão julgados pelo próprio STF. Caso seja crime de responsabilidade, serão julgados pelo Senado Federal.

O STF decidiu que o foro por prerrogativa de função não se estende aos juízes aposentados, eis que se trata de uma prerrogativa de função do cargo.

3.7. VEDAÇÕES AOS MAGISTRADOS

Vedações são proibições de atividades incompatíveis com a missão do poder judiciário. Os juízes estão proibidos de:

- Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério: o STF já decidiu que nada impede que o juiz exerça mais de uma atividade de magistério, desde que haja compatibilidade com o exercício de magistrado. Segundo o STF, nada impede que o juiz exerça essas atividades em horários do expediente do Tribunal, pois poderá compensar sua atividade jurisdicional em outros horários. Isto é, não comprometendo a atividade jurisdicional, poderá dar aula à vontade.
- Receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;
- Dedicar-se à atividade político-partidária: poderá ter opinião política, mas não poderá se filiar a partidos políticos.
- Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;
- Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração: há aqui a denominada quarentena. A ideia é evitar o denominado tráfico de influência, por exploração de prestígio.

3.7.1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO

É o próprio Poder Judiciário que, dentro dos limites estabelecidos na LDO, decide qual será a proposta de seu orçamento que será encaminhada ao Parlamento para lá ser votada. O Poder Judiciário não envia a sua proposta orçamentária diretamente para o Congresso. O que a CF/88 prevê é que o Judiciário irá aprovar a sua proposta orçamentária e encaminhá-la ao chefe do Poder Executivo. Este irá consolidar, ou seja, reunir em um único projeto de Lei Orçamentária, as propostas orçamentárias do Executivo, do Judiciário, do MP e da Defensoria, encaminhando o projeto para ser apreciado pelo Poder Legislativo (art. 99, § 2º da CF/88).

Segundo o STF, salvo em situações graves e excepcionais, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de Poderes, interferir na função do Poder Legislativo de definir receitas e despesas da Administração Pública, emendando projetos de



leis orçamentárias, quando atendidas as condições previstas no art. 166, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. Isso porque, segundo o STF, a atividade de fixar e definir o orçamento é uma típica atribuição do Poder Legislativo.

Ainda que a CF diga que compete ao Judiciário encaminhar suas propostas orçamentárias, não há vedação absoluta, sob o ponto de vista formal, para que o Legislativo realize um controle sobre o que foi proposto. A aprovação da lei orçamentária pode ser classificada como um "ato complexo de elaboração conjunta" considerando que o Judiciário envia sua proposta, o Executivo a consolida e o Legislativo a arbitra.

Não há, portanto, afronta à separação de Poderes quando o Parlamento decide promover mudanças na proposta encaminhada. No caso concreto da Lei nº 13.255/2016, o STF entendeu que as normas procedimentais quanto ao processo legislativo foram todas atendidas, não havendo violação ao art. 99 nem ao art. 166 da CF/88

3.8. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

O CNJ foi criado pela EC 45/04.

Tão logo surgiu o CNJ, pela EC 45/2004, a AMB (Associação dos Magistrados do Brasil), ajuizou uma ADI contra o CNJ sob o argumento de que o CNJ feria a cláusula pétrea do art. 60, §4º, II, CF, que trata da separação de poderes, alegando que seria uma gerência indevida no Poder Judiciário, seria um controle externo no Poder Judiciário, porque teria membros de fora do judiciário controlando-o, afetando a separação de poderes, a independência do poder judiciário e a própria ideia do pacto federativo.

Essa ADI 3367 foi enfrentada pelo STF em 2005 e existia uma grande celeuma sobre essa ADI porque um dos argumentos centrais da AMB, de que haveria controle externo sobre o poder judiciário, era à época, forte, pois o STF já tinha enfrentado situações equivalentes, em tese, de possibilidade de controle do judiciário por membros de fora deste em vários estados, no âmbito das constituições estaduais. O STF, recorrentemente, foi declarando a inconstitucionalidade dessas constituições que traziam um controle do poder judiciário estadual com membros de fora. De tanto decidir sobre isso, o STF editou a súmula 649.

Súmula 649

É inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário do qual participem representantes de outros poderes ou entidades.

O STF, por 7 votos a 4, declarou constitucional o CNJ, sob o fundamento de que a súmula 649 é válida somente para os estados. Continua sendo proibido criar órgão de controle no poder judiciário no âmbito dos estados com membros de fora do poder judiciário.

No âmbito nacional, diz o STF que é importante que tenha um órgão de controle do poder judiciário com membros de fora. Isso, dizia o Min. Cezar Peluso, relator à época, vai abrir a "caixa preta", vai oxigenar, o poder judiciário, sendo bom para a democracia.

Deve-se levar em consideração que a maioria dos membros do CNJ é do poder judiciário.

O CNJ foi considerado constitucional, o argumento de que fere o princípio federativo foi considerado inadequado, não ferindo a autonomia dos estados e do poder judiciário destes, apenas, além da corregedoria que já existe no âmbito dos estados, vai existir um órgão de extração nacional, que fiscaliza o poder judiciário dos estados, bem como a justiça federal e a especializada.

Não há que se falar em controle externo pois o CNJ é um órgão do poder judiciário, embora tenha alguns membros que não sejam do poder judiciário.

O STF nos lembra, no julgamento da ADI 3367, que a própria constituição, à luz da EC 45/04 determina, no seu art. 102, I, r, CF, que compete originariamente o STF julgar ações contra o CNJ e o CNMP.



Este conselho é integrante do Poder Judiciário, não ferindo a separação dos poderes.

O CNJ compete controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e também controlar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.

Os 15 membros do Conselho Nacional de Justiça exercem mandato de 2 anos, admitida 1 recondução, sendo eles:

- 1) Presidente do Supremo Tribunal Federal;
- 2) 1 Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que será o Corregedor Nacional de Justiça;
- 3) 1 Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;
- 4) 1 desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
- 5) 1 juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
- 6) 1 juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça (desembargador federal);
- 7) 1 juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
- 8) 1 juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho (desembargador do TRT);
- 9) 1 juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
- 10) 1 membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República;
- 11) 1 membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual;
- 12) 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- 13) 2 cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

Quem preside o CNJ é o presidente do STF. Caso haja impedimento do presidente do STF, quem assumirá a presidência do CNJ será o vice-presidente do STF, ainda que ele não esteja dentre aqueles compostos no CNJ.

Somente estas duas autoridades (presidente de vice-presidente do STF) é que não se submetem à aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Todos os demais membros do CNJ devem se submeter.

A EC 61 trouxe duas alterações:

- Não tem mais limite de idade para compor o CNJ;
- Poderá distribuir processos ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça.

Quem fica excluído da distribuição de processo é o Ministro do STJ, que será o conselheiro corregedor. Atente-se que esta exclusão da distribuição se dará apenas no Tribunal, e não no CNJ.

O Ministro do STF continua recebendo os processos do STF.

A CF estabelece que o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da OAB irão officiar perante o CNJ, porém ambos não pertencem ao CNJ.

Nos crimes de responsabilidade, os membros do CNJ serão julgados pelo Senado Federal.

Em se tratando de crimes comuns, os membros do CNJ não têm foro por prerrogativa de função, cada um respondendo perante o seu Tribunal respectivo.

As ações contra o CNJ serão processadas e julgadas originariamente perante o STF.

As atribuições do CNJ são exemplificativas, pois, em tese, deverão controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e também controlar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, além de:

- zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;



- zelar pela observância do art. 37 (princípios da administração) e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União: o CNJ poderá rever o ato de ofício.
- receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;
- representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade;
- rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 ano: então, ainda que o processo disciplinar já esteja julgado, nada impede que o CNJ venha a rever de ofício, desde que seja julgado há menos de 1 anos.
- elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;
- elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.

Observe que o CNJ não tem competência para rever a atuação jurisdicional dos magistrados.

Segundo o STF, a competência constitucional do CNJ é autônoma (e não subsidiária). É regular a designação de juiz auxiliar, seja ele originário do Judiciário estadual ou federal, para a condução de sindicância, por delegação do Corregedor-Nacional de Justiça, ainda que o investigado seja magistrado federal. A autoridade delegada atua em nome do CNJ, sendo irrelevante, portanto, se é Juiz Estadual ou Federal (Inf. 799. STF).

O STF decidiu que o CNJ tem competência originária e concorrente com os Tribunais de todo o país para instaurar processos administrativos disciplinares contra magistrados. Ou seja, não está condicionada a uma prévia atuação das corregedorias dos tribunais.

O CNJ em relação ao STF não tem qualquer poder, pois o órgão máximo é o próprio STF.

O STF reconheceu ainda que o CNJ tem poder normativo primário, ou seja, poderá tratar de matérias que lhe são afetas ainda que não haja lei. Poderá expedir normas primárias para regulamentação de normas atribuídas pela Constituição.

O CNJ possui a competência para rever, de ofício ou mediante provocação, as decisões das Corregedorias locais que julgam, a favor ou contra, juízes e membros de Tribunais. No entanto, essa competência revisora deverá ser exercida no prazo máximo de 1 ano depois da decisão proferida (art. 103-B, § 4º, V, da CF/88) (Inf. 808, STF).

Em 2016, o STF decidiu que o CNJ pode determinar que Tribunal de Justiça exonere servidores nomeados sem concurso público para cargos em comissão que não se amoldam às atribuições de direção, chefia e assessoramento, contrariando o art. 37, V, da CF/88 (Inf. 851).

Segundo o STF, no caso, não houve declaração de inconstitucionalidade da qual resultasse a anulação ou revogação da lei discutida, com exclusão de sua eficácia. Ou seja, houve a nulidade dos atos questionados por ser considerada inaplicável, administrativamente, lei estadual com vício de inconstitucionalidade, com a vinculação apenas da atuação de órgão



judicial cujos atos administrativos foram submetidos ao controle do CNJ. Assim, o Conselho não usurpou competência do STF.

Cabe lembrar que o Conselho Nacional de Justiça, embora seja órgão do Poder Judiciário possui, tão somente, atribuições de natureza administrativa e, nesse sentido, não lhe é permitido apreciar a constitucionalidade dos atos administrativos, mas somente sua legalidade.

É forçoso convir que as leis inconstitucionais não são normas atendíveis, porque colidem com mandamento de uma lei superior, que é a Constituição Federal. Em virtude desse entendimento, a doutrina defende que é possível que o chefe do Poder Executivo se recuse a cumprir uma lei se ela for claramente inconstitucional.

Como se viu, o STF afirmou que esse mesmo entendimento pode ser aplicado para órgãos administrativos autônomos, como o TCU, o CNMP e o CNJ. Assim, tais órgãos, ao realizarem controle de validade dos atos administrativos, podem determinar a não aplicação de leis inconstitucionais.

No MS 27750 entendeu a 2ª Turma do STF que o CNJ não pode decidir, em procedimento administrativo, matéria que já foi judicializada, que já foi matéria de ação judicial. Não lhe é dado decidir questões que estão submetidas à atuação judicial.

No MS 33163, o STF decidiu que não possui competência para processar e julgar ações decorrentes de decisões negativas do CNJ e do CNMP. Decisões negativas são aquelas decisões que nada determinam, nada aplicam, nada ordenam e nada invalidam, ou seja, o conteúdo da decisão do CNJ é um conteúdo negativo. Nesse sentido, não houve a prática de nenhum ato, não existe a prática de nenhum ato do CNJ a ser atacado no STF.

Exemplo: supondo que o interessado se dirija ao CNJ pedindo a revisão disciplinar de determinado ato administrativo praticado contra ele. E se o CNJ disser que rejeita o pedido e não tomar nenhuma providência, sob a alegação de que não possui competência para aquela situação, se trata de uma decisão do CNJ que nada determina, nem aplica, nem ordena, etc. O STF não é competente para conhecer decisões do CNJ/CNMP de cunho negativo, não sendo a instância adequada para tal.

Outra situação que também não é adequada é a chamada interpretação restrita, do art. 102, I, r, CF, que diz que compete originariamente ao STF conhecer das ações contra o CNJ e o CNMP. No entanto, o STF não entende dessa forma, dando uma interpretação restritiva ao art. 102, I, r. Não cabe ao STF conhecer de todas as ações contra atos praticados pelo CNJ, mas sim somente daquelas que envolverem remédios constitucionais.

Ou seja, a competência do STF contra o CNJ, de forma originária, será para julgar Mandado de Segurança, *Habeas Corpus*, *Habeas Data* e Mandado de Injunção.

Como o CNJ não possui personalidade jurídica própria, quem figura no pólo passivo é a União e, caso se trate de uma ação ordinária, compete à justiça federal, de primeira instância, nos termos do art. 109, CF.

No entanto, existe exceção. Em 2016 o STF chegou a conhecer e julgar uma ação ordinária contra o CNJ. Essa ação ordinária foi proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos contra uma decisão do CNJ.

O STF, excepcionalmente conheceu dessa ação ordinária contra o CNJ porque no caso concreto discutiu-se o poder do CNJ para afastar lei inconstitucional. O STF julgou essa ação ordinária porque não poderia deixar que a justiça federal definisse atribuições do CNJ. Além disso, foram impetrados, além dessa ação ordinária, Mandados de Segurança, por servidores, contra a decisão do CNJ. Mesmo que a ação ordinária fosse remetida à justiça federal, nos termos do art. 109, CF, e o STF continuar com os Mandado de Segurança, causaria insegurança jurídica em relação aos julgamentos.



3.9. CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO PELOS ESTADOS-MEMBROS

Os estados-membros não têm competência constitucional para criar órgãos de controle interno ou externo para fins de controle administrativo da respectiva atuação dos Tribunais.

Ou seja, não pode haver um conselho estadual de justiça. Isso porque a magistratura tem um caráter nacional, eis que todos os magistrados estão submetidos ao estatuto nacional. É justamente isso que justifica um conselho nacional de justiça.

3.10. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 Ministros, nomeados pelo presidente da república, após a aprovação da maioria absoluta dos membros do Senado Federal.

Para ser ministro do STF é necessário:

- mais de 35 e menos de 65 anos de idade
- notável saber jurídico e reputação ilibada
- brasileiro nato
- pleno gozo dos direitos políticos

O STF possui duas turmas, sendo que ambas possuem as mesmas competências, além de cada uma delas possuir 5 ministro. O presidente do STF não integra qualquer uma delas.

Para que o Tribunal Pleno tenha quórum para deliberação, é necessário que tenha ao menos 8 dos 11 ministros.

Para que se analise a constitucionalidade de uma lei, é indispensável que haja a maioria de 6 votos, ainda que estejam presentes 8 ministros. Esse quórum (6 ministros) é exigido para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do ato.

Caso não tenha quórum suficiente, suspende-se o julgamento do processo e aguarda-se o comparecimento dos ministros faltantes até alcançar o número de 6 votos.

O presidente do STF é eleito diretamente pelos seus pares, tendo mandato de 2 anos, vedada a recondução.

A Suprema Corte tem como tradição eleger como presidente e vice-presidente os dois ministros mais antigos que ainda não tenham sido presidente e vice-presidente.

As competências do STF podem ser divididas em:

- competência originária
- competência recursal

O art. 102 traz o rol exaustivo da competência do STF.

3.10.1. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA

Segundo o art. 102, I, compete ao STF, originariamente, processar e julgar:

- ADI de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ADC de lei ou ato normativo federal (não há estadual);
- nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
- nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;
- o habeas corpus, quando qualquer uma das autoridades acima for paciente; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



- a discussão que recaia sobre o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território: os municípios não estão aqui, pois esta competência será da Justiça Federal, com recurso para o STJ.
 - as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta: o STF faz uma interpretação restritiva, pois, no caso da administração indireta, é preciso que fique evidenciado pelo conflito federativo.
 - a extradição solicitada por Estado estrangeiro (inclusive a prisão preventiva para extradição e expulsão)
 - o *habeas corpus*, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;
 - revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;
 - a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
 - a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;
 - a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
 - os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;
 - o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;
 - o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;
 - as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;
- Esse rol é exaustivo.

O Presidente do Banco Central, por possuir o status de Ministro de Estado, será julgado por seus crimes pelos mesmos órgãos que julgam os ministros de Estado. Ou seja, o Presidente do Banco Central será julgado pelas suas infrações penais comuns e crimes de responsabilidade pelo STF, salvo quanto aos crimes de responsabilidade conexos com os do Presidente da República, hipótese em que será julgado pelo Senado Federal.

É preciso perceber que quando a CF traz o foro por prerrogativa de função, não alcançará ações de natureza cível ajuizados contra estas autoridades.

O STF entendeu que ele não tem competência para julgar mandados de segurança contra decisão negativa do CNJ ou do CNMP. Ou seja, se a decisão for negativa, isto é, se, por exemplo, alguém impugna uma negativa de um Tribunal de Justiça perante o CNJ, mas este indefere este pleito. Neste caso, não se pode questionar esta decisão perante o STF, visto que o CNJ não alterou o ato do Tribunal de Justiça.

Em outras palavras, caso o CNJ seja provocado por um interessado para decidir determinada situação e o órgão se declare incompetente para tanto, o interessado, se desejar impugnar essa decisão, deverá impetrar mandado de segurança perante o juiz de primeiro grau.

Competia ainda ao STF dirimir conflitos de competência entre Ministérios Públicos estaduais e federais, bem como a competência para julgar conflitos entre Ministérios Públicos



estaduais de estados diferentes. Esta não é mais competência do STF, o qual entendeu que compete ao PGR, na condição de órgão nacional do Ministério Público, dirimir conflitos de atribuições entre membros do MPF e de Ministérios Públicos estaduais (Inf. 826).

Segundo a súmula 637 do STF, no mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento.

3.10.2. COMPETÊNCIA RECURSAL

Compete ao STF julgar, em recurso ordinário:

- *habeas corpus*, o mandado de segurança, o *habeas data* e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão: a instância deve ter sido única, para ser ordinário, e a decisão deverá ser denegatória.
- crime político;
- julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
 - a) contrariar dispositivo desta Constituição;
 - b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
 - c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição;
 - d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal: neste caso, como não há hierarquia entre leis, razão pela qual se contestou lei local em face de lei federal, o objetivo é saber qual ente detém a competência segundo a Constituição.

Perceba que a Constituição fala que cabe recurso extraordinário em decisão de única ou última instância, porém não fala se a decisão deva ser de Tribunal. Portanto, é cabível recurso extraordinário contra decisão de Turma Recursal de Juizado Especial.

Cabe ressaltar que é possível recurso extraordinário em face de lei decorrente de constituição anterior, apesar de não estar explicitamente previsto. Isto é, seria possível questionar a validade de ato pré-constitucional em face da Constituição de 1988 ou ainda de constituição pretérita, vigente à época em que aquela lei entrou em vigor. Isso porque não cabe controle abstrato com base em constituição pretérita.

São requisitos para interposição de recurso extraordinário:

- prequestionamento da matéria: esta controvérsia deve ter sido enfrentada na decisão recorrida;
- ofensa direta à constituição: não é admitida ofensas reflexas ou indiretas à Constituição;
- repercussão geral: o recorrente deve demonstrar a repercussão geral das questões debatidas. Em regra, há uma presunção de que a violação direta à constituição geraria uma repercussão geral. Tanto é que para afastar a repercussão geral, é preciso que haja a manifestação de 2/3 dos membros do STF no sentido de que não há repercussão geral.

3.10.3. PRESERVAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DO STF E DA AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES

Cabe Reclamação em caso de usurpação das competências do STF ou descumprimento de suas decisões.

A reclamação é um instrumento constitucional que busca:

- preservar a competência do STF
- garantir a autoridade daquilo que ficou decidido pelo STF
- garantir que súmula vinculante do STF seja aplicada: isso porque a EC 45 ampliou o uso da reclamação, cabendo também nos casos de impugnação de uma decisão



administrativa ou de um ato judicial que contrarie ou que aplique indevidamente súmula vinculante do STF.

A reclamação tem natureza jurídica de petição será de competência originária do STF, bem como será julgada pelas Turmas do STF.

Ademais, a reclamação é instrumento hábil a de interpretação ou reinterpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato.

A partir de um entendimento do STF, foi decidido que o ministro relator de Reclamação poderá julgá-la monocraticamente quando a matéria em questão for objeto de jurisprudência consolidada da Corte.

Cabe destacar dois entendimentos do STF, pois é possível que haja o instituto da reclamação em âmbito estadual, pois os TJ's funcionam como guardiões das constituições estaduais. Além disso, o STF entende que o Ministério Público Estadual, apesar de o PGR ter a competência para exercer suas atividades junto ao STF, o MPE teria legitimidade ativa autônoma para propor reclamação perante a Suprema Corte.

3.11. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O STJ é composto de, no mínimo, 33 Ministros, os quais serão:

1. nomeados pelo Presidente da República
2. dentre brasileiros, natos ou naturalizados
3. com mais de 35 e menos de 65 anos
4. notável saber jurídico e reputação ilibada

Esta escolha depende da aprovação prévia depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.

A composição do STJ deverá ser da seguinte forma:

- 1/3 dentre juízes dos TRF's, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio STJ;
- 1/3 dentre desembargadores dos TJ's, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio STJ;
- 1/3 em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente.

O STF entendeu que os magistrados desta composição de 1/3 do TRF e do TJ podem advir do quinto constitucional.

Observação: alguém que não seja desembargador de carreira, que entrou pelo quinto constitucional, pode concorrer à vaga de ministro do STJ como desembargador. O STF entendeu que é possível, porque a constituição, no que tange ao STJ, só exige que o indivíduo seja desembargador, não exigindo que seja de carreira.

O próprio STJ é que vai elaborar a lista tríplice e encaminhará ao Presidente da República. Diante disso, o presidente escolhe e submete ao Senado Federal.

No caso de advogados e membros do MP, são elaboradas listas sêxtuplas e encaminha ao STJ. A Corte Cidadã, a partir dessa lista sêxtupla, elaborará uma lista tríplice, enviando ao presidente da república.

Em 2009 surgiu um *hardcase* interessante. Surgiu uma vaga de advogado para ser Ministro do STJ e, então, os advogados do Brasil mandaram seus nomes para a OAB, que fez uma lista sêxtupla e enviou ao STJ. O STJ devolveu a lista para a OAB alegando que nenhum dos nomes serviria. A OAB, então, impetrou um Mandado de Segurança contra o STJ e depois um Recurso Ordinário Constitucional em Mandado de Segurança contra o STJ no STF alegando desrespeito do STJ em relação à lista sêxtupla.

O STF então decidiu que o STJ pode devolver a lista da OAB se entender que os requisitos não foram cumpridos. O que o STJ não pode fazer é uma nova lista.

A competência dos STJ pode ser dividida em:

- (a) competência originária
- (b) competência recursal



3.11.1. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA

O STJ terá competência originária para processar e julgar:

- nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal: os vice-governadores são disciplinados pela respectiva Constituição Estadual. Normalmente são submetidos ao TJ.
- nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade, os desembargadores do TJ e TJDFT, os membros dos TCE's, os dos TRF's, dos TRE's e do TRT's, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do MPU que oficiem perante tribunais;
- os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio STJ: perceba que há o questionamento de um ato de ministro de Estado ou de Comandante através de mandado de segurança, razão pela qual será do STJ essa competência.
- os habeas corpus, quando o coator ou paciente for Governador, desembargadores do TJ e TJDFT, membros dos TCE's, os dos TRF's, dos TRE's e do TRT's, membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do MPU que oficiem perante tribunais, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
- os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvada a competência do STF, bem como entre Tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;
- as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;
- a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
- os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União;
- o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;
- a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias: é a mais importante para concursos, pois até a EC 45 era de competência do STF. Exequatur é o "execute-se", sendo uma autorização para que sejam executadas no Brasil as diligências requeridas por autoridade estrangeira. A carta rogatória é recebida de uma autoridade estrangeira pelo Ministério das Relações Exteriores, posteriormente é transmitida ao STJ. Concedida ao exequatur, é encaminhada ao juiz federal para executar a diligência. Após, será devolvida ao STJ para remeter ao país de origem.

3.11.2. COMPETÊNCIA RECURSAL DO STJ

Compete também ao STJ julgar, por recurso ordinário:

- os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos TRF ou pelos TJ e TJDFT, quando a decisão for denegatória: perceba que deverá ser decidido em única ou última instância por Tribunais. Ou seja, deverá ser denegatória.
- os mandados de segurança decididos em única instância pelos TRF ou pelos TJ e TJDFT, quando denegatória a decisão;



- as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País: veja, que a primeira instância é do juiz federal neste caso, pois aqui é caso de recurso ordinário.
- em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos TRF ou pelos TJ e TJDFT, quando a decisão recorrida: Não cabe recurso especial contra decisões de Turmas Recursais, eis que a CF é clara no sentido de que caberá somente de decisão proferida por Tribunais.
- decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
- decisão recorrida julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal: aqui não é lei, mas ato, pois em se tratando de lei, haverá discussão sobre a competência constitucional, cabendo ao STF julgar.
- decisão recorrida der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

Se a decisão de uma turma recursal contraria a interpretação dada pelo STJ, haveria de ingressar com uma reclamação para fazer vale a autoridade de suas decisões. Mas não é possível recurso especial.

Por último, funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça:

- ENFAM: Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira: o curso de formação de juízes é regulamentado pela ENFAM.
- CJF: Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de 1º e 2º graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante: são passíveis de questionamento.

3.12. JUSTIÇA FEDERAL

A Justiça Federal é composta por:

- TRF
- Juízes federais

3.12.1. TRF

O TRF terá o mínimo de 7 juízes, conhecidos informalmente como desembargadores federais.

Para tanto, é necessário ter mais de 30 anos e menos do que 65 anos.

Um quinto do TRF deve ser composto por advogados ou membros do MP, com mais de 10 anos de experiência. Os 4/5 serão por promoção dos juízes federais.

O quinto constitucional tem a finalidade de oxigenar os Tribunais, apesar de isto ser questionável.

A competência do TRF está previsto no art. 108 da CF:

- processar como competência originária:
- os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
- as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região;
- os mandados de segurança e os *habeas data* contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal;
- os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal;
- os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal;



- processar em grau recursal as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Nesse último caso, o juiz atua com competência federal, pois não há vara federal na comarca.

É pacífico no STF que o TRF é competente para julgar Prefeito, Secretário de Estado, Secretário Municipal, nos crimes em que houve a violação de interesse da União, apesar de a CF estabelecer prever que seriam julgados pelo TJ. Nesse caso, se o crime é da competência da JF, serão julgados pelo TRF, originariamente.

3.12.2. JUÍZES FEDERAIS

Os juízes federais têm a sua competência elencada no art. 109 da CF.

A competência da justiça estadual é residual.

Segundo o art. 109, compete aos juízes federais processar e julgar:

- as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho- Observe-se que a sociedade de economia mista, em regra, é de competência da justiça estadual.
- as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País- Neste caso, cabe recurso ordinário contra a decisão do juiz de 1ª instância para o STJ.
- as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;
- os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral- Contravenção penal é de competência da Justiça Estadual, salvo se houver contravenção praticada por autoridade com foro por prerrogativa de função. Da decisão que julga crime político caberá recurso ordinário ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, II, b, CF).
- os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente-Como se vê, exige-se que o delito previsto em tratado ocorra por transnacionalidade.
- as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo;
- os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira- Com base nisso, o crime de redução à condição análoga a de escravo é da competência da JF.
- os *habeas corpus*, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;
- os mandados de segurança e os *habeas data* contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;
- os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar-Os tribunais vêm entendendo que os navios e aeronaves devem ser de grande porte. Do contrário, seria de competência da justiça estadual.
- os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização-



Lembre-se que para haver exequatur ou homologação, é necessário que o STJ seja instado.

- a disputa sobre direitos indígenas- O STF firmou o entendimento de que a justiça federal só é competente quando a controvérsia envolver direitos indígenas típicos e específicos da comunidade indígena. Isto é, não há competência da justiça federal na hipótese em que o indígena praticar crime um furto isoladamente.

Ademais, nas causas em que a União for autora serão ajuizadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.

Nas causas em que a União for ré, o autor poderá ajuizar ação na seção judiciária em que:

- autor for domiciliado
- houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou
- onde esteja situada a coisa, ou, ainda,
- no Distrito Federal.

Com relação às causas previdenciárias, os §§3 e 4 trazem uma regra especial.

Se no domicílio do segurado ou beneficiário não houver vara federal, estas ações serão julgadas pela Justiça Estadual, caso em que o recurso será remetido ao TRF.

Segundo o STF, é possível que o segurado opte por qual vara deseja ingressar. Trata-se, portanto, de mera liberalidade a favor do beneficiário.

A súmula vinculante 36 ainda estabelece que compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil.

A discussão aqui é se seria da justiça federal ou da justiça militar, eis que quem expede esses documentos é a Marinha do Brasil.

O §5º traz a denominada federalização de crimes que violem direitos humanos. Segundo este dispositivo, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos (conceito jurídico aberto), o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

A EC 45/04 trouxe a possibilidade de trazer para a esfera federal crimes que seria originariamente de competência da justiça estadual. Alguns estados possuem situação precária. Neste caso, por haver um risco de que não haja a efetiva aplicação da lei penal, o constituinte, a fim de que os tratados internacionais de que o Brasil faça parte sejam cumpridos, admite que o PGR possa levantar o incidente perante o STJ, de deslocamento de competência da justiça estadual para a justiça federal.

3.13. JUSTIÇA DO TRABALHO

A justiça do trabalho é composta pelos seguintes órgãos:

- Tribunal Superior do Trabalho;
- Tribunais Regionais do Trabalho;
- Juízes do Trabalho.

3.13.1. TST

O Tribunal Superior do Trabalho será composto 27 ministros, escolhidos:

- dentre brasileiros, natos ou naturalizados
- mais de 35 anos e menos de 65 anos
- notável saber jurídico e reputação ilibada
- nomeados pelo Presidente da República



- aprovação prévia pela maioria absoluta do Senado Federal

Atente-se que 1/5 dos membros do TST serão escolhidos dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício.

Os 4/5 restantes serão dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior.

O TST faz uma lista tríplice dos Desembargadores de Carreira, envia para o Presidente da República, que indica um e, após aprovação por maioria absoluta no Senado, é nomeado pelo Presidente da República.

Para membros do MPT e advogados, a lógica é a mesma do quinto constitucional. A OAB ou o MPT faz uma lista sêxtupla, envia para o TST, que faz uma lista tríplice e envia ao Presidente da República, que irá indicar um deles e, caso seja aprovado pelo Senado por maioria absoluta, é nomeado pelo Presidente da República.

O fato dos Desembargadores do TRT que devem ser indicados para o TST serem de carreira foi uma exigência feita pela ANAMATRA (Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho), na EC 45/04.

3.13.2. TRT

Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e:

- nomeados pelo Presidente da República
- brasileiros, nato ou naturalizados
- mais de 30 e menos de 65 anos

Um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94. Os 4/5 serão mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente.

3.13.3. JUSTIÇA DO TRABALHO

Segundo o art. 114, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

- as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios- sendo uma relação trabalhista, submetida à CLT, será da competência da justiça do trabalho.
- as ações que envolvam exercício do direito de greve;

Sendo servidor público estatutário, a relação é jurídico-administrativa, assim como o contrato temporário, devendo ser julgado pela justiça comum, federal ou estadual.

Se for uma relação de emprego público, será da justiça do trabalho.

- as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;
- os mandados de segurança, *habeas corpus* e *habeas data*, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
- os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o;
- as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;
- as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
- a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;



- outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

O STF firmou o entendimento de que a justiça do trabalho é competente para julgar ações possessórias ajuizadas em razão do exercício de direito de greve, no tocante às relações privadas. Por exemplo, se os empregados tomam o prédio da empresa e não deixam os outros funcionários trabalhar, caberá ação possessória, pois o dono da empresa quer ser reintegrado. Esta ação deverá ser ajuizada na Justiça do Trabalho.

Atente-se que Justiça do Trabalho não tem competência para julgar ação penal, nem mesmo habeas corpus.

O STF ainda editou a súmula vinculante 22, estabelecendo que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04.

Antes da EC 45, quem julgava esses casos era a Justiça comum estadual. Após, passou a ser a Justiça do Trabalho. Com relação às ações que estavam em curso, segundo o STF, se não havia sentença de mérito, deveria mandar para a justiça do trabalho. Caso houvesse, permaneceria na justiça comum.

As ações contra o INSS, em que se pleiteia o benefício previdenciário, não são ajuizadas perante a Justiça do Trabalho, mas também não são ajuizadas perante a Justiça Federal, devendo ser ajuizadas na Justiça Estadual.

3.14. JUSTIÇA ELEITORAL

A justiça eleitoral é composta de 4 órgãos:

- (a) Tribunal Superior Eleitoral;
- (b) Tribunais Regionais Eleitorais;
- (c) Juízes Eleitorais;
- (d) Juntas Eleitorais.

3.14.1. TSE

O TSE é composto por, no mínimo, de 7 membros, com mandato de 2 anos, podendo haver recondução por mais 2 anos. Serão escolhidos:

- mediante eleição, pelo voto secreto:
 - (I) 3 juízes dentre ministros do STF: definidos por votação no próprio STF
 - (II) 2 juízes dentre ministros do STJ: definidos por votação no próprio STJ
- por nomeação do Presidente da República:
 - (I) 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal: os advogados serão indicados através de uma lista sêxtupla, que não será definida pela OAB, mas sim pelo STF, que encaminha ao Presidente da República, que nomeia. Não há necessidade de aprovação pelo Senado aqui. Tão logo a lista sêxtupla é encaminhada pelo STF ao Presidente da República, este nomeia

O presidente e o vice-presidente do TSE serão ministros do STF.

Dos 2 ministros do STJ, um deles será corregedor do TSE.

3.14.2. TRE'S

Os TRE's serão compostos por:

- (I) 2 desembargadores do TJ, mediante eleição, pelo voto secreto;
- (II) 2 juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça, mediante eleição, pelo voto secreto
- (III) 1 juiz do TRF, com sede na Capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido pelo Tribunal Regional Federal respectivo;



(IV) 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça, nomeados pelo Presidente da República.

Esses advogados são indicados em lista sêxtupla pelo TJ, e não pela OAB.

Os juízes dos TRE's, servirão por 2 anos, no mínimo, e poderão ser reconduzidos por uma vez, pois nunca estarão por mais de dois biênios consecutivos.

O TRE elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre os desembargadores.

Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.

São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem a Constituição e as denegatórias de *habeas corpus* ou mandado de segurança.

Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:

- forem proferidas contra disposição expressa da Constituição ou de lei;
- ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;
- versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais;
- anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais;
- denegarem *habeas corpus*, mandado de segurança, *habeas data* ou mandado de injunção.

3.15. JUSTIÇA MILITAR

São órgãos da Justiça Militar:

- (a) Superior Tribunal Militar
- (b) Tribunais Militares instituídos por lei
- (c) Juízes Militares

A composição do STM é de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo presidente da república, após aprovação da maioria absoluta do Senado Federal:

- (I) 3 oficiais-generais da Marinha
- (II) 4 oficiais-generais do Exército
- (III) 3 oficiais-generais da Aeronáutica
- (IV) 5 dentre civis: desses 5 civis, 1 juiz militar, 1 membro do MPM e 3 advogados com mais de 10 anos de efetivo exercício da atividade

Em relação aos civis, é necessário que sejam:

- Brasileiros
- Maiores de 35 anos
- 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional
- 2 por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar.

Todos serão nomeados pelo Presidente da República.

Os 10 Oficiais-Generais deverão ser, obrigatoriamente, brasileiros natos. Mas isso não porquê o STM exige, mas sim o cargo de Oficial-General possui essa exigência. O único tribunal superior que exige brasileiro nato é o STF.

Os 5 civis podem ser brasileiros natos ou naturalizados.

O procedimento de escolha se dá da seguinte forma: o Presidente da República indica um nome, que irá ao Senado que aprovará por maioria simples e o Presidente da República nomeia.

Não há na constituição uma determinação de que se faça uma lista para indicação.

A Justiça Militar é competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei.



3.15.1. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

A justiça militar da União julga crimes militares, porém esta competência é exclusivamente penal.

Não julga nenhuma matéria não penal.

Além de militares, a justiça militar da União também julga civis, quando estes praticam crimes contra o patrimônio militar ou contra a ordem administrativa militar.

3.15.2. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL

A justiça militar estadual é composta:

- 1º grau: juízes de direito e conselhos de justiça
- 2º grau: Tribunal de Justiça, ou, caso o Estado possuam efetivo militar superior a 20 mil militares, por um Tribunal de Justiça Militar

Contra as decisões proferidas pela Justiça Militar de 2ª instância caberá recurso para o STJ, ou para o STF, não cabendo em nenhuma hipótese recurso para o Superior Tribunal Militar, pois este tribunal tem competência exclusiva para julgar causas decorrentes da Justiça Militar da União.

A Justiça Militar dos Estados julga apenas militares, nos crimes militares e nos atos disciplinares militares, salvo no caso de crime doloso contra a vida de vítima civil, hipótese em que será julgado pelo Tribunal do Júri. Sendo vítima militar, será julgado pela justiça militar.

O Conselho de Justiça é composto sob a presidência de Juiz de Direito, mas ao Conselho compete julgar os demais crimes militares. Isto é, se houver crime militar cometido contra civil, é o juiz do juízo militar que julga singularmente.

Se é outro crime militar, não cometido contra civil, então é o Conselho de Justiça militar que julgará. Sendo ato disciplinar militar, quem julgará será o juiz de direito singularmente.

É importante e necessário diferenciar a Justiça Militar dos estados e a Justiça Militar Da União.

A Justiça Militar da União diz respeito à crimes praticados pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Além disso, a justiça militar da União julga civis, por uma interpretação restritiva do Código Penal Militar, à luz do art. 9º, CPM, dentre outros, em determinadas situações excepcionais, civis podem ser julgados pela Justiça Militar da União.

Já a justiça militar dos estados não julga civis, estando direcionada diretamente aos Policiais Militares e ao Corpo De Bombeiros Militar.

A Justiça Militar da União não possui segundo grau de jurisdição. No primeiro grau é composto pelas Juntas de Auditoria Militares e vai direto para o Tribunal Superior Militar. Só terá segundo grau em caso de guerra, com os tribunais itinerantes. Não sendo caso de guerra, decisões de primeiro grau das Juntas de Auditorias Militares, envolvendo crimes de membros do Exército, Marinha e Aeronáutica, ou mesmo de civis (com interpretação restrita), vão para o STM.

A Justiça Militar dos estados tem primeiro e segundo grau. No âmbito estadual, em primeiro grau, é composto por juízes militares e, no segundo grau, para julgar pela prática de crimes de Policiais Militares e Corpo de Bombeiro Militar, o Tribunal de Justiça Militar e, também, dentro do Tribunal de Justiça estadual, terão câmaras especializadas, pois nem todo estado terá Tribunal de Justiça Militar.

A existência de Tribunais de Justiça Militares, no âmbito estadual é minoria, uma existência diminuta. Atualmente só existem três TJM no Brasil: Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul.



Dessa forma, o segundo grau da Justiça Militar dos demais estados, dentro d próprio Tribunal de Justiça, teremos câmaras especializadas para julgar policiais militares e corpo de bombeiro militar.

Podem ser criados novos TJM à luz do art. 125, §3º, CF.

3.16. JUSTIÇA ESTADUAL

É a competência residual.

A Lei de Organização Judiciária é de competência do TJ daquele Estado.

O DF não tem competência para organizar, legislar e manter o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, sendo competência da União.

Quem nomeia desembargador é o Presidente da República.

Com relação aos Territórios, se tiverem mais de 100 mil habitantes, haverá Poder Judiciário de primeira e segunda instâncias.

Nos Territórios, a jurisdição que seria da esfera federal vai caber aos juízes da justiça local.

Por fim, o quinto constitucional é composto por membros do MP e por advogados, devendo esta indicação ser feita pelos órgãos da própria instituição.

Haverá uma lista sêxtupla, que será enviada ao tribunal respectivo. O Tribunal elabora uma lista tríplice, que o Chefe do Executivo irá escolher um nos 20 dias subsequentes.

Segundo o STF, o TJ ou TRF não está obrigado a aceitar lista sêxtupla. Ou seja, se o poder judiciário entender que um daqueles indicados não possui reputação ilibada ou notório saber jurídico, poderá recusar a lista, a fim de devolver para que o órgão refaça a lista.

O STF já decidiu que a exigência de submissão do nome escolhido pelo governador à Casa Legislativa, para preenchimento de vaga destinada ao quinto constitucional, invade a atuação do Poder Executivo. O procedimento para a escolha dos Desembargadores foi tratado de forma exaustiva pelo art. 94 da CF/88, não podendo o constituinte estadual inovar e estabelecer novas etapas que não estejam expressamente previstas na Carta Federal (Inf. 775, STF).

Segundo o Supremo, se dividir por 5 os membros do Tribunal e este número não for um número inteiro, deverá ser arredondado para cima.

3.17. JULGAMENTO DE AUTORIDADES

3.17.1. MINISTROS DO STF

O STF é competente para julgamento dos seus atuais ministros em todos os processos, inclusive nos casos de improbidade administrativa. Sendo crime comum, também compete ao próprio STF. Todavia, sendo crime de responsabilidade cometido por ministro do STF, compete ao Senado Federal.

O STF entende que submeter o seu ministro ao julgamento de 1ª instância, haveria a subversão da ordem, quebrando o sistema judiciário como um todo.

3.17.2. GOVERNADORES

Não há previsão na CF de quem seja competente para julgar governadores por crime de responsabilidade.

A Lei 1.079/50 determina que os governadores sejam julgados por um Tribunal Especial, sob a presidência do Presidente do Tribunal de Justiça local, composto por:

- 5 membros do Poder Legislativo
- 5 membros do Poder Judiciário

O presidente do Tribunal de Justiça só votará em caso de empate.



3.17.3. PREFEITOS

Em relação aos prefeitos, o STF concluiu que é preciso fazer uma distinção:

- crime de responsabilidade impróprio: é o crime comum, razão pela qual será de competência do respectivo tribunal, a depender da natureza do crime.
- crime de responsabilidade próprio: é uma infração política-administrativa, devendo ser julgado pela câmara municipal.

3.18. QUINTO CONSTITUCIONAL

Reza no art. 94 da CF que, nos dos tribunais de segundo grau (Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Regionais do Trabalho), um quinto das vagas será destinada à advogados com mais de dez anos de efetivo exercício e atividade e à membros do Ministério Público com mais de dez anos de efetivo exercício de atividade.

No caso dos advogados, a OAB fará uma lista sêxtupla, que será encaminhada ao Tribunal de segundo grau, que fará uma lista tríplice e encaminhará ao chefe do Executivo, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.

Não há participação do Poder Legislativo no Quinto Constitucional. Se uma constituição estadual disser que a Assembleia Legislativa tem que aprovar o nome, está errado.

No caso dos Tribunais de Justiça o chefe do Executivo é o Governador do Estado.

No caso dos Tribunais Regionais Federais, o chefe do Executivo é o Presidente da República.

No caso dos Tribunais Regionais do Trabalho, o chefe do Executivo também é o Presidente da República.

No caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o chefe do Executivo é o Presidente da República. O TJDF faz parte da União, sendo organizado e estruturado por esta, conforme os arts. 21. XIII e 22, XVII, CF.

Em relação ao Ministério Público, o procedimento é igual. O Ministério Público elaborará uma lista sêxtupla com membros de mais de dez anos de efetivo exercício e atividade, envia ao tribunal, que elabora a lista tríplice e o chefe do Executivo nomeia.

Em se tratando de Tribunal Regional do Trabalho, quem faz a lista sêxtupla é o Ministério Público do Trabalho.

Observação 1: se o núcleo de desembargadores do tribunal não for múltiplo de cinco, a regra do quinto constitucional será para o arredondamento para cima. Exemplo: caso hajam 12 desembargadores no tribunal, serão 3 vagas, ainda que matematicamente $1/5$ de 12 seja 2,4, pois o arredondamento é para cima para o não amesquinhamento da regra do quinto constitucional.

Observação 2: supondo que haja uma vaga no quinto constitucional para membro do MP. A CF diz, categoricamente, que o membro do MP deve ter mais de 10 anos de efetivo exercício da atividade. Por conta dessa exigência, não se consegue formar a lista sêxtupla com todos os membros com mais de 10 anos de efetivo exercício da atividade, independente da razão. O STF decidiu, na ADI 1289 que, caso não haja número suficiente para fazer a lista sêxtupla, é possível que membros do MP com menos de dez anos de efetivo exercício da atividade participem da lista, para não haver o amesquinhamento do quinto constitucional, é a chamada tese do pensamento do possível, de Peter Häberle.

Observação 3: o STF já decidiu que o tribunal pode devolver a lista da OAB se ele entender que a lista não preenche os requisitos, no MS 25624.O que não pode é o tribunal fazer a lista.



3.19. PRECATÓRIOS JUDICIAIS

3.19.1. INTRODUÇÃO

Segundo o art. 100, os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em virtude de sentença, será feito exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

Ou seja, não pode abrir o crédito suplementar para pagar determinada dívida. O pagamento é exclusivamente na ordem cronológica. Assim, obedece-se ao princípio da isonomia.

O §5 diz que as entidades públicas serão obrigadas a incluir no seu orçamento verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças condenatórias transitadas em julgado. Todavia, esses débitos são os constantes de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho daquele ano, e tais precatórios serão pagos até 31 de dezembro do ano seguinte. Veja, não vai incidir aqui juros de mora, mas tão somente correção monetária. Só haverá juros de mora se não pagarem nesse prazo.

3.19.2. EXCEÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO

São os denominados RPV's.

No caso dos RPV's, não é aplicado o regime de precatório, devendo o pagamento ser feito pelo poder público diretamente.

Isso ocorre quando a obrigação é de pequeno valor. Porém, cada Estado deve definir o que é considerado pequeno valor.

No entanto, a própria CF estabelece o piso mínimo de RPV, o qual será o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social.

3.19.3. ORDEM DE PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS

A Fazenda vai efetuar o pagamento dos seus débitos, observada a seguinte ordem: apresentada até o dia 1º de julho, devendo ser paga até dia 31 de dezembro do ano seguinte.

Dentre esses precatórios, existe uma preferência, que são os créditos de natureza alimentar.

No entanto, há ainda uma super-preferência. Portanto, os créditos de precatórios observam a seguinte ordem:

- débitos de natureza alimentícia especiais, cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais, ou portadores de doença grave: neste caso, só até o triplo do fixado para RPV, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.
- demais débitos de natureza alimentar
- débitos não alimentícios

São débitos de natureza alimentícia salário, vencimento, pensão, benefício previdenciário, indenização por invalidez, honorários, etc.

O STF entende que pessoa que venha a completar 60 anos após a expedição do precatório, entrará automaticamente na regra de super-preferência.

3.19.4. SEQUESTRO DE VALOR

É possível o sequestro de valor.

O §6 diz que as dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral.

É possível que o Presidente do Tribunal autorize, em caso de preterimento ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, desde que haja requerimento do credor, o sequestro da quantia respectiva.



Veja, autoriza ao sequestro de valores:

- preterimento à ordem de pagamento
- não alocação orçamentária dos valores

3.19.5. DECRETAÇÃO DE INTERVENÇÃO

A CF autoriza que, no caso de desobediência de ordem judicial, é possível a intervenção federal.

Diante disso, poderíamos pensar que o não pagamento de débito de uma sentença transitada em julgado consiste em uma desobediência à ordem judicial, seria possível pensar que o não pagamento do precatório ensejaria intervenção federal.

No entanto, o STF faz uma ponderação a esta regra, interpretando no sentido de que, para se justificar a intervenção federal, é necessário que esta desobediência ao pagamento do precatório judicial seja dolosa e intencional, sem justificativa razoável.

3.19.6. VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO

A CF proíbe a fraude.

Veja, é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total como RPV, e outra parte como precatório.

3.19.7. PRECATÓRIOS PARA COMPRA DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Cabe atentar que é facultada ao credor, conforme a lei do Estado devedor, a entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo ente federado.

3.19.8. CESSÃO DE PRECATÓRIOS

O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor.

Todavia, o cessionário não se beneficiará da regra de preferência, tampouco do pagamento por meio de RPV.

Essa cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora.

3.19.9. CRIME DE RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

Segundo o §7, o Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça.

3.19.10. INCONSTITUCIONALIDADES DA EC

O STF declarou a inconstitucionalidade do dispositivo incluído na CF, por meio de emenda, que instituiu a compensação obrigatória entre os precatórios e os débitos constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora.

Ademais, segundo o STF, aos precatórios de natureza tributária, aplicam-se os juros de mora que incidem sobre os créditos tributários.

O STF declarou inconstitucional o pagamento de precatórios por meio de leilão.

Para o STF não é válido o pagamento de juros de mora dos precatórios com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.

4. INFORMATIVO DE JURISPRIDÊNCIA

4.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



A Constituição Estadual não pode ampliar as hipóteses de reserva de lei complementar, ou seja, não pode criar outras hipóteses em que é exigida lei complementar, além daquelas que já são previstas na Constituição Federal. STF. Plenário. ADI 5003/SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 5/12/2019 (Info 962).

Nos termos expressos da Constituição Federal, é vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada. STF. Plenário. ADI 6062 MC-Ref/DF, ADI 6172 MC-Ref/DF, ADI 6173 MC-Ref/DF, ADI 6174 MC-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 1º/8/2019

A imunidade formal prevista no art. 51, I, e no art. 86, caput, da CF/88 não se estende para os codenunciados que não se encontrem investidos nos cargos de Presidente da República, Vice-Presidente da República e Ministro de Estado.

A finalidade dessa imunidade é proteger o exercício regular dos cargos de Presidente (e Vice) da República e de Ministro de Estado, razão pela qual não é extensível a codenunciados que não se encontrem investidos em tais funções. STF. Plenário. Inq 4483 AgR-segundo/DF e Inq 4327 AgR-segundo/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgados em 14 e 19/12/201

Questões

1) (TJ/MS – 2020) — A Câmara Municipal de uma Capital estadual pretende instalar Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar possível ilicitude na conduta de empresas que, embora prestem serviço na Capital, recolhem o Imposto sobre Serviços em Município vizinho, onde tais empresas têm filiais, e no qual a alíquota incidente sobre a base de cálculo do imposto é menor, prática que, entendem os Vereadores, tem redundado em sonegação fiscal vultosa, causadora de prejuízos à Prefeitura da Capital. Nesse caso, considerada a disciplina da matéria na Constituição Federal e a jurisprudência pertinente do Supremo Tribunal Federal,

a) se instalada, a CPI estará impedida de exigir informações contábeis das empresas investigadas, por não dispor de poderes para determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal das empresas contribuintes investigadas, ambas matérias sujeitas à reserva jurisdicional.

b) os atos de investigação da CPI estarão sujeitos a controle jurisdicional, mediante provocação dos interessados, inclusive por meio de mandado de segurança, em defesa de direito líquido e certo próprio, não se aplicando, nessa hipótese, a regra da prejudicialidade por perda de objeto, ainda que haja a extinção da CPI em virtude da conclusão dos trabalhos investigatórios.

c) para ser instalada, a CPI dependerá do requerimento de, no mínimo, um terço dos membros da Câmara dos Vereadores, sujeitando-se ainda a eventual aprovação do Plenário, caso assim previsto na Lei Orgânica municipal ou Regimento Interno do órgão legislativo respectivo.

d) para seu funcionamento, a CPI estará sujeita ao prazo determinado em seu ato de instalação, admitidas prorrogações, igualmente determinadas e devidamente justificadas, dentro da legislatura respectiva, cabendo-lhe, se for o caso, o encaminhamento de suas conclusões ao Ministério Público, para promoção da responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

e) a CPI não poderá ser instalada, uma vez que o objeto de investigação não se insere dentro das competências do Município, mas sim do Estado, seja por recair sobre



conduta que extrapola os limites territoriais municipais, seja por existir suspeita da prática de crime, sujeita, portanto, à investigação e persecução penal.

2) (MPE/CE-2020) — Um membro do Ministério Público que atua em tribunal de justiça discorda do decidido em um acórdão da corte e pretende recorrer. Percebe, contudo, que o tribunal acolhera integralmente o que fora preconizado para o caso pelo promotor com atuação no primeiro grau.

Nesse caso, o membro do parquet

- a) não poderá recorrer, devido a preclusão processual lógica.
- b) não poderá recorrer, devido ao princípio institucional da unidade do Ministério Público.
- c) não poderá recorrer, devido ao princípio institucional da indivisibilidade do Ministério Público.
- d) poderá recorrer, devido ao princípio institucional da independência funcional.
- e) poderá recorrer, por ocupar posição hierárquica superior em relação ao promotor com atuação no primeiro grau.

Comentários

1) Gabarito: letra D. Nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição, e da jurisprudência do Supremo (RE 194.346 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 14/9/2010, 2ª turma), que se aplica às CPI's federais, estaduais, distritais ou municipais:

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.

...

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

a) Errado. As CPI's podem requerer informações contábeis das empresas investigadas, porquanto o STF já decidiu que o sigilo bancário e fiscal não é oponível à atividade sindicante das CPI's:

A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida (MS 24.749, rel. min. Marco Aurélio, julg. 29/9/2004, Plenário).

O princípio constitucional da reserva de jurisdição — que incide sobre as hipóteses de busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), de interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e de decretação da prisão, ressalvada a situação de flagrância penal (CF, art. 5º, LXI) — não se estende ao tema da quebra de sigilo, pois, em tal matéria, e por efeito de expressa autorização dada pela própria CR (CF, art. 58, § 3º), assiste competência à CPI, para decretar, sempre em ato necessariamente motivado, a excepcional



ruptura dessa esfera de privacidade das pessoas (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, julg. em 16/09/1999).

b) Errado. Em face de orientação em contrário traçada pelo STF:

É firme a jurisprudência deste STF no sentido de que a extinção da CPI prejudica o conhecimento do habeas corpus impetrado contra as eventuais ilegalidades de seu relatório final, notadamente por não mais existir legitimidade passiva do órgão impetrado. (...) (HC 95.277, rel. min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2008, Plenário)

(...) O controle jurisdicional de abusos praticados por CPI não ofende o princípio da separação de poderes. (MS 25.668, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 23/3/2006).

c) Errado. Para ser instalada, a CPI dependerá do requerimento de, no mínimo, um terço dos membros da Câmara dos Vereadores, sujeitando-se ainda a eventual aprovação do Plenário, caso assim previsto na Lei Orgânica municipal ou Regimento Interno do órgão legislativo respectivo.

A criação de CPI's depende unicamente do requerimento de um terço dos membros da Câmara Municipal, não se sujeitando ao escrutínio do plenário. Nesse sentido, o STF:

3º), cumpre, ao presidente da Casa Legislativa, adotar os procedimentos subsequentes e necessários à efetiva instalação da CPI, não se revestindo de legitimação constitucional o ato que busca submeter, ao Plenário da Casa Legislativa, quer por intermédio de formulação de questão de ordem, quer mediante interposição de recurso ou utilização de qualquer outro meio regimental, a criação de qualquer CPI. (MS 26.441, rel. min. Celso de Mello, j. 25/4/2007, Plenário)

e) Errado. O objeto certo de investigação da CPI municipal diz respeito aos interesses do Município, visto que as empresas que prestam serviços no local estão recolhendo ISS no Município vizinho. O fato de existir suspeita de prática de crime, sujeita à investigação e persecução penal, não impede o trabalho investigatório da CPI, que poderá encaminhar o resultado de suas investigações ao Ministério Público, para que promova as ações cabíveis.

2) Gabarito: letra D. O princípio está determinado no §1º do art. 127 da CF/1988. O Princípio da Independência Funcional enuncia que os membros do MP ostentam independência no exercício de suas funções, não se subordinando a quaisquer outros Poderes da República, mas apenas à Constituição Federal, à Lei e ao livre convencimento de seus Membros. Nem mesmo os Procuradores estão submetidos hierarquicamente ao Procurador-Geral da República ou de Justiça, nos Estados. A vinculação é meramente administrativa.

A partir daí, veio a ser deduzida a doutrina do promotor natural, segundo a qual ao integrante do parquet é assegurada a defesa mesmo em face do chefe da instituição (HC 90.277, rel. Min. Ellen Gracie, DJu 1º/8/2008).

a) Errado. Não há preclusão processual nem prevenção em relação ao promotor vinculado ao tribunal de justiça, em virtude do princípio da independência funcional.

b) Errado. O princípio institucional da unidade do Ministério Público estabelece que os membros do MP integram apenas um órgão, sob a direção do procurador-geral, mas não estão hierarquicamente vinculados a ele. Isso decorre de outro princípio, o da independência funcional, segundo o qual os procuradores são livres no exercício de suas funções, não se vinculando a quaisquer poderes e nem mesmo ao Chefe do MP.



c) Errado. O princípio da indivisibilidade estabelece que os membros do MP não estão vinculados ou preventos a quaisquer processos, podendo ser substituídos em qualquer fase.

e) Errado. Não existe qualquer posição hierárquica de um procurador sobre outro, nem mesmo do Procurador-Geral.



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



61 3033-3739



61 98442-2591

CAPÍTULO 18 – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

A CF é uma constituição rígida, sendo necessário observar um procedimento especial para alteração.

Essa rigidez da constituição decorre do princípio da supremacia formal da CF. Isto significa dizer que se uma norma é produzida em descompasso com a CF, esta será considerada nula.

O controle de constitucionalidade é uma análise ou verificação de compatibilidade ou adequação de leis ou atos normativos em relação a uma constituição.

O **parâmetro** é a constituição com suas normas expressas e implícitas e o **objeto do controle** são as leis ou atos do controle.

Caso a CF não fosse rígida, qualquer processo legislativo poderia alterar a CF.

Para que o controle de constitucionalidade seja viável, é preciso que haja um órgão estatal independente do órgão de produção legislativa. Isto gera uma separação de poderes efetiva.

Importante ressaltar os pressupostos do controle de constitucionalidade, em especial o “forte”, que é o que existe no Brasil, Estados Unidos, Áustria, Alemanha, Portugal, Espanha, etc.

São quatro pressupostos de controle de constitucionalidade forte:

- a) Existência de uma constituição formal e rígida;
- b) A Constituição como fundamento de validade para o restante do ordenamento;
- c) Órgão dotado de legitimidade para realizar o controle, para dizer se as leis ou atos normativos são ou não adequadas com a constituição;
- d) Existência de uma sanção: invalidade da lei/ato normativo.

O controle de constitucionalidade fraco, existente no Canadá, Inglaterra e Nova Zelândia, é aquele que não invalida a lei, não estirpa a lei do ordenamento. Isso pode ocorrer, por exemplo, no caso do Canadá, com a chamada “cláusula do não obstante”, da seção 33 da constituição canadense. Os estados províncias do Canadá podem fazer as leis e imunizá-las da apreciação da corte constitucional, por pelo menos cinco anos. O tribunal constitucional pode até achar que a lei é inconstitucional, mas não pode declarar a sua inconstitucionalidade e invalidar a lei por pelo menos cinco anos. É um controle que existe, mas é mais fraco porque o legislativo pode fazer leis imunizadas por pelo menos cinco anos. Passados os cinco anos a imunização pode ser renovada ou não, podendo o tribunal constitucional invalidar a lei se entender cabível.

Na Inglaterra, a corte constitucional pode declarar a incompatibilidade de uma lei frente a um tratado de direitos humanos (*Human Rights Act*), mas não invalida a lei. Essa declaração da corte constitucional inglesa é apenas um constrangimento do Parlamento, que pode simplesmente não fazer nada face à sua supremacia (*Supremacy of Parliament*). Há aqui um controle de constitucionalidade que o Parlamento faz, mas é fraco.

Já o controle de constitucionalidade forte, conhecido como *Strong Judicial Review*, de matriz norte-americana e austríaca, que existe na Alemanha, Itália, Brasil, Portugal, etc. Significa que se o tribunal constitucional entender que a lei contraria a constituição, irá invalidá-la. Tem como instrumentos a ADI, ADC, ADPF e ADO, além da via incidental.

1. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS

Uma lei em vigor é presumivelmente constitucional, isto se dá por dois motivos:

- a lei é elaborada pelo povo, por meio de seus representantes;
- para fins de segurança jurídica, pois passou por um processo legislativo.



Por conta desta presunção de constitucionalidade, a lei deve ser cumprida até que seja declarada inconstitucional.

Aliás, como corolário da excepcionalidade da inconstitucionalidade da lei, é preciso que, sempre que possível, seja promovida a continuidade do ato normativo, devendo a interpretação do ato ser preservado no ordenamento jurídico.

2. REQUISITOS

Os requisitos que as leis ou os atos normativos devem respeitar para serem adequados com a constituição são os formais e materiais.

2.1. REQUISITOS FORMAIS

Dizem respeito ao modo ou forma de produção da lei, que deve respeitar a forma definida na constituição, independente do conteúdo da lei.

2.2. REQUISITOS MATERIAIS

Dizem respeito ao conteúdo da lei, que deve respeitar o conteúdo determinado na constituição.

A inconstitucionalidade formal ocorre quando há o descumprimento de requisitos formais. Existem três tipos de inconstitucionalidade formal:

2.3. TIPOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL

2.3.1. ORGÂNICA

É aquela que ocorre quando regras de competência são descumpridas. Exemplo: art. 22, CF, onde diz as competências privativas da União para legislar, como matéria de direito civil, processual civil, direito penal, processual, eleitoral, do trabalho, etc. Supondo que um estado membro faz uma lei sobre direito do trabalho, será inconstitucional, pois é de competência da União. Não interessa o conteúdo dessa lei, pois vai gerar uma inconstitucionalidade formal orgânica por descumprimento de regras de competência.

No entanto, a inconstitucionalidade formal orgânica não é só por regras de competência envolvendo o federalismo (apesar de ser o mais comum de cair em prova).

Outro exemplo é quando diz respeito à regras de competência de espécie normativa. Supondo que exista uma matéria que o campo de competência seja de lei complementar e o poder legislativo produz uma lei ordinária. Haverá uma inconstitucionalidade formal orgânica por descumprimento de regras de competência normativa.

2.3.2. POR DESCUMPRIMENTO DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DO ATO.

É aquela que ocorre quando regras expressas na constituição para a produção de leis são descumpridas. Se o poder legislativo e o executivo não cumpre, haverá uma inconstitucionalidade formal por descumprimento de pressupostos expressos.

Exemplo 1: art. 62, CF, que trata dos requisitos expressos para edição de Medida Provisória, que são a relevância e urgência. A MP tem que ter relevância e urgência e, caso não possua, haverá inconstitucionalidade formal por descumprimento de pressupostos objetivos.

Exemplo 2: art. 18, §4º, CF, que trata dos requisitos para a produção ou criação de municípios. A lei estadual deve respeitar outros requisitos expressos de forma objetiva, caso contrário será inconstitucional.

2.3.3. PROPRIAMENTE DITA

Ocorre quando há o descumprimento de regras do processo legislativo dos arts. 59 a 69 da CF.

Pode ser uma inconstitucionalidade **formal subjetiva**, que é aquela que ocorre na fase de iniciativa, ou seja, o sujeito sem legitimidade para apresentar proposição a apresenta, havendo um vício de iniciativa.

O exemplo mais comum são as hipóteses do art. 61, §1º, CF⁴¹.

Já a inconstitucionalidade **formal objetiva** ocorre quando as regras da fase constitutiva ou complementar são descumpridas.

Exemplo: supondo que um projeto de lei complementar tramite na Câmara e é aprovado por maioria absoluta e tramita no Senado, onde é aprovado por maioria simples. Descumpriu aqui uma regra do processo legislativo, do art. 69. CF, que exige, para lei complementar, maioria absoluta.

Aqui há uma inconstitucionalidade formal objetiva

Já a inconstitucionalidade material é aquela que ocorre quando o conteúdo da lei descumpra o conteúdo da constituição.

3. SISTEMAS (MATRIZES) DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

No âmbito da jurisdição constitucional forte existem três grandes sistemas ou matrizes de controle e são elas: sistema dos Estados Unidos de 1803, no século XIX, da Áustria, em 1920, e da França, em 1958, ambos no século XX.

3.1. SISTEMA NORTE-AMERICANO (SISTEMA JUDICIAL)

Tem como derivado o caso Marbury vs. Madison, julgado pelo juiz Marshall, que é aqui o grande criador do controle de constitucionalidade moderno.

Esse controle se dá através de um sistema judicial, ou seja, são juízes que irão controlar a constitucionalidade, chamado de controle difuso de constitucionalidade, porque todos os juízes podem controlar a constitucionalidade.

A constituição outorga o poder de fazer o controle de constitucionalidade ao Poder Judiciário.

Esse controle vai se dar sempre em um caso concreto (*in concreto*), que vai ser pela via da exceção e pela via ou modo incidental.

⁴¹ Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.



A questão principal não é a do controle de constitucionalidade, que surge excepcionalmente no caso concreto. A questão principal do caso é uma questão de direito civil, penal, empresarial, tributário, etc, não é de administrativo e nem constitucional.

Surge de forma incidental, como um incidente num caso concreto.

A decisão tem um efeito *inter partes*, ou seja, a norma é declarada inconstitucional entre as partes, no caso concreto.

No âmbito norte-americano, no entanto, existem os *stare decisis* (ater-se ao decidido), ou seja, a decisão da Suprema Corte cria o precedente vinculante e os outros tribunais e a administração têm que seguir aquilo que foi determinado.

A decisão ganha efeito vinculante a partir do *binding precedent*, do precedente obrigatório do *stare decisis*, mas, a princípio, o efeito é *inter partes*.

Exemplo: Caso Roe vs Wade⁴². Roe questionou a lei do Texas sobre aborto e a Suprema Corte entendeu ser inconstitucional. Até o terceiro mês é permitido o aborto desde que sigam determinados padrões. Quando a Suprema Corte decidiu, decidiu *inter partes*, decidindo somente para Roe. Essa decisão passa a valer para toda a sociedade americana, devendo todos os órgãos do judiciário respeitar pelo *stare decisis* e não pelo controle de constitucionalidade. A questão aqui, portanto, é do *common law*, do direito anglo-saxão, da ideia do precedente obrigatório.

3.2. SISTEMA AUSTRIACO

Surge, na constituição da Áustria, com seu grande artífice sendo Hans Kelsen, em outubro de 1920, o sistema austríaco.

O sistema austríaco também é judicial e o controle é concentrado porque apenas um órgão realiza esse controle: a Corte (Tribunal) Constitucional. É essa corte que diz para o país inteiro se uma determinada lei é constitucional ou não.

Esse controle concentrado se dá sempre em abstrato (*in abstracto*), sendo um controle sobre leis e teses, não havendo caso concreto.

Esse controle é feito via ação, e não via exceção. Esse controle não irá surgir excepcionalmente num caso concreto, terá uma ação onde se discutirá isso. A mais famosa ação é a Ação Direta de Inconstitucionalidade.

O efeito, quando o Tribunal Constitucional diz que determinada lei contraria a constituição, o efeito é *erga omnes*, ou seja, é válido para todos.

3.3. SISTEMA FRANCÊS (SISTEMA POLÍTICO)

Surge com a constituição da França e é um sistema político de controle. O órgão de controle é um órgão político, chamado de Conselho Constitucional.

A constituição outorga o poder de controle de constitucionalidade a um poder que não integra o Judiciário.

A composição desse órgão se dá com três membros indicados pelo Presidente da República, três membros indicados pela Câmara dos Deputados (lá chamado de Assembleia

42 O caso de McCorvey (ou Roe, nome que a levou à fama) chama a atenção não apenas pelo pioneirismo da decisão proferida, mas também pelo caminho percorrido até chegar à Suprema Corte. À época, com 22 anos, McCorvey enfrentava sua terceira gestação — já não tinha a guarda de seus dois primeiros filhos, em decorrência de problemas envolvendo inaptidão (não tinha trabalho fixo, era usuária de drogas e já fora moradora de rua). McCorvey não queria levar sua terceira gestação a termo e preferia interromper aquela gravidez. Suas opções, no entanto, eram limitadas: as leis do Texas apenas permitiam o abortamento em casos de risco à vida da gestante, o que não era o caso; em razão de suas condições econômicas, McCorvey não poderia viajar para outro local. (...) A decisão do caso Roe vs. Wade, com sete votos a dois em seu favor, modificou a regulação do aborto existente no país. Fonte: <https://www.conjur.com.br/2018-abr-23/direito-civil-atual-roe-vs-wade-sistema-litigio-estrategico-eua>



Nacional), três membros indicados pelo Senado. Esses nove membros terão um mandato de nove anos.

Além desses nove membros, todos os ex-presidentes também compõe o Conselho Constitucional.

Diante de todo o exposto, é possível afirmar a existência de três sistemas de controle de constitucionalidade:

No Brasil, o sistema adotado é o judicial, mas há temperamentos de controle político, como é o caso da análise da CCJ, veto jurídico do PR etc.

3.4. MODELOS DE CONTROLE

- controle difuso (americano): qualquer juiz analisa a constitucionalidade. Ex.: EUA. Esse controle outorga a competência a todos os órgãos do poder judiciário para analisar a constitucionalidade do ato normativo. Tem origem no caso Marbury vs. Madison. A Suprema Corte, por meio do Juiz John Marshall, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário poderia deixar de aplicar uma lei ao caso concreto, caso essa se mostrasse inconstitucional. Por isso, passou-se a entender que o judiciário poderia fazer o controle das leis.
- controle concentrado (austriaco): o controle de constitucionalidade é concedido a somente um órgão, de natureza jurisdicional. Tem origem na Áustria, por meio de Hans Kelsen. O controle não serviria para a solução de casos concretos, devendo ser analisado abstratamente se a lei é compatível ou não com a constituição.

3.5. VIAS DE AÇÃO

São as formas de impugnação do ato normativo.

- via incidental: o indivíduo busca a inconstitucionalidade. O pedido do indivíduo não é diretamente o pedido de inconstitucionalidade, pois, em verdade, ele quer que seja concedido o bem da vida pleiteado. Trata-se de um direito subjetivo do indivíduo. Existe uma controvérsia concreta que irá exigir que o magistrado aprecie a inconstitucionalidade do ato normativo, em que faz a separação do indivíduo e o bem almejado. Todos os juízes realizam o controle de constitucionalidade diante de casos concretos, inclusive de ofício.
- via principal: o legitimado requer que se reconheça a inconstitucionalidade. É abstrata. O pedido do legitimado é no sentido de inconstitucionalidade da lei. Não há caso concreto tampouco direito subjetivo, eis que o processo é objetivo.

3.6. MOMENTO DE CONTROLE

- preventivo: ocorre quando ainda não há norma em vigor. A inconstitucionalidade ocorre antes do nascimento do ato normativo. A fiscalização incide sobre o projeto de lei ou de emenda. Pode ser feito pela comissão de constituição e justiça dos poderes legislativos, bem como pelo veto jurídico do chefe do poder executivo. Também é possível quando o parlamentar impetra MS, com o objetivo de sustar o andamento de um PL ou uma PEC, sob o argumento de que esse parlamentar teria o direito líquido e certo de participar de um processo legislativo constitucional.
- repressivo: ocorre após a edição do ato normativo. A fiscalização incide sobre o ato normativo já positivado. Nesse caso, é feito pelo poder judiciário, como regra. É possível que se dê na via política, como é o caso de sustação de ato do poder executivo que exorbite o poder regulamentar ou os limites da delegação em caso de lei delegada.



3.7. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL

A jurisdição constitucional serve para dar ideia sobre a possibilidade de dizer se o direito impugnado está de acordo ou em desacordo com a constituição. E para tanto, há uma consagração de diversos mecanismos na via incidental e na via abstrata.

3.8. FISCALIZAÇÃO NÃO JURISDICIONAL

É possível que o controle de constitucionalidade seja feito por órgãos não integrantes do poder judiciário, como o poder legislativo, executivo ou tribunais de contas.

3.8.1. PODER LEGISLATIVO

O poder legislativo vai se manifestar em determinadas hipóteses sobre a continuidade de um ato que pode ou não virar uma norma.

Esse juízo de constitucionalidade legislativo poderá se dar por meio de:

- Comissões de Constituições e Justiça: fiscalizam os projetos de leis dentro das casas legislativas. É um controle político preventivo de constitucionalidade, pois não há norma positivada.
- Sustação de atos normativos do poder executivo que exorbitem o poder regulamentar ou mesmo quando exorbitem a delegação legislativa no momento de elaborar a lei delegada: aqui há violações à constituição. No entanto, este controle político de constitucionalidade é repressivo. Trata-se do denominado veto legislativo. O ato do Congresso Nacional que vai sustar a eficácia da lei não tem efeitos retroativos, a despeito de haver doutrina em sentido contrário.
- Apreciação de medidas provisória pelo poder legislativo: a sua rejeição total pode ser baseada no fato de que a MP não cumpriu os requisitos de relevância e urgência. Aqui também haveria um controle político repressivo feito politicamente pelo poder legislativo.
- Suspensão da eficácia de lei declarada inconstitucional em controle difuso: é feito pelo senado federal, havendo um controle político.

3.8.2. PODER EXECUTIVO

O poder executivo em 3 situações atuará como fiscal do controle de constitucionalidade da lei:

- Veto jurídico: é o controle preventivo de constitucionalidade.
- Inexecução da lei por considerá-la inconstitucional: no entanto, somente ao chefe do executivo poderá tomar essa decisão. Segundo o STF, o chefe do executivo pode determinar que os órgãos subordinados não cumpram a lei, sob o argumento de que a lei é considerada inconstitucional. Trata-se de um poder de autodefesa. Aplica-se ao presidente, governadores e prefeito. Cabe ressaltar que só pode fazer isso se não houver uma manifestação definitiva e vinculante do poder judiciário sobre aquela lei que busca não cumprir.
- Fiscalização por meio de intervenção federal: não deixa de ser um controle de constitucionalidade. Se o Estado não está observando a CF, o restabelecimento da ordem constitucional justificaria a intervenção federal.

3.8.3. TRIBUNAIS DE CONTAS

Os tribunais de contas não são órgãos do poder judiciário, pois pertencem ao legislativo.

Todavia, o STF já decidiu que poderão fazer controle de constitucionalidade, desde que seja feito pela via incidental. Poderão afastar a aplicação de determinadas leis que entenderem inconstitucionais.



A decisão da Corte pode ser submetida ao exame do poder judiciário.

3.9. CONTROLE POLÍTICO PREVENTIVO

Por ser preventivo, significa que é no processo de produção de lei ou ato normativo, ou seja, no processo legislativo.

No Poder Legislativo, pelo processo legislativo, se dá através da Comissão de Constituição e Justiça, chamada de CCJ. A CCJ faz um controle político preventivo porque pode arquivar projeto de lei ou mesmo PEC que entenda inconstitucional.

Já o Poder Executivo faz o controle preventivo através do veto (art. 66, CF), ou seja, o Presidente da República pode vetar projeto de lei que entenda inconstitucional.

3.10. CONTROLE POLÍTICO REPRESSIVO

Já existe lei ou ato normativo.

O Poder Legislativo faz esse controle político repressivo, sendo exemplo o do art. 62, §5º, CF, quando o Presidente da República produz e publica a MP, e o Poder Legislativo pode rejeitar a MP que entende ser inconstitucional por não respeitar o conteúdo e urgência ou que o conteúdo da MP contrarie a constituição, etc.

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

(...)

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.

Outro exemplo é o constante no art. 49, V, CF, que trata da competência exclusiva do Congresso Nacional para sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem os limites da delegação legislativa.

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

(...)

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

O Poder Executivo faz esse controle através de um entendimento do STF de que este poder pode deixar de aplicar, administrativamente, uma lei por entender que esta lei é inconstitucional. Esse precedente do STF é bastante criticado, inclusive dentro da própria Corte. Remete à antiga constituição, à época da intervenção militar, quando o Presidente da República era um General Militar e só havia um legitimado para propor ADI, que era o Procurador Geral da República. Por conta disso, deixava de “mãos atadas” o Poder Executivo, dependente do PGR para propor ADI. Daí surgiu esse entendimento de que o Poder Executivo pode deixar de aplicar, administrativamente, determinada lei ou ato normativo que entenda ser inconstitucional.



À luz da Constituição de 1988, sob o regime democrático de direito, esse entendimento do STF é absurdo, até porque um dos legitimados para propor ADI é o próprio Presidente da República, não justificando mais o entendimento anterior.

O Tribunal de Contas⁴³ faz o controle através da súmula 347, STF.

Súmula 347

O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.

Essa súmula já foi relativizada em algumas situações. O STF, em algumas situações e decisões liminares deixaram de aplicá-la, mas continua válida.

3.11. CONTROLE JUDICIAL PREVENTIVO

Quem faz o controle judicial preventivo é o STF. Esse controle, por ser preventivo, é feito no processo legislativo.

Esse controle judicial preventivo é feito via Mandado de Segurança.

Quem possui legitimidade para impetrar esse Mandado de Segurança são somente os Deputados e Senadores.

O direito líquido e certo desse Mandado de Segurança é o Devido Processo Legislativo. Enquanto participantes do processo legislativo, Deputados e Senadores tem direito de participar de um processo legislativo hígido.

3.12. CONTROLE DIFUSO

O controle difuso é o reconhecimento da inconstitucionalidade de um ato normativo em razão de um caso concreto. Qualquer juiz ou tribunal poderá reconhecer.

É conhecido como controle incidental, *incidenter tantum*, por via de exceção, por via de defesa, controle concreto ou controle indireto.

3.12.1. COMPETÊNCIA

A competência é de qualquer órgão do poder judiciário.

3.12.2. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE PELOS TRIBUNAIS (RESERVA DE PLENÁRIO)

A CF consagra expressamente a cláusula de reserva de plenário, conforme art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Ou seja, a lei é presumivelmente constitucional, de forma que para reconhecer a inconstitucionalidade é indispensável que seja dada por maioria absoluta.

Nos Tribunais com número superior a 25 desembargadores, poderá ser constituído Órgão Especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno.

⁴³ Os Tribunais de Contas, em que pede sejam chamados de Tribunais, são órgãos independentes que auxiliam o Poder Legislativo e não compõe o Judiciário. Os Tribunais de Contas auxiliam no controle da fiscalização financeira e orçamentária.



Sempre que for acatada uma arguição de inconstitucionalidade, o incidente deverá ser encaminhado ao Tribunal Pleno ou ao Órgão Especial, onde houver, de forma que decidirão se o ato será constitucional ou inconstitucional. Após, os autos são devolvidos ao órgão fracionário, de forma que decidirá conforme o que ficou decidido pelo Tribunal Pleno ou ao Órgão Especial.

A reserva de plenário vincula todos os tribunais do Brasil, inclusive o STF, que deverá decidir com maioria absoluta se a norma é constitucional ou inconstitucional.

Cumpra observar que, mesmo na hipótese em que não se declara expressamente a inconstitucionalidade da norma, o órgão fracionário não pode afastar a sua incidência, pois nesse caso estaria reconhecendo a inconstitucionalidade.

Tal tema foi objeto da súmula vinculante 10, estabelecendo que viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

O STF, em razão de celeridade, entende que se já existe declaração anterior de inconstitucionalidade emanada do Órgão Especial ou do Tribunal Pleno, ou se já existe uma manifestação do plenário do STF sobre aquela inconstitucionalidade em controle difuso, não há necessidade de submeter à cláusula de reserva de plenário os casos futuros no mesmo sentido.

Segundo o Supremo, a aplicação do precedente não precisa ser absolutamente literal. Se a partir do julgado for possível concluir um posicionamento acerca de determinada matéria, já se afigura suficiente a invocação do aresto para afastar a vigência da norma maculada pelo vício já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

O atual CPC, no art. 949, parágrafo único, estabelece que os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Em outras palavras, existem duas mitigações à cláusula de reserva de plenário, ou seja, duas hipóteses em que o órgão fracionário poderá decretar a inconstitucionalidade sem necessidade de remessa dos autos ao Plenário (ou órgão especial):

- quando o Plenário (ou órgão especial) do Tribunal que estiver decidindo já tiver se manifestado pela inconstitucionalidade da norma;
- quando o Plenário do STF já tiver decidido que a norma em análise é inconstitucional.

Se o direito analisado é pré-constitucional, não é necessário observar a cláusula de reserva de plenário. Ou seja, para dizer se a lei não foi recepcionada ou foi recepcionada não precisa observar essa regra, pois esta só é necessária para fins de inconstitucionalidade.

Se a Assembleia Legislativa de um Estado edita um decreto legislativo tratando especificamente da situação de determinado Deputado Estadual, mas o órgão fracionário do TRF1, ao apreciar um processo envolvendo este Deputado, declara, em controle difuso, a inconstitucionalidade deste decreto legislativo, sem que tenha levado o debate ao Plenário ou pelo órgão especial deste Tribunal. Neste caso, não houve a violação ao art. 97 da CF/88 e à SV 10, pois o que se sujeita ao princípio da reserva de plenário é a "lei" e o "ato normativo". O decreto legislativo que foi declarado inconstitucional pelo TRF não constitui lei em sentido formal ou material, nem possui caráter de ato normativo.

Segundo Hely Lopes Meirelles, atos normativos são aqueles expedidos sem destinatários determinados, com finalidade normativa, alcançando todos os sujeitos que se encontram na mesma situação de fato abrangida por seus preceitos. São atos de comando abstrato e impessoal, semelhantes aos da lei. Desse modo, para que seja caracterizado como ato normativo são necessários os seguintes requisitos: a) abstração; b) generalidade e c) impessoalidade.



No caso concreto, o decreto legislativo tinha um destinatário específico e referia-se a uma dada situação individual e concreta, exaurindo-se no momento de sua promulgação. Logo, este decreto legislativo não preencheu os requisitos para ser ato administrativo, sendo caracterizado como típico ato estatal de efeitos concretos. Diante disso, não se aplica ao caso a regra do art. 97 da CF/88 nem há ofensa ao Enunciado 10 da SV.

Em suma, o STF entende que não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário do Tribunal que declara inconstitucional decreto legislativo que se refira a uma situação individual e concreta. Isso porque o que se sujeita ao princípio da reserva de plenário é a lei ou o ato normativo. Se o decreto legislativo tinha um destinatário específico e referia-se a uma dada situação individual e concreta, exaurindo-se no momento de sua promulgação, ele não pode ser considerado como ato normativo, mas sim como ato de efeitos concretos (Info 844).

Recentemente, o STF entendeu que não viola a Súmula Vinculante 10, nem a regra do art. 97 da CF/88, a decisão do órgão fracionário do Tribunal que deixa de aplicar a norma infraconstitucional por entender não haver subsunção aos fatos ou, ainda, que a incidência normativa seja resolvida mediante a sua mesma interpretação, sem potencial ofensa direta à Constituição. É o caso em que o juiz entende que a norma não é aplicável ao caso concreto, não significando que esteja declarando a inconstitucionalidade da norma.

3.13. PARÂMETRO DE CONTROLE

Como se sabe, do ponto de vista abstrato, o parâmetro é sempre a constituição em vigor, pois não se admite a análise de ato normativo anterior em face da constituição também anterior.

No entanto, na via incidental, é possível que haja:

- controle da norma pós-constitucional em face da Constituição em vigor: é o tradicional juízo de (in)constitucionalidade.
- controle da norma pré-constitucional em face da Constituição em vigor: é o juízo de recepção ou não recepção da norma pré-constitucional.
- controle da norma pré-constitucional em face da Constituição anterior: o juízo é feito sob os olhos da constituição da época da edição do ato normativo.

A EC 45 passou a dizer no §3 do art. 5 que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Com isso a EC 45 promoveu um alargamento do parâmetro do controle de constitucionalidade, aumentando o bloco de constitucionalidade.

3.14. RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Recurso extraordinário é um meio de se provocar o STF para se manifestar sobre algo do caso concreto. Há uma controvérsia concreta, mas constitucional, que já havia sido suscitada nos juízos inferiores.

Compete ao STF julgar, em grau de recurso extraordinário, as causas em única ou em última instância, quando a decisão recorrida:

- contrariar dispositivo desta Constituição
- declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal
- julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição
- julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Se há um conflito entre lei municipal e lei federal, o que há aqui é um conflito de competência e não de legalidade, motivo pelo qual a matéria é constitucional.

Veja, não fala nada sobre tribunal.

O STF entende que, embora não esteja expressamente consagrado na CF, normas pré-constitucionais que tenham como parâmetro constituições anteriores, podem ser objeto de



recursos extraordinário para que o supremo avalie se a lei é constitucional ou não à época de sua edição.

O STF também admite que por meio de recurso extraordinário se questione se a lei é pré-constitucional foi recepcionada ou não pela Constituição vigente. Não há propriamente um controle de constitucionalidade.

Com a EC 45, o recurso extraordinário passou a exigir que haja repercussão geral da questão constitucional que está sendo discutida, extrapolando os interesses da parte. Isso é importante, pois o STF deverá ser uma via excepcional. No entanto, se a questão é constitucional, há uma certa presunção de que o caso extrapola o interesse das partes. Mas o importante é saber que somente poderá ser recusado a admissibilidade do recurso extraordinário pela manifestação de 2/3 de seus membros.

3.15. EFEITOS DA DECISÃO

A decisão no controle pela via concreta só alcança as partes (inter partes), não dispondo de efeitos vinculantes em relação àquele que não participou do processo. Produz, em regra, efeitos retroativos (ex tunc).

Embora essa seja a regra, o STF pelo voto de 2/3 de seus membros, por conta da segurança jurídica ou de relevante interesse social, poderá modular os efeitos, tornando efeitos prospectivos ou ex nunc para início da vigência da eficácia de sua decisão.

A decisão do controle concreto não dispõe de força vinculante aos demais órgãos do poder judiciário, tampouco para a administração pública, ainda que proferida pelo STF.

Esta decisão vinculará apenas as partes.

Cabe ressaltar que esses efeitos poderão ser ampliados, se houver a suspensão da lei por ato do senado federal, conforme o art. 52, X, ou se o STF decidir editar uma súmula vinculante sobre a matéria.

3.16. ATUAÇÃO DO SENADO FEDERAL

Se o STF reconhece uma inconstitucionalidade no âmbito do controle difuso, haverá a comunicação ao senado federal, o qual poderá, por juízo de conveniência, suspender a execução da lei, dando eficácia *erga omnes* a decisão do STF. Esta suspensão tem efeito meramente prospectivos (ex nunc).

O Senado Federal promove esse ato por meio de resolução.

A decisão sobre suspender ou não é uma decisão política do senado. Uma vez decidido sustar a eficácia da lei, o Senado não pode posteriormente revogar o seu ato de suspensão.

A competência do Senado alcança qualquer ato normativo (lei ou ato administrativo) que tenha sido reconhecido inconstitucional pelo STF, seja ele municipal, distrital, estadual ou federal.

3.17. SÚMULA VINCULANTE

A súmula vinculante é produto da EC 45/04.

A CF passa a trazer a redação do art. 103-A, dizendo que o STF poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

Veja, a súmula vinculante não vincula o STF e nem mesmo o Poder Legislativo.

A súmula vinculante tem por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, em que estejam havendo uma controvérsia atual entre órgãos judiciais ou entre órgãos judiciais e a administração pública, desde que desta controvérsia



acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.

Na verdade, a CF já consagrou um rol mínimo de legitimados a provocar o STF a editar a súmula vinculante, que são aqueles legitimados para propor ADI.

A CF ainda estabelece que do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

3.17.1. INICIATIVA

O STF poderá aprovar, rever ou cancelar a súmula vinculante por iniciativa própria ou por provocação.

São legitimados a propor a edição, cancelamento e revisão de súmula vinculante:

- Legitimados da ADI
- Defensor Público Geral da União
- Tribunais (TJ's, TRF's, TRE's, TRT's, Tribunais Militares, etc.)
- Municípios incidentalmente, no curso do processo.

3.17.2. REQUISITOS

Os requisitos para súmula vinculante são cumulativos:

- matéria constitucional
- reiteradas decisões do STF sobre a matéria
- exista controvérsia entre órgão do judiciário ou entre órgãos do judiciário e administração pública
- exista grave insegurança jurídica
- relevante multiplicação de processo sobre aquela matéria

3.17.3. DELIBERAÇÃO

Para haver a edição ou cancelamento da súmula vinculante, é necessário que haja a votação de 2/3 dos membros do STF, em sessão plenária.

A súmula vinculante passa a ter eficácia a partir da sua publicação na imprensa oficial, tendo eficácia imediata.

Nada obsta que o STF, por decisão de 2/3 de seus membros, restrinja os efeitos vinculantes ou decida outro momento para sua eficácia, desde que haja segurança jurídica ou excepcional interesse público.

3.17.4. DESCUMPRIMENTO

Em caso de descumprimento de súmula vinculante, é possível que haja interposição de reclamação diretamente ao STF.

Ademais, a reclamação é instrumento hábil a de interpretação ou reinterpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato.

No entanto, a reclamação constitucional, fundada em afronta à SV 10, não pode ser usada como sucedâneo (substituto) de recurso ou de ação própria que analise a constitucionalidade de normas que foram objeto de interpretação idônea e legítima pelas autoridades jurídicas competentes.

No caso de ato ou omissão da administração pública, exige-se o prévio esgotamento das vias administrativas.

Se a reclamação estiver sendo ajuizada contra uma decisão administrativa, e o STF acolher essa reclamação, ele dará ciência à autoridade, bem como determinará que os futuros



casos semelhantes deverão observar o disposto na súmula vinculante, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.

3.17.5. CANCELAMENTO OU REVISÃO

Segundo o STF, para admitir-se a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante, é necessário demonstrar que houve pelo menos uma das seguintes hipóteses:

- evidente superação da jurisprudência do STF no tratamento da matéria
- alteração legislativa quanto ao tema; ou
- modificação substantiva de contexto político, econômico ou social.

3.17.6. SÚMULAS ANTERIORES À EC 45

As súmulas anteriores à EC 45 não tem efeitos vinculantes, mas é possível que o STF torne elas vinculantes, desde que haja:

- deliberação por 2/3 dos membros do STF
- nova publicação na imprensa oficial.

3.18. CONTROLE ABSTRATO

3.18.1. INTRODUÇÃO

Teve origem na Constituição da Áustria, elaborada por Kelsen.

Aqui há um controle a partir de um processo objetivo, não havendo, em verdade, sujeitos processuais, visto que não há interesses subjetivos. Veja, não pode sequer desistir da ação direta de inconstitucionalidade.

O objetivo é verificar se a norma em tese é compatível ou não com a constituição.

Se o parâmetro for a CF, competente será o STF. Se for a CE, então será o TJ.

Existem algumas expressões que são utilizadas como sinônimo para o controle abstrato: controle concentrado, controle direto, controle por via de ação, controle por via principal e controle em tese.

3.18.2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Compete privativamente ao STF processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade, que tenha por objeto uma lei ou ato normativo, federal ou estadual, em face da constituição federal.

a) Legitimação ativa

Poderão dar início a uma ADI e ADC:

- Presidente da República
- mesa do Senado
- mesa da Câmara
- mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
- governador de Estado ou do Distrito Federal;
- Procurador-Geral da República;
- Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- partido político com representação no Congresso Nacional;
- confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Há uma série de legitimados. O STF entendeu que apenas partidos políticos e confederação sindical ou entidade de classe necessitam de advogado para propositura de ações no controle abstrato.

É necessário ainda que ele apresente procuração com poderes específicos para impugnar a norma questionada, sob pena da ação ser extinta sem resolução do mérito.



O governador do Estado não precisa de advogado. Nesse caso, poderá praticar todos os atos privativos de um advogado.

Com relação ao partido político com representação no CN, mesmo que perca essa representatividade após a propositura da ação, não implicará a perda da legitimidade inicial, pois esta análise é feita no momento da propositura.

Para caracterizar a entidade de classe como de âmbito nacional é necessário que:

- associados ou membros distribuídos em, pelo menos, 9 Estados da federação;
- o interesse postulado seja da categoria, e não apenas de fração da categoria.

Segundo o STF, as associações de associações, que congregam pessoa jurídicas, possuem legitimidade para instaurar o controle abstrato. Ex.: associações de delegados de polícia de âmbito nacional, formada por associações de delegados de âmbito estadual.

No que toca as centrais sindicais não poderão propor ADI, visto que é exigido confederação sindical, ainda que as centrais tenham abrangência nacional.

O STF distingue os legitimados em dois grupos:

- Legitimados universais: podem propor ADI sobre qualquer matéria:
 - (a) Presidente da República
 - (b) Mesa do Senado
 - (c) Mesa da Câmara
 - (d) Procurador Geral da República
 - (e) Conselho Federal da OAB
 - (f) Partidos políticos com representação no CN
- Legitimados especiais: para propor ADI deve comprovar interesse jurídico ou de agir. ou seja, deve haver uma pertinência temática entre o ato impugnado e as funções do legitimado:

- A) Confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional
- B) Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal
- C) Governadores do Estado e do DF

Os governadores podem impugnar sobre leis de outros Estados, desde que comprove que essas leis afetem o seu Estado. Ex.: benefício de ICMS em um Estado.

Segundo o STF, prerrogativa da Fazenda Pública de prazo em dobro para se manifestar nos autos, é aplicável às ações de controle de constitucionalidade concentrado.

3.18.3. OBJETO

O objeto da ADI é lei ou ato normativo de caráter federal ou estadual. Para ADC, o ato deve ser federal. Ademais, é necessário que a norma seja primária, bem como seja editada posteriormente à Constituição de 1988, pois não se admite ADI de norma pré-constitucional.

Norma distrital pode ser objeto de ADI, desde que a lei distrital esteja tratando de tema de competência estadual.

O STF para uma norma ser objeto de ADI deve preencher os seguintes requisitos:

- editada após a CF/88
- dotada de abstração e generalidade (normatividade)
- natureza primária
- norma deve estar em vigor

Este requisito de abstração e generalidade foi ponderado pelo STF, que passou a admitir o controle de constitucionalidade em face de lei em sentido estrito, com efeitos concretos. Todavia, em regra, não se admite controle de constitucionalidade em face de lei ou ato normativo sem que haja abstração e generalidade. Por conta disso, o STF admite controle de constitucionalidade de leis orçamentárias. Esta regra, em tese, não se aplica à ação direta de constitucionalidade.



Quanto ao último requisito, o CF não admite controle de constitucionalidade de norma que não esteja mais em vigor. Isso porque, se a norma não está mais em vigor no momento em que é proposta a ADI, não há mais objeto, pois ela já foi retirada do ordenamento jurídico.

Da mesma forma, se a lei ou ato normativo perder a vigência ao longo do processo objetivo, a ADI perderá o seu objeto. O STF abre uma exceção para o caso em que esteja pronto para julgamento (já está em pauta), hipótese em que não perderá o objeto a ADI, ainda que tenha sido revogada.

São normas que podem ser impugnadas por ADI:

- Emenda constitucional: não cabe controle de constitucionalidade de norma originária, mas norma derivada é possível.
- Constituições estaduais
- Tratados e convenções internacionais, ainda que verse sobre direitos humanos com quórum especial
- Leis complementares
- Leis ordinárias
- Leis delegadas
- Decretos legislativos
- Resoluções
- Medidas provisórias
- Decretos autônomos do PR
- Decretos legislativos que suspendam a eficácia de delegação ao PR ou que tenha sido editado em razão de o PR ter exorbitado o poder regulamentar
- Regimentos internos dos Tribunais, Câmara e Senado

No que toca às medidas provisórias, sendo ela rejeitada ou perder a eficácia, haverá a perda do objeto da ADI. Caso a MP tenha sido convertida em lei, a ADI prossegue, mas é necessário que seja aditada a petição inicial pelo autor da ação.

3.18.4. PARÂMETRO DE CONTROLE

O objeto deve ser comparado diante do parâmetro de controle, sendo este basicamente a Constituição vigente.

Com a EC 45, houve o alargamento do parâmetro, visto que o §3º do art. 5º passou a dizer que os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados com status de emenda, também constituirão parâmetro para o controle de constitucionalidade.

Ou seja, integra o parâmetro de controle abstrato:

- Constituição, inclusive a parte permanente e as disposições transitórias
- Tratados internacionais de direitos humanos, aprovados com status de emenda

Alguns autores ainda citam os princípios constitucionais implícitos.

Quando se analisa a ADI, a revogação superveniente da lei ou ato normativo, há perda do objeto. Esta é a regra. No controle incidental, a revogação da lei impugnada, diferentemente do controle abstrato, não gera perda do objeto, nem o julgamento da ação. Isso porque o sujeito busca o bem da vida, por meio da declaração de inconstitucionalidade, não importando mais se o ato foi ou não revogado. O indivíduo só quer a declaração de procedência de sua ação. Inclusive o magistrado poderá se manifestar sobre a constitucionalidade daquela lei incidentalmente na sentença.

Recentemente, o STF ratificou o entendimento de que, se o ato normativo que estava sendo impugnado na ADI for revogado antes do julgamento da ação, a regra será a perda superveniente do objeto e a ADI não deverá ser conhecida.

Todavia, há exceções:

- Exceção 1 (fraude processual): não haverá perda do objeto e a ADI deverá ser conhecida e julgada caso fique demonstrado que houve "fraude processual", ou seja,



que a norma foi revogada de forma proposital a fim de evitar que o STF a declarasse inconstitucional e anulasse os efeitos por ela produzidos (STF ADI 3306).

- Exceção 2 (conteúdo do ato impugnado foi repetido): não haverá perda do objeto se ficar demonstrado que o conteúdo do ato impugnado foi repetido, em sua essência, em outro diploma normativo. Neste caso, como não houve desatualização significativa no conteúdo do instituto, não há obstáculo para o conhecimento da ação (ADI 2418/DF).
- Exceção 3 (STF não foi comunicado previamente sobre a revogação): caso o STF tenha julgado o mérito da ação sem ter sido comunicado previamente que houve a revogação da norma atacada. Nesta hipótese, não será possível reconhecer, após o julgamento, a prejudicialidade da ADI já apreciada.

Segundo o STF, se é proposta ADI contra uma medida provisória e, antes de a ação ser julgada, a MP é convertida em lei com o mesmo texto que foi atacado, esta ADI não perde o objeto e poderá ser conhecida e julgada. Como o texto da MP foi mantido, não cabe falar em prejudicialidade do pedido. Isso porque não há a convalidação ("correção") de eventuais vícios existentes na norma, razão pela qual permanece a possibilidade de o STF realizar o juízo de constitucionalidade. Neste caso, ocorre a continuidade normativa entre o ato legislativo provisório (MP) e a lei que resulta de sua conversão.

Ex: foi proposta uma ADI contra a MP 449/1994 e, antes de a ação ser julgada, houve a conversão na Lei nº 8.866/94. Vale ressaltar, no entanto, que o autor da ADI deverá peticionar informando esta situação ao STF e pedindo o aditamento da ação (Inf. 851).

3.18.5. CAUSA DE PEDIR ABERTA

O controle de constitucionalidade obedece ao princípio do pedido, ou seja, alguém deve pedir ao Judiciário para declarar inconstitucional de um ato normativo.

Todavia, o STF pode declarar a inconstitucionalidade com base em outro dispositivo constitucional, ainda que não tenha sido este o alegado pelo legitimado. Ou seja, o STF pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo com base em fundamento jurídico diverso do alegado.

Consoante este entendimento, é forçoso convir que proposta uma ADI questionando a constitucionalidade formal da lei X, poderá o STF julgar procedente a demanda pois sob o fundamento de que há uma inconstitucionalidade material, apenas, na lei.

Por isso, a causa de pedir, no controle abstrato, é uma aberta.

É isso que justifica a impossibilidade de ação rescisória em face de controle de constitucionalidade, pois quando o STF declarara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei, ele avalia tendo por parâmetro toda a CF, e não apenas os artigos ou fundamentos levantados por aquele que peticiona.

Eventualmente, é cabível reanalisar uma norma anteriormente declarada constitucional, por meio de uma nova ADI, tendo em vista que o STF poderia mudar a opinião posteriormente. Isto é, o STF não se submete às decisões do próprio STF.

Da mesma forma, é possível, em uma mesma ação, cumular pedido típico de ADI com pedido típico de ADC. A cumulação objetiva permite o enfrentamento judicial coerente, célere e eficiente de questões minimamente relacionadas entre si (Inf. 786, STF).

3.18.6. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA

O legitimado que propõe a ação não está defendendo direito próprio, e sim um direito objetivo.

Assim sendo, não pode o autor da ADI desistir da ação, tendo em vista o princípio da indisponibilidade da ação. Pode ele não propor, mas tendo proposto, não pode desistir.

Da mesma forma, não se admite o pedido de medida cautelar em ADI.



3.18.7. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Quando se propõe ADI, o relator conhece da ação.

Não havendo rejeição de imediato, o Relator pedirá ao órgão que produziu a norma impugnada preste informações. O prazo para prestar essas informações é de 30 dias. Sendo impugnada uma norma federal, o Relator da ADI pedirá ao Congresso Nacional e ao Presidente da República que prestem informações.

Havendo pedido de medida cautelar, antes do julgamento, os órgãos e as autoridades do qual esse ato emanou terão 5 dias para se manifestar sobre a medida cautelar. Caso o Relator repute indispensável, também serão ouvidos o AGU e o PGR, no prazo de 3 dias.

Após, o Plenário vai julgar a concessão ou não da medida cautelar, e, em seguida, o Relator pedirá informações com maior tempo, que é o período de 30 dias.

A depender da relevância da matéria, o Relator poderá remeter o processo diretamente ao Plenário, efetuando, inclusive, o julgamento de mérito, encerrando a ADI.

Nesse caso, o Relator pede informações ao órgão, o qual prestará as informações em 10 dias. Em seguida, mandará para manifestação do AGU e depois ao PGR, tendo cada um deles se manifestado no prazo de 5 dias.

Todavia, este julgamento direto deve ser justificado, ou seja:

- matéria deve ser relevante
- especial significado para a ordem social e segurança jurídica

Há uma celeridade muito maior no julgamento.

→ Suspeição e impedimento de ministro

Não caberia suspeição de ministro em sede de processo objetivo, pois o que se questiona é de lei em tese, no controle abstrato. Ou seja, caberia sim suspeição em controle concreto, como nos casos de processos subjetivos: recursos extraordinários, julgamento originário, etc.

Já o impedimento, no caso em que o ministro do STF tenha anteriormente atuado, é plenamente possível. É o caso em que anteriormente o ministro do STF tenha atuado como AGU ou PGR.

3.18.8. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

Em regra, não é possível intervenção de terceiros no controle abstrato de constitucionalidade.

Há uma exceção, que é o *amicus curiae*, o qual, segundo o NCPC, passou a ser uma intervenção de terceiros.

Essa proibição de intervenção de terceiros no processo objetivo encontra redação expressa na Lei 9.868, ainda quando o terceiro seja legitimado para propor a ADI.

Por outro lado, é possível que haja litisconsórcio ativo, propondo uma ADI perante o STF. Ex.: Governador e Presidente ingressam com ADI.

3.18.9. ADMISSIBILIDADE DE *AMICUS CURIAE*

Amicus curiae é o amigo da Corte.

São entidades ou órgãos que querem se manifestar sobre uma questão constitucional que está sendo discutida na suprema corte.

Para a admissão do *amicus curiae* no processo, é imprescindível o pedido por meio de advogado. Isto é, o STF não admite que esse pedido seja feito sem assinatura de advogado.

O §2º do art. 7 da Lei 9868 estabelece que o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.



O *amicus curiae* colabora com o aumento da participação da sociedade na formação do convencimento da suprema corte, tornando mais democrática e com maior nível de legitimidade.

A figura do *amicus curiae* vai de encontro a denominada sociedade aberta dos intérpretes, de Peter Häberle.

O *amicus curiae* poderá fazer:

- apresentação de memoriais
- sustentação oral pelo tempo de até 15 minutos

O *amicus curiae* poderá ser admitido até que o processo seja pautado para julgamento. Passando esse prazo, não cabe mais ingresso do *amicus curiae*.

Para que seja admitido o terceiro como *amicus curiae*, é necessário que preencha os seguintes requisitos cumulativos:

- relevância da matéria
- representatividade dos postulantes

Isto significa que pessoa física não poderá atuar como *amicus curiae*, pois não teria representatividade adequada.

O pedido para ser *amicus curiae* será dirigida ao Relator do processo, o qual deverá emitir um despacho irrecorrível. Porém, se o Relator rejeitar a participação do *amicus curiae*, caberia agravo para o Plenário.

O STF afirmou que não são cabíveis recursos interpostos por terceiros estranhos da relação processual, nos processos objetivos, não só na ADI. Portanto, *amicus curiae* não pode interpor recurso em processo de natureza objetiva.

O STF já admitiu o ingresso de *amicus curiae* em sede de recurso extraordinário.

Além disso, o legislador ordinário passou a prever a possibilidade de haver *amicus curiae* no exame de repercussão geral, bem como no procedimento de aprovação de súmula vinculante.

3.18.10. ATUAÇÃO DO AGU

Decorrido o prazo de informações do órgão do qual emanou a lei ou ato normativo, deverá se manifestar nos autos o AGU e o PGR, cada qual no prazo de 15 dias.

Segundo o §3 do art. 103, caberá ao AGU a defesa da constitucionalidade do ato ou texto impugnado. Seria o defensor legis.

No entanto, o STF temperou esta regra, estabelecendo que o AGU deverá defender a norma quando entender que a norma é constitucional, podendo deixar de defender a constitucionalidade da norma quando entender que a norma é inconstitucional, inclusive na hipótese em que for contrária aos interesse da União e nos casos em que o STF já tenha se manifestado anteriormente em situação similar.

O AGU atuaria na ADI, mas caso fosse em uma ADC, a manifestação do AGU seria dispensável. Isso porque na ADC já se está defendendo a compatibilidade da norma com a Constituição.

No tocante à ADO, não haveria norma a ser questionada do ponto de vista de sua inconstitucionalidade, mas sim a ausência de norma. Neste caso, todavia, a Lei 9.868 é expressa no sentido de que cabe ao Relator a decisão de ouvir ou não o AGU em ADO.

3.18.11. ATUAÇÃO DO PGR

O PGR atuará como fiscal da constituição.

O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.

Mesmo quando o PGR propõe a ADI, ele tem direito de opinar a respeito da ADI.

Interessante notar que o PGR poderá ingressar com a ADI, mas se manifestar posteriormente pela constitucionalidade da lei, atuando como fiscal da constituição. Essa



medida se fará necessária principalmente na hipótese em que o PGR não puder desistir da ação, por conta do princípio da indisponibilidade. O PGR não se prende à sua própria manifestação.

3.18.12. ATUAÇÃO DO RELATOR NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO

O Relator, após a manifestação do AGU e do PGR, poderá determinar mais esclarecimentos.

Neste caso, o relator pode requisitar informações, designando um perito ou comissão de peritos, a fim de obter um parecer sobre a questão.

A fim de garantir uma sociedade aberta dos intérpretes, o relator pode fixar uma data em que ouvirá depoimento de pessoas com experiência e autoridade sobre aquela matéria, por meio de uma audiência pública. Há uma maior gama de intérpretes da CF, garantindo maior legitimidade do STF.

Essas perícias, depoimentos, etc., devem ser realizadas no prazo de 30 dias.

Com o vencimento do prazo, o relator lança o relatório e libera para inclusão em pauta de julgamento.

3.18.13. MEDIDA CAUTELAR EM ADI

É cabível medida cautelar em ADI.

O pedido de medida cautelar é apreciado pelo Supremo, diante de uma alegação de que naquele caso é necessário a concessão da cautelar, pois estariam presentes:

- fumaça do bom direito
- perigo da demora (receio de dano irreparável)

A medida cautelar é deferida pela maioria absoluta dos membros do STF.

Para instalação da sessão que apreciará a medida cautelar exige-se um mínimo de 8 ministros, com a exceção do período de recesso.

No caso do recesso, o presidente do STF poderá conceder medida cautelar *ad referendum* do Plenário, ficando sujeito a referenda do Plenário.

Por conta disso, a decisão proferida em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade não se submete à cláusula da reserva de plenário.

Em caso de urgência excepcional, a medida cautelar poderá ser determinada inclusive sem a oitiva do órgão do qual emanou o ato normativo.

A depender da relevância da matéria, o relator pode propor ao plenário para que seja convertido a medida cautelar em julgamento direto da ação.

Via de regra, a medida cautelar é concedida com efeitos *ex nunc*, não retroagindo. Excepcionalmente, o STF pode conferir eficácia retroativa, sendo necessário que o STF se manifeste expressamente nesse sentido.

A medida cautelar é dotada de eficácia *erga omnes* e, portanto, é para todos, geral.

O efeito da medida cautelar também é vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário, pois o STF não se submete, e para a Administração Pública, direta ou indireta. O Poder Legislativo também não se submete no exercício de sua função típica.

Por conta desse efeito vinculante, a medida cautelar também tem o efeito de suspender, durante o período de sua eficácia, o julgamento de todos os processos que envolva a aplicação daquele objeto questionado.

Perceba que há essa suspensão quando do deferimento da medida cautelar, ou seja, o indeferimento da liminar não tem o condão de gerar qualquer efeito vinculante. Ou seja, ainda que o Tribunal indefira a liminar, pode ser que o TJ reconheça a inconstitucionalidade daquele ato normativo, pois o indeferimento da liminar pelo STF não significa julgar improcedente o pedido, mas tão somente que não estariam presentes os requisitos da medida cautelar.



A concessão da medida cautelar, como suspende a vigência da lei, o que há em verdade é a aplicação provisória da legislação anterior, que havia sido revogada. Trata-se de uma repristinação provisória, a qual inclusive é tácita.

Se o STF não se manifesta sobre a possibilidade de repristinação ou não, e aquela lei tenha sua vigência suspensa, haverá a repristinação, pois a lei anteriormente suspensa volta a produzir efeitos.

Há ainda a possibilidade de o STF se manifestar no sentido de que aquela lei revogada não voltará a produzir o efeito repristinatório.

Veja, se o autor da ADI perceber que a norma anterior que foi revogada pela norma atual que está sendo impugnada pela ação padece do mesmo vício de inconstitucionalidade, ele deverá impugnar tanto a lei atual como a revogada. Desse modo, o autor da ADI deverá impugnar todo o "complexo normativo", ou seja, tanto a norma atual como aquelas que eventualmente foram revogadas e que tinham o mesmo vício. Isso porque a norma revogada voltará a ter eficácia, caso não tenha também sido impugnada, gerando, em tese, os mesmos problemas da norma declarada inconstitucional, o que torna a decisão da Suprema Corte inútil, caso não seja também impugnada. Esta medida de impugnação do complexo normativo é denominada de efeito repristinatório indesejado.

Dessa forma, para que não haja o efeito repristinatório indesejado, é necessário que:

- autor tenha feito pedido nesse sentido (princípio do pedido). Ex.: Autor pede que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei B e da Lei A, que foi revogada pela lei B.
- haja manifestação expressa do STF, no sentido de que não haverá efeito repristinatório.

Ficando silente o STF, a repristinação ocorrerá.

Recentemente, a fim de evitar essa "eficácia repristinatória indesejada", o PGR, que ajuizou a ação, impugnou não apenas a Lei nº 3.041/2005, mas também aquelas outras normas por ela revogadas. O STF concordou com o PGR e, ao declarar inconstitucional a Lei nº 3.041/2005, afirmou que não deveria haver o efeito repristinatório em relação às leis anteriores de mesmo conteúdo. O dispositivo do acórdão ficou, portanto, com a seguinte redação:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 3.041/2005, do Estado de Mato Grosso do Sul, inexistindo efeito repristinatório em relação às leis anteriores de mesmo conteúdo, (...)

3.18.14. DECISÃO DE MÉRITO EM ADI

a) Quórum de instalação e de julgamento

A decisão de mérito somente é tomada se estiverem presente 8 ministros. Portanto, o quórum de instalação de julgamento é especial.

Havendo quórum, a manifestação de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade dependerá da manifestação da maioria absoluta do STF. Ou seja, é indispensável que haja no mínimo 6 ministros.

Portanto, se instalado o quórum para julgamento (8 ministros), mas apenas 5 se manifestam a favor da inconstitucionalidade da norma, e 3 votam pela constitucionalidade, o julgamento será suspenso até que retornem os ministros ausentes, a fim de que haja a manifestação num sentido ou noutro.

Isso porque a ADI tem caráter dúplice, e a negativa da inconstitucionalidade significa a constitucionalidade da norma, o que torna a presunção da lei absolutamente constitucional.

O ministro presidente do STF não é obrigado a votar, desde que se alcance os 6 votos antes de ele falar. Mas poderá votar, caso assim deseje. Normalmente, não o faz, razão pela



qual se verifica o placar de 10x0, quando há unanimidade. Todavia, o presidente do STF poderá ser obrigado a votar nos casos em que houver empate.

b) Natureza dúplice ou ambivalente

Quanto à natureza dúplice ou ambivalente da ADI, essa decisão de mérito produzirá efeitos seja num sentido ou seja noutro.

Sendo dado procedente ao pedido da ADI, haverá a inconstitucionalidade da norma. Por outro lado, caso seja julgado improcedente o pedido da ADI, será reconhecida a constitucionalidade da norma.

Por isso, a causa de pedir é aberta, eis que o STF precisa avaliar perante a CF inteira, a fim de avaliar se aquela norma é constitucional ou não, pois sendo julgada improcedente a ADI, ganhará a norma o status de presunção absoluta da constitucionalidade, dispensando ADC posterior.

Cabe atentar que esta regra não vale para todas as normas, pois não cabe ADC para leis ou atos normativos estaduais. Ex.: Lei estadual, sendo julgada improcedente, não dará a ela a presunção absoluta de constitucionalidade, pois não cabe ADC de norma estadual.

c) Efeitos da decisão

Como se sabe, as decisões definitivas numa ADI são, via de regra:

- efeitos *ex tunc*
- eficácia erga omnes: eficácia é geral
- efeitos vinculante: em relação à administração e aos demais órgãos do poder judiciário
- efeito repristinatório: se a lei nasceu morta, não revogou a legislação anterior, vindo a produzir efeitos.

Quando falamos em efeitos retroativos (*ex tunc*), significa dizer que a lei é retirada do ordenamento jurídico desde a sua origem. Ou seja, não se pode invocar qualquer direito tendo por base aquele diploma legal, pois o efeito é retroativo.

Por exemplo, um Estado instituiu um tributo inconstitucional em 2010. Se o STF reconhecer em 2015 a inconstitucionalidade da lei, os tributos deverão ser devolvidos.

Havendo desrespeito a uma decisão do STF em processo objetivo, é cabível reclamação, podendo ser proposta diretamente na suprema corte.

O efeito vinculante atinge a Administração pública direta e indireta, e os demais órgãos do poder judiciário, mas não alcança o STF. E isto é o que justifica agora o entendimento de que o STF pode reconhecer de futuras ações diretas que impugnem as matérias que já foram apreciadas em sede de controle abstrato pela suprema corte.

Assim, é possível modificar o entendimento antes firmado. Isto é, como o STF não se submete àquilo que o STF decidiu, é possível que o Supremo mude de opinião. Ou seja, poderá apreciar a medida de novo, admitindo a ADI que já foi objeto de ação anteriormente pela Suprema Corte.

O efeito vinculante não alcança a atividade normativa do Poder Legislativo, podendo editar uma lei igual àquela anteriormente julgada inconstitucional pelo STF, o que vai justificar a propositura de uma nova ADI sobre aquela lei.

Esta função típica do poder legislativo não pode ser vedada, sob pena de fossilização das normas. Por outro lado, em sua função atípica, o poder legislativo fica submetido ao entendimento do STF.

E isso vale também para o Poder Executivo, o qual não se submete ao efeito vinculante do STF, nos casos em que se vale da função legislativa, como é o caso das medidas provisórias e leis delegadas.

Trata-se de uma reação legislativa à decisão da Corte Constitucional com o objetivo de reversão jurisprudencial.



No caso de reversão jurisprudencial (reação legislativa) proposta por meio de emenda constitucional, a invalidação somente ocorrerá nas restritas hipóteses de violação aos limites previstos no art. 60, e seus §§, da CF/88. Em suma, se o Congresso editar uma emenda constitucional buscando alterar a interpretação dada pelo STF para determinado tema, essa emenda somente poderá ser declarada inconstitucional se ofender uma cláusula pétrea ou o processo legislativo para edição de emendas.

No caso de reversão jurisprudencial proposta por lei ordinária, a lei que frontalmente colidir com a jurisprudência do STF nasce com presunção relativa de inconstitucionalidade, de forma que caberá ao legislador o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente se afigura legítima.

Para ser considerada válida, o Congresso Nacional deverá comprovar que as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais se fundou a decisão do STF no passado não mais subsistem. O Poder Legislativo promoverá verdadeira hipótese de mutação constitucional pela via legislativa (Inf. 801, STF).

É possível que o STF decida que a legislação anterior não volte a produzir efeitos. Então, é possível que o STF entenda que a norma revogadora é inconstitucional e a norma por ela revogada também seja considerada inconstitucional.

Neste caso, é indispensável que:

- autor impugne o pedido cumulativo, no sentido de que seja reconhecida a inconstitucionalidade da norma revogadora e da norma revogada
- o STF se manifeste expressamente neste sentido

d) Modulação dos efeitos temporais

A Lei 9.868 trouxe a técnica de modulação temporal dos efeitos da decisão do controle de inconstitucionalidade, também denominada de técnica de manipulação temporal.

Com base nessa técnica, o STF poderá dizer a partir de quando aquela decisão passará a produzir efeitos, em relação a atos praticados a partir de quando, bem como se vai retroagir ou não.

O tema está no art. 27 da Lei 9.868, estabelecendo que ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Em relação a hipótese de restringir a eficácia contra todos a decisão, é possível que ocorra esta restrição nas seguintes situações:

- afastamento da declaração da inconstitucionalidade em relação a certos atos já praticados: por exemplo, aqueles atos já praticados pela Lei estão salvaguardados, continuando válidos, e regerão esta situação em definitivo.
- afastamento da incidência em relação a determinadas situações: é o caso em que a situação X não pode ser alcançada pela declaração de inconstitucionalidade, pois vai causar mais prejuízos à segurança jurídica, interesse social, etc. do que o reconhecimento da constitucionalidade.

Poderá ainda o STF decidir que a declaração de inconstitucionalidade só vá produzir efeitos prospectivos, *ex nunc*, a partir do trânsito em julgado daquela decisão, resguardada a validade de todos os atos já praticados com base naquela lei.

Ademais o STF poderá fixar um outro momento, que não o trânsito em julgado, podendo ser antes ou depois da declaração de inconstitucionalidade.

O STF, excepcionalmente, admite, em sede de controle concreto, a declaração de inconstitucionalidade pró-futuro, desde que haja manifestação expressa de 2/3 dos seus membros.



Por outro lado, o STF entende que não é cabível a modulação temporal dos efeitos da decisão em relação a direito pré-constitucional, contestado em face da constituição vigente. Isso porque, em verdade, não há um controle concreto, difuso ou incidental. Se o direito é pré-constitucional, é necessário analisar se ele foi recepcionado ou não recepcionado pela nova constituição, não havendo falar em modulação temporal.

Segundo o STF (Inf. 780), depois da proclamação do resultado final do julgamento sobre a inconstitucionalidade de determinada lei, o julgamento deve ser considerado concluído e encerrado e, por isso, mostra-se inviável a sua reabertura para discutir novamente a modulação dos efeitos da decisão proferida. A análise da ação direta de inconstitucionalidade é realizada de maneira bifásica:

- primeiro, o Plenário decide se a lei é constitucional ou não.
- em seguida, se a lei foi declarada inconstitucional, discute-se a possibilidade de modulação dos efeitos.

Uma vez encerrado o julgamento e proclamado o resultado, inclusive com a votação sobre a modulação (que não foi alcançada), não há como reabrir o caso, ficando preclusa a possibilidade de reabertura para deliberação sobre a modulação dos efeitos.

O STF entendeu que a nomeação do Procurador-Geral do Estado e dos Presidentes de sociedade de economia mista e empresas públicas não podem ser submetidas ao crivo da Assembleia Legislativa.

e) Definitividade da decisão de mérito

A decisão do STF é irrecorrível.

É cabível a oposição de embargos declaratórios, mas é para quem participou do pleito.

Não cabe ação rescisória.

f) Limites da eficácia retroativa

A decisão proferida em ADI tem efeitos *ex tunc*, mas seus efeitos só se operam no plano abstrato, da norma, não atingindo diretamente o caso concreto, que foi praticado com base naquela norma.

A decisão de mérito somente mostra que é viável questionar o ato realizado com base naquela lei ou ato normativo. Isto é, deverá a pessoa buscar medidas cabíveis para que o seu bem da vida seja efetivamente alcançado, seja por meio administrativo ou por meio de ações judiciais.

No caso de ações, em que tenha se embasado o ato por uma inconstitucionalidade declarada pelo STF, é preciso que esta ação obedeça a requisito temporal. Isso porque irá caber uma ação rescisória se o julgado se baseou numa declaração de um ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo, mas a ação rescisória somente caberá se for proposta no prazo de 2 anos. Passado este período não cabe mais rescisória.

A decisão do STF, em sede de controle de constitucionalidade abstrato, como se viu, ocorre no plano abstrato. Ou seja, para o plano concreto, é preciso que “pegar” essa decisão do STF e requerer que ela seja aplicada.

Essa é a razão pela qual a decisão do STF não tem efeitos automáticos em relação à sentença, devendo ser aplicado em ações judiciais e recursos, no prazo legal.

Segundo o STF, a decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões proferidas em outros processos anteriores que tenham adotado entendimento diferente do que posteriormente decidiu o Supremo. Para que haja essa reforma ou rescisão, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC 1973 (art. 966, V do CPC 2015), observado o prazo decadencial de 2 anos (art. 495 do CPC 1973 / art. 975 do CPC 2015). Segundo afirmou o STF, não se pode confundir a eficácia normativa de uma sentença que declara a



inconstitucionalidade (que retira do plano jurídico a norma com efeito “ex tunc”) com a eficácia executiva, ou seja, o efeito vinculante dessa decisão. (Inf. 787, STF).

g) Transcendência dos motivos determinantes

Tradicionalmente, dizem que é a parte dispositiva da sentença que transitar em julgado que é capaz de produzir efeitos vinculantes, de forma que não poderia ser objeto de questionamento. O fundamento da decisão não poderia ser considerado vinculante.

Para a teoria da transcendência dos motivos determinantes, os fundamentos que motivaram a decisão vinculariam, transcendendo o objeto específico daquela ação, alcançando outros objetos análogos àquele, se valendo dos fundamentos da suprema corte para declarar que aquele objeto seria inconstitucional.

Ou seja, aqueles fundamentos justificariam a apreciação de objetos análogos àquele que já foi apreciado pela suprema corte.

A consequência da adoção da transcendência dos motivos determinantes é de que se o STF já se manifestou pela inconstitucionalidade de um ato normativo, se outro ato normativo análogo àquele é editado, caberia uma reclamação ao STF, requerendo que a autoridade de suas decisões fossem observadas.

Por exemplo, se o estado de SP tem a lei X reputada inconstitucional pelo STF, não poderia o estado de Goiás editar a lei XGO, sob pena de caber reclamação ao STF contra esta lei, pois os motivos determinantes transcenderiam o objeto daquela ação.

A adoção dessa teoria transcendência dos motivos determinantes não é pacífica no STF.

h) Inconstitucionalidade por arrastamento

A inconstitucionalidade por arrastamento traz a ideia de que o acessório segue o principal. Quando se declara inconstitucional a Lei X, arrasta também o decreto x, que regulamentava a lei X.

Também por vezes se há o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1º de uma Lei, o artigo 2º perde o sentido completamente, ou passa a ter um sentido absolutamente diverso do que tinha, hipótese em que também haverá o arrastamento desse dispositivo para fora do ordenamento jurídico.

Essa inconstitucionalidade por arrastamento está no fato de que um dispositivo inconstitucional da lei é estendido a outro dispositivo, em virtude da interdependência entre eles.

A inconstitucionalidade por arrastamento também é denominada de inconstitucionalidade por atração, consequencial, é uma exceção ao princípio do pedido.

O STF admite e aplica a inconstitucionalidade por arrastamento.

i) Momento da produção de efeitos da decisão

A decisão do STF produz efeitos a partir da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, com a publicação da ata de julgamento.

Não é necessário que se publique o acórdão, bastando que se publique a ata de julgamento.

Não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão, tampouco a publicação integral do acórdão.

3.18.15. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO (ADO)

A ADO é uma novidade da CF/88, pois é uma ação direta, e do controle abstrato, porém visa a interrupção de um estado de inércia de um órgão que não promove aquilo que a CF determinou que ele promovesse.



É o reconhecimento de um estado de inconstitucionalidade por ausência de elaboração de uma norma constitucionalmente devida.

a) Características da ADO

As ADO's têm por características ter como parâmetro a norma constitucional que não seja autoaplicável, ou de eficácia limitada, pois somente estas normas é que poderão exigir regulamentação. Ou seja, se a norma já é, por si só, autoaplicável, não haverá a necessidade de atuação de um órgão da seara infraconstitucional.

Portanto, a ADO tem como referência norma constitucional que não seja autoaplicável de eficácia limitada.

As características de uma ADI são quase as mesmas de uma ADO, justificadas pela natureza do que se pretende em uma ADO.

b) Legitimidade ativa

Os legitimados ativos são os mesmos legitimados da ADI, do art. 103.

c) Legitimidade passiva

É o órgão omissor, é a autoridade que não cumpriu o dever constitucional imposto.

Atente-se que nem sempre é o Congresso Nacional o legitimado passivo. Isso porque há situações em que a inexistência de lei, e o decurso do prazo que já passou do razoável, é atribuída à falta de iniciativa privativa do presidente da república.

Sendo de iniciativa do presidente, não há como o Congresso Nacional legislar, sob pena de vício de iniciativa. Diante desses casos, o legitimado passivo será o presidente da república.

d) Objeto

A ADO tem por objeto a chamada omissão inconstitucional.

Percebe-se que na hipótese de ajuizamento dessa ação não decorre de toda e qualquer omissão. Para haver ADO, essa omissão deverá ser:

- inconstitucional
- decorrente de uma norma de eficácia limitada
- inviabilizar direitos constitucionalmente assegurados

A ADO só pode ser impugnada por omissão normativa federal ou estadual. Isto significa dizer que não cabe ADO por omissão municipal.

Se, antes da apreciação da ADO, a norma constitucional, que serve como parâmetro, é revogada, a ADO perderá o objeto. Na verdade, o processo será extinto por falta de objeto, eis que deixa de existir a omissão constitucional.

Por exemplo, se a CF diz que o direito de greve é assegurado aos servidores públicos, exercendo-se nos termos da lei. Se alguém propôs uma ADO, mas durante o trâmite dessa ação, houve uma emenda à constituição para alterar o dispositivo constitucional, vedando o exercício do direito de greve aos servidores públicos. Com isso, a omissão que existia não mais existe, fazendo com que a ADO perca o objeto.

A ADO também se submete ao princípio da indisponibilidade. Isto é, uma vez proposta, não admite mais a sua desistência.

No caso da ADO, ao contrário da ADI, os outros legitimados, diversos do autor da ação, poderão se manifestar por escrito sobre o objeto da ação, pedindo a juntada de documentos, bem como apresentar memoriais. Esta é uma diferença da ADI. No entanto, intervenção de terceiros também não cabe.

e) Atuação do AGU

O STF entendia que o AGU não precisava atuar nas ADO's.



Todavia, a Lei 9.868/99 estabelece que o Relator poderá solicitar a manifestação do AGU, devendo se manifestar no prazo de 15 dias, sendo uma decisão do relator. Ou seja, poderá também não se manifestar, caso assim deseje o relator.

f) Atuação do PGR

A atuação do PGR é obrigatória, no prazo de 15 dias, eis que é o fiscal da CF.

Nas ações em que ele tenha proposto a ADO, a Lei 9.868/99 suprimiu do PGR o direito de manifestação nas ADO que ele tenha proposto. Na ADI genérica, o PGR se manifestará, mesmo que ele tenha proposto a ação.

g) Concessão de medida cautelar

Segundo o STF, é possível a concessão de medida cautelar em ADO, desde que se manifeste a maioria absoluta de seus membros.

A ADO consistirá na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo, se for de omissão parcial. Ex.: dois grupos estão na mesma situação de vulnerabilidade, de modo que a lei concede benefícios para o grupo A, mas não menciona o grupo B. Haverá inconstitucionalidade por omissão parcial, de modo que o deferimento da cautelar poderá determinar a suspensão dessa lei.

Sendo a omissão total, ou parcial, poderá a medida cautelar ser deferida, no sentido de suspender os processos judiciais e procedimentos administrativos em que se esteja questionando a matéria.

Essa previsão legal torna superado o entendimento do STF, o qual dizia não ser cabível medida cautelar em ADO. Isso porque a lei autoriza a medida cautelar da ADO.

h) Efeitos da decisão de mérito

Sabe-se que a ADO é uma decisão de controle abstrato:

- efeitos erga omnes
- efeitos vinculantes

Sendo julgada procedente a ADO, haverá a comunicação ao poder competente, a fim de que aquele poder adote as providências necessárias.

Se esta omissão é imputável ao órgão administrativo, o STF vai determinar que as providências cabíveis sejam adotadas no prazo de 30 dias, ou em prazo razoável a ser estipulado pelo órgão judicial.

Veja, essa determinação do STF se refere ao órgão administrativo, e não ao Poder Executivo. Isso porque o Supremo não poderia fixar um prazo para que um poder suprisse a sua omissão inconstitucional, eis que violaria o princípio da separação de poderes.

Essa é a razão pela qual o STF também não impõe ao Poder Legislativo essa medida de legislação. O que ele faz é uma comunicação.

Todavia, recentemente, o STF julgou procedente a ADO e declarou haver mora, por parte do Congresso Nacional, em editar determinada lei complementar tributária. Diante disso, foi fixado um prazo de 12 meses para que o Legislativo faça a lei. Na decisão, o STF consignou que, se for ultrapassado o prazo de 12 meses sem que a lei seja editada, o Tribunal de Contas da União (TCU) deverá:

- Fixar o valor total a ser transferido anualmente aos Estados-Membros e ao Distrito Federal, considerando os critérios dispostos no art. 91 do ADCT, a saber, as exportações para o exterior de produtos primários e semielaborados, a relação entre as exportações e as importações, os créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente e a efetiva manutenção e aproveitamento do crédito do imposto a que se refere o art. 155, § 2º, X, “a”, do texto constitucional;



- Calcular o valor das quotas a que cada um fará jus, levando em conta os entendimentos entre os Estados-Membros e o Distrito Federal realizados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz)

3.18.16. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE (ADC)

A ADC visa declarar a constitucionalidade de um ato normativo federal. Veja, não cabe ADC de um ato normativo estadual.

A ADC foi introduzida pela EC 03/93.

Essa ação visa a declaração de que o ato normativo é compatível com a CF.

O STF diz que, em caso de procedência da ADC, uma presunção relativa de constitucionalidade, torna-se presunção absoluta (*jure et jure*).

A ADC possui a mesma natureza da ADI, sendo ambas do controle concentrado, ou seja, ambas são decorrentes de processo objetivo.

a) Legitimidade ativa

Os legitimados da ADC são os mesmos da ADI, sendo de competência exclusiva é do STF.

Há uma diferenciação para a ADI, pois é possível verificar uma ADI em tribunal de justiça para aferir a inconstitucionalidade de um ato normativo estadual ou municipal em face da CE.

Todavia, se o questionamento for da Constituição Federal, o único órgão competente para apreciar a ADC é o STF. É por esse motivo que se percebe as semelhanças da ADI e da ADC.

O restante do procedimento da ADC é o mesmo da ADI,

b) Principais aspectos comuns

Os principais aspectos comuns entre a ADC e a ADI são:

- a causa de pedir é aberta: o STF pode declarar a (in)constitucionalidade por outro parâmetro, diverso daquele que alegado pelo autor da ação. O pedido não é aberto, eis que vigora o princípio da adstrição.
- incabível a intervenção de terceiros, salvo *amicus curiae*
- efeitos da decisão de mérito são erga omnes, vinculante, ex tunc, bem como dotadas de efeito repristinatório.
- é possível que haja a modulação dos efeitos temporais
- as decisões são irrecorríveis, mas cabe embargos de declaração
- não cabe ação rescisória

c) Objeto da ADC

O objeto da ADC é lei ou ato normativo federal.

Não cabe ADC em relação a ato normativo estadual.

d) Relevante controvérsia judicial

A relevante controvérsia judicial é um requisito para o ajuizamento da ADC.

Esta relevância deve colocar em risco a presunção de constitucionalidade que aquela lei tem. Para tanto, o legitimado da ADC ingressa com a ação para conferir a constitucionalidade absoluta (*jure et jure*).

O autor da ADC deve provar a relevante controvérsia judicial no momento do ajuizamento da ação, por meio da juntada de decisões judiciais nesse sentido.

Sempre que for proposta uma ADC, o STF emite, portanto, um juízo de admissibilidade acerca da relevante controvérsia judicial. Aí então, conhecerá da ADC.

Para ADI, não necessita de comprovação de relevante controvérsia judicial.



Proposta a ADC, não haverá pedido de informações, ao contrário da ADI. Isso porque se pretende reconhecer a constitucionalidade, visto que a norma é presumidamente constitucional.

e) Medida cautelar em ADC

No caso de ADC, também se admite a concessão de medida cautelar.

Essa medida cautelar consiste na suspensão dos processos que tratem da questão, até que haja o julgamento definitivo pelo STF.

Concedida a medida cautelar, o STF deve promover o julgamento da ação no prazo de 180 dias, sob pena da eficácia da medida cautelar concedida.

Na prática, o STF não considera esse prazo, pois tem reconhecido a eficácia vinculante da medida cautelar em sede de ADC mesmo depois de esgotado o prazo de 180 dias, entendendo inclusive reclamação para garantir a efetividade de suas decisões.

Essa regra de 180 dias de julgamento existe para ADC, mas não existe para ADI.

f) Não atuação do AGU

No caso da não atuação do AGU, o STF afasta a obrigatoriedade de citação do AGU nos processos de ADC, visto que não há necessidade de defender a lei que já estaria sendo defendida.

3.18.19. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF)

O art. 102, §1º estabelece que a arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.

Portanto, a norma constitucional que trata da ADPF é uma norma de eficácia limitada, visto que exige sua regulamentação. A lei que regulamenta é a Lei 9.882/99.

A competência originária e exclusiva para julgamento e ADPF é do STF.

Questões que antes não eram passíveis de apreciação em sede de controle abstrato, passaram a ser possíveis com a ADPF, tais como atos normativos municipais e direito pré-constitucional em face da CF vigente, neste último o juízo é de recepção ou não recepção do ato normativo.

A ADPF não se restringe a atos normativos, eis que qualquer ato do poder público, desde que resulte à lesão ou à ameaça de lesão a preceito fundamental.

Segundo a Lei, A ADPF será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.

Veja, não precisa ser ato normativo.

O inciso I ainda preceitua que caberá também ADPF quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição.

Perceba que a lei amplia o objeto de questionamento de atos, sejam eles normativos ou não, perante o STF.

a) Arguição autônoma

Atente-se que a arguição de descumprimento fundamental poderá ser autônoma ou incidental.

Essa arguição autônoma terá natureza de ação.

b) Arguição incidental

No caso de arguição incidental de descumprimento fundamental, pressupõe que haja um ação em andamento (ação original), e em função desta ação, um dos legitimados para



propositura da ADPF (que são os mesmos da ADI), suscitará a arguição, levando a apreciação daquela matéria constitucional ao Supremo Tribunal Federal.

Ressalte-se que, neste caso, o controle continua sendo abstrato, não havendo caráter subjetivo da ADPF, ainda que a arguição seja incidental.

O STF e a doutrina majoritária só admitem a ADPF como processo objetivo.

A única diferença entre a ADPF autônoma e incidental é de que nesta última a controvérsia constitucional se origina de um processo concreto, mas a partir desse processo de natureza subjetiva, é levantado um incidente abstrato de controle de constitucionalidade, ou de um juízo de recepção ou revogação, se for uma norma anterior à CF.

c) Objeto da ADPF e conteúdo do pedido

O objeto da ADPF é poderá ser qualquer ato do poder público, seja este ato comissivo ou omissivo. A lei não distingue. A lei exige que este ato implique lesão ou ameaça de lesão a preceito fundamental.

Com isso, é possível perceber que haja a possibilidade de uma ADPF preventiva.

Não se esqueça! É necessário que haja uma controvérsia judicial relevante, e que a aplicação ou a não aplicação desses atos normativos impliquem em lesão ou ameaça de lesão a preceito fundamental.

Veja, existem duas situações que ensejam o cabimento da ADPF:

- ato do poder público que gera lesão a preceito fundamental
- ato normativo que gera lesão ou ameaça de lesão, desde que seja relevante a controvérsia constitucional

O STF já decidiu que ato do poder público não poderá ser ato político, visto que esses não são passíveis de impugnação judicial. Não poderia dizer que o veto político seria um ato de poder público violador de preceito fundamental.

Da mesma forma, o STF entendeu que enunciados de súmula do STF não podem ser objeto de ADPF, pois não podem ser considerados atos lesivos a preceito fundamental.

O STF também entende que não é possível que se promova uma ADPF cujo objeto seja exclusivamente uma decisão transitada em julgado, eis que o ato jurídico perfeito, coisa julgada e o direito adquiridos não poderiam ser violados.

A ADPF pode ser utilizada para fins de controle de uma omissão inconstitucional, visto que o ato do poder público que gera a violação a preceito fundamental poderá ser um ato comissivo ou um ato omissivo. E, portanto, plenamente cabível.

O pedido da ADPF poderá ser para a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do ato do poder público.

d) Preceito fundamental

Não se sabe ao certo o que é preceito fundamental. A Lei 9.882/99 não trouxe o que seria preceitos fundamentais.

O STF já decidiu que compete a ele identificar quais normas são preceitos fundamentais. Essa análise é casuística.

e) Subsidiariedade da ADPF

Cabendo outra ação para resolver de maneira eficaz aquilo que a ADPF resolveria, não caberia a sua proposição.

O art. 4º, §1º, estabelece que não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.

Mas esta norma não se refere apenas ao controle abstrato. Isto é, se houver outro meio eficaz no controle concreto (difuso) também não será cabível ADPF.

Cabe ressaltar que o próprio STF já reconheceu ADPF como ADI, com base no princípio da fungibilidade.



f) Competência da ADPF

É de competência originária e exclusiva do STF.

Os mesmos legitimados da ADI serão os da ADPF.

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo defendem que na ADPF incide o princípio da indisponibilidade, não podendo o legitimado desistir da ação proposta. No entanto, a Lei 9.882/99 não traz essa previsão, se valendo da analogia para sua alegação.

g) Petição inicial e procedimento da ADPF

A petição inicial deverá conter o preceito fundamental que se considera violado ou ameaçado de violação. A prova da violação também deverá ser apresentada com a cópia do ato questionado, além de vir o pedido.

Pode ser que o pedido da ADPF venha com pedido de liminar ou cautelar.

Apreciado esse pedido liminar, o Relator solicitará informações à autoridade responsável pelo ato, no prazo de 10 dias. Após, o Relator lançará um relatório, mandando cópias para todos os ministros e pedirá data para julgamento.

Se o PGR não foi autor da ADPF, então o ele terá vista do processo por 5 dias.

A Lei 9.882/99 não fala sobre a participação do AGU. Ela não obriga que o AGU participe. Todavia, o STF tem exigido a participação do AGU, especialmente quando se questiona a constitucionalidade do ato que fira preceito fundamental.

h) Medida liminar

É plenamente cabível medida liminar em processo de ADPF.

O STF, por decisão da maioria absoluta, poderá deferir medida liminar.

Sendo o caso de urgência, o Relator poderá deferir a liminar, ainda que seja em caso de recesso, desde que haja referendo posterior do Plenário.

A medida liminar poderá consistir na suspensão dos processos que apresentam relação com a matéria objeto da arguição.

i) Informações adicionais da ADPF

A decisão, em ADPF deverá ser tomada por maioria absoluta, mas a decisão deverá se dar por decisão de 2/3 dos ministros, ou seja, 8 ministros do STF.

A lei estabelece que a decisão tenha eficácia contra todos e efeito vinculante.

A lei não faz o detalhamento em relação à ADI.

A decisão de mérito da ADPF produz efeitos imediatos, independentemente da publicação de acórdão. Isto é, no momento em que é prolatada a decisão de mérito, imediatamente passará a produzir efeitos.

O STF, por meio de 2/3 dos seus membros, poderá modular os efeitos da decisão.

Caso alguém não observa esta decisão, é cabível reclamação.

Não se admite ação rescisória, pois sua causa de pedir é aberta.

3.18.20. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INTERVENTIVA

O art. 18 da CF dispõe que todos os entes federados são autônomos.

A autonomia em uma federação é capacidade de auto-organização, auto-governo, auto-administração, auto-legislação, sendo autonomia financeira, tributária, competência legislativa, repartição constitucional de competência, etc.

Todavia, a própria CF autoriza que, excepcionalmente, esta autonomia seja afastada, diante de um interesse de preservação da federação. Ou seja, não se admite o direito de secessão.

Para que o interesse maior, que é a preservação da unidade federativa, a CF permite que em determinadas hipóteses excepcioníssimas haja uma intervenção de uma entidade maior em uma entidade menor.



Para tanto, é necessário que haja afronta a alguns princípios constitucionais, autorizadores da intervenção, a fim de que seja restabelecido a unidade federativa.

Em verdade, a unidade federativa que está sofrendo intervenção, tendo em vista que desrespeitou a constituição. A intervenção federal visa disciplinar a observância dos ditames constitucionais.

As hipóteses de intervenção poderão ser classificadas em:

- intervenção espontânea: é uma intervenção de ofício, possibilitando ao chefe do poder executivo decretar a intervenção.
- intervenção provocada: é uma intervenção que depende da iniciativa de algum órgão. O chefe do poder executivo não poderá intervir de ofício, dependendo da manifestação de um órgão que recebeu da CF esta incumbência.

Veja, em todas as hipóteses em que a intervenção dependa de um provimento judicial, a CF chamou de representação.

Por conta disso, é denominada de representação interventiva.

Como se dá por conta de um ato de um estado-membro que violou a Constituição, e o que se busca aqui é o restabelecimento da força normativa da constituição, a doutrina chama, neste caso, de ação direta de inconstitucionalidade interventiva.

Quando o que se tem é a recusa de execução de uma lei, a doutrina denomina de ação de executividade de lei.

A ação direta de inconstitucionalidade interventiva é ação de controle concentrado, pois quem irá julgar, sendo no âmbito federal, é o STF. Sendo de âmbito estadual, será o Tribunal de Justiça.

Todavia, não poderá ser caracterizado como controle abstrato, pois não trata de uma situação em tese. O que se busca, na maioria das vezes, é a impugnação de um ato concreto, o qual viola a CF. É um ato que o estado ou município praticou

A ação direta de inconstitucionalidade interventiva é uma ação direta, que tem por fim a obtenção de um provimento judicial que declara a inconstitucionalidade daquele ato praticado pelo Estado ou pelo Município.

- intervenção federal: o ato do Estado gera uma intervenção federal.
- intervenção estadual: sendo decorrente de um ato municipal, haverá, como regra, intervenção estadual, salvo se houver um território federal dividido em municípios, hipótese em que a intervenção será federal em município.

Dado esse provimento judicial, o chefe do executivo, a vista do provimento, decreta a intervenção.

Veja, é o Chefe do Poder Executivo que decreta a intervenção, mas será de forma provocada.

Havendo recusa ao cumprimento de lei federal ou ofensa aos princípios constitucionais sensíveis, que estão no art. 34, VII, a intervenção vai depender de provimento do STF, a partir de uma representação do Procurador-Geral da República, sendo o único legitimado para tanto.

Se esta mesma regra se der no âmbito estadual, o titular para promover a respectiva ação de representação por intervenção estadual ficará condicionada ao provimento do Tribunal de Justiça, provocado por uma representação do Procurador-Geral de Justiça, também único legitimado para tanto.

São princípios constitucionais sensíveis:

- forma republicana, sistema representativo e regime democrático: o poder emana do povo!
- direitos da pessoa humana: é a preocupação com a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais do art. 5º.
- autonomia municipal: consagração do município como uma unidade da federação.



- prestação de contas da administração pública, direta e indireta: decorre do princípio republicano, devendo prestar contas.
- aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde: demonstra o mandamento constitucional para que se dê maior atenção à educação e à saúde.

Atente-se que o Poder Judiciário não decreta a intervenção, pois esta intervenção é ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo.

Julgado procedente a representação interventiva, o Poder Judiciário comunicará o Chefe do Poder Executivo. Com isso, o chefe do executivo decidirá sobre a decretação da intervenção, visto que poderá não ser necessária a decretação, pois poderá a simples sustação do ato impugnado resolver o problema.

A intervenção federal se consuma pela edição de um decreto, pelo Presidente da República, ou pelo Governador.

Na verdade, a representação só será cabível a intervenção federal quando se mostrar ineficaz a simples suspensão da execução do ato impugnado.

Se houver a decretação da intervenção, como ela vem de um provimento judicial, não será objeto de controle político do Congresso Nacional, visto que teria advindo de uma provocação do Poder Judiciário. Então, simplesmente o chefe do executivo não ficaria sujeito a este controle político.

A duração da intervenção estará prevista no decreto expedido pelo chefe do poder executivo.

3.18.21. CONTROLE ABSTRATO NOS ESTADOS

O controle abstrato nos Estados é possível, conforme art. 125, §2º, o qual estabelece que cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

Então, não poderá haver um único legitimado a oferecer ADI.

Embora o texto constitucional ter admitido a hipótese de ADI pelos Estados, cabe ressaltar que o STF entende ser possível a criação de outros instrumentos do controle concentrado, tais como ADO, ADC e ADPF.

A CF não prevê a possibilidade de controle de constitucionalidade de lei municipal em face de lei orgânica do município. Isso porque a contrariedade entre lei municipal e lei orgânica é simplesmente um controle de legalidade, e não de constitucionalidade.

A decisão proferida em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade estadual não se submete à cláusula da reserva de plenário.

a) Legitimação da ADI Estadual

A CF não diz quem serão os legitimados do controle abstrato de constitucionalidade para os Estados. O que a CF diz é que não poderá ser um único órgão legitimado.

Portanto, poderá que outros órgãos sejam considerados legitimados pela CE, não sendo necessário escolher apenas aqueles previstos no art. 103 da CF.

Atente-se que não há decisão no STF sobre a Constituição Estadual que disponha sobre menos legitimados do que o art. 103.

Todavia, doutrinariamente, a Constituição estabelece que a CE não poderá atribuir a legitimação a um único órgão.

De qualquer modo, alguns dos legitimados do art. 103 devem estar presentes em todas as constituições estaduais, sob pena de inconstitucionalidade chapada. Não é possível excluir o procurador-geral de justiça do rol de legitimados para a propositura de uma ADI estadual, pois uma de suas funções é defesa da ordem jurídica.



b) Defesa da norma impugnada no âmbito estadual

Em regra, quem defende as normas estaduais é o Procurador-Geral do Estado, funcionando como defensor legis.

O STF entende que é constitucional o dispositivo constitucional que assegure ao Procurador da Assembleia Legislativa a função defensor legis do Estado, ou mesmo quando estabelecer que tal função seja feita pelo PGE ou pelo Procurador da assembleia. Não há obrigatoriedade de simetria em relação à CF.

c) Parâmetro de controle

O parâmetro de controle para a ADI estadual é a própria Constituição Estadual. Os TJ's vão apreciar leis ou atos normativos estaduais e municipais, questionados em face da Constituição Estadual.

Em outras palavras, o TJ não pode examinar se o ato impugnado ofende a Constituição Federal. O STF, em reiteradas oportunidades, já decidiu sobre o tema, estabelecendo que não cabe aos Tribunais de Justiça Estaduais exercer o controle de constitucionalidade de leis e demais atos normativos municipais em face da Constituição Federal.

Os Tribunais de Justiça, ao julgarem a representação de inconstitucionalidade proposta contra lei municipal, poderão declará-la inconstitucional utilizando como parâmetro dispositivos da Constituição Federal, desde que eles sejam normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Será visto mais abaixo.

d) Inconstitucionalidade do parâmetro de controle estadual**Mas, e se aquela norma inconstitucional da CE violar a Constituição Federal?**

Pode acontecer de o TJ, quando estiver avaliando uma ADI estadual, se deparar com a inconstitucionalidade do próprio parâmetro, ou seja, da própria norma da constituição estadual.

Nesse caso, segundo o ministro Gilmar Mendes, nada impede que o Tribunal de Justiça enfrente a questão inconstitucional, e reconheça a inconstitucionalidade desse parâmetro estadual em face da Constituição Federal. Neste caso, declarará incidentalmente a inconstitucionalidade daquela norma constitucional estadual.

Acontece que, se o parâmetro que existia não existe mais, não há mais a possibilidade jurídica do pedido, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito.

Veja, o TJ reconhece incidentalmente a inconstitucionalidade daquele artigo da Constituição Estadual, e em seguida extingue o processo diante da impossibilidade jurídica do pedido. Isso porque não se pode declarar a inconstitucionalidade de um ato normativo em face da Constituição Estadual que viola a Constituição Federal.

Se o artigo da CE que viola a CF é inconstitucional, significa que ele é nulo ou natimorto. Se ele é nulo, não terá validade, não podendo ser utilizado como parâmetro. A partir de então, não há mais o que se questionar, sendo impossível juridicamente, se questionar a constitucionalidade de um ato, se a CE revela-se inconstitucional.

Da decisão do Tribunal de Justiça que declara a inconstitucionalidade do artigo da Constituição Estadual caberá recurso extraordinário ao STF.

Com isso, o STF poderá confirmar, entendendo pela inconstitucionalidade do dispositivo da CE. Também poderá reformar a decisão do TJ, estabelecendo que o artigo da CE é constitucional.

Caso o STF entenda pela constitucionalidade do artigo da CE, o Tribunal de Justiça deverá prosseguir com o julgamento da representação de inconstitucionalidade estadual, visto que ele foi restabelecido, sendo, portanto, juridicamente possível o pedido.

e) Simultaneidade de ações diretas

Neste caso, analisa-se em diferentes esferas.



Se o ato é normativo federal, só se poderá questionar o ato perante à CF. Todavia, sendo o ato normativo estadual, poderá ele ser questionado em face da CE ou da CF. Veja, é possível que haja o duplo controle concentrado.

Poderá que uma mesma lei seja impugnada simultaneamente perante o STF e perante o TJ.

Primeiro, é necessário saber qual é o dispositivo estadual que está servindo de parâmetro para o ato impugnado. Isso porque a CE tem normas que têm natureza autônoma e normas de reprodução obrigatória, as quais reproduzem dispositivos da CF.

- Normas autônomas: o constituinte estadual deliberou por conta do poder constituinte derivado decorrente. Podem ser normas da CF que foram espontaneamente copiadas ou então inovadas no texto constitucional estadual.
- Normas de reprodução obrigatória: essas normas configuram uma simples repetição do texto constitucional, pois devem ser assim. Exemplo é a regra sobre sistema eleitoral, devendo observar aquilo que está previsto na CF.

i. Parâmetro é norma de reprodução obrigatória

Normas de reprodução obrigatória (normas centrais ou normas pré-ordenadas) são dispositivos da Constituição Federal de 1988 que, como o próprio nome indica, devem ser repetidos nas Constituições Estaduais. Se uma norma é de reprodução obrigatória, considera-se que ela está presente na Constituição Estadual mesmo que a Carta estadual seja silente.

Ex: a CF/88 prevê que os Municípios são autônomos (art. 18). Veja, mesmo se a Constituição Estadual não diga que os Municípios são autônomos, ainda assim considera-se que essa regra está presente na Carta Estadual. Outros exemplos são as regras da CF que tratam sobre organização político-administrativa, competências, separação dos poderes, servidores públicos, processo legislativo, entre outras.

Segundo Novelino, as normas de observância obrigatória são diferenciadas em três espécies:

- Princípios constitucionais sensíveis: representam a essência da organização constitucional da federação brasileira e estabelecem limites à autonomia organizatória dos Estados-membros (CF, art. 34, VII);
- Princípios constitucionais extensíveis: consagram normas organizatórias para a União que se estendem aos Estados, por previsão constitucional expressa (CF, arts. 28 e 75) ou implícita (CF, art. 58, § 3.º; arts. 59 e ss.)
- Princípios constitucionais estabelecidos: restringem a capacidade organizatória dos Estados federados por meio de limitações expressas (CF, art. 37) ou implícitas (CF, art. 21).

Portanto, se um dispositivo da Constituição Estadual está sendo impugnado em ADI perante o TJ, por ofensa a uma norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal, o TJ dará início ao processo, podendo inclusive julgá-lo.

Ex.: Município do Paraná aprovou lei tratando sobre direito do trabalho. Foi proposta uma ADI estadual no TJ contra esta lei. O TJ poderá julgar a lei inconstitucional alegando que ela viola o art. 22, I, da CF/88, mesmo que a Constituição do Estado não tenha regra semelhante. Isso porque essa regra de competência legislativa é considerada como norma de reprodução obrigatória. Nesse sentido: STF. 1ª Turma. Rcl 17954 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21/10/2016.

Outro exemplo é caso do Município do Rio Grande do Sul que editou lei criando gratificação para o Prefeito fora do regime de subsídio, o que violaria o art. 39, § 4º, da CF/88. O TJ/RS poderá julgar a lei municipal inconstitucional utilizando como parâmetro este dispositivo da Constituição Federal, porque a regra sobre o subsídio para membros de Poder e detentores de mandato eletivo é considerada norma de reprodução obrigatória. Nesse sentido: STF. Plenário. Rel. originário Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 01/02/2017 (repercussão geral).



Dessa forma, o STF entendeu que Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados (Inf. 852).

Vale destacar que, se a representação de inconstitucionalidade sustentar que a norma apontada como violada (parâmetro) é uma norma de reprodução obrigatória, então, neste caso, caberá recurso extraordinário para o STF contra a decisão do TJ.

Desse modo, Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Contra esta decisão, cabe recurso extraordinário.

Ressalte-se que a decisão do STF neste recurso extraordinário terá eficácia *erga omnes* porque foi proferida em um processo objetivo de controle de constitucionalidade.

Por outro lado, se durante o processo for ajuizada uma ADI em face da Constituição Federal, como o parâmetro é o mesmo, caso o STF reconheça a admissão da ação, ficará suspensa a ação no âmbito estadual, perante o Tribunal de Justiça, havendo duplicidade de ações diretas de inconstitucionalidade.

Nesta hipótese, a decisão do STF necessariamente atingirá a decisão do Tribunal de Justiça.

ii. Parâmetro é norma autônoma

É diferente se a ação direta de inconstitucionalidade tenha como parâmetro uma norma autônoma da CE.

Se durante o desenrolar desta ação perante o TJ for proposta uma ADI em face daquela lei estadual, tendo por parâmetro dispositivo constitucional diverso do parâmetro estabelecido para ADI estadual, os dois Tribunais irão avaliar a constitucionalidade da lei, considerando parâmetro distintos.

Neste caso, se o STF reconhecer que é inconstitucional, não haverá outro caminho para a ADI estadual, visto que, sendo nula a lei, estará retirada do ordenamento jurídico.

Por outro lado, caso o STF considere a lei constitucional, ainda assim o Tribunal de Justiça poderá reconhecer a lei como inconstitucional, mas tendo por base artigo da CE autônomo, que não seja de reprodução obrigatória da CF.

f) Recurso extraordinário contra decisão de ADI estadual

Existem normas da Constituição Estadual que são de reprodução obrigatória.

Segundo o STF, nesta hipótese, em que a ação foi ajuizada tendo como parâmetro uma norma da Constituição Estadual de reprodução obrigatória, será possível que se interponha recurso extraordinário.

Note que o recurso extraordinário, típico de controle concreto, estaria sendo utilizado como controle abstrato. Ou seja, a decisão proferida neste recurso extraordinário, que é do âmbito de controle abstrato, deverá ser dotado de efeito *erga omnes*, devendo se estender a todo o território nacional.

Veja, há uma espécie de controle abstrato no modelo difuso.

O STF ainda vai estabelecer que, neste caso, é desnecessário a maioria absoluta do Tribunal. Este recurso extraordinário poderá ser decidido monocraticamente pelo Relator do processo, desde que este tema já tenha sido definido pela jurisprudência do STF.

Percebe-se que, no âmbito do controle abstrato, é admissível excepcionalmente, quando o parâmetro é uma norma de reprodução obrigatória, o recurso extraordinário.

g) Distrito Federal

O Distrito Federal tem uma peculiaridade, eis que quem disporá sobre a representação de inconstitucionalidade no âmbito distrital será a União, devendo se dar em face da Lei Orgânica do DF.



Só a União tem a competência para legislar sobre a organização do Poder Judiciário no DF.

Perceba que no DF, o controle abstrato não é instituído pela câmara legislativa e nem está na lei orgânica do DF, estando numa lei editada pelo Congresso Nacional, por meio da Lei 11.697/08.

h) Representação interventiva dos Estados

A CF permite que haja a representação interventiva no âmbito estadual, permitindo que os estados intervenham nos municípios.

No art. 35, IV, a CF estabelece que os Estados poderão intervir nos municípios, caso o Tribunal de Justiça dê provimento a representação interventiva nos casos de:

- inobservância pelos municípios de princípios indicados na Constituição Estadual, ou;
- para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

Essas são as hipóteses de representação interventiva dos estados nos municípios.

O legitimado exclusivo é o Procurador-Geral de Justiça.

O STF entende que da decisão do TJ, na representação interventiva estadual, não cabe recurso ao STF. Este inclusive é o entendimento pela súmula 637 do STF.

4. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

Valério Mazzuoli entende que, quando o parâmetro é um tratado ou convenção internacional, fala-se em controle de convencionalidade. Marcelo Novelino adota entendimento diverso, preferindo falar de controle de convencionalidade somente em se tratando de convenção com *status* supralegal.

Não existe nenhum mecanismo previsto de controle de convencionalidade. Ele é feito dentro das ações normais, de forma incidental.

Conceitua-se controle de convencionalidade como sendo o juízo de compatibilidade entre duas normas jurídicas, sendo a norma parâmetro não a Constituição, e sim os Tratados Internacionais que versem sobre Direitos Humanos. De tal controle podem advir dois efeitos, o efeito de afastamento e o efeito paralisante.

5. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Não há, a priori, vedação à utilização de ação civil pública para a realização do controle de constitucionalidade de uma lei. Todavia, para que uma ACP possa ser admitida como instrumento de controle de constitucionalidade, a inconstitucionalidade deve ser apenas fundamento do pedido, questão incidental ou a causa de pedir, e não o pedido em si, que tem de ser de efeitos concretos.

Caso contrário, a ACP seria utilizada como uma espécie de ADI, o que significaria usurpação da competência do STF, hipótese em que seria cabível Reclamação junto ao próprio STF, para que ele pudesse restabelecer sua competência. A esse respeito, ver os seguintes julgados: REsp 557.646, REsp 294.022 e RE 227.159.

Num deles, o MP ajuizou ACP requerendo o fechamento dos Bingos, com causa de pedir baseada na inconstitucionalidade do decreto que autorizava o funcionamento. O Tribunal entendeu que não houve usurpação da competência do STF, em virtude da concretude dos efeitos pedidos.

6. ESPÉCIES DE INCONSTITUCIONALIDADES



6.1. INCONSTITUCIONALIDADE POR AÇÃO E POR OMISSÃO

- Inconstitucionalidade por ação: é uma inconstitucionalidade decorrente de uma “fazer”, de uma ação. O desrespeito decorre de uma conduta comissiva, como é o caso de elaborar uma lei em desacordo com a CF.
- Inconstitucionalidade por omissão: decorre de uma conduta omissiva, de um “não fazer”, frente a uma obrigação de fazer do Estado. A doutrina estabelece que esta inconstitucionalidade por omissão pode ser:

(I) Omissão total: o poder público não elaborou a norma determinada pela CF.

(II) Omissão parcial: o poder público elaborou a norma insatisfatoriamente.

6.2. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E FORMAL

- inconstitucionalidade material: é uma lei que contraria a norma constitucional em relação ao seu conteúdo. Ex.: uma lei que estabelece uma pena de morte viola o conteúdo da CF.
- inconstitucionalidade formal: é um desrespeito ao processo de elaboração da norma conforme determina a CF, ainda que o conteúdo seja perfeito. Ex.: a CF determina que um tema seja elaborado por lei complementar, mas o legislador o elabora por meio de lei ordinária.

A inconstitucionalidade formal pode se subdividir em:

- (I) inconstitucionalidade formal orgânica: o órgão que deu início ou produziu a lei não era competente, motivo pelo qual houve uma inconstitucionalidade orgânica. Ex.: vício de iniciativa.

6.3. INCONSTITUCIONALIDADE TOTAL E PARCIAL

- inconstitucionalidade total: é aquela em que o ato normativo é totalmente nulo.
- inconstitucionalidade parcial: é aquela em que o ato normativo possui parte constitucional e parte inconstitucional. A inconstitucionalidade pode recair sobre um artigo, parágrafo, inciso, alínea e até palavra. Não se confunde com o veto jurídico, que não pode vetar palavras.

6.4. DECLARAÇÃO PARCIAL DE NULIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO E INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO

- Técnica de declaração parcial de nulidade sem redução de texto: é uma técnica do controle de constitucionalidade em que o texto continuará o mesmo de antes do controle de constitucionalidade, porém subtrai do intérprete a possibilidade de aplicação daquela norma a determinado grupo ou determinado período. O texto é mantido, pois a sua supressão implica prejuízo maior do que a sua manutenção. É o caso em que existe uma regra legal, que é inconstitucional, mas que não poderá ser



excluída do texto, sob pena de alcançar um resultado indesejado. Para tanto, o texto continuará, mas haverá uma nulidade parcial, sem redução de texto.

- Técnica de interpretação conforme a Constituição: o texto normativo que está sendo interpretado permite mais de um significado, sendo polissêmico. Com isso, verifica-se que uma ou outra interpretação não se coaduna com a CF, ou que das diversas interpretações possíveis só uma é conforme a CF. A partir daí o Poder Judiciário atua como um legislador negativo, eliminando uma ou algumas possibilidades de interpretação que não se mostram condizentes com a Constituição. Ou seja, a interpretação conforme também não retira a norma do ordenamento jurídico, nem total nem parcialmente, mas preconiza que há apenas uma interpretação possível, constitucional, excluindo-se as demais. Já na declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, ocorre o contrário, apenas um sentido é inconstitucional, admite-se os demais.

Tais técnicas foram positivadas no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei 9.868/99.

6.5. INCONSTITUCIONALIDADE DIRETA E INDIRETA

- Inconstitucionalidade direta: é aquela em que a desconformidade é de um ato normativo primário em face da Constituição. Admite o controle de constitucionalidade perante o STF.
- Inconstitucionalidade indireta: é aquela que decorre de uma norma regulamentar, ou um ato normativo secundário, em face da Constituição. Veja, na inconstitucionalidade indireta, o ato normativo viola a norma primária, e não a CF diretamente. Não é possível questionar a contrariedade à Constituição, ainda que indiretamente infrinja a CF. Para tanto, é necessário que esta afronta à constituição seja direta. O STF entende que isto se trata de controle de legalidade.

A inconstitucionalidade indireta não pode ser confundida com a inconstitucionalidade derivada. Isso porque esta é uma inconstitucionalidade consequente, pois é a hipótese em que uma lei viola a Constituição, e a partir daí, o ato normativo secundário, que emanou do primeiro, é arrastado pela inconstitucionalidade. Na verdade, a inconstitucionalidade da norma primária leva ao inevitável reconhecimento da invalidade da norma secundária, que foi expedida em razão dela.

6.6. INCONSTITUCIONALIDADE CIRCUNSTANCIAL

Há situações em que a aplicação de uma lei, ainda que abstratamente seja constitucional, produza no caso concreto um resultado inconstitucional.

Ou seja, trata-se de uma inconstitucionalidade circunstancial, pois, no caso, aplicar uma lei, que é abstratamente constitucional, é violar a constituição.

É a lei ferindo o seu próprio escopo a partir da sua aplicação nua e crua. O caso concreto pode exigir que a lei seja superada.

Ex.: vedação do ECA a adoção de netos por avós. O STJ reconheceu a possibilidade quando os avós haviam adotado uma filha, que aos 8 anos e já estaria grávida, em decorrência do abuso, hipótese em que a neta, filha da adotanda, também pôde ser adotada pelos avós.

Veja, a norma trazida pelo ECA é constitucional abstratamente, porém no caso concreto feriria a própria Constituição, em razão da dignidade da pessoa humana, dentre outros, motivo pelo qual haveria uma inconstitucionalidade circunstancial.



6.7. INCONSTITUCIONALIDADE ORIGINÁRIA E SUPERVENIENTE

- inconstitucionalidade originária: é aquela em que o ato normativo já nasceu morto. No momento de sua produção, há violação à constituição vigente.
- inconstitucionalidade superveniente: neste caso, a lei nasce constitucional, mas depois, com o advento de uma nova constituição, a lei passa a ser tida como inconstitucional.

O STF não admite a inconstitucionalidade superveniente, sendo o caso de revogação (não recepção) da lei anterior.

6.8. INCONSTITUCIONALIDADE CHAPADA, ENLOUQUECIDA OU DESVAIRADA

Inconstitucionalidade chapada é uma expressão do ministro Sepúlveda Pertence, enquanto a enlouquecida ou desvairada é do ministro Aires Brito.

Esta inconstitucionalidade é flagrante, manifesta ou indubitável. Por exemplo, é o caso da previsão a pena de morte para o crime de furto.

7. HISTÓRICO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL

- ➔ Constituição de 1824: não contemplou qualquer sistema de controle de constitucionalidade, vindo de inspiração da constituição francesa, pois essa era muito rígida no tocante à separação dos poderes. A Constituição outorgava ao legislativo a tarefa de zelar pela guarda da constituição. Não há que se falar em controle de constitucionalidade.
- ➔ Constituição de 1891: foi marcada e influenciada pelos EUA (Rui Barbosa). Os EUA elegeram o controle difuso, de modo que todos os órgãos do poder judiciário poderiam fazer esse controle de constitucionalidade. Só poderia ser feito o controle por meio da via incidental. Não havia a arguição de inconstitucionalidade de uma lei em tese, de forma abstrata.
- ➔ Constituição de 1934: a “Era Vargas” foi de 1934 a 1945. Com a Carta de 1934, a constituição consagrou a cláusula de reserva de plenário. Para um tribunal reconhecer uma lei como inconstitucional, seria preciso que houvesse a manifestação da maioria absoluta do Tribunal, ou do seu Órgão Especial, quando for superior a 25 membros. Foi com essa constituição que se passou a atribuir efeitos gerais ao reconhecimento da inconstitucionalidade de uma norma. Para isso, seria necessário que o senado suspendesse a eficácia da lei com eficácia erga omnes, após ser declarada inconstitucional pelo órgão do poder judiciário. O controle só era difuso.
- ➔ Constituição de 1937: Vargas deixou de ser “bonzinho”. Houve o golpe do Estado Novo. Houve um retrocesso. Esta constituição era “A Polaca”, por ser de influência polonesa. No caso de uma lei tida por inconstitucional pelo poder judiciário, caberia ao presidente da república decidir se essa lei deveria ser mantida constitucional ou não, hipótese em que deveria submetê-la ao exame do parlamento. Portanto, essa constituição cria a possibilidade de o presidente da república passar por cima da palavra do poder judiciário, a fim de restabelecer uma lei tida por inconstitucional. Aqui, deixou de estar prevista a competência do Senado para suspender a execução de lei tida por inconstitucional pelo poder judiciário.



- Constituição de 1946: houve o intervalo democrática. O controle judicial volta a ser exercido de forma difusa. Restaura-se ao senado federal a competência para declarar ineficaz a lei tida por inconstitucional por julgamento do STF. Em 1965, houve uma emenda à constituição, estabelecendo um controle abstrato de normas, ainda sob o domínio da constituição de 1946. Esta emenda atribuía ao STF o julgamento da ADI e a legitimidade conferida exclusivamente ao procurador geral da república.
- Constituição de 1967/69: mantiveram o controle difuso e concentrado.
- Constituição de 1988: foi mantido o controle difuso, mas também houve maior incidência do concentrado. Há doutrinadores que falam estar havendo inclusive uma abstrativização do controle difuso. É o que o ministro Gilmar Mendes defende. Para ele, no momento em que o STF declara a inconstitucionalidade de uma lei no controle difuso, não seria necessário que o senado federal declarasse a suspensão da eficácia do ato, visto que a ele só teria a função de tornar pública tal decisão. Isso geraria uma mutação constitucional do art. 52, X, CF. Esta tese não é vencedora no STF, recebendo fortes críticas da doutrina majoritária, situação denominada de manipulação inconstitucional. O ministro Gilmar Mendes inclusive admite que o Senado possa retirar a eficácia de lei, decreto ou, ainda, outro ato normativo de diferente denominação (ex.: Resolução da Câmara). Essa atuação do Senado abrange atos federais, estaduais, distritais e municipais. Na CF/88, houve a ampliação dos legitimados do controle concentrado perante o STF. Não é mais o PGR que tem o monopólio da ADI. Houve ainda a ampliação das ações, tendo inclusive havido a inserção da ação de descumprimento de preceito fundamental. Há ainda a inovação de se declarar a inconstitucionalidade de uma norma por omissão, seja por meio do mandado de injunção, que se dá na via concreta, ou por meio da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que se dá na via abstrata. Em 1993, com a EC 3, foi criada a ADC (ADECON). Posteriormente, a EC 45 inova, ampliando do rol de legitimados para propor ADPF, estabelecendo o mesmo que para a ADI. A CF/88 criou ainda a denominada súmula vinculante.

8. INFORMATIVO DE JUSPRUDÊNCIA

8.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O afastamento de norma legal por órgão fracionário, de modo a revelar o esvaziamento da eficácia do preceito, implica contrariedade à cláusula de reserva de plenário e ao Enunciado 10 da Súmula Vinculante.

STF. 1ª Turma. RE 635088 AgR-segundo/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 4/2/2020.

Não viola a Súmula Vinculante 10, nem a regra do art. 97 da CF/88, a decisão do órgão fracionário do Tribunal que deixa de aplicar a norma infraconstitucional por entender não haver subsunção aos fatos ou, ainda, que a incidência normativa seja resolvida mediante a sua mesma interpretação, sem potencial ofensa direta à Constituição. STF. 1ª Turma. Rcl 24284/SP, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/11/2016



O Plenário, preliminarmente, afastou a legitimidade de terceiro interessado e, por maioria, não referendou medida cautelar implementada pelo ministro Marco Aurélio (relator) no sentido de conclamar os juízos de execução a analisarem, ante o quadro de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19) e tendo em conta orientação expedida pelo Ministério da Saúde (no sentido de segregação por 14 dias), a possibilidade de aplicação das seguintes medidas processuais: (a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do art. 1º da Lei 10.741/2003; (b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; (c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei 13.257/2016; (d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; (e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; (f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; (g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; e (h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto. O Tribunal afirmou que o amicus curie, por não ter legitimidade para propositura de ação direta, também não tem para pleitear medida cautelar. Entendeu que houve, de ofício, ampliação do pedido da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). Explicou que, no controle abstrato de constitucionalidade, a causa de pedir é aberta, mas o pedido é específico. Salientou que o Supremo Tribunal Federal (STF) analisou detalhadamente, em sessão ocorrida em 9.9.2015, todos os pedidos formulados na petição inicial e que as questões agora discutidas não estariam relacionadas com aqueles pedidos. Explicitou não ser possível a ampliação do pedido cautelar já apreciado anteriormente. A Corte está limitada ao pedido. Aceitar a sua ampliação equivale a agir de ofício, sem observar a legitimidade constitucional para propositura da ação. Ademais, em que pese a preocupação de todos em relação ao Covid-19 nas penitenciárias, a medida cautelar, ao conclamar os juízes de execução, determina, fora do objeto da ADPF, a realização de megaoperação para analisar detalhadamente, em um único momento, todas essas possibilidades e não caso a caso, como recomenda o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Vencidos os ministros Marco Aurélio (relator) e Gilmar Mendes, que referendaram a medida cautelar. O ministro Gilmar Mendes pontuou que a decisão do relator se enquadra no pedido da inicial, na declaração de estado de coisa inconstitucional. ADPF 347 TPI-Ref/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 18.3.2020. (ADPF-347)

EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 35719 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020)



Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 34173 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 10-02-2020 PUBLIC 11-02-2020)

Questões

1) (MPE/SP – 2019) — Assinale a alternativa INCORRETA.

a) A controvérsia em torno da incidência, ou não, do postulado da recepção, por não envolver qualquer juízo de inconstitucionalidade, mas, sim, quando for o caso, o de simples revogação de diploma pré- constitucional, dispensa a aplicação do princípio da reserva de plenário, legitimando a possibilidade de reconhecimento, por órgão fracionário do Tribunal, de que determinado ato estatal não foi recebido pela nova ordem constitucional, além de inviabilizar, porque incabível, a instauração do processo de fiscalização normativa abstrata.

b) A declaração de inconstitucionalidade de qualquer ato estatal, considerando a presunção de constitucionalidade das leis, só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de nulidade da decisão judicial que venha a ser proferida.

c) A causa de pedir aberta das ações do controle concentrado de constitucionalidade torna desnecessário o ajuizamento de nova ação direta para a impugnação de norma cuja constitucionalidade já é discutida em ação direta em trâmite, proposta pela mesma parte processual.

d) O processo de controle normativo abstrato rege-se pelo princípio da indisponibilidade, o que impede a desistência da ação direta já ajuizada. A ação subsiste mesmo diante de revogação superveniente do ato estatal impugnado.

e) A declaração final de inconstitucionalidade, quando proferida em sede de fiscalização normativa abstrata, considerado o efeito repristinatório que lhe é inerente,



importa em restauração das normas estatais anteriormente revogadas pelo diploma normativo objeto do juízo de inconstitucionalidade.

2) (TJ/MS – 2020) — A Constituição Federal estabelece que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), dela decorrente, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na forma da lei. A esse propósito, considerada a regulamentação da matéria à luz da jurisprudência da referida Corte,

a) em sede de medida liminar, pode ser determinada a suspensão dos efeitos de decisões judiciais relacionadas com a matéria objeto da ADPF, admitida a relativização dos decorrentes de coisa julgada, por decisão de maioria qualificada do STF, diante de circunstâncias de excepcional interesse social.

b) admite-se o ingresso de amici curiae na ADPF, pela aplicação, por analogia, do estabelecido em lei relativamente à ação direta de inconstitucionalidade, desde que demonstradas a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.

c) considerado seu caráter subsidiário, não pode a ADPF ser conhecida como ação direta de inconstitucionalidade, acaso manejada em hipótese de cabimento desta, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade entre ações de controle concentrado.

d) não se admite a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em sede de ADPF, por ausência de previsão legal, diferentemente do que ocorre em relação às ações diretas de inconstitucionalidade e declaratórias de constitucionalidade.

e) as normas processuais destinadas a resguardar os interesses da Fazenda Pública, a exemplo da exigência de intimação pessoal dos entes públicos para início da contagem de prazos, são aplicáveis no âmbito da ADPF, embora não o sejam nos demais processos de controle concentrado, por sua natureza objetiva.

Comentários

1) Gabarito: letra D. Primeira parte do item "d" correta, consoante o art. 5º, da Lei 9.868/1999, art. 169, § 1º, do Regimento Interno do STF e da jurisprudência do Supremo. O Supremo admite, em algumas hipóteses, a subsistência da ação mesmo com a revogação do diploma legal vergastado pela ADI:

Pela extinção da ação:

A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. (ADI 1.442, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 3/11/2004, Plenário. No mesmo sentido: ADI 4.041-AgR-AgR-AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 24/3/2011)

(...) revogada a lei arguida de inconstitucional, a ação direta a ela relativa perde o seu objeto, independentemente da ocorrência de efeitos concretos que dela hajam decorrido. (ADI 221, rel. min. Moreira Alves, julgamento em 16/9/1993, Plenário; no mesmo sentido: ADI 3.171, rel. min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, julgamento em 13/4/2010)

Em sentido oposto:

(...) o fato de a lei objeto da impugnação ter sido revogada, não diria, no curso dos processos, mas já quase ao cabo deles, não subtrai à Corte a jurisdição nem a competência para examinar a constitucionalidade da lei até então vigente e suas consequências jurídicas, que, uma vez julgadas procedentes as três ações, não seriam, no caso, de pouca monta. (ADI 3.232, voto do rel. min. Cezar Peluso,



julgamento em 14/8/2008, Plenário. No mesmo sentido: ADI 1.835, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 17/9/2014)

"Configurada a fraude processual com a revogação dos atos normativos impugnados na ação direta, o curso procedimental e o julgamento final da ação não ficam prejudicados." (ADI 3.306, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 17/3/2011)

a) Correto. Via de regra, a aplicação da reserva de plenário alcança o próprio Supremo Tribunal Federal, naturalmente para a declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado de constitucionalidade. A exceção é para o juízo de recepção ou não recepção de norma pré-constitucional.

b) É a regra da cláusula de reserva de plenário.

c) Correto, consoante entendimento consolidado pelo Supremo, no sentido de que se houver ação direta com objeto abrangido por ação anteriormente intentada pela mesma parte, é contraproducente nova impugnação do mesmo ato normativo, pois é possível declinar os mesmos fundamentos em ação já em curso no STF, em face da causa de pedir aberta das ações de controle concentrado, isto é, o Tribunal tem ampla margem de apreciação, podendo decidir com base em fundamentos diversos daqueles declinados pelo autor da ação

2) Gabarito: letra B. O Supremo tem admitido o *amicus curiae* em diversas ADPF, conforme segue:

"AMICUS CURIAE" - INTERVENÇÃO PROCESSUAL EM SEDE DE ADPF - ADMISSIBILIDADE - PLURALIZAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL E A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL (ADPF 187, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 28/5/2014).

Sobre a inexistência de outro meio eficaz para viabilizar a antecipação terapêutica do parto, sem incompreensões, evoca a Confederação recente acontecimento retratado no Habeas Corpus nº 84.025-6/RJ, declarado prejudicado pelo Plenário, ante o parto e a morte do feto anencefálico sete minutos após. Diz da admissibilidade da ANIS – Instituto de Biotécnica, Direitos Humanos e Gênero como *amicus curiae*, por aplicação analógica do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99. (ADPF 54/DF, rel. Min. Carlos Ayres Britto, julg. em 12/4/2012).

c) Errado, pois com base no princípio da fungibilidade, o Supremo tem conhecido ADPF's propostas como ação direta de inconstitucionalidade, ante a perfeita satisfação dos requisitos exigidos à sua propositura - legitimidade ativa, objeto, fundamentação e pedido (dentre outros, ADI 4.180/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 10/03/2010):

2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impropriedade da ação. Conversão em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF. Admissibilidade. Satisfação de todos os requisitos exigidos à sua propositura. Pedido conhecido, em parte, como tal. Aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente. É lícito conhecer de ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando coexistentes todos os requisitos de admissibilidade desta, em caso de inadmissibilidade daquela. (ADI 4.163/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento 29/2/2012)



d) Errado. A modulação dos efeitos temporais da decisão em sede de ADPF é autorizada pelo art. 11, da Lei 9.882/1999 (Lei da ADPF):

Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

e) Errado, visto que essas normas não se aplicam a nenhum processo de índole objetiva, conforme decidiu o Supremo (Agravo ADPF-AgR 2º 205/PI, relator Min. Dias Toffoli, julg. 19/6/2017).



CAPÍTULO 19 – FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

Sob essa rubrica, a CF vai tratar do:

- (I) MP
- (II) Advocacia pública
- (III) Defensoria pública
- (IV) Advocacia privada

1. MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado.

Ao MP incumbe a defesa:

- da ordem jurídica
- do regime democrático
- dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

O MP é autônomo e independente, não estando subordinado a nenhum dos poderes da república, funcionando como fiscal dos poderes.

1.1. COMPOSIÇÃO DO MP

O Ministério Público abrange:

- MPU: compreende o MPF, MPDFT, MPT e MPM.
- MPE

O MP possui um capítulo especial, fora dos demais poderes.

Existe uma corrente que sustenta sua vinculação dentro do Poder Executivo, apesar de ser questionável, pois não estaria subordinado a qualquer dos poderes. No entanto, ao menos do ponto de vista administrativo haveria a vinculação ao executivo.

1.2. PRINCÍPIOS DO MP

A Constituição prevê como princípios:

- unidade: o MP é apenas um. Os membros do MP integra um só órgão, que está sob direção do PGR. Esta unidade é dentro de cada Ministério Público.
- indivisibilidade: quando um membro do MP atua, quem estaria atuando é o próprio MP, e não o membro, podendo, dessa forma, ser substituídos uns pelos outros.
- independência funcional: o MP no exercício de suas competências não obedece à ordem de ninguém. No entanto, dentro do MP, o membro age de acordo com a sua convicção jurídica, havendo esta independência funcional. Existe hierarquia dentro do MP, sendo esta administrativa e não funcional, não podendo incidir sobre a convicção jurídica do membro.
- autonomia administrativa e financeira.
- autonomia administrativa: consiste no poder do MP em propor ao legislativo a criação e extinção de órgãos. O PGR provê estes cargos por meio de concurso público que ele organiza. Com isso, o MP propõe a remuneração e o plano de carreira dos seus membros e servidores.
- autonomia financeira: é a competência para elaborar a sua proposta orçamentária, dentro dos limites da lei de diretrizes orçamentárias, administrando os seus recursos. Esta autonomia não confere ao MP promover a iniciativa de sua proposta orçamentária diretamente ao legislativo. O que ele faz é encaminhar a proposta orçamentária ao poder legislativo, por meio do chefe do poder executivo. Essa proposta do MP integrará o orçamento geral, que é encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo.



Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente.

1.2.1. INICIATIVA CONCORRENTE DA LEI DE ORGANIZAÇÃO DO MP

Percebe-se ainda a autonomia do MP, quando o PGR tem competência para dar início à lei de organização do Ministério Público. Todavia, é atribuída concorrentemente ao chefe do Poder Executivo.

Isto é um dos fundamentos de que administrativamente o Ministério Público estaria dentro do Poder Executivo.

1.2.2. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL

Existe uma discussão sobre a existência do princípio do promotor natural.

O princípio do promotor natural quer vedar a arbitrariedade de designações casuísticas. Isso porque, neste caso, haveria o promotor de exceção, *ad hoc*.

O ministro Celso de Melo diz que este princípio é extraído da independência funcional e da própria inamovibilidade do membro do MP. No entanto, o próprio STF não tem uma posição definida sobre o tema.

1.3. FUNÇÕES DO MP

Segundo o art. 129, são funções institucionais do Ministério Público:

- promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
- zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
- promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;
- defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
- expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;
- exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;

O STF considerou constitucional uma lei do RJ que permitia que o MP requisitasse ao delegado de polícia explicações, quando não fosse concluído IP dentro do prazo de 30 dias em que o réu estivesse solto.

- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
- exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.

Cabe ressaltar que a legitimação do Ministério Público para as ações civis não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses.

Atente-se que as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.

Segundo o STJ, o acesso do MPF às informações inseridas em procedimentos disciplinares conduzidos pela OAB depende de prévia autorização judicial. O fundamento para



esta decisão encontra-se no § 2º do art. 72 da Lei nº 8.906/94, que estabelece que a obtenção de cópia dos processos ético-disciplinares é matéria submetida à reserva de jurisdição, de modo que somente mediante autorização judicial poderá ser dado acesso a terceiros.

1.3.1. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MP

Segundo o STF, fundado na teoria dos poderes implícitos, o MP tem legitimidade para promover investigações de natureza penal, porém não pode instaurar inquérito policial, podendo, tão somente, requisitá-lo.

1.4. ATUAÇÃO DO PGR

A CF vai dispor várias atuações do PGR, no entanto, é necessário trazer as mais importantes:

- PGR deve ser ouvido nas ações diretas de inconstitucionalidades e em todos os processos de competência do STF.
- Compete ao PGR propor a representação interventiva.
- Compete ao PGR propor ADI, ADC, ADO e ADPF.
- Compete ao PGR oficiar perante o CNJ, mas não é membro.
- Compete ao PGR compor e presidir o CNMP.
- Compete ao PGR dirimir conflitos de atribuições entre membros do MPF e de Ministérios Públicos Estaduais (STF).

1.5. INGRESSO NA CARREIRA

O ingresso na carreira do MP depende de:

- concurso público de provas e títulos
- assegurada a participação da OAB em sua realização
- no mínimo, três anos de atividade jurídica e
- nomeações na ordem de classificação.

1.6. NOMEAÇÃO DOS PROCURADORES-GERAIS

1.6.1. PGR

O MPU tem como chefe o Procurador-Geral da República, sendo:

- nomeado pelo Presidente da República
 - dentre integrantes da carreira
 - maiores de 35 anos
 - após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal
- Atente-se que o mandato será de dois anos, permitida sucessivas reconduções.

O MPF é chefiado pelo PGR, chefe do MPU. Os demais, no entanto, tem um procurador geral diverso, tal como o MPT, MPDFT e MPM:

- no MPT e no MPM: o procurador-geral é nomeado pelo Procurador-Geral da República.
- no MPDFT: não é nomeado pelo PGR, e sim pelo Presidente da República, a partir de uma lista tríplice elaborada pelo MPDFT. Nesse caso, a recondução só pode se dar uma única vez.

A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

1.6.2. PGJ

Aqui a regra é diferente, pois a CF estabeleceu diferentemente.



A nomeação do Procurador-Geral de Justiça se dará pelo Chefe do Poder Executivo, a partir de uma lista tríplice dentre integrantes da carreira, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

Atente-se que o PGR não tem limitação para recondução, enquanto o PGJ só poderá ser reconduzido uma única vez. Além disso, não há participação da Assembleia Legislativa. Essas são diferenças básicas.

Apesar da Assembleia Legislativa não participar da nomeação, deverá deliberar na hipótese de destituição do Procurador-Geral de Justiça do cargo, devendo se manifestar pela maioria absoluta.

1.7. GARANTIAS DOS MEMBROS

São garantias dos membros do MP:

- vitaliciedade: após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado.
- inamovibilidade: salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Uma vez no cargo, o membro do MP só poderá ser removido se ele quiser;
 - a) decisão colegiada do órgão competente, dependendo da maioria absoluta;
 - b) determinação do CNMP, a título de sanção administrativa.
- irredutibilidade de subsídio: fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I. Esta irredutibilidade é meramente nominal, não impedindo que tributos sejam majorados.

1.8. VEDAÇÕES AO MEMBRO

São vedações aos membros do MP:

- receber honorários, percentagens ou custas processuais;
- exercer a advocacia- Não poderá exercer advocacia no juízo ou Tribunal que exercia a função pública antes de decorridos 3 anos de seu afastamento. É a denominada quarentena.
- participar de sociedade comercial, na forma da lei-Não pode ser sócio-gerente, nem o administrador.
- exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério-Por conta disso, o STF decidiu que membros do Ministério Público não podem ocupar cargos públicos fora do âmbito da instituição, salvo cargo de professor e funções de magistério, sendo assim a nomeação de membro do MP para o cargo de Ministro da Justiça viola o texto constitucional.
- exercer atividade político-partidária;
- receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.

1.9. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O CNMP tem 14 membros, nomeados pelo Presidente da República, após aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:

- Procurador-Geral da República, que o presidirá;
- 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras (MPF, MPDFT, MPT e MPM).
- 3 membros do Ministério Público dos Estados;
- 2 juízes, indicados um pelo STF outro pelo STJ;



- 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da OAB;
- 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

Ou seja, 8 são representantes do MP (4 do MPU, 3 dos MPE's e o PGR). Os outros 6 são 2 juízes (STF e STJ), 2 advogados (OAB) e 2 cidadãos (Câmara e Senado).

A função do CNMP é controlar a atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros.

Compete ao CNMP:

- zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;
- zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;
- receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;
- rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;
- elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.
- Segundo o STF, o CNMP é competente para monitor e supervisionar o pagamento de precatórios.

O presidente do CNMP é o PGR, sendo que o Corregedor Nacional do CNMP deverá ser dentre os integrantes do Ministério Público, sendo vedada a sua recondução. Esta votação é secreta.

Compete ao Corregedor Nacional do CNMP:

- receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares;
- exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral;
- requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público.

O Presidente do Conselho Federal da OAB oficiará junto ao Conselho, mas não integrará o CNMP.

Caso os membros do Conselho Nacional do MP cometerem crime de responsabilidade, estes serão julgados pelo Senado Federal. No entanto, havendo crime comum, dependerá da sua própria função.

Havendo ação contra o CNMP, competirá ao STF o processo e julgamento originário.

O CNMP não possui competência para realizar controle de constitucionalidade de lei, considerando que se trata de órgão de natureza administrativa, cuja atribuição se resume a fazer o controle da legitimidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público federal e estadual (art. 130-A, § 2º, da CF/88) (Inf. 781, STF).

É nula a decisão do CNMP que, em procedimento de controle administrativo (PCA), notifica o interessado por meio de edital publicado no Diário Oficial da União para restituir



valores aos cofres públicos, tendo em vista que, segundo o STF, tal disposição normativa é inconstitucional, sendo necessária a intimação pessoal (Inf. 805, STF).

1.10. MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS

O Ministério Público junto aos Tribunais de Contas integra este órgão.

Esta norma, segundo o STF, se aplica aos Tribunais de Contas dos Estados, razão pela qual o MP de Contas do Estado também integra os Tribunais de Contas.

1.11. PRERROGATIVA DE FORO

O PGR, caso cometa crime comum, será julgado pelo STF. Sendo crime de responsabilidade, será julgado pelo Senado Federal.

No entanto, sendo membros do MPU, irá depender de onde eles atuam:

- atuam perante os TRF's: serão julgados perante o STJ.
- atuam em 1ª instância: serão julgados pelo TRF, visto que são autoridades federais, salvo se cometerem crime eleitoral, pois serão julgados pelo TRE.

Já os membros dos MPE's, são julgados pelos Tribunais de Justiça, salvo a competência da justiça eleitoral, em que serão julgados pelo TRE.

1.12. ATUAÇÃO PERANTE O STF

O PGR atua em todos os processos perante o STF. Esta legitimidade é privativa do PGR.

Com base nisso, em relação ao Ministério Público Estadual, este também tem legitimidade processual para atuar diretamente no STF, pois não existe relação de dependência entre o MPE e o MPU. Isso porque estamos num estado federal, não havendo hierarquia entre União e Estado.

Nesse mesmo sentido, o STJ decidiu que o MPE possui legitimidade para atuar diretamente no STJ nos processos em que figurar como parte. O MPE, nos processos em que figurar como parte e que tramitam no STJ, possui legitimidade para exercer todos os meios inerentes à defesa de sua pretensão. A função de fiscal da lei no âmbito do STJ será exercida exclusivamente pelo Ministério Público Federal, por meio dos Subprocuradores-Gerais da República designados pelo Procurador-Geral da República.

Segundo o STF, o Ministério Público do Trabalho não possui legitimidade para atuar diretamente perante o STJ. Isso porque o MPT integra a estrutura do MPU.

1.13. ADVOCACIA PÚBLICA

1.13.1. AGU

A advocacia pública, na esfera da União, compete à AGU, que é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente.

A AGU também presta consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

A AGU tem como chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação e exoneração pelo Presidente da República:

- dentre cidadãos maiores de 35 anos
- de notável saber jurídico e reputação ilibada
- não precisa ser integrante da carreira

O Advogado-Geral da União tem status de Ministro de Estado.

Se o Advogado-Geral da União cometer crime de responsabilidade será julgado pelo Senado Federal. Mas se comete crime comum, será julgado pelo STF.

Em se tratando de dívida de natureza tributária, quem representa a União é a Procuradoria da Fazenda Nacional. A PFN é órgão do Ministério da Fazenda, fazendo parte da advocacia pública da União.



1.13.2. PROCURADORIA DOS ESTADOS

Com relação aos Procuradores dos Estados e do DF, o art. 132 estabelece que estes são organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

Aos procuradores é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Não há vitaliciedade, mas estabilidade.

O STF firmou o entendimento de que os procuradores, quando emitem um parecer, e o administrador vai no sentido desse parecer, isto não implica responsabilidade solidária do advogado público por eventual erro, salvo se for decorrente de culpa grave, erro grosseiro, inescusável.

1.14. ADVOCACIA

O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

A partir desse dispositivo resta consagrado o princípio da indispensabilidade do advogado e princípio da imunidade do advogado.

A indispensabilidade significa que, para promover a ação, deve se dar por meio de advogado, salvo nos casos do Juizados Especiais Cíveis, Justiça do Trabalho, habeas corpus, revisão criminal, etc.

Quanto ao princípio da imunidade, esta inviolabilidade é em relação aos atos e manifestações no exercício da profissão. Não legitima o abuso!

O STF entendeu que é constitucional a previsão de que os advogados terão direito à sala de estado-maior. Após a condenação, o advogado deverá ser encaminhado para a prisão comum.

Segundo o STF, é constitucional a isenção do pagamento de contribuição sindical, eis que ele já paga a contribuição anual para a OAB.

1.15. DEFENSORIA PÚBLICA

A CF consagra como direito individual que o necessitado, que apresenta insuficiência de recursos, terá uma prestação estatal jurídica gratuita e integral, conforme art. 5º, LXXIV.

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo a ela:

- orientação jurídica
- promoção dos direitos humanos
- defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados

As defensorias públicas são organizadas em carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes:

- garantia da inamovibilidade
- vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais

Os princípios institucionais da defensoria pública são basicamente os mesmos do MP:

- unidade: quem atua o órgão, e não apenas o membro.
- indivisibilidade: o defensor público não se vincula ao processo que atua.
- independência funcional: atua com convicção jurídica, não estando subordinado a quaisquer poderes com relação a esta atuação. A hierarquia existente é meramente administrativa.

Uma leitura combinada do art. 134, §2, e o art. 96, II, permite concluir que às defensorias públicas é assegurada a autonomia administrativa para propor ao Poder



Legislativo a criação e extinção de cargos e a remuneração dos serviços auxiliares. Inclusive, para propor como será fixado os subsídios de seus membros.

Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

Veja, não há apenas a autonomia administrativa, havendo também autonomia financeira da defensoria pública.

Essa autonomia administrativa e a independência funcional asseguram o direito de o Poder Judiciário não interferir nas escolhas e nos critérios de atuação dos defensores públicos. Por conta disso, não configura crime de desobediência a conduta do Defensor Público Geral que deixa de atender à requisição judicial de nomeação de defensor público para atuar em determinada ação penal, sob alegação de que não há efetivo para tanto, havendo outras comarcas prioritárias para atendimento. Este foi o entendimento do STJ (Inf. 586).

Com relação à ação civil pública, a defensoria pública também possui legitimidade para tanto, razão pela qual o STF ratificou esse entendimento, mesmo que atinja excepcionalmente pessoas não necessitadas.

A CF determinar que os membros da defensoria pública sejam remunerados por meio de subsídios.

O STJ já decidiu que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores idosos que tiveram plano de saúde reajustado em razão da mudança de faixa etária, ainda que os titulares não sejam carentes de recursos econômicos (Inf. 573).

2. INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA

2.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública que vise anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão ao patrimônio público. STF. Plenário. RE 409356/RO, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/10/2018 (repercussão geral)

É constitucional dispositivo da Constituição Estadual que assegura ao Ministério Público autonomia financeira e a iniciativa ao Procurador-Geral de Justiça para propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção dos cargos e serviços auxiliares e a fixação dos vencimentos dos membros e dos servidores de seus órgãos auxiliares. Também é constitucional a previsão de que o Ministério Público elaborará a sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos pela LDO. STF. Plenário. ADI 145/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2018

2.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Admite-se a intervenção da Defensoria Pública da União no feito como custos vulnerabilis nas hipóteses em que há formação de precedentes em favor dos vulneráveis e dos direitos humanos. Salienta-se preliminarmente que, no caso, foi facultada à Defensoria Pública da União a sua atuação nos autos como amicus curiae. Contudo, a DPU postulou a sua intervenção como custos vulnerabilis, ou seja, na condição de "guardião dos vulneráveis", o que lhe possibilitaria interpor todo e qualquer recurso. O art. 1.038, I, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que o relator poderá solicitar ou admitir manifestação de pessoas,



órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno. A Defensoria Pública, nos termos do art. 134 da CF/88, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. Segundo a doutrina, custos vulnerabilis representa uma forma interventiva da Defensoria Pública em nome próprio e em prol de seu interesse institucional (constitucional e legal), atuação essa subjetivamente vinculada aos interesses dos vulneráveis e objetivamente aos direitos humanos, representando a busca democrática do progresso jurídico-social das categorias mais vulneráveis no curso processual e no cenário jurídico-político. A doutrina pondera ainda, "que a Defensoria Pública, com fundamento no art. 134 da CF/88, e no seu intento de assegurar a promoção dos direitos humanos e a defesa [...] de forma integral, deve, sempre que o interesse jurídico justificar a oitiva do seu posicionamento institucional, atuar nos feitos que discutem direitos e/ou interesses, tanto individuais quanto coletivos, para que sua opinião institucional seja considerada, construindo assim uma decisão jurídica mais democrática". Assim, tendo em conta que a tese proposta no recurso especial repetitivo irá, possivelmente, afetar outros recorrentes que não participaram diretamente da discussão da questão de direito, bem como em razão da vulnerabilidade do grupo de consumidores potencialmente lesado e da necessidade da defesa do direito fundamental à saúde, a Defensoria Pública da União está legitimada para atuar como custos vulnerabilis.

Questões

1) (TJ SC-2019) — A propósito de titularidade, âmbito de proteção e conformação constitucional de ação civil pública, assinale a opção correta.

- a) Não é cabível ação civil pública para anular ato administrativo de aposentadoria de servidor público, se esta importar em lesão ao erário.
- b) De acordo com o STF, é inconstitucional lei estadual que atribua legitimação exclusiva a procurador-geral de justiça estadual para propor ação civil pública contra prefeito municipal.
- c) O Ministério Público tem legitimidade para ingressar com ação civil pública relativa ao pagamento de indenizações do seguro DPVAT.
- d) A Defensoria Pública não tem legitimidade para propor ação civil pública que verse sobre a manutenção de creche infantil.
- e) A condenação de agente público por ato de improbidade em ação civil pública depende da tipificação administrativa ou penal do ato lesivo ao patrimônio público.

2) (DPE/SP-2019) — Na evolução histórica do acesso à justiça no Brasil aos mais vulneráveis,

- a) o art. 98 das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988, acrescentado pela EC nº 80/14, prevê que, no prazo de até 10 (dez) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com Defensores Públicos nas Comarcas com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional.
- b) a Constituição de 1988 adotou o modelo público, atribuindo à Defensoria Pública o dever de prestar assistência judiciária como direito de todos e dever do Estado.
- c) a Lei nº 1.060/50, editada sob a égide da Constituição de 1946, adotou o modelo judicare, devendo o Estado remunerar os advogados particulares que atuassem em favor de pessoas necessitadas.



d) a Constituição de 1934 previa, em caráter inédito, que a União e os Estados deveriam conceder assistência judiciária aos necessitados.

e) a Constituição de 1967 atribuiu à União e aos Estados o dever de prestar diretamente assistência jurídica aos necessitados ou fazê-lo, subsidiariamente, por meio de advogados particulares conveniados.

Comentários

1) Gabarito: letra C. Conforme jurisprudência do Supremo assentada em sede de repercussão geral (Tema 471) por entender que há interesse social qualificado na tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos dos titulares do Seguro DPVAT, alegadamente lesados pela Seguradora no pagamento das correspondentes indenizações, a atrair a competência do Ministério Público na propositura de ação civil pública em defesa de beneficiários do DPVAT.

a) Errado, por trazer orientação contrária à jurisprudência do Pretório Excelso, firmada também em sede de repercussão geral. O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 561 da repercussão geral, conheceu parcialmente do recurso extraordinário e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: "O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública que vise anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão ao patrimônio público". (RE 409.356, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 25/10/2018, Plenário, Informativo 921, Tema 561.)

b) Errado, por ter o Supremo firmado entendimento de que a atribuição dada, por lei estadual, ao procurador-geral de Justiça do Estado, não configura usurpação de competência da União, e nem se refere a matéria processual, sendo atinente às atribuições do Parquet local:

"Competência exclusiva do procurador-geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para propor a ação civil pública contra autoridades estaduais específicas. A legitimação para propositura da ação civil pública – nos termos do art. 129, III, da Constituição do Brasil – é do Ministério Público, instituição una e indivisível. (...) A lei complementar objeto desta ação não configura usurpação da competência legislativa da União ao definir as atribuições do procurador-geral. Não se trata de matéria processual. A questão é atinente às atribuições do Ministério Público local, o que, na forma do art. 128, § 5º, da Constituição do Brasil/1988, é da competência dos Estados-membros. (ADI 1.916, rel. min. Eros Grau, julgamento em 14/4/2010, Plenário)

d) Errado, pois em julgado que versou sobre ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais a fim de que o município Belo Horizonte mantenha o funcionamento das creches e escolas de educação infantil da rede municipal de ensino, o STF assentou a legitimidade da Defensoria para propositura da ação:

"A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas" (RE 733.433, rel. min. Dias Toffoli, julgado em 25/10/2012)

e) Errado. Pelo princípio da independência das instâncias a condenação de agente público por ato de improbidade administrativa em ação civil pública independe de lesão efetiva ao erário, tipificável administrativa ou penalmente.

2) Gabarito: letra D. A Constituição Federal de 1934 foi inspirada na Constituição alemã de Weimar, de 1919, e foi a primeira a consagrar direitos sociais como a educação e a cultura (arts. 148 a 158), amparo à maternidade e à infância (art. 141) direitos dos trabalhadores, inclusive previdenciários (arts. 121 e 123), saúde e assistência públicas (art. 10, II), além da previsão de assistência judiciária aos necessitados pela União e pelos Estados (art. 113, parágrafo 32).



a) Errado, pois o prazo estabelecido pelo art. 98 do ADCT é de oito anos, interregno durante o qual os entes federados deverão contar com defensores públicos em todas as comarcas, com prioridade para as de maior exclusão social e adensamento populacional:

Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população.

§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo.

§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional.

b) Errado. A Constituição de 1988 atribuiu à Defensoria Pública o dever de prestar orientação jurídica, promover os direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal (art. 134, CF).

c) Errado, pois aquela norma, modificada recentemente pelo Código de Processo Civil de 2015, previa que o ônus da sucumbência era da parte vencida, quando o beneficiário da assistência gratuita fosse vencedor na causa, sem prejuízo da assistência pública por defensor público:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§ 5º Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

Art. 11. Os honorários de advogados e peritos, as custas do processo, as taxas e selos judiciários serão pagos pelo vencido, quando o beneficiário de assistência for vencedor na causa. (Revogado pela Lei n.º 13.105, de 2015)

§ 1º. Os honorários do advogado serão arbitrados pelo juiz até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o líquido apurado na execução da sentença. (Revogado pela Lei n.º 13.105, de 2015)

§ 2º. A parte vencida poderá acionar a vencedora para reaver as despesas do processo, inclusive honorários do advogado, desde que prove ter a última perdido a condição legal de necessitada. (Revogado pela Lei n.º 13.105, de 2015)

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

e) Errado. A Constituição de 67 previa apenas a assistência jurídica aos necessitados, no parágrafo 32 do art. 150 da Constituição de 1967:

Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

.....

§ 32 - Será concedida assistência Judiciária aos necessitados, na forma da lei.



CAPÍTULO 20 – DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

Trata-se de uma situação de crise constitucional, hipótese em que a CF adotará certas medidas: estado de defesa e estado de sítio.

A ideia é restabelecer a ordem e a normalidade constitucional, em que naquele momento se mostra fragilizada.

Nesse caso, é acionado o sistema constitucional de crises, que é um conjunto de normas constitucionais que buscam restabelecer a normalidade, determinando restrições que em tempo de normalidade não se admite.

A execução dessas medidas demandam uma situação de excepcionalidade.

Para que essas medidas sejam admissíveis, é preciso que observem 3 requisitos:

- Necessidade: é imprescindível que essa medida seja adotada. Caso haja outra forma menos gravosa, não é proporcional que se decrete o estado de defesa ou estado de sítio.
- Temporariedade: quer dizer que esta medida deverá ser imposta por um prazo necessário para restabelecer a ordem. O decreto já vem trazendo o prazo, porém pode ser que não haja prazo específico no caso de guerra declarada.
- Obediência exata dos comandos constitucionais: o estado de defesa e estado de sítio só se legitimam quando estão de acordo com a Constituição, pois, do contrário, haveria uma situação de abusividade.

1. ESTADO DE DEFESA

O estado de defesa é mais brando do que o estado de sítio. Uma das hipóteses do estado de sítio é a ineficácia do estado de defesa.

O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa. A ideia é de que o estado de defesa venha preservar ou restabelecer ordem pública ou a paz social.

Esse estado de defesa é em local restrito e determinado, de forma que o decreto irá especificar o local do estado de defesa.

A anormalidade deve ter causado uma fragilização da ordem pública ou paz social, havendo uma iminente instabilidade institucional ou aquela região tenha sido atingida por calamidades de grandes proporções na natureza.

1.2. PRESSUPOSTOS

Os pressupostos para o estado de defesa são:

- Existência de uma grave instabilidade institucional: não precisa ter se consumado, bastando que seja iminente.
- Calamidades de grandes proporções na natureza

O Presidente da República decreta após a oitiva dos conselhos da república e da defesa nacional, e submete à apreciação do Congresso Nacional, diferentemente do estado de sítio, em que o PR pede autorização ao Congresso Nacional.

Dentro de 24 horas, após a submissão do decreto ao Congresso Nacional, eles irão aprovar ou rejeitar. Se estiver em recesso, o CN será convocado extraordinariamente, ficando mantido ativamente enquanto vigorar o estado de defesa.

Em 10 dias, o CN aprecia, aprovando ou rejeitando o estado de defesa. Caso haja a rejeição, cessará imediatamente as medidas adotadas no estado de defesa.

O decreto do estado de defesa determinará:

- prazo de duração: em face do princípio da temporariedade;
- áreas abrangidas: é requisito que o estado de defesa atinja locais restritos e determinados;



- medidas coercitivas

1.3. PRAZO

O prazo para o estado de defesa não poderá ser superior a 30 dias. Porém, é admitida uma única prorrogação por prazo de até 30 dias, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

Não havendo solução a questão, é possível a decretação do estado de sítio.

1.4. MEDIDAS COERCITIVAS

São medidas coercitivas do estado de defesa:

- restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações;
- restrições aos direitos de sigilo de correspondência;
- restrições aos direitos de sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;
- ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.

Veja, o Estado quer ter o amplo acesso às comunicações das pessoas, a fim de evitar ataques.

Na vigência do estado de defesa é possível que seja alguém preso por crime contra o estado, determinada pelo executor da medida. Neste caso, o executor determina a prisão, mas comunica ao Poder Judiciário. Isso porque o juiz deverá fazer o controle da legalidade dessa prisão. A inafastabilidade do judiciário continuará em vigor.

Essa comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação.

Ainda, o executor da medida poderá determinar a prisão de qualquer pessoa por outro motivo, que não seja o cometimento de crime contra o estado, mas, neste caso, não poderá a prisão exceder o período de 10 dias. Só poderá ultrapassar este prazo se houver autorização do juiz.

Nesta situação há uma anormalidade, a fim de justificar a decretação de prisão por executor da medida, que não é autoridade judicial.

A CF estabelece que é vedada a incomunicabilidade do preso. A doutrina discute se seria vedada em tempos de normalidade. Ocorre que a maioria da doutrina diz que não se admite a incomunicabilidade em tempos de normalidade.

1.5. CONTROLE DO ESTADO DE DEFESA

A decretação do estado de defesa se sujeitará ao controle político e ao controle jurisdicional.

- Controle político: é exercido pelo Congresso, sendo exercido em três momentos:
 - a. Controle introdutório: decretado o estado de defesa, o Presidente comunica, no prazo de 24 horas, ao Congresso Nacional, que se reunirá para apreciar o decreto, mediante a aprovação da maioria absoluta dos parlamentares. Estando em recesso, haverá convocação extraordinária pelo Presidente do Senado, no prazo de 5 dias.
 - b. Controle concomitante: a Mesa do Congresso Nacional designará comissão parlamentar mista para acompanhamento e fiscalização das medidas, sem prejuízo da possibilidade de suspensão do estado de defesa, ainda que tenha sido aprovado anteriormente.
 - c. Controle posterior: após o estado de defesa, o Congresso examina o relatório do presidente da República sobre as medidas adotadas, bem como suas justificativas e a identificação das pessoas atingidas. Se concluir pelo excesso, as autoridades serão responsabilizadas.



- Controle jurisdicional: o Poder Judiciário não é afetado pelo estado de defesa, pois cabe a ele controlar a execução das medidas e repelir quaisquer excessos, sem prejuízo da responsabilização posterior dos responsáveis. O controle judicial incide também sobre os pressupostos formais das medidas de exceção, embora doutrina majoritária não o admita quanto aos pressupostos materiais, eis que decorre de conveniência e oportunidade. O poder judiciário atua principalmente na fiscalização da legalidade das prisões provisórias especiais, conforme o art. 136, §3º. Os instrumentos serão mandado de segurança, habeas corpus, etc. O Poder Judiciário também poderá ser instado a se manifestar pelos atos cometidos durante a medida. A doutrina estabelece que o judiciário fará apenas um controle de legalidade, não podendo fazer controle de conveniência e oportunidade sobre o estado de defesa. Isso porque o ato é político.

2. ESTADO DE SÍTIO

No estado de sítio, o presidente da república poderá, depois de ouvidos o conselho da república e o de defesa nacional, requerer ou solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio.

Essa medida é muito mais gravosa, motivo pelo qual exige essa autorização. Isso enaltece o princípio da separação dos poderes, não podendo adotar uma medida tão gravosa sem que haja o controle do legislativo.

São hipóteses em que se admite o estado de sítio:

- comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia das medidas tomadas durante o estado de defesa;
- situação de guerra ou necessidade de repelir agressão armada estrangeira

Se a solicitação for feita em período de recesso, o Congresso será convocado extraordinariamente pelo presidente do Senado. Caso autorize, o CN ficará em funcionamento até o findar da situação de anormalidade.

2.1. DURAÇÃO

O decreto do estado de sítio indicará a duração. Se for para fins de duração de guerra, a duração do estado de sítio vigorará até o findar da guerra.

O decreto também deverá trazer as normas que serão observadas para a sua execução, isto é, quais garantias constitucionais ficam suspensas. Após, o PR indicará um executor das medidas específicas no decreto.

A duração do estado de sítio dependerá da hipótese que ensejou a medida:

- no caso de comoção grave de repercussão nacional ou de ineficácia do estado de defesa, o estado de sítio poderá ter o prazo de até 30 dias, possibilitando sucessivas prorrogações, desde que haja necessidade.
- no caso de necessidade de guerra ou de repelir agressão armada estrangeira, o estado de sítio perdura durante o tempo em que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira.

2.2. MEDIDAS COERCITIVAS

As medidas coercitivas para o estado de sítio dependerá da hipótese que o fundamentou:



- no caso de comoção grave de repercussão nacional ou de ineficácia do estado de defesa, podem ser tomadas as seguintes medidas, conforme hipóteses taxativas:
 - a) obrigação de permanência em determinada localidade: estado controla o ir e vir do cidadão.
 - b) detenção em edifício não destinado a criminosos comuns: é possível que uma escola pública se torne presídio.
 - c) restrições ao sigilo de correspondência e comunicações, bem como restrições à liberdade de imprensa, salvo pronunciamentos parlamentares difundidos a partir da Câmara ou do Senado, desde que devidamente liberados pelas respectivas Mesas;
 - d) suspensão da liberdade de reunião;
 - e) busca e apreensão e domicílio;
 - f) intervenção nas empresas de serviço público: visa garantir a continuidade dos serviços públicos.
 - g) requisição de bens, públicos ou particulares;
- no caso de necessidade de guerra ou de repelir agressão armada estrangeira, não existe numeração constitucional quanto às espécies de medidas cabíveis: Por conta disso, a doutrina afirma que, no tocante à decretação do estado de sítio nos casos de guerra e para repelir agressão armada estrangeira, a Constituição adotou o sistema flexível para lidar com crises constitucionais.

Todavia, cabe mencionar que a Convenção Americana de Direitos Humanos restringe a possibilidade de suspensão, inclusive nos casos de guerra, dos seguintes direitos fundamentais: direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, direito à vida, direito à integridade pessoal, proibição da escravidão e servidão, princípio da legalidade e da retroatividade, liberdade de consciência e religião, proteção da família, direito ao nome, direito da criança, direito à nacionalidade, direitos políticos.

2.3. CONTROLE

O controle do estado de sítio poderá ser um controle político e um controle jurisdicional:

Controle político: pode ser de três formas:

- Controle preventivo: é realizado quando o presidente solicita a autorização para decretar o estado de sítio, mediante necessidade de prévia autorização do Congresso, por maioria absoluta dos parlamentares.
- Controle concomitante: Congresso fiscaliza pela comissão mista de 5 membros designada ou pela possibilidade de suspender a medida a qualquer tempo, desde que haja votação da maioria absoluta.
- Controle sucessivo: é realizado após a cessação do estado de sítio, com base no relatório presidencial.
- Controle judicial: possibilita responsabilizar os executores das medidas, bem como a verificação de pressupostos formais e materiais do estado de sítio, tal como estabelecido no estado de defesa. Veja, o judiciário não apreciará o mérito do decreto, mas somente a legalidade.

3. FORÇAS ARMADAS

As Forças Armadas são o conjunto de instituições militares, de caráter permanente e regular, incumbidas da defesa da pátria, da garantia dos Poderes constitucionais e da lei e da ordem.

São formadas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica.



As forças armadas objetivam a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

Essas instituições são permanentes e regulares, sendo organizadas com base nos princípios da hierarquia e disciplina.

Além disso, as Forças Armadas têm como autoridade suprema o Presidente da República. As patentes militares são conferidas pelo Presidente da República.

O oficial só perde o posto e a patente se for julgado indigno por decisão de Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de Tribunal Especial, em tempo de guerra.

O oficial definitivamente condenado, pela justiça comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 anos, será submetido ao julgamento de indignidade.

Os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica têm status de ministro de Estado. Ademais, estão ligados ao Ministério da Defesa, sendo o ministro da defesa brasileiro nato.

Os membros das forças armadas são conhecidos como militares.

A CF diz que não cabe *habeas corpus* em relação a punições disciplinares aplicadas a militares, salvo no caso de verificação quanto à legalidade da medida, conforme entendimento do STF.

Ainda, a CF proíbe a sindicalização e a greve. O STF estende essa proibição à polícia civil.

O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político.

Em 2014, a EC 77 possibilitou a acumulação de cargos remunerados pelo militar, desde que seja em caso de prestação de serviços por profissionais da saúde. Ou seja, os militares que atuam na área da saúde, desde que haja compatibilidade de horários, podem cumular cargos e empregos públicos.

O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, salvo no caso de acumulação acima, ficará agregado ao respectivo quadro e, enquanto assim se mantiver, somente poderá ser promovido por antiguidade, contado o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei.

No tocante ao serviço militar obrigatório, em tempo de paz, são isentas as mulheres e os eclesiásticos, os quais ficam sujeitos a outros encargos a serem fixadas em lei que não foi editada.

Para aqueles que, por questões de consciência, crença religiosa, convicção filosófica ou política, se escusarem do serviço militar comum, deverão realizar prestação alternativa, estando regulado pela Lei 8.239/91.

O STF entendeu que o serviço militar obrigatório pode ser remunerado com salário abaixo do salário mínimo. A leitura foi de que os conscritos não exercem, na acepção estrita, como trabalhadores, não sendo a eles garantido a obrigatoriedade do salário mínimo.

Este tema foi objeto da súmula vinculante 6, que estabelece que não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial.

No caso de recusa do serviço alternativo, haverá a suspensão dos direitos políticos.

4. SEGURANÇA PÚBLICA

A segurança pública vem tratada pela Constituição como *numerus clausus*, ou seja, trata-se de um rol exaustivo.

Atente-se que guarda municipal não é órgão de segurança pública.

A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.



São órgãos da segurança pública: Polícia federal, Polícia rodoviária federal, Polícia ferroviária federal, Polícias civis, Polícias militares e corpos de bombeiros militares e polícias penais federal, estaduais e distrital, estes últimos acrescentados pela Emenda Constitucional nº 104 de 2019, sendo aqueles que trabalham na segurança dos estabelecimentos penais.

Para o Supremo, o rol dos órgãos de segurança pública é taxativo, de modo que os Estado-membros e o DF não podem criar ou nele incluir outros órgãos, tais como o Departamento de Trânsito, Polícia Penitenciária ou Instituto Geral de Perícias.

Segundo o STF, o serviço de segurança pública deve ser custeado por meio de impostos, não podendo ser feito por meio de taxas. Isso porque o serviço público deve ser divisível e específico, não sendo possível fazer isso em relação à segurança pública.

Para o Supremo, não é garantido aos policiais civis o direito de greve, tendo em vista que os servidores públicos dos órgãos de segurança exercem serviços público mediante “grupos armados”, razão pela qual se lhes aplica, por analogia, a proibição de greve, referente aos servidores militares.

O STJ já decidiu que não são somente os órgãos da polícia civil os únicos autorizados a proceder à interceptações telefônicas de que trata a Lei 9.296/96.

O STF entendeu que, por aplicação da teoria dos poderes implícitos e em razão de o Ministério Público ser o titular da ação penal, seus membros não estão proibidos de promover a colheita de determinados elementos de prova que demonstrem a existência de autoria e materialidade de determinado delito. Eventuais investigações ministeriais não significam retirar da Polícia Judiciária as atribuições previstas na Constituição, mas apenas harmonizar as normas constitucionais, de modo a compatibilizá-las para permitir não apenas a correta e regular apuração dos fatos supostamente delituosos, mas também a formação da *opinio delicti*.

4.1. POLÍCIA FEDERAL

A polícia federal é instituição policial, organizada e mantida pela União.

À PF compete exercer apurar infrações penais contra a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas federais. Ou seja, não se inclui as sociedades de economia mista, razão pela qual o furto contra o banco do Brasil, em regra, é de atribuição da polícia civil.

O ingresso no cargo de Delegado de Polícia Federal, realizado mediante concurso público de provas e títulos, terá a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o cargo privativo de bacharel em Direito e exige 3 anos de atividade jurídica ou policial, comprovados no ato de posse.

A Polícia Federal atua, de forma preventiva e repressiva, no combate a certos delitos, sendo ainda de sua responsabilidade o exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária da União.

À PF também compete prevenir e reprimir infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei.

Compete ainda à PF prevenir e reprimir o tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. O contrabando é a importação de mercadoria proibida, enquanto no descaminho a mercadoria não é proibida, mas o sujeito não recolhe o imposto devido. O STF admite o princípio da insignificância ao descaminho em valores de até 20 mil reais, enquanto o STJ se limite em até 10 mil reais.

A PF poderá ainda exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.

O exercício das funções de polícia judiciária da União será exercido com exclusividade pela Polícia Federal.



Cabe ainda ressaltar que à polícia federal também terá atribuição para atuar nos casos de competência originária do STF e do STJ.

Também compete à polícia federal exercer a atividade de polícia judiciária da Justiça Eleitoral, apesar de que o TSE atribuiu às polícias civis dos Estados atuação supletiva na apuração de crimes eleitorais praticados em locais onde não existam órgãos da polícia federal.

4.2. POLÍCIA CIVIL

As polícias civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira, tendo a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares e ressalvada a competência da União.

O STF entende que essa exceção não obsta a continuação de uma investigação que corre na polícia civil se fica evidenciada a participação de um militar na prática de um crime comum.

Em relação à polícia civil, foi estendido a proibição do direito de greve.

O STF ainda estabeleceu que é inconstitucional foro por prerrogativa de função para delegado de polícia civil. O fundamento é de que quem faz o controle externo da atividade policial é o MP. Sendo consagrado o foro por prerrogativa ao delegado, ficaria inviabilizado esse controle, pois o promotor não iria poder fazer este controle em relação ao delegado.

Da mesma forma, o STF entendeu inconstitucional dispositivo de CE que exija que o Superintendente da Polícia Civil seja um delegado de polícia integrante da classe final da carreira (Inf. 847, STF).

Segundo o STF, Constituição Estadual poderá prever que a Lei Orgânica da Polícia Civil daquele estado tenha status de lei complementar. Não há nada na CF/88 que impeça o constituinte estadual de exigir quórum maior (lei complementar) para tratar sobre essa questão. Segundo entendeu o STF, seria um exagero negar à Constituição estadual a possibilidade de escolher determinados temas como mais sensíveis, exigindo, para eles, uma aprovação legislativa mais qualificada por meio de lei complementar (Inf. 790).

4.3. POLÍCIA MILITAR

Às polícias militares cabem a polícia ostensiva, que é a ideia de preservar a ordem pública, prevenindo a prática do crime.

O STF entendeu que viola a CF a atribuição ao militar de atendimento a delegacia em cidade que não haja delegado. Apesar de ser uma prática comum, o policial militar não pode fazer às vezes do delegado.

4.4. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Incumbe aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de defesa civil.

Todos os órgãos da polícia judiciária estão subordinados ao Poder Executivo respectivo.

No tocante ao DF, há algumas peculiaridades: quem organiza a polícia civil, polícia militar e o corpo de bombeiros é a União, é uma lei federal que irá dispor subordinação da polícia civil, polícia militar e o corpo de bombeiros militar ao governador do DF.

Por conta disso é que existe uma súmula, estabelecendo que compete à União legislar sobre os vencimentos da polícia civil, polícia militar e o corpo de bombeiros militar do DF.

A CF determina que a remuneração dos servidores públicos policiais será através de subsídios, e não de simples vencimentos.



Os órgãos de segurança pública nos Territórios Federais deverão ser instituídos e organizados pela União, eis que a própria Constituição Federal foi silente.

4.5. POLÍCIA PENAL.

Trata-se de um órgão de segurança pública presente na União, nos Estados e no Distrito Federal, que está vinculado ao órgão que administra o sistema penal e é responsável pela segurança dos estabelecimentos penais.

5. INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA

5.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código de Processo Civil (CPC), para vocalização dos interesses da categoria. Com base nessas orientações, o Plenário, por maioria, deu provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que concluiu pela impossibilidade de extensão aos policiais civis da vedação do direito à greve dos policiais militares. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Para ele, a interpretação teleológica dos arts. 9º, 37, VII, e 144 da Constituição Federal (CF) veda a possibilidade do exercício de greve a todas as carreiras policiais previstas no citado art. 144. Não seria necessário, ademais, utilizar de analogia com o art. 142, § 3º, IV, da CF, relativamente à situação dos policiais militares. Esclareceu que a Constituição tratou das carreiras policiais de forma diferenciada ao deixá-las de fora do capítulo específico dos servidores públicos. Segundo o ministro, as carreiras policiais são carreiras de Estado sem paralelo na atividade privada, visto que constituem o braço armado do Estado para a segurança pública, assim como as Forças Armadas são o braço armado para a segurança nacional. Diversamente do que ocorre com a educação e a saúde — que são essenciais para o Estado, mas têm paralelo na iniciativa privada —, não há possibilidade de exercício de segurança pública seja ostensiva pela Polícia Militar, seja de polícia judiciária pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, na União. Em outras palavras, não há possibilidade de nenhum outro órgão da iniciativa privada suprir essa atividade, que, por si só, é importantíssima e, se paralisada, afeta ainda o exercício do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário. Por isso, considerou que a segurança pública, privativa do Estado, deve ser tratada de maneira diferenciada tanto para o bônus quanto para o ônus. Observou, no ponto, que uma pessoa que opta pela carreira policial sabe que ingressa num regime diferenciado, de hierarquia e disciplina, típico dos ramos policiais. É um trabalho diferenciado, por escala, com aposentadoria especial, diverso das demais atividades do serviço público. Os policiais andam armados 24 horas por dia e têm a obrigação legal de intervenção e realização de toda e qualquer prisão em flagrante delito. Devem cuidar ainda da própria segurança e de sua família, porque estão mais sujeitos à vingança da criminalidade organizada do que qualquer outra autoridade pública. Justamente em razão dessas peculiaridades, o ministro registrou a impossibilidade de os policiais participarem desarmados de reuniões, manifestações ou passeatas. Frisou que, ao analisar os anais da Constituinte relativamente ao art. 144 da CF e às carreiras policiais, verificou uma dupla finalidade nas discussões constituintes: a) atender aos reclamos sociais para uma melhor segurança pública, tendo em vista que no Brasil ocorrem cerca de 58 mil mortes violentas por ano, sendo 52 mil homicídios dolosos; e b) reduzir a possibilidade de intervenção das Forças Armadas em



questões internas, a fim de evitar eventuais retornos autoritários à democracia. As carreiras policiais, que representam o braço armado do Estado, são responsáveis por garantir a segurança pública e a democracia. Portanto, não se pode permitir que realizem greve. Entretanto, segundo o ministro, tem-se verificado a necessidade, cada vez maior, da garantia de lei e ordem, ou seja, de utilização das Forças Armadas em defesa da segurança pública, situação que a Constituição buscou evitar com o equacionamento e com a colocação de carreiras policiais como carreiras de Estado permanentes ao exercício democrático. Ponderou não se tratar, no caso, de um conflito entre o direito de greve e o princípio da continuidade do serviço público ou da prestação de serviço público. Há um embate entre o direito de greve, de um lado, e o direito de toda a sociedade à garantia da segurança pública, à garantia da ordem pública e da paz social, de outro. Quanto a esse aspecto das carreiras policiais, deve ser valorada, no atual conflito, de forma muito mais intensa, a questão da segurança pública, da ordem pública e da paz social. Afinal, eventuais movimentos grevistas de carreiras policiais podem levar à ruptura da segurança pública, o que é tão grave a ponto de permitir a decretação do estado de defesa (CF, art. 136) e, se o estado de defesa, em noventa dias, não responder ao anseio necessário à manutenção e à reintegração da ordem, a decretação do estado de sítio (CF, art. 137, I). Portanto, a prevalência do interesse público e do interesse social na manutenção da ordem pública, da segurança pública, da paz social sobre o interesse de determinadas categorias de servidores públicos — o gênero servidores públicos; a espécie carreiras policiais — deve excluir a possibilidade do exercício do direito de greve por parte das carreiras policiais, dada a sua incompatibilidade com a interpretação teleológica do texto constitucional, em especial dos arts. 9º, § 1º; e 37, VII da CF. Ademais, para o ministro, é viável conciliar as previsões constitucionais sem aniquilar o direito de greve dos servidores públicos. Frisou que a CF prevê a possibilidade de greve do gênero servidores públicos. E, mesmo assim, a lei pode estabelecer restrições e limites, sejam parciais ou, para determinadas carreiras que são espécies dos servidores públicos, totais. Não se está, dessa forma, a aniquilar o direito de greve dos servidores públicos, mas a afirmar que, dentro dessa razoabilidade que a própria Constituição trouxe, não é possível o exercício do direito de greve por determinadas carreiras, como as policiais. Concluiu que, apesar de se referir à greve “lato sensu” da atividade privada, o art. 9º da CF aplica-se também na interpretação do art. 37, VII, da CF. A manutenção da segurança pública e a defesa da vida, da incolumidade física, do patrimônio de toda a sociedade, da atividade de polícia judiciária, a alavancar a atividade do Ministério Público e da própria Justiça criminal, são, “prima facie”, necessidades inadiáveis da comunidade (CF, art. 9º, § 1º). Da mesma forma, o art. 37, VII, da CF prevê termos e limites ao exercício de greve. Ao compatibilizar o art. 144 da CF às razões já ditas, para colocação de um artigo específico para carreiras policiais — como braço armado do Estado —, percebe-se que a própria Constituição já traz, quanto às carreiras policiais, a relatividade do exercício do direito de greve dos servidores públicos. A CF garante o direito de greve ao gênero servidores públicos, com limites e nos termos que a lei estabelecer, e, em relação à espécie carreiras policiais, não possibilita esse exercício, sob pena de total desrespeito ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. O ministro Roberto Barroso acrescentou que, apesar de os policiais civis não poderem exercer o direito de greve, é indispensável que essa categoria — que, no interesse público, sofre a restrição de um direito fundamental — possa vocalizar as suas reivindicações de alguma forma. De “lege ferenda”, afirmou ser perfeitamente possível que, ao mesmo passo em que se veda o direito de greve a policiais civis, seja estabelecida uma vinculação a outra categoria para que eles se beneficiem de reivindicações de categorias afins, que não sejam, entretanto, nem de segurança pública nem portem armas. De “lege lata”, à luz do direito vigente neste momento, reputou que a alternativa está contida no art. 165 do CPC. Vencidos os ministros Edson Fachin (relator), Rosa Weber e Marco Aurélio,



que negavam provimento ao recurso. ARE 654432/GO, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 5.4.2017. (ARE-654432)

Questões

1) (TJ PA-2019) — No que se refere ao estado de defesa e ao estado de sítio, julgue os itens a seguir.

I O Senado Federal pode suspender o estado de defesa, mas não pode suspender o estado de sítio.

II O estado de defesa, decretado pelo presidente da República, deve ser aprovado pelo Congresso Nacional.

III O presidente da República deve solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está certo.
- b) Apenas o item II está certo.
- c) Apenas os itens I e III estão certos.
- d) Apenas os itens II e III estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

2) (MPE MG-2019) — Assinale a opção correta, segundo a Constituição de 1988:

a) O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa.

b) O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, sem autorização do Congresso Nacional, decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa.

c) O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de sítio nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.

d) O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, sem autorização do Congresso Nacional, decretar o estado de sítio nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.

Comentários

1) Gabarito: letra D. Consoante art. 84, IX e do art. 49, IV da CF/88 e art. 137 parágrafo único da CF/88.

I - Incorreta, visto que essas competências são exclusivas do Congresso Nacional:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

...

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.

II - Correta, em face do previsto no art. 84, IX e do art. 49, IV da CF/1988.

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:



...

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio.

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

...

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.

III - Correta, em face do art. 137 e seu parágrafo único da CF/1988.

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:

...

Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta.

2) Gabarito: letra A. De acordo com o art. 137 da CF/88. A questão aborda o estado de sítio que é instaurado como uma medida provisória de proteção do Estado, quando este está sob uma determinada ameaça, como uma guerra ou uma calamidade pública, podendo ser utilizado também em caso de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa.

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:

I – comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;

II – declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.

Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta.



CAPÍTULO 21 – FINANÇAS PÚBLICAS

A CF dedica um capítulo às finanças públicas, dispondo que lei complementar disporá sobre matéria financeira.

A competência para emitir moeda é da União. Todavia, a União emite moeda exclusivamente através do Banco Central.

Lembre-se que é vedado ao Banco Central conceder empréstimo ao Tesouro Nacional, ou a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Portanto, o Banco Central pode conceder empréstimo às instituições financeiras.

Por outro lado, o Banco Central pode comprar e vender títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. A ideia é permitir a atuação do Banco Central, de forma que haja a regulação da moeda e da taxa de juros.

No entanto, as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central.

Já as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei de forma diversa, ou seja, podendo ser depositado em instituição privada.

1. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAIS ORÇAMENTÁRIOS

É necessário alguns princípios para entender o orçamento:

- princípio da anualidade: o orçamento deve ser elaborado para 1 exercício financeiro. Não necessariamente coincide com o calendário. No caso do Brasil, atualmente, coincide, mas não necessariamente coincidirá.
- princípio da universalidade: o orçamento tem que ter todas as receitas e despesas do ente público, inclusive dos fundos e das administrações direta e indireta.
- princípio da unidade: diz que o orçamento é um só para cada ente federado e para cada exercício financeiro. Não confunda este princípio da unidade com a unidade documental, eis que é possível ter diversos documentos orçamentários, como o orçamento fiscal, orçamento de investimento, orçamento de seguridade social etc., pois o orçamento é único.
- princípio da exclusividade: lei orçamentária não pode conter matéria estranha a essa previsão de receita e fixação de despesas. O art. 165, §8º, estabelece que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.
- princípio da especificação: é necessário especificar como serão auferidas as receitas, bem como onde haverá despesas, a fim de permitir a transparência e controle.
- princípio da não afetação: o art. 167, IV, proíbe que haja a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Isso porque os impostos têm natureza não vinculada. No entanto, a própria Constituição traz exceções taxativas, em que poderá haver vinculação nos casos de:
 - a) repartição do produto da arrecadação dos impostos;
 - b) destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para o ensino e para administração tributária
 - c) prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita;



2. LEIS ORÇAMENTÁRIAS

A CF prevê 3 leis orçamentárias: Plano plurianual, Lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e Lei de orçamento anual (LOA)

São leis ordinárias e são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

2.1. PLANO PLURIANUAL

Em relação ao PPA, haverá um plano de duração superior a 1 ano.

A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e para as relativas aos programas de duração continuada.

A duração continuada é aquela superior a 1 ano.

Perceba que o PPA, que tem prazo de 4 anos, orienta as diretrizes e metas da administração.

O PPA é um plano de governo.

O PPA é elaborado durante o 1º ano do mandato do Chefe do Poder Executivo, entrando em vigor somente no 2º ano de mandato. Isto quer dizer que o próximo presidente da República iniciará o mandato obedecendo ao plano firmado pelo governo anterior.

Isto visa a continuidade dos ganhos sociais.

A partir do que ficar definido no PPA é que vem a LDO e a LOA.

Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado se não estiver incluído no PPA, pois passaria a ter um caráter continuado, motivo pelo qual deve observar as diretrizes estabelecidas no PPA.

Atente-se que haverá crime de responsabilidade se for autorizado determinado investimento que ultrapasse um exercício financeiro sem que tenha sido incluído do PPA.

3. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

A LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal.

Nestas diretrizes inclui as despesas de capital para o exercício financeiro seguinte. Então, é por 1 ano só. A LDO vem especificar aquilo que está previsto no PPA. A LDO busca orientar a elaboração da lei orçamentária anual LOA.

A LDO ainda irá dispor sobre as alterações na legislação tributária e vai estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

Isso tem muito a ver com as diretrizes da lei orçamentária anual.

Ainda há um importante papel da LDO, no tocante ao aumento de despesas de pessoal. Isso porque o aumento de remuneração, a criação de cargos e a admissão de pessoal só podem acontecer se estiverem previstas ou autorizadas na LDO.

4. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

A LOA engloba 3 orçamentos: orçamento fiscal, orçamento de investimento: é o orçamento das empresas em que a União atua, ou em que detém o capital votante e orçamento da seguridade social

O orçamento fiscal e de investimento (não inclui o orçamento da seguridade social) tem como função reduzir desigualdades inter-regionais, isto significa que se trata de um objetivo fundamental da República.

5. PROCESSO LEGISLATIVO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS

As leis orçamentárias são leis ordinárias.

A iniciativa é do Presidente da República. Ao chegar o projeto do CN, haverá uma comissão mista de deputados e senadores. Essa comissão é permanente.

Cabe a esta comissão mista examinar e emitir um parecer sobre o projeto de lei orçamentária (PPA, LDO ou LOA).



É possível que estes projetos sofram emendas, devendo ser apresentada na comissão mista, a qual irá emitir um parecer sobre essas emendas apresentadas.

Após o parecer, essas emendas serão apreciadas pelas duas casas do Congresso Nacional em sessão conjunta. Isto significa dizer que serão computados os votos da maioria simples dos senadores e simples dos deputados federais, pois a lei é ordinária.

6. EMENDAS AOS PROJETOS DE LEIS ORÇAMENTÁRIAS

É possível que haja emenda das leis orçamentária.

Mas no tocante à lei orçamentária anual, a CF estabelece algumas peculiaridades. Segundo o art. 166, §3º, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual (LOA) ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; indiquem os recursos necessários, os quais devem ser provenientes de anulação de despesa.

Ainda, é possível que haja emenda ao projeto de lei orçamentária para correção de erros e aspectos formais.

Não é toda despesas indicada pelo Presidente da República que poderá ser anulada. Isto é, não poderá ser excluídas despesas que incidam sobre: dotações para pessoal e seus encargos; serviço da dívida; transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal.

7. ORÇAMENTO IMPOSITIVO

Orçamento impositivo é o orçamento que deve ser cumprido.

Sempre existiu uma controvérsia se a LOA teria um caráter impositivo, ou se as despesas deveriam ser executadas, ou ainda se apenas seriam autorizadas a sua execução.

Isto quer dizer que se o gestor deixa de executar uma despesa discricionária, ele não é sancionada, pois não haveria ilícito. Isso porque o orçamento é meramente autorizativo. Todavia, os deputados aprovaram a EC 86/15.

Com a EC 86/15 houve o acréscimo dos §§9º ao 18 ao art. 166 da CF.

Basicamente, a EC tornou impositivo e obrigatório que se execute as programações orçamentárias resultante de emendas parlamentares individuais.

Perceba que o orçamento em regra é autorizativo, mas se houver uma emenda parlamentar individual, esta programação tem caráter obrigatório e impositivo, devendo ser executada.

Existe um limite para apresentação de emendas, que será de 1,2% da receita corrente líquida que se espera para o ano seguinte, ou seja, prevista no projeto de lei orçamentária.

A CF estabelece um duplo teto, dizendo que a emenda parlamentar será de no máximo 1,2% da receita corrente líquida, baseada naquilo que o presidente da república mandou. No entanto, só é obrigatório o valor até 1,2% da receita corrente líquida do orçamento anterior.

Ainda, metade do valor das emendas parlamentares individuais devem ser destinadas a ações e serviços públicos de saúde.

Ou seja, primeiro há um teto de 1,2%. Após, desse valor, 0,6% será destinado a ações e serviços públicos de saúde. Se o executivo se nega a cumprir, o teto será com base no orçamento anterior.

Enquanto o limite para apresentação de emendas individuais leva em conta o limite previsto na lei orçamentária anual para o exercício subsequente, o limite para aplicar esse regime impositivo de execução dessas mesmas emendas individuais é definido levando-se em conta a receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

O regime impositivo de execução das emendas parlamentares poderá ser excepcionalmente afastado, desde que esteja previsto em situações previstas na própria CF:



- houver contingenciamento de despesas: neste caso, o montante a ser reduzido das emendas individuais poderá ser reduzido até o máximo que sofrerá proporcionalmente à limitação incidente sobre o incidente de despesas discricionárias. Ex.: se o Poder Executivo reduzir as despesas discricionárias em 20%, a emenda parlamentar individual poderá sofrer restrição de 5%, 10%, 15% ou até 20%, no máximo.
- em que haja impedimento de ordem técnica na execução: são os seguintes casos:
 - a) falta de razoabilidade do valor proposto: por exemplo, o parlamentar pediu 20 milhões para construir uma creche para 20 crianças.
 - b) desistência da proposta pelo proponente: o parlamentar desiste.

Nesse caso, começa a ter inviabilidade de ordem técnica, normalmente em razão da “burrice” do parlamentar.

8. CRÉDITOS ADICIONAIS

Na verdade, os créditos adicionais podem ter 3 espécies:

- crédito suplementar: visa suplementar ou dar um reforço à dotação orçamentária. Ou seja, o quantitativo autorizado era insuficiente, devendo haver um reforço.
- crédito especial: não houve dotação orçamentária, mas é necessário fazer a despesa que não está prevista no orçamento.
- crédito extraordinário: a situação aqui é de excepcionalidade. É o desespero! Este crédito serve para despesas imprevisíveis e urgente, como aquelas decorrente de guerra, comoção interna e calamidade pública.

Os créditos suplementar e especial devem ser autorizadas por lei, e depois de autorizadas por lei devem sofrer um decreto executivo. Esta autorização legal é necessária ainda que tenha recursos disponíveis.

No crédito extraordinário não é autorizado por lei, sendo deliberado por medida provisória.

As situações que autorizam o crédito extraordinário tem hipóteses exemplificativas.

E se for no âmbito estadual, será por medida provisória. Caso não haja a disposição de medida provisória, a abertura de crédito extraordinário será feita por decreto executivo.

Em razão desse caráter personalíssimo a abertura de crédito extraordinário não exige a disponibilidade de recursos, tirando de onde não tem e coloca-se onde precisa.

Os créditos especiais e extraordinários tem vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. A exceção é de que se eles forem autorizados nos últimos 4 meses do exercício financeiro, hipótese em que serão abertos no exercício financeiro seguinte, com o restante que não foi executado. Ou seja, o limite de saldo não executado serão incorporados ao exercício financeiro seguinte.

Essa possibilidade só alcança créditos especiais e extraordinários, não alcançando créditos suplementares.

Por fim, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, quando forem destinados aos órgãos do Poder Legislativo, Poder Judiciário, e ao MP e à DP, são entregues a eles, até o dia 20 de cada mês um duodécimo.

9. LIMITES PARA DESPESA COM PESSOAL

A despesa com pessoal ativo e inativo não podem extrapolar limites estabelecidos em lei complementar.

A LC fixa o limite, dando um prazo para que as unidades federativas façam as adaptações trazidas pela lei. Se passar o prazo, e não serem realizadas essas adaptações, serão



suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos estados ou municípios que não observarem esses limites.

Para cumprir esses limites, deverão ser, se houver a necessidade, adotadas as seguintes providências: redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e funções de confiança; exoneração dos servidores não estáveis; exoneração dos servidores estáveis.

Nessa situação, o servidor estável fará jus a uma indenização correspondente a um mês de remuneração para um ano de serviço.

E o cargo que for extinto, não poderá ser criado com as mesmas atribuições pelo prazo de 4 anos, vedando-se a fraude.

Questões

1) (TJ PA-2019) — Conforme as normas constitucionais a respeito do orçamento público, é possível

- a) o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, desde que previstos no plano plurianual.
- b) a concessão de empréstimos pela União a estados e municípios e ao Distrito Federal para o pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, se feitos por antecipação de receita.
- c) a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários, desde que autorizadas em lei.
- d) a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, se autorizadas mediante créditos suplementares com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo.
- e) a abertura de crédito especial sem prévia autorização legislativa, desde que para atender a despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de calamidade pública.

2) (Procurador do Município/São José do Rio Preto-2019) — Em relação aos princípios constitucionais do orçamento, aquele que estabelece que a receita não possa ter vinculações que reduzem o grau de liberdade do gestor e engessa o planejamento de médio, curto e longo prazos, e que se aplicam somente às receitas de impostos, denomina-se princípio

- a) do orçamento bruto.
- b) da não afetação das receitas.
- c) do equilíbrio.
- d) da objetividade.
- e) da exatidão.

Comentários

1) Gabarito: letra D, pois é umas das vedações trazidas pelo inciso III do art. 167 da CF/1988, a chamada regra de ouro orçamentária.

a) Incorreta, pois o inciso I do art. 167 da CF/1988 não traz essa ressalva.

Art. 167. São vedados:

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual.

b) Incorreta, visto que essa é uma vedação trazida pelo inciso X do art. 167 da CF/1988.

Art. 167. São vedados:



...

X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

c) Incorreta, nos termos do inciso II do art. 167 da CF/1988.

Art. 167. São vedados:

...

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.

e) Incorreta, nos termos do inciso V do art. 167 da CF/1988, que não traz essa ressalva. As despesas imprevisíveis e urgentes são cobertas por meio de créditos extraordinários (art. 167, § 3º, CF):

Art. 167. São vedados:

...

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.

....

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.

2) Gabarito: letra B. Além de serem tributos não vinculados, os impostos são tributos de arrecadação não vinculada. Aliás, como regra, a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa é proibida diretamente pela Constituição Federal (inc. IV do art. 167 – princípio da não afetação ou vinculação):

Art. 167, IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;

Isso quer dizer que sua receita se presta ao financiamento das atividades gerais do Estado, remunerando os serviços universais (prestados “uti universi”) que, por não gozarem de referibilidade (especificidade e divisibilidade) não podem ser custeados por intermédio de taxas.

a) As receitas e despesas devem constar no orçamento pelos seus valores globais, sem quaisquer deduções. Art. 6º, Lei nº 4.320/64.

c) A lei orçamentária anual deve assegurar que o valor da despesa fixada não seja superior ao valor da receita prevista. (Lei de responsabilidade fiscal Art. 4, I, alínea “a” e art. 9º)



- d) O orçamento público deve ser apresentado em linguagem clara e objetiva.
- e) De acordo com esse princípio as estimativas devem ser tão exatas quanto possível, de forma a garantir à peça orçamentária um mínimo de consistência para que possa ser empregado como instrumento de programação, gerência e controle.



CAPÍTULO 22 – ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

Superou-se um sistema liberal, pois se mostrou insuficiente, em razão de não ter atendido às necessidades do mundo contemporâneo. Isto redundou num estado social, devendo-se assegurar igualdade material.

No estado social democrático, há uma necessária atuação do Estado no setor econômico. Isto é inquestionável.

Mesmo quem defende o estado mínimo entende que deverá o estado atuar fomentando certas atividades.

A ideologia do bem-estar social faz o casamento entre a liberdade e igualdade.

A CF brasileira é tipicamente dirigente. Isto significa que estabelece os fins que deverá ser perseguido pelo estado, trazendo normas programáticas

O estado brasileiro é um estado social democrático. E por isso, há formas do estado atuar na área econômica.

Meios de atuação do Estado na área econômica:

O Estado pode assumir duas formas de atuação na área econômica:

- atuação direta: o Estado exerce a função de agente econômico. É o estado empresário. Isso poderá ocorrer por meio de:
 - a) **monopólio:** Estado absorve a prestação do serviço ou o fornecimento de bens;
 - b) **participação:** Estado funciona concorrendo com os demais agente econômicos. Ex.: banco público.
- atuação indireta: o Estado fomenta ou desestimula determinadas práticas. Poderá ocorrer de várias formas:
 - a) **indução:** quer dizer que o Estado vai direcionar como o agente econômico vai atuar, incentivando determinadas atividades e desestimulando outras. Com o fomento, por exemplo, por meio de benefício fiscal, financiamento de atividades, etc. Esta é a indução positiva. A indução negativa ocorre quando o Estado leva a imposição de tributos elevados a determinadas atividades. Ex.: tributação sobre cigarros.
 - b) **fiscalização:** o Estado atua de forma indireta quando fiscaliza as atividades da iniciativa privada. É o exercício do poder de polícia, aplicando sanções, restringindo certas atividades, etc.
 - c) **planejamento:** o Estado identifica necessidades no presente e no futuro, demandando programas a longo prazo. Com base nisso, é feito o plano para orientar a atuação do agente econômico. Ex.: o Brasil quer ser uma potência tecnológica, deverá fomentar a área.

Ordem econômica e financeira da Constituição de 1988:

A CF de 1988 trata da ordem econômica e financeira, dividindo-se em 4 capítulos: princípios gerais da atividade econômica, políticas pública, política agrícola e da atividade fundiária e sistema financeiro nacional.



1. FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

O primeiro dos fundamentos da ordem econômica é a valorização do trabalho humano e na livre iniciativa.

É o casamento do capital com o trabalho. A ideia é assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social.

2. PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ORDEM ECONÔMICA

São princípios básicos da ordem econômica:

- soberania nacional: a política econômica do país é de interesse dos cidadãos. Isso significa que deverá a política econômica atender ao máximo as necessidades dessa população.
- propriedade privada: quando consagrada, a propriedade privada terá tipicamente e constitucionalmente que o estado é capitalista. Essa propriedade privada deverá atender a sua função social, pois somente será o país rico quando for atendida essa função social.
- função social da propriedade;
- livre concorrência: a ideia de livre concorrência exige que a ordem econômica assista a todos uma existência digna. Se não for observada a concorrência, então haverá um abuso do poder econômico de determinados grupos, eliminando a concorrência, o que gerará um aumento arbitrário dos lucros, devendo ser reprimido na forma da lei. A livre concorrência permite a existência digna, sob pena de haver massacres da concorrência. O Estado atua não somente com medidas sancionatória, como também por meio preventivo, a fim de impedir esses abusos, pela fiscalização ou regulatória. Ex.: CADE. O Judiciário também poderá ser provocado para tratar de abusos, tanto é que o STF editou a súmula vinculante n. 49, que estabelece que ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.
- defesa do consumidor: a ideia é que se não houver a defesa do consumidor, que é vulnerável, haverá abuso, dificultando o mínimo para o mínimo vital. A defesa do consumidor também tem caráter de direito fundamental.
- defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação: **isto quer dizer que a economia deverá respeitar o meio ambiente, pois, do contrário, não será essa atividade econômica legítima. A ideia é promover o desenvolvimento sustentável.**
- redução das desigualdades regionais e sociais: é o objetivo fundamental da República.
- busca do pleno emprego: é uma das formas de alcançar a redução das desigualdades regionais e sociais.
- tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
- liberdade de exercício de atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos: o art. 170, p.ú., traz o princípio da livre iniciativa. O Estado não pode interferir, pois a regra é a autonomia privada.
- atuação do Estado como agente econômico em sentido estrito: permite que o estado atue como empresário (forma direta) ou fomentando e fiscalizando atividades (forma indireta).



Atuação do Estado como agente econômico em sentido estrito:

Segundo o art. 173, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei (norma de eficácia limitada).

Veja, a Constituição consagra o princípio da subsidiariedade, pois somente em último caso o Estado será empresário.

A atuação direta do Estado se dá, em regra, por pessoas jurídicas que ele constitui com essa finalidade: empresas públicas (capital todo público) e sociedades de economia mista (capital misto, mas a maioria do capital votante é público).

Ou seja, o Estado só atua na economia quando houver: necessária aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo

O §1º diz que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Esta lei veio em 2016, por meio da Lei 13.303/16.

Esse estatuto jurídico irá dispor sobre a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Esta afirmação deverá ser ponderada, devendo ser lida a partir de uma interpretação sistemática.

As empresas públicas e sociedade de economia mista, quando exploradoras de atividades econômicas, não têm responsabilidade civil objetiva, ou seja, será subjetiva, salvo no caso de defesa do consumidor.

Ademais, empresas públicas e sociedade de economia mista não são alcançadas pelo art. 37, §6º, não tendo responsabilidade civil objetiva, salvo se forem prestadoras de serviço público.

As empresas públicas e sociedade de economia mista são obrigadas a licitar, mas é necessário ponderar entre a atividade fim e a atividade meio. Os contratos relativos às atividades fins não estarão sujeitos ao processo licitatório, pois isto estaria incompatível com a atividade econômica. Mas com relação às atividades-meio, haverá a incidência do processo licitatório.

Como se sabe, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Isso porque haveria uma violação da livre concorrência.

Essa vedação comporta duas observações:

- essa vedação que se aplica apenas à sociedade de economia mista e empresas públicas que sejam exploradoras de atividade econômica. Mas se for uma prestadora de serviços público será possível.
- essa vedação também não se aplica às empresas públicas e as sociedades de economia mista que funcionem em regime de monopólio.

Atuação do Estado como prestador de serviços públicos:

Segundo o art. 175, incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Quem presta serviço público é o Poder público, podendo se dar diretamente, ou indiretamente. Neste último caso, prestará por meio de concessão ou de permissão. Em ambos os casos, é necessário que se dê através de licitação.

A titularidade desse serviço será do poder público, podendo ser exercido pelo particular, seja a delegação por concessão ou por permissão.



No Brasil, adota-se a concepção formal de serviço público. Isto quer dizer que serviço público é qualquer prestação concreta que é desempenhada sob regime de direito público por opção do ordenamento jurídico. Serviço público é aquilo que a lei diz que é.

É uma prestação material concreta (fruível), sujeita ao regime jurídico de direito público. Esta é a característica distintiva. Se o serviço é prestado sob regime de direito público, será serviço público.

Existem atividades que devem ser prestadas pelo poder público, mas também são autorizadas que sejam prestadas pela iniciativa privada. Neste caso, quando o particular exerce essa atividade não se submeterá ao regime de direito público, tampouco atuará sob o regime de delegação.

Exemplo disso são as escolas e hospitais, os quais são serviços públicos de ensino e de saúde, respectivamente. Perceba que tais atividades terão duas diferenças.

- inexistência de finalidade lucrativa: sendo serviço público, e explorado pelo Estado, não poderá haver intenção de lucro para as atividades de ensino e saúde. O particular poderá ter essa finalidade.
- inexistência de delegação: a iniciativa privada poderá atuar livremente, mas será fiscalizada pelo poder público. Não são delegatários.

Atuação do Estado como agente econômico em regime de monopólio:

Monopólio é a atividade exercida por uma única pessoa. A CF/88 tem como regra a livre iniciativa, sendo monopólio aquilo que ela quer que o seja.

A lista de atividades em monopólio é *numerus clausus*, ou seja, taxativas. Todas essas hipóteses são de monopólio público, pois não existe monopólio privado. Também não existe monopólio do Estado, Distrito Federal ou Município. Todo monopólio é da União.

Se não for uma destas hipóteses, não será monopólio. Essas atividades poderão ter serviços contratados pela União por empresas. Isto é, se a União quiser, poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades de monopólios.

Em relação às atividades nucleares, o Brasil adota a teoria do risco integral. Isto significa que, havendo dano nuclear, a responsabilidade será objetiva, sem admitir excludentes.

Atuação do Estado como agente regulador

A CF no art. 174 diz que como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de:

- fiscalização: se dará pelo poder de polícia. Ex.: fiscalização do supermercado.
- incentivo: é subsidiar, financiar, fomenta a iniciativa privada. São medidas de indução positivas. Ex.: Zona Franca de Manaus.
- planejamento: o Estado adota planos econômicos, que serão de observância obrigatória ao setor público, mas será indicativo para o setor privado.

Como se vê, não há uma atuação do Estado diretamente, e sim indireta.

É instrumento de atuação de forma indireta as leis orçamentárias, como o PPA, LDO e LOA. Isso porque o PPA traz as metas, mas a LDO traz as diretrizes, mas a LOA efetiva.

Exploração de recursos minerais e potenciais de energia hidráulica:

O art. 20 da CF, nos incisos VIII e IX, vai dizer que são bens da União os potenciais de energia hidráulica e os recursos minerais, inclusive os do subsolo.

A CF estabelece que tais bens são de propriedade distinta da do solo, mas se houver um mineral, este não será do sujeito, e sim da União.

Esses potenciais de energia hidráulica, recursos minerais, inclusive do subsolo, poderão ser explorados pelo particular, mediante autorização ou concessão do poder público. Nesse caso, é garantido para quem explora a propriedade o produto da lavra. Ou seja, a União



vai ganhar o que for pago por esta concessão. O proprietário do solo terá direito de participação no resultado da lavra.

O art. 176 estabelece no §4º que não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. Ou seja, o aproveitamento caseiro não será necessário.

Os §3 e §4 estabelecem que a atividade garimpeira em cooperativas deverá receber tratamento favorecido pelo Estado. A ideia fomenta atividades por meio de cooperativa. Neste caso, as cooperativas têm prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra de recursos e minerais garimpáveis.

3. POLÍTICA URBANA

A competência legislativa para tratar de direito urbanístico é concorrente entre a União, Estados e DF.

Como os municípios possuem a competência para tratar de assuntos de interesse local, e a CF, no art. 182, dá a competência de executar a política de desenvolvimento urbano, o município também tratará de direito urbanístico por meio da lei que institui o Plano Diretor, o qual é obrigatório para município que possuem mais de 20.000 habitantes.

O art. 182 estabelece que o Poder Público municipal tem competência para executar a política de desenvolvimento urbano. Todavia, quem formula a política de desenvolvimento urbano, que tem caráter geral, é a União, por meio do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/08).

O instrumento básico da política de desenvolvimento urbano é o Plano Diretor.

O Plano Diretor é uma lei municipal. Segundo a CF, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências expressas no plano diretor.

O plano diretor é instrumento à concretização da função social da propriedade, podendo ele inclusive justificar hipóteses de desapropriação da propriedade privada, devendo haver indenização prévia, justa e em dinheiro, desde que se dê por interesse público.

Todavia, se o sujeito não observa o Plano Diretor, ou seja, não está cumprindo a função social da propriedade, este sujeito poderá sofrer a desapropriação-sanção, sendo indenizado por títulos da dívida pública, e não em dinheiro.

O §4º do art. 182 diz que o é facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, ou seja, promova o cumprimento da função social da propriedade. Veja, não se pode ter imóveis para fins de especulação, pois a propriedade privada não estaria cumprindo a sua função social.

Caso não a promova o atendimento de aproveitamento do solo, haverá sanções sucessivas: parcelamento ou edificação compulsórios, IPTU progressivo no tempo, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública: estes títulos deverão ser de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal (e não Câmara!), com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

O art. 183 estabelece uma hipótese de usucapião urbano. Para esta espécie, é necessário que o possuidor cumpra os seguintes requisitos: área urbana de até 250m², 5 anos ininterruptos e sem oposição, utilização para fins de moradia ou de sua família, não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural

Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

Ademais, os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Segundo o STF, é possível a usucapião de domínio útil de bem público.



4. POLÍTICA AGRÁRIA

4.1. REFORMA AGRÁRIA

O art. 184 diz que compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Neste caso, a indenização será prévia e justa, porém se dará em títulos da dívida agrária, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão.

Veja que a desapropriação qualquer ente poderá fazer, mas desapropriação para fins de reforma agrária só a União poderá fazer.

A competência para legislar sobre qualquer modalidade de desapropriação é apenas da União. Todavia, a competência para executar todos os entes têm.

A propriedade rural cumprirá a sua função quando obedecer aos requisitos previsto no art. 186 da CF.

A CF estabelece que, mesmo que seja para fins de reforma agrária, as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.

O imóvel desapropriado para fins de reforma agrária será dado ao beneficiário. Esses beneficiários receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, não negociáveis pelo prazo de 10 anos.

4.2. POLÍTICA AGRÍCOLA

Em relação à política agrícola, deverá esta estar ligada à política de reforma agrícola.

A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes.

A eletrificação e habitação serve para trazer a qualidade de vida do trabalhador rural.

Cabe atentar que se incluem no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais.

A CF ainda diz que a destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária.

Com relação às terras públicas, estas poderão ser alienadas. Todavia, se a alienação ou a concessão de terras públicas for de área superior a 2.500 hectares dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional.

Isto significa que se tiver mais de 2.500 hectares não poderá o poder público simplesmente vender, sendo indispensável autorização do CN. No entanto, haverá uma única exceção, caso essa concessão superior a 2.500 hectares for para fins de reforma agrária.

A CF consagra no art. 191 o denominado usucapião pró-labore para o possuidor.

5. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado por leis complementares, inclusive sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.

Cabe ressaltar que as cooperativas de créditos integram o sistema financeiro nacional.

A CF diz que leis complementares irão tratar do sistema financeiro nacional. Todavia, o Código de Defesa do Consumidor é lei ordinária.

O CDC se aplica para o usuário, nos casos de atividades entre instituições financeiras e consumidores?



Segundo o STF, sim. Na relação do consumidor com o banco não se coloca em xeque o a relação do sistema financeiro nacional, pois haveria aqui uma relação entre vulnerável e o fornecedor. As instituições financeiras nas relações com usuários se submetem ao CDC.

Questões

1) (PGE/PE-2018) — Acerca da ordem econômica e financeira nacional, assinale a opção correta.

- a) Com a aplicação do princípio da soberania nacional à atividade econômica, visa-se evitar a influência descontrolada de outros países na economia brasileira.
- b) É inconstitucional o tratamento jurídico favorecido para empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras, em razão de ter sede e administração no país, por afronta ao princípio da igualdade.
- c) Exige-se a autorização do órgão público competente para o trabalho e o exercício de qualquer atividade econômica.
- d) A defesa do consumidor é um direito fundamental individual, não se enquadrando, por isso, como princípio da atividade econômica.
- e) A exploração direta de atividade econômica pelo Estado é permitida irrestritamente, se respeitado o princípio da livre concorrência.

2) (PGE/SP-2018) — A exploração direta de atividade econômica pelo Estado, nos limites delineados pela Constituição da República,

- a) não autoriza a atuação em regime de competição concorrencial com agentes privados, mas apenas em caráter subsidiário, quando verificadas falhas de mercado, de molde a corrigi-las ou mitigá-las.
- b) sujeita-se às disposições da legislação antitruste relativas à prevenção e à repressão às infrações contra a ordem econômica, mesmo quando exercida em regime de monopólio legal.
- c) atende a imperativos da segurança nacional ou relevante interesse público, ensejando, assim, regime tributário essencialmente diverso do que se aplica aos agentes privados que atuem no mesmo mercado competitivo.
- d) não se submete ao controle instituído pela legislação antitruste, eis que tal controle é voltado exclusivamente a agentes privados que explorem atividade econômica sujeita à livre iniciativa.
- e) sujeita-se apenas ao controle setorial, próprio das agências reguladoras, de forma simétrica ao aplicável aos agentes privados, somente incidindo a legislação antitruste quando atue em regime de monopólio legal ou natural.

Comentários

1) Gabarito: letra A. Art. 170, I, da Constituição Federal e seus consectários ainda presentes nos artigos 172. Em um mundo onde o capital é transnacional e seu trânsito instantâneo, esse dispositivo constitucional tornou-se pitoresco, sendo praticamente inexistente em constituições ocidentais modernas. Entretanto, considere-a como tal, para efeitos da prova, com base no art. 170, I, da Constituição Federal e seus consectários ainda presentes nos artigos 172, :

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;



Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.

Demais alternativas incorretas:

b) Errado. A proteção ao mercado interno foi mitigada mas não eliminada pela Emenda Constitucional 6/1995, que instituiu o princípio presente no inciso IX, do art. 170 da Constituição Federal:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

c) Errado, nos termos do art. 170, parágrafo único, da CF:

Art. 170.....

.....

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

d) Errado. É também, além de um direito fundamental individual (art. 5º, XXXII, CF), um princípio de atividade econômica (art. 170, V, CF):

Art. 5º.....

.....

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

Art. 170.....

.....

V - defesa do consumidor;

e) Errado, pois é permitida apenas nas hipóteses do art. 173, quais sejam o relevante interesse coletivo e o imperativo de segurança nacional (RIC ISN):

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

2) Gabarito: letra B. Possui matriz constitucional a existência de normas regulamentadoras da autonomia privada no domínio econômico (arts 173), como, por exemplo, a Lei Antitruste 8.884/94 que dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e que se aplica às empresas estatais exploradoras de atividade econômica; também a Lei nº



8.176/1991, que dispõe sobre os crimes contra a ordem econômica o Código de Defesa do Consumidor, além das leis que criam as Agências Reguladoras, que objetivam regular e fiscalizar determinados segmentos da economia, com vistas a fazer cumprir os princípios constitucionais da atividade econômica.

a) Errado. O princípio constitucional da livre concorrência aplica-se a todos os agentes econômicos, inclusive públicos (art. 170, IV, e art. 173, II e § 2º, da CF):

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

.....

IV - livre concorrência;

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

.....

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

.....

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

c) Errado, nos termos do art. 173, § 2º, da Constituição:

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

.....

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

d) Errado, conforme apontamentos ao item "b".

e) Errado, também conforme apontamentos ao item "b".



CAPÍTULO 23 – ORDEM SOCIAL

O título da ordem social declara que: possui como base o trabalho e como objetivo o bem-estar social e a justiça social.

1. SEGURIDADE SOCIAL

A seguridade social trata de temas relacionado a: saúde, previdência social e assistência social.

Segundo a CF, compete ao Poder Público organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- universalidade da cobertura e do atendimento;
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais: não existir diferenciação entre população urbana e rural;
- seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços: eleger os melhores benefícios.
- irredutibilidade do valor dos benefícios;
- equidade na forma de participação no custeio: todo mundo ajuda, sendo o princípio da solidariedade o que prevalece. O aposentado pelo regime geral não contribui.
- diversidade da base de financiamento;
- caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados;

A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, por meio de recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Além disso, existem contribuições sociais para a seguridade social:

- contribuições do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
 - a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício
 - b) a receita ou o faturamento;
 - c) o lucro;
- contribuições do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201;
- contribuições sobre a receita de concursos de prognósticos.
- contribuições do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

Como se viu, há uma distribuição das fontes de custeio, seja pelos orçamentos, seja pelo trabalhador, empregador, concursos de prognósticos e importador.

Destaque-se que os aposentados e pensionistas pelo regime geral de previdência social não pagam a contribuição para a previdência social. Todavia, o aposentado pelo regime próprio de previdência social pagará.

Tais contribuições poderão ser instituídas por lei ordinária, mas também por medida provisória.



Mas se a União quiser criar uma nova contribuição, sob uma fonte diversa, por meio de uma competência residual, deverá ela o fazer por meio de lei complementar. Neste caso, não haverá possibilidade de medida provisória.

Essas novas contribuições só poderão incidir após 90 dias da sua instituição. É o princípio da noventena. Elas não precisarão observar o princípio da anterioridade anual.

Vale lembrar que são isentas (imunidade) de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

Por fim, nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

1.1. SAÚDE

A saúde é direito de todos e dever do Estado.

A saúde será garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença (função preventiva) e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promover, proteger ou recuperar a saúde.

O STF, com base nessa norma constitucional, estabelece que viola a CF a possibilidade de o paciente pagar um valor para obter uma acomodação superior, ou então para ser atendido por um médico de sua preferência. Esse acesso à saúde deverá ser igualitário.

Essas ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único (SUS), organizado de acordo com: descentralização, mas haverá uma direção única em cada esfera de governo; atendimento deverá ser integral, com prioridade para as atividades preventivas; participação da comunidade.

A CF determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apliquem anualmente percentuais mínimos em ações e serviços públicos de saúde: no caso da União, não poderá ser inferior a 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro; no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3

Vale lembrar que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Atente-se que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, mediante contrato de direito público, ou por meio de convênio, situações em que vigorarão as regras de direito público.

Contudo, haverá preferência das entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Veja, elas poderão atender pelo SUS, mas não poderão obter recursos públicos.

Ademais, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

1.2. PREVIDÊNCIA SOCIAL

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória.

Cabe ressaltar que é vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.

Também é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, salvo no caso de atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar.



Veja, é possível que o servidor esteja no regime próprio de previdência social e também esteja no regime geral, como é o caso do juiz que também é professor da iniciativa privada. Todavia, não poderá o sujeito que esteja no regime próprio ser segurado facultativo do regime geral.

Segurado facultativo é o estudante, dona de casa, etc.

1.2.1. REGRAS PARA APOSENTADORIA

Existem várias regras de transição que são importantes para direito previdenciário.

A aposentadoria para o regime geral é uma garantia ao sujeito, desde que cumpra os requisitos constitucionais.

1.2.2. REGIME DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR

Destaca-se o regime de previdência complementar.

A ideia é de que seja um complemento, razão pela qual será organizado de forma autônoma ao regime geral de previdência social. Ademais, tem caráter facultativo.

Há uma independência financeira do poder público, devendo ser regulado por lei complementar.

Haverá uma publicidade da gestão no tocante ao pleno acesso dos participantes às informações relativas à gestão de seus respectivos planos.

De acordo com a CF, é vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.

1.3. ASSISTÊNCIA SOCIAL

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.

2. EDUCAÇÃO

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

2.1. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAIS DO ENSINO

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (liberdade de ensino);
- pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
- gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais: por essa razão, é vedada a cobrança de taxa de expedição de diploma e de matrícula.
- valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;
- gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
- garantia de padrão de qualidade.



- piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Segundo o STF, por meio da súmula vinculante 12, a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.

Ainda, o STF considerou inconstitucional a cobrança da taxa de alimentação, que é a taxa de anuidade referente à alimentação.

2.2. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES

As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. A ideia é de que a universidade seja livre, pois será importante para a liberdade de pensamento, aprendizado, ensino, etc.

Além disso, as universidades obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

A CF autoriza que universidades admitam professores, técnicos e cientistas estrangeiros, desde que obedecidos os requisitos legais.

2.3. DEVERES DO ESTADO EM RELAÇÃO AO ENSINO

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

- educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;
- progressiva universalização do ensino médio gratuito;
- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; visa a promoção da integração da criança com deficiência.
- educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade;
- acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
- oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
- atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Veja, a própria CF reconhece que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Por conta disso, o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

Compete ainda ao Poder Público recensear (listar) os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.

2.4. PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA

O ensino é livre à iniciativa privada, desde que cumpra as normas gerais da educação nacional; haja autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

Ou seja, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.

O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Não poderá ter matrícula obrigatória.

Ademais, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.



2.5. ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ENSINO

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

Basicamente, município atua em ensino fundamental e educação infantil.

Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.

À União competirá atuar no ensino superior.

2.6. APLICAÇÃO DE RECURSOS NA EDUCAÇÃO

A União vai aplicar, anualmente, não menos de 18% de impostos.

E os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não menos do que 25% da receita resultante de impostos. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.

Esses percentuais serão aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Essa exigência constitui princípio sensível da ordem federativa, de forma que a inobservância dessa aplicação poderá justificar a intervenção federal, através de representação do PGR.

A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada receita do governo que a transferir.

Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. Caso não seja destinado a escola pública, poderá ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei.

Afora isso, os recursos públicos poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os alunos que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.

As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder Público.

2.7. PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

A lei vai estabelecer o plano nacional de educação, de duração de 10 anos.

O objetivo do plano nacional de educação é de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação.

3. CULTURA

O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais.

É direito do sujeito o exercício da cultura, bem como o acesso às fontes da cultura nacional e regionais, motivo pelo qual o Estado vai apoiar e vai incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais.

Ademais, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

A lei também estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público.

A CF traz aquilo que ela considera como patrimônio cultural brasileiro.



Portanto, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos que formaram a sociedade brasileira.

O poder público, com a colaboração da comunidade, vai promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro. Serão formas de proteção e promoção do patrimônio cultural: inventário, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação.

O Sistema Nacional de Cultura será organizado em regime de colaboração e de forma descentralizada e participativa. Este sistema institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade.

Este sistema tem por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.

Tal sistema fundamenta-se na política nacional de cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura.

4. DESPORTO

Desporto é esporte.

A CF estabelece que é obrigação do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais. Ou seja, fomenta-se o esporte de alto desempenho, como o recreativo.

São princípios e regras que orientam o desporto:

- autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento;
- destinação de recursos públicos para a promoção do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento: Veja, o constituinte estabelece uma preferência, pois primeiro é o desporto educacional, ou seja, para todos, mas além disso deverá haver uma destinação ao desporto de alto rendimento.
- tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional; proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.

O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. Traz uma hipótese de contencioso administrativo, sendo indispensável esgotar a justiça desportiva para depois buscar o Judiciário.

Essa justiça desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. Caso não resolva o problema nesse prazo, poderá buscar o Poder Judiciário, ainda que não tenha havido o esgotamento das vias administrativas.

5. CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

A ideia é que a CF determina que o Estado deverá promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

Se o país quiser mudar, é fundamental que o país invista em tecnologia e inovação.

O Estado dará tratamento prioritário à pesquisa científica básica e tecnológica, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.

Essa pesquisa tecnológica será realizada com preponderância para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

Segundo a CF, a lei deverá apoiar e estimular as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, para formação e aperfeiçoamento de seus recursos



humanos, de forma que promova o sistema de remuneração, desvinculando do salário, com a participação nos ganhos resultantes da produtividade do trabalho exercido pelo empregado.

Existe uma faculdade para que os Estados e o Distrito Federal vinculem parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas, as quais fomentam o ensino e a pesquisa científica e tecnológica. Ademais, o Estado, na execução dessas atividades irá estimular a articulação entre os entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo.

Por conta dessa atuação estatal, o Estado vai estimular a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas. E também estimulará os demais entes, públicos ou privados, para constituir e manter parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.

Exemplo disso é o Vale do Silício, nos EUA.

A CF estabeleceu também que será criado o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), o qual é organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

Cabe atentar que haverá uma competência concorrente dos Estados, o Distrito Federal e os Municípios para legislar sobre o assunto.

6. COMUNICAÇÃO SOCIAL

A expressão da atividade artística, intelectual, científica, enfim, a arte de se comunicar não pode ser censurada, nem submetida à prévia licença. A manifestação do pensamento, da criação, da informação e da expressão não poderá sofrer qualquer restrição.

Nenhuma lei poderá conter dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Por conta disso, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

Cabe ressaltar que à lei federal competirá estabelecer as seguintes regras, as quais não figuram como censura: regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada; estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o que determina a CF, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

A família deverá ter um meio de se proteger contra isso, razão pela qual se fundamenta o trabalho do MP.

Dessa forma, a propaganda de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições trazidas pela lei, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.

Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.

A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Isto é, se uma pessoa quiser imprimir um jornal com a sua própria impressora, basta que o faça e passe a entregar nas sinaleiras.

Todavia, para a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão é diferente, pois, neste caso, será indispensável a concessão, permissão ou autorização.

Neste caso, as emissoras de rádio e televisão deverão observar alguns princípios:

- a sua programação deverá ter preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. A ideia é a regionalização da produção. Por conta disso, sempre há antes do “Bom Dia Brasil” o jornal do seu Estado. É necessário ter a produção jornalística de cunho regional.
- a programação deverá conter a promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Exemplo disso é o “Galpão Crioulo”, que dá às 6 horas da manhã do domingo. Ninguém vê! Mas é uma programação cultural.
- a programação deverá promover a regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;
- por fim, a programação deve respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. A CF aqui não diz os valores éticos e sociais, pois estes valores vão mudando com o passar do tempo. Basta ver a novela das 9 dos dias de hoje como seria no ano de 1950. Por óbvio, violaria os valores éticos.

Cabe lembrar que a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou então de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.

Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão devem pertencer a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Neste caso, estes irão exercer obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Isso porque programação é poder, não sendo possível retirar isso do brasileiro. Não se retira o poder do brasileiro de influenciar o brasileiro.

A contrario sensu, não poderá o capital estrangeiro ultrapassar 30% do capital total na respectiva empresa.

Compete ainda ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão. Posteriormente, o Congresso Nacional apreciará o ato. Lembre-se que para jornal escrito não é necessária essa delegação!

A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação do Congresso Nacional, observado o mínimo de 2/5 dos votos, em votação nominal.

O prazo da concessão ou permissão será de:

- 10 anos para as emissoras de rádio e
- 15 anos para as emissoras de televisão.

Caso o poder público quiser cancelar a concessão ou permissão, e este cancelamento seja antes de vencido o prazo, dependerá obrigatoriamente de decisão judicial.

7. MEIO AMBIENTE

Segundo a CF, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Por conta disso, impõe-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

Veja que deve haver uma equidade entre as gerações, formando um pacto intergeracional, de forma que o desenvolvimento deverá se dar de forma sustentável.

O direito ao meio ambiente é um direito de 3ª dimensão.

Com base no art. 225, o STF proibiu a importação de pneus usados, bem como a incineração e depósito de pneus velhos no Brasil, importados de outros países.

Ainda, o STF considerou inconstitucional, com base na proteção do meio ambiente, vedou as chamadas “brigas de galo”, pois o art. 225 é claro, no sentido de que é vedado o tratamento cruel aos animais. Trata-se de uma visão biocêntrica do direito ambiental.



As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente vão sujeitar os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Percebam que há consagração de sanção penal de pessoa jurídica, além de tratar a responsabilidade do meio ambiente como sendo de caráter objetivo.

A própria CF estabelece que para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente, o Poder Público deverá: preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

Estabelece a CF ainda que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

O dispositivo traz ainda os patrimônios nacionais ambientais: Floresta Amazônica brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense, Zona Costeira

A utilização do patrimônio nacional ambiental será feita na forma da lei, desde que as condições assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Quando houver ações discriminatórias, serão consideradas indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, desde que sejam necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

8. FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO JOVEM E DO IDOSO

A CF vai conferir uma proteção especial à família, pois percebe que a família é a base da sociedade.

Exemplo dessa proteção se vislumbra com a gratuidade da celebração do casamento civil. Da mesma forma, motiva o Estado quando diz que o casamento religioso tem efeito civil. Veja, o importante é que case.

Mais uma prova de que existe uma proteção à família, é o reconhecimento do Estado em relação à união estável entre o homem e a mulher, os quais formarão uma entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Apesar de ser homem e mulher, o STF faz uma leitura extensiva, a fim de reconhecer a união homoafetiva como entidade familiar.

Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

A CF estabelece que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, não havendo mais requisito temporal.



Cabe ressaltar que o Estado não intervirá no planejamento familiar, que será de livre decisão do casal, isto enaltece os princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. O Estado deverá, tão somente, propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse planejamento familiar, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Por conta da vulnerabilidade da criança, adolescente e idoso, a CF trouxe certa proteção especial, a qual abrangerá os seguintes aspectos, por exemplo, idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre ao menor de 18 anos, proibição de qualquer trabalho ao menor de 16 anos, salvo a partir de 14 anos, na condição de aprendiz e os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, sujeitos às normas da legislação especial.

Por conta disso, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Segundo a CF, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, protegendo a dignidade e bem-estar do idoso, além de garantir a eles o direito à vida.

Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Nem todo o idoso tem esse direito, pois o Estatuto do Idoso consagra como idoso os maiores de 60 anos.

9. ÍNDIOS

A CF reconhece aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Também a eles é reconhecido os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam.

Neste caso, cabe à União demarcar essas terras dos índios, fazendo a proteção e obrigação de que todos respeitem os seus bens.

São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios: as terras por eles habitadas em caráter permanente, as terras utilizadas para suas atividades produtivas, as terras imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as terras necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

Essas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente. Por essa razão, as riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes são de usufruto exclusivo dos índios.

Todavia, isto deve ser ponderado, pois o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais, em terras indígenas, poderá ser feito, desde que haja autorização do Congresso Nacional, observado dois requisitos: Congresso Nacional ouça as comunidades afetadas e seja garantida à comunidade indígena a participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras. Todavia, esta regra comporta exceções: remoção em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, devendo a medida ser referendada pelo Congresso Nacional; remoção no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional.

Seja qual for o caso, cessando a hipótese de excepcionalidade, fica garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato dos índios logo que cesse o risco.



Vale lembrar que os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.

O procedimento de demarcação das terras indígenas é regulado pelo Decreto 1.775/96, que estabelece, em seu art. 2º, a necessidade de ser elaborado um estudo técnico antropológico e levantamento da área demarcada. A realização da etapa de levantamento da área a ser demarcada é imprescindível, ainda que já tenham sido realizados trabalhos de identificação e delimitação da terra indígena de maneira avançada. O descumprimento dessa etapa configura violação do devido processo legal administrativo e enseja vício de nulidade da demarcação. (Inf. 571, STJ).

Segundo o STJ, é vedada a ampliação de terra indígena já demarcada, salvo em caso de vício de ilegalidade do ato de demarcação e, ainda assim, desde que respeitado o prazo decadencial. Tanto o STF como o STJ condenam essa prática. (Inf. 564, STJ).

10. INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA

10.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, ao apreciar o Tema 822 da repercussão geral, negou provimento a recurso extraordinário em que se discutia a legitimidade da educação domiciliar (Informativo 914).

Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes (redator para o acórdão), no sentido da inexistência de vedação absoluta ao ensino domiciliar, conforme depreendeu da análise dos dispositivos da Constituição Federal (CF) que tratam da família, criança, adolescente e jovem.

A CF, apesar de não o prever expressamente, não proíbe o ensino domiciliar. O próprio texto constitucional permite e consagra a coexistência de instituições públicas e privadas como um dos princípios regentes do ensino [art. 206, III (7)]. Estabelece, também, parceria obrigatória entre família e Estado na educação, em seu sentido amplo. Não o faz para criar rivalidade entre eles, e sim a união de esforços para maior efetividade na educação das novas gerações.

Em um viés democrático e de proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, a solidariedade do dever de educação tem como finalidade precípua a defesa integral dos seus direitos. O Estado não pode abrir mão dessa parceria, nem a família.

A Constituição estabelece princípios, preceitos e regras aplicáveis ao ensino, que integra a educação lato sensu. Isso vale para o Estado e para a família. Independentemente do ensino a ser trilhado, o texto exige alguns requisitos inafastáveis: a necessidade de ensino básico obrigatório entre quatro e dezessete anos [art. 208, I (8)]; a existência de núcleo mínimo curricular [art. 210 (9)]; e a observância de convivência familiar e comunitária (art. 227).

Aparentemente, a CF veda três das quatro espécies mais conhecidas do ensino domiciliar: a desescolarização radical, a moderada e o ensino domiciliar puro. Isso porque elas afastam completamente o Estado do seu dever de participar da educação, o que não ocorre com a quarta espécie, denominada homeschooling ou ensino domiciliar utilitarista ou por conveniência circunstancial. Essa modalidade pode ser estabelecida pelo Congresso Nacional.

Para o redator, o ensino domiciliar carece de regulamentação prévia que firme mecanismos de avaliação e fiscalização, e respeite os mandamentos constitucionais, especialmente o art. 208, § 3º (10). Nesse sentido, é necessário



que a lei prescreva o que será a frequência. Diversamente do ensino público regular, essa frequência possui, também, o fim de evitar a evasão, garantir a socialização do indivíduo, além da convivência com a pluralidade de ideias.

No entendimento dos ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski, que negaram provimento ao recurso, a educação domiciliar é incompatível com a Constituição.

Para o ministro Luiz Fux, além de inexistir fundamento constitucional, a autonomia da vontade dos pais não pode se sobrepor ao direito da criança de estudar com todas as externalidades positivas que decorrem do ambiente escolar.

O ministro Ricardo Lewandowski salientou que o ensino domiciliar não encontra guarida na Constituição, particularmente em face do contido no princípio republicano e no art. 205.

Vencidos o ministro Roberto Barroso (relator), que deu provimento ao recurso extraordinário, e, em parte, o ministro Edson Fachin, que o proveu parcialmente.

RE 888815/RS, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 12.9.2018. (RE-888815)

É constitucional lei estadual que concede o desconto de 50% no valor dos ingressos em casas de diversões, praças desportivas e similares aos jovens de até 21 anos de idade. STF. Plenário. ADI 2163/RJ, rel. orig. Min. Eros Grau, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12/4/2018

Questões

1) (PGM/SJRP)/2019 — De acordo com o que disciplina a Constituição Federal, a questão da Ordem Social tem como base e objetivo, respectivamente,

- a) a defesa do consumidor e a preservação do meio ambiente.
- b) a defesa da propriedade privada e a preservação de um meio ambiente sadio.
- c) a propriedade privada e a defesa do consumidor.
- d) o primado do trabalho e o bem-estar e a justiça sociais.
- e) o primado do trabalho e a defesa do consumidor.

2) (Notário e Registrador (TJ AM)/Provimento/2018) — Conforme o disposto na Constituição Federal no Título VIII “Da Ordem Social”, é correto afirmar:

- a) São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo aos Estados demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, ouvidas as populações dos Municípios envolvidos, nos termos e limites fixados em lei específica da União.
- b) A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, sendo que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos prioritariamente pela mulher.
- c) Dentre os objetivos com base nos quais compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, estão a universalidade da cobertura e do atendimento; seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; irredutibilidade do valor dos benefícios.
- d) As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual complementar específica, sem o que não poderão ser instaladas.

Comentários

1) Gabarito: letra D. Art. 193 da CF/88. Nas demais alternativas, a banca confundiu com os princípios da ordem econômica:



Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

2) Gabarito: letra C. Conforme o art. 194, I, III e IV, da Constituição Federal:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

I - universalidade da cobertura e do atendimento;

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;

V - equidade na forma de participação no custeio;

VI - diversidade da base de financiamento;

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

a) Errado. Não há previsão de oitiva dos municípios quanto ao reconhecimento dos direitos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam, em nenhum dos parágrafos do art. 231 da Constituição Federal. Nesse sentido, qualquer exploração comercial de riquezas minerais ou mesmo remoção de índios de suas terras, em caso de catástrofe ou epidemia, só pode ser realizada com autorização do Congresso Nacional (parágrafos 3º e 5º), e observado o disposto em lei complementar (parágrafo sexto).

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente



ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.

§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º. (Atividade de garimpagem)

b) Errado. Serão exercidos em igualdade de condições pelo homem e pela mulher, nos termos do art. 226, § 5º, ou do transgênero, conforme reconhecido pelo STF (RE 670.422, rel. min. Dias Toffoli, julg. em 15/8/2018), que tem direito à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

.....

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

d) Errado. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei ordinária federal (art. 225, § 6º, CF):

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.



...

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ALEXY, Robert. *Direitos fundamentais no Estado constitucional democrático: para a relação entre direitos do homem, direitos fundamentais, democracia e jurisdição constitucional*. Tradução Luís Afonso Heck. Revista de direito administrativo, Rio de Janeiro, 217, jul/set, 1999.

BULOS, Uadi Lammêgo. *Curso de Direito Constitucional*. 6. ed. rev.amp.atual. São Paulo: Saraiva, 2011.

GUERRA FILHO, Willis Santiago e GARBELLINI CARNIO, Henrique, Teoria Processual da Constituição. Tomo Direito Administrativo e Constitucional, 1ª edição, abril de 2017. Enciclopédia Jurídica da PUC-SP

HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. Tradução Carlos dos Santos Almeida; Gilmar Ferreira Mendes; Inocêncio Martins Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009.

LANDAU, David. Abusive constitutionalism. V.47, n. 1. UC Davis Law Review. Estados Unidos da América, 2013.

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. *Curso de Direito Humanos*. 7.ed. rev., atual., ampliada. São Paulo: Método, 2020.

MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Martires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009.

NOVELINO, Marcelo. *Curso de Direito Constitucional*. 10. ed. rev.amp.atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2015.

SARLET, Ingo Wolfgang. *A eficácia dos direitos fundamentais*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. SARMENTO, Daniel. *Direito Constitucional: teoria, história e métodos de trabalho*. 2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

SARMENTO, Daniel. *Vinculação dos particulares aos direitos fundamentais no direito comparado e no Brasil*. Salvador, editora JusPodivm, 2007.

